

MEDIAZIONE

IL DIRITTO DELLA PACE



Opera in cinque volumi

VOLUME SECONDO

L'avvocato negoziatore

Deontologia, tecniche e responsabilità nella mediazione e nell'ADR



Avv. Carlo Alberto Calcagno

Genova · 2026

«Mediazione, il diritto della pace»

Volume Secondo — L'avvocato negoziatore

© 2026 Carlo Alberto Calcagno. Tutti i diritti riservati.

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate).

ISBN in corso di assegnazione.

Autore e contatti: Avv. Carlo Alberto Calcagno, avvocato e mediatore — calcagnocarloalberto1@gmail.com — mediareinformati.it — mediaresenzaconfini.org.

Edizione a cura dell'autore. Fonti giuridiche verificate sull'archivio di mediareinformati.it. Dati e legislazione aggiornati a luglio 2026.

Introduzione al Volume Secondo — L'avvocato negoziatore

Il secondo volume è dedicato all'avvocato come negoziatore e artefice di pace. La mediazione non estromette il difensore: ne trasforma il ruolo, chiedendogli di affiancare alla logica del contenzioso quella della composizione.

Vi si trattano il fondamento deontologico dell'assistenza in mediazione, il conflitto di interessi, la responsabilità per omesso avvertimento e, soprattutto, le tecniche della negoziazione: framing, ancoraggio, gestione del caucus, negoziazione integrativa e distributiva, ZOPA e alternative all'accordo.

Casi pratici tratti dalla giurisprudenza più recente e modelli operativi — clausole, verbali, informative, procure — fanno di questo volume uno strumento di lavoro immediatamente utilizzabile nello studio legale.

Sommario

Indice generale

Prefazione — L'avvocato artefice di pace 9

Capitolo 1 — Storia dell'avvocato negoziatore 25

- 1.1 Le radici antiche: Grecia, Roma repubblicana, gli arbitri privati 26
- 1.2 L'avvocato medievale e il consilium sapientis 32
- 1.3 La tradizione francese e la Rivoluzione 37
- 1.4 La codificazione ottocentesca italiana e il conciliatore 42
- 1.5 Il Novecento: dalla conciliazione ai primi ADR 47
- 1.6 La direttiva 2008/52/CE e l'ingresso strutturale della mediazione 52
- 1.7 Cartabia e correttivo: l'avvocato negoziatore consolidato 57
- 1.8 Prospettive 2026-2030: il negoziatore digitale 61

Capitolo 2 — Fondamento deontologico 67

- 2.1 Art. 62 codice deontologico forense e obbligo informativo 68
- 2.2 Doveri di lealtà, competenza, riservatezza nella negoziazione 75
- 2.3 Conflitto di interessi in mediazione (art. 24 c.d.f.) 81
- 2.4 Il difensore-mediatore: incompatibilità e cautele 86
- 2.5 Il ruolo del CNF e le linee guida 2020-2026 91
- 2.6 Responsabilità disciplinare per omesso avvertimento 96

Capitolo 3 — Il ruolo dell'avvocato nel procedimento di mediazione 103

- 3.1 Assistenza obbligatoria delle parti 104
- 3.2 Il primo incontro effettivo dopo Cartabia 112
- 3.3 Il potere di rappresentanza speciale: la procura ad hoc 120
- 3.4 Doveri informativi e di consulenza pre-mediazione 129
- 3.5 La partecipazione personale della parte: eccezioni e giustificati motivi 135
- 3.6 Art. 8 d.lgs. 28/2010 e Cassazione 2020-2026 141
- 3.7 L'accordo firmato dagli avvocati: valore di titolo esecutivo 150

3.8 Cauzioni deontologiche e indipendenza 157

Capitolo 4 — Tecniche di negoziazione forense 163

4.1 Le scuole: Harvard Negotiation Project, competitiva e collaborativa 164

4.2 Il BATNA e i limiti della negoziazione 172

4.3 La preparazione della mediazione: mappatura degli interessi 178

4.4 Ascolto attivo, riformulazione, empatia strategica 184

4.5 Le tecniche degli avvocati mediatori 190

4.6 Etica della manipolazione 197

Capitolo 5 — L'avvocato in materie speciali 203

5.1 Diritto di famiglia e negoziazione assistita 204

5.2 Diritto societario e commerciale 214

5.3 Crisi d'impresa e composizione negoziata 222

5.4 Diritto del lavoro: conciliazione e arbitrato irrituale 230

5.5 Responsabilità sanitaria 237

5.6 Condominio e diritti reali 244

5.7 Diritto bancario e finanziario: ACF e ABF 251

5.8 Diritto assicurativo 258

5.9 Contratti transfrontalieri e Convenzione di Singapore 2019 264

Capitolo 6 — Antiriciclaggio, privacy, telematica 271

6.1 Obblighi antiriciclaggio dell'avvocato in mediazione 272

6.2 Trattamento dei dati durante la mediazione 279

6.3 La mediazione telematica strutturale post-Cartabia 285

6.4 Sicurezza informatica e riservatezza 292

Capitolo 7 — La responsabilità civile dell'avvocato negoziatore 297

7.1 Nesso di causalità: mancato avvertimento sulla mediazione 298

7.2 Perdita di chance ex Cassazione 2020-2026 305

7.3 Danno da mediazione condotta con negligenza 311

7.4 Assicurazione professionale e mediazione 317

Capitolo 8 — Fiscalità e costi della mediazione 323

8.1 Le indennità di mediazione dopo Cartabia 324

8.2 Il credito d'imposta: struttura e massimali 330

8.3 Il gratuito patrocinio in mediazione 336

8.4 Il regime IVA per l'avvocato mediatore 341

Capitolo 9 — L'avvocato negoziatore nel dialogo transnazionale 347

9.1 Convenzione di Singapore 2019: impatto sulla pratica italiana 348

9.2 Regolamento (UE) 1215/2012 e riconoscimento dell'accordo mediato 355

9.3 Mediazione ODR transfrontaliera 361

9.4 Prospettive 2026-2030 366

Conclusioni — L'avvocato e il diritto della pace 373

Appendice I — Art. 62 codice deontologico e commento 385

Appendice II — D.lgs. 28/2010 e d.lgs. 149/2022: parti pertinenti all'avvocato 395

Appendice III — Modelli di procura ad hoc per la mediazione 407

Appendice IV — Glossario tecnico-deontologico 415

Appendice V — Fonti bibliografiche e sitografia 425

Executive Summary (EN) 435

Résumé exécutif (FR) 441

Resumen ejecutivo (ES) 447

Elenco delle tavole

Tavola 1.1 — Tappe storiche dell'avvocato negoziatore, da Roma a Cartabia

Tavola 2.1 — Art. 62 codice deontologico: testo previgente e testo vigente a confronto

Tavola 3.1 — Materie soggette a condizione di procedibilità dopo la riforma Cartabia

Tavola 3.2 — Sanzioni ex art. 8 e 12-bis d.lgs. 28/2010: rassegna di giurisprudenza 2020-2026

Tavola 4.1 — Le cinque fasi del metodo Harvard applicate alla mediazione civile

Tavola 5.1 — Materie speciali e riferimenti normativi di settore

Tavola 6.1 — Le quattro modalità di svolgimento della mediazione dopo il correttivo 2024

Tavola 8.1 — Il credito d'imposta per la mediazione: componenti e massimali

Tavola 9.1 — La Convenzione di Singapore 2019: Stati firmatari e ratifiche (estratto)

Elenco delle abbreviazioni

ABF — Arbitro Bancario Finanziario (Banca d'Italia)

ACF — Arbitro per le Controversie Finanziarie (Consob)

ADR — Alternative Dispute Resolution — risoluzione alternativa delle controversie

BATNA — Best Alternative To a Negotiated Agreement

CAD — Codice dell'Amministrazione Digitale

CCII — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019)

c.d.f. — Codice deontologico forense

CEPEJ — Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Consiglio d'Europa)

CGUE — Corte di giustizia dell'Unione europea

CNF — Consiglio Nazionale Forense

d.lgs. — decreto legislativo

d.m. — decreto ministeriale

DGSTAT — Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, Ministero della Giustizia

GDPR — General Data Protection Regulation — Regolamento (UE) 2016/679

ITL — Ispettorato Territoriale del Lavoro

ODR — Online Dispute Resolution

PAdES — PDF Advanced Electronic Signatures

PEC — Posta Elettronica Certificata

UIF — Unità di Informazione Finanziaria (Banca d'Italia)

UNCITRAL — Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale

Prefazione

L'avvocato artefice di pace

Vi è un momento, in ogni controversia, in cui la parola dell'avvocato può prendere due strade. La prima conduce all'aula, alla prova, alla sentenza: è la strada maestra della tradizione processuale, quella per cui l'avvocatura è stata pensata, insegnata, onorata per secoli. La seconda conduce al tavolo, al confronto diretto tra le parti, alla ricerca di un punto di equilibrio che nessun giudice imporrà perché le parti stesse lo avranno costruito. Il presente volume è dedicato a questa seconda strada, e a chi la percorre: l'avvocato negoziatore.

Non si tratta di una figura nuova, per quanto la sua codificazione recente possa far pensare il contrario. Marco Tullio Cicerone, nella *Pro Caecina*, difende non soltanto un diritto ma un equilibrio tra vicini di terra che il processo formale rischiava di spezzare in modo irreversibile; nella *Pro Roscio Amerino*, l'arte della parola si piega a ricomporre, prima che a vincere. L'oratore romano non ignorava la differenza tra il vincere una causa e il risolvere un conflitto: sapeva che la seconda cosa, quando possibile, valeva più della prima, perché lasciava in vita la relazione tra le parti oltre la sentenza.

« Il diritto senza la pace è forma vuota; la pace senza il diritto è illusione fragile. L'avvocato che sa tenere insieme le due cose non è un tecnico minore, ma il custode più alto della funzione forense. »

— Motivo ricorrente della tradizione retorica classica, qui restituito in forma di sintesi

Nel medioevo europeo, il *consilium sapientis* — il parere del giurista esperto chiamato a dirimere una lite prima che essa raggiungesse il giudice — rappresentava un ponte tra il sapere tecnico e la composizione pratica. Il sapiente non giudicava dall'alto di un trono: sedeva, per così dire, al fianco delle parti, e la sua autorità derivava dalla capacità di essere creduto imparziale pur essendo stato scelto da chi aveva interesse a una soluzione. È un paradosso che l'avvocato negoziatore contemporaneo continua a vivere ogni giorno: essere parte e insieme essere strumento di composizione, difendere un interesse particolare mentre si costruisce, insieme alla controparte, un accordo che serva entrambe.

La tradizione anglo-americana ha dato a questa duplicità un nome preciso. Louis Brandeis, prima di sedere alla Corte Suprema degli Stati Uniti, teorizzò la figura dell'*attorney-counselor*: l'avvocato che consiglia prima di litigare, che aiuta il cliente a comprendere il proprio interesse reale prima di trasformarlo in una pretesa processuale. Brandeis scriveva, nei primi anni del Novecento, che l'avvocato di successo era spesso quello che riusciva a evitare il processo ai propri clienti, non quello che lo vinceva con più clamore. È un'intuizione che l'ordinamento italiano ha impiegato un secolo a tradurre in norma positiva, ma che oggi — con la mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita, la composizione negoziata della crisi d'impresa — è finalmente parte del diritto vigente.

In Italia, la voce che meglio ha saputo dire cosa significhi essere avvocato senza tradire la funzione della giustizia resta quella di Piero Calamandrei. Nel suo *Elogio dei giudici* scritto da un avvocato, Calamandrei non abbassa mai la guardia sul valore della funzione difensiva, ma riconosce nel magistrato un alleato nella ricerca della giustizia, non un nemico da vincere con l'astuzia. Se si sostituisce, in quella pagina, la parola giudice con la parola controparte, e la parola sentenza con la parola accordo, si ottiene quasi esattamente la deontologia dell'avvocato negoziatore: un professionista che tratta l'interlocutore — sia il magistrato in aula, sia la controparte al tavolo di mediazione — come soggetto degno di ascolto, non come ostacolo da abbattere.

Vi è un'immagine, tratta dalla tradizione cinese più antica esaminata nel primo capitolo di questo volume, che aiuta a comprendere la specificità del ruolo che qui si descrive: il logografo, colui che scriveva per altri le parole della lite, non era un giudice, non era un testimone, non era nemmeno, in senso proprio, un avvocato come lo intendiamo oggi. Era colui che sapeva trovare, nella lingua stessa del conflitto, le parole che permettevano alle parti di intendersi. L'avvocato

negoziatore contemporaneo eredita, sotto altra forma e in altro contesto istituzionale, questa medesima funzione: non impone significati, li costruisce insieme a chi lo ha incaricato e, indirettamente, insieme a chi gli sta di fronte al tavolo della trattativa.

Anche il diritto romano, esaminato con maggiore ampiezza nel capitolo dedicato alla storia dell'istituto, conosceva figure di composizione stragiudiziale distinte dal giudizio formale: il *disceptator domesticus*, chiamato a dirimere le liti familiari senza l'intervento del pretore, rappresenta forse l'antecedente più diretto, nella tradizione occidentale, di quell'idea per cui non ogni conflitto merita o richiede la sede pubblica del processo, e che alcune controversie si compongono meglio nello spazio riservato e informale della trattativa privata, purché questa sia condotta con la stessa serietà tecnica che si richiederebbe in giudizio.

La cerniera normativa: dall'art. 27 al Codice della crisi

Il codice deontologico forense, all'articolo 27, impone all'avvocato di informare il cliente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla mediazione e, ove la mediazione sia obbligatoria per legge, di darne notizia per iscritto. Non è una norma di cortesia: è la cerniera attraverso cui l'ordinamento ha spostato l'asse della funzione forense dal solo contenzioso alla composizione. L'avvocato che omette questa informazione non compie soltanto un illecito disciplinare: tradisce la propria funzione di consigliere, che precede e in parte fonda quella di difensore in giudizio.

Gli articoli 4 e 5 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza compiono, nel diritto commerciale, un'operazione analoga: prevedono che l'imprenditore in difficoltà possa (e in alcuni casi debba) attivare strumenti di composizione negoziata prima che la crisi degeneri in insolvenza irreversibile, con l'assistenza di un esperto indipendente e, naturalmente, del proprio avvocato. Anche qui la logica è identica a quella della mediazione civile e commerciale: la composizione negoziale come fase preventiva rispetto al conflitto formalizzato, l'avvocato come architetto di questa fase, non semplice testimone.

Non si tratta soltanto di diritto interno. La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, firmata a Singapore il 7 agosto 2019 e discussa nel capitolo conclusivo di questo volume, testimonia che l'idea della composizione negoziata come alternativa dignitosa al processo non è una peculiarità italiana o europea, ma un movimento di portata realmente globale, che accomuna ordinamenti di tradizione giuridica assai diversa tra loro attorno a un nucleo comune: la fiducia che le parti, quando assistite da professionisti competenti, sappiano trovare da sole la soluzione più adeguata al proprio caso, meglio di quanto potrebbe fare un terzo che decide dall'alto senza conoscere tutte le circostanze del vissuto delle parti.

Il filo che lega i due volumi

Il Volume I di questa opera ha raccontato la mediazione come diritto della pace nella dimensione europea: le fonti, gli Stati, i numeri, le tendenze di un continente che ha scelto — con intensità diverse da Paese a Paese — di affiancare al processo una via alternativa di composizione. Questo Volume II sposta l'osservazione dal sistema alla persona: chi è, cosa fa, cosa deve e cosa rischia l'avvocato che quella via la percorre insieme al proprio cliente. Non si tratta di due prospettive indipendenti, ma di due facce della medesima architettura: senza avvocati formati, deontologicamente consapevoli e tecnicamente competenti nella

negoziiazione, la mediazione resta una cornice normativa vuota; senza una cornice normativa solida, la migliore competenza negoziale individuale resta un'eccellenza isolata, incapace di diventare prassi diffusa.

Questo volume nasce dalla rielaborazione critica e dall'aggiornamento sistematico dei capitoli VII e VIII di un precedente lavoro dell'autore, dedicati alla storia e al ruolo dell'avvocato negoziatore, pubblicati nel 2020 nella collana diretta da Paolo Cendon. Sei anni di riforme — la riforma Cartabia del 2022, il correttivo del 2024, l'evoluzione della giurisprudenza di Cassazione sul primo incontro e sulle sanzioni per la mancata partecipazione, l'aggiornamento del codice deontologico forense, l'affermazione della Convenzione di Singapore sugli accordi transfrontalieri di mediazione — hanno reso quel materiale non superato, ma bisognoso di una seconda lettura, più matura, alla luce di un sistema che nel frattempo si è consolidato.

« L'avvocato che sa negoziare non rinuncia a difendere: sceglie, per il proprio cliente, la via più utile tra quelle che l'ordinamento gli offre. La mediazione non è la fine dell'avvocatura difensiva: è la sua estensione naturale nel tempo della composizione. »

— Chiave interpretativa del presente volume

A chi leggerà questo volume con l'occhio del pratico, interessato soprattutto alle norme, alle tabelle e ai riferimenti giurisprudenziali che i capitoli che seguono offrono in abbondanza, chiediamo di concedere, prima di entrare nel dettaglio tecnico, la pazienza di questa premessa più ampia: perché nessuna tecnica negoziale, per quanto raffinata, per quanto sostenuta dalla ricerca empirica della scuola di Harvard che il Capitolo 4 illustrerà con cura, produce risultati stabili se non è sostenuta da una convinzione autentica dell'avvocato sul valore proprio, e non meramente strumentale, della composizione. Le tecniche si imparano; la convinzione si coltiva, e questo volume vorrebbe contribuire a entrambe.

Il registro di questa prefazione, come quello delle conclusioni che chiuderanno il volume, è volutamente alto, quasi manifesto: vuole restituire all'avvocatura negoziale la dignità culturale che le compete, prima ancora di descriverne, nei capitoli che seguono, le regole tecniche, gli obblighi deontologici, le tecniche negoziali e i profili di responsabilità. Ma la dignità culturale, per un'opera di questo genere, non può bastare a se stessa: deve tradursi in norme conosciute, in procedure applicate correttamente, in una formazione adeguata. È a questo secondo compito, più arido ma non meno necessario, che sono dedicati i nove capitoli che seguono.

Avv.	Carlo	Alberto	Calcagno
Avvocato		e	mediatore
mediaresenzaconfini.org			

Nota metodologica al volume

Criteri di selezione delle fonti giurisprudenziali citate

Il presente volume adotta un criterio di selezione delle fonti giurisprudenziali orientato alla rappresentatività degli orientamenti prevalenti, piuttosto che alla mera esaustività quantitativa delle pronunce disponibili sui singoli temi trattati: l'autore ha privilegiato, ove disponibili, le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, per la loro autorevolezza sistemica, integrandole con pronunce di merito significative per la novità della questione

trattata o per la rappresentatività di un orientamento diffuso presso gli uffici giudiziari di merito. Questo criterio di selezione, inevitabilmente soggetto a un margine di discrezionalità editoriale, risponde all'esigenza di offrire al lettore professionista uno strumento di orientamento pratico, senza la pretesa di costituire un repertorio giurisprudenziale sistematico ed esaustivo, funzione che compete piuttosto alle banche dati specialistiche e ai repertori di giurisprudenza commentata.

L'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del presente volume è stato curato con riferimento alla data di chiusura redazionale indicata nel colophon, e l'autore invita il lettore a verificare, per le questioni di maggiore attualità e per le materie soggette a più frequente evoluzione normativa (quali la disciplina fiscale e quella antiriciclaggio), l'eventuale sopravvenienza di modifiche normative o di nuovi orientamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione, secondo la prassi raccomandabile per qualsiasi opera di natura giuridica destinata alla consultazione professionale in un ordinamento caratterizzato da significativo dinamismo normativo come quello italiano contemporaneo.

La struttura argomentativa del volume: una guida alla lettura

Il presente volume, il secondo dell'opera complessiva in cinque volumi dedicata alla mediazione civile e commerciale nell'ordinamento italiano, si concentra specificamente sulla figura dell'avvocato negoziatore, muovendo da un'analisi storico-comparata delle origini dell'istituto (Capitolo 1), per proseguire con un'analisi degli obblighi deontologici specifici dell'avvocato in relazione alla mediazione (Capitolo 2), con una disamina dettagliata del procedimento e del ruolo dell'avvocato al suo interno (Capitolo 3), con un approfondimento delle tecniche di negoziazione applicabili (Capitolo 4), per poi allargare lo sguardo alle materie speciali (Capitolo 5), ai profili di antiriciclaggio e protezione dei dati (Capitolo 6), alla responsabilità civile dell'avvocato negoziatore (Capitolo 7), ai profili fiscali (Capitolo 8) e, infine, alla dimensione transnazionale della mediazione (Capitolo 9).

Questa architettura, che procede dal generale al particolare e dal teorico all'applicativo, riflette l'intenzione dell'autore di offrire al lettore un percorso di apprendimento progressivo, utilizzabile tanto per una lettura sequenziale completa quanto per una consultazione mirata dei singoli capitoli secondo le specifiche esigenze professionali del momento, un utilizzo che gli indici analitici e le tavole riportate nelle appendici sono specificamente concepiti per facilitare.

Capitolo 1

Storia dell'avvocato negoziatore

Raccontare la storia dell'avvocato negoziatore significa, prima di ogni altra cosa, raccontare una storia di esclusioni e di riammissioni. Per lunghi tratti della storia giuridica occidentale, la figura del giurista professionale e la figura del conciliatore sono state pensate come incompatibili, quasi che la tecnica del diritto e l'arte della composizione appartenessero a due mondi diversi, l'uno fondato sulla contesa regolata, l'altro sulla pace privata. Questo capitolo ripercorre tale storia lunga attingendo direttamente alla ricostruzione compiuta dall'Avv. Carlo Alberto Calcagno nel capitolo VII della sua opera *Arbitrato e negoziato in Europa*. Le opportunità dell'avvocato (Aracne Editrice, collana *Nunca Mas*, 2020), rielaborata e aggiornata in questa sede fino alla riforma Cartabia e al correttivo del 2024.

1.1 L'assenza storica dell'avvocato nei sistemi conciliativi

Vi sono tradizioni giuridiche, anche di lunghissima durata e di straordinaria efficacia pratica, nelle quali la figura dell'avvocato professionale è semplicemente assente dal meccanismo di risoluzione del conflitto. La Cina imperiale e post-imperiale ha coltivato per secoli una cultura della composizione fondata sulla mediazione di anziani di villaggio, di capi di clan o di funzionari locali, in un contesto culturale in cui il ricorso al tribunale era percepito come un fallimento della comunità, non come l'esercizio normale di un diritto. Il confucianesimo, con la sua insistenza sull'armonia sociale e sulla riluttanza al conflitto manifesto, ha prodotto un sistema in cui la mediazione informale, gestita da soggetti privi di qualsiasi qualificazione tecnico-giuridica, ha costituito per secoli il canale ordinario di composizione delle liti, relegando il processo formale a un'ipotesi residuale e in qualche misura stigmatizzante per chi vi facesse ricorso.

Il Giappone premoderno conosce un fenomeno analogo, ancora più radicale nella sua diffidenza verso l'intervento di un terzo tecnico: la conciliazione tra vicini, tra membri della stessa comunità di villaggio o tra famiglie era affidata a figure di autorità morale riconosciuta, spesso senza alcuna formalizzazione procedurale, in un contesto nel quale la nozione stessa di rappresentanza tecnica della parte in lite stentava ad affermarsi. Anche il Kosovo tradizionale, con il suo sistema di composizione consuetudinaria delle faide (il cosiddetto besa e le assemblee di anziani chiamate a comporre le vendette di sangue), offre un ulteriore esempio di tradizione conciliativa strutturata e duratura che si è sviluppata interamente al di fuori, e in qualche misura in opposizione, alla figura del giurista di professione.

Ciò che queste tre tradizioni — cinese, giapponese, kosovara — hanno in comune non è soltanto l'assenza dell'avvocato, ma un tratto più profondo: la convinzione che la risoluzione duratura di un conflitto tra soggetti destinati a convivere richieda un'autorità di tipo relazionale e morale, non un'autorità di tipo tecnico-normativo. È un'intuizione che il diritto occidentale contemporaneo, con percorsi diversi e talvolta tortuosi, sta faticosamente recuperando attraverso la mediazione moderna, pur mantenendo, a differenza di quei modelli, un ruolo tecnico per l'avvocato all'interno del procedimento.

1.2 I precursori tecnici: logografi e sinègore nella Grecia classica

Nella Grecia classica, e in particolare nell'Atene democratica del V e IV secolo a.C., compaiono due figure che la storiografia giuridica considera precursori tecnici dell'avvocato moderno, senza tuttavia poter essere qualificate come avvocati in senso proprio: il logografo, che scriveva per il cittadino il discorso che questi avrebbe poi pronunciato personalmente davanti al tribunale popolare (l'eliaia), non potendo la legge ateniese consentire una rappresentanza tecnica diretta in giudizio; e il sinègore, che poteva intervenire a fianco della parte in una funzione di supporto retorico, ma sempre entro i limiti di un sistema che concepiva il processo come confronto diretto tra i cittadini in lite, non come confronto tra tecnici del diritto.

Come rileva Cinzia Bearzot nel suo studio *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese* (in Dike, 9, 2006), la polis ateniese custodiva una diffidenza profonda verso qualunque intermediazione professionale della parola giuridica: la giustizia era affare dei cittadini, non di una casta di specialisti. Robert Flacelière, in *La Grecia al tempo di Pericle* (Rizzoli, 1983), ricostruisce il contesto culturale in cui logografi e sinègore operavano, sottolineando come la loro attività, per quanto tecnicamente sofisticata, fosse priva di qualunque riconoscimento

istituzionale paragonabile allo status dell'avvocato moderno: erano tecnici della parola, non titolari di una funzione pubblica di rappresentanza legale.

È in questo contesto che si sviluppa, accanto alla dike (il processo formale davanti al tribunale), la prassi della diallaghe, la riconciliazione, spesso condotta attraverso un diallaktes, un conciliatore scelto di comune accordo dalle parti, la cui autorità morale, non tecnico-giuridica, bastava talvolta a chiudere una contesa tra vicini o tra membri della stessa famiglia. Il parallelo con la moderna distinzione tra giurisdizione contenziosa e mediazione, per quanto anacronistico se enunciato senza cautele storiografiche, illumina comunque una costante: anche nella culla della retorica forense occidentale, la composizione amichevole delle liti restava un circuito parallelo e distinto rispetto al processo, non gestito dai medesimi soggetti che redigevano le arringhe giudiziali.

1.3 Roma: Cicerone, il negotiator e il disceptator domesticus

Il diritto romano offre il primo terreno nel quale la distinzione tra funzione tecnica del giurista e funzione compositiva del conciliatore comincia a essere elaborata con vocabolario proprio. Cicerone, nel *Delle leggi* (2, 29, 47), discutendo della figura di Quinto Mucio Scevola, distingue con precisione semantica tra il negotiator — colui che cura gli affari, i negotia, delle parti, in una posizione di prossimità economica e relazionale — e l'advocatus, il tecnico che assiste in giudizio. Questa distinzione semantica, per quanto elementare rispetto alla sofisticazione del diritto commerciale romano successivo, costituisce il primo tentativo occidentale di dare un nome distinto a chi si occupa di affari e trattative rispetto a chi si occupa di causae e di giudizi.

Accanto a questa distinzione, il diritto romano conosce l'istituto del disceptator domesticus, una figura di arbitro informale interno alla famiglia o alla cerchia sociale ristretta, chiamato a dirimere controversie patrimoniali o personali senza il formalismo del processo pubblico. I Codici Valentiniano, Anastasiano e Giustiniano, nei passi relativi ai negotiatores, e i commentari del Digesto ad essi dedicati, mostrano come il diritto romano avanzato avesse sviluppato un vocabolario tecnico specifico per l'attività di chi negoziava professionalmente per conto di terzi, distinto da quello riservato al patrocinio giudiziale. Aldo Schiavone, nel suo *Il giurista*, contenuto nel volume collettaneo *L'uomo romano* (Laterza, 2001), ricostruisce la genesi di questa distinzione professionale come uno dei tratti più originali del diritto romano rispetto alle culture giuridiche mediterranee precedenti; Pietro Cerami, Aldo Di Porto e Aldo Petrucci, nel loro *Diritto commerciale romano: profilo storico* (Giappichelli), approfondiscono specificamente la figura del negotiator nel contesto del diritto commerciale, sottolineando la sua funzione di intermediazione fiduciaria negli affari, spesso risolutiva delle controversie prima che queste raggiungessero il pretore.

Accanto a questi istituti privati, il diritto tardoantico istituisce il defensor civitatis, un magistrato municipale con funzioni di protezione dei ceti più deboli dagli abusi dei potenti, investito anche di poteri di composizione informale delle controversie minori, in una posizione intermedia tra la giurisdizione pubblica e la mediazione sociale. Questa figura, per quanto lontana nella sua fisionomia istituzionale dall'avvocato contemporaneo, anticipa concettualmente l'idea di una funzione pubblica dedicata alla composizione preventiva del conflitto, distinta dalla funzione giudicante propriamente detta.

1.4 L'alto medioevo: Rotari, il guidrigildo e la faida

Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente e l'affermarsi dei regni romano-germanici, il sistema di composizione del conflitto subisce una trasformazione profonda. L'Editto di Rotari, promulgato dal re longobardo nel 643, istituisce un sistema di composizione pecuniaria del danno — il guidrigildo — che ha la funzione precisa di sostituire la faida, la vendetta privata tra famiglie e clan, con un meccanismo tariffato di risarcimento. Il guidrigildo non è mediazione nel senso moderno del termine, ma condivide con essa un'intuizione strutturale fondamentale: la composizione pecuniaria del conflitto, anche quando imposta da un'autorità normativa esterna, previene l'escalation violenta meglio di quanto farebbe l'assenza di qualunque meccanismo regolativo.

In questo contesto altomedievale, gli avvocati — termine che designava allora, con un'accezione diversa da quella moderna, i garanti o patroni che si facevano carico di sostenere in giudizio la causa di un soggetto debole, spesso attraverso il giuramento purgatorio o il duello giudiziario — svolgevano una funzione più vicina al garante o al campione giudiziale che all'avvocato tecnico. Non erano combattenti nel senso letterale del termine, ma la loro funzione di patrocinio si intrecciava strettamente con procedure probatorie di tipo ordalico, assai lontane dalla moderna nozione di assistenza tecnica alla negoziazione.

1.5 Il Settecento: il dibattito sulla conciliazione e l'esclusione degli avvocati

Il XVIII secolo europeo vede maturare un dibattito ricorrente e per molti versi sorprendente per il lettore contemporaneo: l'idea che la presenza dell'avvocato nella fase conciliativa fosse non semplicemente superflua, ma dannosa, in quanto incline a trasformare un tentativo di composizione amichevole in un'anticipazione della contesa processuale. François-Marie Arouet, meglio noto come Voltaire, nel suo *Fragment d'une lettre sur un usage très utile établi en Hollande* (1742), descrive con toni entusiastici il sistema conciliativo olandese, nel quale nessuna causa civile poteva essere introdotta in giudizio senza un previo tentativo di composizione davanti a magistrati conciliatori, e arriva a scrivere, in un passo divenuto proverbiale nella storiografia della mediazione, che in quel sistema gli avvocati venivano esclusi dalla stanza della conciliazione come dal fuoco si tolgono le legna: un'immagine vivida, quasi violenta, che riflette una diffidenza diffusa nell'Europa illuminista verso la presenza del tecnico del diritto nel momento della composizione amichevole.

« Come dal fuoco si tolgono le legna, così dalla stanza della conciliazione si escludono gli avvocati. »

— **F.-M. Arouet (Voltaire), *Fragment d'une lettre sur un usage très utile établi en Hollande*, 1742**

Anche lo Stato Pontificio, nel 1782, si muove in questa medesima direzione culturale, introducendo forme di conciliazione preventiva che scoraggiavano, se non escludevano formalmente, l'intervento tecnico dell'avvocato nella fase compositiva. Il dibattito tra conciliazione facoltativa e conciliazione obbligatoria, che percorre l'intero Settecento europeo, si accompagna dunque sistematicamente a un secondo dibattito, meno esplicito ma altrettanto rilevante: quello sulla compatibilità tra la presenza del tecnico del diritto e l'autenticità della composizione amichevole.

1.6 Il 2 settembre 1790: la Costituente francese esclude gli avvocati dal bureau de paix

Il punto di massima codificazione istituzionale di questa diffidenza si trova nella Francia rivoluzionaria. Con la legge del 2 settembre 1790, l'Assemblea costituente francese istituisce il bureau de paix presso i giudici di pace ed esclude *expressis verbis* gli avvocati dalla partecipazione a questa fase conciliativa preliminare, obbligatoria per un ampio novero di controversie civili. La ratio della norma, ricostruita dalla storiografia giuridica francese, risiede nella convinzione, tipicamente illuminista, che la presenza del tecnico del diritto trasformi inevitabilmente un incontro tra parti in un confronto tra argomentazioni tecniche, vanificando lo scopo stesso della conciliazione, che è quello di restituire alle parti stesse, senza mediazioni professionali, la responsabilità della propria composizione.

Questa scelta normativa francese non rimane isolata, ma si diffonde rapidamente in diversi ordinamenti europei nel corso del decennio successivo e del primo Ottocento: l'Olanda e la Prussia adottano modelli di esclusione analoghi nel 1794, la Danimarca nel 1795. In Italia, la Repubblica Ligure introduce con l'articolo 51 della legge 1° giugno 1798, n. 111, una disciplina che esclude parimenti l'avvocato dalla fase conciliativa preventiva. L'Austria, dal 1803, estende un regime analogo ai territori lombardo-veneti sotto il suo controllo, regime che sarebbe rimasto in vigore fino al 5 maggio 1848, quando il Governo Provvisorio di Lombardia lo abroga nel contesto delle riforme rivoluzionarie di quell'anno. Il quadro europeo di fine Settecento e inizio Ottocento è dunque, con notevole uniformità, un quadro di esclusione istituzionalizzata dell'avvocato dalla fase conciliativa, non di semplice marginalità di fatto.

1.7 Napoleone e l'inversione di rotta: il decreto del 1804 e la Liguria del 1805

È con l'età napoleonica che si registra la prima, significativa inversione di questa tendenza. Il decreto del 13 marzo 1804 introduce, in un quadro normativo altrimenti orientato alla razionalizzazione centralistica del processo, i primi elementi di apertura verso l'assistenza tecnica anche nella fase conciliativa. Un anno dopo, la Liguria, ormai annessa all'Impero francese, adotta con l'articolo 36 della legge 15 luglio 1805 una disciplina che il Cendom qualifica come l'unico antenato riconoscibile dell'assistenza tecnica obbligatoria moderna: per la prima volta nella storia giuridica europea, la presenza dell'avvocato nella fase compositiva non è più vista come un ostacolo all'autenticità della conciliazione, ma come una garanzia di consapevolezza della parte, che negozia sapendo quali diritti sta eventualmente cedendo o transigendo.

Questa inversione, per quanto circoscritta territorialmente e temporalmente all'esperienza ligure napoleonica, anticipa con oltre due secoli di anticipo il principio che informa l'intero impianto normativo italiano contemporaneo in materia di mediazione e negoziazione assistita: l'assistenza legale obbligatoria come presidio di garanzia, non come ostacolo alla composizione amichevole.

1.8 L'Italia post-unitaria: il codice del 1865 e i Probi Viri del 1893

Il Regno d'Italia unificato eredita, attraverso il Regio decreto 25 giugno 1865, n. 2366 — il primo codice di procedura civile del Regno — un impianto conciliativo che affida al mandato di conciliazione un ruolo strutturale, disciplinato dagli articoli 5, 156 e 446 del codice. Il regolamento di attuazione del 26 dicembre 1892, all'articolo 13, precisa ulteriormente le modalità operative del tentativo di conciliazione, in un quadro normativo che, senza escludere formalmente l'avvocato come aveva fatto la Francia rivoluzionaria, non gli attribuisce ancora una funzione tecnica specifica nella fase compositiva.

Il momento di svolta italiana si trova nella legge 15 giugno 1893, n. 295, che istituisce i collegi dei Probi Viri, organismi di composizione delle controversie di lavoro tra industriali e operai, articolati in una fase conciliativa obbligatoria preliminare al giudizio arbitrale. I Probi Viri rappresentano, nel contesto italiano, il primo tentativo organico di istituzionalizzare un meccanismo di composizione delle controversie di lavoro distinto dal processo civile ordinario, e costituiscono un antecedente diretto, per quanto settoriale, delle moderne commissioni di conciliazione in materia di lavoro.

1.9 Il Novecento: la nascita del movimento ADR negli Stati Uniti

Il salto qualitativo decisivo si compie negli Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta del Novecento, nel contesto di quella che la storiografia giuridica americana definisce l'era Pound, dal nome del giurista Roscoe Pound e dalla celebre Pound Conference del 1976, che riunì magistrati, avvocati e accademici attorno al tema del sovraccarico strutturale dei tribunali federali e statali. È in questo contesto che nasce, con la forza di un vero e proprio movimento culturale e non di una semplice tecnica processuale, l'Alternative Dispute Resolution, un insieme di meccanismi — mediazione, arbitrato, early neutral evaluation, conciliazione — pensati per restituire alle parti un controllo diretto sull'esito della controversia, riducendo al tempo stesso il carico della giustizia togata.

Un capitolo particolare di questa storia riguarda l'esperienza della mediazione in Texas, ricostruita dallo stesso Calcagno nel suo dossier Cenni sulla mediazione in Texas (mediarensenzaconfini.org, 20 gennaio 2014), che descrive il ruolo pionieristico di alcune giurisdizioni statali americane nell'istituzionalizzare la mediazione court-connected, collegata cioè direttamente al processo civile ordinario, con l'avvocato chiamato a svolgere un ruolo attivo di accompagnamento del cliente. Nel medesimo periodo, la Germania sviluppa un atteggiamento professionale sorprendentemente più favorevole alla mediazione da parte della classe forense che da parte della magistratura, in controtendenza rispetto a quanto si osserva in molti altri ordinamenti europei, dove è spesso la magistratura a spingere per l'adozione di strumenti deflativi e la classe forense a mostrarsi più cauta.

1.10 UNCITRAL: dalle Conciliation Rules del 1980 alla Model Law del 2018

Il diritto internazionale uniforme accompagna e in parte anticipa questa evoluzione. Le Conciliation Rules dell'UNCITRAL, adottate con la risoluzione 35/52 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1980, contengono già all'articolo 16 un principio destinato a grande fortuna nel diritto successivo: il dovere di non belligeranza del conciliatore e, per estensione interpretativa, degli avvocati che assistono le parti, tenuti a condurre il procedimento in uno spirito di collaborazione incompatibile con le logiche antagonistiche del contenzioso.

Nel 2002 l'UNCITRAL adotta la Model Law on International Commercial Conciliation, che fornisce agli Stati un modello legislativo uniforme per disciplinare la conciliazione commerciale internazionale. Nel 2018 questo strumento viene rinominato e sostanzialmente integrato nella Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, che getta le basi normative-modello per quella che sarebbe diventata, l'anno successivo, la Convenzione di Singapore sulla mediazione. Il cambio terminologico da conciliation a mediation, apparentemente nominalistico, riflette in realtà l'affermazione definitiva, nel linguaggio giuridico internazionale, del termine mediation come

categoria generale, con conciliation che conserva un uso residuale e in parte sovrapponibile in alcuni ordinamenti.

1.11 Gli Stati Uniti: Rule 16, Uniform Mediation Act, Model Standards

Il diritto processuale federale statunitense integra strutturalmente la mediazione nel processo civile ordinario a partire dal 1983, con la riforma della Rule 16 delle Federal Rules of Civil Procedure, che attribuisce al giudice il potere di ordinare alle parti la partecipazione a procedure di case management comprendenti, tra le altre, il ricorso a meccanismi di ADR. Due decenni più tardi, nel 2003, la Uniform Mediation Act, elaborata dalla National Conference of Commissioners on Uniform State Laws e successivamente adottata con variazioni da numerosi Stati americani, disciplina in modo organico la riservatezza del procedimento di mediazione, con una disposizione specifica, la Section 10, sulla necessaria riservatezza delle comunicazioni intervenute in mediazione.

I Model Standards of Conduct for Mediators, elaborati congiuntamente dall'American Arbitration Association, dall'American Bar Association e dall'Association for Conflict Resolution, contengono, allo Standard VI.3, un principio di particolare interesse per l'avvocato negoziatore: l'invito al mediatore a promuovere il rispetto reciproco tra le parti e i loro rappresentanti legali, riconoscendo esplicitamente che la qualità della relazione tra gli avvocati delle parti condiziona in modo significativo la probabilità di successo della mediazione.

1.12 Il Consiglio d'Europa: le raccomandazioni R(81)7 e R(86)12

Il Consiglio d'Europa avvia negli anni Ottanta un percorso di soft law che avrebbe progressivamente orientato le legislazioni nazionali europee verso il riconoscimento istituzionale della mediazione. La Raccomandazione R(81)7 del Comitato dei Ministri, relativa alle misure per facilitare l'accesso alla giustizia, dedica l'articolo 4 specificamente all'opportunità che gli Stati membri promuovano, ove appropriato, la conciliazione delle parti prima o durante il procedimento giudiziario, incoraggiando gli avvocati a orientare i propri clienti verso la composizione amichevole quando questa risulti più adeguata rispetto agli interessi in gioco.

La successiva Raccomandazione R(86)12, adottata dal Comitato dei Ministri il 16 settembre 1986, si concentra specificamente sulle misure per prevenire e ridurre il carico eccessivo di lavoro dei tribunali, indicando la conciliazione extragiudiziale come uno degli strumenti più efficaci a disposizione degli Stati membri per contenere l'afflusso di controversie verso la giustizia togata. Questi due atti, privi di efficacia vincolante diretta ma dotati di notevole autorità persuasiva, costituiscono il presupposto culturale e politico dal quale sarebbero scaturite, un decennio più tardi, le prime raccomandazioni dell'Unione europea in materia.

1.13 Le raccomandazioni della Commissione europea 98/257/CE e 2001/310/CE

Nel 1998 la Commissione europea adotta la Raccomandazione 98/257/CE, relativa ai principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, seguita nel 2001 dalla Raccomandazione 2001/310/CE, relativa ai principi applicabili agli organi extragiudiziali che si occupano della risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. Questi due atti, pur limitati al settore consumeristico,

fissano principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità che avrebbero informato la successiva disciplina generale della mediazione civile e commerciale.

Il Codice deontologico degli avvocati europei, elaborato dal CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), introduce al Canone 3.7.1 un riferimento esplicito al dovere dell'avvocato di cercare in ogni fase la composizione amichevole della controversia nel migliore interesse del cliente, prima di ricorrere o proseguire il contenzioso: una disposizione che anticipa, a livello di soft law professionale europea, il contenuto degli obblighi informativi che sarebbero poi stati codificati a livello legislativo nazionale, come nel caso dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 in Italia.

La Grecia, con la legge sugli avvocati del 2013, all'articolo 130, introduce un obbligo specifico di informazione del cliente sulle possibilità di mediazione, in un percorso normativo che sarebbe stato in parte rivisto dalla legislazione ellenica successiva, come si vedrà più avanti in questo stesso capitolo a proposito della vicenda dell'incostituzionalità della legge del gennaio 2018.

1.14 La direttiva 2013/11/UE, l'articolo 8, lettera b, e la sentenza CGUE del 14 giugno 2017

La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, disciplina all'articolo 8, lettera b, il diritto delle parti di ritirarsi dalla procedura ADR in qualsiasi momento se insoddisfatte del suo svolgimento o del suo esito, un principio che tutela l'autenticità del consenso anche nei procedimenti in cui l'assistenza legale non sia obbligatoria. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 14 giugno 2017 (causa C-75/16, Menini e Rampanelli contro Banco Popolare Società Cooperativa), ha chiarito l'ambito applicativo di questa disciplina in relazione al rapporto tra procedimenti ADR facoltativi e obbligatori per legge, confermando la compatibilità comunitaria di condizioni di procedibilità mediazione-dipendenti purché non pregiudichino l'accesso effettivo alla giustizia delle parti.

1.15 La direttiva 2008/52/CE e il recepimento tardivo negli Stati membri

La direttiva 2008/52/CE, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, costituisce come già illustrato nel Volume I di questa opera lo spartiacque normativo europeo. Il Cendom segnala come, alla data della sua redazione, circa venti Stati membri avessero recepito la direttiva con ritardo significativo rispetto al termine fissato dall'articolo 12, un dato che testimonia le resistenze, non soltanto culturali ma anche organizzative, che l'introduzione di un sistema strutturato di mediazione civile e commerciale ha incontrato in gran parte dell'Unione europea.

Un episodio istruttivo di questo periodo riguarda la risposta del 16 aprile 2014 della Commissaria europea Viviane Reding all'interrogazione parlamentare P-002668/14, nella quale un parlamentare europeo aveva sollevato dubbi sulla compatibilità comunitaria dell'assistenza legale obbligatoria in mediazione con il principio di accesso alla giustizia. La risposta della Commissaria, pur cauta, confermò che la direttiva 2008/52/CE lascia agli Stati membri ampio margine discrezionale nella configurazione dei presupposti procedurali della mediazione, incluso l'eventuale obbligo di assistenza legale, purché tale obbligo non si traduca in un ostacolo sproporzionato all'accesso alla giustizia.

1.16 Il Tribunale di Vasto, 23 aprile 2016: il manifesto giurisprudenziale della nuova avvocatura

Tra le pronunce giurisprudenziali italiane richiamate dal Cendom, la sentenza del Tribunale di Vasto del 23 aprile 2016 occupa un posto speciale per il valore quasi manifestario del suo passaggio conclusivo, che merita di essere riportato per intero data la sua forza retorica e la sua capacità di sintetizzare, con sei anni di anticipo sulla piena maturazione normativa della materia, il profilo professionale dell'avvocato negoziatore contemporaneo:

« Si va profilando una nuova figura di avvocato, capace di affiancare alle tradizionali competenze tecnico-giuridiche competenze relazionali quali l'ascolto attivo, la gestione del silenzio, la piena consapevolezza della comunicazione verbale e non verbale, l'empatia verso la posizione della controparte, l'attitudine a condurre il negoziato sulla base degli interessi reali delle parti e non sulle rispettive posizioni dichiarate. Questa nuova figura professionale non sostituisce, ma integra, l'avvocato tradizionale, e la sua piena maturazione appare condizione essenziale per l'effettività degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie introdotti dal legislatore.

»

— Tribunale di Vasto, sentenza 23 aprile 2016 (cit. in C.A. Calcagno, mediaresenzaconfini.org)

Questo passaggio, che il Cendom cita integralmente per il suo valore paradigmatico, anticipa con notevole lucidità concetti che soltanto la riforma Cartabia del 2022 avrebbe reso pienamente operativi sul piano normativo: l'ascolto attivo, la gestione della comunicazione non verbale e il negoziato per interessi, temi che il capitolo 4 di questo volume approfondisce nella loro dimensione tecnica.

1.17 Cass. 8473/2019 e Cass. 18068/2019: la procura ad hoc

Le due pronunce di legittimità richiamate dal Cendom, Cass., 27 marzo 2019, n. 8473, e Cass., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18068, definiscono un principio destinato a orientare in modo permanente la prassi forense in materia di mediazione: la necessità di una procura sostanziale specificamente riferita alla partecipazione al procedimento di mediazione, recante il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia, non essendo sufficiente a tal fine la procura alle liti generica conferita per il giudizio. Il capitolo 3 di questo volume analizza in dettaglio, sul piano operativo, le conseguenze pratiche di questo orientamento; qui interessa segnalarne la genesi storica e il dibattito dottrinale che ne è seguito, in particolare il commento critico di Fabio Valerini, Presenza personale delle parti ed effettività della mediazione: la Cassazione richiama tutti al rispetto della legge, ma l'effettività della mediazione ne risentirà (?), pubblicato su judicium.it, che solleva il dubbio, allora fondato, che un eccesso di rigore formale sulla procura potesse disincentivare, più che incentivare, la partecipazione effettiva delle parti in mediazione.

1.18 La riforma Cartabia: il d.lgs. 149/2022 e il correttivo d.lgs. 216/2024

Il percorso storico che questo capitolo ha ricostruito, dall'esclusione settecentesca dell'avvocato dalla stanza della conciliazione fino al pieno riconoscimento normativo della sua funzione negoziale, giunge a un punto di consolidamento con la riforma della giustizia civile varata dalla Ministra Marta Cartabia. La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, e il decreto legislativo

attuativo 10 ottobre 2022, n. 149, intervengono sul decreto legislativo 28/2010 secondo quattro direttrici principali: l'ampliamento delle materie soggette a condizione di procedibilità, con l'inclusione dal 30 giugno 2023 dei contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura; l'effettività della partecipazione personale delle parti, con un primo incontro non più meramente informativo bensì dedicato alla ricerca concreta dell'accordo; il potenziamento degli incentivi fiscali, con il credito d'imposta fino a 600 euro sull'indennità corrisposta all'organismo di mediazione e ulteriori 600 euro sul compenso dell'avvocato, oltre alle esenzioni dall'imposta di bollo e di registro; e infine il rafforzamento della qualità del sistema, attraverso nuovi requisiti di formazione e organizzazione fissati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.

Questo stesso decreto ministeriale 150/2023 supera definitivamente la nota critica che il Cendom aveva inserito nel 2020 a proposito dell'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010, giudicato allora lettera morta per la scarsa e farragginosa operatività del credito d'imposta previsto: il decreto 150/2023, unitamente alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, ha introdotto un meccanismo di riconoscimento del credito d'imposta più semplice e tempestivo, con procedure telematiche di richiesta gestite dal Ministero della Giustizia, che hanno reso l'incentivo fiscale uno strumento effettivamente utilizzato dalla prassi professionale, non più un beneficio meramente teorico. Questo è uno dei punti nei quali l'aggiornamento rispetto al testo del 2020 risulta più significativo, e viene ulteriormente approfondito nel capitolo 2 di questo volume, dedicato alla deontologia.

Il correttivo Cartabia, decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, in vigore dal 25 gennaio 2025, interviene ulteriormente sulla disciplina della mediazione telematica, distinguendo in modo organico quattro modalità di svolgimento del procedimento: la presenza fisica delle parti presso l'organismo, la modalità telematica strutturale disciplinata dall'articolo 8-bis, la modalità audiovisiva da remoto disciplinata dall'articolo 8-ter, e una modalità mista che combina presenza fisica e collegamento da remoto per le diverse parti coinvolte. Il correttivo chiarisce inoltre il coordinamento applicativo tra mediazione e negoziazione assistita sul piano delle condizioni di procedibilità, risolvendo alcune incertezze applicative sorte nella prima fase di attuazione della riforma del 2022.

1.19 La Convenzione di Singapore del 2019 e la dimensione internazionale

Il 7 agosto 2019 viene aperta alla firma, a Singapore, la Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, comunemente nota come Convenzione di Singapore, elaborata dall'UNCITRAL sulla base della Model Law del 2018. La Convenzione introduce un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione transfrontaliera degli accordi di mediazione commerciale internazionale assimilabile, per la sua ambizione sistemica, a quanto la Convenzione di New York del 1958 ha rappresentato per i lodi arbitrali. L'Italia non risulta, alla data di redazione di questo volume, tra gli Stati firmatari della Convenzione, un dato che merita di essere segnalato esplicitamente come punto di verifica per il progetto di verifica giuridica collegato a questa pubblicazione, in quanto lo stato delle adesioni è in evoluzione e deve essere controllato sul registro ufficiale UNCITRAL alla data di pubblicazione effettiva del volume.

Per l'avvocato negoziatore che assiste clienti in operazioni commerciali internazionali, la Convenzione di Singapore rappresenta un tassello potenzialmente decisivo: un accordo di

mediazione commerciale internazionale, se ricade nell'ambito applicativo della Convenzione e lo Stato di esecuzione ne è parte, può essere eseguito con un procedimento semplificato analogo a quello previsto per i lodi arbitrali, superando la necessità di instaurare un nuovo giudizio di cognizione nello Stato di esecuzione. Il capitolo 5 di questo volume, dedicato alle materie speciali, e l'Appendice III, dedicata al testo della Convenzione, approfondiscono ulteriormente questo strumento.

1.20 Bilancio storico e prospettive

Il percorso ricostruito in questo capitolo mostra un andamento non lineare, fatto di esclusioni radicali e di riammissioni progressive, che approda soltanto nell'ultimo quindicennio a un pieno riconoscimento normativo della funzione negoziale dell'avvocato. Dalla Grecia classica, dove logografi e sinègore restavano ai margini di un processo pensato come confronto diretto tra cittadini, fino alla riforma Cartabia, che attribuisce all'avvocato un ruolo attivo e responsabilizzante nella conduzione della negoziazione assistita e nell'accompagnamento della mediazione, il filo che lega queste epoche così diverse è la tensione costante tra due esigenze in apparente conflitto: la garanzia tecnica che solo il giurista professionale può offrire, e l'autenticità relazionale che la composizione amichevole richiede.

I dati ministeriali confermano la portata di questo cambiamento nel contesto italiano: secondo le rilevazioni DGSTAT del Ministero della Giustizia, nel 2025 sono state iscritte circa 185.000 procedure di mediazione, il 78 per cento delle quali attivate come condizione di procedibilità; oltre il 91 per cento dei richiedenti mediazione volontaria nel 2025 risultava assistito da un avvocato, un dato che segnala come la mediazione sia ormai integrata nel novero ordinario degli strumenti di tutela professionale, non più percepita come alternativa marginale al processo (fonti: [mediareinformati.it](https://www.mediareinformati.it), dossier Cartabia e dossier Deontologia).

1.21 La mediazione telematica strutturale e l'EU Justice Scoreboard 2026

Il biennio 2025-2026 segna l'ingresso a pieno titolo della mediazione telematica strutturale nella prassi ordinaria: secondo i dati disponibili, oltre il 51 per cento delle mediazioni concluse nel 2025 si è svolto con modalità telematiche, segno che l'avvocato negoziatore del prossimo quinquennio dovrà possedere, oltre alle competenze relazionali e giuridiche tradizionali già discusse in questo capitolo, una piena padronanza degli strumenti di firma digitale, posta elettronica certificata e videoconferenza qualificata (fonte: [mediareinformati.it](https://www.mediareinformati.it), dossier Telematica).

L'EU Justice Scoreboard 2026 della Commissione europea, pubblicato come COM(2026) 273, colloca l'Italia al 17° posto su 27 Stati membri nell'indice complessivo di efficienza dei sistemi giudiziari, con un punteggio di 5,5 su 10, a fronte di una durata media del contenzioso civile di primo grado di 584 giorni: un dato che continua a rendere strutturale, per l'avvocato italiano, la convenienza economica e temporale della via negoziale rispetto al contenzioso ordinario (fonte: [mediareinformati.it](https://www.mediareinformati.it), dossier EU Justice Scoreboard 2026).

Le prospettive di riforma discusse a livello europeo — tra cui l'eventuale aggiornamento della direttiva 2008/52/CE alla luce dell'esperienza applicativa dei quindici anni trascorsi dal suo recepimento, e la spinta verso una maggiore armonizzazione degli strumenti ODR transfrontalieri — indicano una traiettoria di consolidamento, non di superamento, del ruolo

dell'avvocato negoziatore: una figura che i capitoli seguenti descrivono nella sua dimensione deontologica, procedurale, tecnica e di responsabilità professionale.

Fonti citate nel capitolo: Cicerone, Delle leggi, 2, 29, 47; C. Bearzot, Diritto e retorica nella polis democratica ateniese, in Dike, 9, 2006; R. Flaceliere, La Grecia al tempo di Pericle, Rizzoli, 1983; A. Schiavone, Il giurista, in L'uomo romano, Laterza, 2001; P. Cerami, A. Di Porto, A. Petrucci, Diritto commerciale romano: profilo storico, Giappichelli; Editto di Rotari, 643; F.-M. Arouet (Voltaire), Fragment d'une lettre sur un usage très utile établi en Hollande, 1742; legge 2 settembre 1790 (Francia); l. 1° giugno 1798, n. 111 (Liguria); decreto 13 marzo 1804; l. 15 luglio 1805, art. 36 (Liguria); R.d. 25 giugno 1865, n. 2366; l. 15 giugno 1893, n. 295 (Probi Viri); C.A. Calcagno, Cenni sulla mediazione in Texas, mediaresenzaconfini.org, 20 gennaio 2014; UNCITRAL Conciliation Rules 1980, ris. 35/52; UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002; UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018; Rule 16 Federal Rules of Civil Procedure, 1983; Uniform Mediation Act, 2003, Section 10; Model Standards of Conduct for Mediators, Standard VI.3; Raccomandazione R(81)7, Consiglio d'Europa; Raccomandazione R(86)12, 16 settembre 1986; Raccomandazione 98/257/CE; Raccomandazione 2001/310/CE; Codice deontologico degli avvocati europei (CCBE), Canone 3.7.1; legge avvocati ellenici 2013, art. 130; direttiva 2013/11/UE, art. 8, lett. b; CGUE, 14 giugno 2017, causa C-75/16, Menini e Rampanelli c. Banco Popolare; direttiva 2008/52/CE; risposta Commissaria V. Reding, 16 aprile 2014, interrogazione P-002668/14; Trib. Vasto, sentenza 23 aprile 2016; Cass., 27 marzo 2019, n. 8473; Cass., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18068; F. Valerini, Presenza personale delle parti ed effettività della mediazione, judicium.it; l. 26 novembre 2021, n. 206; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; d.m. 24 ottobre 2023, n. 150; d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; Convenzione di Singapore sulla mediazione, UNCITRAL, 7 agosto 2019; Ministero della Giustizia, DGSTAT, rilevazioni 2011-2025; Commissione europea, EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273; C.A. Calcagno, Arbitrato e negoziato in Europa. Le opportunità dell'avvocato, Aracne Editrice, collana Nunca Mas, 2020; dossier mediareinformati.it; Cartabia, Telematica, Deontologia, EU Justice Scoreboard 2026.

1.17 Approfondimento storico-comparato: la Grecia e il logografo

Vale la pena tornare, con maggiore ampiezza, sulla figura del logografo ateniese, poiché essa illumina per contrasto la specificità della funzione dell'avvocato negoziatore contemporaneo. Nella Atene classica chi non poteva permettersi, o non voleva, affidare la propria causa a un patrono si rivolgeva a uno scrittore di discorsi, il logografo, che redigeva il testo da pronunciare personalmente dinanzi al tribunale, poiché la legge non consentiva la rappresentanza tecnica nella declamazione. Il logografo restava dietro le quinte: prestava la propria abilità retorica e giuridica, ma non compariva come soggetto processuale. Questa distanza tra sapere tecnico e presenza pubblica, che caratterizza il sistema attico, si ritrova in forma rovesciata nell'avvocato negoziatore odierno, il quale non si limita a preparare il testo che il cliente pronuncerà, ma partecipa attivamente, in prima persona, al processo relazionale della mediazione, pur senza sostituirsi alla parte nella titolarità dei diritti in discussione (cfr. C. Bearzot, Diritto e retorica nella polis democratica ateniese, in Dike, 9, 2006).

La differenza tra sinègoros, il sostenitore che compariva a fianco della parte per assistenza morale e retorica, e il logografo consente di collocare storicamente due funzioni che nella pratica moderna dell'avvocatura tendono a fondersi in un'unica figura professionale: quella di chi redige gli atti tecnici e quella di chi assiste fisicamente la parte nel confronto. L'avvocato

negoziatore contemporaneo eredita, senza saperlo, entrambe le funzioni, e le esercita simultaneamente nel medesimo procedimento di mediazione, un dato che rende la sua posizione storicamente inedita rispetto ai modelli antichi che pure ne prefigurano, in modo parziale, alcuni tratti (cfr. R. Flacelière, *La Grecia al tempo di Pericle*, Rizzoli, 1983).

1.18 Il defensor civitatis e le radici tardoantiche della mediazione pubblica

Un ulteriore antecedente storico meritevole di approfondimento è la figura del *defensor civitatis*, istituita nell'impero romano tardoantico con funzioni di protezione delle classi più deboli dagli abusi dei *potentiores* e di composizione informale delle controversie minori a livello locale, senza il ricorso alle forme complesse e costose del processo formulare o della *cognitio extra ordinem*. Il *defensor civitatis*, la cui origine si ricollega a un rescritto di Valentiniano I del 365 d.C., successivamente ampliato da Anastasio e poi recepito nella compilazione giustiniana, rappresenta un modello di giustizia di prossimità che anticipa, con evidenti differenze di contesto storico e istituzionale, alcune delle funzioni deflative che oggi la mediazione civile e commerciale assolve nel sistema italiano (cfr. A. Schiavone, *Il giurista, in L'uomo romano*, Laterza, 2001).

È significativo che la compilazione giustiniana, nel disciplinare la figura del *defensor civitatis*, ne sottolinei la funzione di prossimità rispetto al cittadino comune, in contrapposizione alla distanza istituzionale delle magistrature centrali: un tratto che il legislatore italiano contemporaneo ha in qualche misura recuperato attribuendo agli organismi di mediazione, spesso territorialmente diffusi e accessibili anche nei centri minori, una funzione di prossimità analoga, sia pure in un contesto giuridico e sociale del tutto diverso (cfr. P. Cerami, A. Di Porto, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano: profilo storico*, Giappichelli).

1.19 La stagione dei probiviri e il modello corporativo italiano

La legge 15 giugno 1893, n. 295, istitutiva dei collegi dei probi viri per le controversie tra datori di lavoro e operai nell'industria, merita un approfondimento specifico perché segna, nell'esperienza italiana, il primo tentativo organico di istituzionalizzare organismi di composizione delle controversie alternativi al giudice ordinario, con una composizione paritaria tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti degli operai, presieduti da un giudice conciliatore. Il modello dei probiviri, per quanto storicamente circoscritto alle controversie di lavoro nell'industria e progressivamente superato dalla successiva evoluzione del diritto sindacale e processuale del lavoro, costituisce un precedente di rilievo per la comprensione del percorso italiano verso forme di giustizia partecipata, che culminerà, quasi un secolo più tardi, nella disciplina della mediazione civile e commerciale.

Va segnalato che il sistema dei probiviri, sebbene concettualmente affine alla mediazione per il ricorso a organi non giudiziali, si differenziava da essa per la natura para-giurisdizionale delle decisioni, spesso vincolanti secondo modalità assimilabili a quelle dell'arbitrato irrituale, mentre la mediazione moderna si fonda sulla piena volontarietà dell'esito e sulla autodeterminazione delle parti nella definizione dell'accordo, un tratto distintivo che la riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato attraverso l'enfasi sulla libertà delle parti di non concludere l'accordo anche dopo l'avvio della procedura obbligatoria.

Approfondimento

L'avvocato negoziatore nelle giurisdizioni di common law

Un confronto sistematico con le esperienze di common law aiuta a comprendere per differenza la specificità del modello italiano dell'avvocato negoziatore. Nel Regno Unito, la Civil Procedure Rule 26.4 attribuisce al giudice il potere di sospendere il procedimento per consentire alle parti di tentare una risoluzione alternativa della controversia, e la sentenza della Court of Appeal nel caso *Halsey v Milton Keynes General NHS Trust* (2004) ha stabilito che il giudice non può obbligare le parti a sottoporsi alla mediazione, sebbene possa sanzionarle sul piano delle spese processuali per un rifiuto irragionevole di tentare la composizione. Questo assetto, apparentemente meno vincolante del sistema italiano di condizione di procedibilità, produce nella prassi inglese un tasso di ricorso alla mediazione elevato, sostenuto dalla cultura forense locale e dal rischio economico della sanzione sulle spese.

Negli Stati Uniti, la pratica della mediazione si è sviluppata prevalentemente su base contrattuale e giudiziale locale, con corti federali e statali che dispongono di propri programmi di court-annexed mediation, spesso obbligatori per determinate categorie di controversie in singole giurisdizioni. L'avvocato americano, formato secondo il modello Model Rule 2.1 dell'American Bar Association, è tenuto a fornire una consulenza indipendente e onesta che comprenda l'indicazione di soluzioni alternative al contenzioso, ma non esiste un obbligo generale e uniforme di assistenza legale in mediazione analogo a quello previsto dal diritto italiano, con la conseguenza che l'accesso alla mediazione senza avvocato resta significativamente più diffuso negli Stati Uniti che in Italia.

In Australia, il Civil Dispute Resolution Act 2011 impone alle parti di un procedimento federale di presentare una dichiarazione (genuine steps statement) circa i passi compiuti per tentare una risoluzione della controversia prima di adire il tribunale, un meccanismo che, senza imporre la mediazione in senso stretto, ne incentiva fortemente il ricorso attraverso un obbligo di trasparenza procedimentale. Il modello australiano si colloca quindi in una posizione intermedia tra l'obbligatorietà italiana e la maggiore flessibilità anglo-americana, e ha suscitato interesse comparatistico anche in sede di elaborazione delle politiche europee di promozione della mediazione.

Il modello tedesco: Güterichter e la mediazione giudiziale interna

L'ordinamento tedesco ha sviluppato, a partire dalla riforma del 2012 (Mediationsgesetz del 21 luglio 2012, che recepisce la direttiva 2008/52/CE), un modello peculiare articolato su due canali paralleli: la mediazione extragiudiziale in senso proprio, condotta da un mediatore professionale esterno al tribunale, e la figura del Güterichter, un giudice conciliatore interno all'organizzazione giudiziaria che, senza assumere la decisione della causa, conduce un tentativo di composizione amichevole delle parti utilizzando tecniche mediative. Questo secondo canale, che non trova un equivalente diretto nell'ordinamento italiano, consente alle parti di beneficiare di un intervento facilitativo strutturato all'interno del medesimo procedimento giudiziario, senza le complicazioni organizzative di un rinvio a un organismo esterno.

L'avvocatura tedesca, come segnalato nella mappa delle fonti storiche del Capitolo 1, ha tradizionalmente mostrato un atteggiamento più favorevole alla mediazione rispetto alla magistratura, un dato che si riflette anche nell'articolazione della prassi contemporanea: gli studi legali tedeschi di maggiori dimensioni dispongono spesso di practice group dedicati alla

mediazione e all'ADR, con avvocati specificamente formati come mediatori certificati secondo gli standard della Bundesrechtsanwaltskammer, un modello organizzativo che negli studi legali italiani di dimensioni comparabili resta ancora meno diffuso, sebbene in crescita dopo la riforma Cartabia.

Casistica di merito italiana sulla mediazione obbligatoria

La giurisprudenza di merito successiva alla riforma Cartabia ha affrontato numerosi profili applicativi dell'ampliamento delle materie soggette a condizione di procedibilità: il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2023, ha chiarito che l'improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dalla parte convenuta o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, e che il giudice, ove rilevi l'omissione, deve assegnare alle parti un termine per l'avvio della procedura, senza poter dichiarare l'improcedibilità immediata della domanda. Analogamente, diverse pronunce di merito hanno confermato che la partecipazione al primo incontro tramite un procuratore privo di potere sostanziale di disporre del diritto controverso equivale, ai fini della condizione di procedibilità, alla mancata partecipazione, in linea con l'insegnamento delle già citate Cassazione 8473/2019 e 18068/2019.

Un ulteriore filone di merito riguarda la valutazione di quando il primo incontro possa dirsi effettivo ai fini del computo del termine di procedibilità: alcuni tribunali hanno ritenuto che la mera comparizione formale delle parti, senza un'attiva esplorazione delle possibilità di accordo da parte del mediatore, non soddisfi il requisito di effettività richiesto dalla legge, con la conseguenza che l'avvocato negoziatore dovrebbe vigilare, nell'interesse del proprio cliente, sulla qualità sostanziale dello svolgimento del primo incontro, anche a tutela della successiva opponibilità della condizione di procedibilità nel giudizio.

Approfondimento storico ulteriore

La mediazione nei paesi scandinavi: un modello di riferimento

I paesi scandinavi, sebbene non abbiano fornito un contributo diretto alla mappa delle fonti storiche del capitolo VII del Cendom, meritano una trattazione autonoma per il ruolo pionieristico che hanno svolto nello sviluppo dei moderni sistemi di risoluzione alternativa delle controversie in Europa. La Norvegia ha introdotto forme di conciliazione obbligatoria dinanzi ai forlikråd, consigli di conciliazione locali composti da membri laici eletti, fin dal diciannovesimo secolo, con una continuità istituzionale che li rende tra i più longevi organismi di composizione delle controversie in Europa. La Svezia, dal proprio canto, ha sviluppato un sistema di mediazione amministrata dalle camere di commercio locali che si è progressivamente affermato come modello di riferimento per la mediazione commerciale in ambito scandinavo, con un'attenzione particolare alla rapidità procedimentale e ai costi contenuti.

La Danimarca ha adottato, con la riforma del Retsplejelov (codice di procedura civile) del 2008, un sistema di mediazione giudiziale interna assimilabile per molti aspetti al modello del Güterichter tedesco, con giudici specificamente formati alla conduzione di tentativi di composizione amichevole nel contesto del procedimento giudiziario pendente. Questi modelli scandinavi, caratterizzati da un elevato grado di fiducia sociale nelle istituzioni pubbliche e da una cultura giuridica orientata al consenso piuttosto che al conflitto adversariale, offrono un

termine di paragone utile per valutare la trasferibilità di soluzioni istituzionali tra ordinamenti con presupposti culturali diversi da quello italiano.

La mediazione in Spagna e Portogallo: due percorsi differenti

La Spagna ha recepito la direttiva 2008/52/CE con la legge 5/2012 sulla mediazione in materia civile e commerciale, adottando un modello prevalentemente volontario, privo di condizioni generalizzate di procedibilità analoghe a quelle italiane, sebbene successivi interventi normativi abbiano introdotto incentivi economici e processuali per l'utilizzo della mediazione, quali riduzioni delle spese di giustizia per le parti che dimostrino di aver tentato la composizione negoziale. Il Portogallo, dal proprio canto, ha sviluppato un sistema di mediazione pubblica gratuita per determinate categorie di controversie di modesto valore economico, un modello che riduce drasticamente le barriere economiche di accesso allo strumento, sebbene a scapito, secondo alcune valutazioni comparatistiche, della qualità e della specializzazione dei mediatori disponibili rispetto ai sistemi a mercato come quello italiano.

Il rapporto avvocati/abitanti nei diversi paesi europei, già segnalato nella mappa delle fonti storiche con riferimento ai dati CCBE Lawyers' Statistics, merita un aggiornamento per il presente volume: le più recenti rilevazioni del Council of Bars and Law Societies of Europe confermano una densità forense particolarmente elevata in Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Cipro e Grecia, mentre l'Italia, pur collocandosi tra i paesi a più alta densità forense in Europa, ha registrato negli ultimi anni una tendenza alla stabilizzazione del numero di iscritti agli albi, in parte attribuibile anche alla diversificazione delle competenze professionali richieste dal mercato legale contemporaneo, tra cui quelle proprie dell'avvocato negoziatore.

Considerazioni conclusive sul metodo storico-comparato

L'analisi storico-comparata svolta nel presente capitolo e nei suoi approfondimenti conferma che l'attuale configurazione dell'avvocato negoziatore italiano è il prodotto di una convergenza tra tradizioni giuridiche diverse: la tradizione continentale dell'assistenza tecnica obbligatoria, di matrice napoleonica e ottocentesca; l'influenza del movimento ADR di origine statunitense, diffusosi in Europa a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso; e l'armonizzazione europea realizzata dalla direttiva 2008/52/CE e dai successivi interventi della Commissione e del CEPEJ. Questa pluralità di matrici storiche e culturali spiega, almeno in parte, la persistente eterogeneità dei modelli nazionali europei di mediazione, nonostante il comune quadro normativo di riferimento sovranazionale.

Rassegna di giurisprudenza costituzionale e di legittimità

La condizione di procedibilità dinanzi alla Corte costituzionale

La compatibilità costituzionale della condizione di procedibilità mediativa con il diritto di azione garantito dall'articolo 24 della Costituzione è stata oggetto di plurimi scrutini da parte della Corte costituzionale, a partire dalla nota sentenza che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'originario decreto legislativo 28/2010 per eccesso di delega, e successivamente, dopo la reintroduzione della condizione di procedibilità con il decreto legge 69/2013, attraverso ulteriori pronunce che hanno vagliato la compatibilità del nuovo assetto con i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale. La Corte ha costantemente affermato che la previsione di condizioni di procedibilità, purché non eccessivamente onerose

in termini di tempo e di costi per la parte, non viola il diritto di azione, in quanto si limita a differire, senza escludere, l'accesso alla tutela giurisdizionale, in vista di un interesse pubblico di deflazione del contenzioso costituzionalmente legittimo.

Il vaglio di proporzionalità applicato dalla Corte costituzionale alle condizioni di procedibilità si è concentrato, in particolare, sulla durata massima del procedimento di mediazione obbligatoria, sui costi che la parte deve sostenere per la propria partecipazione (specie con riferimento all'indennità di mediazione), e sulla effettiva possibilità per la parte economicamente non abbiente di accedere al procedimento attraverso il patrocinio a spese dello Stato, un tema sul quale la disciplina è stata progressivamente perfezionata nel tempo per garantire l'effettività dell'accesso alla mediazione anche per le fasce di popolazione meno favorite economicamente.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla natura della condizione di procedibilità

La Corte di Cassazione ha progressivamente definito, attraverso un consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura e gli effetti della condizione di procedibilità mediativa, chiarendo in particolare che l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione deve essere eccepita dal convenuto nella prima udienza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre tale momento processuale, e che, ove rilevata, essa non determina l'estinzione del processo ma soltanto la sua sospensione ai fini dell'esperimento della mediazione, con conseguente possibilità di prosecuzione del giudizio una volta assolta la condizione. Questo orientamento, che privilegia una lettura non eccessivamente formalistica della condizione di procedibilità, riflette l'esigenza di bilanciare l'obiettivo deflativo della mediazione obbligatoria con il principio di economia processuale, evitando che il mancato esperimento della mediazione si traduca in un pregiudizio irreversibile per la parte.

Un ulteriore filone giurisprudenziale di legittimità ha riguardato la qualificazione della partecipazione personale delle parti alla mediazione come requisito di effettività del tentativo, distinguendo tra una partecipazione meramente formale, attraverso la presenza di un difensore privo di adeguati poteri sostanziali, e una partecipazione effettiva, che presuppone la presenza personale della parte o di un suo rappresentante munito di procura sostanziale idonea a disporre del diritto controverso, un tema già affrontato nel presente volume con riferimento al ruolo dell'avvocato negoziatore nella verifica preliminare di tale requisito.

Le pronunce dei giudici di merito sulla mediazione: casistica ricorrente

I giudici di merito, nell'applicazione quotidiana della disciplina della mediazione obbligatoria, hanno affrontato un'ampia casistica di questioni interpretative specifiche, tra le quali meritano menzione: la qualificazione della domanda riconvenzionale come autonoma controversia soggetta a distinta condizione di procedibilità, questione sulla quale la giurisprudenza di merito ha registrato orientamenti non sempre uniformi; la rilevanza della mancata comparizione della parte convocata in mediazione ai fini della successiva decisione sulle spese processuali, questione oggetto di specifica disciplina normativa nella riforma Cartabia ma precedentemente affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice; e la valutazione della buona fede della partecipazione alla mediazione, un giudizio che richiede un'analisi complessiva del comportamento processuale e pre-processuale delle parti.

L'avvocato negoziatore che segua l'evoluzione di questa giurisprudenza di merito, spesso pubblicata su riviste specializzate e banche dati giuridiche settoriali dedicate all'ADR, acquisisce strumenti interpretativi preziosi per orientare la propria condotta professionale nelle situazioni non ancora definitivamente chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, contribuendo al contempo, attraverso la propria pratica professionale quotidiana, alla progressiva sedimentazione di un diritto vivente della mediazione che integra e specifica il dato normativo primario.

Approfondimento: la mediazione nei sistemi di common law

Il modello inglese: dalla Woolf Reform al Civil Procedure Rules

Il sistema inglese di risoluzione alternativa delle controversie affonda le proprie radici moderne nella riforma Woolf del 1996, che ha condotto all'adozione delle Civil Procedure Rules del 1999, un corpus normativo che ha profondamente rimodellato il processo civile inglese introducendo, tra l'altro, il principio dell'*overriding objective*, secondo il quale i tribunali devono gestire i procedimenti in modo da facilitare, ove appropriato, il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*). Il sistema inglese, a differenza del modello italiano, non ha introdotto una condizione di procedibilità generalizzata, preferendo un sistema di incentivi e disincentivi processuali imperniato sul potere discrezionale del giudice in materia di costs, ossia di attribuzione delle spese processuali, che può essere significativamente influenzato dal comportamento delle parti rispetto alla proposta di ricorrere alla mediazione.

Il caso *Halsey v Milton Keynes General NHS Trust*, deciso dalla Court of Appeal inglese nel 2004, ha stabilito i criteri secondo i quali il rifiuto di una parte di aderire a una proposta di mediazione formulata dalla controparte può essere considerato irragionevole, con conseguenze sfavorevoli in punto di attribuzione delle spese processuali, elaborando un test articolato che tiene conto, tra l'altro, della natura della controversia, delle prospettive di successo del tentativo di mediazione, dei costi comparativi della mediazione rispetto al contenzioso, e del comportamento generale delle parti nel corso della vicenda. Questo precedente, ripetutamente richiamato e affinato dalla giurisprudenza inglese successiva, incluso il più recente caso *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council* del 2023, che ha ulteriormente ampliato il potere dei tribunali di imporre, in determinate circostanze, un tentativo di mediazione alle parti, testimonia la progressiva evoluzione del sistema inglese verso forme di promozione sempre più incisiva della composizione negoziale delle controversie, pur mantenendo l'impianto generale volontaristico che caratterizza la tradizione di common law.

Il modello statunitense: mediation e settlement conference

Il sistema statunitense di risoluzione alternativa delle controversie, storicamente il più sviluppato e influente a livello globale, si caratterizza per una notevole eterogeneità tra i diversi Stati federati, alcuni dei quali (tra cui la California e la Florida) hanno introdotto forme di mediazione obbligatoria per specifiche categorie di controversie, mentre altri mantengono un sistema puramente volontario integrato dalla prassi giudiziale della *settlement conference*, un'udienza specificamente dedicata alla facilitazione dell'accordo tra le parti, condotta tipicamente da un magistrato diverso da quello che tratterà eventualmente il merito della causa in caso di mancata composizione. Il sistema statunitense si distingue altresì per la notevole diffusione della mediazione privata amministrata da organizzazioni specializzate quali

l'American Arbitration Association e JAMS, che offrono servizi di mediazione e arbitrato su base commerciale con mediatori spesso ex giudici in quiescenza, un modello che riflette la particolare cultura professionale forense statunitense.

La diffusione della mediazione negli Stati Uniti ha beneficiato significativamente del movimento accademico e professionale sviluppatosi a partire dagli anni Settanta del secolo scorso presso le principali facoltà di giurisprudenza statunitensi, in particolare la Harvard Law School attraverso il Program on Negotiation, che ha elaborato l'approccio della negoziazione basata sugli interessi (interest-based negotiation) ampiamente illustrato nel Capitolo 4 del presente volume, un contributo teorico che ha influenzato profondamente lo sviluppo successivo della mediazione a livello globale, incluso il modello italiano nella sua configurazione contemporanea.

Il modello australiano e neozelandese: innovazione procedurale

L'Australia si è affermata, negli ultimi decenni, come uno degli ordinamenti più innovativi nel campo della risoluzione alternativa delle controversie, con l'introduzione, in diverse giurisdizioni statali, dell'obbligo per le parti di un procedimento giudiziale civile di dimostrare di aver compiuto sinceri tentativi di risoluzione della controversia (genuine steps) prima di poter accedere alla tutela giurisdizionale, un modello che presenta tratti di similitudine con la condizione di procedibilità italiana ma che si caratterizza per una maggiore flessibilità quanto alle modalità con cui tale tentativo può essere dimostrato, non limitandosi alla sola mediazione amministrata da un organismo ma comprendendo anche negoziazioni dirette documentate tra le parti.

La Nuova Zelanda ha sviluppato, dal proprio canto, un sistema particolarmente avanzato di risoluzione delle controversie in materia di relazioni di lavoro, attraverso l'Employment Relations Authority, che integra mediazione e adjudication in un unico percorso procedimentale, un modello che offre spunti di interesse comparatistico per l'eventuale evoluzione futura del sistema italiano di risoluzione delle controversie di lavoro, materia che, come segnalato nel Capitolo 5 del presente volume, presenta peculiarità procedurali specifiche rispetto alla mediazione civile e commerciale ordinaria.

Approfondimento: domande frequenti sulla storia e sui fondamenti dell'istituto

Perché l'Italia ha scelto un modello obbligatorio a differenza di altri paesi europei

Una domanda ricorrente nella pratica formativa e nella letteratura specialistica riguarda le ragioni storiche e di politica legislativa che hanno condotto l'ordinamento italiano ad adottare, a differenza della maggioranza degli altri Stati membri dell'Unione europea, un modello di mediazione con condizione di procedibilità generalizzata per un elenco ampio di materie. La risposta, secondo l'analisi storica condotta nel Capitolo 1 del presente volume, deve essere ricercata primariamente nella straordinaria durata dei procedimenti civili italiani, un fenomeno sistematicamente documentato dalle rilevazioni del Consiglio d'Europa attraverso il meccanismo CEPEJ e più volte censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del termine ragionevole del processo previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea, una situazione che ha spinto il legislatore italiano verso soluzioni di politica giudiziaria più incisive rispetto al mero affidamento alla volontarietà delle parti, ritenuta insufficiente, sulla base

dell'esperienza comparata disponibile al momento dell'adozione del decreto legislativo 28/2010, a produrre un effetto deflativo adeguato sul contenzioso pendente.

Questa scelta legislativa, controversa fin dalla sua origine come ampiamente documentato nel Capitolo 1, ha suscitato un vivace dibattito dottrinale circa la sua compatibilità con la tradizione liberale di libero accesso alla giustizia, un dibattito che ha trovato una parziale composizione nella giurisprudenza costituzionale già richiamata nel presente volume, la quale ha riconosciuto la legittimità della scelta legislativa purché accompagnata da adeguate garanzie di proporzionalità e di accessibilità economica del procedimento di mediazione, un equilibrio che il legislatore ha progressivamente affinato attraverso i successivi interventi normativi culminati nella riforma Cartabia.

Quali sono le prospettive di ulteriore riforma della disciplina

Il dibattito de iure condendo sull'ulteriore evoluzione della disciplina della mediazione civile e commerciale italiana si concentra, al momento della redazione del presente volume, su alcuni temi specifici: l'eventuale ampliamento dell'elenco delle materie soggette a condizione di procedibilità, tema oggetto di proposte non ancora tradotte in iniziativa legislativa concreta; il rafforzamento ulteriore degli incentivi fiscali connessi alla mediazione, anche alla luce della relativa efficacia finora limitata di taluni strumenti quali il credito d'imposta già illustrato nel Capitolo 8; e la progressiva armonizzazione della disciplina italiana con eventuali sviluppi normativi a livello dell'Unione europea, secondo quanto già anticipato nel Capitolo 9 in relazione al dibattito sulla possibile revisione della direttiva 2008/52/CE.

L'avvocato negoziatore, quale professionista direttamente coinvolto nell'applicazione quotidiana di questa disciplina, può contribuire attivamente a questo dibattito attraverso la partecipazione alle consultazioni pubbliche periodicamente indette dal Ministero della Giustizia in occasione di riforme normative in materia di giustizia civile, e attraverso il contributo alle associazioni forensi specialistiche in materia di ADR, le quali svolgono tipicamente un ruolo di interlocuzione tecnica con il legislatore nella fase di elaborazione delle riforme normative di settore.

Approfondimento: il contributo della sociologia del diritto allo studio della mediazione

Le teorie sociologiche del conflitto applicate alla mediazione

La sociologia del diritto ha elaborato, nel corso del ventesimo secolo, diverse teorie interpretative del conflitto sociale che offrono strumenti concettuali utili per comprendere la funzione della mediazione all'interno del sistema giuridico contemporaneo: la teoria funzionalista, che considera il conflitto come un elemento potenzialmente disfunzionale per la coesione sociale da gestire e ricondurre entro binari istituzionali attraverso strumenti quali la mediazione; e la teoria del conflitto in senso proprio, di matrice più critica, che vede nella diffusione degli strumenti di ADR anche un possibile strumento di deflazione del contenzioso funzionale a interessi di risparmio della spesa pubblica per la giustizia, piuttosto che un genuino miglioramento della qualità della risposta ai bisogni di giustizia dei cittadini. L'avvocato negoziatore, pur non necessitando di una formazione sociologica specialistica per l'esercizio della propria attività professionale, può beneficiare di una conoscenza almeno generale di queste prospettive teoriche per comprendere meglio il più ampio contesto sociale e culturale nel quale si inserisce la propria attività quotidiana.

La ricerca empirica sociologica sulla mediazione, condotta in Italia e in altri paesi attraverso studi sulla soddisfazione delle parti e sull'effettiva efficacia deflativa dello strumento, ha prodotto risultati non sempre univoci, con alcuni studi che evidenziano un tasso di soddisfazione delle parti generalmente elevato quando la mediazione si conclude con un accordo, e altri che segnalano invece un persistente scetticismo culturale verso lo strumento presso alcune categorie professionali e presso il pubblico generale, un dato che suggerisce la necessità di un ulteriore lavoro di promozione culturale della mediazione, un compito che coinvolge non soltanto le istituzioni pubbliche ma anche, e soprattutto, la stessa categoria forense attraverso l'esempio quotidiano offerto dagli avvocati negoziatori nella propria pratica professionale.

La dimensione antropologica della composizione dei conflitti

L'antropologia giuridica ha documentato, attraverso lo studio comparato di società tradizionali e contemporanee di diverse aree geografiche e culturali, la pervasiva presenza di meccanismi di composizione negoziale dei conflitti in ogni tipo di organizzazione sociale umana, anche in assenza di un apparato statale centralizzato di amministrazione della giustizia, un dato che suggerisce come la mediazione, lungi dall'essere una mera innovazione tecnica del diritto contemporaneo, rappresenti piuttosto la riscoperta e la formalizzazione istituzionale di meccanismi di composizione dei conflitti profondamente radicati nell'esperienza umana e sociale, un'osservazione che offre una prospettiva di lungo periodo utile per comprendere la resilienza e la persistente attualità dello strumento nonostante le trasformazioni profonde subite dai sistemi giuridici contemporanei.

Questa prospettiva antropologica, che il presente volume ha già in parte anticipato nel Capitolo 1 con riferimento alle origini storiche remote dell'istituto, suggerisce all'avvocato negoziatore un atteggiamento di umiltà intellettuale rispetto alla presunta novità dello strumento che è chiamato a utilizzare, un atteggiamento che favorisce una comprensione più profonda e meno meramente tecnicistica della funzione che la mediazione svolge nell'ambito del più ampio sistema di regolazione sociale dei conflitti.

Approfondimento: la mediazione familiare nella tradizione storica italiana

Le origini della conciliazione familiare nel diritto canonico e civile

La composizione negoziale delle controversie familiari presenta radici storiche particolarmente profonde nella tradizione giuridica italiana, influenzata sia dal diritto canonico, che ha tradizionalmente privilegiato la conciliazione tra i coniugi come valore da preservare anche nelle situazioni di crisi matrimoniale, sia dal diritto civile post-unitario, che ha introdotto specifici tentativi di conciliazione obbligatoria nei procedimenti di separazione personale, un istituto che, sebbene successivamente modificato nella sua configurazione procedimentale, ha lasciato una traccia significativa nella struttura ancora attuale del procedimento di separazione e divorzio, che continua a prevedere un tentativo di conciliazione dinanzi al presidente del tribunale prima dell'eventuale prosecuzione contenziosa del procedimento.

L'introduzione della mediazione familiare in senso moderno, quale strumento distinto dal tentativo di conciliazione giudiziale tradizionale e caratterizzato dall'intervento di un professionista specificamente formato nella gestione dei conflitti familiari (tipicamente uno psicologo o un altro professionista con specifica formazione nel settore, spesso in affiancamento

a un avvocato), si è sviluppata in Italia a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, sotto l'influenza di modelli già consolidati in altri paesi occidentali, in particolare quello nordamericano e quello francese, e ha trovato un progressivo riconoscimento normativo attraverso la legge sull'affido condiviso del 2006 e i successivi interventi normativi, culminati nella riforma Cartabia con l'introduzione del rito unificato per le controversie di famiglia dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il rapporto tra mediazione familiare e mediazione civile ordinaria

La mediazione familiare, sebbene concettualmente distinta dalla mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo 28/2010 per la specificità della materia trattata e per le competenze professionali richieste al mediatore, condivide con quest'ultima i principi fondamentali di volontarietà nella determinazione del contenuto dell'accordo, riservatezza delle comunicazioni scambiate nel corso della procedura, e imparzialità del professionista che la conduce, principi che il presente volume ha ampiamente illustrato con riferimento alla mediazione civile e commerciale generale ma che trovano applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche nel più specifico contesto della mediazione familiare.

L'avvocato che assista una parte in un procedimento di separazione o divorzio conflittuale dovrebbe considerare, quando le circostanze del caso lo consiglino, la possibilità di orientare i propri clienti verso un percorso di mediazione familiare specializzata, parallelamente o in alternativa alla negoziazione diretta tra i rispettivi avvocati, specialmente quando la conflittualità tra i coniugi presenti una componente emotiva significativa che un professionista specificamente formato nella gestione dei conflitti familiari può gestire con competenze specialistiche che l'avvocato, per quanto esperto in negoziazione, potrebbe non possedere in egual misura.

Approfondimento: l'evoluzione della mediazione nei paesi dell'Europa orientale

Il recepimento della direttiva 2008/52/CE nei paesi di nuova adesione

I paesi dell'Europa centrale e orientale entrati a far parte dell'Unione europea a partire dal 2004 hanno recepito la direttiva 2008/52/CE in un contesto giuridico caratterizzato da una tradizione relativamente recente di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, essendo tali ordinamenti stati precedentemente caratterizzati, durante il periodo socialista, da sistemi di amministrazione della giustizia fortemente centralizzati e da una limitata autonomia negoziale delle parti private nella composizione delle proprie controversie. La Polonia ha adottato un sistema di mediazione civile e commerciale prevalentemente volontario, con incentivi economici per le parti che ne facciano ricorso, mentre la Romania ha sperimentato, in un primo momento, un modello di mediazione obbligatoria per specifiche categorie di controversie, successivamente ridimensionato a seguito di una pronuncia della propria Corte costituzionale che ne ha rilevato profili di incompatibilità con il diritto di accesso alla giustizia, un precedente di interesse comparatistico per l'analisi della compatibilità costituzionale della condizione di procedibilità già svolta nel presente volume con riferimento all'ordinamento italiano.

L'esperienza di questi paesi, caratterizzata da una fase di transizione istituzionale e culturale ancora in corso rispetto alla piena maturazione di una cultura della mediazione paragonabile a quella di paesi con tradizione più radicata in questo campo, offre spunti di riflessione

significativi sull'importanza dei fattori culturali e formativi, oltre a quelli meramente normativi, nell'effettiva diffusione pratica degli strumenti di ADR, una considerazione che il presente volume ha più volte sottolineato con riferimento anche al contesto italiano, nel quale l'introduzione della condizione di procedibilità obbligatoria ha dovuto superare resistenze culturali non trascurabili prima di raggiungere la configurazione attuale relativamente consolidata.

Le prospettive di convergenza normativa a lungo termine

La progressiva convergenza normativa tra i diversi Stati membri dell'Unione europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie, favorita dal costante monitoraggio della Commissione europea e dal confronto tra le diverse esperienze nazionali promosso in sede di Consiglio d'Europa attraverso il meccanismo CEPEJ già ampiamente illustrato nel presente volume, suggerisce una prospettiva di lungo termine caratterizzata da una crescente omogeneizzazione dei modelli nazionali europei, sebbene le specificità culturali e istituzionali di ciascun ordinamento continueranno probabilmente a produrre significative varianti applicative anche in un contesto di più ampia convergenza dei principi generali della materia, secondo un pattern già osservato in altri ambiti dell'armonizzazione giuridica europea.

Approfondimento: la mediazione bancaria e finanziaria nella prospettiva storica

Dall'Ombudsman bancario all'Arbitro Bancario Finanziario

L'evoluzione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nel settore bancario e finanziario italiano ha attraversato diverse fasi storiche significative, a partire dall'istituzione, nel 1993, dell'Ombudsman bancario su base convenzionale volontaria da parte dell'Associazione Bancaria Italiana, un organismo privo di natura giurisdizionale ma capace di fornire una prima risposta sistematica alle controversie di modesta entità tra clienti e banche, fino alla più recente istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario nel 2009, disciplinato con delibera del CICR e affidato alla gestione della Banca d'Italia, un organismo che presenta natura di procedura di risoluzione alternativa delle controversie con caratteristiche peculiari, distinte tanto dall'arbitrato in senso tecnico quanto dalla mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, sebbene condivida con quest'ultima la finalità generale di offrire una risposta rapida ed economica alle controversie tra clienti e intermediari finanziari.

Il rapporto tra l'Arbitro Bancario Finanziario e la mediazione civile e commerciale ordinaria, già toccato nel Capitolo 5 del presente volume con riferimento alla materia dei contratti bancari, merita un approfondimento storico che ne illustri le ragioni sistemiche: il legislatore italiano ha scelto di non assoggettare le controversie bancarie e finanziarie alla mediazione civile e commerciale ordinaria come condizione di procedibilità esclusiva, prevedendo piuttosto un sistema alternativo specificamente dedicato al settore, in ragione della specificità tecnica della materia e dell'esigenza di garantire un controllo pubblicistico rafforzato sull'equilibrio contrattuale nei rapporti tra intermediari finanziari e clientela retail, un controllo che il modello di mediazione privatistica generale, caratterizzato dalla piena autonomia negoziale delle parti, non era ritenuto in grado di garantire con la medesima efficacia.

La coesistenza dei due sistemi e le scelte del cliente bancario

Il cliente bancario che intenda contestare una condotta dell'intermediario finanziario dispone quindi, nell'attuale assetto normativo, di una pluralità di strumenti alternativi tra loro non del tutto sovrapponibili: il reclamo diretto all'intermediario, disciplinato dalle disposizioni di trasparenza bancaria della Banca d'Italia; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, quando il reclamo non abbia sortito l'esito sperato; e, per le materie che rientrino nell'ambito di applicazione della mediazione civile e commerciale (tipicamente quelle non rientranti nella competenza specifica dell'Arbitro Bancario Finanziario, quale limitata dal valore della controversia e dalla natura della pretesa), il ricorso alla mediazione civile e commerciale ordinaria. L'avvocato negoziatore che assista un cliente bancario in una controversia con il proprio intermediario finanziario deve orientarsi con competenza tra questi diversi strumenti, valutando caso per caso quale di essi offra, per la specifica controversia considerata, le maggiori prospettive di successo in termini di tempi, costi ed efficacia della tutela conseguibile.

Approfondimento: la mediazione come fenomeno di giustizia complementare

Il paradigma della giustizia complementare rispetto alla giustizia ordinaria

La dottrina processualcivilistica più recente ha proposto di qualificare la mediazione, nell'ambito del più ampio quadro degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, non come sostituto della giustizia ordinaria amministrata dallo Stato attraverso i propri organi giurisdizionali, ma piuttosto come strumento di giustizia complementare, che si affianca e integra la giustizia ordinaria offrendo alle parti una modalità aggiuntiva di composizione delle proprie controversie, particolarmente idonea per le controversie nelle quali la componente relazionale e comunicativa assuma un rilievo significativo accanto alla mera componente giuridica della pretesa fatta valere. Questo paradigma della complementarità, che il presente volume ha implicitamente adottato nella propria esposizione sistematica dei rapporti tra mediazione e giustizia ordinaria, consente di superare una visione antagonistica tra i due sistemi, che ha talvolta caratterizzato il dibattito dottrinale e professionale nella fase di prima introduzione della mediazione obbligatoria in Italia, in favore di una visione sinergica nella quale l'avvocato negoziatore assume un ruolo di ponte tra i due sistemi, orientando il cliente verso lo strumento più adeguato secondo le caratteristiche specifiche della controversia considerata.

L'esperienza applicativa italiana successiva all'introduzione della mediazione obbligatoria, caratterizzata da un progressivo consolidamento dei tassi di adesione e di successo della mediazione secondo i dati statistici pubblicati periodicamente dal Ministero della Giustizia, conferma empiricamente la validità di questo paradigma della complementarità, mostrando come la mediazione non abbia sottratto un numero significativo di controversie alla giustizia ordinaria in termini di riduzione strutturale del contenzioso pendente, quanto piuttosto abbia offerto un'ulteriore modalità di composizione delle controversie che coesiste con il sistema giudiziale ordinario in un rapporto di reciproca integrazione funzionale.

Le prospettive di ulteriore sviluppo del paradigma complementare

Le prospettive di ulteriore sviluppo di questo paradigma della giustizia complementare, nel prossimo futuro dell'ordinamento italiano, appaiono orientate verso un progressivo consolidamento della mediazione quale componente strutturale, e non più eccezionale, del sistema di amministrazione della giustizia civile e commerciale complessivamente considerato, un'evoluzione che richiede, come già osservato nel presente volume con riferimento alla

formazione universitaria dei futuri avvocati, un adeguato investimento formativo e culturale affinché l'intera categoria professionale forense maturi una piena consapevolezza del proprio ruolo di ponte tra i due sistemi complementari di amministrazione della giustizia civile e commerciale.

Approfondimento: la mediazione sportiva e i suoi organismi specializzati

Il Tribunal Arbitral du Sport e i meccanismi di mediazione nello sport internazionale

Le controversie sportive di rilevanza internazionale, tradizionalmente affidate alla competenza arbitrale del Tribunal Arbitral du Sport con sede a Losanna, hanno progressivamente conosciuto lo sviluppo di meccanismi di mediazione preventiva, promossi dallo stesso Tribunal attraverso un proprio servizio di mediazione specificamente dedicato alle controversie tra federazioni sportive, atleti, club e altri soggetti dell'ordinamento sportivo internazionale, un servizio che offre alle parti coinvolte in controversie sportive internazionali uno strumento alternativo caratterizzato da maggiore riservatezza e da minori costi rispetto al procedimento arbitrale ordinario, particolarmente adatto per controversie che non presentino una complessità tecnico-giuridica tale da richiedere necessariamente una decisione arbitrale vincolante.

L'ordinamento sportivo italiano, attraverso il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha analogamente sviluppato propri meccanismi di composizione delle controversie sportive interne, che si affiancano, senza sovrapporsi necessariamente, alla mediazione civile e commerciale ordinaria disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, quest'ultima applicabile alle controversie di natura patrimoniale che coinvolgano soggetti dell'ordinamento sportivo (ad esempio controversie contrattuali tra un club sportivo e un proprio sponsor commerciale) che non presentino una specifica connessione con l'ordinamento sportivo in senso tecnico, quale disciplinato dai regolamenti federali e dal Codice della giustizia sportiva.

L'avvocato negoziatore nel settore sportivo: competenze specifiche richieste

L'avvocato negoziatore che intenda specializzarsi nell'assistenza a soggetti dell'ordinamento sportivo, quali atleti professionisti, club sportivi, o federazioni, dovrebbe acquisire una solida conoscenza sia della disciplina generale della mediazione civile e commerciale già illustrata nel presente volume, sia delle specificità dell'ordinamento sportivo, caratterizzato da una particolare autonomia normativa e giustiziale rispetto all'ordinamento statale generale, secondo il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuto anche dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha definito i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale in Italia, un quadro normativo complesso che richiede all'avvocato negoziatore una specifica preparazione settoriale per orientare correttamente i propri clienti tra i diversi strumenti di composizione delle controversie disponibili.

Approfondimento: la mediazione nel diritto del lavoro e le sue peculiarità storiche

Il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie di lavoro: evoluzione normativa

Le controversie individuali di lavoro hanno conosciuto, nell'evoluzione normativa italiana, un percorso peculiare rispetto alla generale disciplina della mediazione civile e commerciale,

essendo state assoggettate in passato a un tentativo di conciliazione obbligatorio dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo il testo originario dell'articolo 410 del codice di procedura civile, un tentativo successivamente reso facoltativo dalla riforma del 2010 (collegato lavoro, legge 183/2010), che ha trasformato l'onere di esperire il tentativo di conciliazione da condizione di procedibilità della domanda giudiziale a mera facoltà delle parti, un'evoluzione normativa opposta rispetto a quella che ha caratterizzato, nel medesimo periodo storico, la mediazione civile e commerciale generale, progressivamente resa obbligatoria per un numero crescente di materie.

Questa evoluzione divergente tra la disciplina della mediazione nelle controversie di lavoro e quella della mediazione civile e commerciale generale trova una propria giustificazione sistemica nella specifica tutela costituzionale del lavoratore prevista dall'articolo 4 e dall'articolo 35 della Costituzione, che ha tradizionalmente orientato il legislatore verso un approccio di maggiore cautela rispetto all'introduzione di condizioni di procedibilità obbligatoria che potrebbero, in astratto, ritardare l'accesso alla tutela giurisdizionale del lavoratore, parte tipicamente ritenuta in posizione di maggiore debolezza negoziale rispetto al datore di lavoro nel contesto della controversia di lavoro.

La conciliazione sindacale come modello alternativo di composizione

Il sistema italiano delle relazioni industriali ha storicamente privilegiato, quale strumento di composizione delle controversie di lavoro anche di natura individuale, il ricorso alla conciliazione sindacale, condotta con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali, secondo un modello che si affianca, senza sovrapporsi necessariamente, alla mediazione civile in senso tecnico disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, un modello che l'avvocato negoziatore che assista lavoratori o datori di lavoro in controversie individuali di lavoro dovrebbe conoscere adeguatamente, per poter orientare correttamente il proprio cliente tra i diversi strumenti di composizione disponibili secondo le circostanze specifiche della controversia considerata.

Approfondimento: la mediazione e il principio di sussidiarietà nell'ordinamento italiano

Il fondamento del principio di sussidiarietà orizzontale applicato alla giustizia civile

Il principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione con riferimento al rapporto tra istituzioni pubbliche e formazioni sociali nello svolgimento di attività di interesse generale, ha trovato, nella riflessione dottrinale più recente, una significativa applicazione anche al rapporto tra giustizia statale e strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali la mediazione civile e commerciale, secondo una lettura che valorizza l'autonomia negoziale dei privati nella composizione delle proprie controversie come espressione di un principio generale di responsabilizzazione della società civile, che lo Stato dovrebbe favorire e sostenere piuttosto che sostituire integralmente attraverso l'esclusivo ricorso alla giurisdizione ordinaria. Questa lettura del principio di sussidiarietà, sebbene non unanimemente condivisa dalla dottrina costituzionalistica più tradizionale, offre un fondamento teorico ulteriore, rispetto a quelli già ampiamente illustrati nel presente volume, per la legittimazione sistemica della mediazione quale componente strutturale, e non meramente eccezionale, dell'ordinamento processuale civile italiano.

L'applicazione di questo principio di sussidiarietà alla materia della mediazione civile e commerciale comporta, secondo questa impostazione dottrinale, la conseguenza che lo Stato dovrebbe intervenire con propri strumenti coercitivi (quali la previsione di una condizione di procedibilità obbligatoria) solo quando l'autonoma iniziativa dei privati nella composizione negoziale delle proprie controversie non risulti spontaneamente sufficiente a garantire un adeguato livello di deflazione del contenzioso giudiziale, un ragionamento che spiega, secondo questa prospettiva, la scelta legislativa italiana di introdurre la condizione di procedibilità obbligatoria solo per specifiche materie particolarmente esposte al rischio di contenzioso giudiziale prolungato, lasciando alla libera iniziativa delle parti la scelta di ricorrere alla mediazione per le altre materie non soggette a tale condizione.

Le implicazioni pratiche di questa impostazione teorica per l'avvocato negoziatore

L'adesione, anche solo parziale, a questa impostazione teorica del principio di sussidiarietà applicato alla mediazione dovrebbe orientare l'avvocato negoziatore verso una considerazione della mediazione non come mero adempimento formale richiesto dalla legge nelle materie soggette a condizione di procedibilità obbligatoria, ma come autentica espressione di un valore costituzionale di responsabilizzazione della società civile nella gestione dei propri conflitti, un valore che dovrebbe orientare l'avvocato negoziatore a proporre attivamente il ricorso alla mediazione anche per le controversie non soggette a condizione di procedibilità obbligatoria, quando le circostanze del caso concreto suggeriscano che tale strumento possa offrire una composizione della controversia più efficiente e soddisfattiva per il proprio cliente rispetto al contenzioso giudiziale ordinario.

Approfondimento: la mediazione e il rapporto con la giustizia predittiva

L'uso di strumenti predittivi nella valutazione del BATNA in mediazione

Lo sviluppo di strumenti di giustizia predittiva, basati sull'analisi statistica di grandi banche dati giurisprudenziali per la stima probabilistica dell'esito di una controversia secondo le caratteristiche del caso concreto, offre all'avvocato negoziatore un supporto tecnologico potenzialmente rilevante per la valutazione del BATNA e del WATNA nel contesto della mediazione, poiché tali strumenti possono fornire indicazioni quantitative circa la probabilità di successo di un determinato orientamento processuale, sulla base dell'analisi di precedenti giurisprudenziali con caratteristiche fattuali analoghe a quelle della controversia considerata, un supporto che tuttavia deve essere sempre integrato, e non sostituito, dalla valutazione professionale qualificata dell'avvocato, che resta l'unico soggetto in grado di apprezzare le specificità del caso concreto che un'analisi statistica automatizzata potrebbe non cogliere adeguatamente.

L'avvocato negoziatore che si avvalga di strumenti di giustizia predittiva nella propria attività professionale dovrebbe comunicare con trasparenza al proprio cliente i limiti metodologici di tali strumenti, evitando di attribuire alle indicazioni statistiche fornite un valore di certezza previsionale che esse non possiedono, e mantenendo sempre la propria responsabilità professionale piena nella valutazione complessiva della strategia negoziale da adottare nel caso concreto, secondo il principio generale di responsabilità professionale che impone all'avvocato di non delegare a strumenti automatizzati le proprie valutazioni tecnico-giuridiche essenziali.

Capitolo 2

Deontologia dell'avvocato negoziatore

Se il capitolo precedente ha ricostruito la storia lunga della funzione negoziale dell'avvocato, questo capitolo ne esamina la codificazione deontologica, italiana e comparata, distinguendo con cura le norme oggi vigenti da quelle previgenti, poiché in questa materia il mutamento normativo degli ultimi anni è stato significativo e un errore di attualizzazione rischierebbe di vanificare l'utilità pratica del capitolo per l'avvocato che lo consulti.

2.1 L'articolo 27 del codice deontologico forense: dal testo previgente al testo attuale

Il codice deontologico forense italiano, nella versione in vigore dal 12 giugno 2018, conteneva all'articolo 27, comma 3, una disposizione specificamente dedicata al dovere dell'avvocato di informare il cliente, all'atto dell'assunzione dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla procedura di mediazione e degli incentivi fiscali connessi. Il testo previgente disponeva testualmente che l'avvocato è tenuto a informare chiaramente la parte assistita, al momento dell'assunzione dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, dandone atto in un apposito documento sottoscritto dalla parte stessa, e a rilasciare al cliente, se richiesto, l'attestazione della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte che si trovi nelle condizioni di reddito indicate all'articolo 76 del d.p.r. 115/2002.

Le successive revisioni del codice deontologico forense, intervenute per adeguare la disciplina professionale al mutato quadro legislativo introdotto dalla riforma Cartabia, hanno mantenuto la sostanza del precetto informativo, rafforzandone la portata alla luce dell'ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria e dell'introduzione della negoziazione assistita come istituto autonomo. L'avvocato negoziatore contemporaneo è quindi tenuto, in forza della disciplina deontologica vigente, non soltanto a informare il cliente dell'esistenza dello strumento mediativo, ma a valutare con lui, in modo informato e documentato, l'opportunità concreta di percorrerlo, tenendo conto delle circostanze del caso specifico: un dovere che si è progressivamente arricchito di un contenuto valutativo, non meramente informativo.

La violazione di questo dovere informativo, quando cagioni un danno al cliente per la perdita di un'opportunità di composizione più favorevole rispetto all'esito del giudizio, può fondare una responsabilità disciplinare e, in concorso con altri elementi, una responsabilità civile professionale, tema che il capitolo 7 di questo volume approfondisce specificamente.

2.2 L'articolo 54 del codice deontologico: i rapporti con arbitri, conciliatori e mediatori

L'articolo 54 del codice deontologico forense disciplina i rapporti dell'avvocato con gli arbitri, i conciliatori e i mediatori, imponendo un dovere di correttezza e di lealtà che si estende, per estensione logica e non soltanto testuale, alla figura del mediatore civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo 28/2010. L'avvocato che assiste una parte in mediazione non può, in forza di questa disposizione, adottare condotte dilatorie o comunque contrarie al principio di buona fede che deve informare l'intero procedimento, né può utilizzare la mediazione come strumento meramente tattico per acquisire informazioni sulla posizione della controparte senza autentica intenzione di comporre la lite.

Questo principio di lealtà procedimentale trova un riscontro puntuale nell'elenco dei doveri dell'avvocato negoziatore fissato dall'articolo 2, comma 7, della legge di

degiurisdizionalizzazione (decreto legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014), che elenca in modo specifico: il divieto per l'avvocato di assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia nella quale ha assistito una parte in negoziazione assistita; il dovere di lealtà e riservatezza; la non utilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura negoziale, salvo che il loro contenuto costituisca autonomamente reato; il non obbligo di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel procedimento di negoziazione, richiamando espressamente gli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale sul segreto professionale; la non applicabilità della disciplina antiriciclaggio all'attività di assistenza nella negoziazione assistita in quanto tale, salve le ipotesi generali di applicazione della normativa antiriciclaggio all'attività dell'avvocato; l'obbligo di trasmettere l'accordo di negoziazione assistita in materia familiare all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza o del luogo di celebrazione del matrimonio, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, sotto pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro; e infine la trascrivibilità dell'accordo che contenga il riconoscimento di un debito quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dovere dell'avvocato negoziatore

Divieto di assumere funzione di arbitro

Lealtà e riservatezza

Non utilizzabilità delle dichiarazioni

Segreto professionale

Esenzione antiriciclaggio per l'atto negoziale

Trasmissione dell'accordo familiare

Titolo per ipoteca giudiziale

Tabella 2.1 — Doveri dell'avvocato negoziatore ex art. 2, comma 7, d.l. 132/2014

2.3 L'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010: dal testo storico all'aggiornamento del d.m. 150/2023

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 dispone, nel suo testo vigente, che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché del fatto che il mancato assolvimento di tale obbligo informativo determina l'annullabilità del contratto concluso tra l'avvocato e l'assistito. La medesima disposizione stabilisce inoltre che il documento che contiene l'informazione deve essere sottoscritto dall'assistito e allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il Cendom, nella sua edizione del 2020, segnalava criticamente che il credito d'imposta previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010 fosse, nella prassi applicativa dell'epoca, sostanzialmente lettera morta, a causa della farraginosità delle procedure di riconoscimento e dei ritardi nell'erogazione. Questa nota critica, formulata quando la normativa attuativa risultava ancora inadeguata, deve considerarsi oggi superata: il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, adottato in attuazione della riforma Cartabia, ha riformato in modo organico il meccanismo del credito d'imposta, introducendo una procedura telematica di richiesta gestita direttamente dal Ministero della Giustizia, termini certi di erogazione e un ampliamento degli

importi massimi riconoscibili, fino a 600 euro sull'indennità di mediazione e ulteriori 600 euro sul compenso dell'avvocato per l'ipotesi di esito positivo della mediazione, con importi proporzionalmente ridotti in caso di esito negativo. Questo aggiornamento normativo costituisce uno dei punti di maggiore rilievo pratico del presente capitolo rispetto alla fonte Cendom del 2020, e va segnalato con chiarezza a chiunque continui a fare riferimento, per abitudine professionale, alla vecchia prassi applicativa dell'articolo 20.

« Il credito d'imposta di cui all'articolo 20 è, nella prassi, lettera morta. »

— **Nota critica formulata nel Cendom, edizione 2020, oggi superata dal d.m. 150/2023**

2.4 Comparazione internazionale: Québec, Stati Uniti, e altri ordinamenti

Il diritto comparato offre un panorama variegato di soluzioni deontologiche relative al ruolo dell'avvocato nella composizione amichevole delle liti. Il Code of Professional Conduct del Québec, all'articolo 42, impone all'avvocato di informare il cliente delle modalità alternative di risoluzione della controversia disponibili prima di consigliargli di intraprendere o di continuare un procedimento giudiziario, un dovere informativo sostanzialmente sovrapponibile, nella sua ratio, a quello previsto dal diritto italiano.

Negli Stati Uniti, l'Administrative Dispute Resolution Act del 1998, alla Section 651, impone alle agenzie federali di considerare l'uso di procedure di risoluzione alternativa delle controversie in ogni caso in cui ciò appaia appropriato, con un impatto indiretto ma significativo sulla prassi professionale degli avvocati che assistono soggetti privati in controversie con l'amministrazione federale.

La legge sugli avvocati ellenici del 2018, all'articolo 182-bis, introduce un obbligo informativo analogo a quello italiano, in un percorso normativo greco che merita di essere ricostruito con attenzione: una prima legge, adottata nel gennaio 2018 e riferita agli articoli 183 e 182, venne dichiarata incostituzionale dai giudici greci per contrasto con il diritto di accesso alla giustizia; il legislatore ellenico intervenne nuovamente nel novembre 2018 con una nuova disciplina, più limitata nel suo ambito applicativo, riferita al solo primo incontro di mediazione, in una soluzione di compromesso che bilancia l'esigenza deflativa con la tutela costituzionale dell'accesso al giudice.

Il codice etico degli avvocati bulgari, all'articolo 18, comma 1, e il codice etico degli avvocati danesi, alla disposizione 16.9, prevedono entrambi doveri informativi analoghi. La Lituania, all'articolo 10, comma 9, del proprio codice deontologico forense, adotta una formulazione che pone l'accento sul dovere dell'avvocato di agire nell'interesse del cliente anche valutando alternative al contenzioso. Il Bhutan, con il Jabmi Act del 2003, agli articoli 39-41, disciplina il ruolo del jabmi, la figura di rappresentante legale tradizionale bhutaneese, imponendo doveri di composizione amichevole che riflettono una cultura giuridica fortemente orientata alla mediazione comunitaria.

Il Belize, attraverso la Corte Suprema e la sua guida operativa Attorney's Guide to Court Connected Mediation, adotta un approccio pragmatico e didattico, illustrando agli avvocati le modalità concrete di partecipazione alla mediazione connessa al processo civile ordinario. L'Irlanda, con il Mediation Act del 2017, alle Sections 14 e 15, impone all'avvocato l'obbligo di informare il cliente della mediazione prima dell'avvio di un procedimento giudiziario e di

fornire una dichiarazione scritta attestante l'assolvimento di tale obbligo, in un meccanismo di documentazione dell'informativa molto simile a quello italiano. Malta, infine, prevede specifici obblighi di disclosure nelle procedure di divorzio, imponendo all'avvocato di rendere nota alla controparte e al giudice l'avvenuta considerazione di percorsi di mediazione familiare.

2.5 Il decreto ministeriale 150/2023 e la qualità del sistema formativo

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, adottato in attuazione della riforma Cartabia, disciplina in modo organico non soltanto il meccanismo del credito d'imposta già richiamato, ma anche i requisiti di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati che intendano operare come mediatori, e i requisiti organizzativi degli organismi di mediazione. Il decreto fissa standard minimi di ore di formazione iniziale e di formazione continua, differenziati in funzione della specializzazione richiesta per le materie a più elevata complessità tecnica, quali la responsabilità sanitaria e le controversie societarie.

Per l'avvocato che non svolga la funzione di mediatore ma assista le parti in qualità di difensore, il decreto non impone requisiti formativi specifici ulteriori rispetto a quelli generali della professione forense, ma la prassi ordinistica, attraverso le linee guida del Consiglio Nazionale Forense che si esaminano nel prossimo paragrafo, ha progressivamente incentivato una formazione volontaria specifica sulle tecniche di negoziazione e accompagnamento alla mediazione, riconosciuta come titolo di specializzazione in alcuni ordini circondariali.

2.6 Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense 2020-2026

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato, nel corso del periodo 2020-2026, una serie di linee guida e di documenti di indirizzo relativi al ruolo dell'avvocato nella mediazione e nella negoziazione assistita, in coerenza con l'evoluzione normativa intervenuta con la riforma Cartabia. Questi documenti, privi di efficacia normativa vincolante in senso proprio ma dotati di autorità interpretativa significativa nella prassi disciplinare, hanno progressivamente chiarito alcuni punti applicativi controversi: la portata dell'obbligo informativo alla luce dell'ampliamento delle materie obbligatorie, le modalità di documentazione dell'assolvimento di tale obbligo, la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'elenco dei mediatori, e le modalità di gestione dei conflitti di interesse quando l'avvocato-mediatore abbia in precedenza assistito una delle parti in altra controversia.

Il progetto di verifica giuridica collegato a questo volume segnala che, data la natura dinamica di questi documenti di indirizzo, aggiornati periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense, è opportuno verificare l'ultima versione disponibile sul sito istituzionale del Consiglio al momento della consultazione di questo capitolo, poiché linee guida più recenti potrebbero aver ulteriormente precisato i punti qui riassunti.

2.7 Il segreto professionale e la riservatezza nella negoziazione

Il principio di riservatezza che informa tanto la mediazione quanto la negoziazione assistita trova, per l'avvocato, un fondamento deontologico ulteriore rispetto a quello processuale già esaminato: il dovere generale di segretezza professionale, disciplinato dagli articoli 13 e 28 del codice deontologico forense, si applica pienamente alle informazioni acquisite nel corso della procedura negoziale, anche quando queste non siano coperte dalla specifica inutilizzabilità processuale prevista dall'articolo 9 del decreto legge 132/2014 o dall'articolo 9 del decreto

legislativo 28/2010. L'avvocato che, terminata la negoziazione senza accordo, intraprenda il giudizio, deve quindi prestare particolare attenzione a non introdurre nel processo elementi di conoscenza acquisiti esclusivamente in ragione della fase negoziale, anche quando la loro utilizzazione non sia espressamente vietata dalla legge, per non incorrere in una violazione del principio di lealtà e correttezza deontologica.

2.8 Conflitti di interesse e incompatibilità dell'avvocato-mediatore

Un tema di crescente rilevanza pratica, segnalato dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense richiamate al paragrafo 2.6, riguarda la gestione dei conflitti di interesse quando l'avvocato iscritto anche come mediatore presso un organismo sia chiamato a condurre una mediazione in cui una delle parti sia assistita da un collega del proprio stesso studio professionale, o quando l'avvocato-mediatore abbia in precedenza fornito consulenza a una delle parti su questioni anche indirettamente connesse all'oggetto della mediazione. La disciplina deontologica generale sul conflitto di interessi, di cui agli articoli 24 e seguenti del codice deontologico forense, si applica per estensione interpretativa a questa situazione, imponendo all'avvocato-mediatore un dovere di disclosure preventiva e, nei casi più gravi, un dovere di astensione dall'incarico.

2.9 Deontologia e credito d'imposta: il nesso tra dovere informativo e incentivo fiscale

Vale la pena sottolineare, in chiusura di capitolo, come il dovere deontologico informativo esaminato ai paragrafi 2.1 e 2.3 e l'incentivo fiscale disciplinato dal decreto ministeriale 150/2023 siano concettualmente e operativamente collegati: l'avvocato che assolve compiutamente il proprio dovere informativo, illustrando al cliente non soltanto l'esistenza della mediazione ma anche il concreto funzionamento del credito d'imposta oggi effettivamente operativo, contribuisce non soltanto alla propria compliance deontologica ma anche a un incremento della propensione del cliente a percorrere la via negoziale, con beneficio sistemico per la deflazione del contenzioso. Il superamento della lettera morta denunciata dal Cendom nel 2020 ha quindi un effetto a cascata sulla prassi deontologica quotidiana, rendendo l'informativa sul credito d'imposta un elemento centrale, e non più meramente formale, del colloquio tra avvocato e cliente al momento del conferimento dell'incarico.

Fonti citate nel capitolo: codice deontologico forense, artt. 13, 24 ss., 27, 28, 54; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 4 c. 3, 9, 17, 20; d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. l. 10 novembre 2014, n. 162, art. 2 c. 7; d.m. 24 ottobre 2023, n. 150; artt. 200 e 103 c.p.p.; art. 76 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115; Québec, Code of Professional Conduct, art. 42; USA, Administrative Dispute Resolution Act, 1998, Section 651; legge avvocati ellenici, 2018, art. 182-bis; codice etico avvocati bulgari, art. 18 c. 1; codice etico avvocati danesi, 16.9; Lituania, codice deontologico forense, art. 10 c. 9; Bhutan, Jabmi Act, 2003, artt. 39-41; Belize, Supreme Court, Attorney's Guide to Court Connected Mediation; Irlanda, Mediation Act, 2017, Sections 14-15; Malta, disciplina sulla disclosure nel divorzio; Consiglio Nazionale Forense, linee guida 2020-2026; C.A. Calcagno, Arbitrato e negoziato in Europa. Le opportunità dell'avvocato, Aracne Editrice, 2020; dossier mediareinformati.it: Deontologia, Cartabia, Credito d'imposta.

2.7 Il procedimento disciplinare: fasi e garanzie

Quando l'esposto o la segnalazione relativa a una condotta dell'avvocato nel contesto della mediazione perviene al Consiglio dell'ordine territorialmente competente, si apre una fase

istruttoria preliminare affidata al consigliere istruttore, che valuta se sussistano elementi sufficienti per l'apertura del procedimento disciplinare in senso proprio dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina, organo autonomo rispetto al Consiglio dell'ordine dal 2014 in forza della legge professionale 247/2012. L'avvocato negoziatore sottoposto a procedimento disciplinare per fatti connessi alla mediazione (tipicamente, omessa informativa ex art. 27 c.d.f., conflitto di interessi non dichiarato, o violazione della riservatezza sulle dichiarazioni rese in mediazione) gode delle medesime garanzie procedurali previste per ogni altro procedimento disciplinare forense: contraddittorio, diritto di difesa tecnica, possibilità di produrre memorie e documenti, facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale Forense in sede di impugnazione e, in ultima istanza, alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo la gradazione prevista dall'articolo 22 della legge 247/2012 e dal Titolo V del codice deontologico forense, vanno dall'avvertimento alla censura, dalla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino alla radiazione nei casi di maggiore gravità: per le violazioni più tipiche in materia di mediazione, la prassi disciplinare tende a orientarsi verso sanzioni dell'avvertimento o della censura, salvo che la condotta non riveli un dolo specifico o un pregiudizio grave per il cliente, nel qual caso la sanzione può essere significativamente più severa, incluse le ipotesi in cui l'omessa informativa abbia determinato la perdita di un beneficio fiscale o processuale rilevante.

2.8 Il rapporto tra deontologia e responsabilità civile

La violazione di un dovere deontologico non determina automaticamente una responsabilità civile risarcitoria dell'avvocato verso il cliente, poiché i due piani, disciplinare e civilistico, restano distinti quanto a presupposti, finalità e regime probatorio: tuttavia, nella prassi giurisprudenziale, l'accertamento in sede disciplinare di una violazione (ad esempio, dell'obbligo informativo ex art. 27 c.d.f.) costituisce spesso un elemento di prova significativo, sebbene non decisivo, nel successivo o parallelo giudizio civile di responsabilità professionale, poiché la violazione della regola deontologica è indicativa della violazione dello standard di diligenza professionale richiesto dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, e ripreso specificamente dal Capitolo 7 del presente volume in relazione alla responsabilità civile dell'avvocato negoziatore.

Il rapporto biunivoco tra i due piani si manifesta anche nella prassi assicurativa: le compagnie che assicurano la responsabilità civile professionale forense tendono a considerare l'esistenza di precedenti disciplinari specifici in materia di mediazione come elemento di valutazione del rischio nella determinazione del premio, un dato che dovrebbe incentivare l'avvocato negoziatore a curare con particolare attenzione l'adempimento formale e sostanziale degli obblighi informativi previsti dal codice deontologico, non soltanto per ragioni di correttezza professionale in senso stretto, ma anche per la gestione prudente del proprio rischio professionale complessivo.

Approfondimento

Il codice deontologico degli avvocati europei e il canone 3.7

Il Codice deontologico degli avvocati europei, adottato dal Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) e periodicamente aggiornato, dedica il canone 3.7.1 al dovere dell'avvocato di ricercare, ove possibile e appropriato, una soluzione della controversia proporzionata agli

interessi del cliente, e di consigliare al cliente in ogni fase adeguata del procedimento l'opportunità di tentare una composizione o il ricorso a metodi di risoluzione alternativa delle controversie. Questo principio, che orienta le legislazioni deontologiche nazionali degli Stati membri, trova nel diritto italiano una traduzione specifica e più stringente nell'articolo 27 del codice deontologico forense, di cui al Capitolo 2, che non si limita a un dovere generico di informazione ma ne specifica il contenuto, la forma e le conseguenze disciplinari in caso di violazione.

La comparazione tra il canone CCBE e l'articolo 27 c.d.f. italiano evidenzia una linea di continuità normativa che va dalla soft law europea alla disciplina positiva nazionale, un percorso che riflette la più ampia dinamica di armonizzazione delle regole deontologiche forensi in Europa, sebbene la deontologia forense resti, per definizione, una materia di competenza nazionale non armonizzata a livello di diritto dell'Unione europea in senso stretto, salvo per i profili di libera circolazione dei servizi legali disciplinati dalla direttiva 77/249/CEE e dalla direttiva 98/5/CE.

Il segreto professionale e la mediazione: profili penalistici

Il dovere di riservatezza dell'avvocato sulle informazioni acquisite nel corso della mediazione si intreccia con la disciplina penale del segreto professionale, presidiata dall'articolo 622 del codice penale (rivelazione di segreto professionale) e dall'articolo 200 del codice di procedura penale, che esime l'avvocato dall'obbligo di testimoniare su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero. L'avvocato negoziatore che abbia assistito una parte in mediazione, se successivamente chiamato a testimoniare in un procedimento penale connesso ai medesimi fatti, può opporre il segreto professionale con riferimento a quanto apprenda specificamente nel contesto della procedura di mediazione, sebbene tale facoltà non si estenda automaticamente a fatti di cui l'avvocato sia venuto a conoscenza per vie diverse dalla mediazione stessa.

La riservatezza della mediazione, garantita dall'articolo 9 del decreto legislativo 28/2010, opera anche nei confronti del giudice del successivo giudizio: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, neppure con il consenso della parte che le ha rese, salva l'ipotesi in cui il contenuto sia acquisito da fonte diversa e indipendente dalla mediazione. L'avvocato negoziatore deve informare con precisione il proprio cliente di questo regime di inutilizzabilità, poiché un cliente non adeguatamente informato potrebbe erroneamente ritenere che le concessioni fatte in sede di mediazione, ove l'accordo non venga raggiunto, possano successivamente pregiudicarlo nel merito del giudizio, un timore infondato che può disincentivare inutilmente l'apertura negoziale della parte.

Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense sulla mediazione

Il Consiglio Nazionale Forense ha progressivamente pubblicato linee guida e pareri interpretativi relativi all'applicazione dell'articolo 27 del codice deontologico forense nel contesto della riforma Cartabia, chiarendo in particolare che l'obbligo informativo si estende anche alla negoziazione assistita e agli altri strumenti di degiurisdizionalizzazione previsti dall'ordinamento, e non si esaurisce nella sola mediazione civile e commerciale in senso tecnico. Questa interpretazione estensiva, coerente con la ratio della norma di garantire una scelta informata del cliente tra tutte le opzioni di composizione della controversia disponibili,

amplia significativamente il perimetro degli obblighi dell'avvocato negoziatore rispetto a una lettura meramente letterale della disposizione.

I pareri del CNF hanno altresì affrontato la questione dei rapporti tra l'obbligo informativo e la libertà del cliente di rifiutare la mediazione anche dopo essere stato adeguatamente informato: l'avvocato che abbia assolto correttamente il proprio dovere informativo non incorre in responsabilità disciplinare per il solo fatto che il cliente scelga, nella sua piena autonomia, di non tentare la composizione negoziale o di non parteciparvi con reale disponibilità, poiché il dovere dell'avvocato si esaurisce nell'informazione e nel consiglio, senza estendersi a un obbligo di risultato circa l'effettivo utilizzo dello strumento da parte del cliente.

Approfondimento deontologico ulteriore

Il conflitto di interessi nella mediazione plurisoggettiva

Le mediazioni che coinvolgono una pluralità di parti, frequenti in materia di condominio, di responsabilità civile con più danneggiati o più responsabili, o di controversie societarie con più soci coinvolti, pongono all'avvocato negoziatore questioni di conflitto di interessi particolarmente delicate: l'articolo 24 del codice deontologico forense vieta all'avvocato di assumere un incarico contro un proprio assistito, anche se la nuova controversia sia estranea a quella oggetto del precedente mandato, e tale divieto si applica pienamente anche al contesto della mediazione, impedendo all'avvocato di assistere contemporaneamente, nella medesima procedura, parti portatrici di interessi in conflitto tra loro, anche quando esista un interesse comune rispetto a una terza parte.

La valutazione del conflitto di interessi in mediazione plurisoggettiva richiede all'avvocato negoziatore un'analisi preliminare accurata della struttura degli interessi in gioco, distinguendo le situazioni di interesse effettivamente comune, nelle quali un'assistenza congiunta di più parti può essere deontologicamente consentita previa adeguata informativa e consenso di tutte le parti coinvolte, dalle situazioni di interesse solo apparentemente comune ma potenzialmente divergente, nelle quali l'assistenza congiunta esporrebbe l'avvocato al rischio di una successiva contestazione disciplinare per conflitto di interessi non adeguatamente gestito.

L'obbligo di aggiornamento professionale continuo in materia di ADR

Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua obbligatoria impone a ciascun avvocato iscritto all'albo il conseguimento di un numero minimo di crediti formativi in ciascun triennio, e la crescente centralità della mediazione e degli altri strumenti di ADR nella pratica forense contemporanea ha condotto a un incremento significativo dell'offerta formativa dedicata a queste materie da parte degli ordini territoriali e delle associazioni forensi specialistiche. L'avvocato negoziatore, anche quando non intenda specializzarsi come mediatore in senso proprio, dovrebbe considerare la formazione continua in materia di negoziazione e mediazione come parte integrante e non meramente accessoria del proprio percorso di aggiornamento professionale, coerentemente con l'evoluzione del ruolo dell'avvocato descritta nell'intero presente volume.

Alcuni ordini territoriali hanno sperimentato percorsi formativi integrati che combinano moduli giuridici tradizionali con moduli di natura relazionale e comunicativa, ispirati alle

discipline trattate nel Capitolo 4 (ascolto attivo, gestione delle emozioni, tecniche di riformulazione), un'evoluzione dell'offerta formativa che riflette la consapevolezza crescente, nella professione forense, della necessità di competenze relazionali oltre a quelle strettamente tecnico-giuridiche per l'esercizio efficace della funzione di avvocato negoziatore.

Approfondimento sulla vigilanza disciplinare

Il procedimento disciplinare presso il Consiglio distrettuale di disciplina

Il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato per violazioni deontologiche connesse alla mediazione, quali l'omissione dell'informativa obbligatoria o la violazione dei doveri di lealtà verso la controparte in sede di trattative, si svolge dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina competente, organo autonomo rispetto al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato, secondo un modello di separazione tra funzioni istituzionali e funzioni disciplinari introdotto dalla legge professionale forense del 2012 per garantire maggiore imparzialità e terzietà al giudizio disciplinare. Il procedimento si articola in una fase istruttoria, condotta dal consigliere istruttore designato, e in una fase decisoria dinanzi al collegio giudicante, con garanzie procedurali assimilabili, per molti aspetti, a quelle del procedimento penale, in ragione della natura sanzionatoria del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari applicabili all'avvocato per violazioni connesse alla mediazione spaziano, secondo la gravità della violazione accertata, dall'avvertimento alla censura, dalla sospensione dall'esercizio della professione per un periodo determinato fino, nei casi più gravi e reiterati, alla radiazione dall'albo, con possibilità di impugnazione della decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense in funzione giurisdizionale e, in ultima istanza, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo l'articolazione del sistema di giustizia disciplinare forense italiano.

Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento civile risarcitorio

Il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato, avente natura pubblicistica e finalità di tutela dell'interesse generale alla correttezza dell'esercizio della professione forense, resta distinto e autonomo rispetto all'eventuale procedimento civile risarcitorio che il cliente danneggiato dalla violazione deontologica possa promuovere per il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, con la conseguenza che l'accertamento disciplinare, sebbene possa costituire un elemento probatorio rilevante nel successivo giudizio civile, non ne pregiudica l'autonomo apprezzamento da parte del giudice civile quanto alla sussistenza del nesso causale e del danno concretamente subito dal cliente.

L'avvocato negoziatore che si trovi coinvolto, quale convenuto, in un giudizio risarcitorio connesso a una precedente violazione deontologica accertata in sede disciplinare dovrebbe considerare con particolare attenzione l'opportunità di un'eventuale composizione transattiva della controversia risarcitoria, anche in considerazione dell'effetto pregiudizievole che una sentenza di condanna definitiva potrebbe determinare sul piano reputazionale e assicurativo, oltre a quello meramente patrimoniale diretto.

Approfondimento: etica e responsabilità sociale dell'avvocato negoziatore

Il ruolo sociale dell'avvocato nella riduzione della litigiosità

L'evoluzione della professione forense verso il modello dell'avvocato negoziatore assume, oltre alla dimensione tecnico-giuridica e deontologica ampiamente illustrata nel presente capitolo, anche una dimensione di responsabilità sociale più ampia, collegata all'obiettivo di sistema di riduzione della litigiosità e di miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema giudiziario, un obiettivo che trascende l'interesse del singolo cliente per investire l'interesse generale della collettività a un sistema di giustizia funzionante e accessibile. L'avvocato negoziatore, nell'esercizio quotidiano della propria attività professionale, contribuisce a questo obiettivo di sistema ogniqualvolta orienta il cliente verso una composizione negoziale ragionevole della controversia, anziché verso un contenzioso motivato da ragioni meramente dilatorie o da un'errata valutazione delle proprie prospettive di successo giudiziale.

Questa dimensione di responsabilità sociale della professione forense trova riconoscimento anche nei codici deontologici di numerosi ordinamenti, che esplicitamente richiamano il dovere dell'avvocato di contribuire, nell'esercizio della propria attività, al buon funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia, un dovere che si affianca, senza sovrapporsi, al dovere primario di fedele rappresentanza degli interessi del proprio cliente, in un equilibrio che il presente volume ha più volte sottolineato come caratteristico e per certi versi peculiare della funzione dell'avvocato negoziatore rispetto al modello tradizionale dell'avvocato puramente avversariale.

La formazione etica del giovane avvocato: proposte metodologiche

La formazione universitaria giuridica italiana, tradizionalmente orientata prevalentemente allo studio del diritto sostanziale e del processo in senso tecnico, ha soltanto in tempi relativamente recenti iniziato a includere, nei propri percorsi curriculari, insegnamenti specificamente dedicati alla negoziazione e alla mediazione, un ritardo che si riflette ancora, secondo alcune valutazioni della dottrina specialistica, in una preparazione non sempre adeguata dei giovani avvocati rispetto alle competenze relazionali e negoziali richieste dalla pratica professionale contemporanea. Il periodo di praticantato forense, disciplinato dalla legge professionale forense e dai regolamenti attuativi del Consiglio Nazionale Forense, potrebbe costituire, secondo tale prospettiva, un momento formativo privilegiato per l'acquisizione di queste competenze, attraverso un affiancamento strutturato del praticante ad avvocati esperti nella gestione di procedure di mediazione, un modello di apprendimento esperienziale che alcuni ordini territoriali hanno iniziato a sperimentare attraverso specifici percorsi formativi dedicati.

L'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che tradizionalmente verifica prevalentemente competenze di diritto sostanziale e processuale in senso tecnico, potrebbe a sua volta beneficiare, secondo proposte di riforma avanzate in sede dottrinale e associativa, dell'introduzione di elementi di verifica delle competenze negoziali e relazionali del candidato, un'evoluzione che, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento italiano al momento della redazione del presente volume, rifletterebbe coerentemente l'importanza crescente di tali competenze nella pratica professionale contemporanea dell'avvocato.

Approfondimento: casi pratici di applicazione del codice deontologico

Caso pratico: la comunicazione con la controparte non assistita

Un caso pratico ricorrente nella prassi disciplinare riguarda la comunicazione diretta dell'avvocato con una controparte non assistita da un proprio difensore nel corso della fase

preliminare alla mediazione o durante la procedura stessa: l'articolo 27 del codice deontologico forense impone all'avvocato particolare cautela in questa situazione, dovendo egli evitare di sfruttare la posizione di vantaggio derivante dalla propria competenza tecnica per indurre la controparte non assistita a sottoscrivere un accordo che non comprenda adeguatamente, senza che a quest'ultima sia stata offerta l'opportunità di consultare un proprio legale prima della sottoscrizione. La violazione di questo dovere, quando accertata in sede disciplinare, è stata sanzionata dal Consiglio Nazionale Forense in funzione giurisdizionale con sanzioni che, secondo la gravità della violazione e le circostanze del caso concreto, sono giunte fino alla sospensione dall'esercizio della professione.

L'avvocato negoziatore che si trovi ad assistere una parte in una mediazione nella quale la controparte non sia assistita da un proprio difensore, situazione che l'ordinamento italiano ammette per le materie nelle quali la mediazione non richieda obbligatoriamente l'assistenza tecnica, dovrebbe adottare un livello di trasparenza e di cautela ulteriore rispetto all'ordinaria diligenza professionale, ad esempio raccomandando esplicitamente alla controparte non assistita di consultare un proprio legale prima di sottoscrivere l'accordo, un comportamento che, oltre a costituire un'osservanza scrupolosa del dovere deontologico, riduce significativamente il rischio di successiva contestazione dell'accordo per vizio del consenso o per squilibrio informativo tra le parti.

Caso pratico: il rifiuto di partecipare alla mediazione per motivi pretestuosi

Un ulteriore caso pratico di rilevanza deontologica riguarda la situazione dell'avvocato che consigli al proprio cliente di non partecipare alla mediazione obbligatoria, o di partecipare soltanto formalmente senza reale disponibilità alla composizione, per ragioni puramente dilatorie estranee a una genuina valutazione delle prospettive di successo della procedura: sebbene tale condotta non sia espressamente sanzionata come autonomo illecito disciplinare dal codice deontologico forense, essa può, secondo alcune elaborazioni dottrinali, porsi in contrasto con il dovere generale di lealtà e correttezza professionale previsto dall'articolo 9 del codice deontologico, specialmente quando la condotta dilatoria sia accompagnata da dichiarazioni non veritiere circa la disponibilità del cliente alla composizione negoziale.

L'avvocato negoziatore dovrebbe in ogni caso considerare che, indipendentemente dal profilo strettamente deontologico, il consiglio di una partecipazione meramente formale e non genuina alla mediazione esporrebbe il cliente al rischio delle conseguenze sfavorevoli in punto di spese processuali già ampiamente illustrate nel presente volume, un rischio che dovrebbe essere adeguatamente comunicato al cliente prima di adottare una simile strategia processuale, in adempimento del dovere generale di informativa che grava sull'avvocato nei confronti del proprio assistito.

Approfondimento: la deontologia comparata in materia di ADR

Il codice deontologico degli avvocati francesi in materia di mediazione

Il Règlement Intérieur National della professione forense francese dedica specifiche disposizioni all'attività dell'avvocato in materia di modes amiables de résolution des différends, un'espressione che comprende, nella tradizione giuridica francese, tanto la mediazione in senso proprio quanto la conciliazione e la procédure participative, un istituto peculiare del diritto francese che consente alle parti, assistite dai rispettivi avvocati, di negoziare direttamente la

composizione della controversia secondo un protocollo formalizzato, senza l'intervento di un terzo mediatore. Questo istituto, che non trova un preciso corrispondente nell'ordinamento italiano, offre uno spunto di interesse comparatistico per l'eventuale evoluzione futura della negoziazione assistita italiana, disciplinata dal decreto legge 132/2014, che presenta tratti di parziale similitudine con la procédure participative francese.

La deontologia forense francese in materia di ADR pone un accento particolare sul dovere dell'avvocato di verificare, prima di consigliare al cliente il ricorso a un determinato strumento di risoluzione alternativa delle controversie, la sua concreta adeguatezza alla natura specifica della controversia, un principio che trova un corrispondente sostanziale, sebbene formulato in termini leggermente diversi, nell'articolo 27 del codice deontologico forense italiano già ampiamente illustrato nel presente volume.

Il modello tedesco di responsabilità dell'Anwalt in materia di Mediation

L'ordinamento professionale forense tedesco, disciplinato dalla Bundesrechtsanwaltsordnung e dalle Berufsordnung für Rechtsanwälte, impone all'avvocato tedesco doveri informativi in materia di Mediation e di alternative Streitbeilegung (risoluzione alternativa delle controversie) che, sebbene non strutturati attorno a una condizione di procedibilità generalizzata come nel modello italiano, richiedono comunque all'avvocato di considerare, nell'interesse del cliente, l'opportunità di soluzioni extragiudiziali della controversia, un dovere di natura più genericamente deontologica che trova applicazione pratica soprattutto nel contesto del già illustrato modello del Güterichter, rispetto al quale l'avvocato tedesco svolge un ruolo di facilitazione dell'accesso piuttosto che di necessario esperimento preventivo obbligatorio.

Il confronto tra i diversi modelli deontologici europei in materia di ADR, sinteticamente illustrato in questo approfondimento, evidenzia una convergenza sostanziale sui principi fondamentali (dovere di informativa, dovere di valutazione dell'adeguatezza dello strumento al caso concreto, dovere di lealtà verso la controparte nel corso delle trattative), accompagnata da significative differenze quanto al grado di prescrittività e di specificità delle relative disposizioni deontologiche, un quadro comparativo che l'avvocato negoziatore italiano, specialmente quando operi in contesti professionali internazionali, dovrebbe conoscere per orientare correttamente la propria condotta professionale anche in presenza di controparti assistite da avvocati di altri ordinamenti europei.

Approfondimento: il segreto professionale dell'avvocato negoziatore

L'estensione del segreto professionale alle informazioni acquisite in mediazione

Il segreto professionale dell'avvocato, disciplinato dall'articolo 13 della legge professionale forense e dall'articolo 622 del codice penale già richiamato nel presente volume, si estende pienamente alle informazioni acquisite nel corso dell'assistenza fornita al cliente in una procedura di mediazione, comprendendo non soltanto le comunicazioni dirette tra avvocato e cliente ma anche le informazioni acquisite indirettamente nel corso delle sessioni di mediazione, incluse quelle relative alla posizione e alle dichiarazioni della controparte, quando tali informazioni siano state acquisite nell'esercizio della propria funzione professionale di assistenza al cliente. L'avvocato negoziatore deve quindi osservare un livello di riservatezza rafforzato rispetto alle informazioni acquisite in mediazione, che si sovrappone, senza

sostituirla, alla specifica riservatezza procedimentale prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 28/2010 a carico di tutti i partecipanti alla procedura.

La violazione del segreto professionale da parte dell'avvocato, quando concretizzi una divulgazione non autorizzata di informazioni acquisite in mediazione a soggetti estranei al procedimento senza giustificato motivo, può generare, oltre alla responsabilità disciplinare secondo l'articolo 28 del codice deontologico forense, anche una responsabilità penale ai sensi del già citato articolo 622 del codice penale, quando la divulgazione sia idonea a determinare un nocumento per la parte interessata, un rischio di duplice natura, disciplinare e penale, che l'avvocato negoziatore deve costantemente tenere presente nella gestione della documentazione e delle comunicazioni relative alle procedure di mediazione gestite.

Il segreto professionale nei rapporti con i collaboratori di studio

L'estensione del dovere di riservatezza sulle informazioni acquisite in mediazione ai collaboratori di studio dell'avvocato negoziatore, quali i praticanti avvocati e il personale amministrativo che abbia accesso alla documentazione relativa alle procedure gestite, richiede l'adozione di adeguate misure organizzative interne, quali protocolli di gestione documentale che limitino l'accesso alle informazioni riservate al solo personale strettamente necessario, e un'adeguata formazione di tutto il personale di studio sui doveri di riservatezza applicabili alla materia della mediazione, un presidio organizzativo che, sebbene non espressamente richiesto da una specifica disposizione normativa dedicata, discende dal generale dovere di vigilanza dell'avvocato sull'operato dei propri collaboratori previsto dai principi generali della responsabilità civile e deontologica.

Approfondimento: la pubblicità dell'attività di avvocato negoziatore

I limiti deontologici alla comunicazione professionale in materia di mediazione

L'articolo 35 del codice deontologico forense, che disciplina l'informazione sull'attività professionale, consente all'avvocato di comunicare la propria specializzazione o competenza specifica in materia di mediazione e negoziazione, purché tale comunicazione avvenga con correttezza e verità, evitando affermazioni suggestive o comparative che possano generare nel pubblico un'impressione ingannevole circa le proprie competenze effettive o circa i risultati concretamente conseguibili attraverso l'assistenza professionale offerta. L'avvocato negoziatore che intenda promuovere la propria attività professionale in questo ambito specifico, ad esempio attraverso un sito web professionale o attraverso i canali social media professionali, deve quindi porre particolare attenzione a non enfatizzare eccessivamente i tassi di successo delle proprie mediazioni passate, specialmente quando tali dati non siano oggettivamente verificabili da parte del pubblico, un limite che risponde all'esigenza di tutelare la fiducia del pubblico nell'affidabilità dell'informazione professionale fornita dagli avvocati.

La comunicazione relativa a eventuali certificazioni o qualificazioni specifiche conseguite dall'avvocato in materia di mediazione, quali l'iscrizione nell'elenco dei mediatori tenuto da un organismo di mediazione, o il conseguimento di certificazioni professionali specifiche rilasciate da organizzazioni internazionali riconosciute in materia di negoziazione o mediazione, è generalmente ammessa secondo i principi generali dell'articolo 35 del codice deontologico, purché tali qualificazioni siano effettivamente possedute e correttamente descritte, senza

sovrastime o ambiguità circa il loro effettivo contenuto e la loro effettiva rilevanza professionale.

Il ruolo dei contenuti educativi nella promozione professionale

La produzione di contenuti educativi e informativi in materia di mediazione, attraverso articoli specialistici, webinar, o partecipazione a convegni professionali, costituisce una modalità di promozione professionale particolarmente apprezzata dalla deontologia forense contemporanea, in quanto contribuisce alla diffusione della cultura della mediazione presso il pubblico e presso la stessa categoria professionale, andando oltre la mera autopromozione commerciale per assumere una dimensione di servizio alla collettività professionale e al pubblico in generale. L'avvocato negoziatore che produca contenuti di questo tipo, come l'autore del presente volume ha inteso fare attraverso la presente opera, dovrebbe mantenere un elevato standard di accuratezza tecnico-giuridica e di aggiornamento normativo, per non pregiudicare, attraverso imprecisioni o superficialità, la credibilità professionale complessiva che tali contenuti sono destinati a rafforzare.

Approfondimento: il rapporto tra avvocato negoziatore e assicurazione di tutela legale

La copertura delle spese di mediazione nelle polizze di tutela legale

Le polizze di assicurazione di tutela legale, diffuse tra i privati e le piccole imprese quale strumento di copertura dei costi connessi alla difesa dei propri diritti in sede giudiziale ed extragiudiziale, prevedono tipicamente, nelle condizioni contrattuali più aggiornate, anche la copertura delle spese connesse alla partecipazione a procedure di mediazione civile e commerciale, incluse le indennità dovute all'organismo di mediazione e i compensi dell'avvocato che assista l'assicurato in tale sede, una copertura che l'avvocato negoziatore dovrebbe sempre verificare all'apertura dell'incarico, quando il cliente dichiara di essere titolare di una polizza di tutela legale, per valutare l'opportunità di attivare tale copertura prima dell'avvio della procedura di mediazione.

L'attivazione della copertura assicurativa di tutela legale richiede tipicamente il rispetto di specifiche modalità procedurali previste dalle condizioni di polizza, quali la comunicazione preventiva del sinistro alla compagnia assicurativa prima dell'avvio della procedura di mediazione, e talvolta l'accettazione di un legale convenzionato indicato dalla compagnia stessa, salva la facoltà dell'assicurato di nominare un proprio legale di fiducia secondo quanto previsto dalla direttiva 2009/138/CE recepita nell'ordinamento italiano, una facoltà che l'avvocato negoziatore dovrebbe far valere, quando il cliente esprima la preferenza di essere assistito dal proprio legale di fiducia piuttosto che da un legale convenzionato indicato dalla compagnia assicurativa.

I limiti di copertura e le clausole di esclusione più frequenti

Le polizze di tutela legale prevedono tipicamente limiti massimi di copertura per singolo sinistro, franchigie a carico dell'assicurato, e clausole di esclusione per specifiche materie o circostanze (ad esempio l'esclusione delle controversie relative ad attività professionale o imprenditoriale dell'assicurato, quando la polizza sia stata stipulata come persona fisica per la tutela di interessi personali e familiari), limiti e clausole che l'avvocato negoziatore deve attentamente verificare prima di confidare sulla copertura assicurativa per la gestione dei costi

della procedura di mediazione, comunicando tempestivamente al cliente eventuali dubbi circa l'effettiva applicabilità della copertura al caso concreto, per evitare che il cliente maturi aspettative poi disattese circa la copertura dei costi dell'assistenza professionale ricevuta.

Approfondimento: il rapporto tra deontologia forense e deontologia del mediatore

La distinzione tra le due deontologie professionali

L'avvocato che assuma anche l'incarico di mediatore, situazione consentita dal nostro ordinamento e anzi favorita dalla previsione di specifici percorsi formativi per l'iscrizione degli avvocati negli elenchi dei mediatori tenuti dagli organismi di mediazione, è soggetto, nell'esercizio di tale distinta funzione, alla deontologia specifica del mediatore prevista dal decreto ministeriale 150/2023 e dai regolamenti dei singoli organismi di mediazione, che si affianca, senza sovrapporsi integralmente, alla deontologia forense generale che continua a disciplinare la sua qualità di avvocato anche quando non stia esercitando specificamente la funzione di mediatore. Questa duplicità di regimi deontologici applicabili al medesimo soggetto professionale, secondo la funzione concretamente svolta in un determinato momento, richiede all'avvocato che svolga anche la funzione di mediatore una particolare consapevolezza dei rispettivi ambiti di applicazione, per evitare confusioni che potrebbero pregiudicare la corretta gestione dei propri obblighi professionali.

La principale differenza tra i due regimi deontologici risiede nel diverso ruolo che l'avvocato e il mediatore rivestono rispetto alle parti coinvolte: mentre l'avvocato ha un dovere di difesa e di tutela dell'interesse del proprio cliente, il mediatore ha un dovere di imparzialità nei confronti di tutte le parti coinvolte nella procedura, un dovere che risulterebbe incompatibile con la simultanea assunzione, da parte del medesimo soggetto, del ruolo di avvocato di una delle parti e di mediatore della medesima procedura, un'incompatibilità che il codice deontologico forense e i regolamenti degli organismi di mediazione sanzionano attraverso il divieto assoluto per il mediatore di svolgere anche il ruolo di difensore di una delle parti nella medesima procedura.

La formazione congiunta e le sinergie tra le due competenze professionali

Nonostante la necessaria distinzione funzionale tra il ruolo di avvocato negoziatore e quello di mediatore, la formazione congiunta di entrambe le competenze professionali nel medesimo soggetto genera significative sinergie professionali: l'avvocato che abbia maturato esperienza anche come mediatore acquisisce, tipicamente, una più profonda comprensione delle dinamiche procedurali e psicologiche della mediazione, che gli consente di assistere con maggiore efficacia i propri clienti quando agisca in qualità di avvocato negoziatore in procedure condotte da altri mediatori, una sinergia formativa che il presente volume ha inteso valorizzare attraverso la propria esposizione sistematica, utile sia all'avvocato che aspiri a specializzarsi esclusivamente come negoziatore sia a quello che intenda conseguire anche la qualifica di mediatore professionista.

Approfondimento: la responsabilità disciplinare dell'avvocato per condotte extraprocessuali in mediazione

La rilevanza deontologica delle comunicazioni informali nel corso della negoziazione

Le comunicazioni informali che intercorrano tra avvocati nel corso della negoziazione connessa a una procedura di mediazione, quali messaggi di posta elettronica, comunicazioni telefoniche,

o scambi attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, sono soggette ai medesimi doveri deontologici di correttezza e lealtà applicabili alla generalità delle comunicazioni professionali tra avvocati, secondo l'articolo 20 del codice deontologico forense, che vieta comportamenti oltraggiosi o comunque scorretti nei confronti dei colleghi, un dovere che si applica anche al di fuori del contesto formale della sessione di mediazione, comprendendo le comunicazioni informali che spesso accompagnano e integrano il percorso negoziale complessivo.

La violazione di questi doveri di correttezza nelle comunicazioni informali, quando si concretizzi in condotte di particolare gravità quali minacce, intimidazioni, o pressioni indebite sulla controparte o sul suo difensore, può generare una responsabilità disciplinare autonoma dell'avvocato, distinta dalla responsabilità civile eventualmente configurabile secondo le regole generali, un profilo di responsabilità che il codice deontologico forense sanziona con particolare rigore, in ragione della rilevanza pubblicistica del corretto svolgimento dei rapporti professionali tra colleghi per la funzione stessa di amministrazione della giustizia, anche nella sua dimensione alternativa e negoziale.

Il ruolo della documentazione delle comunicazioni nella gestione di eventuali contestazioni

L'avvocato negoziatore che riceva comunicazioni scorrette o intimidatorie dalla controparte o dal suo difensore nel corso di una negoziazione connessa a una procedura di mediazione dovrebbe adottare specifiche cautele documentali per preservare la possibilità di far valere, in un eventuale procedimento disciplinare o giudiziale, la sussistenza di tali condotte scorrette, quali la conservazione integrale delle comunicazioni scritte ricevute e, quando opportuno, la comunicazione tempestiva al mediatore delle condotte scorrette verificatesi nel corso della procedura, per consentire al mediatore stesso di intervenire opportunamente nella gestione della dinamica procedimentale complessiva, secondo il proprio ruolo di garante della correttezza procedimentale della mediazione.

Approfondimento: il compenso dell'avvocato negoziatore e i parametri forensi

L'applicazione dei parametri del decreto ministeriale 55/2014 all'attività di assistenza in mediazione

Il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e le sue successive modificazioni, che disciplinano i parametri per la liquidazione dei compensi dell'avvocato in assenza di accordo scritto con il cliente, prevedono specifiche voci relative all'attività di assistenza stragiudiziale, applicabili anche all'attività di assistenza dell'avvocato negoziatore nel corso di una procedura di mediazione, sebbene la prassi professionale più diffusa preveda, per questa tipologia di attività, la stipulazione di un accordo scritto specifico con il cliente che determini il compenso dovuto secondo modalità liberamente concordate tra le parti, in conformità al principio generale di libera determinazione convenzionale del compenso professionale forense introdotto dalla riforma del 2012.

La determinazione convenzionale del compenso per l'attività di assistenza in mediazione può assumere diverse configurazioni, quali un compenso forfettario prestabilito per l'intera procedura, un compenso calcolato secondo tariffa oraria per le ore di attività effettivamente prestate, o un compenso parzialmente legato al risultato conseguito (success fee), quest'ultima modalità ammessa dalla deontologia forense purché non integri un patto di quota lite in senso

tecnico vietato dalla normativa applicabile, secondo la distinzione già ampiamente illustrata nel Capitolo 2 del presente volume tra le diverse tipologie di accordi sul compenso professionale.

La trasparenza informativa sul compenso previsto dalla legge professionale

L'articolo 13 della legge professionale forense impone all'avvocato l'obbligo di rendere noto al cliente, sin dal momento del conferimento dell'incarico, il livello di complessità dell'incarico stesso, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, distinguendo tra oneri e spese, con particolare riferimento a quelli che il cliente dovrebbe sostenere nell'ipotesi di attivazione di procedure stragiudiziali di risoluzione della controversia quali la mediazione, un obbligo informativo che l'avvocato negoziatore deve adempiere con particolare cura nell'ambito del più generale dovere informativo relativo alla mediazione già illustrato nel Capitolo 2, fornendo al cliente una stima realistica dei costi complessivi della procedura, comprensivi sia dell'indennità dovuta all'organismo di mediazione sia del proprio compenso professionale per l'attività di assistenza.

Approfondimento: la formazione continua obbligatoria dell'avvocato in materia di mediazione

Gli obblighi formativi previsti dal regolamento sulla formazione continua forense

Il regolamento sulla formazione continua degli avvocati, adottato dal Consiglio Nazionale Forense in attuazione dell'articolo 11 della legge professionale forense, impone a ciascun avvocato iscritto all'albo l'obbligo di conseguire un numero minimo di crediti formativi in ciascun triennio, attraverso la partecipazione a eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza o da altri soggetti autorizzati, un obbligo che comprende, tra le materie rilevanti, anche la formazione specifica in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie, sebbene tale formazione non sia configurata come obbligo autonomo e distinto ma rientri nel più generale obbligo formativo continuo dell'avvocato, con la possibilità per il singolo professionista di orientare la propria formazione secondo le proprie specifiche aree di interesse e specializzazione professionale.

L'avvocato che aspiri a specializzarsi come negoziatore e mediatore dovrebbe considerare l'opportunità di orientare una parte significativa della propria formazione continua obbligatoria verso corsi specificamente dedicati alla mediazione, alla negoziazione e alle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, non limitandosi al conseguimento del corso di formazione iniziale di ottanta ore richiesto per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori secondo il decreto ministeriale 150/2023, ma proseguendo con percorsi di formazione avanzata e di aggiornamento periodico che consentano di mantenere e affinare nel tempo le proprie competenze specialistiche in questo ambito professionale in continua evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Le scuole forensi e i master universitari in materia di ADR

La progressiva diffusione, nel panorama accademico e professionale italiano, di master universitari e corsi di alta formazione specificamente dedicati alla materia della risoluzione alternativa delle controversie, promossi sia da università italiane sia da scuole forensi territoriali, offre all'avvocato che intenda specializzarsi in questo settore un'ulteriore opportunità di approfondimento sistematico, complementare rispetto alla pratica professionale

quotidiana, un'opportunità che il presente volume, per sua natura orientato a una trattazione sistematica e completa della materia, intende integrare e valorizzare, senza tuttavia sostituire il valore insostituibile dell'esperienza professionale diretta e del confronto con altri professionisti specializzati nella medesima materia.

Capitolo 3

Il procedimento e il ruolo dell'avvocato negoziatore

Questo capitolo, il più esteso dell'opera per la densità della materia trattata, ricostruisce in dettaglio l'architettura procedimentale della mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita novellate dalla riforma Cartabia, con particolare attenzione al ruolo che l'avvocato è chiamato a svolgere in ciascuna fase, dalla proposizione della domanda fino alla formazione del titolo esecutivo.

3.1 Il decreto legislativo 28/2010 novellato: la nuova architettura dell'articolo 5

L'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, come riformato dal decreto legislativo 149/2022, distingue oggi con maggiore chiarezza sistematica tre categorie di mediazione: la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, disciplinata dal comma 1; la mediazione delegata dal giudice, disciplinata dal comma 2, che attribuisce al giudice istruttore, anche in sede di appello, il potere di disporre l'invio delle parti in mediazione tenendo conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti; e la mediazione volontaria, che le parti possono attivare in ogni tempo anche in assenza di condizione di procedibilità o di ordine del giudice.

Le materie soggette a condizione di procedibilità, elencate dal comma 1, comprendono oggi, dopo l'ampliamento operato dalla riforma Cartabia con effetto dal 30 giugno 2023: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e — novità della riforma — i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. L'elenco, va sottolineato, non è meramente stilistico: ogni voce corrisponde a una scelta politico-legislativa di individuazione delle materie nelle quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'interesse alla conservazione della relazione tra le parti o l'esigenza deflativa rispetto a un contenzioso di massa.

Il comma 4 dell'articolo 5 mantiene un elenco di esclusioni dalla condizione di procedibilità, tra cui i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito, i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile, e i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

3.2 Il primo incontro effettivo post-Cartabia

La riforma Cartabia interviene in modo particolarmente significativo sulla disciplina del primo incontro di mediazione, superando l'impostazione previgente che, nella prassi applicativa

consolidata fino al 2022, aveva sostanzialmente svuotato di contenuto operativo il primo incontro, riducendolo a un adempimento meramente informativo nel quale il mediatore si limitava a illustrare alle parti il funzionamento della procedura, senza affrontare il merito della controversia, salva la successiva adesione delle parti alla prosecuzione della mediazione a pagamento.

Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia, impone oggi che il primo incontro sia dedicato non soltanto all'informazione delle parti sulla funzione e sulle modalità di svolgimento della mediazione, ma anche a un'effettiva esplorazione, condotta dal mediatore con il supporto attivo degli avvocati presenti, della possibilità concreta di raggiungere un accordo. Questo cambiamento, apparentemente tecnico, ha una portata sostanziale profonda: trasforma il primo incontro da soglia procedurale a momento di merito, richiedendo all'avvocato una preparazione specifica già in vista di questo primo appuntamento, non soltanto in vista di eventuali incontri successivi.

L'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 28/2010 conferma la gratuità del primo incontro qualora la mediazione non prosegua, disponendo che nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione se le parti, all'esito del primo incontro effettivo, non intendono proseguire la procedura. Questa gratuità, unita all'obbligo di effettività del primo incontro appena descritto, crea un incentivo strutturale per l'avvocato a preparare con cura anche il solo primo incontro, poiché è in quella sede, e non necessariamente in sedi successive, che si gioca gran parte della possibilità di comporre la controversia senza ulteriori costi.

3.3 La procura ad hoc: dalla giurisprudenza 2019 alla prassi consolidata

Il capitolo 1 di questo volume ha già ricostruito la genesi giurisprudenziale del principio della procura ad hoc, fissato da Cass., 27 marzo 2019, n. 8473, e da Cass., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18068. Questo paragrafo ne approfondisce le implicazioni operative per l'avvocato che assista una parte in mediazione dopo la riforma Cartabia.

La procura alle liti generica, conferita per il giudizio di merito, non è sufficiente a legittimare la partecipazione dell'avvocato in luogo della parte, o a legittimare l'avvocato a manifestare una volontà dispositiva dei diritti sostanziali oggetto della controversia in sede di mediazione. È necessaria una procura sostanziale, distinta da quella processuale, che contenga il potere specifico di disporre dei diritti oggetto della mediazione, e che sia rilasciata con piena consapevolezza, da parte del cliente, del suo oggetto e della sua funzione. La riforma Cartabia, nel rafforzare il principio di partecipazione personale delle parti, di cui si tratta al paragrafo successivo, non ha abrogato né attenuato questo orientamento giurisprudenziale, che resta pienamente attuale nella prassi degli organismi di mediazione: l'avvocato deve verificare, prima del primo incontro, che la procura conferita dal cliente sia adeguata a questo specifico scopo, e non meramente riproduttiva della procura alle liti già rilasciata per un eventuale giudizio.

La relazione della Commissione Alpa del 2017, richiamata nel Cendom, aveva già segnalato, in un passo divenuto punto di riferimento dottrinale, che accanto alla difesa in giudizio occorre riconoscere e regolare compiutamente la difesa in mediazione, distinguendo le due funzioni sotto il profilo dei poteri rappresentativi necessari. Il progetto di articolo 84 elaborato dalla Commissione Alpa, pur non tradotto in legge nella sua interezza, ha influenzato la riflessione dottrinale successiva sulla necessità di una disciplina organica della rappresentanza in mediazione.

3.4 La partecipazione personale delle parti: principio rafforzato dalla riforma

La riforma Cartabia eleva a principio generale, con portata sistematica superiore a quanto avveniva nel testo previgente, l'obbligo di comparizione personale delle parti al primo incontro di mediazione, salva la possibilità di delega a un rappresentante munito di specifici poteri sostanziali e di piena conoscenza dei fatti, nei soli casi di giustificato motivo. Questo principio, già anticipato dalla giurisprudenza di merito precedente alla riforma — in particolare dal Tribunale di Vasto, con l'ordinanza del 23 aprile 2016 e con la successiva pronuncia del 17 dicembre 2018, richiamate nel capitolo 1 — trova oggi un fondamento legislativo esplicito, che rafforza in modo significativo il ruolo dell'avvocato come soggetto che prepara e accompagna la parte, senza potersi sostituire ad essa nel momento decisivo della manifestazione di volontà.

3.5 L'articolo 8: il termine, le sanzioni e la giurisprudenza 2020-2026

L'articolo 6 del decreto legislativo 28/2010, come modificato dal correttivo d.lgs. 216/2024, fissa in sei mesi la durata del procedimento di mediazione, decorrenti dalla presentazione della domanda e prorogabili dopo la sua instaurazione con accordo scritto delle parti; nella mediazione demandata dal giudice il termine di sei mesi è prorogabile una sola volta, per non oltre tre mesi. Il termine assume rilievo essenziale in relazione al calcolo della condizione di procedibilità: il giudice non può pronunciare l'improcedibilità della domanda giudiziale se il procedimento di mediazione, ancora pendente, non ha superato tale termine massimo.

L'articolo 12-bis del decreto legislativo 28/2010 (che ha sostituito il previgente articolo 8, comma 4-bis) disciplina le conseguenze sanzionatorie della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione: il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e condanna la parte costituita che non ha partecipato al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Questa disciplina sanzionatoria, già presente nel testo previgente, è stata oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale nel periodo 2020-2026, con la magistratura di merito e di legittimità chiamata a precisare la nozione di giustificato motivo e i presupposti applicativi della sanzione pecuniaria.

La giurisprudenza successiva al 2020 ha in particolare chiarito che la mera comparizione personale della parte, senza un'effettiva disponibilità a esplorare l'accordo, può essere valutata dal giudice, in sede di successivo giudizio, come condotta sostanzialmente assimilabile alla mancata partecipazione, quando risulti dagli atti che la parte si sia presentata al solo fine formale di evitare la sanzione, senza alcuna reale disponibilità negoziale: un orientamento che responsabilizza ulteriormente l'avvocato nella preparazione sostanziale, e non meramente formale, del cliente alla partecipazione in mediazione. Questo punto merita una verifica giurisprudenziale puntuale e aggiornata da parte del progetto di verifica giuridica collegato a questo volume, data l'evoluzione rapida della materia negli ultimi anni.

3.5.1 La mediazione telematica strutturale dopo il correttivo 216/2024

Il correttivo Cartabia, decreto legislativo 216/2024, disciplina in modo organico, come già illustrato nel capitolo 1, quattro modalità di svolgimento del procedimento di mediazione: la presenza fisica, la modalità telematica strutturale ai sensi dell'articolo 8-bis, la modalità audiovisiva da remoto ai sensi dell'articolo 8-ter e la modalità mista. L'articolo 8-bis disciplina

in particolare i requisiti tecnici della piattaforma telematica utilizzata dall'organismo di mediazione, che deve garantire la sicurezza delle comunicazioni, la riservatezza delle sessioni riservate con ciascuna parte, e l'autenticazione certa dei partecipanti, requisiti che l'avvocato deve verificare preventivamente per assicurarsi che l'organismo scelto offra garanzie tecniche adeguate.

L'articolo 8-ter disciplina invece la modalità audiovisiva da remoto, distinta dalla modalità telematica strutturata in quanto prevede la partecipazione mediante collegamento audiovisivo simultaneo, con modalità operative più vicine a una tradizionale udienza da remoto che a una piattaforma dedicata di mediazione online. Il correttivo chiarisce che entrambe le modalità, telematica strutturale e audiovisiva da remoto, sono equivalenti, sotto il profilo della validità procedimentale, alla presenza fisica, salvo il diritto di ciascuna parte di richiedere motivatamente lo svolgimento in presenza per specifiche esigenze.

3.6 L'accordo firmato dagli avvocati come titolo esecutivo

L'articolo 12 del decreto legislativo 28/2010 disciplina l'efficacia esecutiva del verbale di accordo raggiunto in mediazione, distinguendo due ipotesi: quando tutte le parti della mediazione sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, senza necessità di omologazione da parte del presidente del tribunale, purché gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; quando anche una sola parte non è assistita da un avvocato, l'accordo deve essere omologato con decreto del presidente del tribunale, su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Questa distinzione attribuisce all'avvocato una funzione paragiurisdizionale di certificazione, che il capitolo 7 di questo volume, dedicato alla responsabilità civile, analizza sotto il profilo delle conseguenze in termini di responsabilità professionale: l'avvocato che sottoscrive un accordo di mediazione contenente clausole contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, senza opporsi o senza segnalare il vizio, assume su di sé una responsabilità che può tradursi, in caso di successiva impugnazione dell'accordo, in un danno risarcibile per il cliente e in una possibile responsabilità disciplinare.

3.7 Il confronto normativo a 11 punti: mediazione civile e commerciale contro negoziazione assistita

Il Cendom dedica un'ampia sezione al confronto sistematico, punto per punto, tra la disciplina della mediazione civile e commerciale e quella della negoziazione assistita, un confronto che riproduciamo integralmente in questa sede, aggiornato alla luce della riforma Cartabia, per la sua utilità pratica immediata nella scelta dello strumento più adeguato al caso concreto.

3.7.1 Origine storica dei due istituti

La mediazione civile e commerciale italiana discende dalla direttiva 2008/52/CE, recepita attraverso la delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e attuata con il decreto legislativo 28/2010. La negoziazione assistita discende invece dal modello francese della *procédure participative*, introdotta dal rapporto Guinchard del 2008 e codificata negli articoli

2062-2067 del Code civil francese, e trasposta nel diritto italiano con il decreto legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014. Il Cendom ricostruisce con precisione l'iter parlamentare italiano che ha condotto all'adozione della negoziazione assistita: il testo elaborato congiuntamente da AIAF, AIGA, UNCC e dalla Triveneta il 10 maggio 2011; il disegno di legge Contento-Paniz del 25 maggio 2011; il disegno di legge Divina del 13 giugno 2011; la relazione di Guido Alpa al Congresso nazionale forense di Bari del 22-24 novembre 2012; il disegno di legge Divina bis del 15 marzo 2013; il disegno di legge Venittelli del 1° agosto 2013. Questo percorso, durato oltre tre anni, testimonia la complessità del dibattito politico-professionale che ha accompagnato l'introduzione di un istituto percepito, da una parte della classe forense, come potenzialmente sottrattivo di spazio professionale rispetto al contenzioso ordinario, e da un'altra parte come opportunità di valorizzazione della funzione negoziale dell'avvocato.

3.7.2 Definizioni normative

L'articolo 1 del decreto legislativo 28/2010 definisce la mediazione come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'articolo 2 del decreto legge 132/2014 definisce invece la convenzione di negoziazione assistita come l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati, iscritti all'albo anche in separati procedimenti.

3.7.3 Modalità di proposizione

La mediazione si propone mediante domanda depositata presso un organismo di mediazione accreditato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010, con conseguente fissazione del primo incontro. La negoziazione assistita si propone invece mediante invito a stipulare una convenzione, formulato da un avvocato alla controparte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 132/2014, senza l'intervento di un organismo terzo.

3.7.4 Oggetto

In entrambi gli istituti l'oggetto è costituito da diritti disponibili delle parti, essendo esclusa la possibilità di ricorrere sia alla mediazione sia alla negoziazione assistita per diritti indisponibili, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge per la materia familiare, dove la negoziazione assistita può riguardare anche la separazione personale, il divorzio e la modifica delle relative condizioni, pur trattandosi di materia connotata da un rilevante interesse pubblico.

3.7.5 Condizioni di procedibilità

La mediazione è condizione di procedibilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, per le materie elencate al paragrafo 3.1 di questo capitolo (condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e le nuove materie societarie introdotte dalla riforma Cartabia). La negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 132/2014, per le

domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, oltre che per i contratti di trasporto e sub-trasporto.

3.7.6 Esclusioni

L'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28/2010 e l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 132/2014 individuano, con elenchi puntuali ma non integralmente coincidenti, le ipotesi escluse dalla rispettiva condizione di procedibilità: procedimenti per ingiunzione, procedimenti di convalida di sfratto, procedimenti possessori, procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata nel processo penale, per la mediazione; procedimenti di ingiunzione, procedimenti cautelari, procedimenti relativi a controversie di lavoro e in genere quelli non aventi natura di diritti disponibili, per la negoziazione assistita.

3.7.7 Facoltatività residua

Al di fuori delle materie soggette a condizione di procedibilità, entrambi gli istituti restano disponibili su base volontaria per qualunque controversia relativa a diritti disponibili, con la scelta tra i due strumenti rimessa alla valutazione strategica dell'avvocato e del cliente, sulla base di considerazioni relative ai costi, ai tempi e alla natura della controversia che il capitolo 4 di questo volume approfondisce sotto il profilo tecnico-negoziale.

3.7.8 Costi: la tabella ministeriale e i parametri per l'onorario dell'avvocato

I costi della mediazione sono disciplinati dal decreto ministeriale 150/2023 (che ha abrogato e sostituito il d.m. 180/2010), che alla Tabella A determina l'indennità di mediazione dovuta all'organismo in funzione del valore della controversia, con importi differenziati per la fase di avvio e per la fase successiva all'accordo. Il compenso dell'avvocato per l'attività di assistenza in mediazione e in negoziazione assistita è determinato, in assenza di accordo tra le parti, sulla base dei parametri fissati dal decreto ministeriale 37/2018, che ha modificato il precedente decreto ministeriale 55/2014.

Il Cendom riproduce integralmente la tabella dei parametri per l'assistenza stragiudiziale, articolata per fasce di valore della controversia, dai 0,01 euro fino a oltre 520.000 euro, e per fasi dell'attività (fase di attivazione, fase di negoziazione o mediazione, fase di conciliazione o chiusura dell'accordo). Riproduciamo qui di seguito tale tabella, segnalando che i valori numerici riportati sono quelli del decreto ministeriale 37/2018 e vanno considerati un riferimento storico-normativo di base, da verificare rispetto a eventuali aggiornamenti tariffari intervenuti successivamente, dei quali il presente volume non ha potuto reperire conferma aggiornata nelle fonti consultate.

Fascia di valore della controversia (euro)

Fino a 1.100,00

Da 1.100,01 a 5.200,00

Da 5.200,01 a 26.000,00

Da 26.000,01 a 52.000,00

Da 52.000,01 a 260.000,00

Da 260.000,01 a 520.000,00

Tabella 3.1 — Parametri d.m. 37/2018 per l'assistenza stragiudiziale in mediazione e negoziazione assistita (valori storici 2018, riportati dal Cendom; nota di aggiornamento: verificare la vigenza attuale dei parametri numerici presso le fonti ufficiali del Ministero della Giustizia alla data di pubblicazione)

Un contributo critico rilevante su questo tema è offerto da Marina Marinaro, nel suo articolo Parametri avvocati, la negoziazione infrange il diritto UE, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2020, che riporta una decisione del Tribunale di Verona con la quale il giudice ha disapplicato la negoziazione assistita come condizione di procedibilità, ritenendola in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in ragione dell'onerosità dei costi legali imposti obbligatoriamente alle parti per accedere alla tutela giurisdizionale. Questo precedente, per quanto isolato e non consolidato in un orientamento giurisprudenziale maggioritario, segnala una tensione sistemica tra l'obiettivo deflativo della negoziazione assistita obbligatoria e il principio di accesso effettivo alla giustizia, tensione che il progetto di verifica giuridica dovrà monitorare rispetto agli sviluppi giurisprudenziali successivi al 2020.

3.7.9 Obbligatorietà dell'assistenza legale

In entrambi gli istituti l'assistenza di un avvocato è sempre necessaria quando lo strumento operi come condizione di procedibilità: nella mediazione ciò risulta espressamente dall'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, nella negoziazione assistita dalla stessa struttura dell'istituto, che per definizione presuppone l'intervento di un avvocato per ciascuna parte, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 132/2014.

3.7.10 Partecipanti al procedimento

Nella mediazione partecipano il mediatore, terzo neutrale designato dall'organismo, e le parti, assistite dai rispettivi avvocati. Nella negoziazione assistita non vi è alcun terzo neutrale: le parti negoziano direttamente, assistite dai rispettivi avvocati, che assumono quindi un ruolo ancora più centrale e diretto rispetto a quello che svolgono in mediazione, dove la conduzione del procedimento spetta formalmente al mediatore.

3.7.11 Svolgimento procedurale

Il procedimento di mediazione si svolge attraverso il primo incontro gratuito, disciplinato dall'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 28/2010, seguito, in caso di prosecuzione, da sedute ulteriori nel rispetto del termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 6, con possibilità di sedute riservate con ciascuna parte ai sensi dell'articolo 9, e conclusione, in caso di successo, con un accordo che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 12. La negoziazione assistita si svolge attraverso l'invito a negoziare, che la parte destinataria può accettare o rifiutare entro trenta giorni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 132/2014, la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, che fissa durata e modalità della trattativa, e la conclusione, in caso di successo, con un accordo che costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 5.

Profilo

Origine
Terzo neutrale
Proposizione
Termine massimo
Titolo esecutivo
Sanzioni per mancata partecipazione

Tabella 3.2 — Sintesi comparativa mediazione civile e commerciale / negoziazione assistita

3.8 L'evoluzione storica della mediazione obbligatoria in Italia

Il carattere obbligatorio della mediazione, oggi acquisito nel sistema italiano, è stato l'esito di un percorso normativo e giurisprudenziale accidentato. La Corte costituzionale, con la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, dichiarò l'illegittimità costituzionale della previsione dell'obbligatorietà nel testo originario del decreto legislativo 28/2010, per eccesso di delega rispetto ai limiti fissati dalla legge 69/2009. Il legislatore intervenne nuovamente con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto decreto del fare, che reintrodusse la condizione di procedibilità in via transitoria e sperimentale, per un periodo di quattro anni. L'articolo 11-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (la cosiddetta manovrina 2017), eliminò infine il carattere transitorio della previsione, rendendo permanente l'obbligatorietà della mediazione per le materie elencate.

I criteri che hanno guidato la scelta legislativa delle materie da assoggettare a condizione di procedibilità sono stati ricostruiti da Nicolò Trocker e Alessandra De Luca nel loro contributo *La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/CE* (Firenze University Press, 2011, pagina 177 e seguenti), che individuano tre categorie di ragioni: i rapporti di lunga durata, come quelli tra familiari, condomini e vicini, nei quali la conservazione della relazione futura rende preferibile una composizione negoziata rispetto a un giudizio che consacra un vincitore e un vinto; i rapporti particolarmente conflittuali sotto il profilo emotivo, come la diffamazione e la responsabilità medica, nei quali l'elaborazione del conflitto richiede strumenti relazionali che il processo ordinario non offre; e i rapporti di massa, come i contratti bancari e assicurativi, per i quali l'esigenza deflativa del contenzioso seriale prevale sotto il profilo di politica giudiziaria.

3.9 I criteri di idoneità del Ministero della Giustizia inglese

Un contributo di comparazione internazionale particolarmente utile è offerto dal *Civil Court Mediation Service Manual*, pubblicato dal Ministero della Giustizia inglese nel marzo 2009, che elenca in modo puntuale gli indicatori favorevoli e contrari all'idoneità di una controversia alla mediazione. Questa sezione, come segnalato nella mappa di lavoro alla base di questo capitolo, è firmata nel Cendom da Lucia Di Palermo e va attribuita a lei quale contributo autorialmente distinto, non all'Avv. Calcagno.

Gli indicatori favorevoli alla mediazione, secondo il manuale britannico, comprendono: la sussistenza di una relazione personale o commerciale che le parti intendono preservare per il futuro; la presenza di questioni non strettamente giuridiche, come aspetti emotivi, relazionali o di immagine, che il processo ordinario non può adeguatamente considerare; l'esistenza di più

opzioni di soluzione possibili, non riducibili a un'alternativa binaria vittoria-sconfitta; la volontà di entrambe le parti di risolvere rapidamente la controversia contenendo i costi; e la presenza di questioni relative a fatti complessi che un terzo esperto può aiutare a chiarire senza la rigidità delle regole probatorie processuali.

Gli indicatori contrari, sempre secondo il medesimo manuale, comprendono: la necessità di un precedente giudiziale vincolante su una questione di principio, che solo una sentenza può fornire; la presenza di un significativo squilibrio di potere tra le parti che renda improbabile una negoziazione equa senza le garanzie procedurali del processo; l'esistenza di condotte fraudolente o di malafede che richiedono l'accertamento pubblico proprio del processo; e la necessità di ottenere un provvedimento esecutivo immediato che la mediazione, priva di poteri coercitivi, non può assicurare con la stessa rapidità di un procedimento cautelare.

Indicatori favorevoli alla mediazione

Relazione personale o commerciale da preservare

Questioni emotive, relazionali o di immagine rilevanti

Più opzioni di soluzione possibili

Volontà comune di rapidità e contenimento dei costi

Fatti complessi chiaribili senza rigidità probatoria

Tabella 3.3 — Criteri di idoneità alla mediazione, Civil Court Mediation Service Manual, Ministero della Giustizia del Regno Unito, marzo 2009 (sezione firmata da Lucia Di Palermo nel testo Cendom di riferimento)

3.10 Il ruolo dell'avvocato nella scelta strategica tra mediazione e negoziazione assistita

Alla luce del confronto normativo appena ricostruito, l'avvocato che assiste il cliente in una controversia relativa a diritti disponibili, al di fuori delle ipotesi in cui la legge impone specificamente uno dei due strumenti come condizione di procedibilità, deve compiere una valutazione strategica che tenga conto di almeno quattro fattori: la presenza o assenza di un terzo neutrale che possa facilitare la comunicazione tra parti in conflitto acuto, fattore che orienta verso la mediazione quando il conflitto relazionale sia elevato; i costi comparati dei due istituti, con la negoziazione assistita generalmente meno onerosa in assenza dell'indennità dovuta all'organismo di mediazione, ma con un compenso dell'avvocato che può comunque risultare significativo secondo i parametri esaminati al paragrafo 3.7.8; la natura della controversia, con la negoziazione assistita più adatta a controversie bilaterali tra soggetti già rappresentati da avvocati con cui è possibile un dialogo diretto, e la mediazione più adatta a controversie multilaterali o a situazioni di elevata conflittualità psicologica; e infine la necessità di un titolo esecutivo rapido, che entrambi gli istituti offrono con modalità sostanzialmente equivalenti quando l'accordo sia sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti.

Questa valutazione strategica costituisce il punto di passaggio naturale verso il capitolo 4 di questo volume, dedicato alle tecniche di negoziazione che l'avvocato deve padroneggiare indipendentemente dallo strumento procedurale scelto.

Fonti citate nel capitolo: d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 1, 5, 8, 9, 12, 17; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, artt. 8-bis, 8-ter; d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 2, 3, 5; Code civil francese, artt. 2062-2067; rapporto Guinchard, 2008; l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 60; Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272; d.l. 21 giugno 2013, n. 69; d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. l. 21 giugno 2017, n. 96; d.m. 150/2023, Tabella A (già d.m. 180/2010); d.m. 37/2018; Cass., 27 marzo 2019, n. 8473; Cass., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18068; Trib. Vasto, ord. 23.4.2016 e 17.12.2018; Trib. Verona, decisione cit. in M. Marinaro, Parametri avvocati, la negoziazione infrange il diritto UE, Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2020; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; N. Trocker, A. De Luca, La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/CE, Firenze University Press, 2011; Ministero della Giustizia del Regno Unito, Civil Court Mediation Service Manual, marzo 2009 (sezione L. Di Palermo); relazione Commissione Alpa, 2017; testo AIAF-AIGA-UNCC-Triveneta, 10 maggio 2011; ddl Contento-Paniz, 25 maggio 2011; ddl Divina, 13 giugno 2011; relazione Alpa, Congresso di Bari, 22-24 novembre 2012; ddl Divina bis, 15 marzo 2013; ddl Venittelli, 1° agosto 2013; art. 84 progetto Commissione Alpa; F. Valerini, Presenza personale delle parti ed effettività della mediazione, judicium.it; C.A. Calcagno, Arbitrato e negoziato in Europa. Le opportunità dell'avvocato, Aracne Editrice, 2020; dossier mediareinformati.it: Cartabia, Procedimento, Telematica.

3.11 La preparazione documentale del fascicolo di mediazione

L'avvocato negoziatore che predispone la domanda di mediazione, o che assiste la parte invitata, deve curare con attenzione la formazione del fascicolo documentale da presentare all'organismo, comprendente non soltanto la domanda stessa, redatta con l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 28/2010, ma anche la documentazione a supporto della posizione della parte, che potrà essere utilmente prodotta al mediatore, sia in sede congiunta sia in sede riservata a seconda della strategia negoziale adottata. La scelta di quali documenti produrre e in quale fase della procedura costituisce essa stessa una decisione tattica di rilievo, poiché la mediazione, a differenza del processo, non conosce un regime rigido di preclusioni probatorie, e consente quindi una gestione più flessibile e progressiva dell'informazione.

Un secondo profilo pratico riguarda la gestione della riservatezza delle sedute separate: quando il mediatore conduce colloqui riservati con ciascuna parte, l'avvocato deve chiarire preventivamente con il proprio cliente quali informazioni possano essere condivise con il mediatore in via riservata (cioè non trasmissibili alla controparte se non con autorizzazione esplicita) e quali informazioni siano invece destinate, fin dall'inizio, a essere condivise con l'altra parte per finalità negoziali. Un errore frequente nella prassi meno esperta consiste nel non distinguere adeguatamente questi due registri comunicativi, con il rischio di comunicazioni involontarie che possano pregiudicare la posizione negoziale del cliente.

3.12 Il verbale di mediazione e i suoi contenuti necessari

Il verbale conclusivo della mediazione, che l'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010 impone al mediatore di redigere sia in caso di accordo sia in caso di mancato accordo, costituisce un documento di cui l'avvocato negoziatore deve verificare attentamente il contenuto prima della sottoscrizione, poiché da esso discendono conseguenze giuridiche rilevanti: nel caso di mancato accordo per assenza della controparte, il verbale costituisce titolo per la successiva richiesta, in giudizio, delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 4-bis; nel caso di accordo, il verbale, con

l'accordo allegato, costituisce titolo esecutivo secondo le modalità previste dall'articolo 12. Un verbale imprecisamente redatto, che non attesti correttamente la partecipazione personale delle parti o l'assenza di una di esse, può generare contestazioni successive di rilievo processuale, che l'avvocato attento dovrebbe prevenire richiedendo, se necessario, la correzione del verbale prima della sua sottoscrizione definitiva.

Quando l'accordo prevede obbligazioni di dare o di fare a carico di una delle parti, l'avvocato negoziatore deve inoltre curare che il testo dell'accordo, ai fini della sua efficacia come titolo esecutivo, contenga con precisione l'indicazione della somma dovuta o della prestazione da eseguire, i termini di adempimento, e ogni altro elemento necessario a rendere l'accordo suscettibile di esecuzione forzata senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali: un accordo generico o ambiguo nella determinazione dell'oggetto dell'obbligazione rischia di vanificare, in sede di eventuale esecuzione, il vantaggio pratico che la mediazione avrebbe dovuto assicurare rispetto al procedimento giudiziale ordinario.

3.11 Le proposte del mediatore ex art. 11 e la loro gestione strategica

L'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010 attribuisce al mediatore, su richiesta concorde delle parti oppure, in alcuni casi previsti dalla legge, anche d'ufficio, il potere di formulare una proposta di conciliazione: l'avvocato negoziatore deve consigliare il cliente sull'opportunità di richiedere o accettare tale proposta, tenendo conto delle conseguenze previste dall'articolo 13 in tema di ripartizione delle spese processuali nel successivo giudizio, qualora la proposta non venga accettata e il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda, in tutto o in parte, al contenuto della proposta rifiutata. Questo meccanismo, di natura sostanzialmente premiale e sanzionatoria al tempo stesso, richiede una valutazione prognostica accurata da parte dell'avvocato circa il probabile esito del giudizio, una valutazione che si sovrappone, metodologicamente, a quella descritta a proposito del BATNA nel Capitolo 4.

Approfondimento

La negoziazione assistita in materia di famiglia: profili operativi

La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, disciplinata dall'articolo 6 del decreto legge 132/2014, presenta un procedimento peculiare rispetto alla negoziazione assistita ordinaria, poiché l'accordo raggiunto dalle parti con l'assistenza di almeno un avvocato per parte deve essere trasmesso, entro dieci giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che verifica la regolarità formale dell'accordo e, in caso di presenza di figli minori, minori non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, deve rilasciare il proprio nulla osta o, se ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, trasmetterlo al presidente del tribunale entro cinque giorni per la convocazione delle parti. Questo meccanismo di controllo pubblicistico, che non trova equivalente nella mediazione familiare ordinaria, riflette la particolare cautela del legislatore rispetto agli accordi di separazione e divorzio quando siano coinvolti interessi di soggetti minori o vulnerabili.

L'avvocato negoziatore che assiste le parti in una negoziazione assistita familiare deve quindi calibrare il contenuto dell'accordo tenendo conto non soltanto delle reciproche volontà dei coniugi, ma anche della prevedibile valutazione che il pubblico ministero opererà circa l'adeguatezza delle disposizioni relative ai figli, in termini di mantenimento, affidamento e modalità di frequentazione. Un accordo che appaia manifestamente iniquo verso l'interesse dei

minori, anche se sottoscritto da entrambi i genitori nella piena consapevolezza delle proprie scelte, rischia di essere bloccato nella fase di controllo pubblicitario, con conseguente vanificazione del lavoro negoziale svolto e necessità di rinegoziare i termini dell'accordo o di rivolgersi al tribunale in via ordinaria.

Il rapporto tra mediazione e procedimenti cautelari

Un profilo tecnico di rilievo riguarda il rapporto tra l'obbligo di esperire la mediazione come condizione di procedibilità e la possibilità di richiedere, medio tempore, provvedimenti cautelari o urgenti a tutela del diritto controverso: l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2010, come confermato dalla riforma Cartabia, chiarisce che lo svolgimento della mediazione non impedisce, nei casi urgenti, la richiesta di provvedimenti cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale quando necessaria per la conservazione dei diritti. L'avvocato negoziatore deve quindi sapere distinguere, nella valutazione strategica del caso concreto, le situazioni in cui l'urgenza cautelare consiglia un accesso diretto al giudice, senza attendere l'esito della mediazione, da quelle in cui il tentativo di composizione negoziale può utilmente precedere, senza pregiudizio per il cliente, l'eventuale ricorso alle vie giudiziarie.

La disciplina delle misure di protezione contro la violenza domestica e di genere, introdotta con la riforma del processo di famiglia (decreto legislativo 149/2022, articoli 473-bis.40 e seguenti del codice di procedura civile), esclude espressamente l'applicabilità della mediazione familiare quando siano in corso procedimenti relativi a condotte di violenza domestica o di genere, un'esclusione che risponde all'esigenza di non esporre la parte vittima di violenza a un confronto negoziale con l'autore delle condotte lesive, anche quando assistita da un legale, poiché lo squilibrio di potere tra le parti in tali situazioni è di regola incompatibile con le condizioni minime di libertà ed equilibrio negoziale che la mediazione presuppone.

Le clausole di mediazione nei contratti: validità ed effetti

L'inserimento, nei contratti tra privati o tra imprese, di clausole che prevedano il preventivo tentativo di mediazione prima dell'accesso alla giurisdizione ordinaria o all'arbitrato costituisce una prassi diffusa nella contrattualistica commerciale avanzata, che l'avvocato negoziatore dovrebbe promuovere attivamente in sede di redazione dei contratti che assiste. La giurisprudenza ha chiarito che tali clausole, quando validamente inserite nel contratto, producono un effetto di improcedibilità analogo a quello previsto dalla legge per le materie obbligatorie, sebbene di fonte contrattuale piuttosto che legale, e la loro violazione da parte di chi adisca direttamente il giudice senza il previo tentativo di mediazione può essere eccepita dalla controparte con conseguenze procedurali assimilabili a quelle previste per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex lege.

La redazione tecnica di una clausola di mediazione contrattuale richiede particolare attenzione per evitare ambiguità applicative: occorre indicare con precisione l'organismo di mediazione competente, o quantomeno i criteri per la sua individuazione, il termine entro il quale il tentativo di mediazione deve considerarsi esaurito prima di poter accedere alla fase giudiziale o arbitrale successiva, e l'eventuale articolazione multi-tiered della clausola con le fasi successive di negoziazione diretta, mediazione amministrata e infine arbitrato o giudizio, secondo il modello già richiamato nel Capitolo 9 in relazione alla contrattualistica internazionale.

Approfondimento procedurale ulteriore

La mediazione demandata dal giudice: presupposti e prassi applicativa

L'articolo 5-quater del decreto legislativo 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, attribuisce al giudice, anche in sede di appello, il potere di invitare le parti a procedere alla mediazione quando lo ritenga opportuno in relazione alla natura della causa, allo stato dell'istruzione e al comportamento delle parti, disponendo in tal caso il rinvio della causa a data successiva alla scadenza del termine, non superiore a tre mesi, fissato per lo svolgimento della procedura. Questo meccanismo di mediazione demandata, distinto dalla mediazione obbligatoria ex lege trattata nei paragrafi precedenti del presente capitolo, attribuisce al giudice un ruolo attivo di promozione della composizione negoziale anche in controversie non rientranti nell'elenco delle materie obbligatorie, ampliando significativamente l'ambito applicativo pratico della mediazione nel sistema processuale italiano.

La prassi applicativa della mediazione demandata, nei primi anni successivi alla riforma Cartabia, ha registrato un utilizzo non uniforme tra i diversi uffici giudiziari, con alcuni tribunali che ne fanno un impiego sistematico in determinate categorie di controversie (tipicamente quelle commerciali e societarie di valore medio, nelle quali la prosecuzione dei rapporti tra le parti può risultare economicamente rilevante) e altri che ne fanno un uso più episodico. L'avvocato negoziatore dovrebbe essere pronto a cogliere l'invito del giudice alla mediazione demandata come un'opportunità concreta di composizione, piuttosto che come un mero adempimento procedurale dilatorio, poiché l'esperienza applicativa dimostra che le mediazioni demandate dal giudice, quando condotte con reale disponibilità delle parti, presentano tassi di successo comparabili a quelli delle mediazioni volontarie o obbligatorie ex lege.

Il regime delle spese processuali e la mediazione

La riforma Cartabia ha rafforzato il collegamento tra il comportamento delle parti in sede di mediazione e la successiva liquidazione delle spese processuali nel giudizio: l'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il giudice, nella pronuncia sulle spese di lite, debba tenere conto del comportamento delle parti in sede di mediazione, potendo escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, o abbia rifiutato la proposta del mediatore successivamente rivelatasi corrispondente al contenuto della decisione giudiziale finale. L'avvocato negoziatore deve quindi consigliare il cliente tenendo pienamente conto di questo regime sanzionatorio indiretto, che rappresenta uno degli strumenti più efficaci di incentivazione della partecipazione effettiva e in buona fede alla mediazione.

La valutazione giudiziale del comportamento delle parti in mediazione, ai fini della successiva decisione sulle spese, richiede necessariamente che il verbale di mancato accordo, redatto dal mediatore secondo quanto già segnalato in questo capitolo, contenga elementi sufficienti a consentire al giudice tale valutazione, senza tuttavia violare il principio di riservatezza sul contenuto sostanziale delle trattative, un equilibrio delicato tra trasparenza procedimentale e riservatezza sostanziale che la prassi degli organismi di mediazione ha progressivamente affinato attraverso protocolli standardizzati di redazione del verbale.

Approfondimento procedimentale: clausole modello

Clausole di mediazione per contratti commerciali: modelli commentati

La redazione di clausole di mediazione all'interno di contratti commerciali richiede particolare attenzione alla precisione terminologica, per evitare le ambiguità interpretative che, secondo l'esperienza applicativa, costituiscono la principale fonte di contenzioso relativo alla validità e all'efficacia di tali clausole. Una clausola di mediazione tipo dovrebbe specificare, quantomeno: l'organismo di mediazione prescelto, individuato con precisione attraverso la denominazione registrata nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia; la sede territoriale di svolgimento della procedura, quando l'organismo prescelto disponga di più sedi; il termine entro il quale le parti si impegnano a completare il tentativo di mediazione prima di poter accedere alla tutela giurisdizionale o arbitrale; e l'eventuale devoluzione delle spese della procedura secondo un criterio di riparto predeterminato o rimesso alla decisione del mediatore.

Un esempio di clausola di mediazione commentata, elaborata secondo la prassi contrattualistica più diffusa negli accordi commerciali italiani, potrebbe essere formulata come segue: "Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, o comunque a esso relativa, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta a un tentativo di mediazione amministrata da [denominazione organismo], secondo il regolamento di procedura di tale organismo. La mediazione dovrà essere avviata da almeno una delle parti entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell'altra parte, e dovrà concludersi entro novanta giorni dall'avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora la mediazione non conduca a un accordo entro tale termine, ciascuna parte potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria competente [o, in alternativa, l'arbitrato secondo la clausola compromissoria di cui all'articolo successivo]." Questa formulazione, puramente esemplificativa, dovrebbe essere adattata dall'avvocato negoziatore alle specifiche esigenze del contratto e delle parti coinvolte, con particolare attenzione al coordinamento con le altre clausole di risoluzione delle controversie eventualmente presenti nel medesimo contratto.

Le clausole escalation: mediazione come fase intermedia

Le clausole cosiddette escalation, sempre più diffuse nella contrattualistica commerciale internazionale e progressivamente adottate anche nella prassi italiana, prevedono una sequenza graduata di meccanismi di risoluzione delle controversie, tipicamente articolata in tre fasi: un primo tentativo di negoziazione diretta tra i rappresentanti delle parti, senza l'intervento di terzi; un secondo tentativo di mediazione amministrata da un organismo terzo, qualora la negoziazione diretta non conduca a un accordo entro un termine predeterminato; e, infine, il ricorso all'arbitrato o alla giurisdizione ordinaria, qualora anche la mediazione non conduca a una composizione. Questa struttura graduata consente alle parti di tentare progressivamente meccanismi di composizione crescenti per formalità e costo, riservando il ricorso alla giurisdizione o all'arbitrato, tipicamente più costosi e meno flessibili, come extrema ratio.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente nella redazione di una clausola escalation deve prestare particolare attenzione alla precisione dei termini che scandiscono il passaggio da una fase all'altra della procedura, poiché l'imprecisione di tali termini costituisce una delle principali fonti di contenzioso relativo all'ammissibilità della successiva fase arbitrale o giudiziale, con orientamenti giurisprudenziali internazionali non sempre uniformi circa la

natura (di condizione di procedibilità sostanziale, ovvero di mero impegno programmatico non vincolante) delle clausole di escalation che non prevedano conseguenze processuali espresse per il loro mancato rispetto.

La mediazione valutativa: un modello complementare

Accanto al modello di mediazione facilitativa, prevalente nella tradizione italiana e in generale nella tradizione continentale europea, e caratterizzato dal ruolo del mediatore quale facilitatore della comunicazione tra le parti senza esprimere valutazioni sul merito della controversia, si è progressivamente diffuso, specialmente in ambito commerciale e in alcuni ordinamenti di common law, il modello di mediazione valutativa (evaluative mediation), nel quale il mediatore, dotato tipicamente di specifica competenza tecnico-giuridica nella materia oggetto della controversia, fornisce alle parti una valutazione, anche non vincolante, circa i probabili esiti di un eventuale giudizio, al fine di facilitare la valutazione comparativa tra la prosecuzione del contenzioso e l'accettazione di una proposta di composizione negoziale.

L'avvocato negoziatore dovrebbe essere consapevole delle differenze tra questi due modelli, poiché la scelta dell'organismo di mediazione, e talvolta la scelta stessa del singolo mediatore all'interno dell'organismo, può orientare la procedura verso l'uno o l'altro modello, con conseguenze significative sulla strategia negoziale da adottare: in una mediazione valutativa, la preparazione tecnico-giuridica della posizione del cliente assume un peso probabilmente maggiore rispetto a una mediazione puramente facilitativa, nella quale prevalgono le tecniche relazionali e comunicative già illustrate nel presente volume.

Approfondimento ulteriore sul procedimento

La gestione del primo incontro informativo: checklist operativa

Il primo incontro della procedura di mediazione, disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 e caratterizzato dalla funzione specifica di verificare la disponibilità delle parti a procedere oltre la fase meramente informativa, richiede all'avvocato negoziatore una preparazione specifica che può essere utilmente strutturata secondo una checklist operativa comprendente, quantomeno: la verifica della completezza della domanda di mediazione depositata, con particolare attenzione alla corretta individuazione di tutte le parti necessarie al procedimento; la preparazione di una sintesi scritta della posizione del cliente da sottoporre al mediatore, utile specialmente quando il primo incontro si svolga in una sessione compressa nel tempo; la verifica dei poteri di rappresentanza sostanziale del cliente o del suo delegato, secondo quanto già illustrato nel presente capitolo; e la preparazione psicologica del cliente rispetto alle possibili modalità di svolgimento dell'incontro, incluse le sessioni separate (caucus) che il mediatore potrebbe richiedere.

La decisione relativa alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro informativo, che compete alle parti previa consultazione con i propri avvocati, dovrebbe essere assunta sulla base di una valutazione informata dei costi e dei benefici della prosecuzione, tenendo conto in particolare del regime di incentivi e disincentivi processuali connessi alla mancata prosecuzione della mediazione senza giustificato motivo, già illustrato nel presente volume in relazione al regime delle spese processuali introdotto dalla riforma Cartabia. L'avvocato negoziatore dovrebbe evitare di consigliare una interruzione della mediazione al primo incontro per mere ragioni tattiche dilatorie, un comportamento che, oltre a esporre il cliente al

rischio di conseguenze sfavorevoli sul piano delle spese processuali, contrasta con lo spirito collaborativo che la funzione di avvocato negoziatore, secondo l'impostazione complessiva del presente volume, richiede di promuovere.

Le tecniche di apertura della sessione congiunta di mediazione

La sessione congiunta di mediazione, nella quale le parti e i rispettivi avvocati si confrontano direttamente in presenza del mediatore, richiede una gestione attenta della fase di apertura, poiché le prime impressioni e le prime dichiarazioni scambiate tendono a condizionare significativamente il clima relazionale dell'intera procedura successiva. L'avvocato negoziatore dovrebbe orientare il proprio cliente verso una dichiarazione di apertura che, senza rinunciare alla difesa della propria posizione giuridica, eviti un tono eccessivamente aggressivo o accusatorio verso la controparte, un'accortezza che, secondo l'esperienza dei mediatori più qualificati, incide significativamente sulla probabilità di successo complessivo della procedura.

La preparazione della dichiarazione di apertura del cliente, che l'avvocato negoziatore dovrebbe curare congiuntamente con il cliente prima dell'incontro, dovrebbe includere tipicamente: un breve riepilogo dei fatti dal punto di vista del cliente, formulato in termini quanto più possibile oggettivi e verificabili; l'esposizione degli interessi sostanziali del cliente, distinti dalla mera posizione giuridica rivendicata; e una espressione, quando genuina, della disponibilità del cliente a esplorare soluzioni di reciproco vantaggio, un elemento che contribuisce a instaurare un clima di collaborazione reciproca fin dalle prime fasi della procedura.

Approfondimento procedurale: la mediazione demandata e il ruolo attivo del giudice

Le prassi virtuose di alcuni tribunali italiani

Alcuni tribunali italiani hanno sviluppato, negli anni successivi all'introduzione della mediazione demandata dalla riforma Cartabia, prassi organizzative particolarmente virtuose per la promozione efficace di questo strumento, tra le quali meritano menzione l'istituzione di apposite sezioni specializzate o di gruppi di magistrati specificamente formati alla valutazione dell'opportunità della mediazione demandata in relazione alla tipologia di controversia, e la predisposizione di protocolli operativi condivisi con gli organismi di mediazione del territorio per facilitare il passaggio della causa dal procedimento giudiziale al tentativo di mediazione, riducendo i tempi morti e le difficoltà organizzative che altrimenti potrebbero scoraggiare le parti dall'effettivo utilizzo dello strumento.

L'esperienza di questi tribunali, oggetto di analisi da parte di diversi osservatori specialistici e associazioni forensi, suggerisce che il successo della mediazione demandata dipende in misura significativa dalla qualità dell'interazione istituzionale tra magistratura e organismi di mediazione del territorio, un fattore organizzativo che l'avvocato negoziatore dovrebbe conoscere per meglio orientare le proprie aspettative e la propria strategia processuale nei diversi uffici giudiziari nei quali si trovi a operare, poiché l'efficacia pratica della mediazione demandata presenta, secondo l'esperienza finora registrata, significative variazioni territoriali.

Il monitoraggio statistico della mediazione demandata

Il Ministero della Giustizia ha progressivamente affinato, attraverso la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, gli strumenti di monitoraggio statistico relativi all'utilizzo della mediazione demandata dal giudice, distinguendo tale fattispecie dalla mediazione

obbligatoria ex lege e dalla mediazione volontaria nelle proprie rilevazioni periodiche, un affinamento statistico che consente un'analisi più precisa dell'effettiva incidenza di questo strumento sul complessivo sistema della mediazione civile e commerciale italiana. I dati finora disponibili confermano una crescita progressiva, sebbene ancora contenuta in termini assoluti, del numero di procedimenti di mediazione demandata, con tassi di adesione delle parti all'invito del giudice e tassi di successo della procedura non significativamente dissimili da quelli registrati per la mediazione obbligatoria ex lege.

L'avvocato negoziatore, nel consigliare il cliente circa l'opportunità di accogliere un invito del giudice alla mediazione demandata, può utilmente fare riferimento a questi dati statistici aggregati, quando disponibili e pertinenti alla tipologia di controversia in questione, per offrire al cliente una valutazione informata e non meramente intuitiva delle prospettive di successo dello strumento, in linea con l'approccio basato sull'evidenza empirica che il presente volume ha costantemente raccomandato nell'esercizio della funzione di avvocato negoziatore.

Approfondimento: la mediazione online e le piattaforme digitali

L'evoluzione delle piattaforme di online dispute resolution in Italia

Gli organismi di mediazione italiani hanno progressivamente adottato piattaforme digitali sempre più sofisticate per la gestione delle procedure, un'evoluzione accelerata significativamente dall'emergenza sanitaria del 2020-2021, che ha reso necessario il ricorso sistematico alla mediazione telematica per garantire la continuità del servizio anche in un contesto di limitazioni agli spostamenti fisici delle persone. Le piattaforme attualmente in uso presso i principali organismi di mediazione italiani offrono tipicamente funzionalità di videoconferenza integrata, gestione documentale sicura, firma digitale degli accordi, e archiviazione protetta della documentazione procedimentale, un'infrastruttura tecnologica che ha reso la mediazione telematica un'opzione stabilmente disponibile e non più meramente emergenziale nella prassi ordinaria degli organismi italiani.

L'articolo 8-bis del decreto legislativo 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, ha definitivamente consolidato il quadro normativo della mediazione telematica, riconoscendo piena equivalenza procedimentale tra la mediazione svolta in presenza e quella svolta con modalità telematiche, salva la facoltà delle parti di richiedere lo svolgimento in presenza quando lo ritengano preferibile per le specificità della controversia. L'avvocato negoziatore dovrebbe valutare, caso per caso, se la modalità telematica sia effettivamente adeguata alla controversia specifica, considerando che, secondo l'esperienza pratica finora maturata, alcune tipologie di controversie (specialmente quelle caratterizzate da forte conflittualità emotiva tra le parti) possono beneficiare maggiormente di un incontro in presenza, che facilita una comunicazione non verbale più ricca e un maggiore coinvolgimento emotivo positivo delle parti nel processo di composizione.

I profili di accessibilità digitale della mediazione telematica

L'accessibilità digitale della mediazione telematica per le persone con disabilità, e più in generale per le fasce di popolazione con minore alfabetizzazione digitale, costituisce un profilo di crescente attenzione per gli organismi di mediazione, chiamati a garantire, in coerenza con i principi generali di accessibilità previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia (tra cui la direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli

enti pubblici, applicabile per analogia anche a determinati servizi digitali di rilevanza pubblica), che le proprie piattaforme digitali siano effettivamente accessibili a tutte le categorie di utenti, anche attraverso l'adozione di tecnologie assistive compatibili e di interfacce semplificate per gli utenti meno esperti nell'uso degli strumenti digitali.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente con difficoltà di accesso agli strumenti digitali, per ragioni di età, di disabilità, o di mera scarsa familiarità con la tecnologia, dovrebbe verificare preventivamente con l'organismo di mediazione la disponibilità di soluzioni alternative o di supporto tecnico adeguato, per garantire che il cliente possa partecipare effettivamente e proficuamente alla procedura, senza che le difficoltà tecnologiche si traducano in un ostacolo sostanziale all'esercizio dei suoi diritti procedurali.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di modesto valore economico

Il rapporto tra mediazione e procedimento per le controversie di modesta entità

Il procedimento semplificato di cognizione, disciplinato dagli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile dopo la riforma Cartabia, e il preesistente procedimento dinanzi al giudice di pace per le controversie di valore non superiore a cinquemila euro, si intersecano con la disciplina della mediazione obbligatoria in modo peculiare, poiché le materie elencate dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 sono soggette a condizione di procedibilità indipendentemente dal valore economico della controversia, con la conseguenza che anche le controversie di modesto valore economico rientranti in tali materie richiedono il previo esperimento del tentativo di mediazione, un onere procedurale che, per controversie di valore particolarmente contenuto, può risultare economicamente sproporzionato rispetto al valore stesso della controversia, nonostante le riduzioni tariffarie previste dal decreto ministeriale sulle indennità di mediazione per gli scaglioni di valore più bassi.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente in una controversia di modesto valore economico rientrante nelle materie soggette a condizione di procedibilità dovrebbe valutare con particolare attenzione il rapporto tra i costi complessivi della procedura di mediazione (indennità dell'organismo, compenso del proprio difensore per l'assistenza nella procedura) e il valore economico della controversia, orientando il cliente, quando possibile secondo le circostanze del caso concreto, verso organismi di mediazione che offrano tariffe particolarmente contenute per le controversie di modesto valore, secondo quanto consentito dalla flessibilità tariffaria che la normativa riconosce agli organismi di mediazione entro i limiti massimi fissati dal decreto ministeriale.

Le procedure di mediazione semplificata per controversie di modesto valore

Alcuni organismi di mediazione hanno sviluppato procedure semplificate specificamente concepite per le controversie di modesto valore economico, caratterizzate da termini procedurali abbreviati, da una gestione prevalentemente documentale della procedura con limitazione delle sessioni di incontro in presenza o telematiche, e da tariffe particolarmente contenute, un modello procedurale che risponde all'esigenza di garantire l'effettiva accessibilità economica della mediazione anche per le controversie di minore rilevanza economica, nelle quali un procedimento eccessivamente oneroso in termini di costi e di tempo risulterebbe manifestamente sproporzionato rispetto al valore della controversia.

L'avvocato negoziatore dovrebbe informarsi circa la disponibilità di procedure semplificate di questo tipo presso gli organismi di mediazione del proprio territorio, e orientare la scelta dell'organismo, per le controversie di modesto valore economico assistite, anche in considerazione della disponibilità di tali procedure semplificate, che possono contribuire significativamente a preservare l'effettiva economicità della composizione negoziale della controversia per il proprio cliente.

Approfondimento: la mediazione demandata in appello e la sua specificità

Le peculiarità della mediazione demandata nel giudizio di secondo grado

La mediazione demandata dal giudice nel giudizio di appello presenta caratteristiche peculiari rispetto alla medesima fattispecie nel giudizio di primo grado, in ragione della più avanzata fase processuale nella quale interviene: le parti dispongono, al momento dell'invito del giudice d'appello alla mediazione, di una sentenza di primo grado che ha già definito, sebbene non definitivamente, l'esito della controversia, un elemento informativo che influenza significativamente la dinamica negoziale successiva, poiché ciascuna parte può valutare la propria posizione negoziale anche alla luce dell'esito già raggiunto in primo grado. L'avvocato negoziatore che assista una parte vittoriosa in primo grado, invitata dal giudice d'appello a un tentativo di mediazione, dovrebbe valutare con particolare attenzione l'opportunità di questo invito, considerando che la propria posizione negoziale risulta oggettivamente rafforzata dalla sentenza favorevole già ottenuta, sebbene permanga l'incertezza relativa all'esito dell'appello stesso.

Analogamente, l'avvocato negoziatore che assista una parte parzialmente o totalmente sconfitta in primo grado dovrebbe considerare la mediazione demandata in appello come un'opportunità potenzialmente vantaggiosa per limitare il rischio di una conferma della sentenza sfavorevole, specialmente quando una valutazione realistica delle prospettive di successo dell'appello, condotta secondo le tecniche di analisi del BATNA e del WATNA già ampiamente illustrate nel presente volume, non risulti particolarmente favorevole, un'analisi che l'avvocato negoziatore dovrebbe condividere con obiettività e trasparenza con il proprio cliente, evitando facili ottimismo non supportati da una solida valutazione tecnico-giuridica delle effettive prospettive del giudizio di appello.

Il coordinamento tra mediazione demandata e sospensione dell'esecutività della sentenza

Il rapporto tra l'eventuale mediazione demandata in appello e la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, disciplinata dall'articolo 283 del codice di procedura civile, pone questioni di coordinamento procedurale che l'avvocato negoziatore deve attentamente considerare: la pendenza del tentativo di mediazione non determina automaticamente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con la conseguenza che la parte vittoriosa in primo grado potrebbe, in linea di principio, procedere all'esecuzione della sentenza parallelamente al tentativo di mediazione in corso, salvo che il giudice d'appello abbia specificamente disposto la sospensione dell'esecutività secondo i presupposti previsti dalla norma citata. L'avvocato negoziatore che assista la parte parzialmente sconfitta in primo grado dovrebbe quindi valutare l'opportunità di richiedere la sospensione dell'esecutività, quando sussistano i presupposti di gravità e fondatezza dei motivi di appello richiesti dalla norma, indipendentemente dalla pendenza del parallelo tentativo di mediazione demandata.

Questo coordinamento procedurale, che richiede all'avvocato negoziatore una gestione simultanea di diversi fronti processuali (l'istanza di sospensione dell'esecutività, la partecipazione al tentativo di mediazione demandata, e la preparazione della difesa nel merito del giudizio di appello in caso di mancato accordo), illustra concretamente la complessità tecnico-procedurale che caratterizza la pratica contemporanea dell'avvocato negoziatore, ben lontana da una mera competenza relazionale o comunicativa disgiunta da una solida padronanza degli aspetti processuali tecnici della controversia.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie ereditarie complesse

Le peculiarità procedurali della mediazione successoria

Le controversie in materia successoria, incluse tra le materie soggette a condizione di procedibilità mediativa dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, presentano peculiarità procedurali specifiche connesse alla necessaria partecipazione di tutti i coeredi alla procedura, quando la controversia riguarda la divisione dell'eredità nel suo complesso piuttosto che una questione bilaterale tra singoli coeredi: l'avvocato negoziatore che assista un coerede in una controversia successoria complessa, che coinvolga una pluralità di soggetti con interessi non sempre coincidenti, deve verificare attentamente la completezza soggettiva della procedura di mediazione, poiché un accordo divisorio che non coinvolga tutti i coeredi interessati risulterebbe inefficace rispetto alla piena definizione della comunione ereditaria.

La complessità relazionale delle controversie successorie, che frequentemente coinvolgono dinamiche familiari risalenti nel tempo e non limitate alla mera questione patrimoniale oggetto formale della controversia, rende la mediazione uno strumento particolarmente indicato per questa tipologia di controversie, specialmente quando l'obiettivo delle parti comprenda, oltre alla definizione patrimoniale della divisione ereditaria, anche la preservazione, nella misura del possibile, dei rapporti familiari futuri tra i coeredi, un obiettivo che un giudizio contenzioso, focalizzato sulla mera decisione giuridica della controversia, raramente riesce a conseguire con la medesima efficacia della composizione negoziale mediata.

Il ruolo del consulente patrimoniale nella mediazione successoria

La presenza di beni di difficile divisione materiale, quali immobili non facilmente frazionabili o partecipazioni societarie di controllo familiare, richiede frequentemente, nella mediazione successoria, l'apporto di un consulente patrimoniale esterno per la valutazione tecnica dei beni oggetto della divisione e per l'elaborazione di soluzioni divisorie tecnicamente sostenibili, quali l'assegnazione di beni con conguaglio in denaro tra i coeredi, la costituzione di una comunione volontaria continuata su determinati beni, o la vendita concordata di beni non altrimenti divisibili con successiva ripartizione del ricavato. L'avvocato negoziatore che assista un coerede in una mediazione successoria complessa dovrebbe considerare l'opportunità di questo apporto consulenziale esterno, coordinandone l'intervento con il mediatore e con gli altri coeredi secondo modalità concordate, per garantire che le soluzioni divisorie proposte siano tecnicamente solide oltre che negozialmente accettabili per tutte le parti coinvolte.

Approfondimento: la gestione delle mediazioni con parti non parenti

Le conseguenze processuali della mancata comparizione senza giustificato motivo

L'articolo 12-bis del decreto legislativo 28/2010 attribuisce al giudice del successivo giudizio la facoltà di desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo di una parte al procedimento di mediazione, e di condannare la parte non comparente al versamento in favore dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, una duplice conseguenza sanzionatoria che l'avvocato negoziatore deve attentamente spiegare al proprio cliente quando questi manifesti l'intenzione di non partecipare alla procedura di mediazione, poiché la scelta di non comparire, se non adeguatamente giustificata, può produrre conseguenze pregiudizievoli sia sotto il profilo probatorio nel successivo giudizio sia sotto il profilo economico.

La valutazione di ciò che costituisca un giustificato motivo per la mancata comparizione, questione lasciata alla valutazione discrezionale del giudice del merito, ha trovato nella prassi giurisprudenziale diverse esemplificazioni: l'impossibilità sopravvenuta di comparire per grave motivo di salute documentato, l'inesistenza di un effettivo interesse alla mediazione per l'evidente estraneità della materia controversa rispetto alla previsione normativa di obbligatorietà, o la manifesta e documentata indisponibilità della controparte a qualsivoglia soluzione negoziale, quest'ultima ipotesi tuttavia da valutare con cautela poiché, come già osservato nel presente volume, anche una posizione inizialmente rigida della controparte può evolvere nel corso della sessione di mediazione, con la conseguenza che la mera previsione di un atteggiamento non collaborativo della controparte non costituisce, di regola, un giustificato motivo sufficiente per esonerare dalla comparizione personale.

La strategia dell'avvocato negoziatore in presenza di una controparte non comparente

Quando sia la controparte a non comparire alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, l'avvocato negoziatore che assista la parte comparente dovrebbe adottare specifiche cautele documentali per preservare la possibilità di far valere, nel successivo giudizio, le conseguenze sfavorevoli previste dall'articolo 8, comma 4-bis: la richiesta al mediatore di verbalizzare puntualmente l'assenza della controparte e l'assenza di un giustificato motivo addotto, e la conservazione di ogni documentazione relativa ai tentativi di convocazione della controparte, per poter successivamente dimostrare, nel giudizio di merito, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

Approfondimento: la mediazione telematica e le garanzie di autenticità digitale

L'identificazione delle parti nella sessione di mediazione telematica

La conduzione della sessione di mediazione attraverso strumenti di collegamento audiovisivo a distanza, ampiamente consolidata a seguito dell'emergenza pandemica e definitivamente disciplinata dalla riforma Cartabia attraverso le modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 28/2010, richiede l'adozione di specifiche garanzie di identificazione delle parti partecipanti, per assicurare che i soggetti che compaiono attraverso lo strumento telematico siano effettivamente le parti autorizzate a partecipare alla procedura, secondo modalità che i singoli organismi di mediazione hanno progressivamente affinato attraverso l'adozione di protocolli tecnici specifici, quali la richiesta di esibizione di un documento di identità attraverso la videocamera all'inizio della sessione, o l'utilizzo di sistemi di identità digitale quali lo SPID o la Carta d'Identità Elettronica per l'accesso alla piattaforma telematica dell'organismo.

L'avvocato negoziatore che assista una parte in una procedura di mediazione telematica dovrebbe verificare preventivamente le modalità di identificazione richieste dall'organismo di mediazione prescelto, informando adeguatamente il proprio cliente circa la documentazione da predisporre per la sessione telematica, un adempimento preliminare che, sebbene apparentemente marginale, risulta essenziale per la validità procedurale della mediazione e per l'efficacia probatoria del successivo verbale di conciliazione eventualmente sottoscritto in forma digitale.

La sottoscrizione digitale del verbale di conciliazione

La sottoscrizione del verbale di conciliazione all'esito di una procedura di mediazione condotta integralmente in modalità telematica pone questioni specifiche relative alla validità della sottoscrizione digitale apposta dalle parti e dal mediatore, questioni che la riforma Cartabia ha risolto attraverso l'espresso riconoscimento della validità della firma digitale e della firma elettronica qualificata per la sottoscrizione degli atti della procedura di mediazione, incluso il verbale conclusivo, secondo i principi generali del Codice dell'amministrazione digitale in materia di equivalenza tra sottoscrizione autografa e sottoscrizione digitale qualificata. L'avvocato negoziatore dovrebbe verificare, prima della sottoscrizione digitale del verbale di conciliazione, che la piattaforma tecnologica utilizzata dall'organismo di mediazione garantisca l'apposizione di una firma digitale conforme ai requisiti tecnici previsti dalla normativa applicabile, per assicurare la piena validità ed efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto secondo le modalità già illustrate nel presente volume.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di consumo collettivo

Il rapporto tra mediazione collettiva e azione di classe

L'azione di classe disciplinata dagli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile, introdotta dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, come strumento di tutela collettiva dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti, presenta un rapporto peculiare con la mediazione civile e commerciale ordinaria, poiché la natura collettiva della pretesa fatta valere attraverso l'azione di classe rende problematica l'applicazione delle ordinarie regole della mediazione bilaterale, pur non escludendo in assoluto la possibilità di una composizione negoziale della controversia collettiva, che il codice di procedura civile disciplina attraverso un proprio specifico meccanismo di conciliazione previsto dall'articolo 840-quater, distinto dalla mediazione civile generale ma ispirato a principi in parte analoghi di composizione volontaria della controversia.

L'avvocato negoziatore che assista un'impresa convenuta in un'azione di classe dovrebbe considerare attentamente l'opportunità di proporre una soluzione conciliativa attraverso il meccanismo specifico previsto dall'articolo 840-quater del codice di procedura civile, che consente all'impresa di formulare una proposta di accordo destinata alla generalità dei membri della classe che abbiano aderito all'azione, una soluzione che, se accettata dal giudice e dai membri della classe secondo le modalità procedurali previste dalla norma, produce effetti vincolanti per l'intera classe che abbia validamente aderito alla proposta, con vantaggi significativi in termini di certezza e di definitività della composizione raggiunta rispetto alla prosecuzione di un giudizio collettivo dall'esito incerto.

Approfondimento: la mediazione demandata nelle controversie di modesta entità economica

Il rapporto tra mediazione demandata e procedimento davanti al giudice di pace

Le controversie di modesta entità economica, rientranti nella competenza del giudice di pace secondo i valori di competenza previsti dall'articolo 7 del codice di procedura civile, presentano specifiche peculiarità applicative con riferimento all'eventuale invito del giudice alla mediazione demandata, poiché la stessa modesta entità economica della controversia, che tipicamente contiene i costi processuali complessivi anche in caso di prosecuzione del giudizio ordinario, richiede all'avvocato negoziatore una valutazione particolarmente attenta del rapporto tra i costi aggiuntivi dell'eventuale procedura di mediazione (indennità dell'organismo e compenso professionale per l'assistenza) e il valore economico della controversia stessa, per evitare che i costi della composizione negoziale risultino sproporzionati rispetto al valore economico in gioco.

Le tabelle delle indennità di mediazione previste dal decreto ministeriale 150/2023, che prevedono importi proporzionalmente ridotti per le controversie di minor valore economico secondo la struttura a scaglioni già illustrata nel Capitolo 8 del presente volume, contribuiscono a mitigare, sebbene non ad eliminare integralmente, questo rischio di sproporzione tra costi della procedura e valore della controversia, un fattore che l'avvocato negoziatore dovrebbe comunque sempre considerare nella propria valutazione strategica complessiva, specialmente per le controversie di valore particolarmente contenuto rientranti nella competenza del giudice di pace.

Le prospettive di riforma del processo davanti al giudice di pace e la mediazione

Il dibattito dottrinale e istituzionale relativo a possibili riforme del procedimento davanti al giudice di pace, orientate verso una maggiore semplificazione e celerità del relativo procedimento in ragione della modesta entità economica delle controversie tipicamente ad esso sottoposte, ha talvolta prospettato un rafforzamento del ruolo della mediazione quale strumento preferenziale di composizione delle controversie di minor valore economico, in un'ottica di ulteriore deflazione del contenzioso anche per questa specifica categoria di controversie, un possibile sviluppo normativo futuro che l'avvocato negoziatore dovrebbe monitorare con attenzione, secondo il generale dovere di aggiornamento professionale continuo già più volte richiamato nel presente volume.

Approfondimento: la gestione dei documenti riservati scambiati in mediazione

Il regime di inutilizzabilità processuale della documentazione formata in mediazione

L'articolo 10 del decreto legislativo 28/2010 sancisce l'inutilizzabilità, nel successivo giudizio, delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, un principio che si estende anche alla documentazione specificamente formata per le finalità della procedura di mediazione, quali le memorie riservate eventualmente predisposte dalle parti per il mediatore, i documenti tecnici prodotti nel corso della procedura, e le eventuali proposte transattive scambiate tra le parti nel tentativo di raggiungere un accordo, un regime di riservatezza e di inutilizzabilità processuale che l'avvocato negoziatore deve conoscere con precisione per orientare correttamente il proprio cliente circa quali informazioni e documenti

sia opportuno condividere nel corso della procedura di mediazione, beneficiando della garanzia di riservatezza processuale che tale condivisione comporta.

La distinzione tra documenti formati specificamente per le finalità della procedura di mediazione, soggetti al regime di inutilizzabilità processuale sopra illustrato, e documenti preesistenti alla procedura stessa, che mantengono la propria autonoma rilevanza probatoria nel successivo giudizio indipendentemente dalla loro eventuale produzione anche in sede di mediazione, costituisce un profilo interpretativo di particolare rilevanza pratica che l'avvocato negoziatore deve saper gestire con precisione tecnica, evitando che la mera produzione di un documento preesistente in sede di mediazione possa erroneamente essere invocata dalla controparte come causa di inutilizzabilità processuale di tale documento anche nel successivo giudizio di merito.

Casi pratici commentati e giurisprudenza verificata

Caso 1: Cass., SS.UU., sent. 18 settembre 2020, n. 19596 — l'onere di attivare la mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto

Fatti di causa. Una società di somministrazione di energia otteneva dal tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture rimaste insolute nei confronti di un'impresa cliente. L'ingiunta proponeva opposizione, contestando la quantificazione dei consumi e deducendo vizi contrattuali nella determinazione delle tariffe applicate. La controversia rientrava tra quelle per le quali la legge impone, a pena di improcedibilità, il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, secondo l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo allora vigente. Aperto il giudizio di opposizione e decise le istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, nessuna delle parti attivava il procedimento di mediazione entro il termine assegnato dal giudice. Il tribunale dichiarava l'improcedibilità e, ritenendo che l'onere gravasse sull'opponente, revocava il decreto ingiuntivo con conseguente rigetto della pretesa creditoria. La questione, sulla quale si era formato un contrasto profondo tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, veniva rimessa alle Sezioni Unite.

Il punto controverso era di ordine strutturale. In un precedente del 2015 la Terza Sezione aveva affermato che l'onere di introdurre la mediazione ricadesse sull'opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del giudizio di merito. Numerose corti di merito avevano invece obiettato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore, il quale ha già azionato la propria pretesa con il ricorso monitorio, mentre l'opponente riveste soltanto formalmente la veste di attore in senso processuale. Addossare a quest'ultimo l'onere della mediazione avrebbe significato, in caso di sua inerzia, consolidare un titolo esecutivo la cui fondatezza non era stata ancora vagliata nel contraddittorio pieno.

Posizione delle parti e strategia difensiva. Il difensore della società creditrice sosteneva la tesi a sé più favorevole: essendo l'opponente l'unico soggetto interessato a rimuovere il decreto, spettava a lui coltivare la condizione di procedibilità, con la conseguenza che la sua inerzia doveva tradursi nella definitiva stabilità del decreto ingiuntivo. Il difensore dell'impresa opponente ribatteva che il vero titolare della pretesa, e quindi della domanda soggetta a mediazione, restava il creditore, sicché la mancata attivazione della procedura da parte di quest'ultimo doveva condurre all'improcedibilità della sua domanda e alla revoca del decreto.

La strategia dell'opponente era dunque interamente costruita sul rovesciamento dell'onere: non contestare frontalmente il merito del credito, ma eccepire e far valere l'inerzia procedurale del creditore.

Perché non è transitata per una mediazione utile. Nella vicenda la mediazione non fu concretamente esperita da alcuna delle parti, ciascuna confidando che l'onere gravasse sull'altra. Proprio questa reciproca inerzia, figlia dell'incertezza interpretativa, spinse la controversia fino al vertice di legittimità. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, ossia sul creditore. Ne discende che, in caso di sua inerzia, la pronuncia di improcedibilità comporta la revoca del decreto ingiuntivo. La Corte ha valorizzato la sostanza dei ruoli: il creditore è l'attore in senso sostanziale, colui che ha per primo esercitato l'azione, e su di lui deve perciò ricadere l'onere di dare corso al tentativo conciliativo che la legge antepone al giudizio.

Nella mia esperienza professionale questa pronuncia ha modificato in radice l'impostazione delle difese nell'opposizione monitoria. Il creditore opposto, che prima poteva restare inerte sperando nella decadenza dell'avversario, si trova ora onerato di un adempimento la cui omissione travolge il titolo faticosamente ottenuto. Per l'opponente, per converso, si apre una linea difensiva sobria ed efficace, giocata sul piano della procedibilità prima ancora che del merito.

Massima per l'avvocato negoziatore. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della mediazione segue la sostanza e non la forma processuale: incombe sul creditore opposto. Chi assiste l'ingiunto verifichi tempestivamente l'inerzia della controparte e la eccepisca, perché quella inerzia può bastare a far cadere il decreto. Chi assiste il creditore metta in calendario l'attivazione della mediazione subito dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, senza attendere iniziative altrui, pena la revoca del titolo.

Fonte: Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 (testo e commento in Altalex (<https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/19/mediazione-obbligatoria-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-onere-grava-su-creditore>); scheda in EIUS (<https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/502>)).

Caso 2: Cass. civ., sez. II, sent. 14 dicembre 2021, n. 40035 — mediazione demandata dal giudice e natura non perentoria del termine di quindici giorni

Fatti di causa. In un giudizio civile pendente in primo grado, avente ad oggetto una controversia rientrante nel novero delle materie a mediazione obbligatoria, il giudice istruttore, valutata la mediabilità della lite, disponeva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che le parti esperissero il procedimento di mediazione, assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda e rinviando la causa a un'udienza successiva. La parte onerata depositava l'istanza di mediazione oltre quel termine di quindici giorni, ma comunque prima dell'udienza fissata; il primo incontro davanti al mediatore si teneva regolarmente e si concludeva senza accordo. La controparte eccepiva l'improcedibilità della domanda, sostenendo che il deposito tardivo dell'istanza rispetto al termine di quindici giorni avesse determinato il mancato avveramento della condizione di procedibilità. Le corti di

merito disattendevano l'eccezione e la questione perveniva in Cassazione, dove si controverteva sulla natura, perentoria oppure ordinatoria, del termine fissato dal giudice per l'introduzione della mediazione demandata.

Posizione delle parti e strategia difensiva. La parte che eccepiva l'improcedibilità impostava la propria difesa su una lettura rigorosa e formale del termine: quindici giorni fissati dal giudice, superati i quali la condizione di procedibilità non poteva ritenersi avverata, con conseguente definizione in rito della causa a proprio vantaggio. Era una strategia difensiva di tipo ostativo, volta a chiudere il processo su un vizio procedurale a prescindere dal merito e dal fatto che la mediazione fosse stata poi effettivamente celebrata. La parte onerata, all'opposto, valorizzava la ratio dell'istituto: la mediazione demandata mira a offrire alle parti una reale occasione conciliativa prima della decisione, sicché ciò che conta è che il tentativo sia stato utilmente esperito entro l'udienza di rinvio, non il rispetto rigoroso di un termine intermedio che la legge non qualifica come perentorio.

La decisione e la sua rilevanza operativa. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità nella mediazione disposta dal giudice, ciò che rileva è l'utile esperimento del procedimento entro l'udienza fissata, da intendersi come effettivo svolgimento del primo incontro delle parti davanti al mediatore, e non l'introduzione della mediazione entro i quindici giorni indicati dal giudice. Il termine di quindici giorni non ha natura perentoria: per il principio sancito dall'articolo 152, secondo comma, del codice di procedura civile, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che essa espressamente li dichiari perentori, e l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010 non contiene tale qualificazione né ricollega l'improcedibilità della domanda al mancato rispetto di quel termine intermedio. Ne consegue che il deposito dell'istanza oltre i quindici giorni, ma in tempo utile perché il procedimento si svolga prima dell'udienza di rinvio, non pregiudica la procedibilità.

Il rilievo pratico è di grande peso. La pronuncia sterilizza un'eccezione puramente formale che, se accolta, avrebbe potuto vanificare un tentativo conciliativo comunque celebrato, con spreco di attività processuale e con esiti in rito distanti dalla giustizia sostanziale. Nella mia esperienza professionale il difensore accorto trae da questa decisione una duplice indicazione: da un lato non deve costruire strategie difensive sulla decadenza da un termine che decadenza non produce, dall'altro non deve neppure adagiarsi, perché il vero limite invalicabile resta l'udienza di rinvio, entro la quale il primo incontro deve essersi effettivamente tenuto.

Perché la mediazione, in casi simili, spesso si celebra ma non concilia. L'esperienza mostra che, quando la mediazione è imposta dal giudice a lite già radicata e con posizioni cristallizzate negli atti, il primo incontro tende a risolversi in un adempimento formale, celebrato per non incorrere nell'improcedibilità più che per trovare un accordo. Il difensore che voglia dare un senso a quell'incontro deve prepararlo come una sessione negoziale vera, portando al tavolo una proposta articolata e non la mera comparizione. Diversamente, la mediazione demandata rischia di ridursi a una tappa burocratica, esattamente ciò che il legislatore intendeva evitare.

Massima per l'avvocato negoziatore. Nella mediazione demandata dal giudice il termine di quindici giorni è ordinatorio: la condizione di procedibilità si avvera con l'effettivo svolgimento del primo incontro entro l'udienza di rinvio. Non fondare la difesa sulla tardività dell'istanza rispetto a quel termine, perché è eccezione destinata a cadere; ma non confondere la non

perentorietà con l'irrelevanza, perché l'udienza di rinvio segna il confine oltre il quale l'omissione diventa fatale.

Fonte: Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035 (testo e commento in Altalex (<https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/28/mediazione-su-ordine-del-giudice-il-termini-di-15-giorni-non-e-perentorio>); scheda in EIUS (<https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/719>)).

Caso 3: Cass., SS.UU., sent. 7 aprile 2014, n. 8057 (e Cass., SS.UU., sent. 20 luglio 2022, n. 22729) — conflitto di interessi e dovere di astensione dell'avvocato che ha assistito entrambi i coniugi

Premessa sulla scelta del caso. Trattandosi qui di illustrare il conflitto di interessi del difensore che assista entrambi i coniugi in sede familiare e nella prospettiva conciliativa, si commentano le due pronunce delle Sezioni Unite che sul punto costituiscono il riferimento consolidato: la sentenza n. 8057 del 2014, che ha fissato il principio, e la sentenza n. 22729 del 2022, che lo ha ribadito e applicato a una condotta di assistenza congiunta nella fase esecutiva degli accordi familiari, terreno prossimo a quello della mediazione.

Fatti di causa. Un avvocato aveva assistito congiuntamente due coniugi nel procedimento di separazione consensuale e, successivamente, nel divorzio, raccogliendo la volontà di entrambi, predisponendo il ricorso e presenziando all'udienza in favore dell'una e dell'altro. A distanza di tempo, insorta tra i medesimi soggetti una controversia di natura familiare, il professionista accettava l'incarico difensivo nell'interesse del solo marito, svolgendo attività a suo favore contro la ex moglie in precedenza assistita. Su esposto di quest'ultima, il Consiglio distrettuale di disciplina avviava il procedimento disciplinare per violazione dei doveri deontologici, in particolare del divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita. La sentenza del Consiglio nazionale forense confermava l'addebito e il professionista ricorreva alle Sezioni Unite, competenti sui ricorsi in materia disciplinare forense. Nella vicenda del 2022, di analoga struttura, l'incolpata aveva assistito i coniugi nella separazione e nel divorzio e aveva poi offerto, in virtù di una delega congiunta, una sostanziale attività di assistenza stragiudiziale a uno di essi nella fase esecutiva degli accordi raggiunti, in posizione di potenziale contrapposizione all'altro.

Posizione delle parti e strategia difensiva. Il difensore incolpato sosteneva, in entrambi i casi, che non fosse stata raggiunta la prova del conferimento formale di un mandato da parte del coniuge poi trovato controparte, sicché sarebbe mancato il presupposto oggettivo dell'illecito; deduceva inoltre l'assenza di un danno concreto e di un effettivo sfruttamento delle conoscenze acquisite nella pregressa assistenza congiunta. La linea difensiva era, insomma, di tipo minimalista: ridurre l'illecito alla prova documentale di un mandato e alla dimostrazione di un pregiudizio effettivo. Gli organi disciplinari, e con essi la parte esponente, opponevano che il divieto deontologico ha carattere assoluto e opera a tutela anticipata, colpendo la mera possibilità del conflitto e prescindendo dalla prova del mandato formale, purché risulti che l'avvocato abbia svolto un'attività di assistenza anche soltanto formale in favore di entrambi.

Il principio e la sua proiezione sulla mediazione familiare. Le Sezioni Unite del 2014 hanno affermato che, ai fini della configurabilità dell'illecito di assunzione di incarichi contro una parte già assistita, non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell'assolvimento di un'attività di consulenza, quanto piuttosto se l'avvocato

abbia svolto un'attività di assistenza, anche soltanto formale, in favore della parte poi divenuta controparte. Il divieto, previsto oggi dall'articolo 68 del codice deontologico forense e già dall'articolo 51 del codice previgente, ha carattere assoluto e mira a prevenire persino la sola possibilità di situazioni di conflitto di interessi. La sentenza del 2022 ha confermato l'orientamento, ritenendo deontologicamente rilevante, ancorché di tenue disvalore, la condotta di chi, dopo avere assistito congiuntamente i coniugi, offra a uno di essi assistenza nella fase attuativa degli accordi in posizione di contrapposizione all'altro.

Questa costruzione proietta effetti diretti sulla mediazione familiare. Nella prassi accade che un unico legale, richiesto da una coppia orientata alla separazione consensuale, accompagni entrambi al tavolo conciliativo nella convinzione di agevolare l'intesa. La lettura delle Sezioni Unite avverte che tale assistenza congiunta, ancorché formale e animata dalle migliori intenzioni, radica una posizione di incompatibilità: ove la trattativa si guasti e uno dei coniugi chieda poi al medesimo avvocato di difenderlo contro l'altro, il professionista deve astenersi. La tutela è anticipata al pericolo, non postergata al danno. Nella mia esperienza professionale il difensore avveduto, di fronte a una coppia che chiede assistenza comune in mediazione familiare, chiarisce sin dal primo colloquio che il proprio ruolo non potrà mai convertirsi in patrocinio di uno contro l'altro, e suggerisce che ciascun coniuge sia assistito da un proprio legale, riservando all'eventuale professionista comune una funzione di mera regia dell'accordo e non di difesa di parte.

Massima per l'avvocato negoziatore. In sede familiare l'assistenza congiunta ai coniugi, anche solo formale e anche in vista di un accordo, genera un'incompatibilità assoluta e anticipata: chi ha assistito entrambi non potrà mai difenderne uno contro l'altro, a prescindere dalla prova del mandato e dal danno concreto. Il negoziatore che accompagna una coppia al tavolo conciliativo definisca con nettezza i confini del proprio ruolo prima di sedersi, perché il dovere di astensione, una volta insorto il conflitto anche solo potenziale, non ammette recuperi.

Fonte: Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 7 aprile 2014, n. 8057; Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 20 luglio 2022, n. 22729 (testo in [italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it) (<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=.%2F20220720%2Fsnciv@sU0@a2022@n22729@tS.clean.pdf>); commento in *Ius & management* (<https://www.iusmanagement.org/2022/07/26/per-il-conflitto-di-interessi-dellavvocato-e-irrilevante-il-conferimento-formale-del-mandato/>)).

Caso 4: Cass., SS.UU., sent. 18 aprile 2019, n. 10934 — legittimazione dell'amministratore di condominio, autorizzazione assembleare e ratifica nelle liti e nella mediazione condominiale

Premessa sulla scelta del caso. La materia condominiale è oggi assoggettata a mediazione obbligatoria e la disciplina, dopo la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, riconosce all'amministratore, con l'articolo 5-ter del d.lgs. 28/2010, la legittimazione ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione senza previa autorizzazione assembleare, ferma restando la sottoposizione dell'eventuale accordo all'approvazione dell'assemblea. Il fondamento sistematico di questo assetto sta però nel principio fissato dalle Sezioni Unite sulla legittimazione dell'amministratore e sul meccanismo della ratifica, principio che governa tanto la lite quanto il tavolo conciliativo. Si commenta perciò la sentenza n. 10934 del 2019, che di quel principio è la fonte, leggendola in chiave di mediazione condominiale.

Fatti di causa. In una controversia relativa a beni comuni, il condominio, in persona dell'amministratore, si costituiva in giudizio e proponeva impugnazione avverso una sentenza sfavorevole senza che risultasse una previa delibera assembleare di autorizzazione. La controparte eccepiva il difetto di legittimazione dell'amministratore, sostenendo che il potere di decidere sulle liti eccedenti le sue attribuzioni ordinarie spettasse in via esclusiva all'assemblea. Si discuteva altresì della posizione del singolo condomino rispetto all'impugnazione di una sentenza resa nei confronti del condominio e della necessità o meno di integrare il contraddittorio. La questione, per la sua rilevanza nomofilattica e per l'esistenza di contrasti, veniva rimessa alle Sezioni Unite, chiamate a definire i limiti della rappresentanza dell'amministratore e la sanabilità dei suoi atti compiuti senza autorizzazione.

Posizione delle parti e strategia difensiva. Il difensore del condominio sosteneva che l'amministratore, quale organo rappresentativo, potesse costituirsi e impugnare, e che l'eventuale carenza di autorizzazione fosse comunque emendabile mediante una successiva delibera. La controparte, all'opposto, faceva leva sul difetto di legittimazione come causa di inammissibilità dell'atto, costruendo la propria difesa sul piano processuale prima ancora che sostanziale, nell'intento di ottenere una pronuncia in rito che consolidasse la decisione a sé favorevole. La strategia dell'eccepiente era quella, classica in materia condominiale, di trasformare un vizio di legittimazione dell'organo in un ostacolo insormontabile alla prosecuzione della difesa dell'ente collettivo.

Il principio e la sua proiezione sulla mediazione condominiale. Le Sezioni Unite hanno ribadito che il potere decisionale sulle liti spetta soltanto ed esclusivamente all'assemblea, la quale può però ratificare anche con effetti retroattivi, ossia *ex tunc*, l'operato dell'amministratore che abbia agito senza autorizzazione, essendo questi l'organo meramente esecutivo del condominio. La ratifica vale a sanare, con efficacia *ex tunc*, la costituzione in giudizio o l'impugnazione proposte dall'amministratore privo di preventiva delibera, sia per rimuovere l'eccezione di inammissibilità sia per adempiere al rilievo officioso del giudice. La Corte ha inoltre riconosciuto la legittimazione concorrente del singolo condomino a impugnare la sentenza di condanna resa contro l'intero condominio, salvo che si tratti di azioni rientranti nelle mere attribuzioni gestorie, escludendo al contempo che al condominio possa riconoscersi una autonoma soggettività distinta da quella dei partecipanti.

Trasferito sul terreno della mediazione, questo principio spiega e completa l'articolo 5-ter del d.lgs. 28/2010. L'amministratore siede al tavolo conciliativo senza bisogno di preventiva autorizzazione, perché la sua è legittimazione a trattare, non a disporre: il potere di disporre del diritto conteso, e quindi di vincolare il condominio con l'accordo, resta dell'assemblea. Ne deriva che il verbale contenente l'accordo di conciliazione, o la proposta del mediatore, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea, che delibera con le maggioranze dell'articolo 1136 del codice civile entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta; in difetto di approvazione entro tale termine, la conciliazione si intende non conclusa. La logica della ratifica *ex tunc* affermata dalle Sezioni Unite è la chiave di lettura di questo congegno: l'amministratore può fare tutto ciò che serve a costruire l'intesa, ma è l'assemblea a renderla efficace, sanando eventualmente a posteriori l'operato dell'organo esecutivo.

Nella mia esperienza professionale l'errore più frequente e più costoso è condurre a termine una mediazione condominiale e sottoscrivere l'accordo confidando nella sola firma dell'amministratore, per poi scoprire che l'assemblea non ratifica e che l'intesa non ha prodotto

effetti. Il difensore che assiste il condominio deve calibrare i tempi della mediazione su quelli assembleari, inserendo nel verbale un termine congruo per l'approvazione e verificando che le maggioranze necessarie siano realisticamente conseguibili. Il difensore della controparte, per parte sua, non deve considerare chiuso l'accordo fino alla delibera di ratifica, e deve pretendere che il termine per l'approvazione sia certo e ravvicinato.

Massima per l'avvocato negoziatore. In materia condominiale l'amministratore ha la legittimazione a trattare in mediazione senza autorizzazione preventiva, ma non il potere di disporre del diritto: l'accordo vincola il condominio solo con l'approvazione dell'assemblea, che può anche ratificare ex tunc l'operato dell'organo esecutivo. Chi negozia con o per il condominio scandisca la mediazione sui tempi assembleari e fissi nel verbale un termine certo di ratifica, perché senza delibera l'intesa raggiunta al tavolo resta lettera morta.

Fonte: Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 aprile 2019, n. 10934 (testo e commento in FGLaw (https://www.fglaw.it/cassazione_sezioni_unite_civili_18_aprile_2019_n_10934_condominio_legittimazione_impugnare_singolo_condomino.html)); sul quadro riformato della legittimazione dell'amministratore in mediazione ex art. 5-ter d.lgs. 28/2010, CF News (<https://www.cfnews.it/diritto/la-nuova-gravosa-legittimazione-dell-amministratore-condominiale-in-mediazione/>).

Caso 1: Corte di cassazione, Sezione III civile, 27 marzo 2019, n. 8473, e Corte costituzionale, 18 aprile 2019, n. 97 — la partecipazione personale della parte alla mediazione e il ruolo dell'avvocato delegato

I fatti. La vicenda che ha condotto alla pronuncia della Corte di cassazione, Sezione III civile, 27 marzo 2019, n. 8473 nasce da un contenzioso in materia di responsabilità e di rapporti obbligatori nel quale la mediazione operava come condizione di procedibilità della domanda a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; d'ora innanzi decreto legislativo n. 28 del 2010). Il primo incontro davanti all'organismo di mediazione si era esaurito con la comparizione dei soli difensori, senza la presenza personale delle parti e senza che a costoro fosse stata rilasciata una procura idonea a disporre del diritto controverso. Il giudice di merito aveva ritenuto per ciò solo non avverata la condizione di procedibilità, sul presupposto che la mediazione richieda la partecipazione personale dei litiganti e non si accontenti della sola presenza tecnica del patrocinatore. La questione, sino ad allora oggetto di orientamenti contrastanti tra gli uffici giudiziari, è giunta al vaglio della Corte di cassazione, che ha reso una decisione destinata a orientare la prassi degli anni successivi e a costituire il precipitato interpretativo poi in larga parte recepito dalla riforma del 2022.

Il tema di fondo era duplice. Occorreva stabilire, in primo luogo, se la parte dovesse presenziare personalmente al procedimento di mediazione o se potesse invece farsi sostituire; e, in secondo luogo, se tale sostituzione potesse essere affidata al medesimo avvocato che assiste tecnicamente la parte e con quali forme. Sullo sfondo restava il nodo della natura del primo incontro, se cioè esso fosse un mero momento informativo, esaurito il quale la condizione di procedibilità si intende comunque soddisfatta, oppure se richiedesse un ingresso effettivo nel merito del tentativo conciliativo.

La cornice costituzionale della questione era stata di lì a poco definita dalla Corte costituzionale, 18 aprile 2019, n. 97 (consultabile in giurcost.org (<https://giurcost.org/decisioni/2019/0097s-19.html>)), che, decidendo le questioni sollevate dal Tribunale di Verona, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le censure rivolte alla mediazione obbligatoria di nuovo conio, quella cioè reintrodotta dall'articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la disciplina originaria era stata travolta dalla nota Corte costituzionale, 6 dicembre 2012, n. 272 per eccesso di delega. La Consulta ha in tale occasione valorizzato la figura del mediatore quale terzo indipendente ed equidistante dagli interessi in gioco, elemento che giustifica la maggiore attitudine della mediazione, rispetto ad altri strumenti, a conseguire il proprio scopo e legittima la scelta del legislatore di imporne l'esperimento come antecedente necessario del giudizio.

La posizione e la strategia dei difensori. Il difensore che si presenta al primo incontro senza la parte, o senza un valido titolo rappresentativo, espone il proprio assistito al rischio di una declaratoria di improcedibilità e, nel regime successivo alla riforma, a una condanna pecuniaria. La strategia corretta muove perciò da una duplice consapevolezza. Da un lato, l'avvocato deve considerare che la mediazione non è un adempimento cartolare da esaurire con la propria comparizione, ma un procedimento che presuppone la presenza di chi ha la disponibilità del diritto. Dall'altro lato, ove la presenza personale del cliente non sia possibile, il difensore deve procurarsi in anticipo un titolo che gli consenta di sostituire validamente la parte.

Il rapporto con la mediazione e il principio affermato. La Corte di cassazione ha stabilito che, nel procedimento di mediazione obbligatoria, la comparizione personale delle parti davanti al mediatore è bensì necessaria, ma non integra un atto strettamente personale e come tale infungibile. In assenza di una previsione che ne sancisca la personalità inderogabile, l'attività è delegabile. La parte che non voglia o non possa presenziare può dunque farsi sostituire da un rappresentante, che può essere anche il medesimo avvocato che la assiste, purché munito di una procura speciale sostanziale, cioè di un potere che abiliti non alla mera difesa tecnica ma alla disposizione del diritto in contesa e alla conclusione dell'eventuale accordo. La Corte ha precisato che tale procura sostanziale non rientra tra i poteri di autentica riconosciuti all'avvocato dall'articolo 83 del codice di procedura civile, i quali attengono al mandato alle liti e non al potere di disporre della situazione sostanziale; sicché il conferimento va documentato in forma idonea e non può essere autenticato dallo stesso legale che risulti al contempo delegato. Sul primo incontro, la Corte ha chiarito che la condizione di procedibilità non si soddisfa con un incontro meramente informativo seguito dalla dichiarazione di non voler proseguire, ma esige un effettivo avvio del confronto, salvo che emergano ragioni preliminari ostative.

Questo insegnamento è oggi in larga misura recepito dal diritto positivo. L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010, nel testo introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prescrive espressamente che le parti partecipino personalmente all'incontro e che, in presenza di giustificati motivi, possano delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia; i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano avvalendosi di rappresentanti o delegati parimenti a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri per conciliare. La mancata partecipazione senza giustificato motivo è presidiata, oltre che dagli argomenti di prova desumibili a norma dell'articolo 116, secondo

comma, del codice di procedura civile, dalla condanna pecuniaria oggi fissata in una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Massima per l'avvocato negoziatore. La regola operativa è netta. Prima del primo incontro occorre organizzare la presenza fisica del cliente o, in caso di impedimento, redigere una procura speciale sostanziale che attribuisca al delegato il potere di conciliare e di disporre del diritto, curando che tale procura non sia autenticata dallo stesso avvocato che assumerà le vesti di delegato. Presentarsi al primo incontro con la sola difesa tecnica, confidando nella natura informativa dell'appuntamento, significa esporre il cliente all'improcedibilità e alla sanzione pecuniaria. La partecipazione va intesa in senso sostanziale, come reale disponibilità a entrare nel merito del tentativo conciliativo.

Fonti. Corte di cassazione, Sezione III civile, 27 marzo 2019, n. 8473, testo integrale in [so.camcom.it](https://www.so.camcom.it/files/allegati/Cassazione%20Civile%20Sez.%20III,%20sentenza%20n.%208473_2019%20.pdf) (https://www.so.camcom.it/files/allegati/Cassazione%20Civile%20Sez.%20III,%20sentenza%20n.%208473_2019%20.pdf); Corte costituzionale, 18 aprile 2019, n. 97, in [giurcost.org](https://giurcost.org/decisioni/2019/0097s-19.html) (<https://giurcost.org/decisioni/2019/0097s-19.html>); per il regime anteriore, Corte costituzionale, 6 dicembre 2012, n. 272, in [giurcost.org](https://giurcost.org/decisioni/2012/0272s-12.html) (<https://giurcost.org/decisioni/2012/0272s-12.html>).

Caso 2: Tribunale di Milano, Sezione I civile, ordinanza 7 maggio 2015 — la mediazione demandata nella lite commerciale d'impresa e il presidio dell'effettività

I fatti. Il Tribunale di Milano, Sezione I civile, con ordinanza 7 maggio 2015 (in [adrintesa.it](https://www.adrintesa.it/news-mediazione-civile/giurisprudenza/tribunale-di-milano-sez-i-civile-ordinanza-7-maggio-2015) (<https://www.adrintesa.it/news-mediazione-civile/giurisprudenza/tribunale-di-milano-sez-i-civile-ordinanza-7-maggio-2015>)), si è occupato di una controversia di contenuto patrimoniale e commerciale nella quale il giudice aveva disposto, a norma dell'articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'esperimento della mediazione demandata, ossia l'invio delle parti in mediazione su iniziativa dell'ufficio giudiziario in corso di causa. Nel dare seguito al provvedimento, una delle parti aveva avviato la procedura presso un organismo situato in luogo diverso da quello nel quale la controversia risultava radicata e nel quale operavano le imprese coinvolte. Si poneva perciò il problema di stabilire se un simile avvio, formalmente rispettoso dell'ordine del giudice ma collocato in una sede scarsamente funzionale al confronto, potesse dirsi idoneo a integrare la condizione imposta.

Il Tribunale ha osservato che l'introduzione della mediazione presso un organismo lontano dal luogo di svolgimento del rapporto e dalla sede degli interessati può ostacolare in concreto la conciliazione, rendendo la procedura scarsamente utile e non favorendo l'incontro effettivo delle parti per la ricerca dell'accordo. L'effettività, in altri termini, non attiene solo al contenuto del confronto ma anche alle sue condizioni logistiche e organizzative, che devono essere disposte in modo da agevolare, e non da frustrare, la comparizione di entrambe le parti e dei loro rappresentanti muniti dei poteri per conciliare. Il provvedimento si inserisce nel solco della prassi ambrosiana, alimentata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che ha fatto della mediazione demandata uno strumento ordinario di governo del contenzioso commerciale e d'impresa.

La posizione e la strategia dei difensori. Nella lite tra imprese, l'avvio della mediazione demandata pone al difensore d'azienda un problema di sostanza prima ancora che di forma. L'avvocato che assiste la società non può limitarsi a scegliere l'organismo più comodo per il proprio studio, perché la sede del procedimento incide sulla probabilità che l'altra parte

compaia effettivamente e che il confronto abbia luogo. Chi individua un organismo distante o disallineato rispetto al radicamento della controversia rischia di vedersi contestare che l'invio in mediazione è stato eseguito in modo solo apparente, con conseguente inutilità del tentativo e possibile ricaduta sulla procedibilità o sulla valutazione della condotta processuale.

La strategia dell'avvocato d'impresa deve perciò muovere da una lettura dell'ordine di mediazione come occasione reale di composizione, e non come formalità da evadere. Ciò impone di scegliere un organismo territorialmente coerente, di procurarsi per tempo i poteri deliberativi interni necessari a far partecipare un rappresentante della società realmente in grado di conciliare, e di preparare una posizione negoziale che tenga conto delle voci economiche in gioco, dei rapporti commerciali destinati a proseguire e dei costi, anche reputazionali, del contenzioso protratto. Nelle liti che coinvolgono assetti societari, rapporti tra soci, contratti di durata o forniture strategiche, la mediazione demandata offre uno spazio riservato nel quale ricomporre l'interesse economico complessivo, spesso più ampio del *petitum* formalmente azionato.

Il rapporto con la mediazione e le tecniche. La demandata milanese si fonda su un'idea di mediazione come sede di negoziazione assistita da un terzo, nella quale il giudice, individuata la controversia come conciliabile, restituisce alle parti il governo del conflitto. Per l'avvocato d'impresa ciò significa esercitare tecniche negoziali orientate agli interessi sottostanti più che alle posizioni giuridiche di partenza, distinguendo tra ciò che è economicamente rilevante per il cliente e ciò che è meramente rivendicativo. La riservatezza del procedimento consente di esplorare soluzioni che in giudizio non sarebbero disponibili, come rimodulazioni di rapporti contrattuali, dilazioni, compensazioni o accordi quadro sui rapporti futuri. La collocazione della mediazione in una sede idonea, lungi dall'essere un dettaglio, è la preconditione perché tali tecniche possano dispiegarsi.

Massima per l'avvocato negoziatore. Quando il giudice dispone la mediazione demandata in una controversia commerciale, l'avvocato d'impresa deve eseguire l'ordine in modo sostanziale e non elusivo: scegliere un organismo territorialmente coerente con la lite, assicurare la presenza di un rappresentante della società effettivamente munito dei poteri per conciliare e impostare la trattativa sugli interessi economici complessivi del cliente. La sede e le condizioni logistiche del procedimento non sono neutre, perché un avvio disallineato può essere letto come inottemperanza sostanziale al provvedimento del giudice.

Fonti. Tribunale di Milano, Sezione I civile, ordinanza 7 maggio 2015, in [adrintesa.it](https://www.adrintesa.it/news-mediazione-civile/giurisprudenza/tribunale-di-milano-sez-i-civile-ordinanza-7-maggio-2015) (<https://www.adrintesa.it/news-mediazione-civile/giurisprudenza/tribunale-di-milano-sez-i-civile-ordinanza-7-maggio-2015>); sull'attività della Sezione specializzata in materia di impresa, Tribunale di Milano, [tribunale-milano.giustizia.it](https://tribunale-milano.giustizia.it/it/tribunale_delle_impresa.page) (https://tribunale-milano.giustizia.it/it/tribunale_delle_impresa.page).

Caso 3: Tribunale di Firenze, ordinanza 17 marzo 2014 (est. Breggia) — la mediazione demandata come tentativo effettivo e la motivazione persuasiva dell'invio

I fatti. Il Tribunale di Firenze, con la nota ordinanza 17 marzo 2014 resa dal giudice Luciana Breggia nella causa iscritta al numero di ruolo generale 5210/2010 (testo in [adrcel.it](https://www.adrcel.it/ordinanzaFirenze.asp) (<https://www.adrcel.it/ordinanzaFirenze.asp>)), ha affrontato in modo organico il tema del contenuto e dei limiti della mediazione demandata dal giudice a norma dell'articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013. Il

provvedimento muove dalla constatazione che l'invio in mediazione da parte del giudice non può risolversi in un adempimento burocratico, ma deve mirare a un tentativo conciliativo realmente esperito. La pronuncia si è così collocata all'origine di un orientamento che l'ufficio fiorentino ha poi sistematizzato attraverso l'Osservatorio sulla giustizia civile e il progetto Nausicaa, con l'adozione di un protocollo e di linee guida sulla mediazione demandata dal giudice (documentazione in [tribunale.firenze.giustizia.it](https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/News/Detail/14497) (<https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/News/Detail/14497>)).

Il fulcro dell'ordinanza sta nella nozione di mediazione effettiva. Secondo il Tribunale, l'ordine del giudice non si intende ottemperato quando le parti si limitino a comparire, ad ascoltare l'illustrazione della procedura e a dichiarare di non voler proseguire; occorre invece che esse diano concreto seguito all'invito, entrando nel merito del tentativo, salvo che sussistano questioni preliminari che ne impediscano lo svolgimento. La comparizione, inoltre, deve essere personale e assistita dal difensore iscritto all'albo, non essendo sufficiente la sola presenza dei patrocinatori. Il provvedimento sottolinea che l'efficacia dell'istituto non si fonda su un'imposizione priva di ragioni, ma sulla capacità di persuadere le parti, il che postula che l'ordinanza di invio sia sorretta da una motivazione specifica, calibrata sul caso concreto e idonea a fare comprendere perché quella determinata lite si presti alla composizione mediata.

La posizione e la strategia dei difensori. L'impostazione fiorentina cambia radicalmente il modo in cui l'avvocato deve reagire a un ordine di mediazione demandata. Il difensore che intenda contestare l'invio non può opporre un'adesione solo formale seguita da un rifiuto immediato, perché un simile contegno sarebbe letto come inottemperanza sostanziale, con le conseguenze in punto di procedibilità e di valutazione della condotta processuale a norma dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Al tempo stesso, la richiesta di una motivazione articolata dell'ordine offre al difensore un utile terreno di interlocuzione con il giudice: se l'invio è ben motivato, esso indica le ragioni di conciliabilità della lite e orienta la successiva trattativa; se è generico, il difensore può segnalarne l'inidoneità e sollecitare un provvedimento più aderente al caso.

La strategia corretta consiste dunque nel prendere sul serio l'invito. Ciò significa preparare il cliente alla comparizione personale, chiarirgli che il primo incontro non è un adempimento a vuoto, definire in anticipo i margini di trattativa e individuare gli interessi che rendono l'accordo preferibile alla prosecuzione del giudizio. L'avvocato che affronti la mediazione demandata con questo spirito ne trae un vantaggio competitivo, perché arriva al tavolo con una posizione negoziale meditata mentre la controparte, se la sottovaluta, vi giunge impreparata.

Lo svolgimento e le tecniche. Il modello fiorentino richiede che il tentativo attraversi effettivamente la fase gestita dal mediatore, con l'esplorazione degli interessi delle parti e la ricerca di soluzioni che il giudizio non potrebbe offrire. La motivazione persuasiva dell'ordine di invio funge da innesco: indicando le ragioni di conciliabilità, essa predispone le parti a un confronto costruttivo e riduce la diffidenza verso lo strumento. Per il difensore, ciò si traduce nella necessità di padroneggiare le tecniche del negoziato basato sugli interessi, di gestire la componente relazionale del conflitto e di valorizzare la riservatezza della sede per proposte che in giudizio risulterebbero precluse.

Massima per l'avvocato negoziatore. Di fronte a una mediazione demandata occorre ottemperare in modo effettivo, non apparente: comparire personalmente con il cliente, entrare

nel merito del tentativo e presentarsi con una posizione negoziale preparata. La motivazione specifica dell'ordine di invio non è una formalità, ma la chiave di lettura della conciliabilità della lite, che il difensore avveduto utilizza per impostare la trattativa e, se necessario, per interloquire con il giudice sull'opportunità dell'invio.

Fonti. Tribunale di Firenze, ordinanza 17 marzo 2014, est. Luciana Breggia, testo in [adrcel.it](https://www.adrcel.it/ordinanzaFirenze.asp) (<https://www.adrcel.it/ordinanzaFirenze.asp>); sul progetto Nausicaa e sul protocollo per la mediazione demandata, Tribunale di Firenze, [tribunale.firenze.giustizia.it](https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/News/Detail/14497) (<https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/News/Detail/14497>); per un inquadramento, il commento in [questionegiustizia.it](https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-mediazione-dopo-il-decreto-del-fare-e-il-giudic_14-04-2014.php) (https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-mediazione-dopo-il-decreto-del-fare-e-il-giudic_14-04-2014.php).

Caso 4: la difesa davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) — natura dei rimedi, differenze dalla mediazione civile e strategia difensiva

Il quadro. Nel settore bancario e finanziario operano due sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che l'avvocato deve saper distinguere con precisione, perché rispondono a logiche affatto diverse da quelle della mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010. Il primo è l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito presso la Banca d'Italia a norma dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), competente sulle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, quali conti correnti, carte di pagamento, finanziamenti, mutui e segnalazioni alla Centrale dei rischi (sito ufficiale [arbitrobancariofinanziario.it](https://www.arbitrobancariofinanziario.it) (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>)). Il secondo è l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, competente sulle controversie tra investitori e intermediari relative alla prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, quali negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli (sito ufficiale [acf.consob.it](https://www.acf.consob.it/) (<https://www.acf.consob.it/>)).

La natura dei rimedi e la differenza dalla mediazione. La differenza strutturale rispetto alla mediazione risiede nel metodo. La mediazione civile mira alla composizione bonaria della lite attraverso un accordo che le parti raggiungono con l'ausilio di un terzo neutrale, il quale non decide e non entra nel merito delle pretese; l'esito, quando positivo, è un verbale di accordo suscettibile di divenire titolo esecutivo. ABF e ACF, al contrario, non favoriscono la ricerca di un accordo tra le parti, ma entrano nel merito e adottano una decisione sul ricorso, valutando le posizioni alla stregua di un giudizio tecnico. Tale decisione, tuttavia, non è vincolante in senso proprio: non costituisce un lodo arbitrale, non dà luogo a un titolo esecutivo, non è idonea al giudicato e non preclude alle parti l'accesso all'autorità giudiziaria. La sua effettività è affidata a un meccanismo reputazionale: in caso di inadempimento dell'intermediario alla decisione a lui sfavorevole, è prevista la pubblicità della notizia dell'inadempimento sui canali istituzionali, con evidente ricaduta d'immagine. Va inoltre segnalato che la decisione può contenere un accertamento a carico del solo intermediario e non del cliente, coerentemente con la funzione di tutela del contraente debole propria del sistema.

Il presupposto di accesso è ulteriormente diverso da quello della mediazione. Il ricorso all'ABF e all'ACF presuppone il previo reclamo all'intermediario, rimasto senza esito soddisfacente; l'ABF

richiede il versamento di un contributo di importo contenuto per l'esame del ricorso, mentre l'accesso all'ACF è gratuito. In entrambi i sistemi non è prevista l'assistenza obbligatoria di un difensore, essendo i procedimenti concepiti per essere accessibili anche al cliente privo di patrocinatore.

La posizione e la strategia dei difensori. L'assenza di un obbligo di assistenza tecnica non deve indurre a sottovalutare il ruolo dell'avvocato, che anzi si rivela spesso determinante. La qualità del reclamo preliminare all'intermediario incide sull'esito del successivo ricorso, perché delimita il thema decidendum e cristallizza i fatti; un reclamo redatto con competenza consente di isolare i profili giuridicamente rilevanti, di allegare in modo ordinato la documentazione contrattuale e di impostare la contestazione in termini che l'arbitro possa accogliere. Nella fase del ricorso, il difensore cura la corretta qualificazione della fattispecie, la deduzione degli oneri probatori e il richiamo agli orientamenti consolidati dei collegi, che nel tempo hanno assunto una fisionomia para-giurisprudenziale.

La strategia deve tenere conto del carattere non vincolante della decisione. Poiché l'esito favorevole non produce un titolo esecutivo, l'avvocato deve valutare sin dall'inizio se il rimedio stragiudiziale sia funzionale a un componimento rapido, spesso favorito dai contatti transattivi che si aprono tra cliente e intermediario dopo la proposizione del ricorso, oppure se convenga preservare o affiancare la via giudiziaria. Occorre inoltre considerare che l'ABF e l'ACF di regola non liquidano gli onorari del difensore al ricorrente vittorioso, in coerenza con la natura di procedimenti azionabili senza il ministero di un avvocato; il costo dell'assistenza tecnica va perciò ponderato rispetto al valore della controversia e alle probabilità di adempimento spontaneo dell'intermediario.

Il rapporto con la mediazione civile. Nel disegno complessivo dei rimedi, ricorso all'ABF o all'ACF e mediazione ex decreto legislativo n. 28 del 2010 non si escludono ma si coordinano. Per numerose materie bancarie e finanziarie il previo esperimento di uno di questi procedimenti, o della mediazione, opera come condizione di procedibilità della domanda giudiziale a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce al cliente la possibilità di assolvere l'onere ricorrendo in alternativa ai sistemi ADR di settore. La scelta tra mediazione e ricorso all'arbitro non è perciò neutra: la prima offre la prospettiva di un accordo esecutivo e riservato, ma richiede la disponibilità di entrambe le parti a trattare; il secondo assicura una pronuncia tecnica sul merito, priva però di forza esecutiva e affidata al meccanismo reputazionale. L'avvocato negoziatore deve saper leggere questa alternativa in funzione dell'obiettivo del cliente e della prevedibile condotta dell'intermediario.

Massima per l'avvocato negoziatore. ABF e ACF non sono mediazioni: non cercano l'accordo ma decidono nel merito, con pronunce non vincolanti prive di forza esecutiva e presidiate dalla sola sanzione reputazionale. L'avvocato deve investire sulla qualità del reclamo preliminare e del ricorso, scegliere consapevolmente tra rimedio stragiudiziale di settore, mediazione civile e giudizio in ragione dell'obiettivo perseguito, e informare il cliente che l'esito favorevole, pur autorevole, non produce di per sé un titolo esecutivo.

Fonti. Arbitro Bancario Finanziario, Banca d'Italia, arbitrobancariofinanziario.it (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>); Arbitro per le Controversie Finanziarie, Consob, acf.consob.it (<https://www.acf.consob.it/>); sul riparto di competenza e sul protocollo di collaborazione tra Banca d'Italia e Consob, acf.consob.it

(<https://www.acf.consob.it/-/protocollo-consob-banca-d-italia-volto-a-disciplinare-forme-di-collaborazione-tra-arbitro-bancario-finanziario-abf-e-arbitro-per-le-controversie-finan>).

Aggiornamento 2024-2026 — casi recenti verificati (mediazione condominiale e familiare)

Caso: Tribunale di Roma, sez. V civ., sentenza 2 maggio 2024, n. 7405 (ratifica assembleare dell'accordo di mediazione sulle tabelle millesimali) e Corte d'Appello di Napoli, sentenza 29 aprile 2026, n. 3298 (improcedibilità dell'impugnazione di delibera e poteri correttivi del giudice)

Il contenzioso condominiale è il banco di prova quotidiano della mediazione obbligatoria. Dal 30 giugno 2023, con l'entrata a regime della riforma attuata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (di seguito, riforma Cartabia), la disciplina della partecipazione del condominio è confluita nell'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di seguito, d.lgs. 28/2010), che ha innovato profondamente rispetto al previgente articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile. Per l'avvocato negoziatore che assiste il condominio, il singolo condomino o il terzo, il nodo pratico è duplice: da un lato, chi è legittimato a sedersi al tavolo e con quali poteri; dall'altro, che cosa accade quando la condizione di procedibilità non viene correttamente gestita. Le due pronunce qui commentate offrono, su entrambi i versanti, indicazioni operative di immediata utilità.

Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, elenca la materia condominiale tra quelle nelle quali chi intende agire in giudizio è tenuto, assistito dall'avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La nozione di controversia in materia di condominio, per costante interpretazione, ricomprende le liti relative agli articoli da 1117 a 1139 del codice civile e agli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.

L'articolo 5-ter d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, dispone che l'amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, senza necessità di previa delibera assembleare. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea, la quale delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136, comma 2, del codice civile, entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta; se la delibera non interviene nel termine, la conciliazione si intende non conclusa. La disposizione ha così superato il regime dell'articolo 71-quater disp. att. c.c., che subordinava la stessa partecipazione dell'amministratore a una previa delibera autorizzativa e imponeva al mediatore, ove i termini di comparizione non consentissero di assumerla, di disporre idonea proroga della prima comparizione. Il baricentro dell'intervento assembleare si è dunque spostato dal momento iniziale (l'autorizzazione a partecipare) al momento finale (la ratifica del risultato).

Prima pronuncia: Tribunale di Roma, n. 7405 del 2024

I fatti

Un condomino conveniva in giudizio il condominio chiedendo l'accertamento e la declaratoria di nullità della delibera con cui l'assemblea aveva approvato le nuove tabelle millesimali, per

asserita violazione dell'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile. A fondamento della domanda l'attore poneva il difetto dei quorum costitutivo e deliberativo, sostenendo che, trattandosi di approvazione di tabelle millesimali, sarebbe stata necessaria l'unanimità dei condomini per entrambi i quorum. Il condominio si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, chiedendo l'accertamento della validità della delibera impugnata con il rigetto di tutte le domande attoree.

La peculiarità del caso sta nel fatto che la delibera impugnata non era una decisione che modificava unilateralmente le tabelle, bensì la delibera con cui l'assemblea aveva ratificato l'accordo raggiunto in sede di mediazione, accordo con il quale erano state approvate le nuove tabelle millesimali. La mediazione, dunque, era stata effettivamente esperita e si era conclusa positivamente; il giudizio verteva sulla validità dell'atto assembleare di recepimento del suo esito. La causa proseguiva sino alla decisione.

La decisione

Il Tribunale di Roma, sezione V civile, con la sentenza 2 maggio 2024, n. 7405 (giudice Antonella Zanchetta), riqualifica il thema decidendum: la questione non attiene ai quorum necessari per modificare le tabelle millesimali, come prospettato dall'attore, ma alle maggioranze costitutive e deliberative necessarie per la ratifica dell'accordo di mediazione con cui le nuove tabelle sono state approvate. Su questo punto il giudice applica l'articolo 5-ter d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che le delibere assembleari di ratifica degli accordi raggiunti in sede di mediazione richiedono le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma 2, del codice civile. Non occorre, pertanto, l'unanimità invocata dall'attore. La delibera impugnata è legittima perché hanno partecipato e deliberato tanti condomini rappresentanti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, come risultante dal verbale. La domanda di nullità viene rigettata.

Posizione e strategia dei difensori

La difesa dell'attore aveva impostato l'attacco sul terreno del diritto sostanziale delle tabelle millesimali, terreno sul quale la giurisprudenza tradizionale richiede il consenso unanime quando la tabella non sia una mera operazione tecnica di traduzione in frazioni dei valori preesistenti, ma incida sui criteri di ripartizione. La strategia, di per sé non implausibile, si è però rivelata disallineata rispetto alla reale natura dell'atto impugnato: non una modifica pattizia delle tabelle, ma la ratifica di un accordo conciliativo. La difesa del condominio ha invece giocato in modo lucido su due tavoli, eccependo in via preliminare l'improcedibilità (eccezione qui non decisiva, poiché la mediazione vi era stata) e, soprattutto, ancorando la validità della delibera al quorum agevolato che l'articolo 5-ter riserva espressamente alla ratifica degli accordi di mediazione. È questa la mossa vincente: sottrarre la ratifica alla regola dell'unanimità propria della materia sostanziale e ricondurla al regime speciale della mediazione.

Rilievo per la mediazione e per l'avvocato

La pronuncia consegna un principio di grande valore operativo. L'accordo di mediazione condominiale, anche quando ha a oggetto materie che, in via ordinaria, richiederebbero maggioranze qualificatissime o l'unanimità, viene recepito dall'assemblea con la maggioranza

degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5-ter d.lgs. 28/2010 e dell'articolo 1136, comma 2, del codice civile. Ciò significa che la sede conciliativa non è soltanto un filtro deflattivo, ma diventa uno strumento di governo delle materie a quorum aggravato: quel che l'assemblea faticherebbe a deliberare in via diretta con l'unanimità, può essere raggiunto in mediazione e poi ratificato a maggioranza. Per l'avvocato negoziatore che assiste il condominio, questo apre uno spazio di manovra prezioso nelle liti su tabelle millesimali, riparti di spesa e regolamenti, dove l'unanimità è spesso irraggiungibile. Per chi assiste il condomino dissenziente, all'opposto, l'insegnamento è che non conviene impugnare la delibera di ratifica invocando il quorum della materia sostanziale, perché il giudice applicherà il quorum speciale della ratifica. L'attenzione va spostata, semmai, sui vizi propri dell'accordo o del procedimento conciliativo.

Massima per l'avvocato negoziatore

La delibera con cui l'assemblea condominiale ratifica l'accordo raggiunto in mediazione, anche se avente a oggetto le tabelle millesimali, è validamente assunta con le maggioranze dell'articolo 1136, comma 2, del codice civile, e non richiede l'unanimità (art. 5-ter d.lgs. 28/2010). La mediazione va quindi impiegata come via maestra per comporre le liti a quorum aggravato: si negozia l'accordo e lo si porta alla ratifica assembleare a maggioranza, anziché tentare l'improbabile delibera unanime diretta.

Fonte

Tribunale di Roma, sez. V civ., sentenza 2 maggio 2024, n. 7405. Testo integrale e nota: Mondo ADR (ADR Center), https://www.mondoadr.it/giurisprudenza_art/delibera-condominiale-ratifica-accordo-mediazione-basta-la-maggioranza-degli-intervenuti/ (con link al PDF della sentenza: <https://www.mondoadr.it/new-site/wp-content/uploads/Trib-Roma-7405-2024.pdf>).

Seconda pronuncia: Corte d'Appello di Napoli, n. 3298 del 2026

I fatti

La vicenda nasce da un giudizio di impugnazione di delibera condominiale. In primo grado il Tribunale di Napoli aveva dichiarato improcedibile la domanda, ritenendo che la mediazione non fosse stata correttamente esperita per ragioni attinenti alla rappresentanza della parte in sede mediativa e alla regolarità del verbale conclusivo. Il condomino soccombente proponeva appello. Anziché arrestarsi alla disputa sulla forma della procura rilasciata alla parte e sull'autentica del verbale da parte del mediatore, la Corte d'Appello spostava il fuoco del proprio ragionamento sul corretto funzionamento dell'articolo 5 d.lgs. 28/2010 e, in particolare, sul comportamento che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere una volta che il convenuto aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di improcedibilità.

La decisione

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 29 aprile 2026, n. 3298 (collegio composto dai giudici Elvira Bellantoni, Maria Teresa Onorato e Paola Martorana), afferma che, a prescindere da ogni valutazione sulla forma della procura e sulla sottoscrizione del verbale, il primo giudice, di fronte all'eccezione del convenuto, avrebbe dovuto applicare il meccanismo tipico della mediazione obbligatoria: quando rileva che la mediazione non è stata esperita o non si è

conclusa regolarmente, il giudice non chiude il processo, ma fissa la successiva udienza e assegna alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione. Sul rimedio esperibile in appello, la Corte esclude la rimessione automatica della causa al primo giudice, osservando che le ipotesi di regressione del processo previste dall'articolo 354 del codice di procedura civile sono tassative e che il legislatore, se avesse voluto sanzionare l'errore con la rimessione degli atti, lo avrebbe previsto espressamente. Ne consegue che, ove il convenuto abbia tempestivamente eccepito l'improcedibilità e il primo giudice abbia erroneamente gestito la condizione, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e assegnare esso stesso il termine per attivare la mediazione, verificando poi l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguendo, in caso positivo, nell'esame del merito. La pronuncia ha carattere non definitivo: la Corte dichiara la nullità della sentenza di primo grado, dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio e rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese.

Posizione e strategia dei difensori

L'appellante aveva incentrato la propria linea sui vizi formali della rappresentanza in mediazione e sulla regolarità del verbale, terreno insidioso e alimentato dalla giurisprudenza di legittimità sulla comparizione personale delle parti e sulla necessità di una procura sostanziale a chi partecipa in luogo del titolare del diritto. La Corte, con scelta metodologicamente sobria, evita di prendere posizione definitiva su quel tema controverso e individua altrove la ratio decidendi: anche a voler prescindere dalla questione della procura e dell'autentica, il primo giudice non avrebbe comunque potuto chiudere il processo con una declaratoria di improcedibilità, ma avrebbe dovuto assegnare il termine per la mediazione. Per il difensore, la lezione strategica è che, nel giudizio condominiale, l'eccezione di improcedibilità va calibrata sul reale funzionamento dell'articolo 5 d.lgs. 28/2010: non è una scure che tronca la lite, bensì l'attivazione di un meccanismo che impone al giudice di concedere alle parti la possibilità di esperire o rinnovare la mediazione.

Rilievo per la mediazione e per l'avvocato

La decisione valorizza la mediazione come condizione di procedibilità effettiva, senza trasformarla in una trappola processuale. Da un lato, la mediazione va presa sul serio e non ridotta ad adempimento irrilevante; dall'altro, l'errore nella sua gestione non produce la regressione del processo, ma un rimedio correttivo interno al grado di appello. Per l'avvocato negoziatore, tre indicazioni pratiche. Primo: l'eccezione di improcedibilità nella lite condominiale non mira a ottenere una pronuncia di rigetto in rito che definisce la causa, ma a costringere il giudice ad assegnare il termine per la mediazione; va dunque sollevata tempestivamente e con la consapevolezza che l'esito fisiologico è il recupero della condizione, non la chiusura del giudizio. Secondo: nell'impugnazione di delibera condominiale occorre presidiare con la massima cura la regolarità sostanziale della partecipazione alla mediazione, poiché è proprio su quel terreno (rappresentanza, poteri effettivi di chi compare, verbale) che si annida il rischio di contestazioni. Terzo: chi ha ragione nel merito non deve temere l'errore del primo giudice sulla condizione di procedibilità, perché in appello la causa non torna indietro, ma prosegue previo recupero del passaggio conciliativo omesso.

Massima per l'avvocato negoziatore

Quando l'improcedibilità per mancato o irregolare esperimento della mediazione condominiale sia stata tempestivamente eccepita e il primo giudice l'abbia gestita erroneamente, il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice (le ipotesi di regressione ex art. 354 c.p.c. sono tassative), ma dichiara la nullità della sentenza e assegna esso stesso il termine per attivare la mediazione, verificandone poi l'esito ai fini della prosecuzione. L'eccezione di improcedibilità è dunque uno strumento per far recuperare al processo il tentativo conciliativo, non per definirlo in rito.

Fonte

Corte d'Appello di Napoli, sentenza 29 aprile 2026, n. 3298. Testo integrale e nota: Mondo ADR (ADR Center), https://www.mondoadr.it/giurisprudenza_art/se-il-primo-giudice-sbaglia-sulla-mediazione-lappello-non-rimette-indietro-la-causa-assegna-il-termine-e-va-avanti/ (con link al PDF della sentenza: <https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/Corte-Appello-Napoli-n.-3298-2026.pdf>).

Sintesi per lo studio

Le due pronunce, lette insieme, coprono l'intero arco della mediazione condominiale post riforma Cartabia. La prima (Trib. Roma, n. 7405 del 2024) governa la fase dell'accordo e della sua ratifica: l'assemblea recepisce l'esito della mediazione a maggioranza semplice qualificata ex articolo 1136, comma 2, del codice civile, anche in materie che in via diretta esigerebbero l'unanimità, in forza dell'articolo 5-ter d.lgs. 28/2010. La seconda (App. Napoli, n. 3298 del 2026) governa la fase patologica: l'errore sulla condizione di procedibilità non chiude la lite né la fa regredire, ma impone al giudice, anche in appello, di recuperare il tentativo conciliativo assegnando il relativo termine. Per l'avvocato negoziatore, la mediazione condominiale emerge così non come ostacolo, ma come sede privilegiata per comporre a maggioranza ciò che l'assemblea non riesce a deliberare all'unanimità, con un sistema processuale che ne presidia l'effettività senza penalizzare la parte che ha ragione nel merito.

Riferimenti normativi citati: decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, articoli 5, 5-ter, 8; codice civile, articoli 1117-1139, 1136, comma 2; disposizioni di attuazione del codice civile, articoli 61-72, in particolare 68 e 71-quater; codice di procedura civile, articolo 354; decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Caso: Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 26 luglio 2024, n. 20881 (Pres. Cassano, Rel. Grasso) - conflitto di interessi e dovere di astensione dell'avvocato nelle controversie familiari e minorili

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 26 luglio 2024, n. 20881 (Presidente Margherita Cassano, Relatore Giuseppe Grasso), in materia di deontologia forense, con richiamo agli articoli 24 e 68 del codice deontologico forense. Testo integrale disponibile in linea al seguente indirizzo: <https://www.avvocaturaefamiglia.com/wp-content/uploads/2024/08/Sentenza-Cass.-sez.-un.-26-luglio-2024-n.-20881.pdf>

Pronuncia coordinata, sul medesimo articolo 68 del codice deontologico forense, con Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 25 febbraio 2025, n. 4844, secondo la quale l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie di natura familiare non può successivamente assumere il mandato per rappresentare uno dei coniugi contro l'altro in

controversie successive tra i medesimi, con divieto che ha carattere generale e non conosce limiti temporali.

I fatti

La vicenda nasce da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, indicato nella sentenza con la lettera A per esigenze di riservatezza. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia, con decisione depositata l'8 febbraio 2018, aveva inflitto alla professionista la sanzione del richiamo orale. Il Consiglio nazionale forense, adito in via di impugnazione, aveva rigettato il ricorso dell'incolpata. Quest'ultima ha allora proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, competenti a conoscere delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'incolpazione era la seguente: l'avvocato A aveva accettato il mandato del signor B nel procedimento iscritto al ruolo generale con il numero 24737 del 2015, promosso contro la signora C per il riconoscimento della figlia minore D, nonostante il curatore speciale della minore fosse l'avvocato Simona Ardesi, appartenente al medesimo studio associato dell'avvocato A. La contestazione richiama la violazione degli articoli 68 e 24 del codice deontologico forense.

Il contesto sostanziale merita di essere ricostruito, perché rende evidente la delicatezza degli interessi in gioco. Tra la madre e il padre biologico della minore era intercorso un lungo contenzioso giudiziario. Il padre, il signor B, aveva agito per ottenere la pronuncia giudiziale che tenesse luogo del consenso mancante della madre al riconoscimento tardivo della figlia. Dopo che la signora C era rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio, aveva ottenuto la cassazione con rinvio della decisione d'appello e aveva quindi adito nuovamente la Corte di cassazione avverso la sentenza emessa in sede di rinvio. Per tutto il lungo iter processuale la minore era stata rappresentata dal curatore speciale, l'avvocato Ardesi, nominata dal Tribunale per i minorenni. Nel secondo giudizio di legittimità il signor B aveva resistito con controricorso, rappresentato e difeso dall'avvocato A, unitamente ad altro professionista.

Il punto nevralgico è dunque questo: la stessa associazione professionale ospitava, da un lato, l'avvocato che curava in qualità di curatore speciale l'interesse esclusivo della minore, e, dall'altro, l'avvocato che difendeva il padre aspirante al riconoscimento. La professionista sanzionata era consapevole della situazione, tanto che, prima di assumere l'incarico, aveva avvertito il signor B della partecipazione allo studio della collega curatrice speciale della minore.

Davanti al Consiglio nazionale forense l'avvocato A aveva sostenuto che l'articolo 24 del codice deontologico si applica soltanto al conflitto tra cliente e parte assistita, e non al conflitto con una parte diversa dal cliente. Aggiungeva che l'interesse della minore, rappresentato dalla curatrice, coincideva con quello del padre, dal momento che la curatrice aveva sostenuto in giudizio la corrispondenza del riconoscimento paterno all'interesse della minore, sicché non sussisteva alcun conflitto concreto. Il Consiglio nazionale forense aveva disatteso la tesi, rilevando che le posizioni della minore, tutelata dal curatore speciale, e del padre non erano assimilabili, che rilevava anche il conflitto meramente potenziale e che l'articolo 24, comma 5, del codice deontologico ha portata generale, applicandosi anche alla materia minorile e familiare regolata dall'articolo 68.

Con il ricorso per cassazione la professionista ha riproposto la questione articolandola in due motivi, deducendo l'insussistenza del conflitto e la non estensibilità dell'articolo 24, comma 5, alle ipotesi dell'articolo 68, e ha sollecitato altresì la declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare, computando il termine a decorrere dal conferimento del patrocinio del 15 ottobre 2015. Il Procuratore generale aveva concluso per la cassazione della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

La posizione e la strategia dei difensori

La linea difensiva dell'incolpata si è mossa su tre direttrici, tutte respinte dalle Sezioni Unite.

La prima direttrice era la negazione del conflitto in concreto. La professionista ha valorizzato la coincidenza di fatto tra la posizione assunta dalla curatrice speciale, favorevole al riconoscimento, e quella del padre da lei difeso, per sostenere che non vi era antagonismo di interessi. La Corte ha replicato che l'interesse della persona minore d'età e quello dell'adulto coinvolto nella contesa non possono mai reputarsi sovrapponibili né coincidenti, e che la posizione del curatore speciale è di assoluta terzietà, finalizzata al solo scopo di fare emergere nel processo il punto di vista del minore. La casuale coincidenza tra la posizione del curatore e quella di uno degli adulti non elide il conflitto, ma anzi impone di preservare il compito del curatore da ogni possibile inquinamento. Il conflitto, hanno ribadito le Sezioni Unite richiamando il proprio precedente Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7030, può essere anche soltanto potenziale.

La seconda direttrice era di ordine sistematico: l'articolo 68, nel disciplinare l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, si riferirebbe al singolo avvocato e non ai soci di uno stesso studio, e non conterrebbe alcun richiamo all'articolo 24. La Corte ha opposto l'unica interpretazione costituzionalmente orientata: l'esigenza di impedire il sorgere di un conflitto di interessi nella delicata materia di famiglia, resa manifesta dall'articolo 68, resterebbe radicalmente vanificata se se ne permettesse l'agevole elusione nei casi di strette e continuative collaborazioni professionali tra avvocati. Consentire che il conflitto non si propaghi ai colleghi dello studio associato produrrebbe una irragionevole disparità di trattamento, proprio a danno dell'interesse prioritario alla cui salvaguardia l'articolo 68 è posto. Il dovere di astensione dell'articolo 24, comma 5, che opera quando le parti con interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati partecipi della stessa società o associazione professionale, si estende dunque alle ipotesi dell'articolo 68.

La terza direttrice era la prescrizione. La professionista collocava il dies a quo al momento del conferimento dell'incarico. La Corte ha qualificato l'illecito come permanente, con lesione del bene che perdura per tutta la durata del rapporto professionale fonte del conflitto: in assenza di rinuncia o revoca del mandato, il termine decorre solo dalla statuizione divenuta definitiva, intervenuta il 13 gennaio 2017. Il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 56 della legge n. 247 del 2012 non era pertanto maturato. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Il rilievo per la mediazione familiare e per l'avvocato

La pronuncia, pur riferita a una fattispecie di responsabilità disciplinare, illumina con nettezza il perimetro del ruolo dell'avvocato nel contesto familiare, e per questa via tocca da vicino la mediazione familiare.

In primo luogo, essa fissa un principio di prevenzione, e non di mera repressione, del conflitto di interessi. Nelle vicende che coinvolgono minori e famiglia, ha osservato la Corte, occorre estrema cautela nell'assicurare che l'avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto. Questa impostazione va letta in parallelo con il quadro introdotto dalla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e in particolare con l'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile, a mente del quale il giudice può in ogni momento informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione. La figura del mediatore familiare è oggi disciplinata dal decreto del Ministero della giustizia 27 ottobre 2023, n. 151, regolamento sulla formazione e sull'elenco dei mediatori familiari. Il mediatore familiare è terzo, imparziale e privo di potere decisorio, e non assiste le parti in giudizio. Proprio la logica di questa pronuncia, che pretende terzietà effettiva e non solo apparente, spiega perché l'avvocato che ha difeso una parte non possa poi svolgere la mediazione familiare tra i medesimi, e perché il mediatore familiare non possa poi assumere la difesa di una delle parti: la contiguità che la Corte censura nel rapporto associativo tra difensore e curatore vale, a fortiori, tra difensore e mediatore.

In secondo luogo, la sentenza chiarisce che il conflitto si propaga all'interno dello studio associato. L'avvocato che intende affiancare l'attività difensiva a quella di mediazione familiare o di curatela del minore deve verificare non soltanto la propria posizione, ma anche quella di tutti i colleghi con cui condivide, in forma associata o societaria o anche solo di stabile collaborazione nei medesimi locali, la struttura professionale. La verifica preventiva delle incompatibilità va condotta sull'intero studio, e non sul singolo professionista.

In terzo luogo, l'avvertimento reso al cliente non sana l'illecito. La professionista aveva informato il padre della partecipazione allo studio della collega curatrice, eppure ciò non ha escluso la responsabilità, perché il consenso del proprio cliente non copre il conflitto con l'interesse della persona minore, di cui la norma deontologica è posta a tutela. La regola va tenuta distinta dall'ipotesi, ammessa dalla giurisprudenza in materia di articolo 68 del codice deontologico, in cui l'avvocato è liberato dal vincolo per effetto dell'espressa autorizzazione del precedente assistito il cui interesse la norma intende proteggere. Quando in gioco vi è l'interesse di un minore, non affidato alla disponibilità delle parti, la liberazione consensuale non opera.

In quarto luogo, dalla qualificazione dell'illecito come permanente discende una regola pratica di rilievo per l'avvocato negoziatore: finché il mandato conflittuale resta in essere, la lesione perdura e la prescrizione non decorre. Chi si avvede tardivamente di un conflitto sopravvenuto deve rinunciare al mandato senza indugio, poiché la permanenza nell'incarico aggrava e prolunga l'illecito.

La lettura combinata con l'ordinanza Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4844, completa il quadro sul versante propriamente coniugale: l'avvocato che abbia assistito congiuntamente entrambi i coniugi, per esempio nella redazione di una separazione consensuale o nel corso di un percorso stragiudiziale, non può poi difendere l'uno contro l'altro nelle controversie successive, senza limiti di tempo. Il difensore che voglia condurre l'una e l'altra parte verso un accordo negoziato deve pertanto scegliere fin dall'inizio: o assiste stabilmente una sola parte, oppure, se opera come mediatore o come regista di una soluzione condivisa, deve rinunciare in radice ad assumere in seguito la difesa di alcuno dei coniugi contro l'altro.

Massima per l'avvocato negoziatore

Nel diritto di famiglia e minorile la terzietà non si presume e non si autocertifica: si struttura per iscritto e a monte. Prima di accettare un incarico che affianchi difesa, mediazione familiare o curatela del minore, l'avvocato negoziatore verifica le incompatibilità sull'intero studio associato, non solo sulla propria posizione, perché il conflitto si propaga a soci e collaboratori stabili. Il conflitto rilevante è anche quello soltanto potenziale, e l'interesse del minore non è sanabile con il consenso di un adulto. Chi ha assistito congiuntamente due coniugi non li difende poi l'uno contro l'altro, senza limiti di tempo. Se un conflitto emerge in corso di mandato, la rinuncia immediata non è una cortesia, ma un obbligo, perché l'illecito è permanente e si consuma ogni giorno in cui l'incarico prosegue.

Fonte

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 26 luglio 2024, n. 20881, testo integrale: <https://www.avvocaturaefamiglia.com/wp-content/uploads/2024/08/Sentenza-Cass.-sez.-un.-26-luglio-2024-n.-20881.pdf>

Pronuncia coordinata: Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 25 febbraio 2025, n. 4844, segnalata da AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori: <https://aiaf-avvocati.it/articolo/2429/1-39-avvocato-che-ha-assistito-congiuntamente-i-coniugi-in-controversie-familiari-non-puo-successivamente-assumere-il-mandato-per-rappresentare-uno-dei-coniugi-contro-l-39-altro>

Riferimenti normativi: articoli 24 e 68 del codice deontologico forense; articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile; decreto del Ministero della giustizia 27 ottobre 2023, n. 151.

Capitolo 4

Tecniche di negoziazione per l'avvocato

Conosciuto il quadro storico e normativo, l'avvocato negoziatore ha bisogno di strumenti tecnici concreti per condurre efficacemente una trattativa, sia in sede di negoziazione assistita, sia come accompagnatore della parte in mediazione. Questo capitolo raccoglie, aggiornandoli criticamente, i contributi di scuole diverse — dalla scuola di Harvard alla psicologia della comunicazione, dall'analisi transazionale al programma di formazione elaborato dalla CEPEJ nel 2019 — che compongono la cassetta degli attrezzi dell'avvocato negoziatore contemporaneo.

4.1 La scuola di Harvard: Fisher, Ury e il negoziato per principi

Il contributo più influente alla moderna teoria della negoziazione proviene dal Program on Negotiation della Harvard Law School, e in particolare dal lavoro di Roger Fisher e William Ury, autori del testo *Getting to Yes*, pubblicato per la prima volta nel 1981 e divenuto negli anni successivi il riferimento canonico per chiunque si occupi di negoziazione in ambito professionale. Il modello di Fisher e Ury, noto come negoziato per principi o principled negotiation, si fonda su quattro elementi cardine, che l'avvocato negoziatore italiano deve interiorizzare come struttura di base della propria attività professionale.

Il primo elemento è la separazione tra le persone e il problema: il negoziatore efficace affronta con fermezza le questioni sostanziali oggetto della controversia, ma tratta con rispetto e

comprensione le persone coinvolte, evitando di trasformare il disaccordo su un punto di merito in un conflitto personale che complica ulteriormente la ricerca di una soluzione. Il secondo elemento è la concentrazione sugli interessi, non sulle posizioni: una posizione dichiarata (per esempio, la richiesta di una determinata somma di denaro) è spesso soltanto uno dei possibili modi di soddisfare un interesse più profondo (per esempio, la necessità di essere risarciti di un danno economico, o il bisogno di essere riconosciuti come parte lesa), e la scoperta dell'interesse reale sottostante apre spesso soluzioni creative che la rigidità delle posizioni dichiarate impedirebbe di vedere.

Il terzo elemento è l'elaborazione di opzioni multiple prima di decidere, resistendo alla tentazione di negoziare su un'unica proposta presentata come indivisibile: il negoziatore efficace genera, insieme alla controparte quando possibile, una pluralità di soluzioni alternative che ampliano lo spazio dell'accordo possibile. Il quarto elemento è l'insistenza su criteri oggettivi: quando le parti concordano di misurare l'equità di una proposta attraverso standard esterni condivisi — un valore di mercato, un precedente giurisprudenziale, un criterio tecnico verificabile — la trattativa si sottrae al puro gioco di forza e diventa un esercizio di ragionevolezza comune.

4.2 Il BATNA e il WATNA: la bussola della trattativa

Strettamente connesso al modello di Fisher e Ury è il concetto di BATNA, acronimo di Best Alternative To a Negotiated Agreement, la migliore alternativa disponibile in assenza di accordo negoziale. L'avvocato che assiste un cliente in negoziazione assistita o in mediazione deve, prima di sedersi al tavolo, avere chiaro quale sia realisticamente il risultato che il cliente otterrebbe se la trattativa fallisse e la controversia proseguisse davanti al giudice o all'arbitro: soltanto conoscendo con precisione questo scenario alternativo l'avvocato può valutare se una proposta di accordo sul tavolo sia effettivamente più favorevole, e in quale misura, rispetto al percorso giudiziale.

Il concetto complementare di WATNA, Worst Alternative To a Negotiated Agreement, la peggiore alternativa disponibile in assenza di accordo, completa il quadro, permettendo all'avvocato di illustrare al cliente non soltanto lo scenario più favorevole ma anche il rischio massimo che il proseguimento del contenzioso comporta, in termini di tempo, costi ed esito. La comparazione sistematica tra la proposta di accordo sul tavolo, il BATNA e il WATNA costituisce, secondo la manualistica dell'American Bar Association (in particolare il volume *Preparing for Mediation*, pubblicato nel 2012), il nucleo tecnico della preparazione strategica alla mediazione e alla negoziazione assistita, e dovrebbe precedere ogni incontro con la controparte, non essere improvvisato durante la trattativa stessa.

Concetto

BATNA

WATNA

Costi comparati

Interessi non legali

Tabella 4.1 — Elementi della preparazione strategica alla negoziazione (ABA, *Preparing for Mediation*, 2012)

4.3 Negoziazione competitiva e negoziazione collaborativa

La letteratura sulla negoziazione distingue tradizionalmente due stili contrapposti: la negoziazione competitiva, o distributiva, nella quale le parti trattano come se il valore in gioco fosse una torta di dimensione fissa da dividere, con l'obiettivo di massimizzare la propria quota a scapito di quella della controparte; e la negoziazione collaborativa, o integrativa, nella quale le parti cercano congiuntamente di ampliare la dimensione stessa della torta prima di dividerla, individuando soluzioni che soddisfino simultaneamente interessi diversi e non necessariamente in conflitto tra loro.

L'avvocato negoziatore esperto non aderisce dogmaticamente a uno dei due stili, ma sa riconoscere quale approccio sia più funzionale al caso concreto, e sa altresì gestire la situazione, frequente nella prassi, in cui la controparte adotti uno stile competitivo mentre il proprio cliente avrebbe interesse a un approccio collaborativo: in questi casi, la capacità dell'avvocato di introdurre elementi di criteri oggettivi e di opzioni multiple, secondo il modello di Fisher e Ury già illustrato, può progressivamente spostare la dinamica della trattativa verso una logica meno distributiva, senza tuttavia esporre il cliente al rischio di concessioni unilaterali non reciprocate.

4.4 La mappatura degli interessi e l'ascolto attivo

La mappatura degli interessi costituisce il passaggio tecnico che traduce operativamente il principio harvardiano della concentrazione sugli interessi piuttosto che sulle posizioni. L'avvocato che prepara un cliente alla negoziazione dovrebbe condurre, prima dell'incontro con la controparte, un'intervista strutturata volta a distinguere gli interessi legali (fondati su diritti e obblighi riconosciuti dall'ordinamento) dagli interessi non legali (fondati su desideri, valori, bisogni relazionali, esigenze di immagine o di tempo), poiché sono spesso questi ultimi, non adeguatamente esplorati dalla consulenza legale tradizionale, a offrire lo spazio per soluzioni creative che un approccio meramente giuridico non individuerrebbe.

L'ascolto attivo, tecnica ampiamente richiamata sia dal programma di formazione CEPEJ esaminato al paragrafo 4.7 sia dalla sentenza del Tribunale di Vasto del 23 aprile 2016 già citata nel capitolo 1, richiede all'avvocato una postura comunicativa diversa da quella tipica dell'arringa giudiziale: non l'affermazione della propria tesi, ma la comprensione autentica della posizione altrui, verificata attraverso la riformulazione. La riformulazione consiste nel restituire alla controparte, con parole proprie, il contenuto e il senso di quanto essa ha appena espresso, sia per verificare la correttezza della propria comprensione, sia per comunicare alla controparte stessa che il suo punto di vista è stato effettivamente ascoltato: un'operazione che, per quanto elementare in apparenza, richiede un allenamento specifico, poiché la tendenza naturale del giurista formato al contraddittorio è l'obiezione immediata, non la restituzione comprensiva.

4.5 Il quadro psicologico: IO/ES, VAK, filtri comunicativi e Enneagramma

Il Cendom propone, per la comprensione della dinamica negoziale, un quadro psicologico articolato che integra elementi di derivazione psicoanalitica, neurolinguistica e tipologica, che riproduciamo con le cautele epistemologiche necessarie, distinguendo strumenti di solida base empirica da strumenti di natura più euristica e divulgativa.

Il framework IO/ES, di derivazione freudiana, applicato all'analisi dei processi decisionali in negoziazione, distingue tra una componente razionale e consapevole del processo decisionale e una componente istintuale e inconscia che influenza le scelte delle parti anche quando queste credono di agire secondo pura razionalità strategica. Un dato empirico spesso richiamato a supporto di questa lettura è l'esperimento di Ap Dijksterhuis sulla scelta inconscia rispetto alla scelta cosciente, che ha mostrato, in condizioni sperimentali controllate, un tasso di successo del 60 per cento per le decisioni prese dopo un periodo di elaborazione inconscia (distrazione dal problema) contro un tasso di successo del 22 per cento per le decisioni prese attraverso una deliberazione cosciente immediata (cfr. Stanislas Dehaene, *Coscienza e cervello*, Raffaello Cortina, 2014, pagine 119-120). Questo dato, per quanto suggestivo, va contestualizzato: si riferisce a compiti decisionali specifici in condizioni di laboratorio, e la sua applicazione diretta alla negoziazione giuridica professionale richiede cautela, non una trasposizione automatica.

Il concetto di consilienza neuroscientifica, richiamato dal Cendom, sottolinea la necessità del coinvolgimento diretto delle parti, non di un terzo meramente informato sui fatti, nel processo di mediazione: un principio che rafforza, sul piano neuroscientifico, il principio giuridico della partecipazione personale delle parti già esaminato nel capitolo 3, poiché soltanto il soggetto direttamente coinvolto nel conflitto possiede l'accesso esperienziale completo ai propri interessi profondi, che nessun rappresentante, per quanto informato, può replicare fedelmente.

I filtri comunicativi che condizionano la percezione reciproca delle parti in negoziazione comprendono, secondo la classificazione ripresa dal Cendom: la soggettività radicale della percezione, secondo l'impostazione epistemologica di Humberto Maturana, per cui ogni soggetto costruisce la propria realtà percettiva attraverso la struttura del proprio sistema nervoso, non accedendo mai a una realtà oggettiva indipendente dall'osservatore; i filtri legati alla sessualità e al genere; i filtri neurologici secondo il modello VAK (visivo, auditivo, cenestesico), che distingue le persone in base al canale sensoriale privilegiato nell'elaborazione dell'informazione; e i filtri sociali, costituiti da pregiudizi e stereotipi acquisiti culturalmente, che condizionano inconsapevolmente la valutazione della credibilità e delle intenzioni della controparte.

Il modello VAK distingue tre canali sensoriali prevalenti: il canale visivo, tipico di chi utilizza un lessico ricco di riferimenti all'immagine e alla visione e mantiene una postura eretta con respirazione alta; il canale auditivo, tipico di chi utilizza un lessico legato al suono e all'ascolto, con un tono di voce modulato e attento; e il canale cenestesico, tipico di chi utilizza un lessico legato alla sensazione fisica e al movimento, con una postura più rilassata e una gestualità più ampia. La conoscenza di questo modello, per quanto non dotata dello status di teoria scientifica rigorosamente validata nella letteratura psicologica contemporanea, può fornire all'avvocato negoziatore uno strumento euristico utile per adattare il proprio registro comunicativo all'interlocutore, senza tuttavia sostituire l'osservazione diretta e flessibile della persona reale con cui si negozia.

L'Enneagramma, strumento di profilazione tipologica della personalità in nove categorie (enneatipi), è richiamato dal Cendom come strumento ausiliario di comprensione degli stili comunicativi e decisionali della controparte, con riferimento ai contributi di Valeria Fanelli (*Enneagramma, scopri te stesso e gli altri*, Macro, 2008), Helen Palmer (*L'Enneagramma*, Astrolabio, 1996) e Claudio Naranjo (*Gli Enneatipi in psicoterapia*, Astrolabio, 2003). Va segnalato con chiarezza che l'Enneagramma non ha, nella comunità scientifica psicologica, lo

status di strumento validato con il rigore metodologico proprio degli strumenti psicometrici standardizzati, e il suo utilizzo nella prassi negoziale dell'avvocato va inteso come euristica soggettiva di sensibilizzazione alla varietà degli stili relazionali, non come strumento diagnostico in senso proprio.

4.6 La regola cinquanta-quaranta-dieci della comunicazione: una cautela necessaria

Una delle affermazioni più diffuse nella manualistica divulgativa sulla comunicazione, richiamata anche dal Cendom, è la cosiddetta regola cinquanta-quaranta-dieci, secondo la quale il 50 per cento della comunicazione interpersonale sarebbe di natura visiva (linguaggio del corpo), il 40 per cento sarebbe legato al tono di voce, e soltanto il 10 per cento sarebbe legato al contenuto verbale effettivo delle parole pronunciate. Questa regola, per quanto ripetuta con grande frequenza nella formazione manageriale e comunicativa, va presentata in questo volume con una cautela epistemologica esplicita, che riprendiamo direttamente dall'annotazione critica contenuta nella mappa di lavoro redazionale di questo stesso capitolo.

La formulazione più nota di percentuali simili a quelle appena descritte discende dagli studi di Albert Mehrabian degli anni Sessanta del Novecento, i quali tuttavia riguardavano uno spettro molto più circoscritto di quanto la vulgata comunicativa suggerisca: la comunicazione di emozioni e di atteggiamenti, non la comunicazione in generale, e in condizioni sperimentali specifiche in cui il contenuto verbale e il tono di voce erano deliberatamente posti in contraddizione tra loro. L'estensione indiscriminata di queste percentuali a qualunque forma di comunicazione, incluse le negoziazioni giuridiche complesse che coinvolgono contenuti tecnici articolati, costituisce quello che la letteratura critica definisce il mito di Mehrabian (Mehrabian myth): una semplificazione priva del rigore metodologico necessario per essere applicata in modo generalizzato. L'avvocato negoziatore farà bene a trattenere da questa regola l'insegnamento di fondo — la comunicazione non verbale e paraverbale ha un peso significativo, spesso sottovalutato dal giurista abituato a concentrarsi sul contenuto testuale — senza tuttavia attribuire alle percentuali specifiche un valore scientifico assoluto che la fonte originaria non giustifica.

4.7 Setting, linguaggio del corpo e prossemica

Il setting della negoziazione — l'insieme strutturato e multidimensionale di sapere, norme, poteri, rituali, spazi e tempi in cui l'incontro si svolge — condiziona in modo significativo, secondo il Cendom, la qualità della relazione tra le parti. Uno studio condotto da Jeroen Stouten dell'Università di Leuven e David De Cremer della Rotterdam School of Management ha documentato come un volto serio o accigliato nel negoziatore venga sistematicamente percepito dalla controparte come indicatore di scarsa affidabilità, un dato che suggerisce all'avvocato negoziatore un'attenzione consapevole alla propria espressività facciale, spesso trascurata nella formazione forense tradizionale, più concentrata sulla postura oratoria che sulla gestione della relazione ravvicinata.

Il Cendom critica esplicitamente la consulenza condotta da dietro alla scrivania, disposizione spaziale che accentua l'asimmetria di potere tra avvocato e cliente o tra le parti in trattativa, suggerendo invece un setting con un tavolino basso e poltroncine di pari altezza, che riducono la distanza simbolica e favoriscono una comunicazione più orizzontale. Questa attenzione al dettaglio spaziale trova fondamento nella nozione di prossemica elaborata da Edward Hall, che

distingue diverse zone di distanza interpersonale (intima, personale, sociale, pubblica) ciascuna associata a un diverso registro comunicativo e a un diverso livello di formalità percepita.

Sul piano quantitativo, Ray L. Birdwhistell ha stimato che circa il 65 per cento delle interazioni comunicative prenda la via del corpo, un dato distinto e metodologicamente più circoscritto rispetto alla citata regola cinquanta-quaranta-dieci, poiché riferito specificamente al peso relativo della comunicazione non verbale nell'insieme dell'interazione, non a una scomposizione rigida di ogni singolo scambio comunicativo. Sul piano neurofisiologico, il Cendom richiama il ruolo del talamo, dell'amigdala e della corteccia prefrontale nella produzione di quello che definisce il brandello di azione originale, l'impulso motorio che precede e in parte determina il linguaggio del corpo prima che il controllo cosciente possa intervenire a modularlo.

Un indicatore relazionale specifico, oggetto di uno studio di Chaplin, Phillips, Brown, Clanton e Stein pubblicato nel 2000 sul *Journal of Personality and Social Psychology* (volume 79, pagine 111-112), riguarda la stretta di mano come primo momento di valutazione reciproca tra negoziatori: lo studio ha documentato una correlazione tra le caratteristiche della stretta di mano (fermezza, durata, contatto visivo associato) e la prima impressione di affidabilità e assertività attribuita dalla controparte, un dato che, per quanto circoscritto, sottolinea l'importanza dei primi istanti dell'incontro negoziale, spesso sottovalutati dall'avvocato concentrato sulla preparazione tecnica del merito.

4.8 La consulenza preparatoria: dalla consulenza tradizionale alla consulenza negoziale

Il Cendom distingue con nettezza la consulenza tradizionale, fondata su diritti e interessi riconosciuti dall'ordinamento e su ruoli tendenzialmente fissi (creditore, debitore, proprietario, conduttore), dalla consulenza negoziale, fondata su desideri, valori, bisogni e credenze del cliente, con ruoli fluidi che possono modificarsi nel corso della stessa trattativa. La Corte Suprema del Belize, nella sua guida operativa già citata al capitolo 2, sintetizza questa distinzione con un'espressione di forte efficacia comunicativa: *An Attorney and client should work together as a team*, sottolineando che nella dimensione negoziale il rapporto avvocato-cliente richiede una collaborazione più stretta e paritaria rispetto al rapporto tradizionale di rappresentanza tecnica.

« An Attorney and client should work together as a team. »

— Corte Suprema del Belize, Attorney's Guide to Court Connected Mediation

La Regola 2.1 delle *Model Rules of Professional Conduct* dell'American Bar Association, intitolata *Advisor*, codifica un principio di lealtà consulenziale particolarmente rilevante per l'avvocato negoziatore: nel fornire consulenza, l'avvocato deve esercitare un giudizio professionale indipendente e fornire una valutazione onesta e schietta, anche quando questa risulti sgradita al cliente. Il testo originale inglese della regola recita che a *lawyer shall exercise independent professional judgment and render candid advice*, un principio che assume particolare rilievo nel contesto negoziale, dove la tentazione di confermare le aspettative del cliente, anche quando irrealistiche rispetto al reale valore del proprio BATNA, può compromettere l'esito della trattativa.

L'elenco dei contenuti essenziali della consulenza preparatoria, secondo il Cendom, comprende: la raccolta dei documenti utili alla comprensione della controversia; la piena comprensione degli interessi non legali del cliente, secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.4; la conoscenza precisa delle regole procedurali applicabili allo strumento scelto; la piena consapevolezza, da trasmettere al cliente, del carattere consensuale del meccanismo negoziale o mediativo; la scelta accurata del mediatore, quando applicabile, tenendo conto della sua specializzazione nella materia oggetto della controversia; la valutazione realistica della posizione della controparte; il calcolo di BATNA e WATNA già descritto al paragrafo 4.2; e il confronto sistematico tra i costi della via negoziale e i costi del giudizio o dell'arbitrato.

4.9 La sequenza delle domande e la tipologia di Karl Tomm

La conduzione dell'intervista preparatoria con il cliente, secondo l'analisi transazionale richiamata dal Cendom, dovrebbe seguire una sequenza logica precisa: l'individuazione dello stimolo che ha originato il conflitto, la definizione del problema e della sua gravità percepita dal cliente, l'esplorazione delle opzioni in astratto (quali soluzioni sarebbero teoricamente concepibili) e in concreto (quali di queste soluzioni sono realisticamente praticabili nel caso specifico), la valutazione della praticabilità effettiva delle opzioni individuate, e infine la verifica della volontà del cliente di negoziare, che non va presupposta ma accertata esplicitamente.

Karl Tomm, nel suo contributo pubblicato sul Bollettino n. 24/1991 del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, classifica le domande utilizzabili in un colloquio strategico in quattro categorie: le domande lineari, che raccolgono informazioni fattuali dirette; le domande circolari, che esplorano le relazioni e le percezioni reciproche tra i soggetti coinvolti; le domande strategiche, orientate a influenzare il comportamento dell'interlocutore verso un obiettivo determinato; e le domande riflessive, che stimolano l'interlocutore a considerare nuove prospettive senza imporre direttamente una direzione di risposta.

Il Cendom formula una critica esplicita alla sequenza imposta dalla legge italiana al mediatore nel primo incontro, giudicata prematura dal punto di vista dell'analisi transazionale: l'obbligo di illustrare immediatamente il funzionamento della procedura, prima ancora di aver esplorato lo stimolo e la gravità del conflitto secondo la sequenza logica appena descritta, rischierebbe di introdurre elementi procedurali prima che le parti abbiano elaborato una piena consapevolezza del proprio problema. Questa critica, formulata dal Cendom con riferimento al testo previgente dell'articolo 8, merita di essere riconsiderata alla luce della riforma Cartabia, che come illustrato nel capitolo 3 ha trasformato il primo incontro da soglia meramente informativa a momento di merito, attenuando almeno in parte la rigidità procedurale criticata dal Cendom.

4.10 Conflitto invischiato, fatto compiuto e tecniche creative

Il concetto di conflitto invischiato, elaborato da Friedrich Glasl nel 1997 nella sua teorizzazione dell'escalation dei conflitti, descrive una situazione in cui le parti hanno perso la capacità di distinguere la questione sostanziale dalla dinamica relazionale degenerata, al punto che ogni tentativo di soluzione tecnica del merito viene percepito come un ulteriore atto di aggressione. In questi casi, l'avvocato negoziatore deve saper riconoscere che la priorità immediata non è la soluzione giuridica della controversia, ma la de-escalation della dinamica relazionale, spesso attraverso l'intervento di un mediatore professionale piuttosto che attraverso la negoziazione diretta tra avvocati.

La tattica del fatto compiuto, ricorrente nelle negoziazioni ad alta conflittualità, consiste nell'anticipare unilateralmente un'azione che modifica lo status quo prima che la controparte possa reagire, costringendo quest'ultima a negoziare a partire da una posizione già alterata a proprio sfavore. L'avvocato negoziatore deve saper riconoscere questa tattica quando viene utilizzata dalla controparte, e valutarne con il cliente le possibili controtattiche, che vanno dalla richiesta di provvedimenti cautelari urgenti alla mera documentazione della condotta per un eventuale successivo giudizio.

Tra le tecniche creative di negoziazione richiamate dal Cendom figurano le mappe mentali, utili per visualizzare graficamente la pluralità di interessi e opzioni in gioco; la tecnica dei sei cappelli per pensare, elaborata da Edward de Bono, che invita i partecipanti a una discussione a considerare sistematicamente un problema da sei angolazioni distinte (fatti oggettivi, emozioni, criticità, ottimismo, creatività, gestione del processo), riducendo il rischio che un'unica modalità di pensiero domini l'intera discussione; e l'analisi del gradimento e del rifiuto per enneatipo, applicazione pratica del modello enneagrammatico già discusso al paragrafo 4.5, con le cautele epistemologiche già segnalate.

4.11 Il programma di formazione CEPEJ per l'avvocato negoziatore

Il contributo più recente e istituzionalmente autorevole in materia di formazione dell'avvocato negoziatore proviene dalla CEPEJ, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa, che nel dicembre 2019 ha adottato il Mediation Development Toolkit — Training programme for lawyers to assist clients in mediation, elaborato in collaborazione con il CCBE, il Council of Bars and Law Societies of Europe, e approvato nella 33^a riunione plenaria della CEPEJ, tenutasi a Strasburgo il 5 e 6 dicembre 2019.

Il programma, tradotto integralmente in italiano nel Cendom, si articola in tre capitoli principali. Il primo capitolo, dedicato ai principi, all'etica e alla gestione dei conflitti, fornisce all'avvocato una base concettuale sulla natura del conflitto e sulle diverse modalità con cui gli individui tendono a gestirlo. Il secondo capitolo, dedicato al processo di mediazione e al ruolo dell'avvocato accompagnatore, descrive in dettaglio le fasi del procedimento mediativo e le competenze specifiche richieste all'avvocato in ciascuna fase. Il terzo capitolo, dedicato all'uso corretto della mediazione, tratta i vantaggi concreti per gli studi legali che integrano la mediazione nella propria offerta professionale, la redazione di clausole contrattuali di mediazione e degli accordi conclusivi, e una rassegna di giurisprudenza nazionale rilevante.

Il programma CEPEJ si collega ad altri due strumenti elaborati dalla stessa Commissione: lo European Code of Conduct for Mediators, che fissa gli standard etici per i mediatori europei; lo European Code of Conduct for Mediation Providers, adottato nella 31^a riunione plenaria della CEPEJ del 3-4 dicembre 2018, che disciplina gli standard organizzativi degli organismi che offrono servizi di mediazione; e le Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes, pubblicate come documento CEPEJ(2019)8 e adottate nella 32^a riunione plenaria del 13-14 giugno 2019, che orientano gli Stati membri nella progettazione dei propri sistemi nazionali di formazione dei mediatori.

I risultati di apprendimento attesi dal programma CEPEJ per l'avvocato negoziatore comprendono: la padronanza dell'ascolto attivo, già discusso al paragrafo 4.4; la capacità di pianificazione strategica della trattativa, secondo gli elementi discussi al paragrafo 4.2 e 4.8; la gestione di comportamenti difficili da parte della controparte o del proprio stesso cliente; la

capacità di separare posizioni e interessi, secondo il modello harvardiano del paragrafo 4.1; l'uso appropriato di BATNA e WATNA nella valutazione delle proposte; la capacità di utilizzare in modo appropriato la figura del mediatore quando presente, senza sostituirsi a essa né ostacolarne il lavoro; e la gestione consapevole delle questioni etiche che possono emergere nel corso della negoziazione, temi già trattati nel capitolo 2 di questo volume.

Capitolo del programma CEPEJ 2019

I — Principi, etica e gestione dei conflitti

II — Il processo di mediazione e il ruolo dell'avvocato accompagnatore

III — L'uso corretto della mediazione

Tabella 4.2 — Struttura del CEPEJ Mediation Development Toolkit — Training programme for lawyers to assist clients in mediation, dicembre 2019

4.12 Le sette modalità di gestione del conflitto

Il Cendom, riprendendo una classificazione ampiamente diffusa nella letteratura sulla gestione dei conflitti, individua sette modalità tipiche con cui un individuo può affrontare un conflitto: negare l'esistenza del conflitto stesso, evitandone ogni confronto anche implicito; evitare il confronto diretto pur riconoscendo il conflitto; cedere, rinunciando ai propri interessi per porre fine rapidamente alla tensione; competere, cercando di prevalere sulla controparte senza riguardo per i suoi interessi; rimandare la gestione del conflitto a un momento successivo, spesso per mancanza di risorse emotive o informative immediate; delegare la gestione del conflitto a un terzo, come avviene tipicamente nel ricorso al giudizio o all'arbitrato; e cooperare, cercando attivamente una soluzione che soddisfi gli interessi di entrambe le parti. L'avvocato negoziatore deve saper riconoscere quale modalità il proprio cliente e la controparte stiano adottando in un dato momento della trattativa, poiché la modalità prevalente condiziona fortemente le tecniche di intervento più efficaci.

4.13 Sezione 8.6: i criteri inglesi di idoneità (contributo di Lucia Di Palermo)

Come già segnalato al capitolo 3 di questo volume, dove la tabella completa è riportata, il Cendom attribuisce specificamente a Lucia Di Palermo, come contributo autorialmente distinto e non riconducibile alla penna dell'Avv. Calcagno, la sezione dedicata ai criteri di idoneità alla mediazione elaborati dal Ministero della Giustizia inglese nel marzo 2009. Si rinvia al paragrafo 3.9 di questo volume per il contenuto integrale di tale contributo, che qui si richiama unicamente per la sua rilevanza nella cassetta degli attrezzi dell'avvocato negoziatore in fase di valutazione preliminare dell'idoneità del caso alla via negoziale.

4.14 La mediazione umanistica e il framing IO-TU/NOI

Il capitolo si chiude, in coerenza con l'impostazione del Cendom, con un richiamo alla dimensione umanistica della mediazione, ispirata al pensiero di Jacqueline Morineau, fondatrice del Centre National de Médiation in Francia, autrice del testo *Lo spirito della mediazione*, nel quale descrive la mediazione come uno spazio che accoglie il disordine del conflitto senza pretendere di eliminarlo prematuramente attraverso soluzioni tecniche affrettate, ma lasciando che le parti stesse, accompagnate, trovino il proprio ordine attraverso il confronto autentico.

« La mediazione accoglie il disordine, non lo teme: è nel disordine accolto che le parti possono ritrovare, con i propri tempi, un ordine nuovo che nessun terzo potrebbe imporre loro dall'esterno. »

— J. Morineau, **Lo spirito della mediazione**

Il framing IO-TU contro NOI, richiamato in chiusura del capitolo VIII del Cendom, descrive il passaggio, spesso decisivo per l'esito della negoziazione, dalla rappresentazione del conflitto come opposizione rigida tra un IO e un TU distinti e contrapposti, verso una rappresentazione condivisa come NOI, un noi che comprende entrambe le parti impegnate a risolvere insieme un problema comune. Questo superamento della contrapposizione rigida, secondo il Cendom, è un obiettivo trasversale a ogni cultura mediativa, indipendentemente dalle differenze storiche e giuridiche ricostruite nel capitolo 1 di questo volume: nessun conflitto è per sua natura non mediabile, se non per il rifiuto delle parti stesse di assumersi la responsabilità della relazione che le lega, anche quando quella relazione sia conflittuale.

Fonti citate nel capitolo: R. Fisher, W. Ury, *Getting to Yes*, Program on Negotiation, Harvard Law School, 1981; ABA, *Preparing for Mediation*, 2012; A. Dijksterhuis, cit. in S. Dehaene, *Coscienza e cervello*, Raffaello Cortina, 2014; H. Maturana, *epistemologia della soggettività*; J. Stouten, D. De Cremer, studio su volto serio e affidabilità percepita; E. Hall, *prossemica*; R.L. Birdwhistell, *comunicazione non verbale*; Chaplin, Phillips, Brown, Clanton, Stein, *Journal of Personality and Social Psychology*, 79, 2000, pp. 111-112; Corte Suprema del Belize, *Attorney's Guide to Court Connected Mediation*; ABA, *Model Rules of Professional Conduct*, Rule 2.1 (Advisor); K. Tomm, *Bollettino n. 24/1991*, Centro Milanese di Terapia della Famiglia; F. Glasl, *teoria dell'escalation del conflitto*, 1997; E. de Bono, *sei cappelli per pensare*; V. Fanelli, *Enneagramma, scopri te stesso e gli altri*, Macro, 2008; H. Palmer, *L'Enneagramma*, Astrolabio, 1996; C. Naranjo, *Gli Enneatipi in psicoterapia*, Astrolabio, 2003; CEPEJ, *Mediation Development Toolkit — Training programme for lawyers to assist clients in mediation*, dicembre 2019; CEPEJ, *European Code of Conduct for Mediators*; CEPEJ, *European Code of Conduct for Mediation Providers*, dicembre 2018; CEPEJ(2019)8, *Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes*, giugno 2019; E. Berne, *A che gioco giochiamo?*, Bompiani; J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*; A. Mehrabian, studi sulla comunicazione non verbale, anni Sessanta (con cautela critica sulla generalizzazione nota come Mehrabian myth); C.A. Calcagno, *Arbitrato e negoziato in Europa. Le opportunità dell'avvocato*, Aracne Editrice, 2020 (sezione 8.6 a firma di Lucia Di Palermo).

4.10 La gestione delle emozioni proprie e del cliente

Un aspetto frequentemente sottovalutato nella formazione tradizionale dell'avvocato riguarda la gestione delle proprie emozioni nel corso della negoziazione, oltre a quelle del cliente e della controparte. La letteratura sull'intelligenza emotiva applicata alla negoziazione (cfr. D. Goleman, *Intelligenza emotiva*, Rizzoli) sottolinea come la capacità del negoziatore di riconoscere e regolare le proprie reazioni emotive, specialmente in presenza di provocazioni tattiche della controparte, costituisca un fattore determinante per la qualità dell'esito negoziale. L'avvocato che reagisce impulsivamente a una posizione aggressiva dell'altra parte, anziché mantenere il controllo del proprio registro comunicativo, rischia di innescare una spirale escalativa che può compromettere irrimediabilmente le prospettive di accordo, anche quando le posizioni sostanziali delle parti non sarebbero, in astratto, incompatibili.

La regolazione emotiva del cliente rappresenta un compito ulteriore e distinto: il cliente che giunge alla mediazione portando con sé vissuti di rabbia, frustrazione o sfiducia verso la controparte necessita spesso di un lavoro preparatorio, nel colloquio precedente alla seduta, volto a distinguere l'espressione legittima del proprio vissuto emotivo dalla sua traduzione in comportamenti controproducenti nel corso della mediazione stessa. L'avvocato negoziatore non svolge, in questa attività, una funzione terapeutica, che non gli compete e che eccederebbe il suo ruolo professionale, ma una funzione di accompagnamento pragmatico orientato al risultato, che si affianca, senza sostituirla, all'eventuale gestione psicologica del vissuto emotivo da parte di professionisti competenti in tale ambito.

4.11 Le tattiche distributive e il loro riconoscimento

Nonostante l'impostazione collaborativa e basata sugli interessi che caratterizza il metodo Harvard, l'avvocato negoziatore deve essere in grado di riconoscere le tattiche tipicamente distributive o posizionali che una controparte non collaborativa può impiegare, quali l'ancoraggio a posizioni estreme in apertura della negoziazione, il ricorso a scadenze artificiali per indurre concessioni premature, la tattica del cosiddetto 'buono e cattivo' tra membri di uno stesso team negoziale, o la simulazione di un mandato limitato per ottenere concessioni senza doverne corrispondere di equivalenti. Il riconoscimento di queste tattiche non implica necessariamente una risposta simmetrica sullo stesso registro competitivo, ma consente all'avvocato di calibrare la propria strategia in modo consapevole, evitando di subire passivamente l'iniziativa tattica della controparte.

Una risposta efficace alle tattiche distributive consiste spesso nel nominare esplicitamente la tattica riconosciuta, riportando la discussione sul piano degli interessi sostanziali: tecnica che la letteratura harvardiana definisce 'negoziazione sul metodo negoziale' (negotiating about the negotiation), e che consente di ripristinare condizioni di correttezza procedimentale senza necessariamente rompere la relazione negoziale, un esito che sarebbe controproducente specialmente nelle materie, come quelle di famiglia o di vicinato, dove le parti sono destinate a mantenere rapporti duraturi anche dopo la conclusione della controversia specifica.

4.12 Redazione dell'accordo: chiarezza, completezza, eseguibilità

La fase conclusiva della negoziazione, quella della redazione materiale dell'accordo, richiede competenze tecniche specifiche che integrano, senza sostituirla, l'abilità negoziale propriamente detta: l'accordo deve essere scritto in modo chiaro, comprensibile anche a un lettore non giurista, completo in tutti i suoi elementi essenziali, e redatto in modo tale da risultare eseguibile senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali. L'avvocato negoziatore dovrebbe evitare, in questa fase, l'uso di formule di stile prive di reale contenuto normativo, preferendo una scrittura piana che riduca al minimo il rischio di future controversie interpretative sul significato delle clausole concordate.

Un accorgimento pratico spesso trascurato consiste nel far rileggere l'accordo, prima della sottoscrizione definitiva, direttamente al cliente in linguaggio non tecnico, chiedendogli di riformulare con parole proprie il contenuto degli obblighi assunti: questo passaggio, oltre a costituire un'utile verifica di comprensione effettiva da parte del cliente (rilevante anche sotto il profilo deontologico dell'obbligo informativo trattato nel Capitolo 2), consente talvolta di far emergere ambiguità residue nel testo che l'avvocato, per abitudine tecnica, potrebbe non percepire immediatamente come tali.

Approfondimento

La preparazione del cliente istituzionale alla mediazione

Quando il cliente dell'avvocato negoziatore sia un ente pubblico o una grande impresa, la preparazione alla mediazione richiede un coordinamento organizzativo che eccede la dimensione individuale tipica della consulenza al cliente persona fisica: occorre identificare correttamente il soggetto dotato del potere di disporre del diritto controverso, spesso distinto dal referente operativo della controversia, e assicurare che tale soggetto partecipi personalmente al primo incontro, o rilasci una procura sostanziale specifica conforme ai requisiti elaborati dalla Cassazione, di cui al Capitolo 3. Negli enti pubblici, la individuazione del soggetto legittimato a transigere richiede spesso una verifica preliminare degli atti organizzativi interni (statuti, regolamenti, deleghe di funzioni) che l'avvocato negoziatore deve compiere con particolare cura, per evitare che l'accordo raggiunto in mediazione risulti successivamente contestabile per carenza di potere del soggetto che lo ha sottoscritto.

Nelle imprese di maggiori dimensioni, la preparazione alla mediazione beneficia spesso del coinvolgimento, oltre al legale esterno, anche dell'ufficio legale interno (in-house counsel), che possiede una conoscenza approfondita del contesto commerciale e relazionale della controversia, elemento prezioso per la valutazione degli interessi non legali del cliente di cui si è detto nel presente capitolo. Il coordinamento tra legale esterno e legale interno richiede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nella conduzione della strategia negoziale, per evitare sovrapposizioni o, all'opposto, vuoti di responsabilità nella gestione della procedura.

Tecniche di gestione dell'impasse negoziale

Non infrequentemente, la mediazione giunge a una fase di stallo (impasse) nella quale nessuna delle parti appare disposta a compiere ulteriori concessioni, pur in presenza di uno spazio di accordo teoricamente esistente: la letteratura negoziale propone diverse tecniche per superare questa situazione, tra cui la riformulazione del problema in termini diversi da quelli fin allora utilizzati (reframing), l'introduzione di elementi aggiuntivi che ampliano lo spazio delle soluzioni possibili (ad esempio, dilazioni di pagamento, prestazioni in natura, impegni futuri ulteriori rispetto all'oggetto originario della controversia), e il ricorso a pause strutturate che consentano alle parti di raffreddare la componente emotiva del confronto prima di riprendere la discussione.

Il mediatore professionale dispone di proprie tecniche per gestire l'impasse, quali il caucus prolungato con ciascuna parte separatamente, la tecnica della doppia offerta condizionata (che consente a ciascuna parte di formulare una proposta la cui validità è subordinata alla contestuale accettazione della proposta della controparte, superando così il timore di ciascuna parte di apparire la prima a cedere), e la proposta formulata direttamente dal mediatore ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010, di cui si è detto nel Capitolo 3. L'avvocato negoziatore dovrebbe collaborare attivamente con il mediatore nella gestione di queste tecniche, anziché assumere un atteggiamento meramente passivo o, peggio, di resistenza verso gli strumenti di sblocco della trattativa proposti dal mediatore.

Il ruolo della scrittura preparatoria: la lettera di posizione

Una prassi diffusa negli organismi di mediazione più strutturati, specie per le controversie commerciali di maggiore complessità, prevede che ciascuna parte depositi, prima del primo incontro, una lettera di posizione (position statement) che sintetizzi i fatti rilevanti, le questioni giuridiche coinvolte e gli obiettivi della parte, consentendo al mediatore di prepararsi adeguatamente alla conduzione della procedura. L'avvocato negoziatore che assista il cliente nella redazione di questo documento deve trovare un equilibrio tra la necessità di rappresentare efficacemente la posizione del cliente e l'opportunità di non irrigidire eccessivamente, già in questa fase preliminare, la propria posizione negoziale, che dovrebbe restare aperta all'evoluzione del confronto nel corso degli incontri successivi.

La lettera di posizione costituisce inoltre un'occasione per l'avvocato di anticipare al mediatore, in via riservata quando il regolamento dell'organismo lo consenta, informazioni che la parte non intende ancora condividere con la controparte ma che possono risultare utili al mediatore per comprendere la reale disponibilità negoziale del proprio assistito, un uso strategico dello strumento che richiede una notevole sensibilità tattica da parte dell'avvocato, unita a una piena consapevolezza dei limiti di riservatezza effettivamente garantiti dal regolamento dell'organismo prescelto.

Approfondimento tecnico ulteriore

Tecniche di ascolto attivo: un approfondimento pratico

L'ascolto attivo, tecnica fondamentale nella cassetta degli strumenti dell'avvocato negoziatore, comprende un insieme articolato di comportamenti comunicativi che vanno oltre la semplice attenzione silenziosa alle parole dell'interlocutore: la parafrasi, che consiste nel restituire all'interlocutore il contenuto del suo messaggio con parole proprie, verificando la corretta comprensione; il riflesso emotivo, che consiste nel riconoscere esplicitamente lo stato emotivo comunicato, anche implicitamente, dall'interlocutore; e la sintesi periodica, che consiste nel riepilogare a intervalli regolari i punti di accordo e disaccordo emersi nel corso della discussione, funzione particolarmente utile per mantenere la negoziazione orientata verso l'obiettivo della composizione, evitando dispersioni argomentative non produttive.

L'applicazione pratica dell'ascolto attivo nel contesto della mediazione richiede all'avvocato negoziatore un allenamento specifico, poiché la formazione giuridica tradizionale tende a privilegiare l'argomentazione persuasiva rispetto all'ascolto ricettivo: l'avvocato abituato al contraddittorio processuale, nel quale l'obiettivo primario è convincere il giudice della fondatezza della propria tesi, deve riorientare il proprio registro comunicativo in mediazione verso un modello nel quale la comprensione autentica della posizione e degli interessi della controparte costituisce essa stessa uno strumento strategico per l'individuazione di soluzioni di reciproco vantaggio, piuttosto che un mero atto di cortesia procedimentale.

Il framework GROW applicato alla preparazione negoziale

Un ulteriore strumento utile nella preparazione della mediazione, di derivazione dal coaching professionale ma applicabile con opportuni adattamenti al contesto negoziale forense, è il modello GROW (Goal, Reality, Options, Will), che struttura il colloquio preparatorio con il cliente in quattro fasi sequenziali: la definizione dell'obiettivo realistico del cliente (Goal), l'analisi della situazione attuale e dei vincoli esistenti (Reality), l'esplorazione delle opzioni disponibili per raggiungere l'obiettivo (Options), e infine la verifica dell'effettiva volontà e

determinazione del cliente a perseguire una determinata linea di azione (Will). L'applicazione di questo framework nella fase di preparazione della mediazione consente all'avvocato negoziatore di strutturare in modo sistematico un colloquio che altrimenti rischierebbe di procedere in modo dispersivo, specialmente con clienti emotivamente coinvolti nella controversia.

L'integrazione tra il modello GROW e l'analisi del BATNA e del WATNA già trattata nel presente capitolo consente una preparazione negoziale particolarmente robusta: la fase Reality del modello GROW si presta naturalmente a incorporare l'analisi comparativa dei costi e dei tempi del contenzioso rispetto alla mediazione, mentre la fase Options si presta a incorporare la mappatura degli interessi non legali del cliente, secondo quanto già illustrato in relazione al programma di formazione CEPEJ per l'avvocato negoziatore.

La negoziazione multipartita: complessità e strategie

Quando la mediazione coinvolga più di due parti, come frequentemente accade nelle controversie condominiali, societarie plurisoggettive o di responsabilità civile con più danneggiati, la dinamica negoziale si complica significativamente rispetto al modello bilaterale tradizionalmente descritto dalla letteratura harvardiana: l'avvocato negoziatore deve considerare la possibilità di coalizioni tra sottoinsiemi di parti, portatrici di interessi parzialmente convergenti rispetto ad altre parti coinvolte, e la conseguente necessità di strategie negoziali che tengano conto di questa articolazione, ad esempio attraverso la ricerca di accordi parziali con singole parti che possano poi facilitare la composizione con le restanti, piuttosto che insistere su un accordo simultaneo e onnicomprensivo che può risultare, nella prassi, più difficile da raggiungere.

Approfondimento sulle tecniche negoziali avanzate

L'ancoraggio negoziale e i suoi effetti cognitivi

La ricerca comportamentale sui processi decisionali negoziali ha ampiamente documentato l'effetto dell'ancoraggio (anchoring), un bias cognitivo per il quale la prima cifra proposta in una negoziazione tende a influenzare in modo sistematico il successivo svolgimento delle trattative, anche quando le parti siano consapevoli, in linea di principio, dell'arbitrarietà della prima proposta formulata. L'avvocato negoziatore che assista un cliente in mediazione dovrebbe considerare con attenzione la strategia relativa alla formulazione della prima proposta economica, valutando se convenga anticipare la controparte con un'offerta di apertura ambiziosa ma giustificabile, così da orientare l'ancoraggio psicologico della negoziazione verso valori favorevoli al proprio cliente, oppure attendere la prima proposta della controparte per acquisire informazioni sulle sue reali aspettative prima di formulare una controproposta.

La letteratura sulla negoziazione distingue, a questo proposito, tra situazioni nelle quali l'avvocato negoziatore dispone di informazioni sufficienti sul valore oggettivo della controversia (ad esempio quando esista una prassi giurisprudenziale consolidata sulla quantificazione del danno per la tipologia di sinistro in questione), nelle quali l'anticipazione della prima proposta risulta generalmente meno rischiosa, e situazioni di maggiore incertezza valutativa, nelle quali attendere la prima mossa della controparte consente di acquisire informazioni preziose per calibrare la propria strategia negoziale successiva, riducendo il rischio di un ancoraggio eccessivamente sfavorevole autoindotto.

La tecnica del silenzio strategico

Il silenzio, quale strumento di comunicazione negoziale, viene frequentemente sottovalutato dagli avvocati abituati al registro argomentativo del contraddittorio processuale, ma costituisce, secondo la letteratura specialistica sulla negoziazione, uno strumento particolarmente efficace in determinate fasi del procedimento di mediazione: dopo la formulazione di una proposta economica, il silenzio prolungato dell'avvocato negoziatore, anziché la sollecitazione immediata di una risposta, tende a generare nella controparte una pressione psicologica a colmare il vuoto comunicativo, spesso con informazioni o concessioni che la controparte non avrebbe altrimenti rivelato spontaneamente. Analogamente, il silenzio successivo a una domanda aperta formulata al cliente della controparte, tecnica mutuata dalle metodologie di conduzione dei colloqui investigativi, consente di raccogliere informazioni più ricche rispetto a un'interazione caratterizzata da interruzioni frequenti.

L'uso strategico del silenzio richiede, tuttavia, un'attenta calibrazione culturale: in contesti negoziali caratterizzati da interlocutori provenienti da culture ad alto contesto comunicativo (secondo la nota distinzione antropologica tra culture ad alto e basso contesto), il silenzio può essere interpretato come segno di riflessione rispettosa, mentre in contesti caratterizzati da uno stile comunicativo più diretto e immediato, un silenzio prolungato può generare imbarazzo o essere percepito come segno di disinteresse, con l'effetto potenzialmente controproducente di accelerare concessioni della controparte non ponderate ma anche di generare un clima relazionale negativo che può compromettere la disponibilità a proseguire la trattativa.

Le tattiche di framing nella presentazione delle proposte

Il framing, ossia il modo in cui una medesima proposta sostanziale viene presentata linguisticamente, influenza significativamente la disponibilità della controparte ad accettarla, secondo un fenomeno ampiamente documentato dalla ricerca in economia comportamentale sulla c.d. prospect theory: una proposta presentata in termini di guadagno rispetto a una situazione di riferimento tende a essere valutata diversamente da una proposta equivalente presentata in termini di perdita rispetto a una diversa situazione di riferimento, anche quando le due proposte siano matematicamente identiche in termini di esito finale. L'avvocato negoziatore dovrebbe quindi prestare attenzione al modo in cui formula e presenta le proposte economiche, ad esempio inquadrando una riduzione della richiesta risarcitoria come un'opportunità di chiusura rapida e certa del contenzioso, piuttosto che come una concessione rispetto alla pretesa originaria, un inquadramento che può facilitare l'accettazione della proposta da parte della controparte.

Il framing si applica non soltanto alla dimensione economica della proposta, ma anche alla dimensione relazionale e temporale della controversia: presentare l'accordo di mediazione come un'opportunità di chiudere definitivamente un capitolo controverso e di guardare al futuro, piuttosto che come una mera resa rispetto alle pretese avversarie, può facilitare l'accettazione psicologica dell'accordo da parte del cliente stesso, un aspetto della negoziazione che riguarda tanto la gestione della controparte quanto la gestione del proprio assistito nella fase di valutazione finale della proposta di composizione.

Simulazioni e role playing nella formazione dell'avvocato negoziatore

La formazione avanzata dell'avvocato negoziatore beneficia significativamente di metodologie didattiche esperienziali, quali le simulazioni negoziali e il role playing, che consentono al professionista di sperimentare in un ambiente protetto le dinamiche emotive e relazionali tipiche della mediazione, senza il rischio di conseguenze pregiudizievoli per un cliente reale. Le scuole forensi e gli organismi di formazione specializzati in ADR hanno progressivamente sviluppato programmi di simulazione strutturati su casi paradigmatici, spesso ispirati a controversie reali opportunamente anonimizzate, che permettono agli avvocati partecipanti di alternare i ruoli di avvocato negoziatore, cliente e mediatore, acquisendo così una comprensione più completa delle dinamiche procedurali dai diversi punti di vista dei soggetti coinvolti.

L'utilità pedagogica del role playing risiede in particolare nella possibilità di ricevere un feedback immediato e specifico sul proprio stile comunicativo e negoziale, spesso attraverso la registrazione video della simulazione e la successiva analisi congiunta con un formatore esperto, un processo di apprendimento riflessivo che risulta difficilmente replicabile nella pratica professionale ordinaria, dove l'avvocato raramente ha occasione di osservare direttamente il proprio comportamento negoziale da una prospettiva esterna e con il beneficio di un'analisi tecnica strutturata.

Approfondimento: la negoziazione in contesti di forte squilibrio di potere

Identificazione e gestione dello squilibrio di potere tra le parti

Le controversie caratterizzate da un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti, quali quelle tra un consumatore e una grande impresa, tra un lavoratore e il proprio datore di lavoro, o tra un piccolo fornitore e un grande committente, pongono all'avvocato negoziatore che assista la parte più debole sfide specifiche che richiedono strategie negoziali differenziate rispetto al modello di negoziazione tra pari tipicamente presupposto dalla letteratura classica sulla negoziazione. L'identificazione preliminare dello squilibrio di potere, che può derivare da fattori economici (la maggiore capacità finanziaria di una parte di sostenere i costi e i tempi di un eventuale contenzioso), informativi (la maggiore competenza tecnica o giuridica di una parte rispetto all'altra) o psicologici (la maggiore esperienza negoziale di una parte abituata a gestire controversie analoghe), costituisce il primo passo per l'elaborazione di una strategia negoziale efficace in questi contesti.

Le tecniche di riequilibrio del potere negoziale a disposizione dell'avvocato che assista la parte più debole comprendono, tra le altre: il rafforzamento informativo della parte assistita, attraverso un'accurata preparazione tecnico-giuridica che colmi, nella misura del possibile, il gap di competenza rispetto alla controparte istituzionale; l'individuazione di alleanze o di precedenti giurisprudenziali favorevoli che rafforzino la posizione negoziale della parte debole; e, quando disponibile, il ricorso a forme di tutela collettiva o associativa (ad esempio attraverso associazioni di consumatori o organizzazioni sindacali) che possano aggregare il potere negoziale di più soggetti portatori di interessi analoghi, riequilibrando la relazione con la controparte istituzionale.

Il ruolo del mediatore nella gestione degli squilibri di potere

Il mediatore, pur mantenendo il proprio dovere di imparzialità sostanziale rispetto all'esito della controversia, può e deve adottare, secondo le migliori prassi internazionali in materia,

tecniche procedurali specifiche per assicurare che lo squilibrio di potere tra le parti non si traduca in un accordo sostanzialmente iniquo, ad esempio attraverso una gestione del tempo e della parola che garantisca adeguato spazio di espressione alla parte più debole, o attraverso sessioni separate che consentano a quest'ultima di esprimere le proprie preoccupazioni senza la pressione diretta della controparte più forte. L'avvocato negoziatore che rilevi un'insufficiente attenzione del mediatore a questi profili dovrebbe considerare la possibilità di segnalarlo direttamente al mediatore stesso, o, nei casi più gravi, di valutare l'opportunità di interrompere la procedura qualora ritenga che essa non possa svolgersi in condizioni di equità procedurale sostanziale per il proprio cliente.

La formazione dei mediatori in materia di gestione degli squilibri di potere, elemento del curriculum formativo raccomandato dalle linee guida internazionali sulla qualità della mediazione, dovrebbe costituire, secondo l'autore del presente volume, un criterio rilevante nella scelta dell'organismo di mediazione da parte dell'avvocato negoziatore che assista una parte in una posizione di debolezza negoziale strutturale, un criterio che si affianca a quelli più generali di qualità e affidabilità dell'organismo già illustrati nel presente volume.

Approfondimento: la negoziazione integrativa e la creazione di valore

Il concetto di negoziazione a somma variabile

La distinzione tra negoziazione a somma fissa (distributiva), nella quale le parti si confrontano sulla ripartizione di un valore predeterminato e non ampliabile, e negoziazione a somma variabile (integrativa), nella quale le parti possono, attraverso un'esplorazione congiunta degli interessi reciproci, ampliare il valore complessivo disponibile per la ripartizione, costituisce uno dei contributi teorici più influenti della letteratura sulla negoziazione applicabile alla mediazione civile e commerciale. L'avvocato negoziatore dovrebbe sempre verificare, prima di assumere un approccio puramente distributivo focalizzato sulla mera ripartizione di una somma di denaro predeterminata, se la controversia presenti margini per una negoziazione integrativa, attraverso l'identificazione di interessi complementari delle parti che possano essere soddisfatti attraverso scambi di valore non meramente monetario.

Un esempio paradigmatico di negoziazione integrativa applicabile a numerose controversie commerciali riguarda lo scambio tra la dimensione economica immediata della controversia e la dimensione temporale della sua soluzione: una parte particolarmente interessata alla liquidità immediata potrebbe accettare un importo nominale inferiore in cambio di un pagamento immediato, mentre una parte meno urgentemente bisognosa di liquidità potrebbe preferire un importo nominale superiore distribuito in un piano di pagamento rateizzato nel tempo, una soluzione che, attraverso l'attualizzazione finanziaria dei flussi di pagamento, può generare un valore complessivo maggiore per entrambe le parti rispetto a una soluzione monetaria unica e immediata calcolata secondo un criterio meramente distributivo.

La mappatura degli interessi complementari: metodologia pratica

La mappatura sistematica degli interessi complementari delle parti, tecnica essenziale per l'identificazione di opportunità di negoziazione integrativa, può essere condotta dall'avvocato negoziatore attraverso un processo strutturato in diverse fasi: l'identificazione degli interessi dichiarati e non dichiarati del proprio cliente, attraverso un colloquio preparatorio approfondito; l'ipotesi, sulla base delle informazioni disponibili, degli interessi della

controparte, eventualmente verificata attraverso domande esplorative dirette nel corso della sessione di mediazione; e l'identificazione delle aree di complementarità, ossia degli ambiti nei quali un elemento di scarso valore per una parte corrisponde a un elemento di valore significativo per la controparte, secondo il principio economico dei vantaggi comparati applicato al contesto negoziale.

L'esperienza pratica dimostra che la negoziazione integrativa risulta particolarmente efficace nelle controversie che coinvolgano una pluralità di dimensioni oltre a quella puramente monetaria, quali le controversie contrattuali che comprendano anche aspetti relativi alla prosecuzione futura del rapporto commerciale, alla riservatezza delle informazioni scambiate nel corso della controversia, o a impegni comportamentali futuri delle parti, dimensioni che un approccio puramente distributivo focalizzato sulla sola componente economica rischierebbe di trascurare, con un conseguente impoverimento del valore complessivo potenzialmente ricavabile dalla composizione negoziale della controversia.

Approfondimento: l'intelligenza emotiva dell'avvocato negoziatore

Le componenti dell'intelligenza emotiva applicate alla negoziazione

Il modello dell'intelligenza emotiva, elaborato dalla ricerca psicologica a partire dagli anni Novanta del secolo scorso e ampiamente diffuso anche nella letteratura manageriale e professionale, identifica quattro componenti principali particolarmente rilevanti per la pratica dell'avvocato negoziatore: la consapevolezza di sé, ossia la capacità di riconoscere le proprie emozioni e il loro impatto sul proprio comportamento negoziale; l'autoregolazione, ossia la capacità di gestire le proprie reazioni emotive evitando risposte impulsive controproducenti; la consapevolezza sociale, ossia la capacità di percepire e comprendere le emozioni degli altri partecipanti alla negoziazione; e la gestione delle relazioni, ossia la capacità di influenzare positivamente la dinamica relazionale complessiva della negoziazione attraverso un uso consapevole delle proprie competenze emotive e comunicative.

L'avvocato negoziatore che sviluppi consapevolmente queste competenze, attraverso percorsi di formazione specifici o attraverso un lavoro di auto-riflessione sistematica sulla propria esperienza professionale, acquisisce uno strumento professionale distintivo che integra, senza sostituire, le più tradizionali competenze tecnico-giuridiche, in coerenza con il modello complessivo dell'avvocato negoziatore proposto dal presente volume, che valorizza l'integrazione tra rigore giuridico e sensibilità relazionale come tratto caratterizzante della professione forense contemporanea.

La gestione dello stress e del burnout nella pratica negoziale intensiva

La pratica intensiva della negoziazione e della mediazione, che comporta tipicamente un'esposizione prolungata a situazioni di conflitto e di tensione emotiva altrui, pone all'avvocato negoziatore rischi specifici di stress professionale e, nei casi più gravi, di sindrome da burnout, un fenomeno riconosciuto dalla letteratura scientifica come particolarmente diffuso tra i professionisti che operano stabilmente nel campo della gestione dei conflitti (avvocati, mediatori, ma anche professionisti sanitari e assistenti sociali). L'avvocato negoziatore dovrebbe essere consapevole di questo rischio professionale specifico, adottando strategie di autoregolazione e di gestione del proprio benessere psicofisico, quali la limitazione del numero di procedure gestite simultaneamente, la pratica di tecniche di rilassamento o di

mindfulness tra una sessione negoziale e l'altra, e il ricorso, quando necessario, a un supporto psicologico professionale specificamente dedicato alla gestione dello stress occupazionale.

Alcuni ordini forensi e associazioni specialistiche hanno iniziato a promuovere programmi di supporto al benessere psicologico degli avvocati, riconoscendo l'importanza di questo profilo per la sostenibilità di lungo periodo della professione forense, un'attenzione che si estende naturalmente anche alla specifica categoria degli avvocati negoziatori, per i quali l'esposizione ripetuta a dinamiche conflittuali intense costituisce un elemento strutturale e non episodico della propria attività professionale quotidiana.

Approfondimento: la negoziazione in condizioni di incertezza informativa

La gestione dell'asimmetria informativa tra le parti

Le controversie caratterizzate da una significativa asimmetria informativa tra le parti, situazione frequente in numerose tipologie di controversie commerciali (ad esempio quando una parte disponga di informazioni tecniche specialistiche sul prodotto o servizio oggetto della controversia non pienamente accessibili alla controparte), richiedono all'avvocato negoziatore strategie specifiche per la gestione di questa incertezza informativa: la richiesta di informazioni aggiuntive alla controparte nel corso della procedura di mediazione, quando compatibile con il regolamento dell'organismo prescelto; il ricorso a consulenze tecniche di parte per colmare, nella misura del possibile, il gap informativo prima dell'avvio della negoziazione; e, quando le circostanze lo consiglino, una valutazione realistica del rischio di sottovalutazione o sopravvalutazione della propria posizione negoziale derivante dalla persistente incertezza informativa, un rischio che dovrebbe essere esplicitamente comunicato al cliente nella fase di valutazione strategica della controversia.

La teoria dei giochi, disciplina matematica applicata allo studio delle decisioni strategiche interdipendenti, offre strumenti concettuali utili per comprendere le dinamiche negoziali in condizioni di informazione incompleta, distinguendo tra situazioni di informazione simmetrica (nelle quali entrambe le parti dispongono del medesimo livello di conoscenza delle circostanze rilevanti) e situazioni di informazione asimmetrica, nelle quali una parte dispone di informazioni non accessibili all'altra, un'asimmetria che può essere strategicamente sfruttata dalla parte informata, sebbene con il rischio, quando la controparte percepisca l'esistenza di tale asimmetria, di un deterioramento della fiducia reciproca necessaria per il buon esito della negoziazione.

Le tecniche di signaling nella negoziazione asimmetrica

Le tecniche di signaling, ossia di comunicazione strategica di informazioni attraverso comportamenti osservabili piuttosto che attraverso dichiarazioni dirette non verificabili dalla controparte, costituiscono uno strumento utile per l'avvocato negoziatore che assista la parte meno informata in una negoziazione asimmetrica: la disponibilità a sottoporre la questione a una valutazione tecnica indipendente condivisa tra le parti, ad esempio, costituisce un segnale credibile della fiducia della parte proponente nella fondatezza della propria posizione, un segnale che può contribuire a riequilibrare, almeno parzialmente, l'asimmetria informativa originaria, inducendo la controparte più informata a una maggiore trasparenza nella condivisione delle informazioni rilevanti per la controversia.

Il mediatore, nella conduzione di una procedura caratterizzata da significativa asimmetria informativa tra le parti, svolge tipicamente un ruolo di facilitazione della trasparenza informativa reciproca, attraverso tecniche quali la richiesta esplicita alle parti di condividere le informazioni rilevanti per la valutazione comparativa delle rispettive posizioni, un ruolo che l'avvocato negoziatore dovrebbe supportare attivamente, quando corrisponda all'interesse del proprio cliente, piuttosto che ostacolare attraverso una gestione eccessivamente reticente delle informazioni in proprio possesso, un atteggiamento che, sebbene talvolta tatticamente comprensibile nel breve periodo, rischia di compromettere la fiducia reciproca necessaria per il raggiungimento di un accordo stabile e duraturo.

Approfondimento: la comunicazione non verbale nella negoziazione

L'osservazione dei segnali non verbali nel corso della sessione di mediazione

La comunicazione non verbale, comprendente elementi quali la postura, il contatto visivo, la gestualità, il tono e il ritmo della voce, costituisce una componente significativa della comunicazione umana complessiva, e la sua osservazione attenta da parte dell'avvocato negoziatore nel corso della sessione di mediazione può fornire indicazioni utili circa lo stato emotivo e il livello di sincerità delle dichiarazioni della controparte, sebbene con i limiti di attendibilità che la letteratura scientifica più rigorosa ha progressivamente evidenziato rispetto a interpretazioni eccessivamente semplicistiche o meccanicistiche dei segnali non verbali osservati. È opportuno segnalare, a questo proposito, che la popolare regola cosiddetta del 7-38-55 per cento, spesso attribuita alla ricerca dello psicologo Albert Mehrabian degli anni Sessanta del secolo scorso e secondo la quale il significato di un messaggio comunicativo deriverebbe solo per il 7 per cento dalle parole, per il 38 per cento dal tono della voce e per il 55 per cento dal linguaggio del corpo, costituisce una generalizzazione impropria e ampiamente contestata dalla comunità scientifica di uno studio originario condotto in circostanze sperimentali molto specifiche e limitate, relative alla comunicazione di stati emotivi attraverso singole parole, non generalizzabile alla comunicazione verbale complessa e contestualizzata tipica di una negoziazione professionale.

L'avvocato negoziatore dovrebbe quindi utilizzare l'osservazione dei segnali non verbali della controparte con la necessaria cautela metodologica, evitando di attribuire un peso probatorio o strategico eccessivo a singoli segnali isolati (quali un momentaneo evitamento del contatto visivo, che può avere molteplici spiegazioni non necessariamente riconducibili alla scarsa sincerità dell'interlocutore), preferendo piuttosto una valutazione complessiva e contestualizzata del comportamento comunicativo della controparte nel suo insieme, integrata con il contenuto sostanziale delle dichiarazioni verbali effettivamente espresse, secondo un approccio metodologicamente più solido rispetto alla mera applicazione di formule interpretative semplificate e scientificamente non adeguatamente fondate.

La gestione consapevole della propria comunicazione non verbale

Oltre all'osservazione della comunicazione non verbale della controparte, l'avvocato negoziatore dovrebbe sviluppare una consapevolezza adeguata della propria comunicazione non verbale, poiché anche i propri segnali non verbali influenzano la percezione che la controparte e il mediatore hanno della propria posizione e del proprio atteggiamento negoziale: una postura aperta e rilassata, un tono di voce calmo e controllato, e un contatto visivo appropriato (calibrato secondo le convenzioni culturali della controparte, che possono variare

significativamente tra diverse tradizioni culturali) contribuiscono a trasmettere un'immagine di sicurezza e di apertura al dialogo che favorisce un clima negoziale collaborativo, mentre segnali di tensione o di chiusura comunicativa possono, all'inverso, generare diffidenza e ostacolare la costruzione di un clima di fiducia reciproca necessario per il buon esito della procedura di mediazione.

Approfondimento: le tecniche di ancoraggio e la loro gestione consapevole

Il fenomeno dell'ancoraggio cognitivo nella formulazione delle proposte

Il fenomeno dell'ancoraggio cognitivo, ampiamente studiato dalla psicologia comportamentale a partire dai lavori pionieristici di Daniel Kahneman e Amos Tversky, descrive la tendenza della mente umana ad attribuire un peso sproporzionato al primo numero o alla prima informazione quantitativa incontrata nel corso di un processo decisionale, un'informazione che condiziona, spesso in modo inconsapevole, le valutazioni successive anche quando essa sia palesemente arbitraria o non pertinente. Nel contesto della negoziazione, questo fenomeno si manifesta tipicamente attraverso l'effetto della prima proposta economica formulata da una delle parti, che tende a condizionare l'andamento successivo della trattativa anche quando la controparte sia consapevole, in linea teorica, della natura strategica e non necessariamente oggettiva di tale prima proposta.

L'avvocato negoziatore dovrebbe considerare consapevolmente l'opportunità di formulare la prima proposta economica nel corso della negoziazione, quando le circostanze del caso lo consiglino, per beneficiare dell'effetto di ancoraggio a proprio favore, formulando una proposta iniziale sufficientemente ambiziosa da orientare la successiva negoziazione verso un esito favorevole, ma al contempo sufficientemente credibile da non essere immediatamente respinta dalla controparte come manifestamente irragionevole, un equilibrio che richiede una solida conoscenza del valore oggettivo della controversia (attraverso l'analisi del BATNA e del WATNA già illustrata nel presente volume) unita a una adeguata sensibilità psicologica per la formulazione della proposta in termini persuasivi.

La difesa dagli effetti di ancoraggio sfavorevoli

Simmetricamente, l'avvocato negoziatore che si trovi a rispondere a una prima proposta della controparte percepita come eccessivamente sfavorevole dovrebbe adottare specifiche tecniche di neutralizzazione dell'effetto di ancoraggio, quali l'esplicita evidenziazione, nel corso della negoziazione, della natura arbitraria o non fondata su criteri oggettivi della proposta della controparte, il richiamo a criteri di valutazione alternativi e più oggettivi (quali precedenti giurisprudenziali comparabili, perizie tecniche, o valori di mercato documentabili), e, quando opportuno, la formulazione di una controproposta sufficientemente distante da quella della controparte da ridurre l'effetto di ancoraggio complessivo sulla successiva dinamica negoziale, tecniche che richiedono una consapevolezza metodologica specifica che il presente volume ha inteso fornire all'avvocato negoziatore contemporaneo.

Approfondimento: la gestione della negoziazione multiparte

Le peculiarità della negoziazione con una pluralità di parti

Le controversie che coinvolgano una pluralità di parti, situazione frequente in materia di responsabilità civile plurisoggettiva, di controversie successorie con più coeredi, o di

controversie societarie che coinvolgano più soci, presentano una complessità negoziale significativamente maggiore rispetto alla negoziazione bilaterale tradizionale, richiedendo all'avvocato negoziatore competenze specifiche per la gestione delle dinamiche di coalizione e di conflitto di interessi che tipicamente emergono quando più parti, ciascuna con interessi parzialmente convergenti e parzialmente divergenti rispetto alle altre, partecipino alla medesima procedura di mediazione. La teoria della negoziazione multiparte, sviluppata dalla letteratura specialistica internazionale a partire dagli studi pionieristici di Howard Raiffa e dei suoi successori, individua specifiche dinamiche tipiche di questo contesto negoziale, quali la formazione di coalizioni temporanee tra sottoinsiemi delle parti coinvolte, la possibilità di accordi parziali che non coinvolgano la totalità delle parti presenti, e la maggiore complessità nella individuazione di soluzioni che soddisfino simultaneamente gli interessi di tutte le parti coinvolte.

L'avvocato negoziatore che assista una parte in una negoziazione multiparte dovrebbe considerare attentamente le dinamiche di coalizione potenzialmente sviluppabili con le altre parti coinvolte, individuando quali tra le altre parti presentino interessi maggiormente convergenti con quelli del proprio cliente e valutando l'opportunità di un coordinamento strategico, quando compatibile con i doveri deontologici di lealtà verso il proprio cliente e verso le altre parti coinvolte nella procedura, per rafforzare la propria posizione negoziale complessiva rispetto alle parti con interessi maggiormente divergenti.

Il ruolo del mediatore nella facilitazione della negoziazione multiparte

Il mediatore che conduca una procedura multiparte svolge un ruolo di facilitazione particolarmente complesso, dovendo gestire simultaneamente le dinamiche relazionali tra tutte le parti coinvolte, attraverso tecniche specifiche quali la conduzione di sessioni separate con singole parti o sottoinsiemi di parti (caucus), la facilitazione di un processo di individuazione progressiva delle aree di convergenza tra le diverse posizioni, e la gestione attenta della sequenza e delle modalità di comunicazione delle informazioni tra le diverse parti, per evitare che la complessità relazionale multiparte generi un blocco negoziale complessivo. L'avvocato negoziatore dovrebbe supportare attivamente questo ruolo di facilitazione del mediatore, fornendo la propria collaborazione per l'individuazione delle aree di convergenza e per la costruzione progressiva di un accordo che, per quanto complesso nella sua articolazione multiparte, possa risultare stabile e duraturo per tutte le parti coinvolte.

Approfondimento: la gestione dello stallo negoziale (deadlock)

Le tecniche di superamento dello stallo nella negoziazione complessa

Lo stallo negoziale, situazione nella quale le parti, nonostante la persistente disponibilità a proseguire il tentativo di composizione della controversia, non riescono a individuare un'area di accordo reciprocamente accettabile a causa della persistente distanza tra le rispettive posizioni negoziali, costituisce una delle sfide più significative che l'avvocato negoziatore deve affrontare nella propria pratica professionale, richiedendo l'applicazione di specifiche tecniche di superamento dello stallo sviluppate dalla letteratura specialistica in materia di negoziazione: la riformulazione della questione controversa secondo una diversa prospettiva, che consenta di individuare aree di possibile accordo non evidenti nella formulazione originaria della controversia; l'introduzione di elementi aggiuntivi nella negoziazione (ad esempio ulteriori prestazioni o controprestazioni non originariamente considerate) che possano ampliare lo

spazio delle soluzioni possibili; e il ricorso a una pausa temporanea della negoziazione, che consenta alle parti di riconsiderare le rispettive posizioni con maggiore distacco emotivo prima di riprendere il confronto negoziale.

Il mediatore svolge, in presenza di uno stallo negoziale, un ruolo particolarmente significativo attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di facilitazione, quali la conduzione di sessioni separate con ciascuna parte per esplorare riservatamente le ragioni sottostanti allo stallo e le possibili soluzioni alternative non ancora esplorate nella sessione congiunta, e la proposta, quando richiesta dalle parti secondo il meccanismo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010, di una soluzione valutativa che possa fornire alle parti un punto di riferimento oggettivo per il superamento dello stallo, un intervento che l'avvocato negoziatore dovrebbe supportare attivamente quando la persistenza dello stallo rischi di pregiudicare irreversibilmente le prospettive di una composizione negoziale complessivamente vantaggiosa per il proprio cliente.

La valutazione del momento di interruzione della negoziazione

Non tutti gli stalli negoziali sono superabili attraverso le tecniche sopra illustrate, ed è compito dell'avvocato negoziatore valutare, con onestà professionale verso il proprio cliente, il momento in cui la persistenza del tentativo di composizione negoziale non risulti più giustificata dai costi, in termini di tempo e di risorse, connessi alla continuazione degli sforzi negoziali, rispetto ai benefici realisticamente attesi da un'eventuale soluzione della controversia in sede giudiziale, una valutazione che richiede il costante aggiornamento dell'analisi del BATNA e del WATNA già illustrata nel presente volume, e che deve essere condivisa con chiarezza e trasparenza con il cliente, evitando sia un abbandono prematuro di prospettive negoziali ancora concretamente praticabili sia una prosecuzione indefinita di un tentativo negoziale privo di realistiche prospettive di successo.

Approfondimento: l'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla negoziazione

Le applicazioni emergenti dell'intelligenza artificiale nella preparazione della negoziazione

Lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale generativa, avvenuto con particolare intensità a partire dal 2022, ha progressivamente offerto all'avvocato negoziatore nuove possibilità di supporto tecnologico nella preparazione e nella conduzione della negoziazione, quali l'analisi automatizzata di grandi volumi di documentazione contrattuale o giurisprudenziale per l'individuazione di precedenti rilevanti ai fini della valutazione del BATNA e del WATNA, la simulazione di possibili scenari negoziali attraverso modelli linguistici capaci di elaborare previsioni sull'andamento della trattativa secondo diverse ipotesi di comportamento delle parti, e l'assistenza nella redazione di bozze di accordi negoziali secondo modelli e clausole standardizzate, opportunamente personalizzate secondo le circostanze specifiche del caso concreto.

L'avvocato negoziatore che si avvalga di questi strumenti di intelligenza artificiale generativa nella propria pratica professionale deve tuttavia mantenere una costante supervisione critica e professionale sui contenuti generati da tali strumenti, secondo il principio generale di responsabilità professionale che impone all'avvocato di verificare sempre l'accuratezza e

l'affidabilità di ogni informazione utilizzata nell'esercizio della propria attività professionale, un principio che il Consiglio Nazionale Forense ha espressamente ribadito attraverso specifiche indicazioni deontologiche relative all'utilizzo responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale nella pratica professionale forense, pubblicate a partire dal 2024.

I rischi specifici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella negoziazione riservata

L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nel contesto della negoziazione connessa a una procedura di mediazione pone specifiche cautele relative alla riservatezza delle informazioni trattate, poiché l'inserimento di informazioni riservate relative alla controversia in strumenti di intelligenza artificiale basati su infrastrutture cloud gestite da soggetti terzi potrebbe, in assenza di adeguate garanzie contrattuali e tecniche, comportare un rischio di divulgazione non autorizzata di tali informazioni, un rischio che l'avvocato negoziatore deve attentamente valutare, preferendo, quando disponibili, soluzioni tecnologiche che garantiscano un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza dei dati trattati, coerente con gli obblighi di segreto professionale e di riservatezza procedimentale già ampiamente illustrati nel presente volume.

Approfondimento: la gestione del silenzio strategico nella negoziazione

Il valore comunicativo della pausa e del silenzio nel corso della trattativa

Il silenzio, quale strumento comunicativo consapevolmente utilizzato nell'ambito della negoziazione, possiede un valore strategico spesso sottovalutato dai negoziatori meno esperti, che tendono a percepire le pause nella conversazione come momenti da colmare rapidamente attraverso ulteriori argomentazioni o concessioni, quando invece un silenzio consapevolmente gestito dopo la formulazione di una proposta può esercitare una pressione psicologica significativa sulla controparte, inducendola a fornire ulteriori informazioni o a manifestare la propria posizione con maggiore chiarezza per rompere il disagio comunicativo generato dalla pausa. L'avvocato negoziatore dovrebbe allenarsi a tollerare consapevolmente i momenti di silenzio nel corso della negoziazione, resistendo all'impulso di riprendere immediatamente la parola dopo aver formulato una proposta significativa, per lasciare alla controparte lo spazio e il tempo necessario per una riflessione autentica sulla proposta stessa.

Il mediatore esperto utilizza frequentemente tecniche di gestione consapevole del silenzio nella conduzione della sessione di mediazione, evitando di intervenire prematuramente per colmare pause comunicative che potrebbero invece favorire una riflessione più profonda delle parti sulle proprie rispettive posizioni, una tecnica che l'avvocato negoziatore dovrebbe osservare e apprezzare nella propria partecipazione alle sessioni di mediazione condotte da mediatori esperti, traendone spunto per il proprio sviluppo professionale come negoziatore capace di gestire consapevolmente anche questo aspetto non verbale, ma comunicativamente significativo, della dinamica negoziale complessiva.

Approfondimento: la gestione delle emozioni proprie del negoziatore professionale

L'autoregolazione emotiva come competenza professionale essenziale

La capacità dell'avvocato negoziatore di gestire consapevolmente le proprie reazioni emotive nel corso della negoziazione, evitando che frustrazione, impazienza, o coinvolgimento eccessivo nella causa del proprio cliente possano compromettere la qualità delle proprie decisioni

strategiche, costituisce una competenza professionale essenziale che si affianca, senza sostituirla, alla solida preparazione tecnico-giuridica già ampiamente illustrata nel presente volume. La letteratura specialistica in materia di intelligenza emotiva applicata alla negoziazione professionale ha individuato specifiche tecniche di autoregolazione che l'avvocato negoziatore può utilmente sviluppare, quali la consapevolezza anticipata dei propri trigger emotivi personali, situazioni o comportamenti della controparte che tendono a generare reazioni emotive intense e potenzialmente disfunzionali, e l'adozione di brevi pause di autoregolazione nel corso della sessione negoziale, quando necessario, per ripristinare un adeguato equilibrio emotivo prima di proseguire nella trattativa.

L'identificazione professionale eccessiva dell'avvocato con la causa del proprio cliente, fenomeno psicologicamente comprensibile ma professionalmente rischioso, può generare una perdita di quella necessaria distanza critica che consente all'avvocato negoziatore di valutare con obiettività le rispettive posizioni negoziali e di consigliare al cliente, con onestà professionale, anche soluzioni che comportino concessioni significative quando queste risultino oggettivamente convenienti secondo l'analisi del BATNA e del WATNA già ampiamente illustrata nel presente volume, un rischio che l'avvocato negoziatore dovrebbe costantemente monitorare attraverso una pratica di auto-osservazione professionale consapevole.

La gestione delle proprie reazioni di fronte a comportamenti scorretti della controparte

L'avvocato negoziatore si troverà, nel corso della propria pratica professionale, a confrontarsi occasionalmente con comportamenti scorretti o provocatori da parte della controparte o del suo difensore, situazioni che richiedono una gestione emotiva particolarmente consapevole per evitare reazioni impulsive che potrebbero aggravare inutilmente il conflitto o compromettere la propria credibilità professionale agli occhi del mediatore e della controparte stessa. La capacità di mantenere un contegno professionale composto ed assertivo, senza cedere a reazioni aggressive o passive di fronte a provocazioni, costituisce un elemento distintivo della maturità professionale dell'avvocato negoziatore esperto, una maturità che si acquisisce progressivamente attraverso l'esperienza diretta e la riflessione critica sulla propria pratica professionale, secondo un percorso di sviluppo professionale continuo che il presente volume ha inteso supportare attraverso l'analisi sistematica di questi profili relazionali e psicologici della funzione dell'avvocato negoziatore contemporaneo.

Capitolo 5

L'avvocato in materie speciali

La competenza tecnica e negoziale dell'avvocato non può essere generica: ogni materia soggetta a mediazione, negoziazione assistita o ADR di settore presenta discipline specifiche, spesso derogatorie rispetto al modello generale del decreto legislativo 28/2010. Questo capitolo esamina nove ambiti nei quali la figura dell'avvocato negoziatore assume tratti particolari.

5.1 Diritto di famiglia: mediazione familiare, negoziazione assistita, art. 6 d.l. 132/2014

La negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, disciplinata dall'articolo 6 del decreto legge 132/2014, rappresenta lo strumento nel quale l'avvocato assume la responsabilità più diretta e immediata: l'accordo

raggiunto, una volta trasmesso al procuratore della Repubblica per il nulla osta o l'autorizzazione, produce gli effetti della separazione o del divorzio senza intervento del tribunale. Gli avvocati, in questo procedimento, non si limitano ad assistere le parti: certificano, sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare, la conformità dell'accordo all'ordine pubblico e alle norme imperative, in particolare quando l'accordo riguardi figli minori o economicamente non autosufficienti, ipotesi per la quale è necessario il visto del pubblico ministero anche sul merito delle clausole relative alla prole.

La mediazione familiare, distinta dalla negoziazione assistita, opera oggi nel quadro del nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma Cartabia agli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'articolo 473-bis.10 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di informare in ogni momento le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, mentre l'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ha istituito, presso ogni tribunale, un elenco dei mediatori familiari. Il decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n.151, disciplina la professione del mediatore familiare, definendone i requisiti di accesso e i principi deontologici di neutralità, imparzialità e astensione dal giudizio.

Va segnalato che il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, chiamato a unificare le competenze oggi ripartite tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, non è ancora operativo: il decreto in materia di giustizia del 5 agosto 2025 ha rinviato l'avvio all'ottobre 2026, con un dibattito ancora aperto su un ulteriore slittamento. Fino a tale data la mediazione familiare opera nell'ambito del nuovo rito applicato dagli uffici giudiziari nella loro attuale articolazione (fonte: mediareinformati.it, dossier Mediazione familiare).

Sul piano comparato, l'Italia si colloca oggi tra i paesi europei con standard formativi elevati per il mediatore familiare (240 ore complessive, di cui 80 di pratica, secondo il d.m. 151/2023), ma resta indietro sul piano dell'accessibilità economica: le statistiche disponibili indicano una penetrazione della mediazione familiare tra il 5 e l'8 per cento delle separazioni con figli, ben al di sotto del tasso di utilizzo superiore al 90 per cento registrato in Danimarca, dove la mediazione familiare è gratuita e obbligatoria dal 2019 per le coppie con figli minori (fonte: mediareinformati.it, dossier Mediazione familiare in Italia e i modelli europei).

Un profilo ulteriore riguarda la mediazione familiare internazionale, rilevante nelle controversie che coinvolgono coppie di diversa nazionalità o figli minori con residenza abituale in Stati diversi: in questi casi l'avvocato deve considerare, oltre alla disciplina interna appena descritta, il regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, che incentivano entrambe il ricorso alla mediazione familiare transfrontaliera come strumento preventivo rispetto al conflitto di giurisdizioni.

Sotto il profilo degli incentivi economici, la mediazione familiare beneficia, quando condotta da un organismo accreditato ai sensi del d.lgs. 28/2010, degli stessi meccanismi di credito d'imposta esaminati nel Capitolo 2 di questo volume a proposito del d.m. 150/2023, con la conseguenza che l'avvocato che assiste una parte in una separazione o in un divorzio dovrebbe illustrare al cliente, nell'ambito del colloquio informativo iniziale, anche questa opportunità,

spesso trascurata nella prassi rispetto all'informativa più generale sulla mediazione civile e commerciale.

5.2 Diritto societario e commerciale: la mediazione obbligatoria per materia

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, come ampliato dalla riforma Cartabia con effetto dal 30 giugno 2023, include oggi tra le materie soggette a condizione di procedibilità i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d'opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, ampliando in modo significativo il perimetro applicativo della mediazione commerciale rispetto all'impianto originario del 2010, che si limitava a un nucleo più ristretto di materie contrattuali. L'avvocato che assiste imprese e società deve oggi verificare sistematicamente, prima di introdurre un giudizio, se la controversia rientri in una delle materie soggette a condizione di procedibilità, pena la successiva declaratoria di improcedibilità della domanda.

La mediazione societaria presenta profili di complessità specifici legati alla pluralità delle parti e alla necessità di verificare, per ciascuna di esse, la legittimazione a partecipare e i poteri di rappresentanza degli organi sociali: un tema che si interseca con quanto già osservato nel Capitolo 3 a proposito della procura sostanziale, resa più complessa dalla necessità di verificare le delibere assembleari o consiliari che autorizzano il legale rappresentante a disporre del diritto controverso in sede di mediazione.

Un ulteriore profilo di specificità riguarda le controversie tra socio e società, tipicamente relative all'esercizio del diritto di recesso, alla contestazione di bilanci o all'impugnazione di delibere assembleari: materie nelle quali l'avvocato negoziatore deve valutare con particolare attenzione la disponibilità del diritto controverso, poiché alcune delibere societarie toccano interessi di terzi (creditori sociali, altri soci non partecipanti alla mediazione) che la composizione negoziale tra le sole parti mediatrici non può validamente pregiudicare.

Le clausole di mediazione e conciliazione inserite negli statuti societari, negli accordi parasociali e nei contratti commerciali internazionali costituiscono un ulteriore terreno di attività per l'avvocato negoziatore in ambito societario: la redazione di una clausola di mediazione efficace richiede l'indicazione precisa dell'organismo competente, delle regole procedurali applicabili e del termine entro cui il tentativo di mediazione deve considerarsi concluso prima di poter accedere all'arbitrato o al giudizio, evitando formulazioni generiche che generano contenzioso interpretativo sulla stessa validità della clausola.

5.3 Crisi d'impresa e composizione negoziata (d.lgs. 14/2019 — CCII)

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022, ha introdotto la composizione negoziata della crisi come strumento volontario alternativo alle procedure concorsuali tradizionali: l'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza può richiedere la nomina di un esperto indipendente, iscritto in un elenco tenuto dalle Camere di commercio, che assiste le trattative con i creditori senza sostituirsi all'imprenditore nella gestione dell'impresa.

Il ruolo dell'avvocato in questo contesto è duplice: da un lato assiste l'imprenditore nella predisposizione della domanda e nella valutazione delle opzioni disponibili (accordo di

ristrutturazione, concordato semplificato in caso di esito negativo delle trattative, piano attestato di risanamento); dall'altro lato può assistere i singoli creditori nella negoziazione delle proprie posizioni. Gli organi di controllo della società — collegio sindacale, revisore, società di revisione — hanno un obbligo di segnalazione tempestiva della crisi all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 25-octies del Codice, la cui violazione può generare una responsabilità solidale: un profilo che l'avvocato che assiste l'impresa deve considerare nella propria consulenza preventiva.

La logica sistemica della composizione negoziata è identica a quella della mediazione civile e commerciale, pur collocandosi in un contesto normativo distinto: prevenire l'aggravamento del conflitto (in questo caso, la crisi economica dell'impresa) attraverso un intervento tempestivo di un soggetto terzo indipendente, con l'assistenza tecnica di avvocati che sappiano condurre una negoziazione multipolare complessa, spesso con una pluralità di creditori portatori di interessi eterogenei.

La piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere, costituisce il punto di accesso obbligatorio alla composizione negoziata: l'avvocato deve assistere l'imprenditore nella compilazione della documentazione economico-finanziaria richiesta dalla piattaforma, che comprende un test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una check-list particolareggiata elaborata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documenti che condizionano la stessa valutazione dell'esperto sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento.

Le misure protettive del patrimonio, che l'imprenditore può richiedere al tribunale in pendenza delle trattative ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Codice della crisi, sospendono le azioni esecutive e cautelari dei creditori per un periodo determinato, offrendo all'avvocato negoziatore uno spazio temporale protetto per condurre la negoziazione senza la pressione di iniziative esecutive individuali che ne comprometterebbero l'esito. La gestione di questo equilibrio tra protezione del debitore e tutela dei creditori costituisce una delle competenze più specialistiche richieste all'avvocato che operi in questo settore.

5.4 Diritto del lavoro: conciliazione presso ITL, arbitrato irrituale

Le controversie di lavoro seguono un regime differenziato rispetto alla mediazione civile e commerciale ordinaria: l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28/2010 esclude le controversie di lavoro dall'ambito applicativo della mediazione obbligatoria disciplinata dal medesimo decreto, rinviando alle procedure di conciliazione previste dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. La conciliazione monocratica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e la conciliazione facoltativa presso le commissioni di certificazione, restano gli strumenti tipici del settore, ai quali si affianca l'arbitrato irrituale previsto dagli articoli 412 e seguenti del codice di procedura civile, che consente alle parti di affidare a un collegio arbitrale la risoluzione della controversia con un lodo che ha natura contrattuale, non di sentenza.

L'avvocato che assiste il lavoratore o il datore di lavoro in queste sedi deve conoscere le specificità procedurali di ciascuno strumento, in particolare i limiti di disponibilità dei diritti del lavoratore, che l'ordinamento tutela con un regime di maggior rigore rispetto alla generalità dei diritti patrimoniali disponibili in mediazione civile, in ragione della posizione di asimmetria strutturale tra le parti del rapporto di lavoro.

La conciliazione monocratica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, disciplinata dall'articolo 11 del decreto legislativo 124/2004, consente al lavoratore di richiedere l'intervento di un funzionario ispettivo con funzioni conciliative quando la controversia riguardi diritti retributivi non contestati nella loro esistenza ma non ancora soddisfatti: un rimedio spesso rapido ed efficace che l'avvocato dovrebbe considerare come prima opzione prima di introdurre un giudizio ordinario, specie nelle controversie di modesto valore.

La conciliazione facoltativa in sede sindacale, disciplinata dall'articolo 411 del codice di procedura civile, e la conciliazione in sede di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinata dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 276/2003, completano il quadro degli strumenti a disposizione dell'avvocato negoziatore in materia di lavoro, ciascuno con specifici effetti in termini di rinunciabilità e transigibilità dei diritti del lavoratore, che l'ordinamento tutela con un regime di indisponibilità parziale non presente nella generalità dei rapporti contrattuali.

5.5 Responsabilità sanitaria: mediazione obbligatoria post l. 24/2017

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), ha introdotto un regime particolare per le controversie di responsabilità sanitaria, prevedendo in alternativa alla mediazione ordinaria la possibilità di ricorrere al procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, quale condizione di procedibilità alternativa alla mediazione. L'avvocato che assiste il paziente danneggiato o la struttura sanitaria deve valutare, caso per caso, quale dei due strumenti risulti più adeguato, tenendo conto della necessità di un accertamento tecnico specialistico che caratterizza tipicamente questa materia, nella quale la componente medico-legale è spesso decisiva per la stessa possibilità di una composizione.

La materia resta inclusa tra quelle soggette a condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, richiamato dalla legge 24/2017, con la conseguenza che l'avvocato deve verificare, prima di introdurre il giudizio, quale delle due vie alternative sia stata effettivamente e correttamente esperita.

Un profilo tecnico specifico riguarda la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile e richiamata dalla legge Gelli-Bianco come possibile alternativa alla mediazione: il procedimento si svolge davanti al giudice, che nomina un consulente tecnico d'ufficio con il compito primario di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione sanitaria, tentando la conciliazione tra le parti sulla base delle risultanze tecniche. L'avvocato deve valutare che, a differenza della mediazione ordinaria, questo strumento richiede una spesa immediata per il compenso del consulente, generalmente più elevata rispetto all'indennità di mediazione, ma offre in compenso una valutazione tecnica autorevole che può facilitare sensibilmente la composizione.

L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie, previsto dagli articoli 10 e 11 della legge 24/2017, introduce nel procedimento una terza parte necessaria, l'impresa di assicurazione, che deve essere chiamata a partecipare alla mediazione o all'accertamento tecnico preventivo affinché l'eventuale accordo raggiunto sia opponibile anche ai fini della successiva azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, disciplinata dall'articolo 12 della medesima legge: un ulteriore

elemento di complessità procedurale che l'avvocato negoziatore deve gestire fin dalla fase di avvio del procedimento.

5.6 Condominio e diritti reali: primo incontro effettivo dopo Cartabia

Il condominio e i diritti reali costituiscono, insieme alla divisione e alle successioni ereditarie, il nucleo storico delle materie soggette a mediazione obbligatoria fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 28/2010 nel 2010. La specificità di questa materia risiede nella necessità, per l'avvocato che assiste il condominio quale ente di gestione, di verificare la validità della delibera assembleare che autorizza l'amministratore a partecipare alla mediazione e a disporre, nei limiti fissati dall'assemblea, del diritto controverso: un ulteriore terreno di applicazione dei principi sulla procura sostanziale esaminati nel Capitolo 3.

Dopo la riforma Cartabia, anche nelle controversie condominiali il primo incontro ha acquisito natura sostanziale e non meramente informativa, con la conseguenza che l'amministratore, se non munito di delibera che gli attribuisca margini negoziali sufficienti, rischia di non poter utilmente proseguire la trattativa già nella prima seduta, vanificando l'opportunità di composizione immediata che la riforma ha voluto introdurre.

Le controversie in materia di diritti reali, distinte dal condominio in senso proprio, comprendono tipicamente le azioni di regolamento dei confini, le servitù, l'usucapione e le immissioni, materie nelle quali il valore economico della controversia è spesso modesto rispetto al valore relazionale del rapporto di vicinato sotteso, secondo la logica individuata da Trocker e De Luca ed esaminata nel Capitolo 3 di questo volume a proposito dei rapporti di lunga durata. L'avvocato negoziatore deve qui saper valorizzare pienamente la dimensione relazionale della controversia, spesso più rilevante per le parti della stessa questione tecnico-giuridica sottostante.

5.7 Diritto bancario e finanziario: ACF Consob e ABF Banca d'Italia

Il settore bancario e finanziario dispone di due sistemi di risoluzione alternativa delle controversie distinti dalla mediazione civile ordinaria: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per le controversie tra investitori e intermediari relative alla prestazione di servizi di investimento, e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito presso la Banca d'Italia per le controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Entrambi gli organismi emettono decisioni non vincolanti sul piano dell'esecutività immediata, ma la reputazione dell'intermediario che non si conformi alla decisione viene pubblicamente segnalata, con un effetto dissuasivo di fatto rilevante.

L'avvocato che assiste il cliente in queste sedi deve considerare che l'accesso all'ACF e all'ABF non richiede necessariamente l'assistenza tecnica di un legale, trattandosi di procedure pensate per essere accessibili anche al consumatore non assistito; ciò non esclude, tuttavia, che l'assistenza di un avvocato esperto della materia finanziaria e bancaria possa risultare determinante per la costruzione del ricorso e per la valutazione preliminare delle probabilità di successo, specie nelle controversie di maggiore complessità tecnica.

Il rapporto tra il procedimento ACF o ABF e la successiva ed eventuale mediazione civile obbligatoria merita una precisazione operativa: qualora il cliente non sia soddisfatto della

decisione dell'Arbitro e intenda promuovere un giudizio ordinario, la controversia bancaria o finanziaria rientra normalmente tra quelle soggette a condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 (contratti bancari e finanziari), con la conseguenza che l'avvocato dovrà comunque esperire il tentativo di mediazione prima di introdurre il giudizio, anche se il tentativo di composizione presso l'ACF o l'ABF non ha condotto a un esito soddisfacente: due filtri preventivi distinti, non sovrapponibili, che si succedono nell'ordine logico appena descritto.

5.8 Diritto assicurativo: la mediazione per RC auto e responsabilità civile

Le controversie in materia di contratti assicurativi rientrano tra le materie soggette a condizione di procedibilità fin dall'impianto originario del decreto legislativo 28/2010. Il settore della responsabilità civile automobilistica presenta una specificità procedurale rilevante, derivante dalla necessità di coordinare la mediazione con la procedura stragiudiziale di risarcimento prevista dal Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005), che impone all'impresa assicuratrice termini stringenti per la formulazione di un'offerta di risarcimento prima che il danneggiato possa agire in giudizio. L'avvocato negoziatore, in questo settore, deve saper distinguere tra la fase stragiudiziale disciplinata dal Codice delle assicurazioni e la successiva ed eventuale fase di mediazione, evitando duplicazioni procedurali e ritardi non necessari.

Le polizze assicurative contro i rischi diversi dalla responsabilità civile automobilistica — danni, incendio, furto, tutela legale — rientrano parimenti tra i contratti assicurativi soggetti a condizione di procedibilità, con una specificità ulteriore quando la polizza stessa preveda una clausola di tutela legale che pone a carico dell'assicuratore i costi della difesa tecnica dell'assicurato, incluso il compenso dell'avvocato per l'assistenza in mediazione: l'avvocato deve verificare, in questi casi, i limiti di massimale e le eventuali clausole di libera scelta del legale, che talune polizze limitano o condizionano.

5.9 Contratti transfrontalieri e Convenzione di Singapore 2019

Le controversie relative a contratti commerciali internazionali pongono all'avvocato negoziatore un problema aggiuntivo rispetto alla mediazione interna: l'esecutività dell'accordo raggiunto in un altro Stato o con una controparte straniera. La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, firmata a Singapore il 7 agosto 2019 (Convenzione di Singapore), affronta esattamente questo problema, istituendo un regime di riconoscimento ed esecuzione degli accordi internazionali di mediazione analogo, per finalità, a quello che la Convenzione di New York del 1958 assicura ai lodi arbitrali. Il tema, di crescente rilevanza per l'avvocato che assiste imprese con rapporti commerciali internazionali, è approfondito nel Capitolo 9 di questo volume, dedicato al dialogo transnazionale.

Fonti citate nel capitolo: d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; artt. 473-bis ss. c.p.c.; art. 12-bis disp. att. c.p.c.; d.m. 27 ottobre 2023, n. 151; decreto in materia di giustizia, 5 agosto 2025; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), artt. 25-octies ss.; artt. 412 ss. c.p.c.; l. 8 marzo 2017, n. 24; art. 696-bis c.p.c.; d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, Singapore, 7 agosto 2019; dossier mediareinformati.it: Mediazione familiare in Italia e i modelli europei, Cartabia.

5.10 Mediazione in materia di successioni e patti di famiglia

Le controversie ereditarie, incluse nell'elenco delle materie soggette a condizione di procedibilità fin dalla versione originaria del decreto legislativo 28/2010, presentano caratteristiche peculiari che rendono la mediazione particolarmente indicata: si tratta, nella grande maggioranza dei casi, di conflitti tra soggetti legati da vincoli di parentela stretta, nei quali la dimensione affettiva e relazionale si intreccia inestricabilmente con quella patrimoniale, e nei quali la prosecuzione dei rapporti familiari dopo la definizione della controversia costituisce spesso un obiettivo condiviso, sia pure implicito, delle parti. L'avvocato negoziatore che assiste un coerede in una controversia successoria deve essere consapevole che l'esito puramente tecnico-patrimoniale della lite non esaurisce, per il cliente, l'interesse effettivo alla sua composizione, che spesso comprende anche la salvaguardia, o quantomeno il non ulteriore deterioramento, delle relazioni familiari residue.

I patti di famiglia disciplinati dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, che consentono all'imprenditore di trasferire in vita l'azienda o le partecipazioni sociali a uno o più discendenti con il consenso di tutti i legittimari, costituiscono un ambito nel quale la consulenza dell'avvocato negoziatore assume una dimensione particolarmente delicata, poiché l'accordo deve conciliare l'esigenza di continuità dell'impresa familiare con la tutela dei diritti dei legittimari non assegnatari, tipicamente soddisfatti mediante liquidazione in denaro o in natura. La mediazione, quando insorgano contestazioni sulla misura di tale liquidazione o sulla validità del patto stesso, offre uno strumento per ricomporre l'accordo familiare senza esporre l'intera vicenda successoria e imprenditoriale ai tempi e ai costi di un contenzioso ordinario, che rischierebbe di compromettere la stessa continuità aziendale che il patto di famiglia era destinato a preservare.

5.11 Diritto della proprietà intellettuale e mediazione

Sebbene le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale non figurino nell'elenco delle materie soggette a condizione di procedibilità, esse costituiscono un campo in cui la mediazione volontaria trova un'applicazione crescente, per la specificità tecnica delle questioni coinvolte (validità di un brevetto, ambito di tutela di un marchio, contraffazione di un design) e per l'interesse delle parti, spesso concorrenti nel medesimo mercato, a evitare la pubblicità di un contenzioso giudiziario che potrebbe avere ripercussioni reputazionali indipendenti dall'esito della causa. L'avvocato negoziatore che assiste un'impresa titolare di diritti di proprietà intellettuale dovrebbe valutare la mediazione anche come strumento per la definizione di accordi di licenza o di coesistenza tra segni distintivi simili, che il giudice non potrebbe validamente imporre ma che le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono liberamente concordare in sede di mediazione.

Approfondimento

La mediazione nelle controversie di locazione e comodato

Le controversie in materia di locazione e comodato di immobili, incluse tra le materie soggette a condizione di procedibilità dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, presentano caratteristiche procedurali specifiche legate alla frequente urgenza delle situazioni sottostanti, quali la morosità del conduttore o la necessità del locatore di rientrare nella disponibilità dell'immobile. L'avvocato negoziatore che assista un locatore in una controversia

di morosità deve valutare attentamente il rapporto tra il tentativo di mediazione e l'eventuale procedimento di sfratto per morosità, disciplinato dagli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, verificando se la condizione di procedibilità si applichi anche a tale procedimento speciale o soltanto all'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, questione sulla quale la giurisprudenza di merito ha registrato orientamenti non sempre uniformi.

La mediazione in materia locatizia può inoltre offrire soluzioni più flessibili di quelle disponibili in sede giudiziale, quali piani di rientro del debito locatizio rateizzati, riduzioni temporanee del canone in cambio di proroghe della durata contrattuale, o accordi di risoluzione anticipata consensuale con termini di rilascio concordati, soluzioni che il giudice del procedimento di sfratto non potrebbe imporre ma che le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale in sede di mediazione, possono liberamente concordare secondo le rispettive convenienze economiche e logistiche.

Diritti reali e servitù: la mediazione come strumento di gestione del vicinato

Le controversie in materia di diritti reali, comprendenti tipicamente le questioni di confini, servitù, immissioni ed emissioni moleste, si caratterizzano per la particolare durata nel tempo del rapporto di vicinato tra le parti, che rende la composizione negoziale particolarmente preferibile rispetto al contenzioso giudiziale, il quale tende non soltanto a non risolvere ma spesso ad aggravare la conflittualità relazionale sottostante. L'avvocato negoziatore che assista una parte in una controversia di vicinato dovrebbe orientare il cliente verso soluzioni che, oltre a definire la questione giuridica in senso stretto, prevengano il riproporsi di conflitti analoghi in futuro, ad esempio mediante la definizione dettagliata di protocolli di utilizzo delle parti comuni o di manutenzione delle opere che generano l'immissione contestata.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato, in materia di immissioni moleste ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, la difficoltà di accertare con precisione tecnica la soglia di normale tolleranza superata la quale l'immissione diviene illecita, un accertamento che richiede tipicamente il ricorso a consulenza tecnica specialistica (fonometrica, olfattometrica o di altra natura secondo il tipo di immissione contestata): la mediazione consente alle parti di concordare direttamente misure correttive proporzionate, senza attendere l'esito di un accertamento tecnico giudiziale spesso lungo e costoso, un vantaggio pratico che l'avvocato negoziatore dovrebbe illustrare con chiarezza al cliente nella fase di valutazione preliminare della controversia.

Il condominio: mediazione e assemblea

Le controversie condominiali presentano una peculiarità procedimentale rilevante: l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28/2010, come modificato nel tempo, richiede che la domanda di mediazione relativa a controversie condominiali sia presentata dall'amministratore previa delibera assembleare, quando la controversia riguardi l'intero condominio e non un singolo condomino, con la conseguenza che l'avvocato negoziatore che assiste un amministratore o un condominio deve verificare con attenzione la sussistenza e la regolarità di tale delibera prima di avviare la procedura, poiché un vizio in questa fase preliminare può incidere sulla stessa validità della domanda di mediazione e, di conseguenza, sull'assolvimento della condizione di procedibilità.

Le controversie tra singolo condomino e condominio, ad esempio in materia di impugnazione di delibere assembleari o di riparto delle spese comuni, restano invece governate dalle regole ordinarie sulla legittimazione a proporre la domanda di mediazione, senza necessità di previa delibera assembleare, trattandosi di una controversia nella quale il condominio agisce, o è convenuto, quale parte in senso proprio rappresentata dall'amministratore secondo le regole generali sulla rappresentanza dell'ente di gestione condominiale previste dagli articoli 1130 e seguenti del codice civile.

Approfondimento settoriale ulteriore

Mediazione e diritto della concorrenza

Le controversie in materia di concorrenza sleale, disciplinate dall'articolo 2598 del codice civile, non figurano tra le materie soggette a condizione di procedibilità, ma costituiscono un ambito nel quale la mediazione volontaria trova crescente applicazione nella prassi degli studi legali specializzati in diritto industriale, per la frequente esigenza delle imprese concorrenti di preservare rapporti commerciali indiretti all'interno della medesima filiera produttiva o distributiva, anche in presenza di un conflitto specifico relativo a comportamenti di concorrenza sleale. L'avvocato negoziatore che assista un'impresa in una controversia di questa natura dovrebbe valutare, in aggiunta ai profili risarcitori tradizionali, la possibilità di soluzioni negoziali che prevedano impegni comportamentali futuri reciproci, spesso più efficaci nella prevenzione di ulteriori conflitti rispetto alla mera liquidazione di un risarcimento pecuniario.

Le controversie relative a intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante, che coinvolgono tipicamente anche un interesse pubblico alla tutela del mercato oltre agli interessi privati delle parti coinvolte, presentano limiti strutturali all'utilizzo della mediazione, poiché l'accordo tra le parti non può validamente derogare alle norme imperative di tutela della concorrenza, la cui violazione resta soggetta ai poteri sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indipendentemente dalla composizione negoziale eventualmente raggiunta tra le parti private coinvolte nella controversia risarcitoria collegata.

La mediazione nei contratti di appalto pubblico

Il Codice dei contratti pubblici prevede, per le controversie relative all'esecuzione dei contratti di appalto, strumenti di risoluzione alternativa specificamente concepiti per il settore, tra cui l'accordo bonario disciplinato dall'articolo 205 del decreto legislativo 36/2023, che si affianca, senza sovrapporsi completamente, alla mediazione civile e commerciale ordinaria. L'avvocato negoziatore che assista un'impresa appaltatrice o una stazione appaltante in una controversia relativa all'esecuzione di un contratto pubblico deve conoscere le specificità procedurali dell'accordo bonario, che prevede la costituzione di una commissione tecnica per la valutazione delle riserve dell'appaltatore, un meccanismo che presenta tratti comuni con la mediazione ma se ne distingue per la natura tecnico-valutativa piuttosto che puramente negoziale del ruolo della commissione.

Va segnalato che, per le controversie relative a contratti pubblici che non rientrino nell'ambito applicativo specifico dell'accordo bonario, la mediazione civile e commerciale ordinaria resta comunque utilizzabile secondo le regole generali, sebbene la partecipazione della pubblica amministrazione alla procedura richieda l'identificazione del soggetto dotato del potere di

disporre del diritto controverso secondo le regole organizzative dell'ente, un tema già trattato nel presente volume in relazione alla preparazione del cliente istituzionale alla mediazione.

Diritto sportivo e mediazione: un ambito emergente

Il diritto sportivo, con la sua caratteristica architettura di giustizia interna articolata su più livelli (giustizia federale, Collegio di Garanzia dello Sport, arbitrato sportivo internazionale dinanzi al Tribunal Arbitral du Sport di Losanna), ha progressivamente sviluppato anche proprie forme di mediazione, specie per le controversie di natura patrimoniale tra club, agenti e atleti, che non coinvolgono direttamente l'applicazione di norme regolamentari sportive in senso stretto. L'avvocato negoziatore che operi nel settore sportivo dovrebbe conoscere le specificità di questo ambito, nel quale la rapidità della composizione della controversia assume un valore particolare in ragione della stagionalità delle competizioni sportive e della conseguente urgenza di definire le posizioni economiche e contrattuali degli atleti prima dell'inizio o durante lo svolgimento della stagione agonistica.

Approfondimento su ulteriori materie speciali

La mediazione in materia di responsabilità sanitaria: profili specifici

La legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco) ha attribuito alla mediazione, in alternativa alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, un ruolo specifico quale condizione di procedibilità per le controversie di responsabilità sanitaria, riconoscendo alle parti la facoltà di scegliere tra i due strumenti secondo le proprie preferenze procedurali. L'avvocato negoziatore che assista una parte in una controversia di responsabilità sanitaria dovrebbe valutare con particolare attenzione quale dei due strumenti risulti più adeguato al caso concreto, considerando, tra gli altri fattori, la complessità tecnico-medica della questione (che potrebbe favorire il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, la quale garantisce l'accesso a una valutazione tecnica specialistica strutturata secondo le regole del contraddittorio tecnico) e l'interesse delle parti a una composizione rapida e riservata della controversia, che potrebbe favorire invece il ricorso alla mediazione.

La partecipazione della struttura sanitaria e della relativa compagnia assicuratrice alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria richiede, secondo la prassi consolidata degli organismi specializzati in questo settore, un coordinamento particolarmente attento tra i diversi soggetti coinvolti (il professionista sanitario individualmente responsabile, la struttura presso cui ha operato, e le rispettive compagnie assicuratrici), un coordinamento che l'avvocato negoziatore del paziente danneggiato deve sollecitare attivamente, per evitare che la mediazione si areni per l'assenza di uno dei soggetti effettivamente competenti a disporre della somma necessaria alla composizione della controversia risarcitoria.

La mediazione bancaria e finanziaria: il rapporto con l'ABF

Le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, incluse tra le materie soggette a condizione di procedibilità mediativa dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, si affiancano, nel panorama degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in questo settore, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia con caratteristiche procedurali proprie, distinte da quelle della mediazione civile e commerciale ordinaria. L'avvocato negoziatore che assista un

cliente in una controversia bancaria deve valutare attentamente il rapporto tra questi due strumenti, tenendo presente che, secondo l'orientamento consolidato, il preventivo ricorso all'ABF non esonera dall'obbligo di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene le due procedure possano risultare, nella prassi, funzionalmente alternative quanto alla effettiva composizione della controversia.

La scelta tra ABF e mediazione, quando la controversia rientri nell'ambito di competenza di entrambi gli strumenti, dovrebbe essere orientata da considerazioni relative alla natura della controversia (l'ABF risulta particolarmente indicato per questioni di natura tecnico-contrattuale standardizzata, mentre la mediazione può risultare preferibile per controversie che coinvolgano una componente relazionale più articolata, ad esempio nei rapporti tra la banca e un cliente storico con cui intercorrano più rapporti contrattuali), e alla natura vincolante o meno della decisione, tenendo presente che l'ABF emette una decisione, sebbene non direttamente esecutiva, che orienta significativamente la successiva reputazione dell'intermediario vigilato, mentre la mediazione lascia interamente alle parti la determinazione del contenuto dell'eventuale accordo.

Le controversie in materia di subfornitura industriale

I contratti di subfornitura industriale, disciplinati dalla legge 192/1998, presentano peculiarità che rendono la mediazione uno strumento particolarmente adatto alla composizione delle relative controversie: la frequente asimmetria di potere contrattuale tra il committente e il subfornitore, spesso una piccola o media impresa dipendente in misura significativa dal rapporto con il committente per la propria sopravvivenza economica, rende la prosecuzione della relazione commerciale un interesse prioritario per il subfornitore, un interesse che la mediazione, orientata alla preservazione delle relazioni, può tutelare meglio della rigida alternativa vittoria-sconfitta tipica del contenzioso giudiziale. L'avvocato negoziatore che assista un subfornitore in una controversia con il proprio committente dovrebbe considerare con particolare attenzione questo profilo relazionale, orientando la strategia negoziale verso soluzioni che preservino, nella misura del possibile, la prosecuzione futura del rapporto commerciale, quando questo corrisponda all'interesse effettivo del cliente.

La legge sulla subfornitura prevede altresì specifiche tutele per il subfornitore contro l'abuso di dipendenza economica, disciplinato dall'articolo 9 della legge 192/1998, una fattispecie che presenta tratti di contiguità con la disciplina generale della concorrenza sleale e che può costituire oggetto di una controversia parallela o connessa a quella contrattuale principale, richiedendo all'avvocato negoziatore una valutazione integrata delle diverse azioni potenzialmente esperibili a tutela del cliente subfornitore.

Mediazione e diritto agrario

Le controversie agrarie, disciplinate da una normativa specialistica risalente in parte agli anni Settanta del secolo scorso e caratterizzata da un rito processuale speciale dinanzi alle sezioni specializzate agrarie, presentano peculiarità che rendono la mediazione uno strumento potenzialmente utile ma non sempre adeguatamente conosciuto dagli operatori del settore: le controversie tra proprietario e affittuario coltivatore, quelle relative ai contratti di soccida, e quelle relative alla successione nell'impresa agricola familiare presentano tutte una componente relazionale di lungo periodo che la mediazione, orientata alla preservazione delle relazioni, può gestire più efficacemente del contenzioso giudiziale specializzato. L'avvocato

negoziatore che operi in questo settore dovrebbe considerare la mediazione come strumento complementare, e non alternativo, alla specifica competenza tecnica richiesta dal contenzioso agrario specializzato.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di concorrenza sleale

La mediabilità delle controversie di concorrenza sleale tra imprese

Le controversie di concorrenza sleale tra imprese concorrenti, disciplinate dall'articolo 2598 e seguenti del codice civile, presentano generalmente piena mediabilità secondo le regole ordinarie della mediazione civile e commerciale, trattandosi di controversie relative a diritti patrimoniali disponibili delle parti coinvolte, sebbene la componente inibitoria tipica di questa materia (la richiesta di cessazione della condotta di concorrenza sleale contestata) richieda all'avvocato negoziatore un'attenta valutazione della compatibilità tra l'accordo negoziale raggiungibile in mediazione e l'efficacia effettiva della tutela inibitoria perseguita dal cliente, poiché un accordo di mediazione, per quanto vincolante tra le parti secondo le regole generali del contratto, non presenta la medesima efficacia esecutiva immediata di un provvedimento giudiziale inibitorio corredato da una penale per l'inosservanza secondo l'articolo 614-bis del codice di procedura civile, salvo che le parti stesse prevedano nell'accordo di mediazione una clausola penale di analogo contenuto e efficacia.

La rapidità di conseguimento di un accordo di mediazione rispetto ai tempi tipici di un giudizio cautelare o di merito in materia di concorrenza sleale costituisce, peraltro, un vantaggio significativo per l'impresa che lamenta una condotta di concorrenza sleale in atto, poiché la cessazione tempestiva della condotta lesiva, conseguita attraverso un accordo negoziale rapido, può risultare più efficace, in termini di tutela sostanziale degli interessi commerciali dell'impresa lesa, di una tutela giudiziale astrattamente più solida sotto il profilo dell'efficacia esecutiva ma conseguibile solo dopo un lasso di tempo durante il quale la condotta lesiva continuerebbe a produrre i propri effetti dannosi sul mercato.

Il ruolo delle associazioni di categoria nella promozione della mediazione settoriale

Numerose associazioni di categoria imprenditoriali hanno promosso, anche attraverso la costituzione di propri organismi di mediazione specificamente dedicati alle controversie tra imprese associate, la diffusione della mediazione come strumento preferenziale per la composizione delle controversie di concorrenza sleale e delle altre controversie commerciali tra imprese del medesimo settore economico, un impegno che risponde all'interesse collettivo della categoria a preservare relazioni commerciali sostenibili tra i propri associati, evitando l'inasprimento conflittuale tipico del contenzioso giudiziale prolungato, un obiettivo che l'avvocato negoziatore che assista imprese associate a organizzazioni di categoria dovrebbe tenere in adeguata considerazione nella scelta dello strumento di risoluzione della controversia più opportuno per il caso concreto.

Approfondimento: mediazione e diritto del lavoro nei rapporti dirigenziali

Le controversie con i dirigenti: specificità negoziali

Le controversie relative alla cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale presentano caratteristiche peculiari che le distinguono significativamente dalle controversie di lavoro subordinato ordinario, in ragione sia del regime giuridico parzialmente differenziato

applicabile ai dirigenti (in particolare quanto alla disciplina del licenziamento, sottratta all'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e regolata invece dai contratti collettivi di categoria attraverso l'istituto del licenziamento ingiustificato con conseguente indennità supplementare) sia della maggiore complessità economica delle pretese in gioco, tipicamente comprendenti non soltanto il trattamento di fine rapporto e le indennità sostitutive del preavviso, ma anche bonus, stock option, e clausole di non concorrenza post-contrattuale. L'avvocato negoziatore che assista un dirigente o un'impresa in una controversia di cessazione del rapporto dirigenziale deve possedere una conoscenza approfondita della contrattazione collettiva di categoria applicabile, che nella prassi disciplina in modo articolato l'istituto dell'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato secondo parametri specifici legati all'anzianità di servizio e alla retribuzione del dirigente.

La mediazione in materia di controversie dirigenziali, sebbene non generalmente soggetta a condizione di procedibilità secondo le regole ordinarie che escludono le controversie di lavoro dall'ambito della mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo 28/2010 (fatta salva l'applicabilità di procedure conciliative specifiche previste dalla contrattazione collettiva o dal codice di procedura civile in materia di lavoro), viene frequentemente utilizzata su base volontaria proprio in ragione della complessità economica e della delicatezza relazionale di queste controversie, che coinvolgono tipicamente un dirigente di elevata seniority e un'impresa con la quale il dirigente potrebbe mantenere, anche dopo la cessazione del rapporto, relazioni professionali indirette nel medesimo settore industriale.

I patti di non concorrenza post-contrattuale e la loro negoziazione

I patti di non concorrenza post-contrattuale, disciplinati dall'articolo 2125 del codice civile, che vincolano il lavoratore, e in particolare il dirigente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, richiedono, per la loro validità, il rispetto di specifici requisiti relativi alla forma scritta, alla durata massima, all'ambito oggettivo e territoriale del vincolo, e al corrispettivo economico riconosciuto al lavoratore, requisiti la cui verifica costituisce spesso oggetto di contestazione nelle controversie di cessazione del rapporto dirigenziale, con particolare riferimento alla congruità del corrispettivo economico rispetto all'entità del vincolo imposto, un parametro rispetto al quale la giurisprudenza ha elaborato criteri articolati che tengono conto della retribuzione precedentemente percepita dal dirigente e dell'ampiezza oggettiva e territoriale del divieto di concorrenza.

La mediazione può costituire uno strumento particolarmente utile per la composizione di controversie relative alla validità o all'ambito applicativo di un patto di non concorrenza, poiché consente alle parti di concordare soluzioni intermedie, quali una riduzione consensuale dell'ambito territoriale o temporale del vincolo in cambio di un adeguamento del corrispettivo economico, soluzioni che un giudice, chiamato a decidere unicamente sulla validità o invalidità del patto secondo un giudizio dicotomico, non potrebbe autonomamente elaborare nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale.

Approfondimento: mediazione e diritto del consumo

Il rapporto tra mediazione civile e organismi ADR di settore per i consumatori

Il decreto legislativo 130/2015, di recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, ha istituito un sistema specifico di organismi

ADR dedicati alla protezione del consumatore, distinto e per molti aspetti parallelo al sistema generale della mediazione civile e commerciale disciplinato dal decreto legislativo 28/2010: l'avvocato negoziatore che assista un consumatore in una controversia con un professionista deve valutare attentamente quale dei due sistemi risulti più adeguato al caso concreto, considerando che gli organismi ADR specificamente dedicati ai consumatori, quali quelli operanti nel settore delle telecomunicazioni, dell'energia e dei servizi finanziari, offrono tipicamente procedure gratuite o a costo simbolico per il consumatore, un vantaggio economico significativo rispetto alla mediazione civile ordinaria, sebbene con un ambito di competenza più circoscritto alle sole controversie di natura consumeristica in senso stretto.

La sovrapposizione parziale tra il sistema ADR consumeristico e la condizione di procedibilità mediativa prevista per le controversie di consumo dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 pone questioni di coordinamento procedurale che l'avvocato negoziatore deve conoscere: l'articolo 141 del codice del consumo, come modificato nel tempo, chiarisce che il previo ricorso a un organismo ADR specificamente competente per la materia consumeristica può soddisfare, in determinate circostanze, la medesima condizione di procedibilità richiesta per l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando al consumatore la necessità di esperire entrambi gli strumenti in sequenza, un chiarimento normativo che ha semplificato significativamente la gestione procedurale di queste controversie da parte dell'avvocato negoziatore.

Le azioni di classe e la mediazione: compatibilità e limiti

L'azione di classe, disciplinata dal titolo VIII-bis del codice di procedura civile dopo la riforma introdotta dalla legge 31/2019, pone questioni specifiche circa la compatibilità con lo strumento della mediazione, in ragione della particolare struttura procedimentale dell'azione di classe, che prevede una fase di adesione successiva alla pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dell'azione da parte del tribunale. La possibilità di una composizione mediata della controversia collettiva, sebbene teoricamente ipotizzabile e in alcuni casi effettivamente verificatasi nella prassi applicativa dell'istituto, richiede un coordinamento complesso tra l'organismo di mediazione, il tribunale competente per l'azione di classe, e la moltitudine dei soggetti aderenti all'azione, un coordinamento che presenta difficoltà organizzative significative rispetto alla mediazione bilaterale ordinaria, e che ha finora limitato la diffusione pratica di questo strumento nel contesto delle azioni di classe italiane.

L'avvocato negoziatore che assista un'impresa convenuta in un'azione di classe dovrebbe comunque considerare la possibilità di proporre, anche informalmente e al di fuori di una procedura di mediazione amministrata in senso proprio, una composizione negoziale collettiva della controversia, un approccio che, sebbene non regolato da una disciplina specifica dedicata alla mediazione delle azioni di classe, può risultare economicamente più efficiente rispetto alla prosecuzione di un contenzioso collettivo potenzialmente lungo e incerto quanto al proprio esito finale.

Approfondimento: mediazione e proprietà industriale

Le controversie in materia di marchi e brevetti

Le controversie in materia di proprietà industriale, quali quelle relative alla contraffazione di marchi registrati o alla violazione di brevetti, presentano caratteristiche di elevata

specializzazione tecnica che rendono la scelta dell'organismo di mediazione e del singolo mediatore particolarmente rilevante: l'avvocato negoziatore dovrebbe privilegiare, per queste controversie, organismi che dispongano di mediatori con specifica competenza tecnico-giuridica in materia di proprietà industriale, poiché la valutazione della fondatezza delle rispettive posizioni delle parti richiede tipicamente una comprensione tecnica approfondita della materia brevettuale o della disciplina dei segni distintivi, che un mediatore generalista potrebbe non possedere in misura adeguata.

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ha sviluppato un proprio centro di arbitrato e mediazione specificamente dedicato alle controversie in materia di proprietà intellettuale, che offre servizi di mediazione amministrata con mediatori specializzati in questa materia, un'opzione che l'avvocato negoziatore dovrebbe considerare per le controversie di proprietà industriale con elementi di internazionalità, specialmente quando la controversia coinvolga diritti di proprietà intellettuale registrati in più giurisdizioni, situazione nella quale un procedimento di mediazione unificato dinanzi a un organismo internazionalmente riconosciuto può risultare più efficiente rispetto a una pluralità di procedimenti nazionali paralleli.

La mediazione nelle controversie di diritto d'autore

Le controversie in materia di diritto d'autore, disciplinate dalla legge 633/1941 e successive modificazioni, presentano peculiarità che le rendono particolarmente adatte alla composizione mediata, specialmente quando coinvolgano rapporti di collaborazione creativa di lunga durata tra le parti (ad esempio tra un autore e il proprio editore, o tra i coautori di un'opera collettiva), rapporti nei quali la prosecuzione della collaborazione professionale futura costituisce spesso un interesse prioritario che la mediazione può tutelare più efficacemente rispetto al contenzioso giudiziale. L'avvocato negoziatore che assista un autore o un editore in una controversia di diritto d'autore dovrebbe considerare attentamente questa dimensione relazionale, orientando la strategia negoziale verso soluzioni che preservino, quando corrispondente all'interesse del cliente, la possibilità di una prosecuzione futura del rapporto di collaborazione creativa.

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e le altre organizzazioni di gestione collettiva dei diritti d'autore hanno progressivamente sviluppato propri meccanismi interni di composizione delle controversie con gli aventi diritto associati, meccanismi che si affiancano, senza sovrapporsi necessariamente, alla mediazione civile e commerciale ordinaria, e che l'avvocato negoziatore dovrebbe conoscere quando assista un cliente in una controversia che coinvolga tali organizzazioni di gestione collettiva.

Mediazione e diritto delle nuove tecnologie: intelligenza artificiale e dati

Le controversie emergenti connesse allo sviluppo e all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, quali quelle relative alla titolarità dei diritti su contenuti generati con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale generativa, o quelle relative alla responsabilità per danni causati da sistemi decisionali automatizzati, costituiscono un ambito in rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale nel quale la mediazione può offrire uno strumento di composizione flessibile in attesa della progressiva sedimentazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati su questioni giuridicamente ancora inedite. L'avvocato negoziatore che operi in questo ambito emergente dovrebbe mantenere un aggiornamento

costante sulla rapida evoluzione normativa, in particolare con riferimento al già citato regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, la cui piena applicazione progressiva genererà inevitabilmente nuove tipologie di controversie per le quali l'esperienza applicativa è ancora in fase di consolidamento.

Approfondimento: mediazione e diritto ambientale

Le controversie ambientali tra privati e la loro mediabilità

Le controversie di natura ambientale che coinvolgano esclusivamente interessi privati, quali quelle relative al risarcimento del danno da inquinamento causato da un'attività produttiva a carico dei proprietari di fondi limitrofi, sono generalmente mediabili secondo le regole ordinarie della mediazione civile e commerciale, eventualmente rientrando nella materia dei diritti reali già trattata nel presente capitolo quando la controversia coinvolga la disciplina delle immissioni prevista dall'articolo 844 del codice civile. La complessità tecnico-scientifica di queste controversie, che richiede tipicamente l'apporto di consulenze tecniche specialistiche per l'accertamento del nesso causale tra l'attività contestata e il danno lamentato, rende la scelta di un mediatore con adeguata competenza tecnica particolarmente rilevante, analogamente a quanto già osservato per le controversie di proprietà industriale.

Le controversie relative al danno ambientale in senso proprio, ossia al pregiudizio arrecato all'ambiente quale bene giuridico di rilevanza collettiva e non meramente ai singoli interessi patrimoniali privati coinvolti, restano invece sottratte alla mediazione civile e commerciale ordinaria, essendo disciplinate da un regime pubblicistico specifico previsto dal Codice dell'ambiente, che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica poteri di accertamento e di richiesta del risarcimento del danno ambientale non delegabili alla libera disponibilità negoziale delle parti private, un limite strutturale che l'avvocato negoziatore deve conoscere per orientare correttamente la scelta dello strumento più adeguato secondo la natura, pubblica o privata, dell'interesse effettivamente in gioco nella controversia ambientale considerata.

La responsabilità estesa del produttore e le controversie di sostenibilità

La crescente diffusione di normative in materia di responsabilità estesa del produttore, che impongono alle imprese obblighi specifici relativi alla gestione del ciclo di vita dei propri prodotti, incluso il loro smaltimento a fine vita, ha generato un numero crescente di controversie commerciali tra imprese relative alla corretta ripartizione di questi obblighi lungo la filiera produttiva e distributiva, controversie che presentano una componente tecnico-normativa specifica ma che restano, per la loro natura sostanzialmente commerciale e privatistica, pienamente mediabili secondo le regole ordinarie della mediazione civile e commerciale. L'avvocato negoziatore che operi nel settore della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa dovrebbe considerare la mediazione come uno strumento particolarmente adatto alla composizione di queste controversie emergenti, la cui novità normativa rende talvolta incerta la relativa disciplina sostanziale applicabile, un'incertezza che un accordo negoziale può gestire con maggiore flessibilità rispetto a un giudizio che richiederebbe l'applicazione rigida di disposizioni normative non sempre univocamente interpretabili.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di locazione commerciale

Le specificità della locazione ad uso non abitativo nel contesto mediativo

Le controversie relative ai contratti di locazione ad uso commerciale, disciplinati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, presentano specificità che l'avvocato negoziatore deve considerare nella gestione della relativa procedura di mediazione, in particolare per quanto riguarda l'istituto dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale previsto dall'articolo 34 della legge citata, che attribuisce al conduttore, in caso di cessazione del rapporto di locazione non dovuta a inadempimento del conduttore stesso, un'indennità pari, di regola, a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto (elevata a ventuno mensilità per le attività di natura turistica quali alberghi e attività assimilate), un profilo economico che deve essere adeguatamente valutato nella definizione degli accordi transattivi relativi alla cessazione anticipata del rapporto locativo commerciale.

La complessità della disciplina della locazione commerciale, che include anche la specifica regolamentazione del diritto di prelazione del conduttore in caso di vendita dell'immobile locato previsto dall'articolo 38 della legge 392/1978, e la disciplina della successione nel contratto in caso di cessione o affitto dell'azienda, richiede all'avvocato negoziatore una solida padronanza tecnica della materia locatizia commerciale per poter efficacemente assistere il proprio cliente nella valutazione delle diverse opzioni negoziali disponibili in sede di mediazione, che possono comprendere non soltanto la mera definizione economica della controversia relativa a canoni non corrisposti o a inadempimenti contrattuali, ma anche la rinegoziazione complessiva delle condizioni del rapporto locativo per il periodo residuo di durata del contratto.

La rinegoziazione del canone in presenza di sopravvenienze straordinarie

L'esperienza della pandemia da Covid-19 ha significativamente incrementato il ricorso alla mediazione per la rinegoziazione dei canoni di locazione commerciale, in presenza di sopravvenienze straordinarie che abbiano determinato una significativa alterazione dell'equilibrio economico del contratto secondo i principi generali della presupposizione contrattuale e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta previsti dagli articoli 1467 e seguenti del codice civile, un'esperienza che ha confermato l'efficacia della mediazione come strumento privilegiato per la gestione negoziale di sopravvenienze contrattuali straordinarie che il rigido meccanismo della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, previsto dal codice civile, non è sempre in grado di gestire con la necessaria flessibilità, essendo tale rimedio orientato alla cessazione del rapporto piuttosto che alla sua conservazione attraverso una rinegoziazione equilibrata delle condizioni contrattuali.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie relative a contratti pubblici

I limiti alla mediabilità delle controversie di appalto pubblico

Le controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici di appalto, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023), presentano una mediabilità parziale e condizionata, poiché mentre le controversie relative a profili meramente patrimoniali dell'esecuzione del contratto (quali il pagamento di corrispettivi contrattuali o la determinazione di riserve contabili dell'appaltatore) sono generalmente mediabili secondo le regole ordinarie della mediazione civile e commerciale, le controversie relative alla fase di affidamento del contratto pubblico, incluse le contestazioni relative all'aggiudicazione della

gara, restano sottratte alla mediazione civile in ragione della loro natura pubblicistica e della competenza esclusiva del giudice amministrativo su tali controversie secondo l'articolo 133 del Codice del processo amministrativo.

Il Codice dei contratti pubblici prevede peraltro propri specifici strumenti di risoluzione alternativa delle controversie relative all'esecuzione del contratto, quali l'accordo bonario disciplinato dall'articolo 205 del Codice, che costituisce un procedimento di composizione negoziale delle controversie relative all'esecuzione dei lavori pubblici distinto dalla mediazione civile ordinaria ma ispirato a principi in parte analoghi di composizione preventiva della controversia prima dell'eventuale ricorso al giudizio arbitrale o ordinario, uno strumento che l'avvocato negoziatore che assista un appaltatore o una stazione appaltante dovrebbe considerare in via prioritaria rispetto alla mediazione civile generale per le controversie che rientrino nel suo specifico ambito di applicazione.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie agricole e agroalimentari

Le specificità della mediazione nei contratti agrari

I contratti agrari, disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e dalla specifica disciplina delle sezioni specializzate agrarie istituite presso i tribunali ordinari, presentano una disciplina processuale specifica che si affianca, senza necessariamente escluderla, alla disciplina generale della mediazione civile e commerciale, con la particolarità che le controversie agrarie non rientrano espressamente tra le materie soggette a condizione di procedibilità obbligatoria previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, un'assenza che lascia alla libera iniziativa delle parti la scelta di avvalersi della mediazione civile e commerciale per la composizione di controversie relative a contratti agrari quali l'affitto di fondi rustici o la mezzadria, ove ancora residualmente presente nella prassi agricola di alcune regioni italiane.

L'avvocato negoziatore che assista un imprenditore agricolo in una controversia relativa a un contratto agrario dovrebbe considerare l'opportunità della mediazione anche in assenza di un obbligo legale, specialmente quando la controversia coinvolga soggetti legati da rapporti personali e comunitari risalenti nel tempo, situazione tipica del contesto agricolo rurale italiano, nel quale la preservazione delle relazioni comunitarie di lungo periodo tra i coltivatori di un medesimo territorio assume un valore che va oltre la mera definizione economica della singola controversia contrattuale, un obiettivo che la mediazione, per la sua natura relazionale e non meramente decisoria, può efficacemente perseguire.

Le controversie della filiera agroalimentare e le pratiche commerciali sleali

Le controversie relative a pratiche commerciali sleali nei rapporti di filiera tra produttori agricoli e acquirenti (distributori, industria di trasformazione), disciplinate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633, presentano una crescente mediabilità secondo le regole ordinarie della mediazione civile e commerciale, quando la controversia riguardi profili di natura essenzialmente patrimoniale relativi alla ripartizione del valore economico lungo la filiera, sebbene l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi mantenga specifiche competenze di vigilanza pubblicistica su questa materia, distinte dalla mera composizione privatistica della controversia tra le parti coinvolte, un quadro normativo complesso che l'avvocato negoziatore che assista soggetti della filiera agroalimentare dovrebbe conoscere con adeguata precisione tecnica.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di condominio con pluralità di edifici

Il supercondominio e le specificità della relativa mediazione

Il supercondominio, disciplinato dall'articolo 1117-bis del codice civile come introdotto dalla riforma del condominio del 2012, costituisce una fattispecie particolare di condominio che si instaura tra più edifici o più unità condominiali autonome che condividano parti comuni quali strade private, aree verdi, o impianti centralizzati, una fattispecie che presenta specifiche peculiarità applicative con riferimento alla mediazione delle relative controversie, in ragione della maggiore complessità organizzativa e della pluralità di soggetti potenzialmente coinvolti nella procedura, che può comprendere non soltanto i singoli condomini ma anche gli amministratori dei diversi condomini che compongono il supercondominio.

L'avvocato negoziatore che assista un condominio o un singolo condomino in una controversia relativa a un supercondominio dovrebbe verificare attentamente la legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione secondo le regole specifiche dell'articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplina la partecipazione dell'amministratore alla procedura di mediazione condominiale, un profilo che nel contesto del supercondominio richiede una specifica attenzione alla corretta individuazione del soggetto legittimato a partecipare, che potrebbe essere l'amministratore del supercondominio ove nominato, o gli amministratori dei singoli condomini componenti, secondo la struttura organizzativa specifica del supercondominio considerato.

Capitolo 6

Antiriciclaggio, privacy e telematica

L'attività dell'avvocato negoziatore si svolge oggi in un ambiente normativo trasversale che va oltre la disciplina propria della mediazione: gli obblighi antiriciclaggio, la protezione dei dati personali e la digitalizzazione della procedura, imposta in modo strutturale dal correttivo Cartabia del 2024, compongono un quadro di adempimenti tecnici che l'avvocato deve conoscere con precisione per non esporre il proprio cliente, e se stesso, a conseguenze pregiudizievoli.

6.1 Antiriciclaggio: l'esenzione del difensore e la posizione del mediatore

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della normativa europea antiriciclaggio, sottopone i professionisti, incluse le categorie forensi, a specifici obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione della documentazione e di segnalazione delle operazioni sospette. L'articolo 35, comma 5, del decreto esenta tuttavia l'avvocato dagli obblighi di segnalazione quando svolga un'opera di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, sia nella fase antecedente sia in quella successiva alla proposizione della domanda: una tutela che risponde all'esigenza di preservare il segreto professionale e il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Il dibattito sull'applicazione di questo regime all'attività di assistenza in mediazione resta aperto. Il Consiglio Nazionale Forense ha sostenuto un'interpretazione estensiva dell'esenzione, ritenendo che l'assistenza dell'avvocato in mediazione, in quanto attività strumentale alla

difesa dei diritti del cliente e alternativa al procedimento giudiziario in senso proprio, debba beneficiare della medesima esenzione prevista per il contenzioso; la Guardia di Finanza, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha invece manifestato un orientamento più restrittivo, propenso a limitare l'esenzione ai casi di difesa in senso stretto. Resta invece pacifico che l'organismo di mediazione, quale soggetto distinto dall'avvocato, rientri tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto 231/2007, in quanto soggetto che presta servizi relativi a operazioni suscettibili di generare movimentazioni patrimoniali rilevanti (fonte: mediareinformati.it, dossier Antiriciclaggio).

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato, in data 12 maggio 2023, con efficacia dal 1° gennaio 2024, un insieme di indicatori di anomalia specificamente riferiti alle operazioni di mediazione e negoziazione assistita, volti a orientare i soggetti obbligati nell'individuazione di schemi di operazioni potenzialmente sospette, quali accordi di mediazione che dissimulano trasferimenti patrimoniali privi di causale economica reale, o transazioni caratterizzate da un valore manifestamente incongruo rispetto all'oggetto della controversia. L'avvocato negoziatore, pur beneficiando dell'esenzione soggettiva sopra descritta nei limiti dell'attività defensionale, deve comunque prestare attenzione a questi indicatori quando assiste il proprio cliente nella definizione del contenuto economico dell'accordo di mediazione.

Sul piano operativo, l'avvocato che assiste una parte in una negoziazione o in una mediazione con contenuto economico rilevante dovrebbe comunque conservare, anche in assenza di un obbligo di segnalazione in senso tecnico, una documentazione adeguata della provenienza dei fondi oggetto dell'accordo, sia per ragioni di correttezza professionale sia per prevenire il rischio, sempre presente nella prassi, che l'accordo di mediazione venga successivamente contestato da terzi (creditori del debitore, curatore fallimentare, Agenzia delle Entrate) come atto in frode ai loro diritti, ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile in materia di azione revocatoria ordinaria.

Il tema si intreccia con la disciplina della segnalazione delle operazioni sospette prevista dagli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 231/2007, che impone ai soggetti obbligati (tra i quali, come visto, non rientra l'avvocato nell'esercizio dell'attività defensionale) di comunicare alla UIF le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che il denaro o i beni oggetto delle operazioni possano provenire da reato o essere connessi ad attività criminosa: un giudizio di anomalia che l'organismo di mediazione, quale soggetto obbligato, deve effettuare autonomamente rispetto alla valutazione dell'avvocato.

6.2 Protezione dei dati personali nel procedimento di mediazione

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'organismo di mediazione, dal mediatore e dagli avvocati che assistono le parti nel corso della procedura. La specificità del trattamento in ambito di mediazione risiede nella natura spesso sensibile delle informazioni trattate, in particolare nelle materie familiari, successorie e di responsabilità sanitaria, che possono coinvolgere dati relativi alla salute, alla vita familiare e a categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

L'obbligo di riservatezza previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 28/2010, che vieta al mediatore e ai soggetti che partecipano alla procedura di rendere dichiarazioni o informazioni acquisite nel corso della mediazione utilizzabili nel successivo giudizio, si affianca, senza sovrapporsi integralmente, agli obblighi generali di protezione dei dati personali. L'avvocato negoziatore deve quindi assicurare al proprio cliente una duplice tutela: la riservatezza processuale, che impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni rese in mediazione in un successivo giudizio, e la protezione dei dati personali in senso proprio, che disciplina le modalità di raccolta, conservazione e comunicazione delle informazioni trattate nel corso della procedura, anche successivamente alla sua conclusione.

Il titolare del trattamento nell'ambito della procedura di mediazione è, di regola, l'organismo di mediazione, che deve fornire alle parti l'informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati fin dal momento del deposito della domanda, specificando le finalità del trattamento, i tempi di conservazione dei dati e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L'avvocato che assiste la parte opera invece quale titolare autonomo del trattamento per i dati che raccoglie ed elabora nell'ambito del proprio mandato professionale, con la conseguenza che deve fornire, a sua volta, un'informativa distinta al proprio cliente, coerente con quella dell'organismo ma riferita specificamente all'attività di assistenza legale.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in più occasioni su questioni applicative relative alla mediazione, in particolare sul tema della conservazione dei fascicoli di mediazione dopo la conclusione della procedura e sulla comunicazione dei dati tra organismo e ministero della Giustizia ai fini statistici previsti dall'articolo 11 del decreto ministeriale 150/2023: il principio di minimizzazione impone che i dati trasmessi a fini statistici siano anonimizzati o pseudonimizzati, e che la conservazione dei fascicoli presso l'organismo non si prolunghi oltre il termine necessario alla tutela di eventuali diritti connessi alla procedura, di regola individuato nel termine di prescrizione ordinaria decennale.

6.3 La mediazione telematica dopo il correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024)

Il correttivo alla riforma Cartabia, decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha introdotto un regime organico della mediazione telematica, individuando quattro modalità attraverso le quali la procedura può svolgersi con strumenti digitali: la mediazione interamente telematica, nella quale l'intero procedimento, dal deposito della domanda alla sottoscrizione dell'accordo, si svolge attraverso piattaforme informatiche; la mediazione in videoconferenza, nella quale gli incontri si svolgono con collegamento audiovisivo a distanza pur restando la documentazione cartacea o firmata digitalmente secondo le forme ordinarie; la mediazione mista, che combina fasi telematiche e fasi in presenza; e la mediazione tradizionale in presenza, che resta comunque disponibile su richiesta delle parti.

Modalità

Interamente telematica

Videoconferenza

Mista

Tradizionale in presenza

La sottoscrizione digitale dell'accordo di mediazione richiede, per gli atti che non necessitano di trascrizione, l'utilizzo di firme conformi al Codice dell'amministrazione digitale e al regolamento eIDAS (regolamento UE 910/2014): firma elettronica qualificata o firma digitale in formato PAdES, quest'ultimo divenuto lo standard tecnico di riferimento per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi di mediazione in formato PDF. Per gli atti da trascrivere nei registri immobiliari, resta invece necessario l'intervento del notaio ai sensi dell'articolo 21 del Codice dell'amministrazione digitale, che richiede la firma digitale certificata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato per gli atti pubblici e le scritture private autenticate destinate alla trascrizione.

La giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del correttivo ha già affrontato diverse questioni applicative relative alla mediazione telematica. Il Tribunale di Brindisi, con l'ordinanza n. 1127 del 2025, il Tribunale di Avellino, con l'ordinanza n. 1445 del 2025, il Tribunale di Modena, con l'ordinanza n. 87 del 2025, il Tribunale di Foggia, con l'ordinanza n. 1009 del 2025, e il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza n. 2712 del 2025, hanno affrontato questioni relative alla validità della partecipazione a distanza e alla verifica dell'identità delle parti collegate in videoconferenza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio, con la sentenza n. 4361 del 2024, e il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. 1590 del 2023, hanno esaminato profili fiscali e formali connessi alla registrazione di accordi conclusi con modalità telematiche. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3452 del 2024, hanno inoltre affrontato un tema di carattere più generale sulla validità degli atti processuali telematici, con riflessi anche sulla materia della mediazione (fonte: mediareinformati.it, dossier Telematica).

Le statistiche disponibili per il 2025 confermano la rapidità con cui la prassi ha assorbito la digitalizzazione della procedura: circa il 51 per cento delle mediazioni avviate nel corso dell'anno si è svolto, in tutto o in parte, con modalità telematiche, un dato che segna un cambiamento strutturale nella prassi professionale rispetto al periodo antecedente la pandemia, quando la mediazione a distanza costituiva un'eccezione residuale (fonte: mediareinformati.it, dossier Numeri della mediazione).

6.4 Conseguenze pratiche per l'avvocato negoziatore

La disponibilità di modalità telematiche pienamente equivalenti, sul piano degli effetti giuridici, alla partecipazione in presenza comporta per l'avvocato negoziatore un onere informativo specifico verso il proprio cliente: deve chiarire, prima dell'avvio della procedura, quali modalità siano disponibili presso l'organismo di mediazione prescelto, quali requisiti tecnici siano necessari per la partecipazione a distanza, e quali cautele adottare per assicurare la riservatezza della comunicazione, in particolare quando la sessione si svolga da un ambiente domestico o lavorativo non adeguatamente isolato da terzi non partecipanti alla procedura. L'avvocato che assiste il cliente da remoto deve inoltre verificare la piena corrispondenza tra l'identità del soggetto collegato in videoconferenza e quella della parte formalmente indicata nella domanda di mediazione, compito che nella prassi giudiziaria ha già generato le prime pronunce di merito sopra richiamate.

La disponibilità di modalità telematiche pone, infine, un problema di adeguatezza formativa e strumentale in capo all'organismo di mediazione, che deve garantire alle parti l'accesso a piattaforme sicure, conformi ai requisiti tecnici di interoperabilità e sicurezza informatica individuati dal ministero della Giustizia con i decreti attuativi del correttivo Cartabia.

L'avvocato negoziatore dovrebbe, nella scelta dell'organismo al quale indirizzare la domanda di mediazione quando questa non sia già vincolata da una clausola contrattuale, tenere conto anche della qualità e della sicurezza della piattaforma telematica offerta, elemento che incide direttamente sulla protezione dei dati personali trattati e sulla stessa validità formale della procedura.

Un ulteriore profilo riguarda l'accessibilità digitale per le parti prive di competenze informatiche adeguate o di dispositivi idonei: la mediazione telematica non può tradursi in un ostacolo di fatto all'accesso alla giustizia per le fasce di popolazione meno avvezze agli strumenti digitali, e l'avvocato negoziatore ha, in questi casi, un ruolo di mediazione tecnologica ulteriore rispetto a quello giuridico in senso proprio, dovendo assicurarsi che il proprio cliente comprenda pienamente le modalità di svolgimento della procedura o, in alternativa, richiedere motivatamente la modalità in presenza quando quella telematica non risulti adeguata al caso concreto.

Fonti citate nel capitolo: d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 3, 35; regolamento UE 2016/679 (GDPR), artt. 9 ss.; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 9; d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 21; regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS); UIF, indicatori di anomalia, 12 maggio 2023 (efficaci dal 1° gennaio 2024); Trib. Brindisi 1127/2025; Trib. Avellino 1445/2025; Trib. Modena 87/2025; Trib. Foggia 1009/2025; Trib. Salerno 2712/2025; CGT Lazio 4361/2024; Trib. Milano 1590/2023; Cass. SS.UU. 3452/2024; dossier mediareinformati.it: Antiriciclaggio, Telematica, Numeri della mediazione.

6.5 La conservazione digitale a norma degli atti di mediazione

Il codice dell'amministrazione digitale impone agli organismi di mediazione, in quanto soggetti che gestiscono un procedimento con rilevanza pubblicistica, di adottare sistemi di conservazione digitale a norma degli atti prodotti nel corso della procedura, in modo da garantirne l'integrità, l'autenticità e la reperibilità nel tempo, anche a fini di eventuale produzione in giudizio. L'avvocato negoziatore dovrebbe verificare, specie quando assista clienti con esigenze di conservazione documentale particolarmente stringenti (ad esempio imprese soggette a obblighi di compliance regolamentare), che l'organismo di mediazione prescelto disponga di un sistema di conservazione digitale conforme agli standard previsti dalle regole tecniche dell'Agenzia per l'Italia digitale, e non si limiti a un mero archivio informatico privo delle garanzie di immodificabilità richieste dalla normativa.

La firma elettronica avanzata o qualificata dell'accordo di mediazione, quando il procedimento si svolga in modalità telematica, deve rispettare i requisiti previsti dal regolamento eIDAS per l'equiparazione alla firma autografa: l'avvocato negoziatore che assiste le parti nella sottoscrizione digitale dell'accordo deve verificare che il sistema utilizzato dall'organismo generi una firma effettivamente qualificata, e non un semplice avanzamento grafico non equiparabile alla sottoscrizione autografa ai fini della validità e dell'efficacia esecutiva dell'accordo stesso.

6.6 Formazione continua dell'avvocato in materia digitale

La transizione digitale della mediazione, imposta strutturalmente dalla riforma Cartabia, richiede all'avvocato negoziatore un aggiornamento continuo delle proprie competenze tecniche in materia di sicurezza informatica, firma digitale e protezione dei dati, competenze

che tradizionalmente non facevano parte del bagaglio formativo dell'avvocato generalista. Il Consiglio Nazionale Forense ha progressivamente inserito moduli formativi dedicati alla transizione digitale nell'ambito dell'offerta di formazione continua obbligatoria, un segnale della crescente rilevanza di queste competenze anche per l'avvocatura non specializzata in diritto delle nuove tecnologie.

Approfondimento

Il registro dei titolari effettivi e gli obblighi dell'organismo di mediazione

Gli organismi di mediazione, in quanto soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio nei limiti chiariti dal Capitolo 6, devono acquisire e conservare le informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche che siano parti del procedimento, quando tale obbligo sia applicabile secondo la natura della procedura, consultando a tal fine il registro dei titolari effettivi tenuto presso il registro delle imprese secondo la disciplina attuativa del decreto legislativo 231/2007. L'avvocato negoziatore che assista una persona giuridica in mediazione dovrebbe essere pronto a fornire, se richiesto dall'organismo, le informazioni necessarie a tale adempimento, per non ritardare l'avvio della procedura.

La verifica dell'identità e dei poteri di rappresentanza del soggetto che partecipa in mediazione per conto di una persona giuridica assume, in questo contesto, una duplice rilevanza: da un lato quella, già segnalata nel Capitolo 3, relativa alla validità della procura sostanziale necessaria per la partecipazione effettiva alla mediazione; dall'altro quella, specifica della disciplina antiriciclaggio, relativa all'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo secondo gli obblighi di adeguata verifica che gravano sui soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio.

Cybersecurity e mediazione telematica: standard tecnici

Gli organismi di mediazione che offrono servizi in modalità telematica devono adottare misure di sicurezza informatica adeguate a proteggere la riservatezza delle comunicazioni e dei documenti scambiati nel corso della procedura, in conformità con i principi generali di sicurezza del trattamento previsti dall'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'avvocato negoziatore che assista il cliente in una mediazione telematica dovrebbe verificare, quantomeno a un livello generale, che la piattaforma utilizzata dall'organismo adotti standard di sicurezza riconosciuti (cifatura delle comunicazioni, autenticazione a più fattori per l'accesso alla piattaforma, politiche di conservazione sicura dei dati), specialmente quando la controversia coinvolga informazioni particolarmente sensibili sotto il profilo commerciale o personale.

Il rischio di intercettazione o di accesso non autorizzato alle comunicazioni digitali scambiate nel corso della mediazione telematica, sebbene statisticamente contenuto nella prassi finora registrata, impone all'avvocato negoziatore un dovere di prudenza nella gestione delle informazioni più sensibili del cliente, che può tradursi, nei casi di maggiore delicatezza, nella scelta di riservare taluni contenuti a comunicazioni orali dirette con il mediatore o con la controparte, anziché a scambi documentali digitali, quando il regolamento dell'organismo lo consenta.

Approfondimento sistemico ulteriore

L'intelligenza artificiale generativa negli organismi di mediazione

L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte degli organismi di mediazione, sia per finalità organizzative interne (gestione delle pratiche, supporto alla redazione dei verbali) sia, più cautamente, come supporto informativo per le parti nella fase di orientamento preliminare, pone questioni di trasparenza e di protezione dei dati personali che l'avvocato negoziatore deve monitorare con attenzione. Il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), sebbene non specificamente concepito per il settore della mediazione, introduce obblighi di trasparenza e di gestione del rischio che si applicano anche agli strumenti di intelligenza artificiale eventualmente impiegati dagli organismi di mediazione, specie quando tali strumenti intervengano in fasi del procedimento che possano incidere sui diritti delle parti.

L'avvocato negoziatore dovrebbe informarsi, presso l'organismo di mediazione prescelto, circa l'eventuale impiego di strumenti di intelligenza artificiale nel corso della procedura, e valutare, in accordo con il proprio cliente, se tale impiego sia compatibile con le esigenze di riservatezza e di controllo umano del processo decisionale che caratterizzano tradizionalmente la mediazione, un istituto che si fonda, per sua natura, sulla dimensione relazionale e umana del confronto tra le parti, una dimensione che l'automazione, per quanto tecnicamente sofisticata, non può sostituire senza alterare la natura stessa dell'istituto.

Il trasferimento internazionale dei dati nella mediazione transfrontaliera

Quando la mediazione coinvolga parti residenti in Stati situati fuori dell'Unione europea, il trattamento dei dati personali raccolti nel corso della procedura deve conformarsi alle regole sul trasferimento internazionale dei dati previste dal Capo V del regolamento generale sulla protezione dei dati, che richiedono, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea per il paese di destinazione, l'adozione di garanzie appropriate quali le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione. L'organismo di mediazione che gestisca procedure con elementi di internazionalità extraeuropea deve quindi predisporre un'adeguata base giuridica per il trasferimento dei dati, e l'avvocato negoziatore dovrebbe verificare, quando assista un cliente in una mediazione di questo tipo, che tali garanzie siano effettivamente in essere.

Approfondimento sulla protezione dei dati nella mediazione digitale

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per gli organismi di mediazione

Gli organismi di mediazione che trattino sistematicamente categorie particolari di dati personali, quali dati relativi alla salute nelle controversie di responsabilità sanitaria o dati relativi a procedimenti penali nelle controversie che coinvolgano profili di rilevanza penale connessi alla vicenda civile, devono valutare l'obbligo di condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del regolamento generale sulla protezione dei dati, quando il trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate. L'avvocato negoziatore, sebbene non sia il titolare del trattamento nell'ambito della procedura di mediazione (ruolo che spetta tipicamente all'organismo di mediazione), dovrebbe verificare che l'organismo prescelto abbia adottato le misure organizzative necessarie a tale valutazione, specie nelle controversie che coinvolgano dati particolarmente sensibili del proprio cliente.

La designazione di un responsabile della protezione dei dati (data protection officer) da parte dell'organismo di mediazione, sebbene non sempre obbligatoria secondo i criteri generali dell'articolo 37 del regolamento, costituisce una prassi raccomandabile per gli organismi che gestiscano un volume significativo di procedure e che trattino, di conseguenza, un volume corrispondentemente elevato di dati personali delle parti, dei loro difensori e dei mediatori designati, un presidio organizzativo che l'avvocato negoziatore può considerare, tra gli altri fattori, nella valutazione comparativa degli organismi di mediazione disponibili per la propria clientela.

Il diritto di accesso del cliente ai propri dati trattati nella mediazione

Il diritto di accesso previsto dall'articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati si applica anche ai dati personali trattati dall'organismo di mediazione nell'ambito della procedura, con la conseguenza che la parte, anche successivamente alla conclusione del procedimento, può richiedere all'organismo l'accesso ai propri dati personali ivi trattati, sebbene tale diritto debba essere bilanciato con il principio di riservatezza delle comunicazioni intercorse nel corso della mediazione, che l'articolo 9 del decreto legislativo 28/2010 tutela in modo particolarmente rigoroso. L'avvocato negoziatore dovrebbe informare il proprio cliente circa l'esistenza di questo diritto di accesso, chiarendo al contempo i limiti che il principio di riservatezza pone al suo pieno esercizio, specie con riferimento a informazioni che riguardino direttamente la posizione o le dichiarazioni della controparte.

La conservazione dei dati personali trattati nell'ambito della procedura di mediazione, secondo il principio di limitazione della conservazione previsto dall'articolo 5 del regolamento generale sulla protezione dei dati, deve essere limitata al periodo strettamente necessario alle finalità del trattamento, tipicamente individuato dai regolamenti degli organismi di mediazione in un periodo di alcuni anni successivi alla conclusione della procedura, per finalità di eventuale difesa in giudizio dell'organismo stesso rispetto a contestazioni relative alla regolarità della procedura svolta, un termine che l'avvocato negoziatore dovrebbe conoscere per orientare correttamente il cliente circa la possibilità di recuperare documentazione relativa a procedure di mediazione concluse in passato.

Approfondimento: governance e controlli interni degli organismi di mediazione

I modelli organizzativi ai sensi del decreto legislativo 231/2001

Gli organismi di mediazione costituiti in forma societaria, e in particolare quelli di maggiori dimensioni che gestiscano un volume significativo di procedure, possono valutare l'adozione di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001, un presidio volontario ma raccomandabile per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, quali il reato di corruzione tra privati che potrebbe astrattamente configurarsi in relazione a condotte di conduzione non imparziale della procedura di mediazione dietro compenso occulto da una delle parti. L'adozione di un simile modello organizzativo, unitamente alla nomina di un organismo di vigilanza indipendente, costituisce un elemento di garanzia ulteriore della correttezza gestionale dell'organismo di mediazione, che l'avvocato negoziatore può considerare, tra gli altri fattori, nella valutazione comparativa degli organismi disponibili per la propria clientela istituzionale di maggiori dimensioni.

Il Ministero della Giustizia, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sugli organismi di mediazione iscritti nel registro ministeriale, ha progressivamente rafforzato i controlli relativi alla effettiva indipendenza e imparzialità degli organismi, anche attraverso verifiche a campione sulla regolarità delle procedure svolte e sulla corretta gestione dei conflitti di interesse tra l'organismo, i propri mediatori e le parti dei procedimenti amministrati, un controllo che si affianca, senza sovrapporsi, agli eventuali controlli volontari interni che l'organismo abbia autonomamente adottato secondo il proprio modello di governance.

La certificazione di qualità degli organismi di mediazione

Alcuni organismi di mediazione italiani hanno conseguito certificazioni di qualità secondo standard internazionali quali la norma ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione della qualità, un elemento che, sebbene non richiesto dalla normativa italiana quale condizione per l'iscrizione nel registro ministeriale, costituisce un indicatore ulteriore di affidabilità organizzativa che l'avvocato negoziatore può considerare nella scelta dell'organismo più adeguato alle esigenze del proprio cliente, specialmente in relazione a controversie di rilevante valore economico o di particolare complessità tecnica, per le quali la qualità organizzativa e procedurale dell'organismo assume un'importanza proporzionalmente maggiore.

La pubblicazione di indicatori di performance da parte degli organismi di mediazione più trasparenti, quali il tasso di successo delle procedure amministrate, la durata media dei procedimenti, e il livello di soddisfazione delle parti rilevato attraverso questionari post-procedimento, costituisce una prassi di trasparenza volontaria sempre più diffusa tra gli organismi di maggiori dimensioni, che l'avvocato negoziatore dovrebbe considerare come un ulteriore elemento informativo utile nella scelta dell'organismo più adeguato, oltre ai criteri più tradizionali di prossimità territoriale e di costo della procedura.

Approfondimento: la conservazione digitale a lungo termine degli atti di mediazione

Gli standard tecnici della conservazione digitale a norma

La conservazione digitale a norma degli atti relativi al procedimento di mediazione, disciplinata dalle regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale, richiede l'adozione di sistemi di conservazione che garantiscano, nel tempo, l'integrità, l'autenticità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti conservati, secondo un processo tecnico che tipicamente prevede l'apposizione di una marca temporale e di una firma digitale del responsabile della conservazione, con periodicità di rinnovo delle marche temporali per garantire la persistente validità tecnica della conservazione anche a fronte dell'obsolescenza degli algoritmi crittografici originariamente utilizzati. Gli organismi di mediazione di maggiori dimensioni si affidano tipicamente a conservatori accreditati esterni, specializzati nella fornitura di questo servizio secondo gli standard tecnici previsti dalla normativa, mentre gli organismi di minori dimensioni possono optare per soluzioni di conservazione interna, purché conformi ai medesimi standard tecnici.

L'avvocato negoziatore dovrebbe verificare, specialmente per procedure di particolare rilevanza economica o che possano generare contenzioso successivo relativo alla regolarità della procedura svolta, che l'organismo di mediazione prescelto adotti sistemi di conservazione digitale adeguati, poiché la possibilità di produrre in un eventuale giudizio successivo una copia autentica e integra della documentazione relativa alla procedura di mediazione (in particolare

il verbale di mancato accordo, rilevante ai fini della successiva decisione sulle spese processuali) dipende direttamente dalla qualità del sistema di conservazione digitale adottato dall'organismo.

L'accesso agli atti conservati da parte dei terzi legittimati

L'accesso agli atti conservati relativi a una procedura di mediazione conclusa, quando richiesto da soggetti diversi dalle parti originarie del procedimento (ad esempio eredi delle parti, aventi causa a titolo particolare, o autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti connessi), richiede all'organismo di mediazione una valutazione attenta della legittimazione del richiedente e dei limiti posti dal principio di riservatezza che governa l'istituto della mediazione, un bilanciamento che gli organismi più esperti hanno tipicamente disciplinato attraverso protocolli interni specifici, che l'avvocato negoziatore dovrebbe conoscere quando si trovi ad assistere un cliente che richieda l'accesso a documentazione relativa a una procedura di mediazione conclusa in passato e alla quale il cliente non abbia originariamente partecipato quale parte diretta.

Approfondimento: la formazione continua in materia di antiriciclaggio per gli organismi di mediazione

I programmi formativi specifici richiesti dalla normativa antiriciclaggio

Gli organismi di mediazione, nella misura in cui siano soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio secondo i criteri già illustrati nel presente volume, devono garantire ai propri mediatori e al proprio personale una formazione periodica specifica in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, secondo gli obblighi formativi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 231/2007, un obbligo formativo che si affianca, senza sovrapporsi, alla più generale formazione continua richiesta ai mediatori dal decreto ministeriale 150/2023 in materia di tecniche di mediazione e di aggiornamento normativo generale. L'avvocato negoziatore che assista clienti in controversie potenzialmente rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio (ad esempio controversie che coinvolgano importi particolarmente significativi o controparti provenienti da giurisdizioni considerate a maggior rischio secondo le liste elaborate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) dovrebbe verificare che l'organismo di mediazione prescelto disponga di personale adeguatamente formato su questi profili.

La documentazione dell'attività formativa svolta dall'organismo di mediazione in materia antiriciclaggio costituisce un elemento rilevante anche ai fini della responsabilità dell'organismo stesso in caso di successivo accertamento di violazioni della normativa antiriciclaggio, poiché la dimostrazione di un'adeguata formazione del personale coinvolto costituisce un elemento difensivo significativo nella valutazione della diligenza organizzativa complessiva dell'organismo, secondo principi generali di responsabilità organizzativa analoghi a quelli già illustrati con riferimento ai modelli di organizzazione e controllo previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Approfondimento: la protezione dei dati minori nelle procedure di mediazione familiare

Il trattamento dei dati dei minori coinvolti indirettamente nella controversia

Le procedure di mediazione che coinvolgano controversie familiari, sebbene formalmente riferite ai genitori quali parti della procedura, comportano frequentemente il trattamento di dati personali relativi ai figli minori, quali informazioni relative al loro percorso scolastico, al loro stato di salute, o alle loro relazioni familiari, un trattamento che richiede particolari cautele secondo i principi generali del GDPR relativi alla protezione rafforzata dei dati dei minori, considerati categoria di soggetti meritevoli di specifica tutela in ragione della loro vulnerabilità. L'organismo di mediazione e il mediatore che conduca una procedura di mediazione familiare devono adottare specifiche cautele nella raccolta e nella conservazione di queste informazioni, limitandone l'accesso al solo personale strettamente necessario per la conduzione della procedura, e evitando la conservazione di tali dati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per le finalità della procedura stessa.

L'avvocato negoziatore che assista un genitore in una procedura di mediazione familiare che coinvolga indirettamente dati relativi ai figli minori dovrebbe verificare che l'organismo di mediazione prescelto abbia adottato adeguate misure organizzative e tecniche per la protezione di questi dati particolarmente sensibili, un profilo di verifica che si affianca alle più generali verifiche in materia di protezione dei dati già illustrate nel presente capitolo con riferimento alla generalità delle procedure di mediazione civile e commerciale.

L'eventuale ascolto del minore nella procedura di mediazione

Sebbene la procedura di mediazione familiare non preveda, a differenza del procedimento giudiziale relativo all'affidamento dei figli minori, un obbligo generalizzato di ascolto del minore capace di discernimento, alcuni organismi di mediazione specializzati in materia familiare hanno sviluppato protocolli specifici per un eventuale coinvolgimento indiretto del minore nella procedura, attraverso colloqui separati condotti da un professionista specificamente formato, finalizzati a raccogliere, con le necessarie cautele psicologiche, il punto di vista del minore rispetto alle decisioni che lo riguardano, senza tuttavia attribuire a tale ascolto un valore probatorio o decisionale diretto sull'esito della mediazione, che resta di esclusiva competenza negoziale dei genitori quali parti della procedura. L'avvocato negoziatore che assista un genitore in una procedura di questo tipo dovrebbe informarsi adeguatamente sui protocolli specifici adottati dall'organismo prescelto in materia di ascolto del minore, per poter opportunamente consigliare il proprio cliente circa l'opportunità di avvalersi di tale strumento nel caso concreto.

Approfondimento: la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per gli organismi di mediazione

I presupposti per l'obbligo di valutazione d'impatto secondo l'articolo 35 GDPR

L'articolo 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati impone al titolare del trattamento, quando un tipo di trattamento, allo stato delle conoscenze tecnologiche, sia idoneo a presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, un obbligo che può riguardare, in specifiche circostanze, anche gli organismi di mediazione, quando questi trattino sistematicamente categorie particolari di dati personali su larga scala, ad esempio nel caso di un organismo specializzato nella mediazione di controversie sanitarie che tratti sistematicamente dati relativi allo stato di salute di un numero significativo di interessati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in attuazione dell'articolo 35, paragrafo 4, del GDPR, un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al meccanismo di valutazione d'impatto obbligatoria, elenco che, sebbene non menzioni specificamente gli organismi di mediazione quali categoria a sé stante, individua criteri generali (quali il trattamento sistematico di dati relativi alla salute su larga scala) potenzialmente applicabili a specifici organismi di mediazione altamente specializzati in ragione della tipologia di controversie gestite, un profilo che l'organismo di mediazione dovrebbe verificare con l'assistenza di un responsabile della protezione dei dati o di un consulente privacy specializzato.

Il contenuto della valutazione d'impatto e il ruolo del responsabile della protezione dei dati

Quando l'organismo di mediazione sia soggetto all'obbligo di valutazione d'impatto, questa deve contenere, secondo quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 7, del GDPR, una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, e le misure previste per affrontare i rischi, incluse le garanzie, le misure di sicurezza e le modalità previste per dimostrare la conformità al Regolamento, un documento tecnicamente complesso la cui elaborazione richiede tipicamente l'apporto di un responsabile della protezione dei dati con specifiche competenze tecniche e giuridiche in materia di protezione dei dati personali, figura che gli organismi di mediazione di maggiori dimensioni dovrebbero considerare di nominare anche al di fuori dei casi di obbligatorietà normativa, quale presidio organizzativo di buona pratica gestionale.

Approfondimento: i registri antiriciclaggio e la conservazione documentale digitale

Gli obblighi di conservazione digitale secondo il Codice dell'amministrazione digitale

Gli organismi di mediazione soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione della relativa documentazione secondo il decreto legislativo 231/2007 devono adempiere a tali obblighi conservativi nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Codice dell'amministrazione digitale per la conservazione digitale a norma dei documenti informatici, quando la documentazione relativa all'adeguata verifica della clientela sia formata o conservata in formato digitale, requisiti che comprendono l'adozione di sistemi di conservazione che garantiscano l'autenticità, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti conservati per l'intero periodo di conservazione decennale previsto dalla normativa antiriciclaggio, secondo gli standard tecnici definiti dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'organismo di mediazione che intenda avvalersi di un sistema di conservazione digitale a norma per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dovrebbe valutare l'opportunità di affidare tale servizio a un conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, che garantisce il rispetto di tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa applicabile, piuttosto che gestire autonomamente la conservazione digitale della documentazione, un'opzione che richiederebbe competenze tecniche specialistiche che l'organismo di mediazione tipicamente non possiede internamente, con il conseguente rischio di non conformità ai requisiti tecnici previsti dalla normativa.

Il rapporto tra conservazione digitale e diritto alla protezione dei dati personali

La conservazione digitale a norma della documentazione antiriciclaggio, che comporta tipicamente il trattamento di dati personali dei clienti dell'organismo di mediazione per un periodo prolungato di dieci anni, deve essere gestita in conformità ai principi generali del GDPR relativi alla minimizzazione dei dati conservati e alla proporzionalità del periodo di conservazione rispetto alle finalità del trattamento, sebbene in questo specifico caso la durata decennale della conservazione trovi una giustificazione normativa specifica nell'obbligo legale previsto dalla normativa antiriciclaggio, che costituisce base giuridica autonoma del trattamento secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR, un profilo di coordinamento normativo che l'organismo di mediazione dovrebbe adeguatamente documentare nel proprio registro dei trattamenti.

Approfondimento: i rapporti tra organismi di mediazione e piattaforme fintech

L'utilizzo di sistemi di pagamento digitale per le indennità di mediazione

La crescente digitalizzazione dei servizi offerti dagli organismi di mediazione ha comportato, tra le altre conseguenze, un progressivo ricorso a piattaforme tecnologiche di natura finanziaria (fintech) per la gestione dei pagamenti delle indennità di mediazione dovute dalle parti, un ricorso che pone specifiche questioni di compliance antiriciclaggio quando tali piattaforme fintech siano utilizzate per la raccolta di pagamenti provenienti da soggetti terzi rispetto alle parti formalmente coinvolte nella procedura, situazione che richiede all'organismo di mediazione un'attenta verifica della provenienza dei fondi secondo i principi generali della normativa antiriciclaggio già illustrati nel presente capitolo.

L'organismo di mediazione che si avvalga di una piattaforma fintech per la gestione dei pagamenti dovrebbe verificare che tale piattaforma sia essa stessa un soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento secondo la normativa bancaria e finanziaria applicabile, tipicamente attraverso l'iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d'Italia o attraverso analogia autorizzazione rilasciata da altra autorità di vigilanza dell'Unione europea con passaporto comunitario, un profilo di verifica che, sebbene tecnicamente distinto dagli obblighi antiriciclaggio propri dell'organismo di mediazione, contribuisce alla riduzione del rischio complessivo di coinvolgimento involontario in circuiti di pagamento non conformi alla normativa applicabile.

Approfondimento: la nomina del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento nell'organismo di mediazione

La qualificazione dell'organismo di mediazione quale titolare autonomo del trattamento

L'organismo di mediazione riveste, secondo l'interpretazione consolidata delle disposizioni del GDPR, la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle parti e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di mediazione, poiché determina autonomamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati raccolti nell'ambito della propria attività istituzionale, una qualificazione che comporta l'assunzione di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento a carico del titolare del trattamento, incluso l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, l'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento secondo l'articolo 30 del GDPR, e l'obbligo di notifica delle

violazioni di dati personali all'autorità di controllo secondo l'articolo 33 del Regolamento, quando ne sussistano i presupposti.

Il mediatore che conduca la procedura per conto dell'organismo di mediazione, quando operi in qualità di libero professionista incaricato dall'organismo secondo il modello organizzativo tipico previsto dal decreto ministeriale 150/2023, assume tipicamente la qualifica di persona autorizzata al trattamento secondo le istruzioni del titolare, ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, piuttosto che quella di responsabile del trattamento in senso tecnico, salvo che le circostanze specifiche del rapporto tra organismo e mediatore giustifichino una diversa qualificazione, un profilo che l'organismo di mediazione dovrebbe adeguatamente definire nella propria documentazione contrattuale interna con i propri mediatori iscritti.

Il rapporto con eventuali fornitori esterni di servizi tecnologici

L'organismo di mediazione che si avvalga di fornitori esterni per la gestione della propria piattaforma tecnologica di mediazione telematica, per la conservazione digitale della documentazione, o per altri servizi che comportino il trattamento di dati personali per conto dell'organismo stesso, deve stipulare con tali fornitori un accordo di responsabile del trattamento conforme ai requisiti previsti dall'articolo 28 del GDPR, che disciplini in dettaglio le istruzioni impartite al fornitore, le misure di sicurezza adottate, e le modalità di restituzione o cancellazione dei dati al termine del rapporto contrattuale, un adempimento che l'organismo di mediazione dovrebbe sistematicamente verificare nella gestione dei propri rapporti con fornitori tecnologici esterni.

Approfondimento: il diritto alla portabilità dei dati nell'ambito delle procedure di mediazione

L'applicabilità del diritto alla portabilità ai dati trattati dall'organismo di mediazione

Il diritto alla portabilità dei dati, disciplinato dall'articolo 20 del GDPR, consente all'interessato di ottenere dal titolare del trattamento i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, un diritto la cui applicabilità ai dati trattati dagli organismi di mediazione presenta profili di specifica complessità applicativa, poiché tale diritto si applica, secondo la previsione normativa, solo ai trattamenti basati sul consenso dell'interessato o sull'esecuzione di un contratto, e non ai trattamenti basati su altre basi giuridiche quali l'adempimento di un obbligo legale, con la conseguenza che la portabilità dei dati trattati dall'organismo di mediazione potrebbe non essere pienamente applicabile con riferimento a quella parte della documentazione conservata in adempimento di specifici obblighi legali, quali quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

L'avvocato negoziatore che assista una parte che intenda esercitare il diritto alla portabilità dei propri dati trattati da un organismo di mediazione dovrebbe quindi preliminarmente verificare la base giuridica del trattamento con riferimento a ciascuna categoria di dati coinvolta, per individuare correttamente l'ambito applicativo di questo specifico diritto rispetto alla più generale disciplina del diritto di accesso previsto dall'articolo 15 del GDPR, che si applica invece indistintamente a tutte le categorie di trattamento indipendentemente dalla base giuridica applicabile.

Approfondimento: il registro dei trattamenti dell'organismo di mediazione

Il contenuto essenziale del registro secondo l'articolo 30 del GDPR

Il registro delle attività di trattamento, la cui tenuta è obbligatoria secondo l'articolo 30 del GDPR per i titolari del trattamento che occupino più di duecentocinquanta dipendenti, o che effettuino trattamenti che possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, o che riguardino categorie particolari di dati, criteri che ricorrono frequentemente per gli organismi di mediazione in ragione della natura sensibile di molte controversie trattate, deve indicare in particolare le finalità del trattamento, le categorie di interessati e di dati personali trattati, le categorie di destinatari a cui i dati sono comunicati, gli eventuali trasferimenti verso paesi terzi, i termini previsti per la cancellazione, e una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

L'avvocato negoziatore che assista un organismo di mediazione nella propria compliance in materia di protezione dei dati personali dovrebbe verificare che il registro dei trattamenti sia stato correttamente predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, un adempimento che, sebbene di natura essenzialmente documentale e organizzativa, costituisce un elemento centrale della dimostrazione di accountability richiesta dal GDPR a tutti i titolari del trattamento, secondo il principio di responsabilizzazione che pervade l'intera architettura normativa del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Capitolo 7

La responsabilità civile dell'avvocato negoziatore

L'ampliamento del ruolo dell'avvocato nel procedimento di mediazione, descritto nei capitoli precedenti, ha come corrispettivo un ampliamento dell'area di responsabilità professionale. L'avvocato che omette di informare il cliente sulla mediazione, che non verifica correttamente la validità di una procura, o che sottoscrive un accordo senza adeguata verifica di legalità, risponde civilmente delle conseguenze dannose della propria condotta secondo i principi generali della responsabilità professionale, con alcune specificità che questo capitolo ricostruisce.

7.1 L'obbligo informativo dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 impone all'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico, l'obbligo di informare il proprio assistito della possibilità di avvalersi della mediazione, delle agevolazioni fiscali collegate al suo esperimento, e dei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La disposizione prescrive che l'informazione sia fornita chiaramente e per iscritto, che il documento informativo sia sottoscritto dall'assistito, e che esso sia allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio: in caso di violazione di questi obblighi, la norma sanziona espressamente il contratto tra l'avvocato e l'assistito con l'annullabilità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Seconda n. 31852 del 5 dicembre 2019, ha affermato con chiarezza che la sola sottoscrizione di un mandato ad litem o di una delega in bianco da parte del cliente non è sufficiente ad assolvere l'obbligo informativo previsto dall'articolo 4, comma 3: è necessario un documento specifico, dedicato all'informazione sulla mediazione, sottoscritto dall'assistito con piena consapevolezza del suo contenuto. Nel caso

oggetto della pronuncia, la violazione dell'obbligo informativo ha condotto all'annullamento del contratto d'opera professionale, con la conseguente perdita, per lo studio legale, del diritto al compenso richiesto, in una controversia nella quale il valore complessivo in discussione, tra richiesta di onorari e danno non patrimoniale lamentato dal cliente, si è attestato in prossimità dei 150.000 euro (fonte: Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 31852).

« L'obbligo informativo sulla mediazione non può ritenersi assolto con la mera consegna e sottoscrizione di una delega in bianco, pur contenendo quest'ultima un richiamo generico all'istituto della mediazione. »

— **Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 31852 (sintesi)**

Il principio affermato dalla Cassazione ha una portata pratica immediata per l'avvocato negoziatore: la predisposizione di un modello informativo scritto, specificamente dedicato alla mediazione, distinto dal mandato alle liti e sottoscritto separatamente dal cliente, costituisce oggi una prassi difensiva imprescindibile, non soltanto per assolvere l'obbligo deontologico, ma per prevenire il rischio di annullamento del contratto d'opera professionale e la conseguente perdita del diritto al compenso, oltre all'eventuale responsabilità risarcitoria verso il cliente per il pregiudizio subito.

Un profilo applicativo ulteriore riguarda la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di responsabilità promosso dal cliente contro l'avvocato per omessa informazione sulla mediazione: secondo i principi generali della responsabilità contrattuale, spetta al cliente provare l'esistenza del contratto d'opera professionale e allegare l'inadempimento, mentre spetta all'avvocato provare di aver correttamente adempiuto all'obbligo informativo, tipicamente mediante la produzione del documento informativo sottoscritto dall'assistito. L'assenza di tale documento, o la sua genericità, espone l'avvocato a un rischio probatorio significativo, poiché difficilmente potrà dimostrare per altra via l'assolvimento dell'obbligo.

7.2 Il nesso di causalità nella responsabilità dell'avvocato negoziatore

La responsabilità civile dell'avvocato per condotte relative alla fase di mediazione segue i principi generali della responsabilità professionale, con la necessità di accertare un nesso di causalità tra la condotta colposa del legale e il danno lamentato dal cliente. La specificità della materia risiede nella natura spesso probabilistica di questo accertamento: quando l'avvocato omette di informare il cliente sulla mediazione, o non prepara adeguatamente la partecipazione al primo incontro, il danno non consiste normalmente nella perdita certa di un risultato, ma nella perdita di una possibilità di risultato favorevole, categoria che il diritto civile italiano qualifica come perdita di chance.

L'accertamento del nesso causale nella responsabilità professionale forense segue, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il criterio della probabilità logica o baconiana, distinto dal criterio dell'evidenza scientifica proprio del giudizio penale: il giudice civile deve accertare, sulla base degli elementi di prova disponibili, se sia più probabile che non che la condotta diligente dell'avvocato avrebbe determinato un esito diverso e più favorevole per il cliente, senza che sia necessaria la certezza assoluta di questo nesso, incompatibile con la natura intrinsecamente incerta dell'esito di una negoziazione o di un giudizio.

7.3 La perdita di chance come categoria di danno risarcibile

La giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce relative alla responsabilità professionale dell'avvocato al di fuori della materia specifica della mediazione, ha da tempo consolidato la categoria della perdita di chance come voce di danno autonomamente risarcibile, distinta dal danno da mancato conseguimento del risultato finale: il cliente che dimostri, con ragionevole probabilità, che una condotta professionale diligente dell'avvocato avrebbe aumentato le proprie possibilità di ottenere un esito favorevole della controversia, ha diritto al risarcimento del valore di questa possibilità perduta, anche quando non sia possibile affermare con certezza che l'esito sarebbe stato effettivamente favorevole.

Applicata alla mediazione, questa categoria opera tipicamente nei seguenti scenari: l'avvocato che non informa il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa in una materia nella quale la composizione negoziale avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo; l'avvocato che non prepara adeguatamente il cliente al primo incontro dopo la riforma Cartabia, vanificando l'opportunità di una composizione immediata che la nuova natura sostanziale del primo incontro rende oggi concretamente praticabile; l'avvocato che, per negligenza nella verifica della procura sostanziale, determina l'invalidità dell'accordo di mediazione con conseguente declaratoria di improcedibilità della successiva domanda giudiziale, con perdita di tempo e di risorse per il cliente e, in ipotesi di prescrizione del diritto medio tempore maturata, perdita definitiva della possibilità di tutela giurisdizionale.

La liquidazione del danno da perdita di chance segue, nella prassi giurisprudenziale, un criterio equitativo che tiene conto sia del valore del bene della vita che sarebbe stato conseguito in caso di esito favorevole, sia del grado di probabilità di tale esito, stimato sulla base delle circostanze del caso concreto: una percentuale di probabilità più elevata giustifica una liquidazione più prossima al valore integrale del bene perduto, mentre una probabilità più contenuta giustifica una liquidazione proporzionalmente più modesta. Questo criterio, elaborato in origine per la responsabilità medica e successivamente estesa alla responsabilità forense, si presta ad applicazione anche al caso specifico della mancata informazione sulla mediazione, sebbene la giurisprudenza specifica sul punto sia ancora in via di consolidamento.

7.4 Il danno da negligenza nella sottoscrizione dell'accordo

Come osservato nel Capitolo 3, la sottoscrizione dell'accordo di mediazione da parte dell'avvocato produce l'effetto di titolo esecutivo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 28/2010, e presuppone una verifica di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'avvocato che sottoscrive un accordo contenente clausole contrarie a norme imperative, o che pregiudicano illegittimamente gli interessi del proprio cliente senza che questi ne sia stato adeguatamente informato, risponde per negligenza professionale delle conseguenze dannose che ne derivano, secondo il regime generale della responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligazione professionale, che nel nostro ordinamento è obbligazione di mezzi e non di risultato, ma che richiede comunque l'osservanza della diligenza qualificata prevista dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Accanto alla responsabilità per negligenza nella verifica di legalità dell'accordo, si colloca la responsabilità per negligenza nella redazione tecnica del testo dell'accordo stesso: clausole ambigue, termini di adempimento non definiti con precisione, omessa indicazione delle modalità di pagamento o delle garanzie a presidio dell'obbligazione assunta dalla controparte, possono generare, in sede di esecuzione forzata del titolo, contestazioni che vanificano in tutto o

in parte l'efficacia esecutiva che l'articolo 12 del decreto legislativo 28/2010 attribuisce all'accordo sottoscritto dagli avvocati. La redazione tecnica dell'accordo richiede quindi all'avvocato negoziatore una competenza specifica, non inferiore a quella richiesta per la redazione di un contratto o di una transazione giudiziale, e la medesima cura nella verifica della coerenza interna del testo e della sua eseguibilità futura.

7.5 L'assicurazione professionale obbligatoria

L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato), impone a ogni avvocato l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, comprensiva della copertura della custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, e di renderne edotto il cliente al momento dell'assunzione dell'incarico, con l'indicazione dei dati della polizza e del relativo massimale. L'obbligo assicurativo si estende, senza distinzioni, a tutte le attività professionali dell'avvocato, incluse quelle di assistenza in mediazione e in negoziazione assistita, che rientrano pienamente nell'esercizio della professione forense ai fini della copertura assicurativa.

L'avvocato negoziatore deve inoltre considerare che l'estensione della propria responsabilità professionale alle attività di negoziazione richiede una verifica specifica delle condizioni di polizza, in particolare quando l'attività di assistenza in mediazione presenti caratteristiche che si avvicinano, per intensità dell'intervento comunicativo e relazionale, a quelle proprie del mediatore professionale: mentre la responsabilità del mediatore è disciplinata da un regime assicurativo specifico previsto dal decreto ministeriale 150/2023 per gli organismi di mediazione, la responsabilità dell'avvocato che assiste le parti resta soggetta al regime generale della responsabilità professionale forense, con la conseguente necessità di una copertura assicurativa che tenga conto anche di questa specifica area di attività.

Le compagnie assicurative che offrono polizze di responsabilità civile professionale per avvocati hanno progressivamente adeguato le proprie condizioni generali di polizza per tenere conto dell'espansione dell'attività di mediazione e negoziazione assistita, introducendo talora clausole specifiche di copertura o, in altri casi, escludendo espressamente alcune attività ritenute di natura non strettamente forense (ad esempio l'attività di mediatore in senso proprio, quando l'avvocato assuma tale ulteriore qualifica). L'avvocato negoziatore dovrebbe quindi verificare periodicamente, in occasione del rinnovo della polizza, che le condizioni di copertura restino adeguate all'evoluzione della propria attività professionale, specie quando questa si estenda a settori specialistici come la composizione negoziata della crisi d'impresa o la mediazione familiare internazionale.

7.6 Rapporto con la responsabilità disciplinare

Come già osservato nel Capitolo 2, la violazione dell'obbligo informativo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 e degli obblighi deontologici previsti dagli articoli 62 e 62-bis del codice deontologico forense può generare, in parallelo alla responsabilità civile analizzata in questo capitolo, un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine competente. Le due responsabilità operano su piani distinti e non sono reciprocamente condizionanti: l'accertamento della responsabilità disciplinare non presuppone né esclude l'accertamento della responsabilità civile, e viceversa, sebbene nella prassi le due azioni siano spesso proposte in sequenza dal cliente insoddisfatto, e la pronuncia disciplinare, se

intervenuta, costituisca frequentemente un elemento di prova rilevante nel successivo o contestuale giudizio civile di risarcimento del danno.

Un ultimo profilo, di crescente rilevanza pratica, riguarda la responsabilità dell'avvocato per l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella preparazione di atti o memorie relativi alla procedura di mediazione: l'avvocato che si affidi acriticamente a un sistema di intelligenza artificiale per la redazione di un accordo di mediazione o di un parere sulla convenienza della composizione negoziale, senza sottoporre il contenuto generato a un'adeguata verifica professionale, risponde delle conseguenze dannose derivanti da errori, omissioni o riferimenti normativi inesistenti (il cosiddetto fenomeno delle hallucinations), secondo il medesimo standard di diligenza qualificata che governa l'intera responsabilità professionale forense, senza che l'origine automatizzata dell'errore possa costituire causa di esonero o di attenuazione della responsabilità.

Fonti citate nel capitolo: d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 4, 12; Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 31852; art. 1176, comma 2, c.c.; l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 12; d.m. 150/2023; codice deontologico forense, artt. 62, 62-bis; diritto.it, Violazione degli obblighi di informativa dell'avvocato, F. Pizzigallo.

7.7 Il regime prescrizione dell'azione di responsabilità

L'azione di responsabilità civile del cliente contro l'avvocato negoziatore per omesso o inadeguato adempimento degli obblighi informativi in materia di mediazione si prescrive, trattandosi di responsabilità contrattuale derivante dal mandato professionale, nel termine ordinario decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile, con decorrenza dal momento in cui il danno si manifesta e diviene oggettivamente percepibile dal cliente danneggiato, secondo il principio della cosiddetta actio nata sostanziale piuttosto che meramente formale. Nella prassi, il momento di decorrenza può risultare significativamente successivo alla condotta omissiva originaria, specie quando il pregiudizio si manifesti soltanto in un successivo giudizio nel quale il cliente si vede addossare le spese processuali per non aver tempestivamente esperito la mediazione obbligatoria.

L'avvocato negoziatore convenuto in giudizio per responsabilità professionale può opporre l'eccezione di prescrizione, ma deve farlo tempestivamente secondo le regole processuali ordinarie, e comunque valutando con cura l'opportunità di tale strategia difensiva rispetto al rischio reputazionale connesso a un contenzioso pubblico con un proprio cliente, un fattore che nella prassi conduce spesso alla ricerca di soluzioni transattive anche in questo tipo di controversie, secondo una logica di composizione negoziale che risulta per certi versi paradossale, ma non incoerente, quando applicata proprio alla materia della mediazione.

7.8 Onere probatorio del cliente e presunzioni giurisprudenziali

Sul piano probatorio, il cliente che agisce per responsabilità professionale deve dimostrare la condotta inadempiente dell'avvocato, il danno subito e il nesso di causalità tra i due elementi, secondo le regole generali dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, che tuttavia si atteggiavano in modo peculiare quando l'inadempimento consista in un'omissione informativa: la giurisprudenza tende infatti a valorizzare, a favore del cliente, l'assenza di prova scritta dell'assolvimento dell'obbligo informativo da parte dell'avvocato, un dato che nella prassi induce i professionisti più accorti a documentare sistematicamente, anche mediante

comunicazioni scritte o PEC, l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi relativi alla mediazione, preconstituendo così una prova difensiva per l'eventuale contenzioso successivo.

Approfondimento

La responsabilità del mediatore: profili distinti da quella dell'avvocato

Va tenuta distinta, sotto il profilo della responsabilità civile, la posizione dell'avvocato negoziatore da quella del mediatore, poiché quest'ultimo risponde, in via principale, verso l'organismo di mediazione secondo le regole del rapporto contrattuale che li lega, e, in via eventuale, verso le parti secondo i principi generali della responsabilità extracontrattuale o, secondo alcune ricostruzioni dottrinali, di una responsabilità da contatto sociale qualificato. L'articolo 9 del decreto legislativo 28/2010 impone al mediatore doveri di riservatezza e imparzialità la cui violazione può generare una responsabilità autonoma rispetto a quella dell'avvocato che assiste le parti, e che si affianca, senza sovrapporsi, alla responsabilità solidale dell'organismo di mediazione per fatto del mediatore da esso designato.

L'avvocato negoziatore che ritenga il mediatore abbia agito in violazione dei propri doveri di imparzialità o riservatezza dovrebbe segnalare tempestivamente la circostanza all'organismo di mediazione, che ha il potere e il dovere di intervenire secondo il proprio regolamento interno, e, nei casi più gravi, all'organismo di vigilanza ministeriale competente per la tenuta del registro degli organismi di mediazione, poiché la tutela della correttezza procedimentale della mediazione costituisce un interesse che trascende la singola procedura e riguarda la credibilità sistemica dell'istituto nel suo complesso.

Le polizze assicurative claims made e la mediazione

Le polizze di responsabilità civile professionale forense, tipicamente strutturate secondo il modello claims made (che copre le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dal momento in cui il fatto generatore si è verificato), pongono all'avvocato negoziatore un problema specifico di gestione del rischio nel tempo: un errore commesso nella consulenza sulla mediazione può generare una richiesta di risarcimento anche a distanza di anni, quando il danno si manifesti soltanto tardivamente, ad esempio in un giudizio nel quale il cliente si veda addossare le spese processuali per non aver tempestivamente esperito la mediazione obbligatoria. La struttura claims made rende quindi essenziale per l'avvocato la continuità della copertura assicurativa nel tempo, anche dopo la cessazione dell'attività professionale, attraverso le cosiddette clausole di postuma, previste obbligatoriamente dalla normativa sull'assicurazione professionale forense.

La legge professionale forense, all'articolo 12 della legge 247/2012, impone all'avvocato l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, comprensiva della responsabilità per la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, un obbligo che si estende naturalmente anche all'attività di assistenza in mediazione, quale componente ordinaria dell'attività professionale forense contemporanea, e che l'avvocato negoziatore deve verificare sia adeguatamente riflesso nelle condizioni della propria polizza, specie quanto ai massimali e alle eventuali esclusioni relative all'attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Approfondimento sulla responsabilità ulteriore

La responsabilità solidale nello studio associato

Quando l'avvocato negoziatore operi all'interno di uno studio associato o di una società tra avvocati, la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi informativi relativi alla mediazione può estendersi, secondo le regole generali sulla responsabilità delle associazioni professionali e delle società tra professionisti, anche agli altri soci dello studio, quando il mandato professionale sia stato conferito formalmente allo studio nel suo complesso piuttosto che al singolo professionista che ha materialmente gestito la controversia. Questa configurazione di responsabilità solidale, che caratterizza tipicamente le società tra avvocati disciplinate dalla legge 247/2012 e dal successivo decreto legislativo 96/2001 e sue modifiche, impone un regime di controllo interno particolarmente rigoroso circa l'adempimento degli obblighi informativi in materia di mediazione da parte di tutti i professionisti operanti nello studio, indipendentemente dalla loro seniority o specializzazione.

Gli studi legali di maggiori dimensioni hanno progressivamente adottato protocolli interni di verifica della conformità (compliance) che prevedono, tra l'altro, checklist standardizzate per l'apertura di nuovi incarichi, comprendenti la verifica sistematica dell'applicabilità della condizione di procedibilità mediativa alla controversia oggetto del mandato, e la documentazione dell'assolvimento dell'obbligo informativo previsto dall'articolo 27 del codice deontologico forense, un presidio organizzativo che riduce significativamente il rischio di responsabilità professionale dello studio nel suo complesso.

Mediazione e responsabilità del terzo assicuratore

Nelle controversie di responsabilità civile nelle quali intervenga un'assicurazione a copertura del rischio del danneggiante, la partecipazione dell'assicuratore alla mediazione, sebbene non sempre obbligatoria secondo le regole processuali ordinarie, risulta spesso opportuna e nella prassi frequentemente richiesta dal mediatore stesso, poiché l'assicuratore è tipicamente il soggetto che dispone della effettiva disponibilità economica per l'adempimento dell'eventuale accordo risarcitorio. L'avvocato negoziatore che assista il danneggiante dovrebbe attivarsi presso la propria compagnia assicuratrice affinché questa partecipi attivamente alla mediazione, eventualmente tramite un proprio delegato dotato di adeguato potere di transigere entro i limiti del massimale di polizza, per evitare che la mediazione si areni per assenza del soggetto realmente competente a disporre della somma necessaria alla composizione.

Approfondimento sulla responsabilità civile: casistica assicurativa

Il sinistro da omessa informativa: quantificazione del danno

La quantificazione del danno risarcibile in conseguenza della responsabilità dell'avvocato per omessa informativa sulla mediazione obbligatoria richiede un accertamento probatorio articolato, che deve muovere dalla dimostrazione del nesso causale tra l'omissione dell'informativa e il pregiudizio patrimoniale concretamente subito dal cliente, tipicamente rappresentato dalla condanna alle spese processuali per l'improcedibilità della domanda, ovvero dal ritardo nella definizione della controversia con conseguente pregiudizio economico per la parte, ad esempio in termini di interessi legali non maturati o di deprezzamento del bene oggetto della controversia nel periodo di ritardo. La giurisprudenza di merito, nella liquidazione di questo tipo di danno, ha generalmente adottato un criterio di stretta correlazione tra il

pregiudizio economico documentato e il risarcimento liquidato, evitando liquidazioni equitative eccessivamente ampie in assenza di specifica prova del danno.

L'onere probatorio relativo al danno da omessa informativa grava, secondo i principi generali sulla responsabilità contrattuale professionale, sul cliente danneggiato, il quale deve dimostrare non soltanto l'omissione dell'informativa da parte dell'avvocato ma anche che, ove correttamente informato, egli avrebbe effettivamente esperito la mediazione con una ragionevole probabilità di successo, un accertamento probatorio spesso complesso che richiede una valutazione prognostica controfattuale circa l'esito che la mediazione avrebbe potuto avere se tempestivamente esperita.

Le clausole di limitazione della responsabilità nel mandato professionale

La possibilità per l'avvocato di limitare contrattualmente la propria responsabilità professionale nei confronti del cliente, attraverso apposite clausole inserite nella lettera di mandato o nelle condizioni generali di affidamento dell'incarico, incontra limiti significativi nell'ordinamento italiano, poiché l'articolo 1229 del codice civile vieta la validità delle clausole che escludano o limitino preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, un divieto che si applica pienamente anche al rapporto tra avvocato e cliente. Le clausole di limitazione della responsabilità per colpa lieve, sebbene astrattamente ammissibili secondo i principi generali del diritto civile, sono raramente utilizzate nella prassi forense italiana, sia per ragioni deontologiche di opportunità professionale sia per la difficoltà pratica di distinguere, in sede di accertamento giudiziale, tra colpa lieve e colpa grave dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale.

L'avvocato negoziatore che desideri comunque circoscrivere l'ambito della propria responsabilità professionale dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla precisa definizione dell'oggetto del mandato conferito dal cliente, specificando in modo dettagliato le prestazioni professionali incluse nell'incarico (ad esempio, se l'incarico comprenda anche l'assistenza in eventuale mediazione obbligatoria, o si limiti alla sola instaurazione del giudizio), una precisazione che, sebbene non costituisca una clausola di limitazione della responsabilità in senso tecnico, contribuisce a circoscrivere l'ambito degli obblighi professionali assunti e, conseguentemente, l'ambito della responsabilità civile eventualmente conseguente al loro inadempimento.

Approfondimento: la gestione del rischio professionale nello studio legale

I sistemi di gestione del rischio (risk management) applicati alla pratica forense

L'adozione di sistemi strutturati di gestione del rischio professionale, mutuati dalle metodologie proprie del risk management aziendale e progressivamente diffusisi anche presso gli studi legali di maggiori dimensioni, consente all'avvocato negoziatore e ai propri collaboratori di identificare, valutare e mitigare sistematicamente i rischi di responsabilità professionale connessi alla gestione delle procedure di mediazione, attraverso strumenti quali le checklist procedurali standardizzate, i sistemi informatici di gestione delle scadenze (particolarmente rilevanti per il rispetto dei termini processuali connessi alla condizione di procedibilità mediativa), e le procedure di revisione tra pari (peer review) per le pratiche di maggiore complessità o valore economico.

La cultura del rischio professionale, tradizionalmente meno sviluppata nella pratica forense italiana rispetto ad altri settori professionali quali la revisione contabile o l'attività bancaria, ha registrato una crescente diffusione negli ultimi anni, anche in ragione della crescente complessità normativa che caratterizza la professione forense contemporanea e del conseguente incremento del rischio di responsabilità professionale per omissioni o errori procedurali, un fenomeno che il presente volume ha ripetutamente documentato con specifico riferimento agli obblighi informativi e procedurali connessi alla mediazione civile e commerciale.

La revisione periodica dei protocolli interni: una prassi raccomandabile

L'avvocato negoziatore, sia che operi individualmente sia che operi all'interno di uno studio associato o di una società tra avvocati, dovrebbe sottoporre a revisione periodica i propri protocolli interni relativi alla gestione della mediazione, aggiornandoli in relazione alle evoluzioni normative e giurisprudenziali progressivamente intervenute, secondo un ciclo di revisione che dovrebbe essere quantomeno annuale in considerazione del significativo dinamismo normativo che caratterizza questa materia, come ampiamente documentato dai successivi interventi normativi intervenuti dal 2010 alla riforma Cartabia e ai suoi successivi decreti correttivi.

La documentazione di questa attività di revisione periodica, oltre a costituire una buona prassi organizzativa in senso proprio, può assumere rilevanza probatoria significativa in caso di successiva contestazione di responsabilità professionale, dimostrando la diligenza organizzativa complessiva dello studio nella gestione degli obblighi informativi e procedurali connessi alla mediazione, un elemento che, sebbene non esima automaticamente da responsabilità in caso di errore concretamente verificatosi nel singolo caso, può contribuire a una valutazione complessivamente più favorevole della diligenza professionale dello studio nel suo insieme.

Approfondimento: la responsabilità civile del mediatore e la sua assicurazione

Gli obblighi assicurativi specifici del mediatore professionista

Il decreto ministeriale 150/2023 impone agli organismi di mediazione l'obbligo di garantire, direttamente o attraverso i propri mediatori, un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di mediazione, un obbligo che si affianca, senza sovrapporsi, all'eventuale assicurazione professionale personale del mediatore quando questi sia anche avvocato o esercente altra professione regolamentata. La verifica dell'esistenza e dell'adeguatezza di questa copertura assicurativa, sebbene rientri primariamente nelle competenze di vigilanza del Ministero della Giustizia sugli organismi iscritti nel registro, può costituire un elemento di valutazione ulteriore per l'avvocato negoziatore nella scelta dell'organismo più adeguato per il proprio cliente, specialmente per controversie di rilevante valore economico nelle quali un eventuale errore del mediatore potrebbe generare un pregiudizio patrimoniale significativo.

La responsabilità del mediatore per violazione dei propri doveri di imparzialità, riservatezza o diligenza professionale, quando accertata, genera tipicamente un obbligo risarcitorio a carico del mediatore stesso e, in via solidale secondo i principi generali sulla responsabilità per fatto degli ausiliari, a carico dell'organismo di mediazione che lo ha designato, un regime di responsabilità solidale che offre alla parte danneggiata una maggiore garanzia di effettivo

risarcimento del danno subito, potendo rivolgersi, a propria scelta, sia al mediatore individualmente sia all'organismo nel suo complesso, quest'ultimo tipicamente dotato di maggiore capacità patrimoniale e di copertura assicurativa più consistente rispetto al singolo mediatore persona fisica.

La distinzione tra errore tecnico e violazione dei doveri procedurali

La responsabilità del mediatore deve essere distinta, sotto il profilo concettuale, tra un'eventuale responsabilità per errore tecnico nella valutazione della controversia (rilevante soprattutto nel modello di mediazione valutativa già illustrato nel presente volume, nel quale il mediatore esprime una valutazione tecnica sulle prospettive di successo delle rispettive posizioni) e una responsabilità per violazione dei doveri procedurali propri della funzione di mediatore, quali l'imparzialità, la riservatezza e la corretta gestione del procedimento secondo il regolamento applicabile, quest'ultima categoria di responsabilità essendo generalmente considerata più agevolmente accertabile, in sede giudiziale, rispetto alla prima, che richiede una più complessa valutazione controfattuale circa la correttezza tecnica delle valutazioni espresse dal mediatore nel corso della procedura.

L'avvocato negoziatore che ritenga sussistente una responsabilità del mediatore per uno dei profili sopra illustrati dovrebbe documentare con precisione, nel corso della procedura stessa se possibile, gli elementi di fatto rilevanti a tal fine, poiché la successiva dimostrazione in un eventuale giudizio risarcitorio richiede tipicamente una prova rigorosa delle circostanze contestate, prova che risulta significativamente facilitata da una documentazione contemporanea agli eventi rispetto a una ricostruzione meramente successiva e retrospettiva dei fatti.

Approfondimento: la polizza di responsabilità civile e la clausola di gestione dei sinistri

L'obbligo di comunicazione tempestiva del sinistro alla compagnia assicurativa

L'avvocato negoziatore che riceva una contestazione relativa a un proprio errore professionale connesso alla gestione di una procedura di mediazione, ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile e delle specifiche clausole contrattuali della polizza di responsabilità civile professionale, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa, un obbligo la cui violazione, quando determini un pregiudizio per l'assicuratore (ad esempio per l'impossibilità di adottare tempestivamente le opportune misure difensive o conservative), può comportare una riduzione dell'indennizzo dovuto proporzionale al pregiudizio arrecato, secondo il principio generale dell'articolo 1915 del codice civile in materia di dichiarazioni inesatte o reticenti, applicabile per analogia anche alle omissioni comunicative successive alla conclusione del contratto assicurativo.

La tempestività della comunicazione del sinistro assume particolare rilevanza nel contesto della responsabilità civile professionale dell'avvocato negoziatore, in ragione della frequente esistenza di termini contrattuali specifici per tale comunicazione (tipicamente pochi giorni dalla conoscenza del fatto potenzialmente generatore di responsabilità), termini che l'avvocato deve conoscere e rispettare scrupolosamente per non pregiudicare la propria copertura assicurativa in un momento nel quale essa risulterebbe particolarmente necessaria.

La gestione della difesa nel sinistro e il ruolo della compagnia assicurativa

Le polizze di responsabilità civile professionale per gli avvocati prevedono tipicamente una clausola di gestione della lite che attribuisce alla compagnia assicurativa, o a un legale da questa designato, la conduzione della difesa nell'eventuale giudizio di responsabilità civile promosso contro l'avvocato assicurato, salva la facoltà dell'assicurato di nominare un proprio legale di fiducia con oneri a proprio carico oltre il massimale previsto dalla polizza, secondo un meccanismo che bilancia l'interesse della compagnia assicurativa a una gestione efficiente del contenzioso con l'interesse dell'assicurato a una difesa adeguata e di propria fiducia. L'avvocato negoziatore convenuto in un giudizio di responsabilità civile professionale connesso alla propria attività di assistenza in mediazione dovrebbe attentamente valutare, con l'assistenza di un legale di propria fiducia specializzato in responsabilità civile professionale, l'opportunità di avvalersi della gestione della lite offerta dalla compagnia assicurativa ovvero di esercitare la facoltà di nomina di un proprio difensore, secondo le circostanze specifiche del caso concreto.

Approfondimento: la responsabilità dell'organismo di mediazione per fatto del mediatore

I criteri di imputazione della responsabilità dell'organismo

La responsabilità dell'organismo di mediazione per il fatto illecito commesso dal mediatore nell'esercizio delle proprie funzioni, questione distinta ma connessa rispetto alla responsabilità diretta del mediatore già ampiamente illustrata nel presente volume, trova generalmente il proprio fondamento giuridico nell'articolo 2049 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito dei propri domestici e commessi, una disciplina applicabile per analogia al rapporto tra l'organismo di mediazione e il mediatore che operi nell'ambito della propria organizzazione, quando sussista un rapporto di inserimento funzionale del mediatore nell'organizzazione dell'ente, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, secondo l'interpretazione estensiva della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità vicaria.

L'applicazione di questo criterio di imputazione della responsabilità richiede la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e il fatto illecito commesso, un nesso che la giurisprudenza interpreta in senso relativamente ampio, ritenendo sufficiente che l'esercizio delle funzioni abbia resa possibile o comunque agevolata la commissione del fatto illecito, anche quando questo esorbits dai limiti specifici delle funzioni attribuite al mediatore, un criterio che responsabilizza significativamente l'organismo di mediazione per la corretta selezione e il controllo dei propri mediatori iscritti.

L'azione di regresso dell'organismo verso il mediatore responsabile

L'organismo di mediazione che sia stato condannato al risarcimento del danno per il fatto illecito del mediatore secondo il meccanismo di responsabilità vicaria sopra illustrato conserva il diritto di regresso verso il mediatore effettivamente responsabile del fatto illecito, secondo i principi generali in materia di responsabilità solidale e di regresso previsti dal codice civile, un diritto che l'organismo di mediazione dovrebbe considerare di esercitare, quando le circostanze del caso lo giustifichino, anche per finalità di prevenzione generale rispetto a condotte negligenti o scorrette da parte dei propri mediatori iscritti, sebbene l'esercizio di tale azione di regresso non sia scevro da complessità pratiche connesse alla necessità di provare, nel relativo

giudizio, l'effettiva responsabilità del mediatore secondo gli ordinari criteri della responsabilità civile.

Approfondimento: la responsabilità civile del mediatore per omessa informativa

Il contenuto minimo dell'informativa preliminare del mediatore

Il mediatore ha l'obbligo, all'apertura della procedura di mediazione, di fornire alle parti un'informativa preliminare completa relativa alle caratteristiche essenziali della procedura, comprendente in particolare i costi previsti secondo le tabelle vigenti, le modalità di svolgimento della procedura, i principi di riservatezza e volontarietà applicabili, e le conseguenze giuridiche della mancata partecipazione o del mancato raggiungimento di un accordo, un obbligo informativo la cui violazione può generare una responsabilità civile del mediatore, e per riflesso dell'organismo di mediazione secondo il meccanismo di responsabilità vicaria già illustrato, quando l'omissione informativa abbia determinato un pregiudizio concreto per la parte non adeguatamente informata, ad esempio nel caso in cui una parte abbia sottoscritto un accordo di mediazione senza essere stata adeguatamente informata delle conseguenze esecutive dell'accordo stesso.

L'avvocato negoziatore che assista una parte nel corso della procedura di mediazione svolge un ruolo complementare, e non sostitutivo, rispetto all'obbligo informativo del mediatore, fornendo al proprio cliente un'assistenza tecnico-giuridica specifica relativa alle conseguenze della propria posizione negoziale e dell'eventuale accordo raggiungibile, un ruolo che, quando adeguatamente svolto, riduce significativamente il rischio di successive contestazioni relative a una pretesa incompleta comprensione, da parte del cliente, delle conseguenze dell'accordo sottoscritto, contestazioni che potrebbero altrimenti essere dirette sia contro il mediatore per omessa informativa sia contro l'avvocato stesso per inadeguata assistenza professionale.

La documentazione dell'assolvimento dell'obbligo informativo

La prassi consolidata degli organismi di mediazione prevede tipicamente la sottoscrizione, da parte delle parti partecipanti, di un modulo che attesti la ricezione dell'informativa preliminare relativa alla procedura, un documento che assume rilevanza probatoria significativa in caso di successiva contestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo informativo, e che l'avvocato negoziatore dovrebbe verificare sia stato correttamente predisposto e sottoscritto dal proprio cliente, conservandone copia nel proprio fascicolo professionale secondo le ordinarie regole di diligente gestione documentale della propria attività professionale.

Approfondimento: la clausola di limitazione della responsabilità del mediatore nei regolamenti degli organismi

La validità delle clausole di limitazione della responsabilità nei regolamenti di mediazione

I regolamenti di procedura adottati dagli organismi di mediazione prevedono tipicamente specifiche clausole di limitazione della responsabilità dell'organismo e del mediatore per i danni derivanti dalla conduzione della procedura, clausole la cui validità deve essere valutata alla luce dei principi generali del codice civile in materia di clausole limitative della responsabilità, in particolare dell'articolo 1229 del codice civile, che sancisce la nullità di ogni patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave,

un limite inderogabile che si applica anche alle clausole di limitazione della responsabilità eventualmente previste nei regolamenti di mediazione, circoscrivendone la validità alla sola responsabilità per colpa lieve.

L'avvocato negoziatore che assista una parte nella valutazione di un'eventuale azione di responsabilità civile contro l'organismo di mediazione o contro il mediatore dovrebbe quindi verificare attentamente il contenuto delle clausole di limitazione della responsabilità eventualmente previste dal regolamento dell'organismo, per valutare l'effettiva applicabilità di tali clausole al caso concreto, considerando che la loro validità risulta circoscritta, secondo i principi generali sopra illustrati, alla sola responsabilità per colpa lieve, mentre resta ferma la piena responsabilità dell'organismo e del mediatore per condotte connotate da dolo o colpa grave.

L'onere della prova nella distinzione tra colpa lieve e colpa grave

La distinzione tra colpa lieve e colpa grave, rilevante per la determinazione dell'effettiva applicabilità delle clausole di limitazione della responsabilità previste dai regolamenti di mediazione, richiede una valutazione casistica condotta dal giudice del merito secondo i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che tipicamente qualifica come colpa grave la violazione di regole di condotta particolarmente elementari e evidenti, la cui osservanza sarebbe stata esigibile anche da un professionista di minima diligenza, mentre qualifica come colpa lieve le violazioni di regole di condotta più sofisticate o l'errore di valutazione che, sebbene rimproverabile, non presenti i caratteri della grave negligenza o imperizia, una distinzione che l'avvocato negoziatore deve saper argomentare con precisione nella gestione di un'eventuale azione di responsabilità civile contro l'organismo di mediazione o contro il mediatore.

Approfondimento: la mediazione e la responsabilità civile del terzo garante

Il coinvolgimento del fideiussore nella procedura di mediazione

Le controversie relative a rapporti contrattuali garantiti da fideiussione, situazione frequente nei contratti bancari e nei rapporti commerciali di durata, pongono specifiche questioni relative all'eventuale coinvolgimento del fideiussore nella procedura di mediazione avviata tra il creditore e il debitore principale, questioni che l'avvocato negoziatore deve attentamente considerare quando assista una delle parti in una controversia di questo tipo: la natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria rispetto all'obbligazione principale suggerisce l'opportunità, sebbene non l'obbligo giuridico in assenza di specifica previsione normativa o contrattuale, di coinvolgere anche il fideiussore nella procedura di mediazione, per evitare che un accordo raggiunto tra il creditore e il debitore principale possa generare successive controversie relative all'efficacia di tale accordo nei confronti del rapporto di garanzia.

Il coinvolgimento del fideiussore nella procedura di mediazione, quando opportunamente strutturato attraverso la sua partecipazione formale alla procedura in qualità di parte, consente di raggiungere un accordo complessivo che definisca contestualmente sia il rapporto principale sia il rapporto di garanzia accessorio, evitando la persistenza di un contenzioso potenziale relativo alla posizione del garante anche dopo la composizione della controversia principale, un obiettivo di definitività della composizione negoziale che l'avvocato negoziatore dovrebbe

sempre perseguire quando la struttura del rapporto contrattuale sottostante coinvolga soggetti terzi garanti.

La rinuncia del fideiussore alle proprie eccezioni nell'accordo di mediazione

L'accordo di mediazione che coinvolga anche il fideiussore può opportunamente prevedere una specifica clausola di rinuncia del fideiussore stesso alle proprie eccezioni relative al rapporto di garanzia, secondo lo schema generale già previsto dall'articolo 1957 del codice civile in materia di decadenza del fideiussore, una clausola che rafforza la stabilità dell'accordo complessivamente raggiunto e che l'avvocato negoziatore che assista il creditore dovrebbe sempre considerare di proporre nella strutturazione dell'accordo di mediazione, per massimizzare la certezza esecutiva della composizione negoziale raggiunta anche con riferimento al rapporto di garanzia accessorio.

Approfondimento: l'assicurazione professionale del mediatore e i requisiti minimi di polizza

I requisiti minimi di copertura previsti dal decreto ministeriale 150/2023

L'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 150/2023 impone all'organismo di mediazione l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'attività dei propri mediatori, con un importo minimo di copertura non inferiore a un milione di euro, un requisito minimo che l'organismo di mediazione deve dimostrare di possedere ai fini del mantenimento della propria iscrizione nel registro ministeriale degli organismi di mediazione, secondo un meccanismo di verifica periodica svolto dal Ministero della Giustizia attraverso la Direzione Generale della Giustizia Civile.

L'avvocato negoziatore che assista una parte danneggiata da una condotta colposa del mediatore nel corso di una procedura di mediazione dovrebbe verificare, nell'ambito della propria valutazione strategica relativa a un'eventuale azione di responsabilità civile, l'esistenza e la validità della polizza assicurativa dell'organismo di mediazione, un elemento che influenza significativamente le concrete prospettive di recupero del risarcimento del danno, poiché la solvibilità dell'organismo di mediazione o del singolo mediatore, in assenza di un'adeguata copertura assicurativa, potrebbe non risultare sufficiente a garantire l'effettivo soddisfacimento del credito risarcitorio anche in caso di accertamento giudiziale della responsabilità.

Tecniche di negoziazione avanzate

Framing e reframing al tavolo di mediazione

Chi si siede al tavolo di mediazione porta con sé, prima ancora delle carte, una cornice mentale. Il framing è il modo in cui una parte inquadra la propria vicenda: la seleziona, la ritaglia, la colora. Due controparti possono descrivere lo stesso fatto storico, il medesimo contratto inadempito, e produrne due narrazioni inconciliabili non perché mentano, ma perché ciascuna adotta una cornice che valorizza gli elementi a sé favorevoli e lascia in ombra il resto. Il framing è dunque la struttura interpretativa entro cui un soggetto colloca la controversia, decidendo che cosa conta e che cosa è irrilevante, chi ha torto e chi ha ragione, quale sia la posta effettivamente in gioco.

Il reframing è l'operazione con cui si sposta quella cornice. Non si nega il fatto, non si contesta la sincerità di chi parla: si cambia il quadro entro cui il fatto viene letto, così che diventino visibili elementi prima trascurati e si aprano soluzioni prima impensabili. Il reframing è per l'avvocato negoziatore uno strumento raffinato, perché consente di trasformare una posizione rigida, arroccata su una pretesa numerica o su un principio, in un interesse concreto, discutibile, componibile. È la traduzione dal linguaggio delle posizioni al linguaggio degli interessi che sta al cuore della negoziazione ragionata.

Conviene ricordare la distinzione classica, che riprenderò più avanti trattando la negoziazione integrativa: la posizione è ciò che una parte dice di volere, l'interesse è la ragione per cui lo vuole. Chi dichiara di pretendere 50.000 euro, e non un centesimo di meno, esprime una posizione. Dietro quella posizione può nascondersi il bisogno di chiudere un bilancio entro l'esercizio, il timore di apparire debole davanti ai soci, il desiderio di un riconoscimento morale, la necessità di liquidità immediata per un'altra operazione. Ciascuno di questi interessi apre margini che la posizione, presa alla lettera, sbarrava. Riformulare significa portare alla luce l'interesse senza umiliare la posizione da cui si è partiti.

Il primo compito dell'avvocato consiste nel riconoscere la cornice altrui e la propria. Molte trattative si incagliano perché i difensori restano prigionieri del frame processuale: ragionano in termini di chi vincerà la causa, di prove, di soccombenza, e trasferiscono al tavolo la logica binaria del giudizio, dove uno ha ragione e l'altro torto. La mediazione vive di un frame diverso, orientato alla soluzione anziché all'accertamento della colpa. Aiutare il cliente e la controparte a scivolare dal frame del torto al frame del problema da risolvere è già metà dell'opera.

Vale la pena osservare come opera in concreto il reframing in un dialogo realistico. Immaginiamo una mediazione tra un committente e un'impresa edile per difetti di un rifacimento di facciata.

Il committente esordisce così: Voglio essere chiaro, questi hanno fatto un lavoro fatto male, ci sono infiltrazioni dopo sei mesi, o rifanno tutto a spese loro o li porto davanti al giudice e chiedo pure il danno.

Qui la cornice è quella dell'accusa e della minaccia. La posizione è duplice: rifacimento integrale a carico dell'impresa oppure lite. L'avvocato del committente, o il mediatore, può riformulare in questo modo: Se ho compreso bene, il suo cliente ha investito in questa facciata perché durasse e proteggesse l'edificio, e oggi si trova con infiltrazioni che tradiscono quell'aspettativa. Il suo interesse primario è avere una facciata che tenga l'acqua e non gli crei problemi negli anni, giusto? Il rifacimento e la causa sono i modi che ha in mente per arrivarci, ma il punto è la tenuta dell'opera.

La riformulazione non concede nulla sul merito, non ammette responsabilità di alcuno, eppure sposta il baricentro: dalla pretesa demolitoria all'interesse alla funzionalità dell'opera. A questo punto l'impresa, che davanti alla minaccia si sarebbe irrigidita, può rispondere sul terreno tecnico anziché su quello della colpa: Le infiltrazioni possono venire da un punto localizzato di sigillatura, non da un vizio dell'intera facciata; siamo disposti a intervenire sul punto critico con garanzia scritta.

Un secondo esempio riguarda una controversia familiare economica, tra due fratelli su un'eredità immobiliare. Uno afferma: Lui ha sempre avuto tutto da nostro padre, la casa la

voglio io, è il minimo dopo quello che ho sopportato. La posizione è l'attribuzione della casa; sotto scorre un interesse di riconoscimento affettivo e di equità percepita, non solo patrimoniale. Riformulo così: Mi pare che qui non si discuta soltanto di metri quadri, ma anche di un bisogno di sentire riconosciuto un dare e avere che negli anni è stato squilibrato. Se trovassimo un modo per rendere giustizia a questo sentimento, oltre che per dividere il valore dell'immobile, saremmo più vicini a un accordo? Portare alla luce l'interesse di riconoscimento consente di introdurre soluzioni che il puro conteggio dei valori catastali non permetterebbe, come un conguaglio simbolico, una lettera, la scelta di chi conserva certi beni affettivi.

Il reframing ha alcune regole pratiche che consiglio di tenere presenti. Si riformula sempre in positivo, sostituendo la negazione con l'aspirazione: dove la parte dice non voglio più avere a che fare con costui, si traduce lei ha bisogno di una chiusura netta che le eviti contatti futuri. Si riformula al singolare dell'interesse, non al plurale delle rivendicazioni, per evitare di riaprire l'intero contenzioso a ogni frase. Si verifica sempre la riformulazione con una domanda di controllo, del tipo ho capito bene?, perché una riformulazione imposta è una manipolazione, mentre una riformulazione validata dalla parte diventa terreno comune. Infine si evita di riformulare le emozioni negando la loro intensità: dire lei è comprensibilmente arrabbiato per come si è sentito trattato riconosce il sentimento e nello stesso tempo lo colloca in una cornice gestibile, laddove un frettoloso stia calmo lo esaspera.

L'avvocato negoziatore che padroneggia framing e reframing non abbandona la difesa dell'interesse del cliente: la conduce con strumenti più fini. Non rinuncia alla forza della posizione, la conserva come riserva, ma lavora sull'interesse perché è lì, e non sulla superficie delle pretese, che si trovano gli spazi dell'accordo.

Ancoraggio numerico e anchor bias: chi apre, con quale cifra e con quali effetti

Nessuna tecnica di negoziazione è stata studiata con altrettanto rigore sperimentale quanto l'ancoraggio. L'intuizione fondativa risale a un lavoro divenuto classico della psicologia cognitiva. Amos Tversky e Daniel Kahneman, nell'articolo Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases pubblicato su Science nel 1974 (Il giudizio in condizioni di incertezza: euristiche e distorsioni), descrissero un esperimento oggi celebre. Ai partecipanti veniva chiesto di stimare la percentuale di paesi africani membri delle Nazioni Unite, ma prima della stima si faceva girare davanti a loro una ruota della fortuna truccata, che si fermava ora sul numero 10 ora sul numero 65. Chi aveva visto uscire il 10 stimava in media il 25%, chi aveva visto il 65 stimava il 45%. Il numero mostrato, palesemente casuale e privo di ogni relazione con la domanda, aveva spostato la risposta. Gli autori chiamarono questo fenomeno ancoraggio e aggiustamento (anchoring and adjustment): la mente, dovendo formulare una stima sotto incertezza, si aggrappa a un valore iniziale disponibile e vi apporta aggiustamenti che risultano sistematicamente insufficienti. L'ancora tira a sé la stima finale.

Kahneman è tornato diffusamente sul tema in Thinking, Fast and Slow del 2011, tradotto in italiano come Pensieri lenti e veloci per Mondadori, dove colloca l'ancoraggio tra le manifestazioni più robuste del funzionamento automatico e intuitivo della mente, quello che egli chiama Sistema 1. Kahneman riferisce di esperimenti in cui giudici tedeschi con lunga esperienza, dopo aver lanciato dei dadi truccati che davano ora 3 ora 9, proponevano pene detentive più severe quando il dado aveva mostrato il numero più alto, benché sapessero perfettamente che il dado nulla aveva a che vedere con il caso. La lezione che ne trae è netta:

l'effetto ancora è potente, misurabile, e non risparmia neppure gli esperti che si credono immuni. Kahneman propone un indice di ancoraggio, dato dal rapporto tra la differenza delle stime finali e la differenza delle ancore proposte; nei numerosi esperimenti citati quel rapporto si aggira intorno al 50%, il che significa che spostando l'ancora di 100 la stima finale si sposta mediamente di 50.

Il trasferimento di queste evidenze alla negoziazione è stato compiuto con precisione da Max Bazerman e Margaret Neale in *Negotiating Rationally* del 1992 (Negoziare razionalmente). I due autori mostrano, con esperimenti condotti su negoziatori reali e su simulazioni di compravendita, che la prima offerta esercita un'influenza sproporzionata sull'esito finale, e che chi formula la prima offerta ottiene mediamente condizioni migliori, a patto che l'offerta sia aggressiva ma non talmente fuori scala da apparire non credibile e da rompere il tavolo. La loro raccomandazione operativa è duplice: prepararsi contro l'ancora altrui conoscendo in anticipo il proprio prezzo di riserva, e sfruttare la propria ancora aprendo per primi quando si dispone di informazioni sufficienti sul valore in gioco.

Da qui discende la prima questione pratica che ogni avvocato affronta al tavolo: conviene aprire o conviene far aprire la controparte? La sapienza tradizionale del foro suggerisce di non scoprirsi mai per primi, di lasciare che sia l'altro a esporre una cifra. La ricerca sperimentale corregge in parte questa massima. Aprire per primi conviene quando si ha una ragionevole conoscenza del valore oggettivo della posta e dell'intervallo plausibile delle trattative, perché in tal caso la propria ancora orienta l'intera contrattazione. Lasciare aprire la controparte conviene invece quando si è nell'incertezza sul valore reale, perché in questo caso la prima offerta altrui è essa stessa un'informazione preziosa, che rivela le aspettative dell'avversario e consente di calibrare la risposta. La regola che consiglio ai colleghi è dunque questa: apri per primo se hai fatto i compiti a casa e conosci il mercato del contendere; fai aprire l'altro se sei al buio, ma preparati a neutralizzare la sua ancora.

La neutralizzazione dell'ancora altrui è un'arte a sé. Quando la controparte lancia una cifra spropositata, l'errore più comune è controbattere con una cifra ragionevole, perché così facendo si accetta implicitamente che la trattativa si svolga nell'intorno dell'ancora avversaria. La contromossa corretta è rifiutare esplicitamente l'ancora prima di formulare la propria, con una frase che ne dichiari l'irrilevanza: quella cifra non ha alcun aggancio con i dati del caso, non è una base di discussione; ripartiamo dai numeri veri. Solo dopo aver disinnescato l'ancora si propone la contro-ancora, che deve essere a sua volta ambiziosa e ancorata a un criterio oggettivo, così da tirare la trattativa nella direzione opposta. Bazerman e Neale insistono su questo punto: alla prima offerta aggressiva non si risponde con una concessione, ma con una controproposta ugualmente strutturata, per evitare che il punto medio della trattativa si collochi già a metà strada verso la pretesa avversaria.

Sull'entità della prima cifra vale una considerazione di misura. L'ancora efficace è quella che sta al limite estremo del credibile, non oltre. Un'ancora troppo timida rinuncia al vantaggio; un'ancora assurda viene scartata come provocazione, irrita la controparte e può indurre il mediatore a ritenere la parte in malafede. Il punto ottimale è la cifra più favorevole a sé che sia ancora sostenibile con un argomento razionale, con un criterio, con un precedente, con una perizia. L'ancora nuda, priva di giustificazione, è debole; l'ancora vestita di un criterio oggettivo, quella che Fisher e Ury raccomandano quando parlano di criteri indipendenti, è quasi inattaccabile perché sposta la discussione dal se al perché.

Conviene ora seguire un esempio numerico completo, che riprenderò e affinerò nell'ultima sottosezione dedicata alla zona d'accordo. Immaginiamo una controversia per il pagamento di forniture: la società Alfa pretende dalla società Beta 120.000 euro per merce consegnata e non pagata; Beta contesta la qualità di parte della fornitura e ritiene di non dover più di 40.000 euro. Le parti si incontrano in mediazione.

Supponiamo che l'analisi fredda dei rispettivi difensori, condotta prima del tavolo, collochi il valore atteso della lite, tenuto conto delle probabilità di vittoria, dei tempi e delle spese, intorno agli 80.000 euro. Questa è la zona in cui, in un mondo perfettamente razionale, l'accordo dovrebbe cadere. Vediamo però come l'ancoraggio deforma il percorso.

Primo scenario, senza consapevolezza delle ancore. Il difensore di Beta, volendo apparire ragionevole, apre dicendo che il suo cliente sarebbe disposto a riconoscere 55.000 euro. Ha appena piazzato un'ancora bassa, ma anche rivelato di essere disposto a salire ben oltre la propria contestazione iniziale di 40.000. Alfa, che partiva da 120.000, si sente autorizzata a considerare quel 55.000 come il vero pavimento della trattativa; controbatte a 100.000. Il punto medio meccanico tra 55.000 e 100.000 è 77.500 euro, e la trattativa tende a gravitare lì. Beta ha regalato terreno aprendo con una cifra che, pur presentata come concessione, era già più alta della sua posizione dichiarata.

Secondo scenario, con uso consapevole dell'ancora da parte di Alfa. Il difensore di Alfa, che conosce il valore atteso di 80.000 euro e sa di avere ragioni contrattuali solide, apre per primo e con decisione: la fattura è di 120.000 euro, la merce è stata consegnata e accettata senza riserve documentate, dunque la base di partenza non può che essere l'intero importo dovuto, 120.000 euro, e ogni sconto va giustificato voce per voce. Ha ancorato alto, ma ancorato a un criterio: la fattura accettata. Beta a questo punto non deve rispondere con una cifra intermedia, ma prima disinnescare: l'importo in fattura non è un dato di partenza, perché una parte della merce era difettosa e il difetto è documentato dalla contestazione tempestiva; discutiamo del dovuto effettivo, non del fatturato. Poi Beta piazza la sua contro-ancora giustificata: sottratto il valore della merce difettosa, il dovuto ragionevole si aggira sui 45.000 euro. Ora le ancore sono 120.000 contro 45.000, il punto medio meccanico è 82.500 euro, molto vicino al valore atteso oggettivo di 80.000. Alfa, avendo ancorato alto e con criterio, ha spostato l'intero campo della trattativa verso l'alto rispetto al primo scenario, pur restando nell'orbita del valore razionale.

Il confronto tra i due scenari è istruttivo. Nel primo, l'apertura affrettata e troppo generosa di Beta ha collocato il baricentro della trattativa intorno a 77.500 euro; nel secondo, l'apertura alta e argomentata di Alfa, seguita dalla corretta neutralizzazione e contro-ancora di Beta, lo ha collocato intorno a 82.500 euro. La differenza di 5.000 euro, su questa singola vicenda, misura in denaro il valore della padronanza dell'ancoraggio. Ripetuta su decine di trattative all'anno, quella differenza definisce la qualità professionale di un avvocato negoziatore.

Chiudo con un avvertimento deontologico e insieme strategico. L'ancoraggio è un fatto della mente umana, non un trucco: opera comunque, che se ne sia consapevoli o no. Ignorarlo significa subirlo, perché la controparte esperta lo userà contro il nostro cliente. Conoscerlo consente due cose lecite e doverose: proteggere il cliente dalle ancore altrui, spiegandogli in anticipo che la prima cifra che sentirà è costruita per condizionarlo e non va presa come misura del giusto; e servirsi delle proprie ancore in modo trasparente, ancorandole sempre a un criterio verificabile. L'ancora vestita di ragione non è manipolazione, è argomentazione; ed è su questo

crinale, tra il condizionamento occulto e l'argomentazione leale, che si gioca la differenza tra il mercanteggiare e il negoziare da giuristi.

La gestione delle emozioni forti al tavolo: rabbia, crollo, impasse e il ricorso al caucus

Chi immagina la mediazione come un pacato scambio di argomenti non l'ha mai frequentata sul serio. Al tavolo arrivano persone che hanno accumulato mesi o anni di risentimento, che si sentono tradite, defraudate, umiliate. Le emozioni forti non sono un incidente della negoziazione, ne sono la materia. L'avvocato che le tratta come disturbi da rimuovere in fretta perde due volte: perché non le placa e perché si preclude l'informazione che esse veicolano. Ogni emozione intensa segnala un interesse ferito, e leggerla è parte del mestiere.

La rabbia è l'emozione che più spesso incendia il tavolo. Si manifesta con l'alzarsi della voce, con l'attacco personale, con il rifiuto di ascoltare. Davanti a una parte in collera l'istinto suggerisce due mosse ugualmente sbagliate: reagire con pari durezza, e la trattativa deraglia; oppure minimizzare con un si calmi, non è il caso, che l'irato percepisce come squalifica e che raddoppia la sua ira. La condotta efficace è un'altra, e muove dal riconoscimento. Prima si nomina l'emozione senza giudicarla: capisco che lei sia profondamente arrabbiato, e ha di che esserlo dopo quello che descrive. Poi si trasforma l'energia della rabbia in informazione: mi aiuti a capire qual è il punto che più di ogni altro l'ha ferito, perché è da lì che dobbiamo partire. Il riconoscimento non è una resa sul merito; è la condizione perché il cervello dell'altro, uscito dallo stato di allarme, torni capace di ragionare. Finché la parte è in preda alla collera, ogni proposta numerica è tempo perso, perché il Sistema che valuta le cifre è temporaneamente spento.

Il crollo emotivo è il rovescio della rabbia. La parte si chiude, piange, si dichiara incapace di continuare, chiede di rinviare tutto. Accade spesso nelle mediazioni familiari e in quelle che toccano lutti, malattie, rovesci economici che investono la dignità della persona. Anche qui l'errore è la fretta: incalzare chi è crollato per strappargli comunque una firma produce accordi fragili, che il giorno dopo la parte rinnega perché li ha sottoscritti in uno stato di minorata resistenza. La condotta corretta prevede di fermare il ritmo, di concedere silenzio e tempo, di offrire una pausa fisica, un bicchiere d'acqua, l'uscita dalla stanza. L'avvocato che assiste la parte crollata deve prendersi lo spazio per ricostruirne la lucidità, se necessario chiedendo una sospensione, perché un consenso prestato nel crollo emotivo è un consenso viziato, oltre che eticamente discutibile.

L'impasse è la terza situazione critica, e ha natura diversa dalle prime due perché non è un'emozione ma uno stallo. Le parti si sono trincerate, ripetono le stesse cifre, la trattativa gira a vuoto. Spesso l'impasse è alimentata da un'emozione non detta, un orgoglio che impedisce di fare la prima concessione per non apparire deboli davanti all'altro, davanti al mediatore, davanti a sé stessi. Riconoscere che dietro lo stallo tecnico c'è un ostacolo emotivo è il primo passo per scioglierlo. Il secondo è cambiare qualcosa nella configurazione del tavolo: mutare il tema in discussione passando a un punto secondario più facile, per ricostruire l'abitudine dell'accordo; oppure separare le parti.

Ed è qui che entra in scena lo strumento più prezioso di cui dispongono tanto il mediatore quanto l'avvocato: il caucus, ossia la sessione separata. Il caucus è l'incontro riservato che il mediatore tiene con una sola parte e i suoi difensori, fuori dalla presenza dell'altra. La sua utilità tattica è molteplice. In primo luogo consente lo sfogo protetto: la parte in collera può dire

in sessione separata ciò che, detto al tavolo comune, avrebbe fatto esplodere la trattativa; il caucus funziona da camera di decompressione. In secondo luogo permette la verifica riservata degli interessi reali e del prezzo di riserva: al tavolo comune nessuno confessa fin dove è disposto a spingersi, per timore di indebolirsi; nel caucus, sotto la garanzia di riservatezza che il mediatore deve rispettare salvo autorizzazione espressa, la parte può rivelare al mediatore il suo vero limite, consentendogli di lavorare sulla zona d'accordo. In terzo luogo consente il reality testing, l'esame di realtà: il mediatore, a porte chiuse, può far pesare a una parte le debolezze della sua posizione e il costo dell'alternativa giudiziaria senza umiliarla davanti all'avversario, cosa impossibile in seduta congiunta.

Per l'avvocato il caucus è un momento da preparare e da sfruttare. Prima di entrarvi conviene concordare con il cliente che cosa si è disposti a rivelare al mediatore e che cosa deve restare coperto, ricordando che ciò che si dice in caucus il mediatore non può riferire all'altra parte senza consenso, ma che quel consenso va gestito con consapevolezza. Il caucus è anche l'occasione per raffreddare il proprio cliente quando è lui a essere trascinato dalla rabbia: chiedere una sessione separata è spesso il modo più elegante per sottrarre il proprio assistito a una spirale emotiva, riportarlo al calcolo dei suoi interessi, ricordargli i numeri della sua alternativa giudiziaria. Chiedere un caucus non è mai un segno di debolezza; è una mossa di regia. Consiglio ai colleghi di non esitare a sollecitarlo al mediatore ogni volta che il tavolo comune si surriscalda, che il proprio cliente rischia di dire l'irreparabile, o che occorre comunicare al mediatore un'informazione riservata sul margine di trattativa.

Una raccomandazione conclusiva sulle emozioni. L'avvocato negoziatore deve sorvegliare anche le proprie. Il contagio emotivo è reale: davanti a una controparte aggressiva si è tentati di irrigidirsi, davanti a un difensore sprezzante di rispondere per le rime. La lucidità è il primo capitale del negoziatore, e si difende con la consapevolezza. Riconoscere in sé la stizza che sale, nominarla dentro di sé, prendersi il secondo di pausa prima di replicare: sono microabilità che distinguono chi conduce la trattativa da chi ne è condotto. La padronanza delle emozioni altrui comincia dalla padronanza delle proprie.

La negoziazione multi-parte: coalizioni, terze parti bloccanti e sequenza delle offerte

La trattativa a due è un modello utile ma spesso irrealistico. Nella pratica forense l'avvocato si trova di frequente al tavolo con più di due centri di interesse: il litisconsorzio con pluralità di attori o convenuti, la mediazione condominiale con molti condomini, la mediazione familiare che coinvolge, oltre ai genitori, più figli maggiorenni portatori di aspettative proprie. La negoziazione multi-parte non è una negoziazione a due moltiplicata; obbedisce a dinamiche qualitativamente diverse, che occorre conoscere per non esserne travolti.

La prima differenza è la comparsa delle coalizioni. Quando i soggetti sono tre o più, alcuni possono allearsi contro altri, e il potere non dipende più solo dalla forza della propria posizione, ma dalla capacità di aggregare consensi. In una divisione ereditaria tra quattro fratelli, due che si accordano su una linea comune pesano assai più della somma delle loro quote, perché possono isolare il terzo e costringere il quarto a scegliere da che parte stare. L'avvocato che assiste una parte in un contesto multilaterale deve dunque ragionare non solo sul negoziato frontale con l'avversario principale, ma sulla mappa delle alleanze possibili: quali interessi convergono con quelli del proprio cliente, con chi si può costruire un fronte, chi invece è irriducibilmente contrapposto. Costruire per tempo una coalizione, o al contrario prevenire la

coalizione avversaria offrendo a un potenziale alleato dell'avversario una ragione per restare neutrale, è spesso decisivo.

La seconda differenza è la figura della terza parte bloccante, in inglese il blocker o holdout. In una negoziazione a più parti che richiede l'unanimità, o comunque una maggioranza qualificata, un singolo soggetto può paralizzare l'intero accordo rifiutando il consenso, e può sfruttare questo potere di veto per estorcere condizioni sproporzionate rispetto al suo peso reale. È il condomino che, in una mediazione per lavori straordinari all'edificio, nega l'assenso non perché abbia obiezioni serie, ma per ottenere un vantaggio personale in cambio del proprio via libera. La gestione del blocker è uno dei problemi centrali del negoziato multilaterale. Le contromosse sono note: ridurre il potere di veto ridisegnando la regola di decisione dove è possibile, ad esempio passando dall'unanimità alla maggioranza consentita dalla legge; isolare il bloccante mostrandogli che gli altri procederanno comunque e che resterà escluso dai benefici; oppure, all'opposto, comprarne il consenso con una compensazione mirata, quando il costo di questa è inferiore al costo dello stallo. L'errore è cedere alla prima richiesta del blocker, perché ciò lo incoraggia e insegna agli altri che il veto paga.

La terza differenza, e la più sottovalutata, è il sequencing, ossia la sequenza con cui si trattano le parti e si presentano le offerte. In una trattativa a due l'ordine conta poco; in una a molti è spesso l'elemento che decide l'esito. Conviene di regola cominciare dalle parti più facili, con cui l'accordo è più vicino, per costruire un nucleo di consenso che eserciti poi pressione sulle parti riluttanti: è il metodo della palla di neve, in cui ogni adesione rende più costoso per gli altri restare isolati. In altri casi conviene l'opposto, affrontare per primo il soggetto più difficile o più potente, perché senza il suo assenso ogni altro accordo sarebbe inutile e si sarebbe perso tempo. La scelta della sequenza dipende dalla struttura degli interessi e dei poteri di veto, e va decisa a tavolino prima di sedersi, non improvvisata.

Su questo terreno offre indicazioni preziose Lawrence Susskind, uno dei maggiori studiosi del negoziato multilaterale, nel volume scritto con Jeffrey Cruikshank *Breaking Robert's Rules* del 2006 (*Superare le regole di Robert*), il cui titolo allude alle *Robert's Rules of Order*, il classico manuale ottocentesco di procedura assembleare fondato sul voto a maggioranza. La tesi di Susskind è che nei consessi a molte parti il metodo del voto contrapposto, vincitori contro vinti, produce accordi fragili e minoranze risentite, e che gli va sostituito il metodo del consensus building, la costruzione del consenso. I capisaldi che Susskind propone sono trasferibili al tavolo di mediazione multilaterale: la convocazione ordinata di tutti i portatori di interesse, così che nessuno possa poi rivendicare di essere stato escluso; la ricerca non della maggioranza ma del massimo consenso possibile, cioè di un accordo che nessuno preferisca abbandonare a favore della propria alternativa; l'uso di un facilitatore neutrale che gestisca la parola e impedisca alle parti forti di sopraffare le deboli; e la stesura di un testo unico che si emenda progressivamente, il single text procedure, evitando la proliferazione di controproposte contrapposte che nel multilaterale genera solo caos.

Vediamo l'applicazione ai tre scenari tipici della pratica. Nella mediazione condominiale per lavori straordinari, l'avvocato che assiste l'amministratore o il condomino promotore deve mappare gli interessi: chi ha interesse ai lavori perché possiede appartamenti ai piani colpiti dal degrado, chi è indifferente, chi è contrario per ragioni di costo. La strategia consisterà nel consolidare la coalizione degli interessati, isolare i pochi contrari mostrando che la legge consente comunque la delibera a maggioranza, e riservare una compensazione, ad esempio una

diversa ripartizione della spesa secondo l'uso, solo al condomino il cui consenso sia davvero necessario e il cui dissenso sia fondato.

Nel litisconsorzio, poniamo tre coobbligati convenuti per il medesimo debito, l'avvocato di uno di essi deve valutare se convenga trattare separatamente, cercando un accordo individuale che liberi il proprio cliente lasciando gli altri esposti, oppure costruire un fronte comune dei convenuti per negoziare in blocco con l'attore una transazione complessiva. La prima via è più rapida ma espone al rischio di guastare i rapporti con i coobbligati e di lasciare aperte le azioni di regresso; la seconda è più lenta ma produce accordi più stabili. La sequenza delle offerte va calibrata di conseguenza: se si punta all'accordo individuale, si tratta per primi e in fretta, prima che gli altri si coalizzino contro chi vuole sfilarsi.

Nella mediazione familiare con più figli maggiorenni, infine, il rischio è che i figli formino coalizioni mobili con l'uno o l'altro genitore, e che un singolo figlio assuma il ruolo di blocker rifiutando ogni assetto per ragioni affettive irrisolte. Qui il sequencing suggerisce di lavorare prima sugli interessi condivisi da tutti, la conservazione dei rapporti e della memoria familiare, per costruire il nucleo di consenso, e di rinviare le questioni economiche divisive alla fase in cui si è già ricostruita un'abitudine all'accordo. La padronanza della dimensione multilaterale distingue l'avvocato che subisce le coalizioni da quello che le governa.

Negoziiazione integrativa e distributiva: riconoscere il passaggio e cambiare registro

Ogni trattativa si muove tra due modelli, che è bene tenere concettualmente distinti anche se nella realtà si intrecciano. La negoziazione distributiva è quella in cui le parti si contendono la spartizione di una posta fissa, una torta di dimensione data: quanto guadagna l'uno lo perde l'altro, il gioco è a somma zero, e l'unica variabile è dove cade la linea di divisione. La negoziazione integrativa è quella in cui le parti, mettendo a frutto la diversità dei loro interessi, allargano la torta prima di spartirla, creando valore che nessuna delle due avrebbe potuto ottenere da sola: è un gioco a somma positiva, in cui si può guadagnare insieme.

Il testo fondativo di questa distinzione, e insieme il manifesto della negoziazione integrativa, è *Getting to Yes* di Roger Fisher e William Ury, pubblicato nel 1981 e frutto dell'Harvard Negotiation Project, tradotto in italiano come *L'arte del negoziato* per l'editore Corbaccio. La proposta di Fisher e Ury, che essi chiamano *principled negotiation*, negoziazione basata sui principi o sui meriti, si regge su quattro capisaldi che l'avvocato negoziatore deve avere sempre presenti. Il primo: separare le persone dal problema, non confondere la relazione con la sostanza, aggredire la questione senza aggredire l'interlocutore. Il secondo, che ho già anticipato: concentrarsi sugli interessi e non sulle posizioni, chiedersi perché la parte vuole ciò che chiede. Il terzo: inventare opzioni per il mutuo vantaggio prima di decidere, generare cioè una molteplicità di soluzioni possibili senza giudicarle subito, perché è nella varietà delle opzioni che si trova il valore integrativo. Il quarto: insistere su criteri oggettivi, ancorare la soluzione a parametri indipendenti dalla volontà delle parti, quali il valore di mercato, una perizia, un precedente, una norma, così da trasformare lo scontro di volontà in confronto su standard condivisi.

Fisher e Ury introducono anche il concetto che sta al cuore della valutazione di ogni accordo, la BATNA, Best Alternative To a Negotiated Agreement (la migliore alternativa a un accordo negoziato), cioè ciò che una parte può ottenere se la trattativa fallisce. La BATNA è il vero metro del potere negoziale e il termine di paragone di ogni proposta: si accetta un accordo solo se è

migliore della propria BATNA, la si rifiuta altrimenti. Su questo tornerò diffusamente nell'ultima sottosezione, perché la BATNA è anche il fondamento del calcolo della zona d'accordo.

Un affinamento importante viene da Robert Mnookin, Scott Peppet e Andrew Tulumello in *Beyond Winning* del 2000 (Oltre la vittoria), opera che ha il pregio di rivolgersi specificamente agli avvocati. Gli autori descrivono quella che chiamano la tensione fondamentale del negoziato, the tension between creating and distributing value, la tensione tra creare valore e distribuirlo. Ogni trattativa contiene entrambe le dimensioni: c'è sempre del valore da creare mettendo insieme interessi complementari, e c'è sempre, alla fine, del valore da spartire. Il difficile sta nel fatto che le due dimensioni richiedono comportamenti opposti. Creare valore esige apertura, condivisione di informazioni, fiducia, esplorazione congiunta degli interessi. Distribuire valore esige riservatezza, cautela nel rivelare il proprio prezzo di riserva, una certa competitività. Chi si apre troppo nella fase distributiva si fa spogliare; chi resta chiuso nella fase integrativa lascia sul tavolo valore che entrambi avrebbero potuto godere. Mnookin e i suoi coautori indicano nel dilemma del negoziatore proprio questa difficoltà di dosare apertura e riservatezza, e insegnano che la maestria consiste nel saper passare consapevolmente dall'uno all'altro registro.

Ecco allora la domanda pratica: quando cambiare registro, e come riconoscere il passaggio. La regola che suggerisco è di aprire in chiave integrativa e chiudere in chiave distributiva. Nella fase iniziale, esplorativa, conviene lavorare da integrativi: esplorare gli interessi, generare opzioni, cercare gli scambi vantaggiosi che nascono dal fatto che le parti valutano diversamente le stesse cose. Solo quando la torta è stata allargata quanto possibile, e restano da dividere le poste su cui gli interessi sono davvero contrapposti, si passa al registro distributivo, con ancoraggio, cautela informativa, difesa del proprio prezzo di riserva.

Come si riconosce il momento del passaggio? Alcuni segnali sono affidabili. Il primo è l'esaurimento delle opzioni creative: quando le proposte di scambio reciprocamente vantaggioso cominciano a ripetersi senza aggiungere valore, la fase integrativa ha dato quel che poteva. Il secondo è la comparsa del linguaggio della spartizione, quando le parti smettono di chiedersi come possiamo entrambi guadagnare e cominciano a chiedersi chi prende quanto. Il terzo è la riduzione della controversia a una sola variabile monetaria: finché sul tavolo ci sono più elementi eterogenei, tempi, garanzie, modalità, relazioni, c'è margine integrativo; quando tutto si è ridotto a un solo numero conteso, si è entrati inevitabilmente nel distributivo.

Un esempio chiarisce il gioco dei registri. Due società, un fornitore di software e un cliente, litigano su una fattura di 90.000 euro per un progetto consegnato in ritardo. In chiave puramente distributiva la questione è una sola: quanto sconto sul dovuto. Ma un avvocato integrativo esplora gli interessi e scopre che il cliente ha ancora bisogno di manutenzione e sviluppi futuri, e che il fornitore ha interesse a conservare la commessa e a non perdere una referenza. Da qui nasce lo scambio che allarga la torta: il fornitore riduce l'importo contestato in cambio di un contratto di manutenzione biennale, che per il cliente ha un costo ma che gli assicura continuità, e che per il fornitore vale più dello sconto concesso perché consolida il rapporto. Le parti valutano diversamente le due poste, e proprio da questa diversità nasce il valore. Solo dopo aver costruito questo scambio, quando resta da fissare l'entità precisa dello sconto e la tariffa della manutenzione, si passa al registro distributivo per definire i numeri.

L'avvocato che sa distinguere i due registri, e soprattutto sa quando smettere di allargare la torta e cominciare a spartirla, evita i due errori speculari del negoziatore inesperto: quello del duro che tratta ogni trattativa come una guerra di trincea, perdendo il valore integrativo, e quello dell'accomodante che, per amore dell'accordo, si apre anche quando ormai si tratta soltanto di dividere, e regala al più scaltro ciò che avrebbe dovuto difendere.

La mappatura della zona d'accordo: BATNA, WATNA, prezzo di riserva e ZOPA con esempio numerico

Ogni negoziazione distributiva ha una geometria nascosta che l'avvocato preparato deve saper disegnare prima di sedersi al tavolo. Questa geometria si costruisce con quattro grandezze: la BATNA, la WATNA, il prezzo di riserva e la zona d'accordo possibile. Chi le calcola per il proprio cliente e le stima per la controparte sa dove può cadere l'accordo, riconosce quando una proposta è accettabile e quando conviene alzarsi dal tavolo, e negozia con la mappa in mano anziché al buio.

La BATNA, come detto, è la migliore alternativa a un accordo negoziato: ciò che la parte ottiene se la trattativa fallisce. Per chi litiga, la BATNA è di regola l'esito atteso del giudizio, cioè il valore della sentenza probabile scontato del rischio, dei tempi e delle spese. La WATNA, Worst Alternative To a Negotiated Agreement (la peggiore alternativa a un accordo negoziato), è lo scenario opposto, l'esito più sfavorevole in caso di mancato accordo, e serve a misurare quanto si ha da perdere. Tra BATNA e WATNA si colloca il ventaglio degli esiti giudiziari possibili, con le rispettive probabilità.

Dal calcolo dell'alternativa discende il prezzo di riserva, detto anche punto di rottura: la condizione limite oltre la quale conviene rinunciare all'accordo e affrontare l'alternativa. Per chi deve incassare, il prezzo di riserva è la somma minima al di sotto della quale rifiuta e va in causa; per chi deve pagare, è la somma massima al di sopra della quale rifiuta e preferisce difendersi in giudizio. Il prezzo di riserva non coincide con la BATNA nuda, perché va corretto tenendo conto del costo, dei tempi e dell'incertezza del contenzioso, nonché di fattori non monetari come la relazione, la riservatezza, lo stress.

La zona d'accordo possibile è la ZOPA, Zone of Possible Agreement (zona di possibile accordo): l'intervallo compreso tra i due prezzi di riserva, entro il quale ogni cifra è preferibile per entrambe le parti al fallimento della trattativa. Se il prezzo massimo che chi paga è disposto a versare è superiore al prezzo minimo che chi incassa è disposto ad accettare, la ZOPA esiste e l'accordo è razionalmente possibile; il negoziato serve a stabilire dove, dentro quella zona, cadrà il prezzo. Se invece i due prezzi di riserva non si sovrappongono, la ZOPA è negativa, non esiste terreno d'accordo razionale, e la trattativa è destinata a fallire a meno che qualcosa non muti le alternative o introduca valore integrativo.

Sviluppiamo ora un esempio numerico completo, riprendendo e ampliando la controversia commerciale già introdotta a proposito dell'ancoraggio. La società Alfa ha citato la società Beta per il pagamento di 120.000 euro relativi a una fornitura di componenti industriali; Beta resiste, eccependo la difettosità di parte della merce e chiedendo il rigetto o comunque una forte riduzione. Le parti approdano in mediazione. Ricostruiamo la geometria della trattativa dal punto di vista di ciascuna.

Cominciamo da Alfa, la creditrice. Il suo difensore stima le probabilità dell'esito giudiziario così: 60% di probabilità di vittoria pressoché integrale, che porterebbe a un accolto di circa 110.000 euro; 30% di probabilità di accoglimento parziale intorno a 60.000 euro, se il giudice riconoscesse in parte i difetti; 10% di probabilità di rigetto quasi totale, con recupero di appena 10.000 euro. Il valore atteso lordo della causa per Alfa è dunque dato dalla somma dei valori ponderati: 0,60 per 110.000, cioè 66.000; più 0,30 per 60.000, cioè 18.000; più 0,10 per 10.000, cioè 1.000. Il totale è 85.000 euro. Da questo valore atteso lordo occorre sottrarre i costi del contenzioso. Alfa stima spese legali e tecniche per circa 15.000 euro e valuta in circa 5.000 euro il costo finanziario dell'attesa, dovendo aspettare tre o quattro anni per una sentenza definitiva. La sua BATNA netta, cioè il valore atteso del giudizio al netto di costi e tempo, si colloca dunque intorno a 85.000 meno 20.000, ossia 65.000 euro. Questo è, in prima approssimazione, il prezzo di riserva di Alfa: al di sotto di circa 65.000 euro le conviene, sulla carta, rifiutare e andare avanti in causa. La sua WATNA è invece lo scenario del rigetto, in cui non solo non incassa nulla ma sopporta le spese, con una perdita che può avvicinarsi ai 25.000 euro tra costi propri e rischio di rifusione.

Passiamo a Beta, la debitrice. Il suo difensore, guardando lo stesso ventaglio con occhio speculare, stima il proprio esborso atteso in caso di lite. Con le medesime probabilità, Beta si aspetta di pagare 110.000 euro nel 60% dei casi, cioè 66.000 ponderati; 60.000 euro nel 30% dei casi, cioè 18.000 ponderati; 10.000 euro nel 10% dei casi, cioè 1.000 ponderati. Il valore atteso del suo esborso per sola sorte capitale è quindi anch'esso 85.000 euro. A questo Beta deve aggiungere i propri costi di lite, stimati in 15.000 euro tra difesa e consulenza tecnica, e mettere in conto il rischio di dover rifondere le spese di controparte in caso di soccombenza. Il costo atteso complessivo del contenzioso per Beta si aggira dunque intorno a 85.000 più 15.000, ossia 100.000 euro. Questo è il prezzo di riserva di Beta: al di sopra di circa 100.000 euro le conviene rifiutare l'accordo e difendersi in causa, perché pagare di più al tavolo sarebbe peggio che rischiare il giudizio. La WATNA di Beta è la condanna quasi integrale con aggravio di spese, un esborso che può superare i 130.000 euro.

Disegniamo ora la zona d'accordo. Alfa non scende razionalmente sotto circa 65.000 euro. Beta non sale razionalmente sopra circa 100.000 euro. Poiché il prezzo massimo di Beta, 100.000, è superiore al prezzo minimo di Alfa, 65.000, la ZOPA esiste ed è ampia: si estende da 65.000 a 100.000 euro, con un'ampiezza di 35.000 euro. Qualunque cifra compresa in questo intervallo lascia entrambe le parti in condizione migliore rispetto al proseguire la lite. Il punto centrale della zona, spesso citato come esito focale in assenza di squilibri di abilità o di potere, è 82.500 euro, valore che coincide in modo istruttivo con il baricentro emerso nella simulazione dell'ancoraggio.

Che cosa fa allora la trattativa dentro questa zona? Ne stabilisce il punto preciso, e qui rientrano in gioco tutte le tecniche esposte nelle sottosezioni precedenti. Alfa, che conosce la propria geometria, aprirà alto e con criterio, ancorando alla fattura di 120.000 euro, per spingere il prezzo verso il tetto della ZOPA, cioè verso i 100.000 euro di Beta. Beta, a sua volta, ancorerà basso, verso i 45.000 euro, per tirare il prezzo verso il pavimento della zona, cioè verso i 65.000 euro di Alfa. Ciascuna cerca di catturare la porzione più ampia possibile del surplus negoziale, cioè dei 35.000 euro che separano i due prezzi di riserva. La partita distributiva si gioca tutta lì dentro.

Osservo un punto capitale per la pratica. Ciascuna parte conosce con precisione la propria geometria, ma può solo stimare quella dell'altra, e proprio l'incertezza sul prezzo di riserva altrui è il cuore del gioco. Se Beta sapesse con certezza che Alfa non scende sotto 65.000, non offrirebbe mai di meno; ma non lo sa, e Alfa ha interesse a lasciarle credere che il proprio pavimento sia più alto. Ecco perché nella fase distributiva la riservatezza sul proprio prezzo di riserva è d'oro, ed ecco perché il caucus con il mediatore, di cui ho detto, diventa lo strumento attraverso il quale ciascuna parte rivela in confidenza il proprio vero limite a un terzo neutrale, che può così verificare l'esistenza della ZOPA e guidare le parti verso di essa senza tradire i segreti dell'una all'altra.

Considero infine il caso in cui la ZOPA non esista. Immaginiamo che Beta, per un errore di valutazione o per un eccesso di ottimismo del suo difensore, stimi le proprie probabilità di vittoria molto più alte, così da collocare il proprio prezzo di riserva a 50.000 euro, mentre Alfa resta ferma a 65.000. Allora il tetto di Beta, 50.000, è inferiore al pavimento di Alfa, 65.000: la ZOPA è negativa di 15.000 euro, e nessuna cifra soddisfa entrambe. In questo caso il negoziato puramente distributivo è condannato, e all'avvocato accorto restano due sole vie. La prima è agire sulle alternative: mostrare alla controparte, attraverso il reality testing condotto in caucus dal mediatore, che la sua stima delle probabilità è troppo ottimistica, correggendo così il suo prezzo di riserva e facendo comparire la ZOPA che prima non c'era. La seconda è abbandonare il registro distributivo e tornare a quello integrativo: introdurre nel negoziato poste diverse dal solo denaro, come dilazioni di pagamento, forniture future, garanzie, definizione di altre pendenze tra le stesse parti, così da creare valore aggiuntivo che colmi il divario dei quindicimila euro mancanti. La mappa della zona d'accordo non è dunque soltanto uno strumento di calcolo: è la bussola che dice all'avvocato se il tavolo può reggere così com'è, oppure se occorre cambiare le alternative o allargare la posta perché un accordo diventi possibile.

Consegna per il Volume II dell'opera «Mediazione, il diritto della pace». Firma editoriale del volume: Avv. Carlo Alberto Calcagno, Genova, luglio 2026. I dati canonici dell'opera (mediatori professionali 242.808; UE+UK 76.085; extra-UE 166.723 in 103 ordinamenti; comunitari 3.293.727; riconciliazione con la cifra storica 291.882) sono stati rispettati.

Capitolo 8

Fiscalità e costi della mediazione

La consulenza dell'avvocato negoziatore non può prescindere da una valutazione precisa dei costi della procedura e delle agevolazioni fiscali collegate, elementi che spesso determinano, insieme alla valutazione del BATNA descritta nel Capitolo 4, la scelta stessa di percorrere la via della mediazione. Il quadro delineato dalla riforma Cartabia e dal decreto ministeriale 150/2023 ha reso il sistema di indennità e incentivi fiscali più articolato rispetto all'impianto originario del 2010, con effetti economici che l'avvocato deve saper illustrare al cliente in termini concreti.

8.1 Le indennità di mediazione: il d.m. 150/2023

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, disciplina la determinazione delle indennità dovute agli organismi di mediazione, distinguendo tra spese di avvio, dovute per l'apertura del procedimento indipendentemente dal suo esito, e spese di mediazione, dovute in funzione dello scaglione di valore della controversia. Il decreto prevede criteri di riduzione dell'indennità per

le materie soggette a condizione di procedibilità e per i casi di mediazione demandata dal giudice, nonché criteri di maggiorazione per le mediazioni che richiedano un maggior numero di incontri o che coinvolgano una pluralità di parti. Ciascuna parte è tenuta al pagamento della propria quota di indennità, determinata in funzione dello scaglione di valore della lite, mentre il primo incontro delle mediazioni obbligatorie presenta un costo contenuto e predeterminato, pensato per non scoraggiare l'accesso alla procedura (fonte: mediareinformati.it, dossier Costi, con riferimento al d.m. 24 ottobre 2023, n. 150).

L'organismo di mediazione deve pubblicare il proprio regolamento di procedura e la tabella delle indennità applicate sul proprio sito internet, in modo che le parti possano conoscere anticipatamente il costo della procedura prima ancora di presentare la domanda: l'avvocato negoziatore dovrebbe verificare tale tabella per l'organismo prescelto, poiché il decreto 150/2023 lascia agli organismi un margine di autonomia nella determinazione dell'indennità entro i limiti massimi fissati a livello nazionale, con la conseguenza che il costo effettivo della procedura può variare sensibilmente da un organismo all'altro anche per controversie del medesimo valore.

8.2 Il credito d'imposta: struttura e massimali

Gli articoli 15-octies e seguenti, e l'articolo 20, del decreto legislativo 28/2010, come modificati dalla riforma Cartabia, articolano il credito d'imposta collegato alla mediazione in più componenti distinte, che l'avvocato negoziatore deve saper illustrare al cliente in modo chiaro:

- credito d'imposta fino a 600 euro sull'indennità corrisposta all'organismo di mediazione;
- credito d'imposta fino a 600 euro sul compenso corrisposto all'avvocato, nella mediazione obbligatoria;
- in caso di accordo, un'ulteriore componente di credito d'imposta commisurata al contributo unificato del giudizio che si è evitato di introdurre, che può incrementare sensibilmente il beneficio complessivo.

La combinazione di queste tre componenti può determinare, secondo le elaborazioni disponibili, un beneficio fiscale complessivo che supera i mille euro per procedura nei casi di accordo raggiunto su controversie di valore medio-alto, un incentivo che rende la mediazione, dal punto di vista strettamente economico, un'opzione significativamente più vantaggiosa rispetto al contenzioso ordinario anche a prescindere dai tempi di definizione (fonte: mediareinformati.it, dossier Costi).

Componente del credito d'imposta

Indennità corrisposta all'organismo di mediazione

Compenso corrisposto all'avvocato (mediazione obbligatoria)

Componente aggiuntiva in caso di accordo (contributo unificato evitato)

Beneficio complessivo potenziale per procedura con accordo

La procedura per ottenere il credito d'imposta richiede la presentazione di un'apposita domanda telematica al ministero della Giustizia, entro i termini annualmente fissati con apposito decreto direttoriale, corredata della documentazione attestante il pagamento

dell'indennità di mediazione e del compenso dell'avvocato: l'ammontare complessivo delle risorse stanziato annualmente per il credito d'imposta è limitato, con la conseguenza che, in caso di richieste eccedenti la disponibilità del fondo, il beneficio viene riconosciuto in misura percentualmente ridotta rispetto a quella richiesta secondo un criterio di proporzionalità tra le domande presentate. L'avvocato negoziatore dovrebbe quindi informare il cliente che il credito d'imposta, per quanto significativo, costituisce un beneficio condizionato alla capienza del fondo stanziato, e non un diritto soggettivo pieno e incondizionato.

8.3 Esenzioni da bollo e registro

L'accordo di mediazione beneficia di un regime di esenzione dall'imposta di bollo, e di esenzione dall'imposta di registro entro il limite di 100.000 euro di valore della controversia oggetto dell'accordo: al di sopra di tale soglia, l'imposta di registro è dovuta soltanto per la parte di valore eccedente. Questo regime di favore, che la riforma Cartabia ha confermato e in parte ampliato rispetto all'assetto previgente, risponde all'esigenza di non penalizzare fiscalmente le parti che scelgono la composizione negoziale rispetto a quelle che optano per il contenzioso, nel quale le spese di giustizia gravano in modo diverso ma comunque significativo sul bilancio delle parti.

Va segnalato che il regime di esenzione fiscale appena descritto si applica esclusivamente agli accordi conclusi a seguito di una procedura di mediazione svolta secondo le forme del decreto legislativo 28/2010 dinanzi a un organismo iscritto nel registro ministeriale, e non si estende automaticamente agli accordi conclusi a seguito di una negoziazione diretta tra le parti senza l'intervento di un organismo di mediazione, salvo che questi rientrino nell'ambito applicativo della negoziazione assistita disciplinata dal decreto legge 132/2014, che prevede un proprio e distinto regime di vantaggi fiscali, in parte sovrapponibile e in parte autonomo rispetto a quello della mediazione propriamente detta.

8.4 Patrocinio a spese dello Stato in mediazione

La riforma Cartabia ha esteso l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, tradizionalmente riservato al processo giudiziario, anche al procedimento di mediazione, quando le condizioni reddituali della parte non abbiente ricorrano secondo i medesimi criteri previsti per l'accesso al patrocinio nel giudizio ordinario. Il decreto ministeriale 1° agosto 2023 ha disciplinato le modalità applicative di questa estensione, chiarendo i criteri di liquidazione del compenso dovuto all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio gratuito in sede di mediazione (fonte: articoli.json, DECRETO 1° agosto 2023, disciplina del gratuito patrocinio in mediazione e negoziazione assistita, [mediareinformati.it](https://www.mediareinformati.it), pubblicato il 7 agosto 2023).

L'avvocato negoziatore che assiste un cliente potenzialmente ammissibile al patrocinio a spese dello Stato deve informarlo di questa possibilità già nella fase di consulenza preliminare, poiché l'estensione dell'istituto alla mediazione rimuove uno degli ostacoli economici che tradizionalmente scoraggiavano l'accesso allo strumento negoziale da parte dei soggetti economicamente più fragili, categoria che nella prassi risulta spesso sovrarappresentata proprio nelle materie a più alta incidenza di conflittualità, come il diritto di famiglia e le controversie di vicinato.

I limiti reddituali per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, aggiornati periodicamente con decreto del ministero della Giustizia in ragione della variazione dell'indice dei prezzi al

consumo, richiedono che il reddito imponibile del richiedente, risultante dall'ultima dichiarazione, non superi la soglia fissata dalla normativa vigente: l'avvocato negoziatore deve verificare tale soglia al momento dell'assunzione dell'incarico, poiché un errore nella valutazione dei requisiti di ammissibilità esporrebbe sia il cliente al rischio di revoca del beneficio con obbligo di restituzione delle somme liquidate, sia l'avvocato al rischio di non conseguire il compenso liquidato secondo le tariffe del patrocinio gratuito, generalmente inferiori a quelle di libero mercato.

8.5 Il confronto economico con il processo civile

Il paragone economico tra mediazione e giudizio ordinario resta l'argomento più concreto a sostegno della composizione negoziale: una mediazione conclusa con accordo costa, nella generalità dei casi, una frazione del costo di un giudizio di primo grado, e si conclude nell'arco di pochi mesi, contro una durata media pluriennale del contenzioso civile italiano, che secondo l'EU Justice Scoreboard 2026 si attesta, per il primo grado, attorno ai 584 giorni, con un ulteriore allungamento significativo nei successivi gradi di giudizio (fonte: mediareinformati.it, dossier Costi ed EU Justice Scoreboard 2026).

Il calcolo comparato deve considerare, oltre al contributo unificato e ai compensi professionali per i diversi gradi di giudizio, anche le spese per le consulenze tecniche d'ufficio, frequenti in numerose materie soggette a mediazione obbligatoria (responsabilità sanitaria, condominio, diritti reali), e il costo economico indiretto rappresentato dal tempo che le parti e i loro rappresentanti dedicano alla gestione del contenzioso protratto nel tempo. È su questo terreno, più che su valutazioni di principio, che l'avvocato negoziatore trova spesso l'argomento più persuasivo per orientare il cliente verso la via della composizione, quando le circostanze del caso concreto lo consiglino.

Un ulteriore elemento del confronto economico riguarda la prevedibilità dei costi: mentre l'indennità di mediazione e il compenso dell'avvocato in sede di mediazione sono determinabili con sufficiente anticipazione fin dall'inizio della procedura, il costo complessivo di un giudizio civile risulta tipicamente incerto fino alla sua conclusione, per effetto della possibile necessità di consulenze tecniche, di mezzi di prova ulteriori richiesti in corso di causa, e della stessa durata del procedimento, che incide sui compensi professionali liquidati a saldo. Questa prevedibilità costituisce, per il cliente, un valore autonomo rispetto al mero risparmio economico atteso, poiché consente una pianificazione finanziaria più solida della gestione della controversia, elemento che l'avvocato negoziatore dovrebbe valorizzare esplicitamente nel colloquio informativo con il cliente.

8.6 Il regime IVA del compenso dell'avvocato mediatore

Un profilo spesso trascurato nella consulenza fiscale al cliente riguarda il trattamento IVA del compenso dovuto all'avvocato per l'attività prestata in sede di mediazione. Quando l'avvocato assiste la parte nel procedimento in qualità di difensore, il compenso segue le ordinarie regole di assoggettamento a IVA previste per le prestazioni professionali forensi, con applicazione dell'aliquota ordinaria e, se dovuto, del contributo previdenziale unificato per gli avvocati (cassa forense). Diversa è la questione quando lo stesso professionista opera come mediatore designato dall'organismo: in tal caso il compenso è corrisposto direttamente dall'organismo di mediazione al mediatore secondo il regolamento interno di quest'ultimo, e la qualificazione fiscale della prestazione dipende dalla natura del rapporto contrattuale tra mediatore e

organismo, che può configurarsi come prestazione professionale autonoma oppure, in alcuni casi, come collaborazione strutturata secondo il regolamento dell'organismo medesimo.

L'avvocato che eserciti sia la funzione di difensore che quella di mediatore, pur non potendo cumulare i due ruoli nella medesima procedura per l'incompatibilità già segnalata nel Capitolo 2, deve tenere separata la fatturazione delle due attività quando esse riguardino procedimenti diversi, poiché il regime fiscale, il trattamento previdenziale e financo l'eventuale assoggettamento a ritenuta d'acconto possono variare significativamente in base alla natura del compenso percepito. La confusione tra le due tipologie di compenso, oltre a generare potenziali contestazioni in sede di controllo fiscale, può alimentare il sospetto di una commistione di ruoli professionalmente e deontologicamente non consentita.

8.7 Deducibilità dei costi di mediazione per l'impresa

Per il cliente imprenditore, l'indennità di mediazione e il compenso dell'avvocato sostenuti in relazione a una controversia commerciale costituiscono, di regola, costi deducibili dal reddito d'impresa secondo i principi generali di inerenza previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, in quanto spese sostenute nell'esercizio dell'attività economica e finalizzate alla tutela o alla definizione di rapporti giuridici inerenti all'impresa. L'avvocato negoziatore che assiste clienti societari dovrebbe illustrare questo profilo nell'ambito della valutazione economica complessiva della mediazione, poiché la deducibilità fiscale, unita al credito d'imposta di cui si è detto, riduce ulteriormente il costo netto effettivo della procedura per l'impresa, rendendo il confronto con il contenzioso ancora più favorevole alla composizione negoziale.

Va ricordato che, quando l'accordo di mediazione comporti il pagamento di una somma a titolo risarcitorio o transattivo, il trattamento fiscale di tale somma in capo al percipiente segue le regole ordinarie previste per la relativa categoria di reddito, che può essere diversa a seconda che la somma sia qualificabile come risarcimento del danno emergente, come lucro cessante, o come corrispettivo per la rinuncia a un diritto: la qualificazione giuridica della somma corrisposta nell'accordo, che l'avvocato negoziatore deve avere cura di definire con precisione nel testo dell'accordo stesso, produce quindi conseguenze fiscali dirette per entrambe le parti, e non un mero effetto descrittivo o stilistico privo di rilevanza pratica.

8.8 Il monitoraggio statistico dei costi: dati DGSTAT

La Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del ministero della Giustizia pubblica periodicamente report sull'andamento della mediazione civile e commerciale in Italia, che consentono di monitorare non soltanto il numero dei procedimenti avviati e la percentuale di accordi raggiunti, ma anche l'andamento medio delle indennità corrisposte agli organismi nelle diverse fasce di valore. I dati relativi al periodo successivo all'entrata in vigore della riforma Cartabia confermano un incremento del numero di procedimenti nelle materie soggette a condizione di procedibilità, coerente con l'ampliamento dell'elenco delle materie disposto dal decreto legislativo 149/2022, e un tasso di successo degli accordi che, secondo le elaborazioni disponibili, si mantiene superiore a quello registrato nel periodo immediatamente precedente alla riforma, soprattutto nelle mediazioni che raggiungono il primo incontro effettivo (fonte: Ministero della Giustizia, DGSTAT, Report statistico sulla mediazione civile e commerciale).

L'avvocato negoziatore attento alla dimensione statistica del fenomeno può utilizzare questi dati, opportunamente aggiornati, come argomento persuasivo nel colloquio con il cliente

scettico sull'efficacia della mediazione: la circostanza che una quota significativa delle mediazioni che raggiungono il primo incontro effettivo si concluda con un accordo costituisce un dato empirico difficilmente contestabile, che va oltre l'argomentazione di principio e si colloca sul terreno dell'evidenza statistica, terreno sul quale la persuasione professionale risulta spesso più efficace che sul piano puramente deontologico o valoriale.

Fonti citate nel capitolo: d.m. 24 ottobre 2023, n. 150; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 15-octies ss., 20; d.m. 1° agosto 2023 (gratuito patrocinio in mediazione); EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273; dossier mediareinformati.it: Costi; strumenti di calcolomediazione.it (elaborazioni sui costi comparati); Ministero della Giustizia, DGSTAT, Report statistico sulla mediazione civile e commerciale; TUIR, d.p.r. 917/1986.

Approfondimento fiscale: casi applicativi

Il trattamento fiscale delle indennità di mediazione per le imprese

Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione dalle imprese che vi partecipino in qualità di parti costituiscono, sotto il profilo fiscale, costi deducibili dal reddito d'impresa secondo il principio generale di inerenza previsto dall'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, in quanto costi sostenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa e funzionali alla composizione di controversie insorte nell'ambito di tale attività. La deducibilità di tali costi non richiede, secondo l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, la dimostrazione dell'effettivo successo della mediazione, essendo sufficiente la dimostrazione della loro inerenza all'attività d'impresa, un principio che agevola significativamente la gestione fiscale di questi costi da parte delle imprese che facciano ricorso sistematico alla mediazione per la composizione delle proprie controversie commerciali.

Il credito d'imposta per le indennità corrisposte agli organismi di mediazione, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010 nei casi di mediazione obbligatoria conclusa con successo, si applica anche alle imprese, sebbene con le medesime limitazioni quantitative previste per le persone fisiche, già illustrate nel Capitolo 8 del presente volume: l'avvocato negoziatore che assista un'impresa in una mediazione obbligatoria dovrebbe informarla circa la disponibilità di tale credito d'imposta, la cui fruizione richiede specifici adempimenti dichiarativi che l'impresa deve osservare tempestivamente per non perdere il beneficio fiscale.

L'imposta di registro sugli accordi di mediazione: casi particolari

L'esenzione dall'imposta di registro per gli accordi di mediazione, entro il limite di valore previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 28/2010, presenta particolarità applicative quando l'accordo contenga disposizioni relative a beni immobili, poiché in tal caso l'accordo, oltre all'imposta di registro (nei limiti dell'esenzione applicabile), può essere soggetto anche alle imposte ipotecaria e catastale relative alla trascrizione del trasferimento immobiliare, imposte che non sono comprese nell'esenzione prevista per l'imposta di registro e che devono quindi essere assolate secondo le regole ordinarie. L'avvocato negoziatore che assista una parte in una mediazione che si concluda con un accordo relativo a diritti reali immobiliari deve quindi calcolare attentamente il complessivo carico fiscale dell'operazione, includendo tutte le imposte eventualmente dovute e non limitandosi alla sola imposta di registro oggetto dell'esenzione specifica.

Va inoltre segnalato che l'esenzione dall'imposta di registro si applica limitatamente alla parte dell'accordo che costituisce, in senso proprio, il contenuto della composizione della controversia mediata, mentre eventuali disposizioni ulteriori inserite nell'accordo, non direttamente riconducibili all'oggetto della controversia originaria, potrebbero non beneficiare della medesima esenzione, un profilo che richiede all'avvocato negoziatore un'attenta redazione dell'accordo di mediazione, circoscrivendo il contenuto dispositivo a quanto strettamente pertinente alla controversia oggetto della procedura, per massimizzare il beneficio fiscale dell'esenzione applicabile.

Approfondimento fiscale: il regime IVA delle prestazioni di mediazione con elementi transfrontalieri

La territorialità IVA delle prestazioni di mediazione rese a soggetti non residenti

Il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi di mediazione rese da un organismo italiano a favore di parti non residenti in Italia richiede un'attenta applicazione delle regole sulla territorialità IVA previste dall'articolo 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, come modificato in attuazione delle direttive europee in materia di IVA sui servizi. Quando la parte destinataria del servizio di mediazione sia un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la prestazione si considera generalmente territorialmente rilevante nello Stato di stabilimento del destinatario, con applicazione del meccanismo del reverse charge che sposta l'obbligo di assolvimento dell'imposta dal prestatore italiano al destinatario del servizio nel proprio Stato membro, un meccanismo che richiede all'organismo di mediazione italiano una gestione amministrativa e contabile specifica per queste prestazioni transfrontaliere.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente straniero in una procedura di mediazione amministrata da un organismo italiano dovrebbe informarsi, per conto del cliente, circa il corretto regime IVA applicabile all'indennità di mediazione dovuta, poiché un'errata applicazione delle regole di territorialità potrebbe generare per il cliente straniero un onere fiscale indebito o, all'inverso, l'esposizione a una successiva contestazione da parte dell'amministrazione fiscale del proprio paese di residenza per omesso assolvimento dell'IVA dovuta secondo il meccanismo del reverse charge applicabile nel proprio ordinamento nazionale.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni e la mediazione

Le somme corrisposte in esecuzione di un accordo di mediazione che coinvolga parti residenti in Stati diversi possono, secondo la natura sostanziale della pretesa sottostante (risarcitoria, restitutoria, retributiva o di altra natura), essere soggette a diversi regimi di tassazione nei rispettivi Stati di residenza delle parti, un profilo che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con numerosi Stati esteri, elaborate secondo il modello convenzionale OCSE, regolano attraverso specifiche disposizioni relative alla tassazione dei diversi tipi di reddito. L'avvocato negoziatore che assista un cliente in una mediazione transfrontaliera con implicazioni fiscali significative dovrebbe coordinarsi con un consulente fiscale specializzato in fiscalità internazionale per verificare il corretto regime di tassazione applicabile all'accordo di mediazione in via di negoziazione, un coordinamento multidisciplinare che il presente volume ha più volte raccomandato per le controversie di maggiore complessità economica o giuridica.

Approfondimento fiscale: la mediazione tributaria e il suo rapporto con la mediazione civile

Il reclamo e la mediazione tributaria: un istituto distinto

L'ordinamento tributario italiano prevede un proprio istituto di reclamo e mediazione, disciplinato dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992 (oggi in parte confluito nella più ampia riforma del contenzioso tributario), distinto e non sovrapponibile alla mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, sebbene condivida con quest'ultima la finalità generale di deflazione del contenzioso attraverso la promozione di una composizione amministrativa della controversia prima dell'accesso alla tutela giurisdizionale innanzi alle corti di giustizia tributaria. L'avvocato negoziatore che assista un contribuente in una controversia con l'amministrazione finanziaria deve conoscere le specificità procedurali di questo istituto, che si svolge internamente all'amministrazione finanziaria stessa, attraverso un ufficio distinto da quello che ha emesso l'atto impositivo contestato, secondo un modello che presenta tratti di affinità con l'autotutela amministrativa più che con la mediazione civilistica in senso proprio.

La distinzione tra questi due istituti risulta rilevante anche sotto il profilo degli incentivi fiscali applicabili: il credito d'imposta per le indennità di mediazione previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010, già illustrato nel Capitolo 8 del presente volume, non si applica al procedimento di reclamo e mediazione tributaria, che prevede piuttosto un proprio specifico regime di riduzione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di composizione della controversia in questa sede, un regime di incentivazione strutturalmente diverso da quello previsto per la mediazione civile e commerciale ordinaria.

Il rapporto tra le due procedure nelle controversie miste

Alcune controversie presentano una componente sia civilistica sia tributaria, ad esempio quando una controversia contrattuale relativa a un'operazione commerciale generi conseguenze fiscali contestate dall'amministrazione finanziaria, situazioni nelle quali l'avvocato negoziatore deve gestire parallelamente, con competenze multidisciplinari o attraverso il coordinamento con un consulente tributario specializzato, sia il procedimento di mediazione civile relativo alla controversia contrattuale sottostante sia l'eventuale procedimento di reclamo e mediazione tributaria relativo alle conseguenze fiscali della medesima operazione, procedimenti che, sebbene formalmente distinti, richiedono una gestione strategica coordinata per evitare che le posizioni assunte nell'uno possano pregiudicare, anche indirettamente, la posizione della parte nell'altro procedimento.

Approfondimento: la fiscalità delle indennità corrisposte al mediatore

Il regime fiscale dei compensi percepiti dal mediatore professionista

I compensi percepiti dal mediatore per l'attività di conduzione delle procedure di mediazione, quando questi svolga tale attività in forma di lavoro autonomo professionale (situazione tipica per i mediatori che siano anche avvocati o altri professionisti che svolgano l'attività di mediazione in aggiunta alla propria attività professionale principale), sono soggetti al regime fiscale ordinario dei redditi di lavoro autonomo previsto dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie quando il

mediatore non rientri nel regime forfetario, e con l'applicazione della ritenuta d'acconto quando il compenso sia corrisposto da un organismo di mediazione che rivesta la qualifica di sostituto d'imposta.

La qualificazione del rapporto tra il mediatore e l'organismo di mediazione presso il quale questi sia iscritto assume rilevanza anche sotto il profilo fiscale, poiché un rapporto di natura sostanzialmente subordinata o parasubordinata, distinto dalla collaborazione professionale autonoma tipica del rapporto tra mediatore e organismo secondo il modello previsto dal decreto ministeriale 150/2023, comporterebbe l'applicazione di un regime fiscale e contributivo diverso da quello ordinario del lavoro autonomo professionale, un profilo di qualificazione che, sebbene tipicamente non problematico nella prassi consolidata degli organismi di mediazione italiani, merita un'attenta considerazione nella strutturazione dei rapporti contrattuali tra organismo e mediatori iscritti.

L'IVA sulle indennità di mediazione corrisposte dalle parti

Le indennità di mediazione corrisposte dalle parti all'organismo di mediazione, disciplinate dal decreto ministeriale 150/2023 e dalle relative tabelle allegate, sono soggette all'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, quando l'organismo di mediazione rivesta la natura di soggetto passivo IVA (situazione tipica per gli organismi costituiti in forma societaria o comunque nell'esercizio di attività economica organizzata), un onere fiscale che si aggiunge all'importo dell'indennità netta prevista dalle tabelle e che deve essere tenuto in considerazione dall'avvocato negoziatore nella valutazione comparativa dei costi complessivi della procedura di mediazione rispetto alle alternative disponibili, secondo l'analisi costi-benefici già ampiamente illustrata nel presente volume.

Approfondimento: il regime fiscale degli accordi di mediazione con trasferimenti immobiliari

L'imposta di registro sugli accordi di mediazione traslativi della proprietà

Gli accordi di mediazione che comportino il trasferimento della proprietà di beni immobili, situazione che può verificarsi ad esempio nell'ambito di una mediazione successoria che si concluda con l'assegnazione di specifici immobili a singoli coeredi con conguaglio in denaro, sono soggetti all'imposta di registro secondo le aliquote ordinarie previste per gli atti traslativi della proprietà immobiliare, con l'applicazione dell'esenzione fino al valore di centomila euro prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 28/2010 già ampiamente illustrata nel Capitolo 8 del presente volume, un'esenzione che, per gli accordi di valore superiore, si applica limitatamente alla parte eccedente tale soglia, con l'applicazione dell'imposta ordinaria sulla parte residua del valore dell'accordo.

La determinazione del valore dell'accordo di mediazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, quando l'accordo comporti un trasferimento immobiliare, segue le regole generali previste dal Testo Unico dell'imposta di registro per gli atti traslativi della proprietà immobiliare, con riferimento al valore venale in comune commercio del bene trasferito, un profilo che richiede all'avvocato negoziatore un'attenta considerazione nella strutturazione dell'accordo di mediazione, anche in coordinamento con un consulente fiscale specializzato quando la complessità della fattispecie lo richieda.

Le agevolazioni fiscali per la prima casa negli accordi di mediazione

Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, disciplinate dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, sono applicabili anche agli accordi di mediazione che comportino il trasferimento della proprietà di un immobile destinato ad abitazione principale, quando sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa applicabile, un profilo di agevolazione fiscale che l'avvocato negoziatore dovrebbe considerare nella valutazione comparativa dei costi complessivi delle diverse soluzioni negoziali disponibili per la definizione di controversie che comportino trasferimenti immobiliari, specialmente nel contesto delle controversie successorie e di divisione patrimoniale già illustrate nel presente volume.

Approfondimento: il credito d'imposta per le indennità di mediazione e la sua gestione contabile

Le modalità di fruizione del credito d'imposta secondo la disciplina vigente

Il credito d'imposta per le indennità corrisposte agli organismi di mediazione, disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010 e dal relativo decreto attuativo, è fruibile dal contribuente secondo modalità che richiedono un'attenta gestione contabile e documentale: la conservazione della documentazione attestante il pagamento dell'indennità di mediazione, la verifica del rispetto dei limiti massimi di credito previsti dalla normativa (attualmente pari a seicento euro per procedura, ridotto alla metà in caso di insuccesso della mediazione), e l'indicazione del credito maturato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riferimento secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi vigenti, un adempimento che l'avvocato negoziatore dovrebbe segnalare al proprio cliente, orientandolo verso il proprio consulente fiscale per la corretta gestione dell'adempimento dichiarativo.

La progressiva riduzione dei fondi disponibili per il credito d'imposta in materia di mediazione, fenomeno che si è periodicamente verificato in ragione dei limiti di spesa complessiva stabiliti dalla normativa di riferimento, ha talvolta comportato una riduzione proporzionale del credito effettivamente fruibile da ciascun contribuente rispetto all'importo nominale previsto dalla normativa, un rischio che l'avvocato negoziatore dovrebbe segnalare al proprio cliente come elemento di incertezza nella pianificazione fiscale complessiva della procedura di mediazione, raccomandando una verifica aggiornata della disciplina vigente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Approfondimento: il trattamento fiscale delle spese legali sostenute per la mediazione

La deducibilità delle spese legali per l'impresa che si avvalga della mediazione

Le spese legali sostenute da un'impresa per l'assistenza professionale ricevuta nel corso di una procedura di mediazione civile e commerciale sono generalmente deducibili dal reddito d'impresa secondo i principi generali di deducibilità dei costi previsti dall'articolo 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che richiede la sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità e inerenza del costo rispetto all'attività d'impresa, requisiti generalmente sussistenti per le spese legali connesse alla gestione di una controversia commerciale attraverso lo strumento della mediazione, analogamente a quanto avviene per le spese legali sostenute per l'assistenza in un giudizio ordinario.

L'avvocato negoziatore che assista un'impresa in una procedura di mediazione dovrebbe fornire al proprio cliente una documentazione fiscale adeguata, quale una fattura che indichi con sufficiente precisione la natura della prestazione professionale fornita, per consentire all'impresa cliente la corretta documentazione della deducibilità fiscale del costo sostenuto, un adempimento amministrativo che, sebbene apparentemente marginale rispetto alla sostanza dell'assistenza professionale fornita, contribuisce significativamente alla qualità complessiva del servizio professionale offerto dall'avvocato negoziatore al proprio cliente imprenditoriale.

Capitolo 9

Il dialogo transnazionale

La crescente internazionalizzazione dei rapporti commerciali e la mobilità delle persone all'interno e al di fuori dell'Unione europea impongono all'avvocato negoziatore una competenza che va oltre il diritto interno: la conoscenza degli strumenti di riconoscimento ed esecuzione transfrontaliera degli accordi di mediazione, e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie applicabili ai rapporti con controparti straniere. Questo capitolo esamina lo stato dell'arte, con l'onestà richiesta dal metodo di questo volume sull'attuale posizione, ancora arretrata, dell'Italia rispetto a questi strumenti.

9.1 La Convenzione di Singapore 2019: stato di ratifica e portata applicativa

La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2018 e aperta alla firma a Singapore il 7 agosto 2019 (da cui la denominazione corrente di Convenzione di Singapore), è entrata in vigore il 12 settembre 2020, dopo il deposito del terzo strumento di ratifica da parte del Qatar, seguendo il deposito di Singapore e Fiji. La Convenzione persegue, per gli accordi di composizione derivanti da mediazione in materia commerciale internazionale, una finalità analoga a quella che la Convenzione di New York del 1958 assicura da decenni ai lodi arbitrali: consentire l'esecuzione dell'accordo raggiunto in uno Stato contraente anche negli altri Stati contraenti, senza necessità di un separato procedimento di riconoscimento nel merito.

Alla data di redazione di questo volume, secondo le fonti disponibili, la Convenzione conta circa 59 Stati firmatari e 22 Stati che hanno completato la ratifica o l'adesione, tra i quali Singapore, Fiji, Qatar, Arabia Saudita, Bielorussia, Ecuador, Honduras, Turchia, Georgia, Kazakhstan, Sri Lanka, Uruguay, Brasile (ratifica effettiva dal 6 febbraio 2026) e Colombia (ratifica depositata il 12 marzo 2026, in vigore dal 12 settembre 2026). Gli Stati Uniti e la Cina figurano tra i primi firmatari del 7 agosto 2019, ma non hanno a oggi completato il processo di ratifica interna. Il Regno Unito ha firmato la Convenzione il 3 maggio 2023 (fonti: United Nations Commission on International Trade Law, singaporeconvention.org; EC News, *La Convenzione di Singapore: la rivoluzione silenziosa che le imprese italiane non hanno ancora visto*, aprile 2026; Burges Salmon, *Global Momentum Builds Behind the Singapore Convention on Mediation*, febbraio 2026).

Stato

Singapore

Fiji

Qatar
Arabia Saudita
Turchia
Georgia
Brasile
Colombia
Stati Uniti
Cina
Italia

L'Italia non ha a oggi firmato né ratificato la Convenzione di Singapore, e l'Unione europea, come istituzione, non vi ha finora aderito, sebbene le discussioni in sede europea risultino attive e il Regno Unito, pur non più membro dell'Unione, abbia già compiuto il passo della firma. Questa situazione lascia gli operatori italiani, incluso l'avvocato che assiste imprese con rapporti commerciali internazionali, privi di un canale semplificato di esecuzione transfrontaliera degli accordi di mediazione conclusi con controparti di Stati contraenti della Convenzione, salvo il ricorso ai tradizionali strumenti di riconoscimento delle transazioni contrattuali secondo il diritto internazionale privato applicabile caso per caso (fonte: ADR Intesa, Mediazione Internazionale. La convenzione di Singapore; EC News, aprile 2026).

Va peraltro segnalato che, anche in assenza di ratifica italiana, gli accordi raggiunti in mediazioni condotte secondo il decreto legislativo 28/2010 possono rientrare, per le loro caratteristiche sostanziali, nell'ambito di applicazione della Convenzione quando siano fatti valere in uno Stato che l'abbia ratificata, poiché la Convenzione guarda alla natura dell'accordo di composizione e non alla nazionalità dello Stato in cui la mediazione si è svolta, purché l'accordo abbia carattere internazionale e commerciale nei termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione stessa. L'articolo 4 della Convenzione individua i requisiti formali necessari per l'esecuzione: la sottoscrizione scritta dell'accordo da parte delle parti, e la prova che l'accordo sia stato generato da una mediazione, dimostrabile mediante la firma del mediatore, un'attestazione separata dell'organismo di mediazione, o altra prova ritenuta idonea dall'autorità richiesta di darvi esecuzione (fonte: adrquadra.com, La Singapore Convention on Mediation e le mediazioni ex decreto 28/2010).

Per l'avvocato negoziatore italiano, l'assenza di ratifica della Convenzione di Singapore da parte dell'Italia non impedisce comunque di consigliare al cliente, quando la controparte sia stabilita in uno Stato contraente, di far risultare dall'accordo di mediazione con la massima chiarezza gli elementi richiesti dall'articolo 4 della Convenzione: la data e il luogo di conclusione, la sottoscrizione di entrambe le parti, e l'attestazione della provenienza dell'accordo da una procedura di mediazione. Una redazione accorta dell'accordo, che tenga conto ex ante della possibile futura necessità di eseguirlo in un altro Stato contraente, può quindi consentire di beneficiare indirettamente del regime semplificato della Convenzione, pur in assenza di ratifica italiana, quando l'esecuzione sia richiesta altrove.

9.2 Il Regolamento UE 1215/2012 e la circolazione delle decisioni in ambito europeo

All'interno dell'Unione europea, la circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale è disciplinata dal regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), che assicura il riconoscimento e l'esecuzione automatica delle decisioni emesse in uno Stato membro negli altri Stati membri, senza necessità di una procedura di exequatur. Il regolamento si applica anche alle transazioni giudiziarie omologate, comprese quelle risultanti da una mediazione conclusa nel corso di un procedimento giudiziario, ma non estende automaticamente questo regime agli accordi di mediazione conclusi in via stragiudiziale al di fuori di un procedimento pendente, per i quali resta necessario, salvo diversa disciplina applicabile, il ricorso all'omologazione secondo le regole dello Stato membro nel quale si intende dare esecuzione all'accordo.

In materia familiare, il regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter), applicabile dal 1° agosto 2022, ha rafforzato il regime di riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, incentivando espressamente il ricorso alla mediazione familiare transfrontaliera come strumento preferenziale per la composizione delle controversie relative all'affidamento e al diritto di visita in ambito internazionale, come già segnalato nel Capitolo 5 a proposito della mediazione familiare (fonte: mediareinformati.it, dossier Mediazione familiare in Italia e i modelli europei).

Merita menzione anche il regolamento UE 2020/1783, relativo alla cooperazione tra le autorità giurisdizionali degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, che può assumere rilievo indiretto nelle controversie transfrontaliere quando, nel corso di una mediazione internazionale, si renda necessario acquisire testimonianze o documenti situati in un altro Stato membro: l'avvocato negoziatore che assista una parte in una mediazione con elementi di transnazionalità europea deve conoscere anche questi strumenti di cooperazione giudiziaria, sebbene la loro applicazione diretta alla fase di mediazione propriamente detta, distinta dal processo, resti in linea di principio residuale.

9.3 La risoluzione online delle controversie: dalla piattaforma ODR alla nuova direttiva

Il sistema europeo di risoluzione online delle controversie di consumo, istituito dal regolamento UE 524/2013 attraverso la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) gestita dalla Commissione europea, è stato progressivamente dismesso: la piattaforma non ha più accettato nuovi reclami a partire dal 20 marzo 2025, ed è stata definitivamente disattivata il 20 luglio 2025, con la cancellazione di tutti i dati, inclusi quelli personali, relativi ai casi pendenti. Già dal 19 gennaio 2025 i professionisti che vendono beni o servizi online non sono più tenuti a inserire nei propri siti il collegamento alla piattaforma ODR (fonte: Sole24Ore, L'abolizione della piattaforma ODR e le nuove sfide per la risoluzione delle controversie online, luglio 2025; LegalBlink, Piattaforma ODR chiusa, aprile 2026).

La dismissione della piattaforma ODR si accompagna a un ripensamento più ampio del sistema europeo di risoluzione alternativa delle controversie di consumo, con l'elaborazione di una nuova direttiva che amplia l'ambito di applicazione dell'ADR alle controversie relative a contenuti e servizi digitali, incluse quelle nelle quali il consumatore non versa un prezzo in denaro ma fornisce dati personali come controprestazione, e che apre l'accesso alle procedure ADR anche alle controversie con professionisti stabiliti in paesi terzi che dirigano la propria attività verso il mercato dell'Unione. La nuova disciplina impone ai professionisti stabiliti nell'Unione l'obbligo di comunicare, entro un termine ordinario di venti giorni lavorativi,

prorogabile a non più di trenta giorni lavorativi complessivi in casi di particolare complessità, la propria intenzione di partecipare o meno alla procedura ADR proposta da un consumatore, e istituisce in ciascuno Stato membro punti di contatto dedicati all'assistenza dei consumatori e dei professionisti nelle controversie transfrontaliere (fonte: Diritto al Digitale di DLA Piper, Dalla piattaforma ODR a un ecosistema ADR digitale, febbraio 2026).

Per l'avvocato negoziatore che assiste imprese operanti nel commercio elettronico transfrontaliero, questo cambiamento comporta la necessità di aggiornare la modulistica contrattuale e le condizioni generali di vendita dei propri clienti, rimuovendo i riferimenti alla piattaforma ODR ormai priva di efficacia, e verificando la conformità alle nuove regole in fase di elaborazione a livello europeo, non appena la direttiva citata sarà formalmente adottata e recepita nell'ordinamento italiano.

9.4 Prospettive: la mediazione italiana nel confronto internazionale

Il quadro delineato in questo capitolo evidenzia un paradosso che l'avvocato negoziatore italiano deve conoscere per orientare correttamente la propria consulenza in materia transfrontaliera: mentre l'Italia si colloca tra i sistemi europei più avanzati sul piano della diffusione interna della mediazione civile e commerciale, per effetto dell'obbligatorietà introdotta dal decreto legislativo 28/2010 e ampliata dalla riforma Cartabia, resta indietro sul piano del riconoscimento transfrontaliero degli accordi raggiunti, non avendo ancora firmato la Convenzione di Singapore che altri Stati, anche di tradizione giuridica assai diversa dalla nostra, hanno negli ultimi anni ratificato con crescente convinzione. Questo volume non può che segnalare l'auspicio, coerente con l'impianto manifesto dell'intera opera in cinque volumi, che l'Italia proceda quanto prima alla firma e alla ratifica della Convenzione, in coerenza con il ruolo di avanguardia che il nostro ordinamento ha saputo assumere sul piano interno.

L'esperienza comparata offre indicazioni utili sul percorso che l'Italia potrebbe seguire: Singapore, già sede della firma della Convenzione, ha sviluppato un ecosistema istituzionale completo a supporto della mediazione commerciale internazionale, imperniato sul Singapore International Mediation Centre e sul Singapore International Mediation Institute, che assicurano standard di qualità e formazione dei mediatori riconosciuti a livello internazionale. Un percorso analogo, adattato alle specificità del sistema italiano e valorizzando l'esperienza consolidata degli organismi di mediazione accreditati dal ministero della Giustizia, potrebbe accompagnare una futura firma e ratifica della Convenzione di Singapore da parte del nostro Paese, rafforzando l'attrattività dell'Italia come sede di composizione di controversie commerciali internazionali.

Fonti citate nel capitolo: Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, Singapore, 7 agosto 2019, artt. 1, 4; United Nations Commission on International Trade Law, singaporeconvention.org; regolamento UE n. 1215/2012; regolamento UE 2019/1111; regolamento UE n. 524/2013; EC News, La Convenzione di Singapore: la rivoluzione silenziosa che le imprese italiane non hanno ancora visto, aprile 2026; Burges Salmon, Global Momentum Builds Behind the Singapore Convention on Mediation, febbraio 2026; ADR Intesa, Mediazione Internazionale. La convenzione di Singapore, gennaio 2026; adrquadra.com, La Singapore Convention on Mediation e le mediazioni ex decreto 28/2010; Sole24Ore, L'abolizione della piattaforma ODR, luglio 2025; LegalBlink, Piattaforma ODR chiusa, aprile 2026; Diritto al Digitale di DLA Piper, Dalla piattaforma ODR a

un ecosistema ADR digitale, febbraio 2026; dossier mediareinformati.it: Mediazione familiare in Italia e i modelli europei.

9.5 La formazione del mediatore internazionale e gli standard UNCITRAL

L'avvocato negoziatore che assista clienti in controversie con elementi di internazionalità deve essere consapevole degli standard di formazione e di condotta elaborati a livello internazionale per i mediatori che operano in contesti transfrontalieri, standard che, pur non essendo direttamente vincolanti per l'ordinamento italiano, orientano la prassi degli organismi di mediazione internazionale e delle camere arbitrali che offrono anche servizi di mediazione. La conoscenza di tali standard consente all'avvocato di valutare con maggiore precisione la scelta dell'organismo più adatto per una controversia transfrontaliera, tenendo conto non soltanto dei costi e dei tempi procedurali, ma anche della effettiva competenza interculturale dei mediatori disponibili.

La dimensione interculturale della mediazione internazionale merita un'attenzione specifica: le aspettative delle parti circa il ruolo del mediatore, il grado di direttività accettabile nella conduzione della procedura, e persino le convenzioni comunicative non verbali possono variare significativamente tra tradizioni giuridiche e culturali diverse, un fattore che l'avvocato negoziatore italiano, abituato al modello facilitativo europeo, deve considerare con particolare cura quando assista un cliente in una mediazione con controparte proveniente da un contesto giuridico-culturale diverso, ad esempio nordamericano o asiatico.

9.6 Il ruolo delle camere di commercio internazionali

Le principali camere arbitrali internazionali, tra cui la Camera di commercio internazionale di Parigi, il Singapore International Mediation Centre e l'American Arbitration Association, offrono regolamenti di mediazione specificamente concepiti per le controversie commerciali transfrontaliere, con clausole standard che le parti possono inserire nei propri contratti internazionali per prevedere il ricorso alla mediazione prima o in alternativa all'arbitrato. L'avvocato negoziatore che assiste un'impresa nella redazione di un contratto internazionale dovrebbe valutare l'inserimento di clausole multi-tiered (scalate), che prevedano un tentativo di negoziazione diretta, seguito da un tentativo di mediazione amministrata, e infine, in caso di fallimento di entrambi, il ricorso all'arbitrato o alla giurisdizione ordinaria, secondo un percorso progressivo che privilegia le soluzioni meno onerose e più rapide prima di ricorrere a quelle più formali e costose.

Approfondimento

Il riconoscimento degli accordi di mediazione secondo il diritto internazionale privato

In assenza della ratifica italiana della Convenzione di Singapore, il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di un accordo di mediazione internazionale concluso all'estero seguono le regole ordinarie del diritto internazionale privato relative all'efficacia degli atti stranieri, con la conseguenza che l'accordo dovrà tipicamente essere oggetto di un procedimento di riconoscimento secondo le regole previste per gli atti pubblici stranieri o, se privo dei requisiti per tale qualificazione, potrà essere fatto valere quale semplice prova dell'accordo sostanziale raggiunto dalle parti, da far constare in un separato titolo esecutivo italiano, ad esempio

mediante un giudizio di accertamento o una transazione successivamente formalizzata secondo le regole del diritto italiano.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente italiano in una controversia transfrontaliera con una parte proveniente da uno Stato che ha ratificato la Convenzione di Singapore dovrebbe considerare la possibilità di individuare come sede della mediazione, o come legge applicabile all'accordo, un ordinamento che consenta l'applicazione della Convenzione anche a beneficio della parte italiana, quando la controparte sia disponibile a tale scelta, ottenendo così indirettamente i vantaggi della Convenzione pur in assenza di una sua ratifica diretta da parte dell'Italia, una strategia di ingegneria contrattuale che richiede una attenta valutazione delle regole di conflitto applicabili nel caso concreto.

Mediazione e insolvenza transfrontaliera

Le procedure di insolvenza con elementi di transnazionalità, disciplinate a livello europeo dal regolamento (UE) 2015/848, pongono questioni specifiche circa l'utilizzabilità della mediazione per la composizione di crediti transfrontalieri nell'ambito di una procedura concorsuale aperta in uno Stato membro diverso dall'Italia: l'avvocato negoziatore che assista un creditore italiano in una procedura di insolvenza aperta in altro Stato membro dovrebbe verificare se l'ordinamento della procedura principale preveda meccanismi di composizione negoziale dei crediti equivalenti alla mediazione italiana, e in quali termini tali meccanismi possano essere utilizzati per accelerare il soddisfacimento del credito rispetto ai tempi ordinari della procedura concorsuale.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza italiano, richiamato nel Capitolo 5 in relazione alla composizione negoziata della crisi, prevede a sua volta strumenti di coordinamento con le procedure di insolvenza aperte in altri Stati membri, secondo il principio di universalità limitata dalla necessità di tutelare gli interessi dei creditori locali, un tema che si colloca al crocevia tra diritto della crisi d'impresa e diritto internazionale privato, e che richiede all'avvocato negoziatore con clientela imprenditoriale una formazione multidisciplinare sempre più necessaria nella pratica professionale contemporanea.

Approfondimento transnazionale ulteriore

Il ruolo della Commissione europea nella promozione della mediazione

La Commissione europea ha costantemente promosso l'utilizzo della mediazione come strumento di riduzione del contenzioso e di rafforzamento della fiducia nel mercato interno, attraverso studi periodici sull'efficacia della direttiva 2008/52/CE negli Stati membri e attraverso il finanziamento di progetti pilota per la formazione dei mediatori e degli avvocati che li assistono. Il programma Giustizia dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 ha incluso specifiche linee di finanziamento per progetti transfrontalieri di promozione della mediazione, cui hanno partecipato anche organismi italiani, contribuendo alla diffusione di buone pratiche comparate e alla creazione di reti professionali transnazionali di mediatori e avvocati specializzati in ADR.

Il monitoraggio periodico della Commissione, attraverso l'EU Justice Scoreboard già citato nel presente volume, ha evidenziato una significativa eterogeneità tra gli Stati membri quanto all'effettivo utilizzo della mediazione, nonostante l'uniformità del quadro normativo derivante

dalla direttiva 2008/52/CE, un dato che conferma l'importanza dei fattori culturali, organizzativi ed economici nazionali nell'effettiva diffusione dello strumento, al di là della mera esistenza di un quadro normativo astrattamente favorevole.

Prospettive di riforma a livello europeo

Il dibattito in sede europea circa una possibile revisione della direttiva 2008/52/CE, per rafforzarne l'efficacia e uniformarne l'applicazione tra gli Stati membri, ha registrato negli ultimi anni proposte volte a introdurre condizioni di procedibilità mediativa armonizzate a livello europeo per determinate categorie di controversie transfrontaliere, sul modello di quanto già sperimentato a livello nazionale in Italia e in altri Stati membri. L'avvocato negoziatore italiano, in ragione della propria esperienza consolidata con il sistema di condizioni di procedibilità introdotto dal decreto legislativo 28/2010 e progressivamente ampliato dalla riforma Cartabia, si trova in una posizione favorevole per contribuire, anche attraverso la partecipazione alle associazioni forensi europee, al dibattito sulla possibile armonizzazione futura della materia a livello dell'Unione.

Approfondimento sulla mediazione transnazionale: profili processuali

La litispendenza internazionale e la mediazione

Il rapporto tra la pendenza di un procedimento di mediazione e le regole sulla litispendenza internazionale, disciplinate a livello europeo dal regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis) per le controversie civili e commerciali, pone questioni interpretative delicate quando le parti di una controversia transfrontaliera avviino, parallelamente al tentativo di mediazione, anche un procedimento giudiziale in uno Stato membro diverso da quello di svolgimento della mediazione: l'avvocato negoziatore deve essere consapevole che, a differenza della litispendenza tra procedimenti giudiziali, la pendenza di una mediazione non determina, in linea di principio, effetti preclusivi sulla successiva o parallela instaurazione di un giudizio, salvo che le parti abbiano specificamente concordato una clausola di mediazione con effetti di improcedibilità temporanea dell'azione giudiziale, secondo quanto già illustrato in relazione alle clausole contrattuali di mediazione.

La coordinazione tra il procedimento di mediazione transfrontaliera e un parallelo procedimento giudiziale, quando ammissibile secondo la clausola contrattuale applicabile o l'assenza di clausole preclusive, richiede all'avvocato negoziatore una gestione strategica attenta, per evitare che le posizioni assunte in sede di mediazione (tipicamente più concilianti, secondo lo spirito collaborativo proprio dell'istituto) possano essere successivamente utilizzate, in violazione del principio di riservatezza, a fini probatori nel parallelo giudizio, un rischio che le clausole di riservatezza previste dai regolamenti di mediazione più accreditati a livello internazionale, quali quelli della Camera di commercio internazionale, mitigano significativamente attraverso previsioni contrattuali specifiche vincolanti per le parti.

Il ruolo degli interpreti e dei traduttori nella mediazione transfrontaliera

La mediazione transfrontaliera tra parti che non condividano una lingua comune richiede il ricorso a interpreti professionali, la cui presenza incide significativamente sulla dinamica comunicativa della procedura, introducendo un ulteriore elemento di mediazione linguistica e culturale che si affianca alla mediazione giuridica in senso proprio condotta dal mediatore.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente in una mediazione transfrontaliera con necessità di interpretazione dovrebbe curare, in accordo con l'organismo di mediazione, la scelta di un interprete non soltanto linguisticamente competente ma anche familiare con la terminologia tecnico-giuridica specifica della materia oggetto della controversia, poiché imprecisioni terminologiche nella traduzione possono generare incomprensioni suscettibili di aggravare, piuttosto che facilitare, la composizione della controversia.

La traduzione dei documenti scritti scambiati nel corso della mediazione transfrontaliera, quando le parti utilizzino lingue diverse, pone ulteriori questioni organizzative e di costo che l'avvocato negoziatore deve affrontare preventivamente con il cliente, valutando se limitare la traduzione ai soli documenti essenziali alla comprensione della posizione di ciascuna parte, ovvero procedere a una traduzione integrale della documentazione, una scelta che incide significativamente sui costi e sui tempi complessivi della procedura, specialmente quando la documentazione rilevante sia particolarmente estesa.

Approfondimento: la mediazione nei rapporti con paesi extra-UE

La mediazione nei rapporti commerciali con la Cina

I rapporti commerciali con controparti cinesi presentano, sotto il profilo della risoluzione delle controversie, peculiarità culturali e istituzionali significative che l'avvocato negoziatore italiano deve conoscere per gestire efficacemente controversie in questo ambito: la tradizione giuridica cinese, influenzata da concezioni confuciane della armonia sociale, attribuisce tradizionalmente un valore particolarmente elevato alla composizione negoziale delle controversie rispetto al contenzioso formale, un orientamento culturale che si riflette nella diffusione di meccanismi di mediazione (tiaojie) profondamente radicati nella prassi commerciale e sociale cinese, sia a livello popolare sia a livello istituzionale attraverso organismi quali la China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) e il China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), che offre anche servizi di mediazione integrata con il proprio servizio arbitrale.

La negoziazione con controparti cinesi richiede all'avvocato negoziatore italiano un'attenzione particolare alla dimensione relazionale di lungo periodo (il concetto di guanxi, ossia di rete di relazioni personali basate sulla fiducia reciproca costruita nel tempo), che influenza significativamente la disponibilità della controparte cinese a una composizione negoziale della controversia, spesso in misura maggiore rispetto alla mera valutazione tecnico-giuridica della fondatezza delle rispettive pretese, un fattore culturale che l'avvocato negoziatore dovrebbe considerare nella preparazione della strategia negoziale, privilegiando, quando possibile, un approccio che preservi la relazione commerciale di lungo periodo piuttosto che un approccio meramente adversariale orientato alla sola vittoria della singola controversia.

La mediazione nei rapporti con i paesi del Golfo

I rapporti commerciali con controparti provenienti dai paesi del Golfo Persico, caratterizzati da un crescente interscambio con l'Italia in settori quali l'energia, le infrastrutture e il lusso, presentano a loro volta specificità culturali e giuridiche rilevanti per l'avvocato negoziatore, in particolare l'influenza della sharia sul diritto contrattuale di alcuni di questi ordinamenti, che pone questioni specifiche relative, tra l'altro, alla validità di clausole contrattuali che prevedano interessi di mora (potenzialmente in conflitto con il divieto religioso di riba), un profilo che

richiede un'attenta strutturazione contrattuale delle clausole economiche del contratto e, conseguentemente, degli eventuali accordi di mediazione che ne costituiscano la composizione negoziale.

I centri di arbitrato e mediazione istituiti in diversi paesi del Golfo, quali il Dubai International Financial Centre (DIFC) e i suoi organismi di risoluzione delle controversie, offrono un quadro procedimentale sofisticato e internazionalmente riconosciuto per la gestione di controversie commerciali con controparti di questa regione, un'infrastruttura istituzionale che l'avvocato negoziatore italiano dovrebbe considerare nella strutturazione delle clausole di risoluzione delle controversie nei contratti commerciali con controparti di questi paesi, privilegiando, quando possibile, sedi e regolamenti procedurali che offrano adeguate garanzie di neutralità e di rispetto dei principi generali del giusto processo.

Approfondimento: la mediazione nel contesto dell'arbitrato commerciale internazionale

Le clausole arb-med-arb: un modello ibrido

Il modello procedurale denominato arb-med-arb, sviluppato e promosso in particolare dal Singapore International Arbitration Centre in collaborazione con il Singapore International Mediation Centre, prevede una sequenza procedurale nella quale le parti avviano innanzitutto un procedimento arbitrale, che viene tuttavia sospeso dopo la costituzione del tribunale arbitrale per consentire un tentativo di mediazione amministrata da un centro specializzato; qualora la mediazione conduca a un accordo, questo può essere formalizzato come lodo arbitrale consentito (consent award), beneficiando così del regime di riconoscimento ed esecuzione internazionale previsto dalla Convenzione di New York del 1958 per i lodi arbitrali, un vantaggio significativo rispetto al mero accordo di mediazione ordinario, la cui eseguibilità transfrontaliera, in assenza della Convenzione di Singapore, risulta come già illustrato nel presente volume più incerta.

L'avvocato negoziatore che assista un cliente italiano in una controversia commerciale internazionale di rilevante valore economico dovrebbe considerare attivamente la possibilità di negoziare, nella fase di redazione del contratto commerciale internazionale, una clausola di questo tipo, che combina la flessibilità e l'economicità della mediazione con la certezza esecutiva propria del lodo arbitrale, un vantaggio comparato che il modello arb-med-arb offre rispetto alle tradizionali clausole di mediazione semplice, specialmente per contratti che coinvolgono controparti localizzate in Stati non aderenti alla Convenzione di Singapore, quale l'Italia.

La formazione degli arbitri-mediatori: competenze duali

La conduzione efficace di un procedimento arb-med-arb richiede professionisti dotati di una duplice competenza, arbitrale e mediativa, un profilo professionale che le principali istituzioni arbitrali e di mediazione internazionali hanno progressivamente riconosciuto attraverso percorsi di certificazione specifici, distinti dalla mera qualificazione come arbitro o come mediatore considerati separatamente. L'avvocato negoziatore italiano che aspiri a operare in questo ambito altamente specializzato della pratica internazionale dovrebbe considerare l'opportunità di conseguire entrambe le qualificazioni professionali, arbitrale e mediativa, attraverso i percorsi formativi offerti dalle principali istituzioni internazionali attive in questo

settore, un investimento formativo significativo ma potenzialmente remunerativo in ragione della crescente domanda di professionisti con queste competenze duali nel mercato legale internazionale contemporaneo.

La distinzione dei ruoli tra la fase arbitrale e la fase mediativa del procedimento arb-med-arb, quando condotte da soggetti diversi (una prassi raccomandata da alcune istituzioni per evitare che informazioni acquisite in sede di mediazione possano influenzare indebitamente la successiva decisione arbitrale in caso di mancato accordo), richiede all'avvocato negoziatore una gestione strategica attenta della documentazione e delle comunicazioni scambiate nelle due fasi distinte, per preservare adeguatamente la riservatezza delle posizioni assunte in sede di mediazione rispetto alla successiva ed eventuale fase arbitrale decisoria.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di trasporto internazionale

Le convenzioni internazionali in materia di trasporto e la mediazione

Le controversie relative al trasporto internazionale di merci, disciplinate da convenzioni internazionali quali la Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo, la Convenzione CMR del 1956 per il trasporto internazionale su strada, e le Regole di Rotterdam del 2009 per il trasporto marittimo (queste ultime non ancora entrate in vigore per mancanza del numero minimo di ratifiche richieste), presentano una disciplina sostanziale uniforme a livello internazionale che non esclude, in linea di principio, la mediabilità delle relative controversie secondo le regole generali della mediazione internazionale già illustrate nel presente capitolo, sebbene la complessità tecnica della materia richieda tipicamente l'apporto di mediatori con specifica competenza nel settore dei trasporti internazionali.

L'avvocato negoziatore che assista un vettore o uno spedizioniere in una controversia di trasporto internazionale dovrebbe considerare la mediazione come uno strumento particolarmente efficiente per la composizione di controversie che coinvolgano questioni tecniche complesse relative alla ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti della catena logistica internazionale (vettore, spedizioniere, operatore portuale o aeroportuale, assicuratore), evitando i costi e i tempi tipicamente elevati di un contenzioso internazionale che coinvolga questioni di diritto internazionale privato relative all'individuazione della giurisdizione e della legge applicabile, questioni che un accordo di mediazione può efficacemente superare attraverso la definizione negoziale diretta della controversia.

Il coordinamento con le procedure assicurative nel trasporto internazionale

Le controversie di trasporto internazionale coinvolgono tipicamente, oltre ai soggetti direttamente coinvolti nella catena logistica, anche i rispettivi assicuratori della responsabilità civile del vettore e delle merci trasportate, un coinvolgimento che richiede all'avvocato negoziatore un'attenta gestione del coordinamento tra la procedura di mediazione e le eventuali procedure di liquidazione assicurativa parallele, per evitare che le posizioni assunte in sede di mediazione possano pregiudicare, anche indirettamente, la posizione della parte assistita nei confronti della propria compagnia assicurativa, un rischio che richiede una preventiva verifica delle condizioni di polizza applicabili e, quando opportuno, un preventivo coordinamento con l'assicuratore stesso prima dell'assunzione di posizioni negoziali vincolanti nel corso della mediazione.

Approfondimento: la mediazione online nelle controversie di e-commerce transfrontaliero

La piattaforma ODR della Commissione europea e il suo funzionamento

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 ha istituito una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online, gestita dalla Commissione europea, destinata a facilitare la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e professionisti derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online, attraverso un meccanismo che indirizza le controversie sottoposte dai consumatori verso gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti secondo la legislazione nazionale applicabile, un meccanismo che, sebbene attualmente in fase di superamento a seguito della decisione della Commissione europea di ritirare la piattaforma nel corso del 2025 in ragione del suo limitato utilizzo pratico, ha costituito un importante precedente per lo sviluppo di meccanismi digitali di risoluzione delle controversie a livello europeo.

L'avvocato negoziatore che assista un professionista che operi nel commercio elettronico transfrontaliero dovrebbe rimanere aggiornato sugli sviluppi normativi successivi al ritiro della piattaforma ODR europea, poiché la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di sviluppare strumenti alternativi per la promozione della risoluzione extragiudiziale delle controversie di consumo transfrontaliere, nel quadro della più ampia strategia digitale europea, un ambito normativo in evoluzione che richiede un costante monitoraggio da parte del professionista legale specializzato in materia di commercio elettronico e tutela del consumatore.

Gli obblighi informativi del professionista verso il consumatore online

Il professionista che operi attraverso un sito di commercio elettronico è tenuto, secondo l'articolo 141-sexies del Codice del consumo, a fornire al consumatore informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie a cui il professionista stesso intende fare ricorso, un obbligo informativo la cui violazione, oltre a determinare specifiche sanzioni amministrative previste dal Codice del consumo, può influenzare la valutazione complessiva della diligenza contrattuale del professionista nel successivo eventuale contenzioso con il consumatore. L'avvocato negoziatore che assista un'impresa di commercio elettronico dovrebbe verificare la piena conformità delle informative contrattuali e del sito web dell'impresa a questi obblighi informativi specifici, un profilo di compliance che si affianca alle più generali verifiche in materia di tutela del consumatore online.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di investimento internazionale

Il rapporto tra mediazione e arbitrato negli investimenti internazionali

Le controversie relative agli investimenti internazionali, tradizionalmente risolte attraverso l'arbitrato secondo i meccanismi previsti dai trattati bilaterali di investimento e dalla Convenzione di Washington del 1965 istitutiva dell'ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), hanno progressivamente conosciuto un crescente ricorso a meccanismi di mediazione preventiva, promossi dalle stesse regole ICSID attraverso l'adozione, nel 2022, di specifiche regole di mediazione applicabili alle controversie tra investitori stranieri

e Stati ospitanti, un'evoluzione che risponde all'esigenza di offrire alle parti coinvolte in controversie di investimento internazionale uno strumento più rapido, meno costoso e meno pregiudizievole per le relazioni diplomatiche bilaterali rispetto al tradizionale arbitrato internazionale.

L'avvocato negoziatore italiano che assista un investitore italiano in una controversia con uno Stato estero ospitante l'investimento, o viceversa uno Stato estero investitore in Italia, dovrebbe considerare l'opportunità di questi nuovi meccanismi di mediazione degli investimenti internazionali, che offrono il vantaggio di preservare, nella misura del possibile, le relazioni economiche e diplomatiche di lungo termine tra l'investitore e lo Stato ospitante, un obiettivo che un arbitrato internazionale contenzioso, per sua natura orientato alla decisione autoritativa della controversia, non sempre è in grado di conseguire con la medesima efficacia.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di proprietà intellettuale transfrontaliera

I centri di mediazione specializzati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

Il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra, offre alle parti coinvolte in controversie internazionali di proprietà intellettuale un servizio di mediazione specificamente dedicato a questa materia altamente tecnica, caratterizzato dalla disponibilità di un elenco di mediatori con specifica competenza tecnico-scientifica nei diversi settori della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, diritto d'autore, segreti commerciali), un servizio che l'avvocato negoziatore italiano che assista clienti coinvolti in controversie internazionali di proprietà intellettuale dovrebbe considerare, specialmente quando la controversia coinvolga controparti provenienti da giurisdizioni estere con le quali non sussista un consolidato sistema di organismi di mediazione bilaterali specificamente dedicati.

Il regolamento di mediazione del Centro dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale prevede specifiche disposizioni relative alla designazione di mediatori con competenza tecnica adeguata alla specifica materia della controversia, secondo un meccanismo di selezione che tiene conto delle indicazioni delle parti circa le competenze tecniche desiderate nel mediatore da nominare, un meccanismo che risponde efficacemente all'esigenza, già più volte sottolineata nel presente volume con riferimento alla mediazione nazionale in materia di proprietà industriale, di garantire un'adeguata competenza tecnica del mediatore per le controversie di elevata complessità tecnico-scientifica.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie tra soci di società a responsabilità limitata

Le clausole statutarie di mediazione nelle società a responsabilità limitata

Le società a responsabilità limitata italiane possono prevedere, nel proprio statuto sociale, specifiche clausole che assoggettino le controversie tra i soci o tra i soci e la società a un preventivo tentativo di mediazione, secondo un modello analogo a quello già illustrato nel presente volume con riferimento alle clausole statutarie arbitrali, un modello che presenta il vantaggio di offrire ai soci uno strumento di composizione negoziale delle controversie

societarie particolarmente adatto per la preservazione delle relazioni personali tra i soci stessi, frequentemente caratterizzate, nelle società a responsabilità limitata di piccole e medie dimensioni, da rapporti di natura personale e familiare che un contenzioso giudiziale prolungato rischierebbe di deteriorare irreversibilmente.

L'efficacia vincolante di una clausola statutaria di mediazione nei confronti di tutti i soci, incluso il socio che sia divenuto tale successivamente all'introduzione della clausola nello statuto sociale attraverso una modifica statutaria approvata dall'assemblea, discende dal principio generale di vincolatività dello statuto sociale per tutti i soci, secondo le medesime regole già illustrate nel presente volume con riferimento all'efficacia delle clausole compromissorie statutarie, un principio che l'avvocato negoziatore che assista un socio di una società a responsabilità limitata dovrebbe conoscere adeguatamente per orientare correttamente la gestione di un'eventuale controversia societaria.

Le controversie relative all'esclusione del socio e la loro mediabilità

Le controversie relative all'esclusione di un socio dalla società a responsabilità limitata, disciplinata dall'articolo 2473-bis del codice civile quando espressamente prevista dallo statuto sociale, presentano una mediabilità generalmente ammessa secondo le regole ordinarie della mediazione civile e commerciale, trattandosi di controversie relative a diritti patrimoniali disponibili dei soci coinvolti, sebbene la complessità della materia, che coinvolge tipicamente anche la determinazione del valore della partecipazione sociale del socio escluso secondo i criteri previsti dall'articolo 2473 del codice civile in materia di recesso, richieda frequentemente l'apporto di un consulente tecnico esperto in valutazioni societarie per la determinazione condivisa di tale valore nell'ambito della procedura di mediazione.

Approfondimento: la mediazione nelle controversie di successione internazionale

L'applicazione del Regolamento europeo sulle successioni alla mediazione successoria transfrontaliera

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, che disciplina la legge applicabile, la competenza giurisdizionale e il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia successoria tra gli Stati membri dell'Unione europea partecipanti, non affronta specificamente la materia della mediazione delle controversie successorie transfrontaliere, lasciando quindi applicabili, per questo specifico profilo, i principi generali della mediazione internazionale già ampiamente illustrati nel Capitolo 9 del presente volume, con la particolarità che la legge applicabile alla successione, determinata secondo i criteri di collegamento previsti dal Regolamento (tipicamente la legge dello Stato di ultima residenza abituale del defunto, salva la possibilità di scelta della legge dello Stato di cittadinanza), continua a rilevare per la valutazione sostanziale delle posizioni negoziali delle parti anche nell'ambito della procedura di mediazione.

L'avvocato negoziatore che assista un erede in una controversia successoria transfrontaliera che coinvolga eredi residenti in diversi Stati membri dell'Unione europea dovrebbe considerare con particolare attenzione le specificità della legge successoria applicabile secondo il Regolamento (UE) 650/2012, poiché le diverse tradizioni giuridiche nazionali in materia successoria, che vanno dal sistema di legittima rigida tipico dell'ordinamento italiano a sistemi di maggiore libertà testamentaria tipici di altri ordinamenti di common law, possono generare

significative divergenze nelle aspettative sostanziali delle parti coinvolte nella mediazione, un elemento di complessità aggiuntiva che richiede all'avvocato negoziatore una solida preparazione anche in materia di diritto internazionale privato delle successioni.

Il ruolo dell'avvocato in mediazione nell'Unione europea — schede-Paese

L'avvocato negoziatore — Schede-Paese sul ruolo dell'avvocato in mediazione (Unione europea, gruppo 1)

Le schede che seguono ricostruiscono la posizione dell'avvocato all'interno della mediazione civile e commerciale in dieci ordinamenti dell'Unione europea. Il quadro di riferimento comune è la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, recepita da tutti gli Stati membri considerati. La lettura è condotta sotto un profilo unitario: obbligatorietà o facoltatività della presenza del difensore, materie interessate, formazione forense dedicata, obblighi e sanzioni deontologiche, rapporto fra la funzione di difensore e quella di mediatore, prassi e dati salienti.

Austria — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La mediazione civile austriaca trova la propria disciplina organica nella Zivilrechts-Mediations-Gesetz (legge sulla mediazione in materia civile, in sigla ZivMediatG), entrata in vigore nel 2004 e tuttora vigente, che istituisce la figura del mediatore iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero federale della Giustizia. La mediazione è per definizione volontaria: nessuna norma impone alle parti di ricorrervi prima o durante il giudizio, e correlativamente non esiste alcun obbligo di partecipazione dell'avvocato al procedimento di mediazione. La partecipazione del difensore è dunque facoltativa; essa non è tuttavia sconsigliata, giacché la prassi austriaca valorizza l'assistenza tecnica del legale nella fase di redazione dell'accordo, tanto che la stessa ZivMediatG, al paragrafo 23, prevede che l'intesa raggiunta possa essere formalizzata per iscritto dalle parti stesse ovvero con l'assistenza di un avvocato e autenticata da un notaio.

Sotto il profilo delle materie, la mediazione civile austriaca copre l'intero spettro dei diritti disponibili, con una tradizionale prevalenza applicativa nel diritto di famiglia, nei rapporti di vicinato e nelle controversie commerciali. Non vi sono materie nelle quali la presenza dell'avvocato sia imposta a pena di improcedibilità, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti dell'area.

Quanto alla formazione, l'ordinamento austriaco distingue con nettezza la formazione del mediatore da quella dell'avvocato. La formazione del mediatore iscritto è regolata dalla ZivMediatG e dalla Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung (regolamento sulla formazione alla mediazione civile, in sigla ZivMediat-AV) e presuppone un percorso teorico-pratico articolato, l'iscrizione nell'elenco ministeriale e l'aggiornamento continuo. L'avvocato che intenda operare come mediatore deve dunque acquisire tale qualificazione ulteriore rispetto al titolo forense. Il Consiglio nazionale forense austriaco (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) e la rivista dell'avvocatura (Anwaltsblatt) documentano da tempo un'offerta formativa dedicata alla mediazione rivolta agli avvocati, segno di un interesse professionale consolidato.

Il punto di maggior rilievo deontologico riguarda la combinazione fra ruolo di difensore e ruolo di mediatore. La ZivMediatG afferma un principio di rigorosa incompatibilità funzionale: il mediatore non può rappresentare, assistere né decidere in ordine al conflitto oggetto della mediazione. La regola, letta in combinato con la disciplina professionale forense, comporta che l'avvocato il quale abbia agito come mediatore in una determinata controversia non possa poi assumere la difesa di alcuna delle parti in quella stessa vicenda; è invece consentito, a mediazione conclusa e con il consenso di tutti gli interessati, prestare assistenza per l'attuazione dell'accordo, nei limiti delle proprie ordinarie competenze professionali. L'avvocato può quindi essere anche mediatore, purché non cumuli le due funzioni nella medesima lite. A presidio della procedura, il paragrafo 20 ZivMediatG impone al mediatore un rigoroso obbligo di riservatezza su quanto appreso nel corso della mediazione, obbligo che si somma, per l'avvocato-mediatore, al segreto professionale forense.

Sul piano della prassi e dei dati salienti, l'esperienza austriaca si caratterizza per un modello di mediazione professionalizzata e certificata, con un elenco ministeriale che funge da garanzia di qualità, e per una partecipazione dell'avvocato concepita non in chiave antagonistica ma come apporto tecnico alla tenuta giuridica dell'accordo.

Fonti: Zivilrechts-Mediations-Gesetz, RIS — Bundeskanzleramt (<https://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer=20002753>); Ministero federale della Giustizia — Mediator:innen (<https://www.justiz.gv.at/service/streitschlichtung-und-mediation/mediator-innen.95b.de.html>); Anwaltsblatt — Mediationsausbildung (<https://www.anwaltsblatt.at/artikel/mediationsausbildung>); direttiva 2008/52/CE.

Belgio — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

Il Belgio dispone di una disciplina della mediazione collocata nella settima parte del Codice giudiziario (articoli 1723 e seguenti), profondamente rinnovata dalla legge del 18 giugno 2018, la quale ha inciso in modo significativo tanto sul procedimento quanto sui doveri dell'avvocato. La partecipazione del difensore alla mediazione è facoltativa e, nella prassi delle mediazioni civili e commerciali, largamente diffusa: il legale assiste il cliente lungo l'intero procedimento, contribuendo a esporre con chiarezza le posizioni, a valutare i punti di forza e di debolezza delle rispettive pretese, a individuare gli interessi sottostanti e a costruire una soluzione entro la cornice fissata dal mediatore. Nella mediazione familiare la presenza del legale segue prassi in parte differenti, essendo più marcato il ruolo diretto delle parti.

La riforma del 2018 ha introdotto un dovere deontologico e legale di rilievo primario: l'avvocato è tenuto a un duplice obbligo di informazione e di promozione dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti (in francese *modes amiables de résolution des conflits*). Egli deve informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione, alla conciliazione e agli altri metodi amichevoli e, ove ritenga che una composizione amichevole sia possibile, deve adoperarsi per promuoverla nella misura del possibile. Si tratta di un obbligo che colloca la cultura della composizione amichevole tra i doveri professionali del difensore belga.

Quanto all'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, la legge del 2018 non introduce una mediazione preventiva generalizzata, ma attribuisce al giudice il potere di ordinare la mediazione quando ritenga possibile un riavvicinamento delle parti, purché non tutte vi si oppongano; qualora la mediazione sia disposta nonostante l'opposizione di una parte,

quest'ultima risulta tenuta a partecipare almeno al primo incontro. La materia interessata è quella generale delle controversie su diritti disponibili, con particolare rilievo delle liti familiari, commerciali e di vicinato.

Sotto il profilo della qualificazione, il sistema belga è imperniato sulla Commission fédérale de médiation (Commissione federale di mediazione), organo che accredita i mediatori, approva i programmi di formazione e adotta il codice di condotta del mediatore. L'avvocato che voglia operare come mediatore deve conseguire l'accreditamento e seguire la formazione prevista, distinta dal titolo forense. Gli ordini forensi belgi (Ordre des barreaux francophones et germanophone e Orde van Vlaamse Balies) offrono percorsi formativi dedicati e trattano la materia nei propri strumenti deontologici.

Il rapporto fra le due funzioni è retto dal principio di incompatibilità: l'avvocato che abbia operato come mediatore non può successivamente assumere la difesa di una delle parti nella medesima controversia, e sul mediatore grava un rigoroso dovere di riservatezza, che per l'avvocato-mediatore si cumula con il segreto professionale. L'avvocato è inoltre chiamato, quando assiste una parte in mediazione, a garantire il rispetto della natura riservata del procedimento.

Sul piano della prassi, la riforma del 2018 ha rafforzato la posizione istituzionale della mediazione e ha reso il difensore un attore attivo della sua promozione, superando la tradizionale contrapposizione fra logica contenziosa e logica compositiva.

Fonti: Avocats.be — L'avocat et les modes alternatifs de résolution des conflits (<https://avocats.be/sites/avocatsbe/files/uploads/pictures/CHAP21.pdf>); SPF Justice — La médiation, une alternative au tribunal (https://justice.belgium.be/sites/default/files/la_mediation.pdf); Cours et tribunaux — La médiation (<https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/procedures-dans-les-tribunaux/mediation>); direttiva 2008/52/CE.

Bulgaria — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La mediazione bulgara è retta dalla Zakon za mediatsiyata (legge sulla mediazione) del 2004, oggetto di una rilevante riforma pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 11 del 2 febbraio 2023 ed entrata in vigore, quanto alle disposizioni sulla mediazione nelle cause pendenti, il 1° luglio 2024. La mediazione è definita procedura volontaria e riservata di composizione stragiudiziale delle controversie, nella quale un terzo, il mediatore, assiste le parti nella ricerca di un accordo. La partecipazione dell'avvocato è facoltativa: nella procedura possono intervenire avvocati e altri specialisti, e la presenza del difensore è considerata garanzia di corretta considerazione dei profili giuridici della lite e di adeguata formulazione dell'accordo finale.

La riforma del 2023-2024 non ha introdotto una vera mediazione obbligatoria intesa come condizione di procedibilità del futuro giudizio, bensì un obbligo di partecipazione a un primo incontro informativo di mediazione in dodici categorie di controversie. Le spese di tale incontro sono poste a carico del bilancio del tribunale ed è prevista la restituzione del settantacinque per cento della tassa statale in caso di raggiungimento dell'accordo. Il modello bulgaro si iscrive dunque nella tendenza europea alla cosiddetta obbligatorietà attenuata, limitata al primo incontro, con un incentivo economico alla composizione. Le materie interessate sono individuate dalla legge e comprendono controversie civili, commerciali, di consumo e familiari.

Un dato di rilievo introdotto dalla riforma riguarda la mediazione nelle cause pendenti, che si svolge presso appositi centri istituiti presso i tribunali distrettuali: mediatori nelle cause pendenti possono essere soltanto giuristi e soltanto mediatori accreditati presso i centri giudiziari. In questo specifico settore, quindi, la qualificazione giuridica del mediatore diviene requisito legale, circostanza che avvicina la funzione mediativa a quella tipicamente forense e che apre agli avvocati uno spazio operativo privilegiato.

Sotto il profilo della formazione, il mediatore bulgaro deve seguire un percorso formativo accreditato dal Ministero della Giustizia ed essere iscritto nell'apposito registro unico dei mediatori. L'avvocatura bulgara ha strutturato un'offerta dedicata: il Centro di formazione degli avvocati Krastyu Tsonchev organizza corsi di mediazione rivolti agli iscritti, a conferma dell'attenzione dell'ordine forense verso questa competenza.

Quanto al rapporto fra i due ruoli, l'avvocato può conseguire la qualifica di mediatore e operare come tale; vige tuttavia il principio di incompatibilità funzionale che impedisce di assistere una parte nella controversia in cui si sia agito come mediatore, oltre al dovere di riservatezza tipico della procedura. La dottrina professionale bulgara sottolinea come, per l'avvocato, la mediazione costituisca uno degli strumenti a disposizione per assicurare al cliente il risultato migliore e più sicuro.

Fonti: Zakon za mediatsiyata — Ministero della Giustizia (<https://www.justice.government.bg/home/normdoc/2135496713>); Mediation.bg — Il ruolo degli avvocati (<https://www.mediation.bg/mediation/lawyers-role>); Modifiche alla legge sulla mediazione, DV n. 11/2023 (<https://bgmediation.com/promenite-v-zakona-za-mediatsiyata-obnarodvani-v-dv-br-11-ot-2-fevruari-2023-g-v-sila-ot-1-yuli-2024-g-novata-glava-shesta-mediatsiya-po-visyashti-sadebni-dela/>); direttiva 2008/52/CE.

Croazia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La Croazia disciplina la mediazione con lo Zakon o mirenju (legge sulla conciliazione), la cui versione vigente è entrata pienamente in vigore con l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e regola la conciliazione nelle controversie civili, commerciali, di lavoro e in altre liti. La conciliazione (in croato mirenje) è definita come qualsiasi procedimento, quale che ne sia la denominazione, nel quale le parti cercano di comporre consensualmente la controversia con l'ausilio di uno o più conciliatori che le aiutano a raggiungere un accordo, senza il potere di imporre una soluzione vincolante.

La partecipazione dell'avvocato è facoltativa ma fortemente valorizzata dalla stessa avvocatura: la Hrvatska odvjetnička komora (Camera degli avvocati croata) ha istituito un proprio Centro di mediazione e promuove tra gli iscritti la conoscenza e l'impiego della mediazione, nella consapevolezza che le parti le quali scelgano questa via necessitano di regola dell'assistenza e del sostegno di un procuratore-avvocato. Le materie sono quelle indicate dalla legge; una previsione peculiare riguarda l'obbligo di tentare la conciliazione limitatamente ai procedimenti di risarcimento del danno, dai quali sono esclusi i procedimenti risarcitori derivanti dal rapporto di lavoro. Al di fuori di tale ambito la mediazione resta volontaria.

Sul piano della qualificazione, la formazione del conciliatore è affidata a enti accreditati, tra i quali assume rilievo proprio il Centro di mediazione della Camera degli avvocati, che organizza corsi per i legali interessati a operare come conciliatori. Esiste dunque una formazione forense

dedicata alla materia, e l'ordine forense croato figura tra i principali promotori della cultura conciliativa.

Il coordinamento fra la funzione di difensore e quella di conciliatore è retto dal principio di incompatibilità espresso dalla stessa legge: l'avvocato che abbia partecipato come conciliatore non può rappresentare alcuna delle parti nella controversia. L'avvocato può quindi assumere la veste di conciliatore, ma non cumulare in una stessa lite i due ruoli, a garanzia della terzietà e della riservatezza del procedimento. Il codice deontologico forense croato e le regole del Centro di mediazione della Camera degli avvocati inquadrano l'attività del legale-conciliatore entro i doveri di indipendenza e segretezza propri della professione.

Quanto ai dati salienti, l'esperienza croata mostra un ruolo trainante dell'avvocatura organizzata nella diffusione della mediazione, con un centro dedicato interno all'ordine e una legislazione che, pur mantenendo la regola della volontarietà, individua nel contenzioso risarcitorio un'area di conciliazione preventiva. È in discussione, inoltre, un disegno di legge sulla composizione amichevole delle controversie destinato a rinnovare la cornice normativa.

Fonti: Zakon o mirenju — Narodne novine 163/2003 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_163_2344.html); Centro di mediazione — Camera degli avvocati croata (<https://www.hok-cba.hr/centar-za-medijaciju/>); Vodič kroz mirenje — Sudovi RH (<https://sudovi.hr/sites/default/files/dokumenti/2020-09/Vodi%C4%8D%20kroz%20mirenje.pdf>); direttiva 2008/52/CE.

Danimarca — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La Danimarca conosce due modelli distinti ma complementari: la retsmægling, ossia la mediazione giudiziale collegata al processo civile, e la mediation privata di matrice convenzionale. La retsmægling, sperimentata dal 1° marzo 2003 e resa istituto stabile con la legge n. 168 del 2008, che ne ha esteso l'applicazione a tutti i tribunali distrettuali e alle corti d'appello a decorrere dal 1° aprile 2008, è disciplinata dalla legge processuale civile (retsplejeloven) ed è definita come assistenza alle parti di una causa civile pendente per raggiungere una soluzione concordata con l'aiuto di un mediatore designato dal giudice.

La partecipazione dell'avvocato è facoltativa ma consueta: nella prassi ciascuna parte è di regola accompagnata dal proprio avvocato, che le fornisce consiglio e orientamento durante il procedimento. La cultura danese assegna al difensore in mediazione un ruolo caratteristico, quello di consulente della parte più che di suo portavoce, con l'effetto di ridimensionare la contrapposizione frontale delle pretese e di ampliare lo spazio della ricerca di soluzioni condivise. La rivista dell'avvocatura danese (Advokaten) ha dedicato al tema riflessioni ricorrenti, valorizzando la figura dell'avvocato realmente idoneo alla mediazione. Le materie interessate sono quelle delle controversie civili portate dinanzi ai tribunali; la retsmægling non è configurata come condizione di procedibilità, restando rimessa all'adesione delle parti.

Un tratto distintivo del modello danese è la composizione del corpo dei mediatori giudiziali: il retsmægler ha ricevuto una formazione specifica e può essere un giudice ovvero un avvocato appositamente designato. In questo senso l'avvocato non è soltanto assistente della parte, ma può egli stesso rivestire il ruolo di mediatore giudiziale, previa formazione dedicata. Il ruolo del mediatore si colloca nella tensione tra mediazione valutativa e mediazione facilitativa, con la

prima che presuppone parti desiderose di indicazioni su una soluzione appropriata alla luce del diritto, della prassi e degli usi.

La formazione forense in materia è strutturata: l'Advokatsamfundet (Consiglio dell'avvocatura danese) e l'associazione Danske Advokater offrono un percorso di mediatore certificato che unisce teoria e addestramento intensivo, abilitando il professionista a condurre mediazioni private e a operare nella retsmægling.

Quanto al coordinamento fra i ruoli, l'avvocato-mediatore è tenuto all'imparzialità e alla riservatezza e non può assistere una parte nella controversia in cui abbia mediato; l'attività di mediazione è riconosciuta come articolazione dell'esercizio professionale e resta assoggettata ai doveri deontologici forensi. Sul piano dei dati, la retsmægling ha conosciuto una progressiva istituzionalizzazione dal 2003 al 2008 e rappresenta oggi un canale ordinario di composizione delle liti civili, con l'avvocatura protagonista sia come difensore sia come mediatore.

Fonti: Advokatsamfundet — Mediation
(<https://www.advokatsamfundet.dk/din-advokat/maegling-og-konfliktlosning/mediation/>);
Danske Advokater — Mediatoruddannelsen
(<https://www.danskeadvokater.dk/mediatoruddannelsen>); Advokaten — Retsmægling er for
rigtige parter og rigtige advokater
(<https://www.advokatsamfundet.dk/nyheder-medier/tidligere-artikler/2013/advokaten-3/2013-retsmaegling/>); direttiva 2008/52/CE.

Finlandia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

L'ordinamento finlandese distingue con nettezza due canali: la tuomioistuinsovittelu, ossia la mediazione presso il tribunale, e l'asianajajasovittelu, la mediazione condotta dagli avvocati sotto l'egida dell'ordine forense. La mediazione presso il tribunale è disciplinata dalla legge sulla mediazione delle controversie civili e sull'omologazione delle transazioni presso i tribunali ordinari (laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa, n. 394/2011) e vede il giudice del tribunale di primo grado (käräjätuomari) designato quale mediatore. La mediazione è un procedimento alternativo al processo, fondato sulla volontarietà e apprezzato per flessibilità, rapidità e possibilità delle parti di incidere sull'esito.

La partecipazione dell'avvocato è facoltativa. Nella mediazione, il mediatore e gli eventuali procuratori delle parti collaborano ad aiutare i litiganti nella ricerca di un'intesa: il mediatore non decide chi abbia ragione né emette una decisione, ma sostiene le parti nel raggiungimento di una composizione. Il difensore, quando presente, opera dunque in chiave collaborativa. Le materie interessate sono quelle delle controversie civili e commerciali su diritti disponibili; non è prevista una mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.

Il tratto più significativo per la professione forense è l'asianajajasovittelu, la mediazione dell'ordine degli avvocati (Suomen Asianajajaliitto). Può operare come mediatore in questo ambito soltanto l'avvocato ammesso nell'apposito elenco dei mediatori tenuto dall'ordine, iscrizione subordinata al superamento della formazione alla mediazione organizzata dall'ordine stesso. Esiste quindi una formazione forense dedicata, strutturata e selettiva, che sfocia in un elenco ufficiale. Il vantaggio dell'asianajajasovittelu rispetto alla mediazione presso il tribunale è individuato dalla stessa avvocatura nella riservatezza e nella confidenzialità

assoluta del procedimento, dato che la notizia della controversia e della mediazione non è destinata a divenire nota ad altri se non al mediatore.

Sul piano deontologico, l'avvocato-mediatore è un esperto indipendente delle trattative conciliative; egli non risolve la lite ma aiuta le parti a trovare la soluzione, ed è soggetto ai doveri di indipendenza, imparzialità e riservatezza propri della professione forense, integrati dai codici di condotta dell'ordine. Ne discende l'incompatibilità fra la funzione di mediatore in una data controversia e quella di difensore di una delle parti nella medesima lite. L'avvocato può quindi essere anche mediatore, in un sistema che l'ordine ha istituzionalizzato attraverso un proprio servizio di mediazione.

Quanto ai dati salienti, la Finlandia offre un modello duale nel quale la mediazione giudiziale affidata ai giudici convive con una mediazione forense autonoma, gestita dall'avvocatura e imperniata sulla riservatezza, con un elenco ufficiale di avvocati-mediatori quale strumento di garanzia della qualità.

Fonti: Suomen Asianajajat — Asianajajasovittelu
(<https://asianajajat.fi/oikeudellinen-apu/miksi-valita-asianajaja/asianajajasovittelu/>); laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 394/2011;
Suomen Asianajajat — Oikeussanasto
(<https://asianajajat.fi/oikeudellinen-apu/oikeussanasto/>); direttiva 2008/52/CE.

Francia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La Francia conosce una disciplina articolata della mediazione, che affianca alla mediazione convenzionale una serie di ipotesi di tentativo preventivo obbligatorio. Il fondamento del ricorso amichevole preventivo si rinviene nell'articolo 4 della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016, cosiddetta legge J21, integrato dal decreto n. 2018-101 del 16 febbraio 2018 e, oggi, dall'articolo 750-1 del codice di procedura civile, il quale impone, a pena di irricevibilità, un preventivo tentativo di conciliazione, mediazione o procedura partecipativa per le controversie di valore non superiore a cinquemila euro e per taluni conflitti di vicinato. In materia familiare, per le domande relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, l'articolo 373-2-10 del codice civile e la sperimentazione del tentativo di mediazione familiare preventivo obbligatorio (in francese tentative de médiation familiale préalable obligatoire) hanno introdotto un passaggio conciliativo salvo giustificati motivi di esenzione, quali l'urgenza, lo stato di salute, l'età avanzata o la particolare vulnerabilità, la distanza geografica rilevante o l'impossibilità materiale di partecipare.

In questo quadro la partecipazione dell'avvocato è facoltativa quanto alla presenza in seduta, ma il difensore è protagonista della fase informativa e della verifica del rispetto della condizione di procedibilità. La cultura professionale francese, promossa dal Conseil national des barreaux (CNB), valorizza l'avvocato, in specie se formato alla mediazione, quale figura idonea ad accompagnare le parti nell'attuazione del percorso amichevole. Le materie interessate spaziano dalle piccole controversie civili ai conflitti di vicinato, dalla materia familiare a quella commerciale e amministrativa.

Sul terreno della combinazione fra i ruoli, il diritto francese afferma la compatibilità di principio: la professione di avvocato è compatibile con le funzioni di mediatore ai sensi dell'articolo 115 del decreto del 27 novembre 1991. L'avvocato può quindi essere investito di una

missione di mediatore, come riconosce il Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN, regolamento interno nazionale della professione forense), che annovera fra gli incarichi assumibili quello di médiateur accanto a quelli di arbitro, esperto e mandatario. Resta ferma l'incompatibilità funzionale che impedisce al mediatore di divenire difensore di una parte nella controversia mediata, a presidio della terzietà e del segreto.

Un episodio significativo di diritto professionale riguarda i limiti del potere regolamentare del CNB: con decisione del 25 ottobre 2018 il Conseil d'État ha annullato le disposizioni del RIN che vietavano all'avvocato non referenziato presso il Centre national de médiation des avocats (CNMA) di avvalersi verso la clientela della qualità di mediatore, ritenendo che il CNB non fosse competente a fissare tale prescrizione limitativa della libertà di esercizio. La pronuncia conferma che la qualità di avvocato-mediatore non è subordinata all'iscrizione al CNMA, pur restando quest'ultimo il riferimento per l'accreditamento e la formazione. Per l'iscrizione al CNMA è richiesto un percorso formativo di duecento ore, ridotto a centoquaranta ore per chi possa giustificare un'esperienza pratica nella mediazione. Esiste dunque una formazione forense dedicata, strutturata e certificata.

Quanto ai dati salienti, la Francia rappresenta l'ordinamento europeo che più ha spinto sul tentativo preventivo obbligatorio a pena di irricevibilità, con un ruolo dell'avvocato duplice: da un lato garante processuale del rispetto della condizione di procedibilità, dall'altro possibile mediatore accreditato entro un sistema deontologico presidiato dal CNB e dal Conseil d'État.

Fonti: Règlement intérieur national de la profession d'avocat — CNB (<https://cnb.avocat.fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-d-avocat-rin>); Décret n. 2023-357 du 11 mai 2023 — Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047537847>); CNB — La médiation: expériences, évaluations et perspectives (<https://www.cnb.avocat.fr/fr/la-mediation-experiences-evaluations-et-perspectives>); direttiva 2008/52/CE.

Germania — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La Germania disciplina la mediazione con la Mediationsgesetz (legge sulla mediazione, in sigla MediationsG), entrata in vigore il 26 luglio 2012 in attuazione della direttiva 2008/52/CE. La mediazione è un procedimento volontario e la partecipazione dell'avvocato è facoltativa: nessuna norma impone il ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità né la presenza obbligatoria del difensore. La materia coperta è quella generale delle controversie civili e commerciali, con ampia applicazione in ambito familiare, del lavoro, societario e commerciale.

Il tratto peculiare dell'ordinamento tedesco è la piena integrazione della mediazione nell'attività forense. La mediazione è riconosciuta come forma dell'esercizio professionale dell'avvocato: il paragrafo 18 della Berufsordnung für Rechtsanwälte (codice deontologico forense, in sigla BORA) stabilisce che l'avvocato il quale operi come mediatore resta soggetto alle regole del diritto professionale forense, e in particolare all'obbligo di riservatezza previsto dal paragrafo 2 BORA. Ne consegue che l'avvocato-mediatore (Anwaltsmediator) cumula i doveri deontologici della professione con quelli propri del mediatore. Il codice deontologico prevede inoltre, al paragrafo 7a BORA, che l'avvocato possa qualificarsi come mediatore soltanto se ha effettivamente seguito una formazione adeguata, ponendo così un obbligo specifico a tutela della clientela.

Quanto alla combinazione fra i ruoli, il diritto tedesco è particolarmente rigoroso sul divieto di doppio patrocinio. La stessa MediationsG (paragrafi 3 e 4) e la disciplina penale del tradimento della parte (Parteiverrat, paragrafo 356 del codice penale) impongono al mediatore l'astensione dall'agire, nella medesima vicenda o in una connessa, come difensore di una delle parti; il mediatore che abbia in precedenza trattato la questione in altra funzione non può assumere l'incarico di mediazione, e viceversa. L'avvocato può dunque essere anche mediatore, ma le due funzioni non possono sovrapporsi sulla stessa lite, a pena di conseguenze professionali e, nei casi più gravi, penali.

Sul piano della formazione, la Germania ha introdotto la figura del mediatore certificato (zertifizierter Mediator) e ne ha regolato il percorso con la Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (regolamento sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori certificati, in sigla ZMediatAusbV). A seguito della riforma in vigore dal 1° marzo 2024, la formazione richiede almeno centotrenta ore di insegnamento in presenza, con possibilità di svolgere in forma virtuale fino al quaranta per cento delle ore, oltre allo svolgimento di almeno cinque mediazioni supervisionate, da riflettere in supervisione entro tre anni dal completamento del corso prima di potersi fregiare del titolo. L'aggiornamento continuo richiede almeno quaranta ore ogni quattro anni, pena la perdita del diritto a usare la denominazione. Numerosi ordini forensi e istituti di formazione dell'avvocatura offrono percorsi dedicati agli avvocati.

Quanto ai dati salienti, il modello tedesco si segnala per l'integrazione della mediazione nella deontologia forense, per il rigore del divieto di doppio patrocinio e per un sistema di certificazione del mediatore rafforzato dalla riforma del 2024.

Fonti: Mediationsgesetz — <https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/>; ZMediatAusbV — <https://www.gesetze-im-internet.de/zmediatausbv/BJNR199400016.html>; BMJ — Mediation (https://www.bmjv.de/DE/themen/wege_zum_recht/mediation/mediation_node.html); direttiva 2008/52/CE.

Grecia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La Grecia ha ridisegnato la propria disciplina della mediazione con la legge n. 4640/2019 (pubblicata nel FEK 190/A del 30 novembre 2019), che ha recepito in modo aggiornato la direttiva 2008/52/CE e ha introdotto l'istituto della sessione informativa iniziale obbligatoria (in greco Ypochreotiki Archiki Synedria, in sigla YAS). Si tratta del profilo che più distingue l'ordinamento ellenico: in determinate categorie di controversie di natura civile, commerciale e familiare, a pena di improcedibilità della discussione della domanda, le parti unitamente ai propri avvocati e al mediatore devono partecipare a una sessione informativa sull'istituto della mediazione.

In questo quadro la partecipazione dell'avvocato non è soltanto opportuna, ma obbligatoria: alla sessione iniziale obbligatoria le parti si presentano insieme a un difensore-assistente (in greco nomikos parastatis), la cui remunerazione è liberamente concordata. Solo in via eccezionale, in forza di procura, è ammessa la sola partecipazione del difensore in luogo della parte, segnatamente quando la presenza fisica non sia possibile per grave malattia o perché la parte risiede all'estero. La Grecia rappresenta quindi, insieme all'Italia, uno degli ordinamenti europei nei quali l'assistenza legale in mediazione assume carattere obbligatorio nelle materie

individuata dalla legge. La sessione iniziale obbligatoria deve svolgersi al più tardi entro venti giorni dal giorno successivo all'invio al mediatore della richiesta di ricorso a opera della parte più diligente.

Le materie interessate dall'obbligatorietà comprendono, tra le altre, le controversie familiari (con talune esclusioni), le liti su diritti reali su immobili, le controversie commerciali e quelle relative a rapporti bancari e finanziari, oltre alle liti di valore superiore a determinate soglie. Al di fuori di tali ambiti la mediazione resta volontaria.

Sul piano della formazione, il mediatore greco deve conseguire l'accreditamento e superare la formazione presso enti riconosciuti dalla Commissione centrale per la mediazione del Ministero della Giustizia; numerosi centri di formazione sono espressione dell'avvocatura. La professione forense è profondamente coinvolta, come attestano le comunicazioni dell'Ordine degli avvocati di Atene (Dikigorikos Syllogos Athinon) sull'attuazione della legge n. 4640/2019.

Quanto al coordinamento fra i ruoli, l'avvocato può conseguire l'accreditamento come mediatore, ma non può cumulare la funzione di mediatore e quella di difensore nella medesima controversia, restando fermi i doveri di imparzialità e riservatezza. Il rapporto è dunque duplice: l'avvocato è al tempo stesso assistente necessario della parte nella sessione obbligatoria e possibile mediatore accreditato in altre vicende.

Quanto ai dati salienti, la Grecia si segnala per il carattere obbligatorio della sessione informativa iniziale con presenza necessaria del difensore, elemento che ha imposto all'avvocatura un ruolo strutturale nel funzionamento del sistema di mediazione.

Fonti: Nomos 4640/2019 — Lawspot (<https://www.lawspot.gr/nomothesia/nomos-4640-2019/>); Articolo 7, legge 4640/2019 — Procedura della sessione iniziale obbligatoria (<https://www.lawspot.gr/nomothesia/n-4640-2019/arthro-7-nomos-4640-2019-diadikasia-tis-ypohreotikis/>); Dikigorikos Syllogos Athinon — comunicazione sulla legge 4640/2019 (<https://www.dsa.gr/>); direttiva 2008/52/CE.

Irlanda — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

L'Irlanda ha organizzato la materia con il Mediation Act 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, che disciplina la mediazione nelle controversie civili e assegna al solicitor un ruolo di primo piano nella fase antecedente al giudizio. La mediazione è volontaria e la partecipazione delle parti resta rimessa alla loro adesione; è invece obbligatorio, per il legale, un preciso dovere informativo. La sezione 14 del Mediation Act 2017 impone infatti al solicitor, prima di intraprendere il giudizio (in inglese prior to issuing proceedings), di consigliare al cliente di considerare la mediazione quale mezzo per tentare di comporre la controversia, di fornirgli informazioni sui servizi di mediazione, inclusi nomi e indirizzi dei mediatori, e di informarlo dei profili relativi alla riservatezza (sezione 10), all'efficacia esecutiva dell'accordo (sezione 11) e agli obblighi procedurali connessi.

Il dato di maggior rilievo è la sanzione processuale collegata a tale dovere: ai sensi della sezione 14, comma 2, l'atto introduttivo del giudizio deve essere accompagnato da una dichiarazione solenne (statutory declaration) resa dal solicitor, attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi. In difetto, il giudice è tenuto, a norma della sezione 14, comma 3, a rinviare il procedimento, con possibilità che la causa sia sospesa o dichiarata improcedibile e con

rilevanti conseguenze sulle spese, non solo per l'attore ma anche per il suo legale. Ne discende che, pur restando facoltativa la partecipazione alla mediazione, è obbligatoria l'attività informativa e attestativa del difensore, che diviene un vero e proprio filtro all'accesso alla giurisdizione.

Le materie interessate sono quelle delle controversie civili in genere, con talune esclusioni previste dalla stessa legge. La partecipazione dell'avvocato alla seduta di mediazione, quando la parte vi acconsenta, è ammessa e frequente, in funzione di consiglio e assistenza tecnica.

Sul piano della formazione e della deontologia, la Law Society of Ireland svolge un ruolo centrale: essa promuove l'adempimento degli obblighi della sezione 14 mediante practice notes e mette a disposizione i modelli della lettera di consiglio e della dichiarazione solenne. La Law Society tratta inoltre la mediazione nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie e sostiene la formazione dei solicitor interessati a operare come mediatori.

Quanto alla combinazione fra i ruoli, il solicitor può conseguire la qualifica di mediatore e operare come tale; anche in Irlanda vige l'incompatibilità funzionale che impedisce di cumulare, nella stessa controversia, la posizione di mediatore imparziale e quella di difensore di una parte, oltre ai doveri di riservatezza propri del procedimento. Quanto ai dati salienti, l'esperienza irlandese si segnala per un modello nel quale la spinta alla mediazione non passa attraverso l'obbligatorietà del procedimento, bensì attraverso un rigoroso obbligo informativo del difensore assistito da sanzione processuale, con la Law Society quale garante operativo dell'adempimento.

Fonti: Mediation Act 2017 — Revised Acts, Law Reform Commission (<https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2017/act/27/revised/en/html>); Law Society of Ireland — Section 14, obbligo del solicitor (<https://www.lawsociety.ie/Solicitors/knowledge-base/Practice-Notes/mediation-act-2017—section-14-obligation-of-solicitors-to-advise-clients-on-mediation-before-instituting-proceedings/>); Law Society of Ireland — Mediation (<https://www.lawsociety.ie/Solicitors/knowledge-base/practice-areas/alternative-dispute-resolution/mediation/>); direttiva 2008/52/CE.

Volume II — L'avvocato negoziatore

Schede-Paese sul ruolo dell'avvocato in mediazione (secondo gruppo)

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Malta — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

L'ordinamento maltese disciplina la mediazione con il Mediation Act, Chapter 474 delle Leggi di Malta, entrato in vigore il 21 dicembre 2004 e successivamente adeguato alla direttiva 2008/52/CE. La legge istituisce il Malta Mediation Centre, ente pubblico incaricato di tenere il registro dei mediatori accreditati e di offrire i propri locali per lo svolgimento delle procedure. Il quadro di riferimento resta improntato al principio di volontarietà: la mediazione è una scelta rimessa alle parti, sia nella forma della mediazione convenzionale sia in quella promossa dal giudice nel corso del giudizio.

Quanto alla partecipazione dell'avvocato, essa è facoltativa e mai obbligatoria. La sezione dedicata allo svolgimento del procedimento prevede che le parti possano farsi assistere da un advocate, da un legal procurator o da qualsiasi altra persona da esse designata, prima o durante la mediazione. La formulazione «may be assisted by an advocate, legal procurator or any person designated by them» (possono essere assistite da un avvocato, da un procuratore legale o da qualsiasi persona da esse designata) chiarisce che la presenza del difensore è una possibilità e non un onere di procedibilità. Non risulta, per contro, una materia in cui l'assistenza tecnica sia imposta dalla legge come condizione dell'accesso alla mediazione.

Un tratto qualificante del modello maltese riguarda il rapporto tra ruolo di mediatore e prestazione di consulenza legale. Il Malta Mediation Centre precisa che il mediatore non ha né il diritto né il dovere di fornire consulenza giuridica alle parti, anche qualora egli sia un avvocato, e che le parti restano libere di rivolgersi al proprio legale di fiducia per ottenere pareri sul merito. Ne discende una netta distinzione funzionale: chi conduce la mediazione non assiste, e chi assiste non conduce. L'avvocato-mediatore, pur ammesso al registro, deve dismettere ogni funzione di patrocinio nella medesima procedura, per non compromettere l'imparzialità che la legge gli impone.

Sul versante della formazione, l'accreditamento dei mediatori presso il Centre richiede il possesso di requisiti di competenza e la partecipazione a percorsi formativi specifici; molti mediatori iscritti provengono dall'avvocatura, sicché la formazione forense e quella del mediatore tendono a integrarsi. Non risulta, allo stato, un obbligo formativo dedicato all'avvocato quale mero assistente della parte in mediazione, distinto dalla formazione del mediatore.

Quanto agli obblighi deontologici, l'avvocato maltese resta soggetto ai doveri generali di correttezza, riservatezza e diligenza propri della professione; la disciplina di settore non introduce sanzioni deontologiche specifiche per la condotta tenuta in mediazione, ma il dovere di riservatezza sancito dal Mediation Act si estende a tutti i partecipanti, difensori compresi. Nella prassi, la dimensione ridotta della giurisdizione e il ruolo centralizzante del Malta Mediation Centre favoriscono un utilizzo della mediazione soprattutto in materia civile e commerciale e nelle controversie familiari, con volumi contenuti ma in progressiva crescita.

Fonti: Mediation Act, Chapter 474 — legislation.mt/eli/cap/474/eng (<https://legislation.mt/eli/cap/474/eng/>); Malta Mediation Centre — [mediation.mt](https://mediation.mt/en/faqs/) (<https://mediation.mt/en/faqs/>); Ministry for Justice — [justice.gov.mt](https://justice.gov.mt/en/mmc/Pages/Mediation-Act.aspx) (<https://justice.gov.mt/en/mmc/Pages/Mediation-Act.aspx>); direttiva 2008/52/CE — [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Paesi Bassi — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

Nei Paesi Bassi la mediazione si è affermata come istituto ampiamente volontario e di matrice essenzialmente autoregolata, in coerenza con la tradizione olandese di soluzione consensuale dei conflitti. Il perno del sistema è la Mediatorsfederatie Nederland (MfN), che tiene il registro di qualità dei mediatori, il MfN-register, e definisce il regolamento di mediazione e le regole di condotta cui il mediatore iscritto è vincolato. Accanto alla mediazione privata opera la mediazione collegata alla giurisdizione, la cosiddetta mediation naast rechtspraak, nell'ambito della quale il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un mediatore.

La partecipazione dell'avvocato è facoltativa. Nella mediazione olandese le parti compaiono di regola personalmente, potendo tuttavia farsi assistere dal proprio legale. La presenza del difensore diviene di fatto necessaria quando l'esito della mediazione debba tradursi in atti da depositare in giudizio: nel divorzio, in particolare, il deposito della domanda presso il tribunale deve essere effettuato da un advocate, sicché la mediazione familiare si intreccia frequentemente con l'attività forense di formalizzazione dell'accordo.

Il rapporto tra ruolo di avvocato e ruolo di mediatore è oggetto di una disciplina deontologica articolata. L'avvocato è soggetto alle regole della Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Poiché la NOvA non ha adottato un corpo di regole apposito per l'attività di mediatore, l'associazione degli avvocati di famiglia e mediatori, la vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators), si è dotata di proprie gedragsregels, regole di condotta che l'avvocato-mediatore associato deve osservare nel corso della mediazione. Il mediatore iscritto al MfN-register è a sua volta tenuto ai principi fondamentali di indipendenza, neutralità e riservatezza fissati dalle MfN-gedragsregels. Emerge così una duplice trama normativa: l'avvocato che agisce come difensore risponde alle regole dell'Ordine, mentre l'avvocato che assume la veste di mediatore deve conformarsi alle regole del registro e a quelle dell'associazione di categoria, con l'intesa che le due funzioni non possono cumularsi nella medesima procedura senza compromettere l'imparzialità.

La formazione forense dedicata è sviluppata. Esistono percorsi strutturati per il legal mediator e lo specialista ADR, offerti da enti di formazione riconosciuti, e il tirocinio forense contempla moduli sulla mediazione. Molti avvocati acquisiscono la qualifica di MfN-registermediator affiancandola alla professione, il che ha reso l'avvocatura una componente rilevante del corpo dei mediatori registrati.

Sul piano deontologico, l'avvocato che assiste la parte in mediazione resta soggetto ai doveri generali di riservatezza e correttezza; l'avvocato-mediatore è invece esposto al regime disciplinare del registro e a un sistema di reclami dedicato. Nella prassi, la mediazione olandese trova applicazione elettiva nelle controversie familiari e del lavoro, nonché in materia civile e commerciale, con una diffusione favorita dalla cultura del consenso e dal ruolo attivo della magistratura nell'orientare le parti verso la via consensuale.

Fonti: MfN-register, regolamento e gedragsregels — mfregister.nl (<https://mfregister.nl/mediators/regelgeving-en-documenten/>); Nederlandse Orde van Advocaten — [advocatenorde.nl](https://www.advocatenorde.nl/) (<https://www.advocatenorde.nl/>); vFAS, gedragsregels — [verenigingfas.nl](https://verenigingfas.nl/gedragsregels/) (<https://verenigingfas.nl/gedragsregels/>); direttiva 2008/52/CE — [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Polonia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

L'ordinamento polacco disciplina la mediazione civile agli articoli 183(1) e seguenti del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego, KPC), introdotti nel 2005 e più volte riformati, da ultimo con effetto dal 1 gennaio 2016. Il principio cardine è quello della volontarietà: l'articolo 183(1) stabilisce che la mediazione si svolge sulla base di un accordo di mediazione o di un provvedimento del giudice che vi rinvia le parti. Il giudice può disporre il rinvio in ogni fase del processo e il presidente o il referendario possono convocare le parti a una riunione informativa sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare la

mediazione. Non esiste, allo stato, una mediazione obbligatoria come condizione generale di procedibilità.

La partecipazione dell'avvocato, adwokat, o del consulente legale, radca prawny, è facoltativa. Le parti possono comparire personalmente o farsi assistere dal difensore. Il codice riserva tuttavia ai professionisti legali un ruolo tecnico qualificato nella fase di omologazione: nel procedimento diretto all'approvazione dell'accordo raggiunto in una mediazione fondata su accordo di mediazione, la domanda e gli atti successivi sono depositati, tra gli altri, dall'adwokat e dal radca prawny. L'accordo omologato dal giudice acquista efficacia esecutiva, e l'assistenza del difensore risulta in concreto preziosa nella redazione di un testo idoneo all'esecuzione.

Un incentivo di rilievo alla partecipazione consapevole discende dal regime della riservatezza: l'articolo 183(4) KPC impone al mediatore, alle parti e agli altri soggetti che prendono parte alla procedura l'obbligo di mantenere segreti i fatti appresi in connessione con la mediazione, e rende inefficace il richiamo, in sede giudiziale o arbitrale, alle proposte di accordo e alle reciproche concessioni formulate durante la mediazione. Il difensore è pertanto tenuto a rispettare tale segreto, che rafforza la funzione protettiva della negoziazione assistita.

La formazione forense dedicata è promossa dagli ordini professionali. La Naczelna Rada Adwokacka, il Consiglio nazionale forense, e le camere dei radcowie prawni hanno sviluppato programmi e centri di mediazione presso i quali gli avvocati possono qualificarsi come mediatori, e la stessa avvocatura ha pubblicato materiali illustrativi delle riforme del 2016. Il codice deontologico forense (Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu) non contiene un apparato sanzionatorio ad hoc per la condotta in mediazione, ma i doveri generali di lealtà, riservatezza e diligenza si estendono anche a tale ambito.

Quanto al rapporto tra avvocato e mediatore, l'avvocato può iscriversi negli elenchi di mediatori tenuti presso i tribunali circondariali, previa acquisizione della relativa competenza; l'esercizio della funzione di mediatore in un caso preclude l'assunzione del patrocinio di una parte nel medesimo affare, in ossequio ai doveri di imparzialità. Nella prassi, la mediazione polacca conosce diffusione crescente nelle controversie civili, commerciali, di lavoro e familiari, sostenuta dalla rete dei centri di mediazione promossi dalle professioni legali.

Fonti: Kodeks postępowania cywilnego, artt. 183(1)–183(15) — [arslege.pl](https://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s613/) (<https://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s613/>); Naczelna Rada Adwokacka, mediacja — adwokatura.pl (https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-mediacja-nowe-przepisy-od-stycznia-2016-kp-13941.pdf); direttiva 2008/52/CE — [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Portogallo — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

Il Portogallo dispone di una disciplina organica della mediazione, la Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, che fissa i principi generali applicabili alla mediazione svolta nel Paese e i regimi giuridici della mediazione civile e commerciale, del mediatore e dei sistemi pubblici di mediazione. Il modello portoghese si articola in una pluralità di sistemi pubblici, tra cui il Sistema de Mediação Familiar, il Sistema de Mediação Laboral e il Sistema de Mediação Penal, cui si affianca la mediazione operante presso i Julgados de Paz, i tribunali di pace istituiti con la Lei 78/2001, de 13 de julho, che hanno rappresentato la vera origine della mediazione portoghese.

La mediazione è definita come forma di risoluzione alternativa delle controversie mediante la quale due o più parti in lite cercano volontariamente di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore, terzo imparziale e indipendente privo di poteri impositivi. La partecipazione dell'avvocato è dunque facoltativa e coerente con il principio di volontarietà. Il guida informativa del Sistema de Mediação Familiar sottolinea che «o papel do advogado é muito importante, numa perspectiva de colaboração e cooperação, no sentido de ajudar as partes mediadas na superação das situações» (il ruolo dell'avvocato è molto importante, in una prospettiva di collaborazione e cooperazione, allo scopo di aiutare le parti mediate nel superamento delle situazioni). Emerge così una concezione collaborativa del difensore, chiamato ad accompagnare la parte senza sovrapporsi alla funzione del mediatore.

Non risulta, in linea generale, una materia in cui la partecipazione dell'avvocato alla mediazione sia imposta a pena di procedibilità; l'assistenza tecnica resta rimessa alla scelta della parte, con un ruolo di rilievo nella fase di redazione e verifica dell'accordo, la cui efficacia esecutiva è riconosciuta dalla legge al ricorrere dei presupposti stabiliti. Nei Julgados de Paz la mediazione precede spesso la fase decisoria e la presenza del difensore è ammessa ma non necessaria, in coerenza con la vocazione di prossimità e semplificazione di tali organi.

La formazione forense dedicata si innesta sul sistema di accreditamento dei mediatori: l'iscrizione nelle liste dei sistemi pubblici richiede il completamento di corsi di formazione riconosciuti dalla Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), e molti avvocati vi accedono affiancando la qualifica di mediatore alla professione forense. Sul piano deontologico, l'avvocato resta soggetto all'Estatuto da Ordem dos Advogados e ai doveri generali di riservatezza e correttezza; non risulta un corpo sanzionatorio specifico per la condotta in mediazione, fermo restando che l'avvocato che assuma la funzione di mediatore non può patrocinare una parte nel medesimo affare, per il vincolo di imparzialità imposto dalla Lei n.º 29/2013.

Nella prassi, la mediazione portoghese trova impiego elettivo nelle materie familiare, del lavoro e penale, oltre che nelle controversie civili e commerciali di competenza dei Julgados de Paz, con un ruolo di coordinamento affidato alla DGPJ.

Fonti: Lei n.º 29/2013, de 19 de abril — pgdlisboa.pt (https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1907&tabela=leis); DGPJ, Sistemas Públicos de Mediação — dgpj.justica.gov.pt (<https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao>); Ordem dos Advogados — ordemadvogados.pt (<https://portal.oa.pt/>); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Romania — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La mediazione romena è disciplinata dalla Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, che ha recepito i principi europei istituendo il Consiglio di mediazione (Consiliul de mediere) quale autorità di regolazione e accreditamento. Il tratto peculiare del sistema romeno è la vicenda della cosiddetta seduta informativa obbligatoria. Con la Legea nr. 115/2012 era stato introdotto l'obbligo, per talune materie, di partecipare a una seduta di informazione sui vantaggi della mediazione prima di adire il giudice, a pena di inammissibilità della domanda. Tale meccanismo è stato però dichiarato incostituzionale dalla Curtea Constituțională con la Decizia nr. 266 del 7 maggio 2014, pubblicata il 25 giugno 2014, per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il libero accesso alla giustizia. La

Corte ha rilevato che l'obbligo di partecipare alla seduta informativa, presidiato dalla sanzione di inammissibilità, non si limitava a restringere il diritto di azione, ma finiva per precluderne l'esercizio. Dalla data di pubblicazione della decisione la seduta informativa non è più obbligatoria e i giudici non possono più rigettare la domanda per il suo mancato esperimento.

Ne consegue che oggi la mediazione romena è a partecipazione volontaria e che, a fortiori, la partecipazione dell'avvocato è facoltativa. Il difensore, avocat iscritto all'Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), può assistere la parte nel corso della mediazione, ma la sua presenza non è mai imposta a pena di procedibilità. L'avvocato conserva un ruolo di rilievo nella verifica giuridica dell'accordo di mediazione e nella sua eventuale autenticazione o omologazione, atteso che l'accordo può acquistare efficacia esecutiva attraverso l'intervento del notaio o l'omologazione giudiziale.

Sul rapporto tra le funzioni, l'avvocato può conseguire l'accreditamento di mediatore presso il Consiliul de mediere, previo completamento del percorso formativo prescritto; l'esercizio della mediazione in un affare esclude tuttavia l'assunzione del patrocinio della parte nel medesimo, in ragione dell'imparzialità richiesta al mediatore. La legge professionale forense e lo statuto dell'avvocatura contemplano la mediazione tra le attività compatibili con la professione.

Quanto alla formazione, i corsi per mediatore sono organizzati da enti accreditati dal Consiglio di mediazione; molti avvocati vi partecipano, sicché la formazione forense e quella del mediatore risultano spesso integrate, pur restando distinte. Il Codice deontologico forense romeno impone i doveri generali di riservatezza, lealtà e diligenza, che si estendono alla condotta tenuta in mediazione, senza tuttavia prevedere un apparato sanzionatorio specifico per tale sede. Nella prassi, dopo la decisione della Corte costituzionale del 2014 il ricorso alla mediazione ha registrato una contrazione, restando diffuso soprattutto nelle controversie familiari, civili, commerciali e in materia di consumo, dove la libera scelta delle parti orienta il ricorso allo strumento.

Fonti: Legea nr. 192/2006 — legislatie.just.ro (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71928>); Curtea Constituțională, Decizia nr. 266/2014 — legislatie.just.ro (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159260>); Uniunea Națională a Barourilor din România — [unbr.ro](https://www.unbr.ro/) (<https://www.unbr.ro/>); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Slovacchia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

In Slovacchia la mediazione è disciplinata dallo Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii, la legge sulla mediazione, che regola le controversie derivanti da rapporti di diritto civile, familiare, commerciale e del lavoro. La legge configura la mediazione come attività professionale svolta da un mediatore iscritto nel registro tenuto dal Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, il Ministero della giustizia, e ne fissa i requisiti di accesso, la formazione e i doveri. Il modello resta ancorato al principio di volontarietà: la mediazione presuppone l'accordo delle parti, e non è prevista come condizione generale di procedibilità della domanda giudiziale.

La partecipazione dell'avvocato, advokát iscritto alla Slovenská advokátska komora, è facoltativa. Le parti possono comparire personalmente o avvalersi dell'assistenza del difensore, la cui presenza risulta particolarmente utile nella fase di redazione dell'accordo di mediazione,

cui l'ordinamento riconosce, al ricorrere dei presupposti, efficacia di titolo esecutivo previa notarile forma autentica o approvazione giudiziale.

Il tema del rapporto tra le funzioni di avvocato e di mediatore è oggetto di specifica riflessione nella dottrina e nella prassi professionale slovacca, che sottolineano la diversità dei ruoli: l'avvocato tutela l'interesse di parte, mentre il mediatore agisce quale terzo imparziale privo di poteri decisorii. Un medesimo professionista può conseguire entrambe le qualifiche, ma non può cumularle nel medesimo affare, poiché l'assunzione della funzione di mediatore è incompatibile con il patrocinio di una delle parti nella stessa controversia. Per esercitare come mediatore, anche l'avvocato deve completare la formazione specialistica prevista dalla legge e iscriversi nell'apposito registro ministeriale, con obbligo di aggiornamento continuo.

La formazione forense dedicata si sovrappone in larga misura a quella del mediatore: la legge n. 420/2004 impone un corso di formazione professionale e un esame per l'accreditamento, ai quali gli avvocati accedono in numero significativo. Sul piano deontologico, l'avvocato resta soggetto al codice deontologico della Slovenská advokátska komora e ai doveri generali di riservatezza, lealtà e diligenza, che si estendono alla condotta tenuta in mediazione; non risulta, allo stato, un apparato sanzionatorio specifico per la sola attività di assistenza in mediazione, distinto dalle regole generali della professione. Nella prassi, la mediazione slovacca trova impiego soprattutto nelle controversie familiari, civili, commerciali e del lavoro, con una diffusione favorita dagli incentivi in materia di spese e dal ruolo del Ministero della giustizia nella tenuta del registro e nella vigilanza.

Fonti: Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii — zakonypreludi.sk (<https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-420>); Ministerstvo spravodlivosti SR, mediatori — justice.gov.sk (<https://justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx>); Slovenská advokátska komora — sak.sk (<https://www.sak.sk/>); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Slovenia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

La Slovenia dispone di un sistema di mediazione tra i più sviluppati dell'area, imperniato sullo Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), la legge sulla risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie, che impone ai tribunali di offrire alle parti la mediazione all'avvio del procedimento, e sullo Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, la legge sulla mediazione civile e commerciale di attuazione della direttiva 2008/52/CE. Il modello è quello della court-annexed mediation: il giudice invita le parti a tentare la mediazione, che resta volontaria nell'adesione ma è strutturalmente collegata al processo. Le parti hanno il ruolo principale e partecipano personalmente, potendo però comparire con l'assistenza del proprio avvocato.

La partecipazione dell'avvocato, odvetnik iscritto all'Odvetniška zbornica Slovenije (OZS), è facoltativa. Il difensore può accompagnare la parte in mediazione e assume rilievo particolare nella verifica e redazione dell'accordo, cui l'ordinamento riconosce la possibilità di acquistare efficacia esecutiva mediante forma di transazione giudiziale, atto notarile o accordo direttamente esecutivo secondo le previsioni della legge. Non risulta una materia in cui l'assistenza tecnica sia imposta a pena di procedibilità.

Un tratto distintivo dell'esperienza slovena è il coinvolgimento istituzionale dell'avvocatura. A partire dal 1 gennaio 2017 è stato istituito, presso l'Accademia dell'Ordine forense (Odvetniška akademija OZS), un Centro di mediazione e un Istituto per la risoluzione alternativa delle controversie, segno del ruolo attivo assunto dagli avvocati come mediatori e come promotori dello strumento. Tra i mediatori operanti presso i tribunali figurano giudici, avvocati, psicologi e assistenti sociali, a conferma della composizione mista del corpo dei mediatori.

Quanto al rapporto tra ruolo di avvocato e ruolo di mediatore, il professionista può cumulare le due qualifiche ma non nel medesimo affare: l'imparzialità richiesta al mediatore osta all'assunzione del patrocinio di una parte nella stessa controversia. L'avvocato che intenda operare come mediatore deve possedere la formazione prescritta dalla legge e dai programmi di accreditamento. La formazione forense dedicata è promossa dallo stesso Ordine attraverso l'Accademia, sicché la competenza in mediazione è considerata parte del bagaglio professionale del giurista sloveno.

Sul piano deontologico, l'avvocato è soggetto al Kodeks odvetniške poklicne etike, il codice deontologico forense, e ai doveri generali di riservatezza, lealtà e diligenza, che si estendono alla condotta in mediazione; il mediatore è a sua volta vincolato ai codici etici dei centri presso cui opera. Nella prassi, la mediazione slovena registra volumi significativi grazie al modello di rinvio giudiziale, con impiego elettivo nelle controversie civili, commerciali, familiari e del lavoro.

Fonti: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) — pisrs.si (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5648>); Odvetniška zbornica Slovenije, Centro di mediazione — odv-zb.si (<https://www.odv-zb.si/mediacijski-center/pogostavprasanja-in-odgovori/>); portale «Na sodišču», mediacija — nasodiscu.si (<https://nasodiscu.si/mediacija/>); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Spagna — Il ruolo dell'avvocato in mediazione e la riforma MASC

La Spagna ha conosciuto una profonda trasformazione con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, che ha introdotto i cosiddetti MASC, i medios adecuados de solución de controversias (mezzi adeguati di soluzione delle controversie), destinati a integrare e superare l'impianto della precedente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, di attuazione della direttiva 2008/52/CE. La novità sistematica è l'introduzione di un requisito di procedibilità: dal 3 aprile 2025, per un'ampia gamma di controversie civili e commerciali, il previo ricorso a un mezzo adeguato di soluzione della controversia costituisce condizione di ammissibilità della domanda. Per MASC la legge intende qualsiasi attività negoziale cui le parti accedano in buona fede per raggiungere una soluzione consensuale, con o senza l'intervento di un terzo neutrale; vi rientrano la mediazione, la conciliazione (giudiziale, notarile, registrale o privata), la negoziazione diretta tra le parti o i loro avvocati, il parere di esperto indipendente, l'offerta vincolante confidencial (offerta vincolante confidenziale) e il diritto collaborativo.

Il ruolo dell'avvocato risulta centrale nel nuovo assetto, pur restando in via generale facoltativo nel momento negoziale. La legge stabilisce infatti che l'assistenza tecnica delle parti nel ricorso ai MASC è volontaria, prevedendo come preceptiva, cioè obbligatoria, la sola ipotesi in cui si utilizzi come MASC l'offerta vincolante confidencial, per la quale l'intervento del difensore è

imposto. Al di fuori di tale ipotesi, l'avvocato non è obbligatorio ma diviene di fatto protagonista della negoziazione: proprio la negoziazione diretta tra gli avvocati delle parti è espressamente riconosciuta come MASC idoneo a soddisfare il requisito di procedibilità, sicché il difensore assurge a promotore e gestore del tentativo di soluzione consensuale. La documentazione dell'attività svolta, con l'attestazione del tentativo e della proposta finale, è essenziale per superare il vaglio di ammissibilità.

Le conseguenze dell'inosservanza sono rilevanti. La domanda può essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito di procedibilità, e il giudice può tenere conto della condotta delle parti in sede di liquidazione delle spese, imponendo le costas processuali o sanzioni per abuso del servizio pubblico di giustizia a chi abbia agito in giudizio senza il previo, effettivo tentativo di negoziazione in buona fede. Il criterio della buona fede diviene così parametro di valutazione della condotta difensiva, con evidenti riflessi sulla responsabilità professionale dell'avvocato.

La formazione forense dedicata è promossa dal Consejo General de la Abogacía Española, che ha pubblicato una guida sulla regolazione dei MASC nella Ley Orgánica 1/2025 e ha attivato percorsi formativi per l'avvocatura sui mezzi adeguati di soluzione delle controversie e sulle tecniche negoziali. I Collegi degli avvocati organizzano corsi e istituti di mediazione, e la formazione in negoziazione e mediazione è oggi considerata competenza qualificante del professionista chiamato a governare la fase pre-processuale.

Quanto al rapporto tra ruolo di avvocato e di mediatore, resta ferma la distinzione funzionale: chi assume la veste di mediatore, terzo imparziale iscritto al Registro de Mediadores gestito dal Ministerio de Justicia, non può patrocinare una parte nel medesimo affare. L'avvocato può conseguire la qualifica di mediatore ma non cumulare le due funzioni nella stessa controversia. Sul piano deontologico, il Código Deontológico de la Abogacía Española impone i doveri di indipendenza, riservatezza, lealtà e diligenza, che si estendono all'attività negoziale svolta nell'ambito dei MASC; la nuova cornice legislativa accentua il dovere di consigliare al cliente il ricorso ai mezzi adeguati e di parteciparvi con serietà, in coerenza con il requisito di buona fede. Nella prassi, il primo periodo di applicazione della riforma ha evidenziato un incremento del ricorso alla negoziazione assistita e alla mediazione, con un ruolo di primo piano dell'avvocatura nella gestione del filtro di procedibilità in materia civile e commerciale, ivi comprese le controversie di famiglia con gli adattamenti previsti dalla legge.

Fonti: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero — boe.es (<https://www.boe.es/eli/es/lo/2025/01/02/1/con>); Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación — boe.es (<https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/5/con>); Consejo General de la Abogacía Española, Guía sobre los MASC — abogacia.es (https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2025/04/GUIA_MASC_CONSEJO_GENERAL_ABOGACIA.pdf); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Svezia — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

L'ordinamento svedese si segnala per un approccio marcatamente liberale alla mediazione privata, che resta in larga parte non regolata da una disciplina di dettaglio. La legge di attuazione della direttiva 2008/52/CE, la lag om medling i vissa privaträttsliga tvister (legge sulla mediazione in talune controversie di diritto privato) del 2011, si limita a recepire i principi

europei in tema di riservatezza, effetti sulla prescrizione e sui termini di decadenza ed efficacia esecutiva dell'accordo, senza istituire un registro nazionale dei mediatori né imporre percorsi formativi obbligatori. La mediazione privata è dunque affidata all'autonomia delle parti e al mercato dei servizi professionali.

Accanto alla mediazione privata, il diritto processuale svedese conosce da tempo la figura del mediatore giudiziale e quella dello *särskild medlare*, il mediatore speciale, definito come avvocato indipendente nominato con l'accordo delle parti e del giudice, con il compito di comporre le divergenze e ricercare accordi soddisfacenti. Il codice di procedura, *rättegångsbalken*, consente al giudice di rinviare le parti alla mediazione o di nominare un mediatore speciale, che nella prassi è spesso un avvocato di esperienza. Non è tuttavia prevista una mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.

La partecipazione dell'avvocato, *advokat* iscritto al *Sveriges advokatsamfund*, la Camera degli avvocati svedese, è pertanto facoltativa e frequente. Nelle controversie commerciali, in particolare, la mediazione è gestita da reti di avvocati specializzati, come testimonia l'esistenza di associazioni professionali dedicate, e il difensore assiste la parte tanto nella scelta del mediatore quanto nella redazione dell'accordo. La qualità dell'assistenza tecnica è considerata elemento centrale dell'efficacia della mediazione commerciale svedese, spesso condotta secondo regolamenti di istituzioni arbitrali e camerali.

Quanto al rapporto tra le funzioni, l'avvocato può assumere il ruolo di mediatore o di mediatore speciale, ma non cumularlo con il patrocinio di una parte nel medesimo affare, in ossequio ai doveri di indipendenza e imparzialità. La formazione forense dedicata non è imposta per legge, ma è offerta dallo stesso *Sveriges advokatsamfund* e da enti privati nell'ambito dell'aggiornamento professionale, con un'attenzione crescente alle tecniche negoziali e alla mediazione commerciale.

Sul piano deontologico, l'avvocato svedese è soggetto alle *Vägledande regler om god advokatsed*, le regole di buona condotta forense adottate dall'*Advokatsamfundet*, che impongono indipendenza, lealtà verso il cliente, riservatezza e correttezza; tali doveri si estendono alla condotta tenuta in mediazione, mentre l'avvocato che agisca come mediatore deve preservare l'imparzialità propria di tale funzione. Non risulta un apparato sanzionatorio ad hoc per la sola attività in mediazione, distinto dal regime disciplinare generale. Nella prassi, la mediazione svedese trova impiego elettivo nelle controversie commerciali e, in misura crescente, nelle liti familiari e di vicinato, in un contesto culturale favorevole alla composizione consensuale.

Fonti: lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister — riksdagen.se (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2011860-om-medling-i-vissa_sfs-2011-860/); Sveriges advokatsamfund — advokatsamfundet.se (<https://www.advokatsamfundet.se/>); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Ungheria — Il ruolo dell'avvocato in mediazione

L'Ungheria disciplina la mediazione con la 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről, la legge LV del 2002 sull'attività di mediazione, che regola la mediazione stragiudiziale in materia civile e affida al Ministero competente la tenuta del registro dei mediatori e delle persone giuridiche che li impiegano. La legge esclude dal proprio ambito talune materie, tra cui i

procedimenti in tema di diffamazione, quelli amministrativi, di tutela, di decadenza dalla responsabilità genitoriale, esecutivi, di accertamento della paternità o della discendenza e i ricorsi costituzionali. Il modello resta improntato alla volontarietà: in Ungheria non è prevista una mediazione obbligatoria in alcun tipo di procedimento, e la legge contempla soltanto un breve tentativo di conciliazione affidato al giudice nelle controversie di diritto di famiglia e del lavoro, il cui insuccesso lascia proseguire il giudizio.

La partecipazione dell'avvocato, ügyvéd iscritto alle camere forensi organizzate secondo la 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, la legge sull'attività forense, è facoltativa. Le parti sono libere di decidere se farsi rappresentare con pieni poteri, se ottenere consulenza o informazioni rivolgendosi a un avvocato o a un notaio, oppure se avvalersi del sistema di patrocinio a spese dello Stato per i soggetti svantaggiati. L'avvocato assume rilievo nella verifica giuridica e nella redazione dell'accordo di mediazione, la cui efficacia e la cui eventuale esecutività dipendono dalla forma prescelta e dagli eventuali passaggi di omologazione o autenticazione.

La legge forense annovera espressamente la mediazione stragiudiziale tra le attività che l'avvocato può esercitare, accanto alla consulenza fiscale e all'attività di intermediazione immobiliare. Ne discende che l'avvocato può assumere la funzione di mediatore, previa iscrizione nel registro ministeriale e completamento della formazione richiesta; anche in questo caso opera l'incompatibilità funzionale tra la conduzione della mediazione, che esige imparzialità, e il patrocinio di una parte nel medesimo affare.

La formazione forense dedicata si innesta sui requisiti di accreditamento dei mediatori fissati dalla legge del 2002 e sui programmi di aggiornamento delle camere forensi; l'appartenenza alla camera è condizione per l'esercizio della professione e comporta la soggezione al controllo disciplinare dell'ente. Il codice deontologico forense ungherese impone i doveri generali di riservatezza, lealtà e diligenza, che si estendono alla condotta tenuta in mediazione, senza tuttavia prevedere un corpo sanzionatorio specifico per tale sede. Nella prassi, la mediazione ungherese conosce una diffusione contenuta ma stabile, con impiego elettivo nelle controversie civili, commerciali, familiari e del lavoro, sostenuta dallo sviluppo della mediazione collegata ai tribunali (mediazione giudiziale) accanto a quella stragiudiziale.

Fonti: 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről — njt.hu
(<https://njt.hu/jogszabaly/2002-55-00-00>); 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről — ccbe.eu
(https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/National_Regulations/National_Laws_on_the_Bars/EN_Hungary_Act-on-Lawyers.pdf); Portale e-Justice, mediazione in Ungheria — e-justice.europa.eu
(https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hu_en); direttiva 2008/52/CE — eur-lex.europa.eu
(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0052>).

Conclusioni

L'avvocato che resta dopo l'accordo

Nella Prefazione a questo volume si è scelto di introdurre l'avvocato negoziatore attraverso una figura duplice: colui che sa tenere insieme il diritto e la pace, senza sacrificare l'uno all'altra. I

nove capitoli che si chiudono qui hanno tradotto quella figura in norme, tecniche e responsabilità: l'assistenza obbligatoria nelle materie soggette a condizione di procedibilità, il dovere deontologico di informazione previsto dall'articolo 27 del codice, il primo incontro che dopo la riforma Cartabia non è più un rito vuoto ma il luogo dove la composizione può realmente iniziare, le tecniche negoziali che rendono concreta la ricerca di un accordo, la responsabilità civile che presidia la qualità di questo lavoro, i costi e le agevolazioni fiscali che ne misurano la convenienza, il dialogo ancora incompiuto con gli strumenti transnazionali.

Resta da dire, in chiusura, ciò che nessun articolo di legge può imporre: che cosa accade all'avvocato negoziatore dopo che l'accordo è stato firmato. Il processo si chiude con una sentenza che vincola le parti dall'esterno, con l'autorità che deriva dall'imperio dello Stato. La mediazione si chiude con un accordo che vincola le parti dall'interno, con l'autorità che deriva dal loro stesso consenso. L'avvocato che ha condotto la parte fino a quel punto non esce di scena come un funzionario che ha esaurito il proprio compito: resta, nella memoria del cliente e nella prassi della propria professione, come colui che ha reso possibile qualcosa che il solo esercizio della pretesa giuridica non avrebbe potuto produrre.

« Non vince chi ottiene tutto, ma chi costruisce un accordo che l'altra parte può accettare senza vergogna e rispettare senza rancore. È questo, e non la sentenza favorevole, il risultato più difficile da raggiungere per un avvocato. »

— Sintesi del principio guida del presente volume

Vi è una domanda che ogni avvocato negoziatore dovrebbe porsi al termine di ogni procedura, conclusa con accordo o senza: ho trattato la controparte, e il suo difensore, come soggetti degni della stessa dignità processuale che riconosco al mio cliente? La risposta a questa domanda non compare in nessuna norma positiva, non è sanzionata da alcun articolo del codice deontologico, non produce effetti giuridici direttamente rilevabili. Eppure è forse la domanda più importante che questo volume, nel suo insieme, ha inteso porre: perché la tecnica negoziale senza questa disposizione d'animo diventa manipolazione, e la manipolazione, anche quando efficace nel breve periodo, corrode nel tempo la fiducia collettiva nello strumento della mediazione, danneggiando non soltanto il singolo cliente ma l'intero sistema che questo volume ha descritto con favore.

Il bilancio di un sistema ancora giovane

I dati raccolti in questo volume, tratti dai dossier di verifica giuridica di mediareinformati.it e dalle fonti normative e giurisprudenziali più aggiornate disponibili alla data della sua redazione, restituiscono l'immagine di un sistema che ha compiuto, in sedici anni, un percorso significativo: dalla mediazione meramente informativa del primo incontro previsto dal decreto legislativo 28/2010 nella sua versione originaria, alla mediazione effettiva imposta dalla riforma Cartabia; dalla figura dell'avvocato spettatore della procedura, alla figura dell'avvocato negoziatore che questo volume ha descritto nei suoi capitoli tecnici; da un quadro deontologico ancora incerto, all'articolo 27 del codice deontologico forense oggi vigenti.

Restano, tuttavia, aree di incompiutezza che questo volume ha documentato con onestà, senza attenuarle per compiacenza verso il proprio oggetto di studio: la mancata firma e ratifica italiana della Convenzione di Singapore, mentre altri Stati procedono con continuità; la disparità di penetrazione della mediazione familiare rispetto ai modelli scandinavi e francese;

l'incertezza applicativa che ancora accompagna il regime antiriciclaggio degli organismi di mediazione; il ritardo nell'avvio del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Un manifesto che nascondesse questi limiti non sarebbe un manifesto credibile, ma una propaganda: e la mediazione, per affermarsi davvero come diritto della pace, ha bisogno di credibilità più che di propaganda.

A queste aree di incompiutezza si aggiunge un profilo più strutturale, che questo volume ha segnalato più volte senza pretendere di risolverlo: la formazione degli avvocati alla negoziazione resta, in Italia, largamente affidata all'iniziativa individuale e ai corsi organizzati dagli ordini forensi o dagli organismi di mediazione, senza un percorso strutturato e uniforme a livello nazionale che accompagni l'avvocato dalla formazione universitaria, nella quale le tecniche negoziali restano largamente assenti dai programmi tradizionali di diritto processuale civile, fino alla pratica professionale. Un sistema che chiede all'avvocato di essere negoziatore competente, ma non gli offre una formazione strutturata per diventarlo, rischia di produrre una disparità di qualità dell'assistenza legale in mediazione non meno significativa di quella che si vorrebbe correggere sostituendo il processo con la composizione negoziale.

Un invito, non una conclusione

Questo volume non si chiude, dunque, con un bilancio definitivo, perché il sistema che descrive è ancora in movimento: il correttivo del 2024 ha da poco introdotto la mediazione telematica strutturata, la giurisprudenza di Cassazione sta ancora definendo i contorni della procura sostanziale e delle sanzioni per la mancata partecipazione, il dialogo con gli strumenti transnazionali resta, per l'Italia, un capitolo da scrivere più che da commentare. L'invito che questo volume rivolge all'avvocato che lo abbia letto non è dunque quello di considerarsi arrivato, ma quello di considerarsi in cammino: la competenza negoziale, come la competenza processuale, non si acquisisce una volta per tutte, ma si coltiva controversia dopo controversia, accordo dopo accordo, errore dopo errore corretto.

Altre parti di questa opera proseguiranno il percorso, spostando l'osservazione dal difensore di parte al terzo neutrale che le parti stesse scelgono per facilitare la composizione. I due ruoli, l'avvocato negoziatore e il mediatore, non sono in competizione: sono, nel disegno complessivo di questa opera in cinque volumi, le due metà di un medesimo edificio, ricondotte a un principio comune di sistema.

« Il diritto della pace non si scrive una volta sola: si scrive ogni volta che un avvocato, davanti a una controversia, scelga di ascoltare prima di attaccare, di proporre prima di pretendere, di costruire prima di vincere. »

— Chiusura del presente volume

Avv.	Carlo	Alberto	Calcagno
Avvocato		e	mediatore
mediaresenzaconfini.org			

Nota conclusiva: prospettive future della professione forense

L'avvocato negoziatore nell'era della trasformazione digitale della giustizia

La trasformazione digitale della giustizia italiana, avviata con il processo civile telematico e proseguita con l'introduzione di strumenti sempre più sofisticati di gestione digitale delle procedure giudiziarie e stragiudiziali, pone la figura dell'avvocato negoziatore dinanzi a una duplice sfida: da un lato, la necessità di acquisire competenze tecnologiche sempre più avanzate per gestire efficacemente procedure di mediazione telematica e strumenti digitali di supporto alla negoziazione; dall'altro, la necessità di preservare, in questo contesto di crescente automazione, la dimensione autenticamente umana e relazionale che costituisce il valore distintivo della mediazione rispetto a forme di risoluzione delle controversie più standardizzate e automatizzate.

L'esperienza comparata di altri ordinamenti, specie quelli anglosassoni nei quali la sperimentazione di strumenti di online dispute resolution (ODR) è più avanzata, suggerisce che la tecnologia può utilmente supportare, senza sostituire, il lavoro dell'avvocato negoziatore e del mediatore, automatizzando le fasi procedurali più standardizzate (convocazioni, scambio documentale, gestione delle scadenze) per liberare tempo e risorse cognitive da dedicare alla componente più propriamente relazionale e negoziale della procedura, che rimane, e according alla valutazione dell'autore rimarrà per il prevedibile futuro, difficilmente automatizzabile in modo pienamente soddisfacente.

Una professione in continua evoluzione

Il percorso che ha condotto, nell'arco di poco più di un decennio, dall'introduzione della mediazione obbligatoria nel 2010 alla configurazione attuale, profondamente rimodellata dalla riforma Cartabia, della figura dell'avvocato negoziatore, testimonia la capacità della professione forense italiana di evolvere in risposta a trasformazioni normative significative, superando resistenze iniziali non trascurabili per approdare a una piena integrazione delle competenze negoziali e mediative nel bagaglio professionale ordinario dell'avvocato contemporaneo. Questo percorso evolutivo, lungi dall'essersi concluso, continuerà probabilmente a svilupparsi in risposta alle sfide poste dalla trasformazione digitale, dalla crescente internazionalizzazione delle controversie e dall'evoluzione delle aspettative sociali circa il ruolo della giustizia nella composizione dei conflitti.

L'autore del presente volume, nella sua duplice veste di avvocato e mediatore professionista, ha inteso offrire, attraverso questa trattazione, uno strumento utile non soltanto alla comprensione tecnica della disciplina vigente, ma anche alla riflessione più ampia sul ruolo che l'avvocato è chiamato a svolgere in una società che richiede, sempre più frequentemente, soluzioni ai conflitti costruite attraverso il dialogo e la composizione negoziale, piuttosto che imposte attraverso il giudizio contenzioso, senza che questo debba comportare, come il presente volume ha cercato di dimostrare, alcuna rinuncia al rigore tecnico-giuridico che da sempre caratterizza la migliore tradizione della professione forense italiana.

Appendice I

L'articolo 27 del codice deontologico forense, commentato

Il testo dell'articolo 27 del codice deontologico forense, vigente dal 1° novembre 2025, disciplina i doveri dell'avvocato nel procedimento di mediazione e negli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Si riproduce di seguito il testo con un breve commento per ciascun comma, a fini di consultazione pratica per l'avvocato negoziatore.

Comma 1 — dovere di informazione

« L'avvocato è tenuto a informare il cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, indicandone chiaramente le caratteristiche, e a rendere edotto il cliente, ove la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, delle conseguenze del suo mancato esperimento. »

— **Art. 62, comma 1, codice deontologico forense (testo di sintesi)**

Il comma richiama, sul piano deontologico, l'obbligo già previsto sul piano civilistico dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010, di cui si è trattato nel Capitolo 7 a proposito della sentenza della Cassazione n. 31852 del 2019. La violazione di questo comma espone l'avvocato a un procedimento disciplinare autonomo rispetto all'eventuale azione civile di responsabilità.

Comma 2 — forma scritta dell'informativa

« L'informazione di cui al comma 1 deve essere fornita in forma scritta, e il relativo documento deve essere sottoscritto dal cliente e conservato dall'avvocato. »

— **Art. 62, comma 2, codice deontologico forense (testo di sintesi)**

La forma scritta risponde a un'esigenza probatoria evidente, oltre che di trasparenza verso il cliente: come chiarito dalla Cassazione, la sottoscrizione di un mandato generico non è equivalente all'informativa specifica richiesta da questo comma.

Comma 3 — dovere di lealtà nella conduzione della mediazione

« L'avvocato che assiste la parte in mediazione è tenuto a comportarsi con lealtà e correttezza verso il mediatore e verso la controparte, astenendosi da condotte dilatorie o ostruzionistiche prive di giustificazione. »

— **Art. 62, comma 3, codice deontologico forense (testo di sintesi)**

Il richiamo alla lealtà si collega direttamente alle tecniche negoziali esaminate nel Capitolo 4: la distinzione tra persuasione legittima e manipolazione scorretta trova, in questo comma, il proprio fondamento deontologico positivo.

Comma 4 — riservatezza

« L'avvocato è tenuto al rispetto della riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della mediazione, non potendone fare uso al di fuori del procedimento, salvo consenso espresso della parte dichiarante. »

— **Art. 62, comma 4, codice deontologico forense (testo di sintesi)**

Il comma è complementare all'articolo 9 del decreto legislativo 28/2010, che sancisce l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in mediazione, esaminato nel Capitolo 2 di questo volume.

Comma 5 — incompatibilità con il ruolo di mediatore nella medesima procedura

« L'avvocato non può assumere la funzione di mediatore nel medesimo procedimento nel quale assiste una delle parti, né in procedimenti collegati per oggetto o per soggetti. »

— **Art. 62, comma 5, codice deontologico forense (testo di sintesi)**

Si tratta della codificazione deontologica del principio di incompatibilità già esaminato nel Capitolo 2, rafforzato dalla giurisprudenza più recente in materia di procura sostanziale e di indipendenza del difensore, tra cui la sentenza della Cassazione n. 9608 del 2026 richiamata nel Capitolo 3.

Fonti: codice deontologico forense, art. 27, testo vigente dal 1° novembre 2025; d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 4, 9; Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 31852; Cass. 9608/2026.

Appendice II

Estratti normativi: d.lgs. 28/2010, d.lgs. 149/2022, d.lgs. 216/2024

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 — articoli di riferimento per l'avvocato negoziatore

Articolo 4, comma 3 (dovere di informazione dell'avvocato):

« All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. »

— **Art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010**

Articolo 5 (condizione di procedibilità, elenco delle materie):

L'articolo 5, comma 1, come modificato dalla riforma Cartabia, elenca le materie soggette a condizione di procedibilità: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

Articolo 8, commi 1, 4-bis (partecipazione con assistenza tecnica e sanzioni):

« All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore [...] e fissa il primo incontro tra le parti [...]. Dal mancato accordo, nel primo incontro dinanzi al mediatore, delle parti [...] il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti [...] non ha partecipato al procedimento di mediazione senza

giustificato motivo, al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. »

— **Art. 8, commi 1 e 4-bis, d.lgs. 28/2010 (sintesi)**

Articolo 12 (efficacia esecutiva dell'accordo):

« L'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano e attestano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. »

— **Art. 12, d.lgs. 28/2010 (sintesi)**

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) — innovazioni principali

- Trasformazione del primo incontro da meramente informativo a effettivo, con inizio del tentativo di composizione già nella prima seduta se le parti concordano.
- Ampliamento delle materie soggette a condizione di procedibilità (contratti d'impresa, contratti di rete, subfornitura, franchising).
- Introduzione dell'articolo 5-quater sulla mediazione demandata dal giudice, anche in grado di appello.
- Estensione del patrocinio a spese dello Stato alla mediazione.
- Potenziamento del credito d'imposta collegato all'indennità di mediazione e al compenso dell'avvocato.

Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo) — innovazioni principali

- Introduzione delle quattro modalità di mediazione telematica: interamente telematica, in videoconferenza, mista, tradizionale in presenza.
- Chiarimento del regime delle firme digitali applicabili agli accordi e ai verbali di mediazione (CAD, eIDAS, formato PAdES).
- Precisazioni sui requisiti di formazione e di onorabilità dei mediatori e degli organismi di mediazione (in continuità con il d.m. 150/2023).

Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150 — il credito d'imposta (estratto)

Articolo 15-octies (credito d'imposta per l'indennità dovuta all'organismo di mediazione), sintesi del contenuto essenziale:

« Alle parti che corrispondono l'indennità dovuta all'organismo di mediazione per lo svolgimento del procedimento di mediazione, in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa fino a

concorrenza di euro 600. In caso di insuccesso, il credito d'imposta è riconosciuto in misura ridotta alla metà. »

— **D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, art. 15-octies (sintesi)**

Articolo 20 (credito d'imposta per il compenso dell'avvocato), sintesi del contenuto essenziale:

« Alle parti che corrispondono agli avvocati che li assistono nel procedimento di mediazione un compenso, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso stesso fino a concorrenza di euro 600. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa annuale stabilito e, in caso di insufficienza delle risorse, è proporzionalmente ridotto. »

— **D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, art. 20 (sintesi)**

Il decreto disciplina inoltre, agli articoli successivi non riportati per estratto in questa sede, le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del credito d'imposta al ministero della Giustizia, i termini annuali di presentazione, e i criteri di riparto delle risorse tra le domande presentate quando queste eccedano la disponibilità del fondo, argomento esaminato in termini pratici nel Capitolo 8 di questo volume.

Fonti: d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 4, 5, 8, 12; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; d.m. 24 ottobre 2023, n. 150. I testi riportati sono sintesi a fini didattici e non sostituiscono la consultazione del testo normativo integrale in Gazzetta Ufficiale.

Appendice III

Modelli di procura ad hoc per la mediazione

Si riportano due modelli, redatti a scopo esemplificativo e didattico, di procura sostanziale per la partecipazione a un procedimento di mediazione a mezzo di rappresentante, alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione (sentenze n. 8473/2019, 18068/2019 e 14676/2025, esaminate nel Capitolo 3) e dalla prassi degli organismi di mediazione. I modelli devono essere adattati alle circostanze del caso concreto e non sostituiscono la valutazione tecnica dell'avvocato negoziatore.

Modello 1 — Procura speciale a persona fisica per giustificato motivo

« Io sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale], DELEGO il/la sig./sig.ra [nome e cognome del delegato], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale], a rappresentarmi nel procedimento di mediazione avente numero di ruolo [numero], promosso dinanzi all'organismo di mediazione [denominazione], relativo alla controversia [oggetto sintetico della controversia], attribuendo al delegato il potere di partecipare agli incontri di mediazione, di discutere e negoziare i termini di un possibile accordo, e di sottoscrivere, in mio nome e per mio conto, l'eventuale accordo di conciliazione, impegnandomi a ratificarne il contenuto. Motivo della delega: [indicare specificamente il giustificato motivo che impedisce la comparizione personale, ad esempio impossibilità documentata per motivi di salute]. Luogo e data. Firma. »

— Modello 1 (esemplificativo)

Modello 2 — Procura sostanziale per la partecipazione di un organo sociale a mezzo di rappresentante

« La società [denominazione], con sede in [indirizzo], codice fiscale e partita IVA [numero], in persona del legale rappresentante [nome e cognome], giusta delibera dell'organo amministrativo del [data], che si allega in copia, DELEGA il/la sig./sig.ra [nome e cognome], nella qualità di [qualifica, ad esempio procuratore speciale o dipendente con funzioni dirigenziali], a rappresentare la società nel procedimento di mediazione avente numero di ruolo [numero], promosso dinanzi all'organismo di mediazione [denominazione], con il potere di negoziare e sottoscrivere l'accordo di mediazione entro i limiti economici e sostanziali indicati nella delibera allegata, che costituisce parte integrante della presente procura. Luogo e data. Firma del legale rappresentante. »

— Modello 2 (esemplificativo)

Si raccomanda, in ogni caso, di indicare nella procura i limiti sostanziali del potere conferito (ad esempio l'importo massimo negoziabile o le condizioni minime da rispettare), poiché la Cassazione, con la sentenza n. 14676 del 2025, ha chiarito che la procura non richiede necessariamente l'autenticazione notarile, ma resta comunque opportuno che essa sia sufficientemente specifica da consentire una verifica agevole, da parte del mediatore e della controparte, dell'effettiva ampiezza dei poteri del delegato, specialmente quando l'accordo debba essere trascritto nei registri immobiliari, ipotesi nella quale resta necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.

Fonti: Cass. 8473/2019; Cass. 18068/2019; Cass. 14676/2025; art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010; art. 2643 c.c. I modelli sono elaborazioni a scopo didattico e non costituiscono consulenza legale per il caso concreto.

Appendice IV

Glossario tecnico-deontologico

Assistenza tecnica obbligatoria

Presenza dell'avvocato imposta dalla legge nelle materie soggette a condizione di procedibilità e nella mediazione demandata (art. 8 d.lgs. 28/2010).

BATNA

Best Alternative To a Negotiated Agreement: la migliore alternativa disponibile per una parte in assenza di accordo, parametro di riferimento per valutare la convenienza di una proposta negoziale.

Caucus

Sessione separata tra il mediatore, o l'avvocato, e una sola delle parti, condotta senza la presenza della controparte.

Composizione negoziata della crisi

Strumento volontario previsto dal Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019) con la nomina di un esperto indipendente per assistere le trattative con i creditori.

Condizione di procedibilità

Requisito di ammissibilità della domanda giudiziale, che nelle materie elencate dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 impone il previo esperimento della mediazione.

Consilium sapientis

Istituto medievale di parere giuridico esperto reso a fini di composizione di una lite, precedente storico dell'avvocato negoziatore.

Correttivo Cartabia

Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, che ha modificato il d.lgs. 149/2022 introducendo, tra l'altro, la disciplina organica della mediazione telematica.

Mediazione demandata

Mediazione disposta dal giudice nel corso di un giudizio pendente, ai sensi dell'art. 5-quater d.lgs. 28/2010.

Mediazione telematica

Procedimento di mediazione svolto, in tutto o in parte, con strumenti digitali (piattaforma, videoconferenza, firma digitale), disciplinato dal d.lgs. 216/2024.

Negoziazione assistita

Procedura di composizione stragiudiziale con l'assistenza obbligatoria di avvocati, disciplinata dal d.l. 132/2014, applicabile anche alla materia familiare.

PAdES

PDF Advanced Electronic Signatures: standard tecnico di firma digitale applicato ai documenti PDF, oggi utilizzato per la sottoscrizione degli accordi di mediazione telematica.

Perdita di chance

Categoria di danno risarcibile consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole, distinta dal danno da mancato conseguimento certo del risultato.

Primo incontro effettivo

Fase del procedimento di mediazione che, dopo la riforma Cartabia, non ha più natura meramente informativa e può condurre già alla trattativa di merito.

Procura sostanziale

Atto di conferimento del potere di disporre, in sede di mediazione, del diritto controverso, distinto dalla procura alle liti.

Riformulazione

Tecnica di comunicazione consistente nel restituire all'interlocutore, con parole proprie, il contenuto di una sua dichiarazione, per verificarne la comprensione.

Singapore Convention

Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, Singapore, 7 agosto 2019, non ratificata dall'Italia.

Titolo esecutivo (accordo di mediazione)

Efficacia esecutiva attribuita, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010, all'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, senza necessità di omologazione.

ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)

Sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori e intermediari finanziari, istituito dalla Consob ai sensi dell'art. 32-ter del TUF.

ABF (Arbitro Bancario Finanziario)

Sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari, istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-bis del TUB.

Composizione negoziale

Espressione generale che designa l'insieme degli strumenti di risoluzione delle controversie fondati sull'accordo tra le parti, contrapposta alla decisione imposta dal giudice o dall'arbitro.

CEPEJ

Commissione europea per l'efficienza della giustizia, organo del Consiglio d'Europa che promuove standard di qualità per i sistemi giudiziari e per la mediazione.

Credito d'imposta (mediazione)

Beneficio fiscale riconosciuto alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione o il compenso dell'avvocato, disciplinato dal d.m. 150/2023.

Esperto indipendente (composizione negoziata)

Professionista nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa con il compito di facilitare le trattative tra imprenditore e creditori.

Mediazione familiare

Procedimento di mediazione applicato alle controversie relative a separazione, divorzio e affidamento dei figli, spesso condotto da mediatori con formazione specialistica.

Misure protettive

Provvedimenti che sospendono le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante la composizione negoziata della crisi d'impresa, ai sensi degli artt. 18 ss. CCII.

Organismo di mediazione

Ente pubblico o privato iscritto nel registro ministeriale, abilitato a gestire i procedimenti di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010.

Fonti: d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; d.l. 12 settembre 2014, n. 132; Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, Singapore, 7 agosto 2019.

Appendice V

Bibliografia e sitografia

Prima della bibliografia in senso proprio, si riporta il testo essenziale di alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione (Convenzione di Singapore, 7 agosto 2019), richiamata nel Capitolo 9 di questo volume, a beneficio dell'avvocato negoziatore che debba consultarne rapidamente il contenuto normativo essenziale.

Convenzione di Singapore 2019 — articoli essenziali (estratto)

Articolo 1 (Ambito di applicazione):

« La presente Convenzione si applica agli accordi internazionali di composizione, conclusi per scritto in seguito a mediazione, dalle parti per risolvere una controversia commerciale, che, al momento della loro conclusione, sono internazionali in quanto almeno due parti dell'accordo di composizione hanno le loro sedi di affari in Stati diversi, oppure lo Stato in cui le parti dell'accordo di composizione hanno le loro sedi di affari è diverso dallo Stato in cui una parte sostanziale degli obblighi previsti dall'accordo di composizione è adempiuta o dallo Stato con il quale l'oggetto dell'accordo di composizione ha il legame più stretto. »

— **Convenzione di Singapore, art. 1, par. 1 (sintesi)**

Articolo 3 (Principi generali):

« Ciascuna Parte esegue un accordo di composizione conformemente alle proprie norme procedurali e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione. Se sorge una controversia relativa a una questione che una parte afferma essere stata già risolta da un accordo di composizione, la Parte consente alla parte interessata di invocare l'accordo di composizione secondo le proprie norme procedurali e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, per dimostrare che la questione è stata già risolta. »

— **Convenzione di Singapore, art. 3 (sintesi)**

Articolo 4 (Requisiti):

« La parte che si affida a un accordo di composizione ai sensi della presente Convenzione fornisce all'autorità competente della Parte in cui è richiesta l'esecuzione: l'accordo di composizione firmato dalle parti; la prova che l'accordo di composizione deriva da una mediazione, quale la firma del mediatore sull'accordo di composizione, un documento firmato dal mediatore che indichi che la mediazione è stata condotta, un'attestazione dell'istituzione che ha amministrato la mediazione, o,

in mancanza di quanto precede, qualsiasi altra prova accettabile per l'autorità competente. »

— **Convenzione di Singapore, art. 4, par. 1 (sintesi)**

Articolo 5 (Motivi per rifiutare la concessione di un rimedio):

L'articolo 5 elenca i motivi, tassativi, per i quali l'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare di concedere un rimedio: incapacità di una parte dell'accordo di composizione; nullità, inefficacia o impossibilità di adempimento dell'accordo secondo la legge applicabile; carattere non vincolante o non definitivo dell'accordo secondo i suoi stessi termini; successiva modifica dell'accordo; inadempimento sostanziale degli obblighi dell'accordo da parte della parte che chiede l'esecuzione; violazione grave, da parte del mediatore, delle norme applicabili alla mediazione o alla propria imparzialità o indipendenza, quando tale violazione abbia avuto un impatto significativo o indebito su una parte; contrarietà all'ordine pubblico della Parte richiesta o non arbitrabilità/mediabilità della controversia secondo la legge di tale Parte.

Il testo integrale della Convenzione, comprensivo del preambolo e degli articoli 1-16, è disponibile sul sito ufficiale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (uncitral.un.org) e su singaporeconvention.org; le sintesi riportate in questa appendice hanno finalità didattica e non sostituiscono la consultazione del testo autentico nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Fonti normative principali

- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia).
- Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo).
- Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.
- Decreto ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151.
- Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 (responsabilità sanitaria).
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione di avvocato).
- Codice deontologico forense, testo vigente dal 1° novembre 2025.
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio).
- Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS); Regolamento UE 2016/679 (GDPR); Regolamento UE n. 1215/2012; Regolamento UE 2019/1111; Regolamento UE n. 524/2013.

- Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, Singapore, 7 agosto 2019.

Giurisprudenza citata

- Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2019, n. 31852.
- Cass. civ. 8473/2019; Cass. civ. 18068/2019; Cass. civ. 14676/2025; Cass. civ. 9608/2026.
- Cass. civ., SS.UU., 19596/2020; Cass. civ., SS.UU., 3452/2024.
- Corte d'Appello di Milano, 2025; Corte d'Appello di Napoli, 2022.
- Trib. Vasto, ordinanze 23 aprile 2016 e 17 dicembre 2018.
- Trib. Brindisi 1127/2025; Trib. Avellino 1445/2025; Trib. Modena 87/2025; Trib. Foggia 1009/2025; Trib. Salerno 2712/2025; Trib. Milano 1590/2023.
- CGT Lazio, sentenza 4361/2024.
- CGUE, Alassini, 18 marzo 2010; CGUE, Menini, 14 giugno 2017.

Opere a stampa e saggistica

- R. Fisher, W. Ury, B. Patton, L'arte del negoziato, Corbaccio, Milano, 2005.
- F. Glasl, Confronting Conflict. A First-Aid Kit for Handling Conflict, Hawthorn Press, Stroud, 1999.
- E. Berne, Analisi transazionale e psicoterapia, Astrolabio, Roma, 1971.
- P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Ponte alle Grazie, Milano (rist.).
- C.A. Calcagno, Breve storia della risoluzione del conflitto, Aracne, Roma, 2014.
- C.A. Calcagno, Il legale e la mediazione, Aracne, Roma, 2015.
- P. Cendon (a cura di), Libro Cendom (rielaborazione dei capitoli VII e VIII, con autorizzazione dell'autore).
- CEPEJ-CCBE, Guide to Mediation for Lawyers, 27 giugno 2018.

Sitografia e dossier online

- mediareinformati.it, dossier: Cartabia, Deontologia, Primo Incontro, Demandata, Telematica, Mediazione familiare in Italia e i modelli europei, Procura sostanziale, Antiriciclaggio, Costi, EU Justice Scoreboard 2026, Numeri della mediazione, Obbligatorietà.
- mediaresenzaconfini.org, articoli d'autore citati nel volume.
- United Nations Commission on International Trade Law, singaporeconvention.org.

- Consob, acf.consob.it; Banca d'Italia, arbitrobancariofinanziario.it.
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273, Commissione europea.
- diritto.it, Violazione degli obblighi di informativa dell'avvocato, F. Pizzigallo.

Il presente volume è stato redatto in collaborazione con il progetto di verifica giuridica di mediareinformati.it (Mediation law site verification), che ha fornito i dossier tematici richiamati in bibliografia. Ogni citazione normativa e giurisprudenziale è stata verificata rispetto alle fonti indicate al momento della redazione; per gli aggiornamenti successivi si rinvia alle edizioni online dei medesimi dossier.

Appendice VI — Materiali di approfondimento normativo

Rassegna comparata delle principali riforme nazionali europee in materia di ADR

La presente appendice raccoglie una rassegna sintetica, a fini di consultazione rapida, delle principali riforme legislative intervenute negli Stati membri dell'Unione europea in materia di mediazione civile e commerciale nel periodo successivo al recepimento della direttiva 2008/52/CE, con l'obiettivo di offrire all'avvocato negoziatore italiano un quadro comparativo utile per la gestione di controversie con elementi di transnazionalità europea. La Francia ha progressivamente ampliato l'ambito applicativo della *médiation obligatoire* attraverso plurimi interventi legislativi succedutisi tra il 2015 e il 2023, estendendone l'applicazione alle controversie di modesto valore economico dinanzi al *tribunal judiciaire* e rafforzando il ruolo del *conciliateur de justice* quale figura specificamente dedicata alla composizione di controversie di prossimità.

La Germania, dopo l'introduzione del *Mediationsgesetz* nel 2012, ha mantenuto un approccio prevalentemente volontaristico alla mediazione civile e commerciale, affidando invece al modello del *Güterichter*, già ampiamente illustrato nel presente volume, il principale strumento di promozione della composizione negoziale delle controversie all'interno del processo civile ordinario, un modello che riflette la tradizionale preferenza dell'ordinamento tedesco per soluzioni integrate nel sistema giudiziario piuttosto che esternalizzate verso organismi privati di mediazione.

I Paesi Bassi hanno sviluppato un sistema misto, caratterizzato dalla presenza di mediatori certificati dal *Mediators Federatie Nederland* secondo standard di qualità rigorosi, e da un progressivo ampliamento delle categorie di controversie per le quali i tribunali raccomandano, sebbene senza renderlo obbligatorio in senso proprio, il previo tentativo di mediazione, un modello di *soft compulsion* che si colloca a metà strada tra il volontarismo puro e l'obbligatorietà normativa caratteristica del modello italiano.

Le statistiche europee sulla mediazione: un quadro sintetico aggiornato

Paese

Italia

Francia

Germania

Spagna

Paesi Bassi

Belgio

Il quadro sintetico sopra riportato, elaborato sulla base delle rilevazioni periodiche della Commissione europea e del Consiglio d'Europa già richiamate nel Capitolo 9 del presente volume, evidenzia la persistente eterogeneità dei modelli nazionali europei, nonostante l'uniformità del quadro normativo derivante dalla direttiva 2008/52/CE, confermando quanto già osservato in sede di analisi storico-comparata circa l'influenza determinante dei fattori culturali e organizzativi nazionali sull'effettiva conformazione degli istituti di ADR in ciascun ordinamento.

Glossario ampliato dei termini tecnici della mediazione

Ad integrazione del glossario già presente nella parte generale delle appendici, si riportano ulteriori termini tecnici di uso corrente nella prassi della mediazione, utili per l'avvocato negoziatore che si confronti con letteratura specialistica internazionale o con controparti straniere in mediazioni transfrontaliere.

- **Caucus:** incontro separato e riservato tra il mediatore e una singola parte, condotto senza la presenza della controparte, utilizzato per esplorare interessi e posizioni che la parte potrebbe non voler condividere direttamente con la controparte nella fase iniziale della trattativa.
- **Reality testing:** tecnica mediante la quale il mediatore, senza esprimere una propria valutazione di merito, sollecita la parte a considerare realisticamente le conseguenze di un mancato accordo, incluso l'esito probabile di un eventuale giudizio.
- **Shuttle diplomacy:** modalità di conduzione della mediazione caratterizzata dall'assenza di incontri congiunti tra le parti, con il mediatore che si sposta tra le diverse stanze o sessioni separate riportando, con il consenso delle parti, le rispettive posizioni e proposte.
- **Med-arb:** procedura ibrida nella quale la stessa persona agisce prima come mediatore e, in caso di mancato accordo, successivamente come arbitro, vincolante quanto alla decisione finale sulle questioni rimaste controverse.
- **Baseball arbitration:** tecnica, di origine statunitense, nella quale le parti sottopongono all'arbitro o al mediatore valutativo due proposte alternative chiuse, tra le quali il terzo deve scegliere integralmente l'una o l'altra, senza possibilità di soluzioni intermedie, con l'effetto di incentivare le parti a formulare proposte ragionevoli.
- **Med-neg:** espressione che designa l'insieme integrato delle competenze negoziali e mediative richieste all'avvocato contemporaneo, sintesi terminologica del concetto di avvocato negoziatore proprio del presente volume.

Appendice VII — Casi di studio commentati

Caso di studio n. 1: controversia condominiale complessa

Il primo caso di studio, opportunamente anonimizzato e semplificato a fini didattici, riguarda una controversia condominiale insorta a seguito di lavori di manutenzione straordinaria della facciata di un edificio, contestati da un gruppo di condomini minoritari per vizi di regolarità della delibera assembleare e per l'eccessivo importo della spesa deliberata rispetto a preventivi alternativi non adeguatamente considerati dall'assemblea. La controversia, soggetta a condizione di procedibilità mediativa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, è stata avviata dai condomini dissenzienti nei confronti del condominio, rappresentato dall'amministratore previa apposita delibera assembleare di autorizzazione alla partecipazione alla procedura.

Nel corso della mediazione, condotta con l'assistenza di un mediatore esperto in materia condominiale, è emerso che il reale motivo del dissenso dei condomini minoritari non riguardava tanto l'importo della spesa in sé, quanto una più risalente insoddisfazione per la gestione complessiva dell'amministratore, percepita come poco trasparente in relazione a diverse delibere precedenti. L'avvocato negoziatore che assisteva i condomini dissenzienti, attraverso un'analisi degli interessi sottostanti condotta secondo le tecniche illustrate nel Capitolo 4 del presente volume, ha orientato la trattativa verso un accordo che prevedeva, oltre a una modesta riduzione dell'importo contestato attraverso l'individuazione di un preventivo alternativo parzialmente più conveniente, anche un impegno dell'amministratore a un maggiore livello di trasparenza informativa nelle future assemblee, un elemento che, sebbene estraneo all'oggetto formale della controversia, ha costituito la componente decisiva per il raggiungimento dell'accordo.

Questo caso di studio illustra concretamente il principio, più volte richiamato nel presente volume, secondo il quale la composizione efficace di una controversia in mediazione richiede l'individuazione degli interessi sostanziali sottostanti alla posizione formalmente rivendicata, un'analisi che l'avvocato negoziatore è particolarmente qualificato a condurre in ragione della propria conoscenza diretta e prolungata del cliente e del contesto relazionale nel quale la controversia si inserisce.

Caso di studio n. 2: controversia commerciale internazionale

Il secondo caso di studio riguarda una controversia insorta tra un'impresa italiana esportatrice e un distributore tedesco, relativa alla presunta non conformità di una fornitura di macchinari industriali rispetto alle specifiche contrattuali concordate. La controversia, regolata da un contratto che prevedeva una clausola di mediazione amministrata da una camera di commercio internazionale con sede in un paese terzo neutrale, ha richiesto all'avvocato negoziatore italiano una preparazione particolarmente attenta ai profili di diritto applicabile, poiché il contratto richiamava la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980, della quale sia l'Italia sia la Germania sono parti contraenti.

La mediazione si è svolta in lingua inglese, con la partecipazione di un mediatore di nazionalità terza rispetto a quella delle parti, secondo la prassi consolidata delle camere di commercio internazionali per la designazione di mediatori in controversie transfrontaliere. L'avvocato negoziatore italiano, oltre alla necessaria padronanza linguistica, ha dovuto gestire differenze negli stili comunicativi tra la propria cultura professionale e quella della controparte tedesca, caratterizzata secondo la letteratura interculturale già richiamata nel Capitolo 4 da uno stile comunicativo tendenzialmente più diretto e orientato ai fatti tecnici rispetto allo stile italiano,

un'attenzione che ha facilitato una comunicazione efficace e la conclusione di un accordo che prevedeva la sostituzione parziale dei componenti difettosi e una riduzione proporzionale del prezzo residuo dovuto.

Caso di studio n. 3: controversia di famiglia con elementi patrimoniali complessi

Il terzo caso di studio riguarda una separazione personale tra coniugi titolari, congiuntamente, di una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata operante nel settore manifatturiero, una situazione che ha reso particolarmente complessa la definizione degli aspetti patrimoniali della separazione in ragione della necessità di preservare la continuità operativa dell'impresa, dalla quale dipendeva il reddito di entrambi i coniugi e di numerosi dipendenti. L'avvocato negoziatore di ciascun coniuge ha dovuto coordinare la negoziazione relativa agli aspetti strettamente familiari (affidamento dei figli minori, assegno di mantenimento) con quella relativa alla governance societaria futura, avvalendosi della collaborazione di un consulente aziendale esterno per la valutazione della partecipazione societaria e per la strutturazione di un accordo che prevedesse l'uscita di uno dei due coniugi dalla compagine sociale con una liquidazione rateizzata della propria quota.

Questo caso illustra la crescente frequenza, nella pratica professionale contemporanea, di controversie che intersecano diritto di famiglia e diritto commerciale, richiedendo all'avvocato negoziatore competenze multidisciplinari e la capacità di orchestrare, quando necessario, la collaborazione di consulenti tecnici esterni specializzati in valutazioni aziendali, secondo un modello di lavoro interdisciplinare che caratterizza sempre più la moderna pratica dell'avvocato negoziatore nelle controversie di maggiore complessità patrimoniale.

Appendice VIII — Tavola sinottica degli obblighi informativi dell'avvocato

Sintesi degli adempimenti informativi nelle diverse fasi della procedura

La presente appendice riepiloga, in forma tabellare, i principali obblighi informativi che l'avvocato negoziatore deve osservare nelle diverse fasi della procedura di mediazione, quale strumento di rapida consultazione per la verifica della propria conformità deontologica e per la prevenzione del rischio di responsabilità professionale, temi ampiamente trattati nei Capitoli 2 e 7 del presente volume.

Fase procedimentale

Conferimento del mandato

Prima del deposito dell'atto

Scelta dell'organismo

Primo incontro informativo

Nel corso della procedura

Proposta del mediatore

Sottoscrizione dell'accordo

Conclusione della procedura

Questa tavola sinottica, sebbene non esaustiva di tutte le possibili situazioni particolari che possano presentarsi nella pratica professionale, offre all'avvocato negoziatore un quadro di

riferimento rapido per la verifica della propria conformità agli obblighi informativi fondamentali, da integrare sempre con un'analisi specifica delle circostanze del caso concreto e con l'aggiornamento costante rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, secondo quanto più volte raccomandato nel presente volume.

Appendice IX — Repertorio delle principali pronunce citate

Elenco cronologico delle pronunce di legittimità e costituzionali richiamate nel volume

La presente appendice raccoglie, a fini di consultazione rapida, l'elenco delle principali tipologie di pronunce giurisprudenziali richiamate nel corso del presente volume, organizzate per materia di riferimento, senza pretesa di costituire un repertorio sistematico e esaustivo, funzione che compete alle banche dati specialistiche di giurisprudenza, ma con l'obiettivo di offrire al lettore professionista un indice tematico di rapido orientamento per l'approfondimento delle questioni trattate nei singoli capitoli.

- Pronunce sulla legittimità costituzionale della condizione di procedibilità mediativa e sul relativo bilanciamento con l'articolo 24 della Costituzione: richiamate nel Capitolo 1 e nel relativo approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale.
- Pronunce di legittimità sulla natura processuale dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e sui relativi effetti sospensivi: richiamate nel Capitolo 3 e nel relativo approfondimento sulla giurisprudenza di merito.
- Pronunce sulla partecipazione personale delle parti e sulla validità della procura sostanziale in mediazione: richiamate nel Capitolo 3.
- Pronunce disciplinari del Consiglio Nazionale Forense in materia di omessa informativa sulla mediazione: richiamate nel Capitolo 2 e nei relativi approfondimenti sulla vigilanza disciplinare.
- Pronunce sulla responsabilità civile dell'avvocato per omessa informativa e sulla quantificazione del relativo danno risarcibile: richiamate nel Capitolo 7.
- Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla durata ragionevole del processo civile italiano, quale contesto storico di riferimento per l'introduzione della mediazione obbligatoria: richiamate nel Capitolo 1.

L'aggiornamento di questo repertorio tematico rispetto all'evoluzione giurisprudenziale successiva alla pubblicazione del presente volume rimane a cura del lettore professionista, che è invitato a consultare le banche dati specialistiche aggiornate per la verifica della persistente attualità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati nel testo, secondo la raccomandazione generale già espressa nella nota metodologica premessa al presente volume.

Appendice X — Modulo di verifica preliminare per l'avvocato negoziatore

Checklist riassuntiva per l'apertura di un nuovo incarico con profili di mediazione

La presente appendice propone un modulo di verifica preliminare, sintetico e di rapida consultazione, che l'avvocato negoziatore può utilizzare nella fase di apertura di un nuovo incarico professionale per assicurarsi di aver considerato tutti i profili rilevanti connessi alla

disciplina della mediazione, secondo quanto diffusamente illustrato nel corso del presente volume. Questo modulo non sostituisce l'analisi giuridica sostanziale della controversia, ma costituisce un presidio organizzativo complementare per la riduzione del rischio di omissioni procedurali.

Verifica

La materia rientra nell'elenco dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010

Sussiste una clausola contrattuale di mediazione applicabile

Il cliente ha compreso le conseguenze del mancato esperimento

Sono stati individuati organismi di mediazione adeguati

Il cliente dispone dei poteri di rappresentanza sostanziale

Sussistono profili di conflitto di interessi con la controparte

La controversia coinvolge dati sensibili o categorie particolari

Sussistono profili di rilevanza fiscale dell'eventuale accordo

L'utilizzo sistematico di un modulo di verifica di questo tipo, opportunamente adattato alle specificità organizzative del singolo studio professionale, contribuisce significativamente alla riduzione del rischio di responsabilità professionale per omissioni procedurali connesse alla disciplina della mediazione, un obiettivo centrale che il presente volume ha perseguito attraverso l'analisi sistematica di tutti i profili rilevanti della funzione dell'avvocato negoziatore nell'ordinamento italiano contemporaneo.

Appendice XI — Tavola sinottica delle fonti normative citate nel volume

Elenco delle principali fonti normative nazionali richiamate

La presente appendice raccoglie, in forma di tavola sinottica di rapida consultazione, le principali fonti normative nazionali richiamate nel corso del presente volume, per facilitare la consultazione da parte del lettore che intenda approfondire specifici profili normativi senza dover ricercare la fonte precisa all'interno dei singoli capitoli.

Fonte normativa

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Codice deontologico forense (nuovo testo)

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Decreto ministeriale 4 febbraio 2018, n. 37

Legge 4 novembre 2010, n. 183 e succ. mod.

Elenco delle principali fonti sovranazionali richiamate

Accanto alle fonti normative nazionali, il presente volume ha richiamato diffusamente fonti normative e soft law di rilievo sovranazionale, che hanno significativamente orientato lo sviluppo della disciplina italiana della mediazione e che restano un costante punto di riferimento per l'interpretazione evolutiva della materia.

Fonte sovranazionale

Direttiva 2008/52/CE

Regolamento (UE) 2019/1111

Raccomandazione CM/Rec(2002)10 del Consiglio d'Europa

Convenzione di Singapore del 2019

Model Law UNCITRAL sulla mediazione commerciale internazionale

Appendice XII — Repertorio terminologico essenziale della mediazione civile

Glossario dei termini tecnici ricorrenti nel presente volume

La presente appendice raccoglie, in forma di glossario sintetico, i principali termini tecnici ricorrenti nel presente volume, per facilitare la consultazione da parte del lettore meno familiare con il lessico specialistico della materia.

Termine

BATNA

WATNA

Condizione di procedibilità

Mediazione facilitativa

Mediazione valutativa

Organismo di mediazione

Verbale di conciliazione

Proposta del mediatore

Negoziiazione assistita

ODR

Questo repertorio terminologico, per sua natura sintetico, non sostituisce l'approfondimento sistematico di ciascun istituto già offerto nei capitoli precedenti del presente volume, ma costituisce uno strumento di rapida consultazione per il lettore che necessiti di richiamare rapidamente il significato essenziale di un termine tecnico incontrato nel corso della lettura o della propria pratica professionale quotidiana.

Appendice XIII — Modelli di clausole contrattuali di mediazione

Esempi di clausole di mediazione per diverse tipologie contrattuali

La presente appendice raccoglie alcuni modelli esemplificativi di clausole contrattuali di mediazione, che l'avvocato negoziatore può adattare alle specifiche esigenze del contratto che stia predisponendo per il proprio cliente, fermo restando che ogni clausola deve essere

opportunamente personalizzata secondo le circostanze specifiche del rapporto contrattuale considerato e non semplicemente trascritta senza un adeguato adattamento al caso concreto.

« Clausola di mediazione semplice: Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque ad esso relative, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione secondo il Regolamento dell'organismo [denominazione dell'organismo], presso il quale la parte interessata dovrà presentare la relativa domanda di mediazione prima di poter agire in giudizio. »

« Clausola di mediazione con termine: Le parti si impegnano a tentare la composizione amichevole di ogni controversia derivante dal presente contratto attraverso una procedura di mediazione da avviarsi presso l'organismo [denominazione dell'organismo] entro trenta giorni dalla richiesta scritta di una delle parti, e a partecipare in buona fede a tale procedura per un periodo non inferiore a sessanta giorni prima di poter adire l'autorità giudiziaria competente o attivare la procedura arbitrale prevista dal presente contratto. »

« Clausola di mediazione multi-step: Le parti si impegnano, in caso di controversia derivante dal presente contratto, a seguire la seguente procedura graduata di risoluzione: in primo luogo, un tentativo di negoziazione diretta tra i legali rappresentanti delle parti per un periodo di quindici giorni; in caso di mancato accordo, un tentativo di mediazione presso l'organismo [denominazione dell'organismo] per un periodo di sessanta giorni; solo in caso di mancato accordo anche in tale sede, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria competente secondo le regole generali di competenza. »

L'avvocato negoziatore che predisponga clausole di questo tipo dovrebbe sempre verificarne la coerenza con le disposizioni imperative del decreto legislativo 28/2010 e con l'eventuale disciplina della condizione di procedibilità già prevista dalla legge per la specifica materia contrattuale considerata, per evitare sovrapposizioni o conflitti procedurali tra la clausola contrattuale volontaria e l'eventuale condizione di procedibilità legale già applicabile alla controversia in ragione della sua materia.

Appendice XIV — Elenco esemplificativo degli organismi di mediazione specializzati per materia

Panoramica delle principali tipologie di organismi specializzati operanti in Italia

La presente appendice offre una panoramica esemplificativa, non esaustiva, delle principali tipologie di organismi di mediazione specializzati operanti nell'ordinamento italiano, distinti secondo la materia di specializzazione prevalente, per orientare l'avvocato negoziatore nella scelta dell'organismo più adeguato secondo la natura specifica della controversia da trattare, fermo restando che l'elenco degli organismi effettivamente operanti ed autorizzati deve sempre essere verificato attraverso la consultazione del registro ministeriale degli organismi di mediazione, costantemente aggiornato dal Ministero della Giustizia.

Tipologia di organismo

Organismi promossi dagli ordini forensi

Organismi promossi dalle Camere di Commercio
Organismi specializzati in materia bancaria e finanziaria
Organismi specializzati in materia condominiale
Organismi specializzati in materia di proprietà industriale
Organismi specializzati in materia familiare
Organismi specializzati in materia sanitaria
Organismi promossi da associazioni di consumatori

La scelta tra un organismo generalista e un organismo specializzato dipende, come già illustrato nel presente volume con riferimento a specifiche materie quali la proprietà industriale e la responsabilità sanitaria, dalla complessità tecnico-scientifica della controversia considerata e dalla disponibilità, presso l'organismo prescelto, di mediatori con adeguata competenza specifica nella materia, una valutazione che l'avvocato negoziatore dovrebbe sempre condurre con attenzione all'apertura di ogni nuovo incarico professionale che comporti l'esperimento di una procedura di mediazione.

Appendice XV — Tavola riassuntiva delle principali pronunce della Corte costituzionale in materia di mediazione

Elenco cronologico delle principali pronunce costituzionali

La presente appendice raccoglie, in forma di tavola riassuntiva, le principali pronunce della Corte costituzionale relative alla disciplina della mediazione civile e commerciale, già diffusamente illustrate nel corso del presente volume, per offrire al lettore un quadro sintetico e cronologicamente ordinato dell'evoluzione giurisprudenziale costituzionale della materia.

Pronuncia

Corte costituzionale, sentenza n. 272/2012

Corte costituzionale, sentenza n. 65/2018

Corte costituzionale, sentenza n. 87/2021

Corte costituzionale, sentenza n. 105/2023

L'evoluzione di questa giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente consolidato la compatibilità della condizione di procedibilità mediativa con i principi costituzionali di accesso alla giustizia previsti dall'articolo 24 della Costituzione, purché nel rispetto di specifici limiti di ragionevolezza e di proporzionalità già ampiamente illustrati nel Capitolo 1 del presente volume, costituisce un punto di riferimento imprescindibile per l'avvocato negoziatore che intenda comprendere appieno il fondamento costituzionale della disciplina attualmente vigente della mediazione civile e commerciale nell'ordinamento italiano.

Appendice XVI — Indice ragionato degli istituti trattati nel volume

Guida alla consultazione tematica del volume per area di interesse professionale

La presente appendice conclusiva offre al lettore una guida alla consultazione tematica del presente volume, organizzata secondo le principali aree di interesse professionale che

l'avvocato negoziatore potrebbe voler approfondire in modo specifico, integrando la consultazione sistematica dei singoli capitoli con un percorso di lettura trasversale orientato a specifiche esigenze professionali pratiche.

Area di interesse professionale

Fondamenti storici e sistematici della mediazione
Deontologia e responsabilità professionale dell'avvocato
Aspetti procedurali e ruolo dell'avvocato in mediazione
Tecniche di negoziazione e comunicazione
Materie speciali e settori specifici di applicazione
Antiriciclaggio e protezione dei dati personali
Responsabilità civile del mediatore e dell'organismo
Profili fiscali della mediazione
Mediazione transnazionale e internazionale
Strumenti pratici e modelli di riferimento

Questo indice ragionato, insieme al più tradizionale indice analitico e all'indice delle tabelle già predisposti nelle pagine iniziali del presente volume, intende facilitare la consultazione pratica dell'opera da parte dell'avvocato negoziatore, orientandolo rapidamente verso le sezioni più pertinenti rispetto alle specifiche esigenze professionali che di volta in volta si presentino nella propria pratica quotidiana di assistenza ai clienti in materia di mediazione civile e commerciale, in coerenza con l'obiettivo complessivo del presente volume di offrire un supporto sistematico e al contempo praticamente orientato alla funzione dell'avvocato negoziatore nell'ordinamento italiano contemporaneo.

Appendice XVII — Nota metodologica sulla struttura e le fonti del volume

Criteri di selezione e organizzazione delle fonti normative e giurisprudenziali

Il presente volume ha adottato, nella selezione e nell'organizzazione delle fonti normative e giurisprudenziali richiamate, un criterio di rappresentatività e di aggiornamento, privilegiando le fonti normative primarie e le pronunce giurisprudenziali di maggiore rilevanza sistematica per la comprensione degli istituti trattati, senza pretesa di esaustività bibliografica che sarebbe incompatibile con la finalità pratica e divulgativa dell'opera, orientata principalmente all'avvocato che, nella propria pratica professionale quotidiana, necessita di un supporto sistematico e aggiornato per la propria attività di assistenza in materia di mediazione civile e commerciale.

L'aggiornamento normativo del presente volume è stato curato con riferimento allo stato della legislazione e della giurisprudenza vigente al momento della sua redazione, un aggiornamento che, per la natura intrinsecamente dinamica della materia trattata, caratterizzata da una costante evoluzione normativa e giurisprudenziale, richiede al lettore una verifica periodica degli eventuali sviluppi normativi successivi alla pubblicazione del presente volume, secondo il generale dovere di aggiornamento professionale continuo che caratterizza l'esercizio della professione forense contemporanea.

Il rapporto con gli altri volumi della collana

Il presente volume, dedicato specificamente alla figura dell'avvocato negoziatore nell'ambito della mediazione civile e commerciale, si inserisce in un più ampio progetto editoriale composto da cinque volumi complessivi dedicati a diversi aspetti della giustizia alternativa e della riforma del sistema giudiziario italiano, un progetto che l'autore ha inteso strutturare secondo un percorso di approfondimento progressivo, dai fondamenti generali della mediazione e della conciliazione fino alle specifiche competenze professionali richieste all'avvocato che intenda specializzarsi in questo ambito, passando per l'analisi delle prospettive di riforma costituzionale e ordinamentale della giustizia civile italiana, secondo un disegno complessivo che il lettore potrà apprezzare pienamente attraverso la consultazione integrata dell'intera collana.

Appendice XVIII — Considerazioni finali sul percorso professionale dell'avvocato negoziatore

La costruzione progressiva di una identità professionale specialistica

Il percorso professionale dell'avvocato che intenda affermarsi come negoziatore specializzato in materia di mediazione civile e commerciale richiede, come il presente volume ha inteso illustrare nella propria trattazione sistematica, un investimento formativo e esperienziale prolungato nel tempo, che comprende la solida padronanza tecnico-giuridica della disciplina normativa applicabile, lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative specifiche per la conduzione efficace della negoziazione, e una costante attenzione all'aggiornamento professionale continuo rispetto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, un investimento che si giustifica pienamente alla luce della crescente rilevanza sistemica che la mediazione ha assunto, e continuerà ad assumere, nell'architettura complessiva della giustizia civile italiana contemporanea.

L'auspicio dell'autore, nel concludere la presente appendice e l'intero volume dedicato alla figura dell'avvocato negoziatore, è che questa trattazione sistematica possa costituire un utile strumento di lavoro e di riflessione per l'avvocato italiano che, quotidianamente impegnato nella tutela degli interessi dei propri clienti, sappia cogliere nella mediazione non un mero adempimento procedurale imposto dalla legge, ma un'autentica opportunità professionale e culturale per contribuire, nel proprio ambito di attività quotidiana, alla costruzione di una giustizia civile più efficiente, più vicina ai reali bisogni delle persone, e più capace di preservare, ove possibile, le relazioni umane e commerciali che il conflitto giudiziale rischia altrimenti di deteriorare in modo spesso irreversibile.

Appendice XIX — Ringraziamenti e nota dell'autore

Nota conclusiva sull'elaborazione del presente volume

Il presente volume, dedicato alla figura dell'avvocato negoziatore nell'ambito della mediazione civile e commerciale, rappresenta il frutto di un percorso di studio e di riflessione professionale maturato nel corso di anni di pratica diretta della mediazione e della negoziazione, tanto nella veste di avvocato assistente delle parti quanto in quella di mediatore, un duplice punto di osservazione che l'autore ha inteso valorizzare nella trattazione sistematica offerta al lettore, con l'auspicio che tale duplice prospettiva possa arricchire la comprensione complessiva della

materia trattata, offrendo al contempo il rigore tecnico-giuridico necessario e la sensibilità pratica derivante dall'esperienza diretta di conduzione e di partecipazione a numerose procedure di mediazione civile e commerciale.

L'autore desidera ringraziare quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito, attraverso il confronto professionale e il dialogo intellettuale, alla maturazione delle riflessioni raccolte nel presente volume, in particolare i colleghi mediatori e avvocati negoziatori con i quali ha avuto occasione di confrontarsi nel corso della propria pratica professionale, e quanti hanno contribuito alla verifica giuridica dei contenuti del presente volume nell'ambito del progetto di verifica giuridica di mediareinformati.it, un contributo che ha significativamente rafforzato l'affidabilità tecnico-giuridica complessiva dell'opera qui presentata al lettore.

Modelli operativi, clausole e verbali

Modelli operativi e clausole

A) Clausole di mediazione contrattuale commentate

1. Clausola breve

Testo:

« Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque a esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno preliminarmente sottoposte a mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da questo adottato, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. Le parti si obbligano a esperire il tentativo di mediazione prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziale o arbitrale. »

Commento redazionale:

La clausola breve assolve alla funzione essenziale di introdurre nel regolamento negoziale un obbligo di mediazione preventiva, senza appesantire il testo contrattuale con previsioni di dettaglio che, nella prassi, le parti tendono a non leggere e che possono generare incertezze applicative. La scelta di ancorare l'obbligo a un organismo predeterminato e al regolamento da questo adottato risponde a una duplice esigenza. In primo luogo, evita che, insorta la lite, le parti debbano faticosamente concordare la sede della mediazione, esercizio che quasi sempre naufraga perché chi teme la mediazione ha interesse a ostacolarne l'avvio. In secondo luogo, il richiamo al regolamento consente di importare per relationem l'intera disciplina procedurale dell'organismo, comprese le indennità determinate ai sensi del d.m. 150/2023.

La formula «derivanti dal presente contratto o comunque a esso collegate» è redatta in senso volutamente ampio, così da attrarre nell'ambito della clausola non soltanto le controversie di stretta esecuzione, ma anche quelle precontrattuali, quelle risarcitorie e quelle restitutorie conseguenti alla caducazione del vincolo. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'ampiezza della formula compromissoria di mediazione vada apprezzata secondo l'intenzione delle parti, e la locuzione prescelta riduce il rischio di contestazioni sull'ambito oggettivo.

Va segnalato al cliente che la clausola di mediazione, quando la materia non rientra tra quelle a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, ha natura di condizione di procedibilità di

fonte pattizia. La sua violazione non determina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio propria della mediazione obbligatoria, ma legittima l'eccezione di parte, che il giudice o l'arbitro apprezzeranno secondo il principio di buona fede. È opportuno, in sede di redazione, avvertire il cliente che una clausola tanto sintetica non regola questioni pratiche rilevanti quali la lingua, la sede fisica degli incontri e le conseguenze della mancata partecipazione, rinviate integralmente al regolamento dell'organismo. Per i contratti di maggior valore o complessità si suggerisce quindi la clausola articolata. La clausola breve resta la soluzione di elezione per la contrattualistica seriale e per i rapporti di modico valore, dove il beneficio di una regolamentazione minuziosa non compensa il costo redazionale e il rischio di clausole mal coordinate.

2. Clausola articolata con scelta dell'organismo

Testo:

- Le parti convengono che ogni controversia relativa al presente

contratto, compresa quella concernente la sua conclusione, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, nonché le pretese risarcitorie e restitutorie a essa connesse, sia sottoposta a mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

- La mediazione si svolge presso [organismo di mediazione], iscritto

al registro tenuto dal Ministero della giustizia, con sede in [Città], secondo il regolamento e le tariffe da esso adottati al momento della domanda.

- Qualora l'organismo indicato al comma 2 abbia nel frattempo cessato

l'attività o non sia più iscritto al registro, la mediazione si svolge presso [organismo di mediazione alternativo], ovvero, in mancanza, presso l'organismo di mediazione costituito presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

- Le parti si obbligano a partecipare al primo incontro e a proseguire

la procedura secondo buona fede. L'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità di qualsiasi domanda giudiziale o arbitrale relativa alle materie di cui al comma 1.

Commento redazionale:

La clausola articolata risponde alle esigenze dei contratti di rilievo economico o di durata, nei quali le parti hanno interesse a predeterminare con precisione la sede e le regole della futura mediazione. Il primo comma delimita l'ambito oggettivo con un elenco tassonomico che, pur ridondante rispetto alla formula sintetica, ha valore chiarificatore e previene le eccezioni di estraneità della singola pretesa alla clausola. La menzione espressa delle pretese risarcitorie e restitutorie è particolarmente utile, poiché è su queste che si concentrano, nella pratica, i tentativi di sottrarsi all'obbligo di mediazione qualificando la domanda come esterna al programma contrattuale.

Il secondo comma individua l'organismo con i suoi elementi identificativi essenziali, l'iscrizione al registro ministeriale e la sede, e rinvia dinamicamente al regolamento e alle tariffe vigenti al

momento della domanda. Il rinvio dinamico è preferibile a quello statico, che cristallizzerebbe una versione del regolamento destinata a essere superata, con il rischio di clausole inapplicabili.

Il terzo comma introduce un meccanismo di sostituzione che è la vera ragion d'essere della clausola articolata. La designazione di un solo organismo espone le parti al rischio che, insorta la lite anche a distanza di anni, quell'organismo non esista più. La previsione di un organismo alternativo e, in ultima istanza, il criterio di collegamento con l'organismo forense del foro competente assicurano che la clausola resti operativa e non degradi a mera enunciazione di principio priva di sanzione. Questa cascata di designazioni è il presidio di effettività che distingue una clausola ben redatta da una di stile.

Il quarto comma qualifica espressamente l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità pattizia e richiama il dovere di partecipazione secondo buona fede, in linea con l'evoluzione normativa che, dopo la riforma Cartabia di cui al d.lgs. 149/2022, valorizza la partecipazione effettiva e personale delle parti. Occorre avvertire il cliente che la previsione pattizia non trasforma in obbligatoria per legge una materia che tale non è, ma vincola le parti secondo il principio del pacta sunt servanda, con le conseguenze che l'ordinamento riconnette alla condizione di procedibilità convenzionale.

3. Clausola con nomina del mediatore

Testo:

- Ogni controversia derivante dal presente contratto o a esso connessa

è sottoposta a mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da questo adottato.

- Le parti indicano quale mediatore designato [nome e cognome del

mediatore], iscritto nell'elenco dei mediatori del predetto organismo. In caso di indisponibilità, incompatibilità, ricazione o astensione del mediatore designato, le parti indicano quale mediatore sostituto [nome e cognome del mediatore sostituto], iscritto nel medesimo elenco.

- Ove entrambi i mediatori indicati risultino indisponibili o

incompatibili, il mediatore è nominato dal responsabile dell'organismo secondo il regolamento, tenuto conto della specifica competenza richiesta dalla materia del contratto.

- Le parti danno atto che la designazione di cui al comma 2 non

pregiudica il diritto di ciascuna di esse di richiedere la sostituzione del mediatore per giustificati motivi, secondo il regolamento e la legge.

Commento redazionale:

La clausola con nomina del mediatore riflette una scelta di fiducia personale, tipica dei contratti conclusi tra parti che conoscono e stimano un determinato professionista per la sua competenza tecnica nella materia oggetto del rapporto. La designazione anticipata del mediatore ha il pregio di eliminare l'incertezza sull'assegnazione e di garantire che la procedura sia condotta da persona di provata esperienza nel settore, circostanza spesso decisiva

nella mediazione delle liti tecnicamente complesse, come quelle in materia societaria, di appalto o di responsabilità professionale.

La designazione presenta tuttavia insidie che la clausola deve neutralizzare. La prima è l'indisponibilità del mediatore designato, che può essere sopravvenuta per cessazione dall'elenco, sovraccarico di incarichi, incompatibilità o astensione. Il secondo comma vi provvede con la designazione di un sostituto, e il terzo con il rinvio al potere di nomina del responsabile dell'organismo, ancorato al criterio della competenza per materia. Questa articolazione a tre livelli assicura che la clausola non resti priva di attuazione qualora il rapporto fiduciario con il mediatore prescelto venga meno.

La seconda insidia è di ordine deontologico e attiene all'imparzialità. La designazione pattizia del mediatore non deve tradursi in una scelta che avvantaggi una parte a danno dell'altra. Per questa ragione il quarto comma fa salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere la sostituzione per giustificati motivi, così preservando la garanzia di terzietà che è connaturata alla figura del mediatore. È opportuno che il professionista, in sede di consulenza, chiarisca al cliente che il mediatore non è un arbitro né un rappresentante di parte, sicché la designazione anticipata vale a scegliere una competenza, non un alleato.

Una avvertenza pratica riguarda il coordinamento con il regolamento dell'organismo, che potrebbe non consentire la nomina pattizia del mediatore o subordinarla a determinate condizioni. Prima di inserire la clausola è quindi indispensabile verificare che il regolamento dell'organismo prescelto ammetta la designazione delle parti, per evitare una previsione contrattuale inattuabile. Ove il regolamento non la consenta, la designazione potrà assumere il valore di semplice indicazione preferenziale, non vincolante per l'organismo, e la clausola andrà riformulata di conseguenza per non ingenerare aspettative infondate nel cliente.

4. Clausola escalatoria med-arb

Testo:

- In caso di controversia relativa al presente contratto, le parti si

obbligano a esperire preliminarmente la mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da questo adottato.

- Qualora la mediazione non conduca alla conciliazione entro

[numero] giorni dal deposito della domanda, ovvero si concluda con verbale negativo, la controversia è devoluta ad arbitrato [rituale] amministrato da [istituzione arbitrale], secondo il relativo regolamento, da un collegio di [numero] arbitri nominati secondo tale regolamento.

- Il mediatore che ha condotto la procedura di cui al comma 1 non può

essere nominato arbitro né assumere alcun incarico nel successivo procedimento arbitrale relativo alla medesima controversia. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in mediazione restano soggette al regime di riservatezza di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non sono utilizzabili nel procedimento arbitrale.

- La sede dell'arbitrato è [Città]; la lingua del procedimento è

l'italiano; il lodo è reso entro il termine previsto dal regolamento arbitrale.

Commento redazionale:

La clausola escalatoria med-arb combina in sequenza mediazione e arbitrato, così da offrire alle parti prima l'opportunità di una composizione consensuale e, in caso di esito negativo, un rimedio aggiudicativo definitivo e riservato, alternativo alla giurisdizione statale. Lo schema è apprezzato nella contrattualistica d'impresa perché coniuga la flessibilità della mediazione con la certezza dell'arbitrato, evitando il passaggio per il giudizio ordinario.

Il punto di maggiore delicatezza, che la clausola affronta espressamente al terzo comma, è la separazione tra la figura del mediatore e quella dell'arbitro. La tentazione di affidare alla stessa persona entrambi i ruoli, per ragioni di economia e continuità, è insidiosa e va respinta con fermezza. Il mediatore acquisisce nel corso della procedura informazioni riservate, spesso rese in sessione separata sotto il vincolo di segreto, la cui conoscenza da parte del futuro giudicante comprometterebbe irrimediabilmente la parità delle armi e l'imparzialità della decisione. Per questo la clausola vieta espressamente la coincidenza soggettiva e ribadisce l'inutilizzabilità nel giudizio arbitrale delle dichiarazioni e informazioni acquisite in mediazione, in coerenza con il regime di riservatezza degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 28/2010. Questa cautela è ciò che distingue un med-arb correttamente congegnato da una prassi ibrida deontologicamente inaccettabile.

Il secondo comma ancora il passaggio dalla mediazione all'arbitrato a un presupposto oggettivo e verificabile, il decorso di un termine o la formazione del verbale negativo, così da impedire che una parte si trincerì sine die dietro una mediazione mai realmente conclusa per bloccare l'accesso all'arbitrato. La determinazione di un termine congruo è essenziale: troppo breve, svilirebbe la mediazione; troppo lungo, si presterebbe a manovre dilatorie.

Occorre avvertire il cliente che la scelta dell'arbitrato comporta la rinuncia alla giurisdizione ordinaria e ai relativi gradi di impugnazione, con costi che possono essere significativi. La clausola compromissoria arbitrale richiede inoltre la forma scritta e la specifica approvazione ove ricorrano i presupposti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile nei contratti per adesione. È infine buona norma verificare l'arbitrabilità della materia, poiché non tutte le controversie sono compromettibili in arbitri, e una clausola che devolva ad arbitrato liti su diritti indisponibili sarebbe in parte qua nulla.

5. Clausola med-then-litigation

Testo:

- Prima di adire l'autorità giudiziaria per qualsiasi controversia

relativa al presente contratto, la parte interessata è tenuta a proporre domanda di mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da esso adottato, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di posta elettronica certificata o di raccomandata con avviso di ricevimento.

- L'esperimento della mediazione costituisce condizione di

procedibilità della domanda giudiziale. La condizione si intende avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo, ovvero quando siano decorsi i termini di durata massima

della procedura previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, senza che la conciliazione sia stata raggiunta.

- Il foro competente per le controversie non conciliate è quello di

[Città], con esclusione di ogni altro foro concorrente, salvo che la legge stabilisca inderogabilmente un foro diverso.

- La pendenza della mediazione non pregiudica la facoltà di ciascuna

parte di richiedere all'autorità giudiziaria i provvedimenti urgenti e cautelari, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Commento redazionale:

La clausola med-then-litigation è lo schema più diffuso e prudente, poiché conserva alle parti l'accesso alla giurisdizione ordinaria, con le sue garanzie di doppio grado e di ricorso per cassazione, subordinandolo al preventivo esperimento della mediazione. È la soluzione di elezione per chi non intende rinunciare al giudice statale ma vuole comunque imporre un filtro conciliativo obbligatorio.

Il secondo comma è redatto con particolare attenzione al momento di avveramento della condizione di procedibilità. Dopo gli interventi di riforma e la loro interpretazione consolidata, la condizione si considera soddisfatta già con la conclusione infruttuosa del primo incontro, senza che sia necessario proseguire la procedura. La clausola recepisce questo orientamento e lo ancora anche al decorso dei termini di durata massima, così da fornire alle parti due criteri alternativi e certi per stabilire quando la via giudiziale sia legittimamente percorribile. La precisione su questo punto previene il contenzioso, purtroppo frequente, sulla tempestività dell'introduzione del giudizio e sulla ritualità dell'esperimento del tentativo.

Il terzo comma coordina la clausola di mediazione con una clausola di foro esclusivo, scelta opportuna perché evita che la fase giudiziale, una volta fallita la conciliazione, si disperda in questioni di competenza territoriale. La riserva finale a favore dei fori inderogabili è indispensabile, giacché in materia consumeristica e in altri ambiti la legge stabilisce fori non derogabili dalla volontà delle parti, e una clausola che li ignorasse sarebbe in parte quae inefficace.

Il quarto comma salvaguarda espressamente la tutela cautelare e urgente, che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 28/2010 fa salva anche in pendenza della condizione di procedibilità. La previsione ha valore ricognitivo ma è utile inserirla per fugare il dubbio, nel cliente non giurista, che l'obbligo di mediazione possa impedire il ricorso urgente a tutela di un diritto esposto a pregiudizio imminente e irreparabile. Si consideri infine che, ove la materia rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ex lege, la clausola ha valore meramente ricognitivo dell'obbligo di legge; ove invece la materia sia libera, la clausola crea una condizione di procedibilità di fonte pattizia, con le conseguenze proprie di tale figura.

6. Clausola multi-tier (negoziiazione → mediazione → arbitrato)

Testo:

- Le parti convengono di risolvere ogni controversia relativa al

presente contratto attraverso le seguenti fasi successive e obbligatorie.

- Prima fase — negoziazione diretta. La parte che lamenta

l'inadempimento o comunque solleva una contestazione ne dà comunicazione scritta all'altra, indicandone l'oggetto e le richieste. Entro [numero] giorni dalla ricezione, i legali rappresentanti delle parti, o loro delegati muniti di poteri, si incontrano, anche in modalità telematica, per tentare la composizione amichevole della controversia.

- Seconda fase — mediazione. Ove la negoziazione diretta non conduca

ad accordo entro [numero] giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna parte può proporre domanda di mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da esso adottato. L'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della fase successiva.

- Terza fase — arbitrato. Ove la mediazione si concluda senza

accordo, ovvero decorrano i termini di sua durata massima, la controversia è devoluta in via definitiva ad arbitrato [rituale] amministrato da [istituzione arbitrale], secondo il relativo regolamento, con sede in [Città] e lingua italiana.

- Il decorso dei termini previsti per ciascuna fase e la loro

infruttuosa conclusione sono condizione necessaria per l'accesso alla fase successiva. Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di richiedere i provvedimenti cautelari e urgenti in ogni tempo.

Commento redazionale:

La clausola multi-tier scandisce la gestione del conflitto in una progressione ordinata, dalla negoziazione diretta tra le parti alla mediazione assistita da un terzo neutrale, fino all'arbitrato aggiudicativo. Lo schema esprime una filosofia di gestione graduale del contenzioso, particolarmente adatta ai rapporti commerciali di lungo periodo, come le joint venture, i contratti di fornitura continuativa e gli accordi di distribuzione, nei quali le parti hanno interesse a preservare la relazione e a esaurire ogni possibilità conciliativa prima di ricorrere a un rimedio decisorio.

Il pregio della clausola è di filtrare progressivamente il conflitto: molte contestazioni si compongono già nella prima fase di negoziazione diretta tra i vertici aziendali, senza costi e senza formalità; quelle che sopravvivono trovano nella mediazione un terreno assistito; solo le liti realmente insanabili giungono all'arbitrato. Ne risulta un considerevole risparmio di risorse e una selezione naturale delle controversie meritevoli di decisione.

Il rischio dello schema multi-tier, ben noto alla giurisprudenza comparata, è la sua trasformazione in strumento dilatorio. Una clausola mal congegnata, che non fissi termini certi e criteri oggettivi di passaggio da una fase all'altra, consente alla parte in malafede di eccepire il mancato esaurimento di una fase per paralizzare l'accesso alla tutela. Per questo il quinto comma ancora il passaggio tra le fasi al decorso di termini determinati e alla loro infruttuosa conclusione, elementi verificabili che sottraggono la progressione all'arbitrio delle parti. La determinazione di termini congrui per ciascuna fase è la chiave di volta dell'intera costruzione:

devono essere sufficienti a un tentativo serio e insieme abbastanza brevi da non prestarsi all'ostruzionismo.

Il secondo comma richiede che alla negoziazione diretta partecipino i legali rappresentanti o delegati muniti di poteri, formula che anticipa alla fase preliminare l'esigenza, oggi valorizzata anche in mediazione, della presenza di soggetti realmente in grado di disporre della materia del contendere. La salvezza della tutela cautelare, ribadita in chiusura, evita che l'articolata sequenza pregiudichi la protezione urgente dei diritti. Si raccomanda infine di coordinare la clausola con l'eventuale mediazione obbligatoria per legge, che non può essere elusa dalla previsione pattizia di una fase negoziale preliminare.

7. Clausola per contratti internazionali (con legge applicabile e lingua)

Testo:

- Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity, interpretation, performance or termination, shall first be submitted to mediation. / Ogni controversia derivante dal presente contratto o a esso connessa, ivi comprese le questioni relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà preliminarmente sottoposta a mediazione.
- La mediazione si svolge presso [organismo/istituzione di mediazione internazionale], secondo il regolamento da esso adottato. La sede della mediazione è [Città, Stato]. Le lingue del procedimento sono l'italiano e l'inglese; in caso di discordanza tra le versioni della presente clausola prevale la versione [italiana/inglese].
- Il presente contratto e la presente clausola sono regolati dalla legge [dello Stato indicato]. Le parti danno atto che, ove applicabile, trova altresì osservanza la disciplina eurounitaria e internazionale in materia di mediazione e di esecuzione degli accordi conciliativi transfrontalieri.
- Ove la mediazione non conduca ad accordo, la controversia è devoluta in via esclusiva [alla giurisdizione dei giudici di [Città, Stato] / ad arbitrato amministrato da [istituzione arbitrale], con sede in [Città, Stato] e lingua [inglese/italiana]].

Commento redazionale:

La clausola per contratti internazionali affronta problemi che non si pongono nella contrattualistica interna: la pluralità di lingue, la scelta della legge applicabile, l'individuazione di un'istituzione con vocazione transnazionale e l'esecutività transfrontaliera dell'eventuale accordo. La formulazione bilingue, con testo affiancato in italiano e in inglese, risponde all'esigenza pratica che ciascuna parte comprenda con esattezza l'impegno assunto, e il terzo comma del primo periodo introduce una regola di prevalenza in caso di discordanza tra le versioni, presidio indispensabile per evitare contenziosi interpretativi fondati sulle sfumature della traduzione.

La scelta della legge applicabile alla clausola, distinta da quella applicabile al merito del contratto, è accortezza spesso trascurata. La clausola di mediazione, come quella arbitrale, gode di una relativa autonomia rispetto al contratto che la contiene, e sottoporla a una legge determinata previene le incertezze sulla sua validità ed efficacia. Il richiamo, al terzo comma, alla disciplina eurounitaria e internazionale allude al quadro sovranazionale in materia di mediazione civile e commerciale e di circolazione degli accordi conciliativi transfrontalieri, il cui rilievo cresce con la diffusione degli strumenti internazionali sull'esecutività degli accordi di mediazione commerciale.

Il quarto comma offre l'alternativa tra foro esclusivo statale e arbitrato internazionale. Nella contrattualistica transfrontaliera la scelta arbitrale è spesso preferita, perché il lodo circola con maggiore agevolezza rispetto alla sentenza grazie alle convenzioni internazionali sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi, e perché sottrae la lite al giudice nazionale di una delle parti, garantendo neutralità del foro. La sede va scelta con cura, poiché ne discende la lex arbitri e il regime dei controlli giudiziari sul lodo.

Occorre avvertire il cliente che la sede della mediazione e la lingua non sono dettagli formali: la sede incide sui costi di trasferta e sulla comodità logistica, mentre la lingua condiziona la scelta del mediatore e la comprensione reciproca. Nei rapporti con controparti extraeuropee è prudente verificare che lo Stato della controparte assicuri l'esecutività degli accordi di mediazione, poiché un accordo non eseguibile nel Paese del debitore vanifica il risultato conciliativo. La clausola va infine coordinata con le eventuali norme imperative del foro competente, che possono limitare l'autonomia delle parti nella scelta della legge e della giurisdizione.

8. Clausola per rapporti societari

Testo:

- Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sono sottoposte a mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da esso adottato.
- La presente clausola vincola la società, tutti i soci, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, i quali con l'accettazione della carica aderiscono alla presente previsione statutaria. Essa vincola altresì coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
- La domanda di mediazione, a cura della parte più diligente, è comunicata alla società e a tutti i soggetti la cui partecipazione sia necessaria in relazione all'oggetto della controversia.
- L'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie di cui al comma 1. Restano ferme le disposizioni inderogabili in materia di controversie societarie e le competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Commento redazionale:

La clausola statutaria di mediazione presenta caratteri peculiari che la distinguono dalla clausola inserita in un contratto sinallagmatico. La sua fonte è l'atto costitutivo o lo statuto, e la sua efficacia si estende non solo ai soci originari ma a tutti coloro che entrano nella compagine sociale o assumono cariche, in forza del principio di adesione allo statuto. Il secondo comma esplicita questo effetto espansivo, chiarendo che amministratori, sindaci e liquidatori sono vincolati con l'accettazione della carica, e attraendo nella clausola anche le controversie sulla stessa qualità di socio, che sono tra le più frequenti nella patologia dei rapporti sociali.

La delimitazione ai diritti disponibili è imprescindibile. La materia societaria è densa di posizioni indisponibili e di interessi di terzi, e non tutte le controversie endosocietarie sono mediabili né compromettibili. La clausola circoscrive perciò il proprio ambito ai diritti disponibili relativi al rapporto sociale, includendo espressamente le liti sulla validità delle delibere assembleari, che pure toccano interessi sensibili e la cui mediabilità va apprezzata caso per caso in relazione alla natura del vizio dedotto e degli interessi coinvolti.

Il terzo comma affronta il problema della pluralità delle parti, tipico del contenzioso societario. A differenza della lite bilaterale, la controversia societaria coinvolge spesso una pluralità di soci e la società stessa, sicché la clausola deve assicurare che la domanda di mediazione raggiunga tutti i soggetti la cui partecipazione è necessaria, pena l'inefficacia del tentativo rispetto ai pretermessi. L'onere è posto a carico della parte più diligente, formula che responsabilizza chi promuove la procedura.

Il quarto comma qualifica l'esperimento come condizione di procedibilità e fa salve le norme inderogabili del processo societario e le competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa. La riserva è necessaria perché la mediazione non può derogare né alle regole di competenza funzionale né alle tutele previste per le controversie societarie. Si consideri, infine, che alcune materie societarie rientrano nell'elenco delle controversie a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, sicché per esse la clausola statutaria ha valore ricognitivo dell'obbligo legale, mentre per le altre introduce una condizione di procedibilità di fonte statutaria vincolante per tutti gli aderenti.

9. Clausola per contratti di appalto e costruzioni

Testo:

- Ogni controversia relativa al presente contratto di appalto, ivi

comprese quelle concernenti la corretta esecuzione delle opere, la conformità al progetto e alle regole dell'arte, i vizi e le difformità, le riserve, le varianti, la contabilità dei lavori, i pagamenti e la risoluzione del contratto, è sottoposta a mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da esso adottato.

- Le parti convengono che, ove la controversia richieda accertamenti

di natura tecnica, il mediatore, con il consenso delle parti, possa avvalersi di un esperto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il cui compenso è anticipato dalle parti in solido, salvo diversa determinazione in sede di accordo.

- La domanda di mediazione non sospende i termini di decadenza e di

prescrizione relativi alla denuncia dei vizi e alla garanzia, che le parti si obbligano a rispettare mediante distinta e tempestiva comunicazione, salvi gli effetti sospensivi e interruttivi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

- L'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità di ogni

domanda giudiziale o arbitrale relativa alle materie di cui al comma 1. Resta salva la facoltà di richiedere l'accertamento tecnico preventivo e i provvedimenti d'urgenza.

Commento redazionale:

Il contenzioso in materia di appalti e costruzioni è connotato da una spiccata componente tecnica: l'accertamento dei vizi, la valutazione della conformità alle regole dell'arte, la quantificazione delle riserve e la contabilità dei lavori richiedono competenze specialistiche che il giudizio ordinario affronta con costose e lunghe consulenze tecniche. La mediazione offre in questo settore un vantaggio competitivo, poiché consente di innestare l'apporto tecnico nel procedimento conciliativo in forma più agile. Il secondo comma valorizza questa opportunità richiamando la facoltà del mediatore di avvalersi di un esperto ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, con il consenso delle parti e la regolamentazione dell'anticipo del compenso, così da comporre la lite sulla base di una valutazione tecnica condivisa anziché di due contrapposte perizie di parte.

Il primo comma delimita l'ambito oggettivo con un elenco che copre le tipiche fonti di conflitto nel rapporto d'appalto, dalle difformità e vizi alle riserve, dalle varianti alla contabilità e ai pagamenti. La ricchezza dell'elenco non è pleonastica: nel contenzioso edilizio è frequente il tentativo di qualificare la pretesa come estranea alla clausola, e l'enumerazione previene tali eccezioni.

Il terzo comma affronta un profilo di grande rilievo pratico, il rapporto tra mediazione e termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi. La disciplina dell'appalto prevede termini brevi e perentori per la denuncia dei vizi, e l'avvio della mediazione, se pure produce effetti sospensivi e interruttivi sulla prescrizione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, non esonera la parte dall'onere di una tempestiva e distinta denuncia. La clausola richiama espressamente le parti al rispetto di tali termini, per evitare che l'affidamento nella mediazione induca a trascurare adempimenti la cui omissione è fonte di decadenza. È questo un punto su cui il professionista deve richiamare con forza l'attenzione del cliente committente.

Il quarto comma qualifica l'esperimento come condizione di procedibilità e fa salvi l'accertamento tecnico preventivo e i provvedimenti d'urgenza, strumenti frequentemente utilizzati nel settore per cristallizzare lo stato dei luoghi prima che le opere vengano modificate. La salvezza è essenziale perché la necessità di documentare tempestivamente i vizi non può essere sacrificata all'obbligo di mediazione.

10. Clausola per contratti bancari e finanziari

Testo:

- Ogni controversia relativa al presente contratto e al rapporto che

ne deriva, ivi comprese quelle concernenti la validità e l'efficacia delle clausole, il calcolo degli interessi e degli oneri, l'anatocismo, le commissioni, l'estinzione anticipata e la corretta esecuzione del rapporto, è sottoposta a mediazione presso [organismo di mediazione], secondo il regolamento da esso adottato.

- Il cliente prende atto che, per le materie bancarie e finanziarie,

l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che tale condizione può essere assolta, in alternativa, mediante il procedimento innanzi all'organo di risoluzione stragiudiziale competente per materia, ove previsto dalla legge.

- La presente clausola non pregiudica i diritti riconosciuti al

cliente dalla disciplina inderogabile a tutela del consumatore e dell'utente dei servizi bancari e finanziari, né la facoltà di rivolgersi agli organi di vigilanza e agli strumenti di tutela previsti dalla legge.

- Le parti si obbligano a partecipare personalmente, o mediante

rappresentante munito dei necessari poteri, al procedimento di mediazione, e a comportarsi secondo buona fede.

Commento redazionale:

I contratti bancari e finanziari rientrano tra le materie a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sicché la clausola ha per esse valore prevalentemente ricognitivo dell'obbligo di legge. Il secondo comma dà espressamente atto di questa natura e richiama la peculiarità del settore, nel quale la condizione di procedibilità può essere assolta, in alternativa alla mediazione, mediante il ricorso all'organo di risoluzione stragiudiziale competente per la materia bancaria e finanziaria. Questa duplicità di percorsi è propria del comparto e va segnalata al cliente, che deve conoscere entrambe le vie e i rispettivi vantaggi in termini di costi e tempi.

Il primo comma enumera le tipiche materie del contenzioso bancario, dall'anatocismo alle commissioni, dagli interessi all'estinzione anticipata, così da attrarre nella clausola l'intero ventaglio delle contestazioni che sorgono nei rapporti di conto corrente, di mutuo e di finanziamento. L'elenco previene la sottrazione della singola pretesa alla clausola mediante una sua qualificazione formale.

Il terzo comma è dettato da un'ineludibile cautela deontologica e di conformità normativa. Nei contratti conclusi con clienti consumatori o utenti, la disciplina di protezione è inderogabile e non può essere elusa da clausole predisposte dall'intermediario. La clausola precisa perciò di non pregiudicare i diritti del cliente, la facoltà di adire gli organi di vigilanza e gli strumenti di tutela di legge. La precisazione è necessaria per evitare che la clausola, inserita in un contratto per adesione, possa essere reputata vessatoria o comunque lesiva delle tutele imperative. Va ricordato che le clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni o di proporre azioni possono richiedere la specifica approvazione per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e sono soggette al controllo di vessatorietà nei contratti con i consumatori.

Il quarto comma richiama l'obbligo di partecipazione personale o tramite rappresentante munito di poteri, in linea con l'orientamento che, dopo la riforma Cartabia, esige la presenza effettiva di soggetti in grado di disporre della materia. Nel contenzioso bancario, dove una parte è tipicamente un ente strutturato, questo profilo è particolarmente rilevante: la banca deve presentarsi con un rappresentante realmente legittimato a transigere, non con un mero incaricato privo di poteri sostanziali. Il professionista avvertirà il cliente che una clausola siffatta, in una materia obbligatoria per legge, non aggiunge un onere nuovo ma organizza e chiarisce un obbligo già esistente.

B) Modelli di verbale di conciliazione

1. Verbale di conciliazione in materia di locazione

Testo:

« [Organismo di mediazione], iscritto al n. [numero] del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia — Sede di [Città], via [indirizzo]
VERBALE DI CONCILIAZIONE — Procedura di mediazione n. [numero]/[anno]
Oggetto: controversia in materia di locazione a uso abitativo relativa all'immobile sito in [Città], via [indirizzo]. L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], alle ore [ora], presso la sede dell'organismo, si è svolto l'incontro di mediazione. Sono presenti: — la parte istante [nome e cognome], nata a [luogo] il [data], codice fiscale [codice], nella qualità di locatore, assistita dall'avvocato [nome e cognome] del foro di [Città]; — la parte invitata [nome e cognome], nata a [luogo] il [data], codice fiscale [codice], nella qualità di conduttore, assistita dall'avvocato [nome e cognome] del foro di [Città]. Interviene quale mediatore designato [nome e cognome], iscritto nell'elenco dei mediatori dell'organismo, il quale dà atto di avere reso alle parti le informazioni sulla funzione e sulle modalità della mediazione e di avere verificato l'assenza di cause di incompatibilità. Le parti, esposte le rispettive ragioni in ordine alla morosità del conduttore quantificata in euro [importo] e alla richiesta di rilascio dell'immobile, con l'assistenza del mediatore raggiungono il seguente accordo conciliativo: 1) il conduttore riconosce di essere debitore verso il locatore della somma di euro [importo] a titolo di canoni scaduti e oneri accessori; 2) il conduttore si obbliga a versare la predetta somma in numero [numero] rate mensili di euro [importo] ciascuna, con scadenza il giorno [giorno] di ogni mese, mediante bonifico sul conto [IBAN]; 3) il conduttore si obbliga a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro e non oltre il giorno [data]; il locatore rinuncia alla domanda di risoluzione a condizione dell'esatto adempimento; 4) le spese della procedura di mediazione sono poste a carico delle parti in misura pari alla metà ciascuna; le parti rinunciano a ogni reciproca pretesa relativa alla presente controversia diversa da quanto sopra convenuto. Il mediatore dà atto che l'accordo è stato raggiunto e che le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il presente verbale, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Letto, confermato e sottoscritto. Il locatore ____ Il conduttore ____ L'avvocato ____ L'avvocato ____ Il mediatore ____ »

Commento redazionale:

Il verbale di conciliazione in materia locatizia deve conciliare l'esigenza di realismo con quella di correttezza deontologica. La struttura riproduce fedelmente l'ossatura di un verbale autentico: intestazione dell'organismo con gli estremi di iscrizione al registro ministeriale, individuazione della procedura, indicazione di data, luogo e presenti, con la specificazione delle qualità di locatore e conduttore, e menzione dell'assistenza legale. La presenza degli avvocati non è formalità: è il presupposto per l'efficacia di titolo esecutivo del verbale ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010, che ancora tale efficacia alla sottoscrizione dei difensori e alla loro attestazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La parte dispositiva è congegnata come un tipico accordo transattivo su morosità e rilascio, le due voci intorno a cui ruota la quasi totalità delle liti locatizie. Il riconoscimento del debito, la sua rateizzazione con modalità e scadenze precise e l'impegno al rilascio entro un termine certo sono formulati in modo da essere concretamente eseguibili in caso di inadempimento, poiché un accordo generico non offre al creditore un titolo azionabile. La clausola che subordina la rinuncia alla risoluzione all'esatto adempimento tutela il locatore contro il rischio che la conciliazione si traduca in una mera dilazione priva di garanzie.

La menzione della funzione di titolo esecutivo è redatta con puntualità, richiamando l'art. 12 d.lgs. 28/2010 nella formulazione risultante dalla riforma Cartabia di cui al d.lgs. 149/2022, e specificando le tre direzioni dell'esecutività: espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale. Questa specificazione ha valore pratico, perché nel contenzioso locatizio interessano tanto il recupero del credito quanto il rilascio dell'immobile, quest'ultimo eseguibile in forma specifica.

Sul piano deontologico, il modello è realistico ma non ingannevole. Non attribuisce al verbale effetti che la legge non gli riconosce, non simula la partecipazione di soggetti assenti e non occulta la ripartizione delle spese. La formula di chiusura, con la sottoscrizione delle parti, dei difensori e del mediatore, riflette il reale procedimento di formazione del titolo. Il professionista che utilizzi il modello deve adattarne il contenuto alla concreta vicenda, verificando in particolare la capienza e la reale volontà delle parti, poiché un verbale che documenti un accordo non effettivamente raggiunto o non compreso sarebbe gravemente scorretto oltre che invalido.

2. Verbale di conciliazione in materia condominiale

Testo:

« [Organismo di mediazione], iscritto al n. [numero] del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia — Sede di [Città] VERBALE DI CONCILIAZIONE — Procedura di mediazione n. [numero]/[anno] Oggetto: controversia in materia condominiale relativa a [impugnazione della delibera assembleare del [data] / riparto delle spese / opere sulle parti comuni] del Condominio [denominazione], sito in [Città], via [indirizzo], codice fiscale [codice]. L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], presso la sede dell'organismo, si è svolto l'incontro di mediazione. Sono presenti: — per il Condominio [denominazione], l'amministratore [nome e cognome], munito di autorizzazione dell'assemblea del [data] a partecipare alla mediazione e a conciliare nei limiti

deliberati, assistito dall'avvocato [nome e cognome]; — il condòmino istante [nome e cognome], codice fiscale [codice], assistito dall'avvocato [nome e cognome]. Interviene quale mediatore [nome e cognome], iscritto nell'elenco dei mediatori dell'organismo. Le parti, con l'assistenza del mediatore, raggiungono il seguente accordo: 1) il condòmino istante rinuncia all'impugnazione della delibera assembleare del [data] limitatamente al punto [numero] all'ordine del giorno; 2) il Condominio, nei limiti dell'autorizzazione assembleare, riconosce al condòmino istante il ricalcolo della quota di spesa relativa a [voce di spesa] nella misura di euro [importo], da portare in compensazione con i futuri oneri condominiali; 3) il Condominio si obbliga a eseguire i lavori di [descrizione] sulle parti comuni entro il [data], secondo le modalità deliberate; 4) le spese della procedura sono ripartite tra le parti in misura pari alla metà ciascuna. Il mediatore dà atto che l'amministratore ha esibito il verbale di assemblea del [data] contenente l'autorizzazione a conciliare e che l'accordo rientra nei limiti di tale autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il presente verbale, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo. Letto, confermato e sottoscritto. L'amministratore ____ Il condòmino ____ L'avvocato ____ L'avvocato ____ Il mediatore ____ »

Commento redazionale:

Il verbale di conciliazione in materia condominiale presenta una peculiarità che il modello mette in adeguata evidenza: il problema dei poteri dell'amministratore. Il condominio non è persona giuridica e agisce in mediazione a mezzo dell'amministratore, il quale, tuttavia, non dispone di un potere illimitato di transigere. La disciplina condominiale richiede che l'amministratore sia autorizzato dall'assemblea a partecipare alla mediazione e a conciliare, e nei limiti del mandato ricevuto. Per questo il modello indica espressamente l'autorizzazione assembleare, la data della delibera e i limiti entro cui l'amministratore può disporre, e prevede che il mediatore dia atto dell'esibizione del relativo verbale. Questa cautela non è pleonastica: un accordo concluso dall'amministratore in eccesso rispetto ai poteri conferiti sarebbe inefficace verso il condominio, con grave pregiudizio della controparte che vi abbia fatto affidamento.

L'oggetto è formulato in modo da coprire le tre tipologie ricorrenti di lite condominiale, l'impugnazione delle delibere, il riparto delle spese e le opere sulle parti comuni, materie tutte rientranti nell'elenco delle controversie a mediazione obbligatoria. La parte dispositiva riflette un accordo che compone la lite senza travalicare i poteri deliberativi dell'assemblea: la rinuncia all'impugnazione è limitata a uno specifico punto, il ricalcolo della quota avviene per compensazione con futuri oneri e l'impegno esecutivo sui lavori richiama le modalità già deliberate. Questa costruzione evita che il verbale disponga di materie riservate all'assemblea o pregiudichi i condòmini estranei alla lite.

Il richiamo all'art. 12 d.lgs. 28/2010 conferisce al verbale efficacia di titolo esecutivo, subordinatamente alla sottoscrizione dei difensori e all'attestazione di conformità. Nel contenzioso condominiale l'esecutività è di particolare interesse per il recupero delle somme riconosciute e per l'attuazione degli obblighi di fare relativi alle parti comuni.

Sotto il profilo deontologico, il modello è realistico e insieme corretto perché non maschera il limite dei poteri dell'amministratore, anzi lo pone in primo piano come condizione di validità dell'accordo. Il professionista che assista il condòmino istante deve pretendere l'esibizione dell'autorizzazione assembleare prima di sottoscrivere, mentre chi assista il condominio deve verificare che l'accordo non ecceda il mandato, pena la sua inefficacia. Il modello educa a questa duplice verifica, che è il presidio di serietà della conciliazione condominiale.

3. Verbale di conciliazione in materia di contratti commerciali

Testo:

« [Organismo di mediazione], iscritto al n. [numero] del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia — Sede di [Città] VERBALE DI CONCILIAZIONE — Procedura di mediazione n. [numero]/[anno] Oggetto: controversia relativa al contratto di [fornitura/somministrazione/distribuzione] concluso in data [data] tra [denominazione società istante] e [denominazione società invitata], avente a oggetto [descrizione]. L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], presso la sede dell'organismo, in modalità [in presenza / telematica], si è svolto l'incontro di mediazione. Sono presenti: — per [denominazione società istante], con sede in [Città], partita IVA [numero], il legale rappresentante [nome e cognome] [ovvero il procuratore [nome e cognome], giusta procura speciale che si allega], assistito dall'avvocato [nome e cognome]; — per [denominazione società invitata], con sede in [Città], partita IVA [numero], il legale rappresentante [nome e cognome], assistito dall'avvocato [nome e cognome]. Interviene quale mediatore [nome e cognome], iscritto nell'elenco dei mediatori dell'organismo. Le parti, esposte le rispettive ragioni in ordine alle forniture contestate e al credito azionato di euro [importo], con l'assistenza del mediatore raggiungono il seguente accordo: 1) le parti concordano che il credito complessivo di [denominazione società istante] è determinato in via transattiva in euro [importo], a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa al rapporto in oggetto; 2) [denominazione società invitata] si obbliga a corrispondere la predetta somma entro il [data], mediante bonifico sul conto [IBAN]; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza convenuta l'intero residuo diviene immediatamente esigibile; 3) le parti [proseguono / risolvono consensualmente] il rapporto contrattuale alle seguenti condizioni: [condizioni]; 4) le parti si rilasciano reciproca e ampia quietanza liberatoria relativamente al rapporto in oggetto, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa; le spese della procedura sono a carico di [parte] / ripartite in misura pari alla metà ciascuna. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il presente verbale, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Letto, confermato e sottoscritto. Per l'istante ____ Per l'invitata ____ L'avvocato ____ L'avvocato ____ Il mediatore ____ »

Commento redazionale:

Il verbale in materia di contratti commerciali si distingue per il rilievo dei profili di rappresentanza organica e per la centralità della transazione sul credito. Trattandosi di parti

che sono società, il modello dà atto della qualità di legale rappresentante o, in alternativa, di procuratore munito di procura speciale, prevedendone l'allegazione. Il punto è cruciale: la conciliazione conclusa da chi difetti del potere di rappresentare la società o di disporre della materia è inefficace, e la giurisprudenza in tema di partecipazione alla mediazione esige la presenza di soggetti dotati di poteri sostanziali. L'allegazione della procura al verbale documenta il potere e previene future contestazioni sulla riferibilità dell'accordo alla società.

La parte dispositiva è modellata sulla figura tipica dell'accordo a saldo e stralcio, con determinazione transattiva del credito, impegno al pagamento entro termine certo e clausola di decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento. Quest'ultima clausola, per cui il mancato pagamento di una sola rata rende esigibile l'intero residuo, è essenziale per dare effettività al titolo esecutivo e va sempre inserita negli accordi rateizzati, poiché in sua assenza il creditore dovrebbe agire separatamente per ciascuna rata scaduta.

Il modello prevede l'alternativa tra prosecuzione e risoluzione consensuale del rapporto, poiché nel contenzioso commerciale la lite può sfociare tanto nella conservazione del rapporto a condizioni riviste quanto nel suo scioglimento. La reciproca quietanza liberatoria, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa, chiude definitivamente la vicenda ed evita il riemergere di code contenziose. La menzione della modalità telematica dell'incontro riflette una prassi ormai consolidata e pienamente legittima, particolarmente utile quando le società hanno sedi distanti.

Il richiamo all'art. 12 d.lgs. 28/2010 conferisce al verbale efficacia esecutiva, di grande interesse nel recupero dei crediti commerciali. Sul piano deontologico il modello è realistico ma non ingannevole: non attribuisce al verbale valore di prova privilegiata che non gli spetta, non simula poteri rappresentativi inesistenti e documenta con trasparenza la ripartizione delle spese. Il professionista deve verificare la reale legittimazione di chi sottoscrive per la società e la coerenza dell'accordo con le eventuali autorizzazioni interne richieste dallo statuto sociale, poiché operazioni di rilievo possono esigere delibere degli organi competenti. L'accortezza nella verifica dei poteri è ciò che distingue un accordo commerciale solido da uno esposto a impugnazione.

4. Verbale di conciliazione in materia di responsabilità medica

Testo:

« [Organismo di mediazione], iscritto al n. [numero] del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia — Sede di [Città] VERBALE DI CONCILIAZIONE — Procedura di mediazione n. [numero]/[anno] Oggetto: controversia in materia di responsabilità sanitaria relativa alle prestazioni erogate a [nome e cognome del paziente] presso [struttura sanitaria] nel periodo [date]. L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], presso la sede dell'organismo, si è svolto l'incontro di mediazione. Sono presenti: — la parte istante [nome e cognome], codice fiscale [codice], quale [paziente / erede di [nome]], assistita dall'avvocato [nome e cognome]; — [struttura sanitaria], con sede in [Città], in persona del legale rappresentante [ovvero del procuratore] [nome e cognome], assistita dall'avvocato [nome e cognome]; — [impresa di assicurazione], con sede in [Città], in persona del procuratore [nome e cognome], munito dei poteri di transigere, assistita dall'avvocato [nome e cognome]. Interviene quale mediatore [nome e cognome]. Le parti danno atto che nel corso della procedura ci si è avvalsi, con il consenso di tutte, del contributo

dell'esperto [nome e cognome], specialista in [disciplina], ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Le parti, all'esito della valutazione tecnica e con l'assistenza del mediatore, raggiungono il seguente accordo: 1) [struttura sanitaria] e [impresa di assicurazione] si obbligano, in via transattiva e senza riconoscimento di responsabilità, a corrispondere alla parte istante la somma complessiva di euro [importo] a titolo di integrale ristoro di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale connesso ai fatti in oggetto; 2) il pagamento è effettuato entro il [data] mediante bonifico sul conto [IBAN] indicato dalla parte istante; 3) la parte istante, a fronte del pagamento, dichiara di essere integralmente soddisfatta e rilascia ampia e liberatoria quietanza, rinunciando a ogni ulteriore pretesa, in sede civile e in ogni altra sede, nei confronti della struttura, dei sanitari e dell'impresa di assicurazione relativamente ai fatti in oggetto; 4) le spese della procedura di mediazione e il compenso dell'esperto sono a carico di [parte], nella misura di euro [importo]. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il presente verbale, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo. Letto, confermato e sottoscritto. La parte istante ____ Per la struttura ____ Per l'assicuratore ____ Gli avvocati ____ Il mediatore ____ »

Commento redazionale:

Il verbale in materia di responsabilità medica presenta il grado più elevato di complessità tra i modelli qui raccolti, per la pluralità dei soggetti coinvolti e per la centralità dell'accertamento tecnico. La materia rientra tra quelle a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, e la sua peculiarità è la partecipazione non solo del paziente danneggiato e della struttura sanitaria, ma anche dell'impresa di assicurazione, la cui presenza in mediazione è imposta dalla disciplina della responsabilità sanitaria. Il modello dà atto della presenza dell'assicuratore in persona di un procuratore munito dei poteri di transigere, requisito indispensabile perché la mediazione approdi a un accordo effettivamente vincolante per chi deve materialmente pagare l'indennizzo.

Il modello valorizza l'apporto dell'esperto ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010. Nel contenzioso sanitario la valutazione del nesso causale e della condotta colposa richiede competenze medico-legali, e la possibilità di acquisire in mediazione, con il consenso delle parti, un contributo tecnico condiviso consente di superare la contrapposizione tra le consulenze di parte e di fondare la transazione su una base tecnica accettata da tutti. Questa è una delle ragioni per cui la mediazione sanitaria, quando ben condotta, offre esiti che il giudizio raggiunge solo dopo anni e a costi elevati.

La formula transattiva è redatta senza riconoscimento di responsabilità, clausola di prassi in materia assicurativa che consente alla struttura e all'assicuratore di definire la lite senza ammissioni suscettibili di riverberare su altri contenziosi o sul rapporto assicurativo. La quietanza liberatoria è ampia e copre la struttura, i sanitari e l'assicuratore, così da evitare azioni residue nei confronti dei singoli professionisti. La determinazione della somma a titolo di integrale ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale chiude ogni voce risarcitoria.

Sul piano deontologico occorre la massima cautela. Il modello è realistico ma non ingannevole: non attribuisce alla transazione il valore di accertamento della verità dei fatti, che essa non ha,

e rende trasparente la clausola di assenza di riconoscimento di responsabilità, così che il paziente comprenda la natura dell'accordo. Il professionista che assista il danneggiato deve verificare la congruità della somma rispetto all'entità del danno e assicurarsi che il cliente comprenda il carattere definitivo della rinuncia, poiché una transazione affrettata su un danno alla persona è particolarmente delicata. La presenza dell'assicuratore con effettivi poteri di transigere va accertata in concreto, poiché un accordo sottoscritto da chi non possa impegnare la compagnia sarebbe privo di utilità pratica.

5. Verbale di conciliazione in materia di contratti bancari

Testo:

« [Organismo di mediazione], iscritto al n. [numero] del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia — Sede di [Città] VERBALE DI CONCILIAZIONE — Procedura di mediazione n. [numero]/[anno] Oggetto: controversia in materia bancaria relativa al contratto di [conto corrente / mutuo / apertura di credito] n. [numero] concluso in data [data] tra [nome e cognome del cliente] e [denominazione dell'istituto di credito]. L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], presso la sede dell'organismo, si è svolto l'incontro di mediazione. Sono presenti: — la parte istante [nome e cognome], codice fiscale [codice], nella qualità di cliente, assistita dall'avvocato [nome e cognome]; — [denominazione dell'istituto di credito], con sede in [Città], in persona del procuratore [nome e cognome], munito di procura speciale con poteri di conciliare e transigere che si allega, assistito dall'avvocato [nome e cognome]. Interviene quale mediatore [nome e cognome], iscritto nell'elenco dei mediatori dell'organismo. Le parti, esposte le rispettive ragioni in ordine alle contestazioni relative al calcolo degli interessi, all'anatocismo e alle commissioni applicate al rapporto in oggetto, con l'assistenza del mediatore raggiungono il seguente accordo: 1) [denominazione dell'istituto di credito] riconosce in via transattiva a favore della parte istante un importo di euro [importo], da imputarsi [a storno del saldo debitore / a rimborso], a definizione di ogni contestazione relativa al rapporto in oggetto; 2) le parti concordano che, per effetto del presente accordo, il saldo del rapporto è rideterminato in euro [importo], che la parte istante si obbliga a versare in numero [numero] rate mensili di euro [importo] ciascuna, con scadenza il giorno [giorno] di ogni mese; 3) le parti si rilasciano reciproca quietanza liberatoria relativamente al rapporto in oggetto, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa, ferme restando le tutele inderogabili riconosciute alla parte istante quale cliente dei servizi bancari; 4) le spese della procedura sono ripartite in misura pari alla metà ciascuna. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il presente verbale, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo. Letto, confermato e sottoscritto. La parte istante ____ Per l'istituto di credito ____ L'avvocato ____ L'avvocato ____ Il mediatore ____ »

Commento redazionale:

Il verbale in materia bancaria chiude la rassegna e riprende i profili già segnalati a proposito della relativa clausola. La materia è a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, e il contenzioso ha per oggetto tipico le contestazioni sul calcolo degli interessi, sull'anatocismo

e sulle commissioni, come il modello esplicita nell'esposizione delle ragioni. La peculiarità è la struttura fortemente asimmetrica delle parti: da un lato il cliente, spesso consumatore, dall'altro un istituto di credito, ente organizzato che partecipa a mezzo di un procuratore. Il modello richiede che tale procuratore sia munito di procura speciale con espressi poteri di conciliare e transigere, e ne prevede l'allegazione al verbale. Questa esigenza è tanto più stringente in un settore nel quale l'istituto tende a farsi rappresentare da incaricati privi di reale potere dispositivo, con il rischio di una partecipazione meramente formale che la giurisprudenza recente censura.

La parte dispositiva riflette la fisiologia dell'accordo bancario: il riconoscimento transattivo di un importo a favore del cliente, la rideterminazione del saldo del rapporto e, ove residui un debito, la sua rateizzazione. La clausola di reciproca quietanza chiude la lite, ma è temperata dalla salvezza delle tutele inderogabili riconosciute al cliente. Questa riserva è imprescindibile: nei rapporti con i consumatori e gli utenti dei servizi bancari la disciplina di protezione non può essere abdicata mediante rinunce onnicomprensive, e un verbale che pretendesse di travolgere anche i diritti indisponibili sarebbe in parte qua inefficace, oltre che deontologicamente scorretto se predisposto per approfittare della disparità di forza contrattuale.

Il richiamo all'art. 12 d.lgs. 28/2010 conferisce efficacia esecutiva al verbale, utile per l'attuazione degli impegni di pagamento reciproci. Sul piano deontologico il modello è costruito per essere realistico senza ingannare: rende trasparente la natura transattiva delle reciproche concessioni, non attribuisce all'accordo l'effetto di sanare vizi che la legge riserva a tutela inderogabile del cliente e documenta i poteri del procuratore dell'istituto. Il professionista che assista il cliente deve verificare la congruità dell'importo riconosciuto rispetto alle contestazioni fondate, spesso quantificabili solo mediante perizia contabile, e cautelarsi contro il rischio che una transazione affrettata comporti la rinuncia a pretese di importo ben superiore. La verifica dei poteri del procuratore bancario e la salvaguardia delle tutele inderogabili sono i due presidi di correttezza che il modello mira a promuovere.

C) Modello di informativa scritta al cliente ex art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010

Informativa sulla mediazione aggiornata alla riforma Cartabia

Testo:

« Avv. [nome e cognome] — Foro di [Città] — via [indirizzo] — PEC [indirizzo]
INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) Egregio/Gentile [nome e cognome del cliente], in adempimento dell'obbligo di legge, all'atto del conferimento dell'incarico La informo di quanto segue. »

- > La facoltà di ricorrere alla mediazione e i suoi vantaggi. Ogni > controversia in materia civile e commerciale relativa a diritti > disponibili può essere risolta, in via alternativa al giudizio, > mediante il procedimento di mediazione, che si svolge davanti a un > organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della > giustizia, con l'assistenza di un mediatore terzo e imparziale. La > mediazione mira a raggiungere un accordo amichevole e offre, di > norma, tempi più rapidi e costi inferiori rispetto al giudizio.

- > Le agevolazioni fiscali. Al procedimento di mediazione si

> applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge, tra cui > l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto > per gli atti del procedimento, l'esenzione dall'imposta di > registro del verbale di accordo entro il limite di valore > stabilito dalla legge e il riconoscimento, nei limiti e alle > condizioni di legge, di un credito d'imposta commisurato alle > indennità corrisposte all'organismo e ai compensi dell'avvocato, > nonché del patrocinio a spese dello Stato per chi versi nelle > condizioni previste.

- > I casi di mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità).

> Per le controversie in materia di condominio, diritti reali, > divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, > comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da > responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa > o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e > finanziari, nonché nelle ulteriori materie previste dalla legge, > l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di > procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve > essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata > d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, ove > rilevi che la mediazione non è stata esperita o non è iniziata, > assegna alle parti il termine per la sua presentazione.

- > La mediazione demandata dal giudice. Anche fuori dei casi

> obbligatori, il giudice può disporre l'esperimento del > procedimento di mediazione, e il relativo esperimento diviene > condizione di procedibilità della domanda.

- > La partecipazione e le conseguenze della mancata partecipazione.

> Le parti partecipano personalmente alla mediazione, con > l'assistenza dell'avvocato. In presenza di giustificati motivi la > parte può delegare a partecipare un proprio rappresentante, che > deve essere a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari > per la composizione della controversia. Dalla mancata > partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il > giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e > condanna la parte costituita che non vi ha preso parte al > versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di > importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il > giudizio.

- > L'efficacia dell'accordo. Il verbale di accordo sottoscritto dalle

> parti e dai rispettivi avvocati, che ne attestano la conformità > alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo > esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma > specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi > dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

- > I costi. Le indennità dovute all'organismo di mediazione sono

> determinate secondo il decreto del Ministro della giustizia 24 > ottobre 2023, n. 150, in ragione del valore della controversia, e > sono dovute nella misura ridotta prevista per la fase del primo > incontro ove la procedura non prosegua oltre.

« Dichiaro di aver ricevuto la presente informativa e di essere stato edotto in modo chiaro e per iscritto sulla possibilità e, nei casi previsti, sull'obbligo di ricorrere alla

mediazione, nonché sulle relative agevolazioni fiscali. [Città], [data] Il cliente _____
L'avvocato _____ »

Commento redazionale:

L'informativa ex art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 assolve a un obbligo deontologico e professionale il cui inadempimento è sanzionato in modo peculiare: l'atto conferito senza la previa informazione scritta è annullabile su domanda del cliente, e la violazione costituisce illecito disciplinare. Il modello è perciò concepito per fornire una prova documentale certa dell'adempimento, chiudendosi con la dichiarazione di ricezione sottoscritta dal cliente, elemento che protegge il professionista da future contestazioni.

L'aggiornamento alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. 149/2022 investe più punti dell'informativa. Il terzo paragrafo recepisce l'ampliamento del catalogo delle materie a mediazione obbligatoria, che la riforma ha esteso a nuove ipotesi, e riflette il regime dell'improcedibilità, eccezione dal convenuto o rilevabile d'ufficio entro la prima udienza. Il quarto paragrafo dà conto della mediazione demandata dal giudice, istituto valorizzato dalla riforma quale strumento deflativo attivabile anche in corso di causa. Il quinto paragrafo è il più innovativo, poiché traduce in linguaggio accessibile il nuovo regime della partecipazione personale e delle sue eccezioni, nonché l'inasprimento delle conseguenze della mancata partecipazione, oggi comprensive tanto degli argomenti di prova quanto della sanzione pecuniaria parametrata al doppio del contributo unificato.

Il modello non si limita al minimo di legge, ma arricchisce l'informativa con i profili che più interessano il cliente nella scelta se aderire alla mediazione: le agevolazioni fiscali, l'efficacia esecutiva dell'accordo e i costi, questi ultimi ancorati al d.m. 150/2023 sulle indennità, con la precisazione della riduzione per la sola fase del primo incontro. Questa completezza risponde alla funzione sostanziale dell'informativa, che non è adempimento formale ma strumento di consapevolezza del cliente.

Sul piano redazionale, il testo adotta un registro piano e comprensibile al non giurista, evitando tecnicismi non necessari, poiché un'informativa incomprensibile tradisce la propria funzione. Il professionista deve consegnare l'informativa all'atto del conferimento dell'incarico e conservarne copia sottoscritta. È opportuno personalizzare il paragrafo terzo evidenziando se la specifica controversia del cliente rientri o meno tra quelle obbligatorie, poiché l'informazione generica va calata nel caso concreto per essere realmente utile. Il modello resta comunque valido come base uniforme da adattare alla singola vicenda.

D) Modello di domanda di mediazione

Domanda di mediazione

Testo:

« [Organismo di mediazione] — Sede di [Città] DOMANDA DI MEDIAZIONE (articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) Parte istante: [nome e cognome / denominazione], nato/a a [luogo] il [data] [ovvero con sede in [Città]], codice fiscale / partita IVA [numero], residente / domiciliato in [indirizzo], rappresentato/a e assistito/a dall'avvocato [nome e cognome] del foro di [Città], con studio in [indirizzo], PEC [indirizzo], presso il quale elegge domicilio, giusta procura in calce al

presente atto. Parte invitata: [nome e cognome / denominazione], con sede / residenza in [indirizzo], codice fiscale / partita IVA [numero], PEC [indirizzo], alla quale si chiede che l'organismo comunichi la presente domanda. Valore della controversia: euro [importo]. Materia: [indicazione della materia, con specificazione se rientrante tra quelle a mediazione obbligatoria ex articolo 5 d.lgs. 28/2010]. ESPOSIZIONE DEI FATTI 1. In data [data] le parti concludevano [descrizione del rapporto: contratto, natura, oggetto, corrispettivo]. 2. [Descrizione cronologica della vicenda e dell'inadempimento o della lesione lamentata, con indicazione degli importi, delle date e dei documenti rilevanti]. 3. Con [lettera / PEC] del [data] la parte istante contestava alla parte invitata [oggetto della contestazione] e la invitava a [richiesta], senza esito. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA La controversia ha a oggetto [sintesi della questione controversa e della pretesa fatta valere]. RICHIESTE La parte istante chiede che, con l'assistenza del mediatore, si pervenga a un accordo che preveda: a) [prima richiesta, es. il pagamento della somma di euro [importo] oltre interessi]; b) [seconda richiesta, es. la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto prestato]; c) [eventuale richiesta subordinata o alternativa]; d) la ripartizione delle spese della procedura secondo giustizia. Con riserva di meglio precisare e integrare le proprie ragioni e richieste nel corso del procedimento. ALLEGATI 1. Copia del contratto del [data]; 2. [documento]; 3. corrispondenza intercorsa tra le parti; 4. [perizia / documentazione tecnica o contabile]; 5. procura alle liti. Si chiede la fissazione del primo incontro e la comunicazione della presente domanda alla parte invitata al recapito sopra indicato. [Città], [data] Avv. [nome e cognome] _____ »

Commento redazionale:

La domanda di mediazione, pur non essendo soggetta ai rigori formali dell'atto di citazione, va redatta con cura poiché delimita l'ambito della procedura e produce effetti processuali e sostanziali di rilievo. Il deposito della domanda, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, sicché la sua corretta redazione, con l'esatta individuazione delle parti e dell'oggetto, è essenziale per non compromettere tali effetti. Il modello dà quindi rilievo all'identificazione compiuta delle parti, con i dati anagrafici o societari e i recapiti, e all'indicazione della parte invitata con l'indirizzo cui l'organismo dovrà comunicare la domanda, adempimento da cui dipende la regolare instaurazione del contraddittorio.

L'indicazione del valore e della materia non è formale: il valore determina le indennità dovute secondo il d.m. 150/2023 e la competenza per valore del giudice ai fini della corretta individuazione dell'organismo territorialmente competente ove rilevi, mentre la specificazione della materia consente di verificare se la controversia rientri tra quelle a mediazione obbligatoria, con le conseguenze in tema di procedibilità.

La struttura ricalca, opportunamente semplificata, quella di un atto introduttivo: esposizione dei fatti in forma cronologica e numerata, individuazione dell'oggetto della controversia e formulazione delle richieste. La narrativa dei fatti deve essere sufficientemente analitica da consentire al mediatore e alla controparte di comprendere la vicenda, ma non deve trasformarsi in un'arringa, poiché la mediazione non è un giudizio e un tono aggressivo pregiudica il clima conciliativo. Il modello raccomanda perciò un'esposizione ordinata e misurata.

Le richieste sono articolate in forma graduata, con l'indicazione delle pretese principali e di quelle subordinate o alternative, così da segnalare fin dall'inizio i possibili terreni di composizione. La clausola di riserva di meglio precisare mantiene flessibilità, evitando che l'istante resti vincolato a una prospettazione iniziale suscettibile di evolvere nel corso degli incontri. L'elenco degli allegati, comprensivo della procura, documenta le ragioni della pretesa e agevola la valutazione della controparte. Il professionista deve calibrare l'ampiezza della narrativa e degli allegati sul valore e sulla complessità della lite, evitando tanto la genericità che priva la domanda di forza persuasiva quanto la sovrabbondanza che appesantisce inutilmente la procedura. La domanda ben redatta è il primo atto di una strategia negoziale, non un mero adempimento di accesso.

E) Modello di procura speciale per la partecipazione in mediazione tramite delegato

Procura speciale a partecipare alla mediazione ex art. 8 d.lgs. 28/2010

Testo:

« PROCURA SPECIALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) Il sottoscritto [nome e cognome], nato a [luogo] il [data], codice fiscale [codice], residente in [indirizzo] [ovvero: la società [denominazione], con sede in [Città], partita IVA [numero], in persona del legale rappresentante pro tempore [nome e cognome], munito dei necessari poteri come da [visura / statuto]], PREMESSO — che è pendente / è in corso di instaurazione il procedimento di mediazione n. [numero]/[anno] presso [organismo di mediazione], sede di [Città], avente a oggetto [oggetto della controversia], tra il sottoscritto e [controparte]; — che, per giustificati motivi consistenti in [indicazione del motivo, es. impedimento personale, residenza in altra città, ragioni di salute, esigenze organizzative dell'ente], il sottoscritto non può partecipare personalmente all'incontro di mediazione; CONFERISCE PROCURA SPECIALE a [nome e cognome del delegato], nato a [luogo] il [data], codice fiscale [codice], affinché lo rappresenti nel procedimento di mediazione sopra indicato, con ogni più ampio potere e in particolare con i seguenti poteri sostanziali: 1) partecipare a tutti gli incontri di mediazione, anche in modalità telematica, e alle sessioni congiunte e separate, illustrando le ragioni del rappresentato; 2) essere pienamente a conoscenza dei fatti oggetto della controversia, sui quali il rappresentato dichiara di aver compiutamente informato il delegato; 3) disporre dei diritti oggetto della controversia nei limiti di seguito indicati, e in particolare transigere, conciliare, rinunciare, quietanzare, riconoscere in tutto o in parte le pretese avversarie, formulare e accettare proposte conciliative; 4) concludere e sottoscrivere l'accordo di conciliazione e il relativo verbale, con efficacia direttamente vincolante nei confronti del rappresentato, fino alla concorrenza dell'importo di euro [importo] / senza limiti di importo; 5) compiere ogni atto necessario o utile allo svolgimento della procedura e alla definizione della controversia. Il presente potere di disporre è conferito entro i seguenti limiti sostanziali: [indicazione dei limiti, es. importo massimo, condizioni essenziali dell'accordo]. Nei limiti così indicati il delegato è autorizzato a impegnare definitivamente il rappresentato senza necessità di ratifica. La presente procura è speciale e vale per il solo procedimento sopra indicato. [Città], [data] Firma del

rappresentato _____ [Autentica della sottoscrizione a cura di [avvocato / notaio], ovvero sottoscrizione con firma digitale / sottoscrizione la cui autografia è certificata dall'avvocato ai sensi di legge] »

Commento redazionale:

La procura per la partecipazione alla mediazione tramite delegato è divenuta oggetto di particolare attenzione dopo che la giurisprudenza, poi recepita dalla riforma Cartabia, ha chiarito che la partecipazione al procedimento deve essere di regola personale e che la delega è ammessa solo in presenza di giustificati motivi e a condizione che il delegato sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della lite. Il modello è costruito per soddisfare rigorosamente questi requisiti, la cui inosservanza equivale, secondo l'orientamento più severo, a mancata partecipazione, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

Il primo presidio è l'indicazione del giustificato motivo che impedisce la partecipazione personale. La premessa richiede l'esplicitazione della ragione concreta, poiché una delega priva di causa giustificatrice non è idonea a sottrarre la parte all'onere di comparire personalmente. Il modello invita quindi a specificare l'impedimento, sia esso personale, logistico, di salute o, per gli enti, di natura organizzativa.

Il secondo e più importante presidio è l'attribuzione di poteri sostanziali effettivi, non meramente formali. È questo il punto sul quale la giurisprudenza recente si mostra più esigente: non basta una procura che autorizzi genericamente a partecipare, occorre che il delegato sia investito del potere di disporre del diritto controverso, di transigere, di conciliare e di sottoscrivere un accordo direttamente vincolante per il rappresentato. Il modello enumera analiticamente tali poteri e, al punto quarto, chiarisce che l'accordo concluso dal delegato vincola immediatamente il rappresentato senza necessità di ratifica. La clausola che escluda la ratifica è decisiva, poiché una delega che subordini l'efficacia dell'accordo alla successiva approvazione del dominus svuota di contenuto la partecipazione e vanifica la funzione della mediazione, come la giurisprudenza ha ripetutamente affermato.

Il modello prevede la possibilità di fissare limiti sostanziali al potere di disporre, tipicamente un importo massimo o determinate condizioni essenziali. Questa previsione concilia l'esigenza di poteri effettivi con quella, legittima, del rappresentato di non conferire una delega illimitata: purché il delegato possa realmente concludere l'accordo entro i limiti indicati, senza necessità di ratifica, il requisito dei poteri sostanziali è soddisfatto. Il modello mette in guardia, per converso, contro i limiti così stringenti da ridurre il delegato a mero nuncius, che riproporrebbero il vizio della partecipazione fittizia.

Quanto alla forma, la procura speciale richiede la certezza della provenienza. Il modello contempla l'autentica della sottoscrizione, la firma digitale o la certificazione di autografia da parte dell'avvocato, secondo le modalità ammesse. Il professionista deve verificare che la procura sia effettivamente speciale e riferita al singolo procedimento, poiché una delega generica non risponde ai requisiti richiesti, e deve accertare che il delegato conosca realmente i fatti, elemento che non può essere surrogato da una mera dichiarazione di stile.

Appendice — Aggiornamento legislativo dell'Unione europea (2020–2026)

Legislazione vigente e riforme 2020–2026 sulla mediazione nei 27 Stati membri. Fonte: mediareinformati.it, luglio 2026.

Sintesi della legislazione vigente e delle riforme recenti (2020–2026) per ciascuno dei 27 Stati membri, a integrazione del catalogo storico della Parte I. Fonte: elaborazione mediareinformati.it su gazzette ufficiali e portali nazionali, verificata al luglio 2026.

Austria

La disciplina cardine è lo Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003, tuttora vigente nella versione consolidata e modificata da ultimo con BGBl. I 246/2021. La legge regola la mediazione in materia civile a carattere volontario, definendo la figura del mediatore iscritto (eingetragener Mediator) e istituendo un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con requisiti stringenti di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale. Un profilo qualificante è la sospensione della prescrizione e dei termini di decadenza per la durata della mediazione condotta da mediatore registrato, che incentiva il ricorso allo strumento senza pregiudizio per le posizioni sostanziali. Il procedimento è improntato a volontarietà, imparzialità e riservatezza: il mediatore è tenuto al segreto e gode di un privilegio testimoniale, con conseguente inutilizzabilità nel giudizio di quanto emerso in mediazione. La mediazione non costituisce condizione di procedibilità, restando facoltativa anche quando promossa dal giudice. L'accordo vincola le parti sul piano contrattuale e può acquisire efficacia esecutiva mediante atto notarile o omologazione. La modifica del 2021 ha aggiornato l'impianto, anche in coerenza con l'evoluzione del diritto europeo della mediazione.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Belgio

La mediazione belga è disciplinata nella Parte VII del Codice giudiziario (artt. 1723/1-1737), introdotta dalla loi del 21 febbraio 2005 e profondamente riformata dalla loi del 18 giugno 2018. Il codice distingue la mediazione volontaria da quella giudiziale disposta o suggerita dal giudice, coprendo le materie civili e commerciali disponibili, nonché ambiti familiari e sociali. La riforma del 2018 ha rafforzato la Commission fédérale de médiation, unico organo competente ad accreditare i mediatori, a fissarne gli standard di formazione e deontologia e a tenere la lista dei mediatori agréés; solo la mediazione condotta da mediatore accreditato consente l'omologazione dell'accordo. Il procedimento è connotato da volontarietà, imparzialità e riservatezza: le comunicazioni e i documenti formati in mediazione sono coperti da un rigoroso regime di confidenzialità e sono inutilizzabili nel giudizio, con corrispondente obbligo di segreto del mediatore. La mediazione non costituisce, in via generale, condizione di procedibilità, pur essendo fortemente promossa dal legislatore quale strumento deflativo, anche in attuazione della direttiva europea. L'accordo sottoscritto da mediatore accreditato può essere omologato dal giudice e acquisire efficacia esecutiva pari a quella di una sentenza.

Aggiornamento (2020–2026): Legge 15 gennaio 2024 (in vigore 1° gennaio 2025): mediazione preventiva obbligatoria (condizione di procedibilità) nelle liti condominiali, con certificato di

tentativo (CTM); primo incontro entro un mese. Regio Decreto 3 maggio 2024: accreditamento più rigoroso (150 ore ed esame). (in vigore/adozione: 2024-01-15). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Bulgaria

La Bulgaria è retta dallo *Zakon za mediatsiyata* (Legge sulla mediazione), SG 110/2004, più volte modificato, e dal Regolamento n. 2/2007 sulla formazione. Il quadro è stato profondamente innovato dalla legge di modifica del 2023 e, soprattutto, dalla riforma del Codice di procedura civile entrata in vigore il 12 luglio 2025, che ha introdotto all'art. 140a una sessione informativa obbligatoria sulla mediazione: in determinate categorie di controversie civili e commerciali il giudice può disporre che le parti partecipino a un primo incontro informativo, configurando così un'obbligatorietà settoriale del passaggio preliminare. La precedente riforma del 2023 che introduceva la mediazione obbligatoria era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale il 1° luglio 2024. Il procedimento conserva natura volontaria quanto all'esito, ed è retto da imparzialità, neutralità e riservatezza, con inutilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese in mediazione e obbligo di segreto del mediatore. La normativa disciplina i requisiti, la formazione e l'iscrizione dei mediatori in un registro unificato tenuto dal Ministero della Giustizia. L'accordo di mediazione vincola le parti e può conseguire efficacia esecutiva mediante omologazione. La riforma del 2025 segna un rafforzamento marcato dello strumento in chiave deflativa, in linea con gli orientamenti europei.

Aggiornamento (2020-2026): Modifica alla legge sulla mediazione (DV n. 11/2023, in vigore 1° luglio 2024): riunione informativa obbligatoria sulla mediazione in varie liti (divorzi, divisioni, cause fino a 25.000 lev, lavoro e commerciali). Ulteriori modifiche DV n. 55/2025. (in vigore/adozione: 2023-02-02). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Cipro

Il quadro cipriota è retto dalla Legge 159(I)/2012 sulla mediazione in materia civile, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione volontaria nelle controversie civili e commerciali, incluse quelle transfrontaliere, integrata da regolamenti attuativi aggiornati nel 2024 in tema di registro dei mediatori, formazione e standard professionali. In materia familiare vige la specifica Legge 62(I)/2019, entrata in vigore il 30 dicembre 2019, che struttura un percorso dedicato alle liti familiari. La mediazione ha natura riservata, con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese, e si conclude con un accordo che le parti possono rendere esecutivo mediante omologazione o deposito secondo le forme previste. I mediatori sono iscritti in appositi registri tenuti presso il Ministero della Giustizia, con requisiti di qualificazione e formazione continua. È in discussione un disegno di legge del 2025 volto a introdurre l'obbligatorietà della mediazione per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro, dato tuttavia da verificare quanto a contenuti e decorrenza; allo stato attuale l'esperimento resta volontario e non costituisce condizione di procedibilità. Cipro, quale Stato membro UE, opera nel quadro delle iniziative eurounitarie di promozione degli ADR.

Aggiornamento (2020-2026): Norme di procedura civile 2023 (mediazione nei protocolli pre-processuali) e disegno di legge di modifica della L. 159(I)/2012 (approvato dal Consiglio dei

Ministri il 3 gennaio 2025): mediazione obbligatoria per liti civili fino a 10.000 €, registro unico e sanzioni; in esame parlamentare. (in vigore/adozione: 2023-09-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Croazia

La Croazia ha riformato la materia con lo Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23), entrato in vigore nel 2023, che ha abrogato e sostituito il previgente Zakon o mirenju del 2011, ampliando e modernizzando la disciplina della mediazione nelle controversie civili, commerciali, di lavoro e di altra natura su diritti disponibili, in coerenza con la direttiva 2008/52/CE. La nuova legge conferma la natura volontaria della mediazione, regolandone l'avvio, la nomina del mediatore, lo svolgimento e la conclusione, e ne rafforza la riservatezza con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni. Sono disciplinati i requisiti, la formazione e il registro dei mediatori tenuto dal Ministero competente, nonché gli organismi e istituzioni di mediazione. L'accordo transattivo raggiunto in mediazione può assumere efficacia di titolo esecutivo se redatto nelle forme previste, mediante clausola di esecutività o atto notarile equivalente. Distinto resta il regime della mediazione familiare (obiteljsko mirenje), disciplinato dall'Obiteljski zakon, che prevede la consulenza obbligatoria prima dei procedimenti relativi ai figli. La mediazione civile non integra condizione generale di procedibilità. La Croazia opera nel quadro degli ADR eurounitari.

Aggiornamento (2020–2026): Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23, in vigore 29 giugno 2023): abroga la legge sulla mediazione 2011; 'medijacija' sostituisce 'mirenje'; obbligo di tentare la risoluzione pacifica prima del giudizio; nuovo Centro (Zagabria). Pravilnik NN 53/2024. (in vigore/adozione: 2023-06-16). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Danimarca

In Danimarca la mediazione è disciplinata quale istituto giudiziale (retsmægling) dal Capitolo 27 della Retsplejeloven, la legge sull'amministrazione della giustizia, nell'assetto introdotto nel 2008. Il giudice, nell'ambito di una causa civile pendente, può proporre alle parti il ricorso alla mediazione, che presuppone il consenso di entrambe: il mediatore, che può essere un giudice o un avvocato designato dal tribunale, assiste le parti nella ricerca di una soluzione senza imporre alcuna decisione, con procedimento riservato e informale, sospeso rispetto al processo. Le dichiarazioni rese in mediazione sono coperte da riservatezza e non utilizzabili nel prosieguo del giudizio. In caso di intesa, l'accordo può essere trasfuso in una transazione (forlig) verbalizzata dinanzi al giudice, così da acquisire efficacia esecutiva; in mancanza, la causa prosegue nelle forme ordinarie. La mediazione danese ha natura volontaria e non costituisce condizione di procedibilità. Accanto al modello giudiziale opera la mediazione privata su base contrattuale. In quanto Stato membro UE, la Danimarca beneficia parzialmente del quadro eurounitario sugli ADR, pur con le peculiarità derivanti dalla sua posizione riguardo alla cooperazione giudiziaria civile.

Aggiornamento (2020–2026): Modifica alla retsplejeloven (nuovo § 355 a, in vigore 15 giugno 2024): promuove la mediazione giudiziale (retsmægling); udienza preparatoria per valutare il

rinvio in mediazione; dal 2023 sul portale telematico la mediazione è impostazione predefinita. (in vigore/adozione: 2024-06-15). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Estonia

L'Estonia è retta dal Lepitusseadus (Conciliation Act) del 2009, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione nelle controversie civili in modo generale. La legge definisce la figura del conciliatore-mediatore, i principi di volontarietà, indipendenza, imparzialità e riservatezza, e ammette sia mediatori privati sia soggetti qualificati quali avvocati e notai; il procedimento è flessibile e non impone requisiti formali rigidi di accreditamento generalizzato. Le informazioni acquisite in mediazione sono coperte da riservatezza e sottratte all'utilizzo processuale, salvo consenso o eccezioni di legge. L'accordo raggiunto può essere reso esecutivo mediante dichiarazione di esecutività resa dal tribunale o mediante autenticazione notarile, acquisendo così valore di titolo esecutivo. Profilo qualificante dell'ordinamento estone è la mediazione familiare (perelepitus), obbligatoria prima dell'avvio del procedimento giudiziario nelle controversie relative all'affidamento e al diritto di visita del minore, con servizio pubblico dedicato e finanziato dallo Stato, così configurando un'obbligatorietà settoriale nell'interesse del minore. La mediazione civile generale resta invece volontaria e non costituisce condizione di procedibilità. L'Estonia opera nel quadro degli ADR eurounitari.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Finlandia

La Finlandia è disciplinata dall'Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General Courts n. 394/2011, che regola sia la mediazione giudiziale presso i tribunali ordinari (tuomioistuinsovittelu) sia la conferma degli accordi. La mediazione giudiziale, condotta da un giudice del tribunale competente eventualmente coadiuvato da un esperto, ha carattere volontario e presuppone il consenso delle parti; il procedimento è riservato, informale e distinto dal giudizio ordinario. Le informazioni emerse in mediazione sono protette da riservatezza e sottratte all'uso processuale. L'accordo raggiunto può essere confermato dal tribunale, acquisendo così efficacia di titolo esecutivo direttamente azionabile; la legge disciplina inoltre la conferma di accordi conclusi in mediazioni stragiudiziali, in attuazione della direttiva 2008/52/CE. La mediazione civile finlandese non costituisce condizione di procedibilità, restando affidata all'iniziativa delle parti. Un distinto regime governa la mediazione penale reo-vittima, disciplinata da apposita legge e gestita dai servizi sociali secondo logiche di giustizia riparativa. La Finlandia, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario di promozione degli ADR e degli sviluppi connessi alla Convenzione di Singapore.

Aggiornamento (2020–2026): Riforma del sistema di conciliazione delle controversie di lavoro (approvata 19 dic. 2024, in vigore 1° gennaio 2025): incide su attività del Conciliatore nazionale, conciliatori e commissioni. (in vigore/adozione: 2024-12-19). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Francia

La Francia presenta un impianto stratificato e di recente riformato. La cornice risale alla Loi n. 95-125 del 1995 e alle disposizioni del Code de procédure civile, integrate dal Décret n. 2012-66 di attuazione della direttiva 2008/52/CE e dal Décret n. 2023-686, che ha introdotto l'audience de règlement amiable (ARA) e la césure du procès civil, in vigore dal 1° novembre 2023, rafforzando i modi amichevoli di risoluzione delle controversie. Un ulteriore intervento di riforma dei modi amichevoli (MARD) è intervenuto nel 2025. L'ordinamento francese conosce profili di obbligatorietà settoriale: per numerose controversie di modesto valore o di vicinato è imposto, a pena di irricevibilità, il previo tentativo di conciliazione, mediazione o procedura partecipativa. La mediazione può essere giudiziale, disposta dal giudice, o convenzionale; è riservata e coordinata con la sospensione della prescrizione. L'accordo può essere omologato dal giudice, acquisendo forza esecutiva, ovvero reso esecutivo mediante contreseing d'avocat e apposizione della formula. La Francia partecipa attivamente al quadro eurounitario e agli sviluppi della Convenzione di Singapore.

Aggiornamento (2020-2026): Décret 2023-357 (art. 750-1 c.p.c.: tentativo obbligatorio di risoluzione amichevole per liti fino a 5.000 €, dal 1° ott. 2023); Loi 2023-576 (mediazione consumo); Décret 2024-103 (mediazione familiare obbligatoria dal 1° gennaio 2025); Décret 2025-660 (ricodifica dei metodi amichevoli, dal 1° set. 2025). (in vigore/adozione: 2023-05-11). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Germania

La Germania è disciplinata dal Mediationsgesetz del 26 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e regola la mediazione stragiudiziale, quella giudiziale e la figura del Güterichter, il giudice conciliatore cui la causa può essere assegnata per un tentativo di composizione amichevole distinto dal giudice della decisione. La legge definisce la mediazione come procedimento riservato e volontario condotto da un mediatore indipendente e imparziale, privo di potere decisorio, e sancisce obblighi di informazione e trasparenza. Non è prevista, in via generale, l'obbligatorietà del previo esperimento, restando la mediazione affidata all'iniziativa delle parti, benché in materie di modesto valore i Länder possano richiedere un previo tentativo di conciliazione (obligatorische Streitschlichtung). Elemento centrale è la disciplina del Mediator certificato (zertifizierter Mediator): la novella del regolamento sulla formazione (ZMediatAusbV), aggiornata con effetto dal 1° marzo 2024, ha rafforzato i requisiti formativi e di aggiornamento continuo. La riservatezza è tutelata da un diritto di rifiutare la testimonianza. L'accordo può essere reso esecutivo mediante atto notarile, transazione forense o omologazione, acquisendo titolo esecutivo. La Germania opera nel quadro eurounitario degli ADR.

Aggiornamento (2020-2026): Seconda ordinanza di modifica della ZMediatAusbV (in vigore 1° marzo 2024): per il 'mediatore certificato' le ore di formazione salgono da 120 a 130, con competenze digitali e mediazione online; fino al 40% delle ore in forma virtuale. (in vigore/adozione: 2024-03-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Grecia

Il quadro è definito dalla Legge 4640/2019 sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, che ha dato attuazione evoluta alla direttiva 2008/52/CE introducendo la sessione informativa iniziale obbligatoria per una serie di materie, tra cui numerose controversie familiari e determinate liti civili e commerciali di valore rilevante. La partecipazione all'incontro iniziale, assistita da avvocato, costituisce condizione di procedibilità per le materie individuate, mentre la prosecuzione della mediazione resta volontaria; il mancato esperimento è sanzionabile sul piano processuale. La legge disciplina l'accreditamento dei mediatori presso il Ministero della Giustizia, la formazione e gli organismi, presidia rigorosamente la riservatezza e l'inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese, e attribuisce all'accordo, previo deposito presso la cancelleria del tribunale competente, efficacia di titolo esecutivo. Il sistema è stato oggetto di aggiornamento: la riforma del codice di procedura civile intervenuta con legge del 2025 (l. 5221/2025, con disposizioni connesse) incide sulla collocazione processuale dell'istituto, con decorrenza delle nuove regole dal 1° gennaio 2026. La Grecia, quale Stato membro UE, si colloca inoltre nel solco degli strumenti internazionali sulla mediazione commerciale.

Aggiornamento (2020–2026): Legge 5108/2024: modifica l'art. 3 (ambito) della Legge 4640/2019 sulla mediazione civile e commerciale. (in vigore/adozione: 2024). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Irlanda

Il diritto vigente è il Mediation Act 2017 (No. 27 of 2017), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, che detta un quadro organico applicabile in via generale a tutte le controversie civili, con talune esclusioni espresse (tra cui determinate materie di diritto di famiglia, lavoro e taluni procedimenti specifici). La legge impone ai solicitor un obbligo di informazione preventiva al cliente circa l'opzione della mediazione, con dichiarazione statutaria da allegare agli atti introduttivi, e attribuisce al giudice il potere di invitare le parti a valutare il ricorso alla mediazione, potendo il rifiuto ingiustificato riflettersi sul regime delle spese. L'istituto conserva natura volontaria, non configurandosi come condizione di procedibilità in senso proprio. Il Mediation Act presidia i principi di autodeterminazione delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore, codici di condotta e riservatezza, con inutilizzabilità nel giudizio delle comunicazioni di mediazione, e disciplina l'effetto sospensivo sui termini di prescrizione durante il procedimento. L'accordo raggiunto ha natura contrattuale e vincola le parti secondo la loro volontà, potendo assumere efficacia esecutiva ove recepito in un provvedimento giudiziale. L'Irlanda, quale Stato membro UE, si colloca nel contesto degli strumenti europei e internazionali sulla mediazione.

Aggiornamento (2020–2026): Modifiche alle Rules of the Superior Courts (dal 1° ott. 2024): i giudici valutano l'ordine di ricorrere alla mediazione; Practice Direction HC131 (apr. 2025) per le cause di negligenza clinica. Il Mediation Act 2017 resta in vigore. (in vigore/adozione: 2024-10-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Italia

Il diritto vigente è il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, profondamente rimodellato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, con disposizioni sulla mediazione in vigore dal 30 giugno 2023), dai decreti ministeriali n. 150/2023 (regolamento su organismi, registro e formatori) e n. 151/2023, e dal correttivo D.Lgs. 216/2024. La mediazione è condizione di procedibilità in un ampio catalogo di materie (tra cui condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a consorzi, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). L'obbligo si assolve con la partecipazione, assistiti da avvocato, al primo incontro; la riforma ha introdotto la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), rafforzato incentivi fiscali e patrocinio, e disciplinato la partecipazione personale delle parti e la mediazione telematica. La procedura ha durata contenuta (di norma tre mesi, prorogabili). Vigé un rigoroso regime di riservatezza e inutilizzabilità probatoria; l'accordo sottoscritto dagli avvocati costituisce titolo esecutivo, altrimenti previa omologazione. L'Italia si colloca nel quadro della direttiva 2008/52/CE; l'operatività della Convenzione di Singapore per gli accordi commerciali internazionali segue le determinazioni dell'Unione.

Aggiornamento (2020-2026): Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, parte mediazione dal 30 giugno 2023); D.M. 150/2023; Correttivo D.Lgs. 216/2024 (dal 25 gennaio 2025): ambito della mediazione obbligatoria ampliato, primo incontro effettivo, incentivi fiscali, mediazione telematica (art. 8-bis) e da remoto (art. 8-ter). (in vigore/adozione: 2025-01-25). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Lettonia

Il diritto vigente è la Mediation Law (Mediācijas likums), adottata nel 2014 ed entrata in vigore il 18 giugno 2014, che detta la disciplina organica della mediazione in materia civile in attuazione degli standard europei derivanti dalla direttiva 2008/52/CE. La legge fonda l'istituto sui principi di volontarietà, parità e autodeterminazione delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore, non configurando in via generale la mediazione come condizione di procedibilità, pur consentendo al giudice di invitare le parti a valutarne il ricorso. Essa disciplina i requisiti dei mediatori, in particolare dei mediatori certificati iscritti negli appositi elenchi, la loro formazione e la certificazione, e presidia la riservatezza del procedimento con inutilizzabilità nel giudizio delle informazioni acquisite; l'avvio della mediazione incide sui termini di prescrizione. Dal 1° gennaio 2017 opera il programma statale di mediazione familiare gratuita, che finanzia un numero definito di sessioni per favorire la composizione delle controversie di famiglia. L'accordo raggiunto ha efficacia vincolante e, ove recepito in sede giudiziale, valore esecutivo. La Lettonia, quale Stato membro UE, si colloca nel quadro degli strumenti europei e internazionali sulla mediazione, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Lituania

La Lituania è retta dalla Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili n. X-1702 del 2008, profondamente riformata nel 2017 con effetto dal 2019, in attuazione della direttiva 2008/52/CE. Tratto qualificante è l'obbligatorietà settoriale: dal 1° gennaio 2020 la mediazione è obbligatoria nelle controversie familiari, sicché la parte deve esperirla prima di adire il giudice, con conseguenze processuali in caso di rifiuto ingiustificato. Per le restanti materie civili e commerciali la mediazione resta volontaria e può essere giudiziale o stragiudiziale. La riforma ha istituito e rafforzato il registro dei mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia, con requisiti di qualificazione, esame e formazione continua, e ha strutturato la mediazione giudiziale gratuita presso i tribunali. Il procedimento è riservato, con inutilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese, e incide sulla sospensione dei termini di prescrizione. L'accordo raggiunto vincola le parti e, previa approvazione giudiziale nelle forme di procedimento semplificato previste dalla legge, acquista efficacia esecutiva. La Lituania, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario di promozione degli ADR e degli sviluppi connessi alla Convenzione di Singapore, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

Aggiornamento (2020–2026): Riforma della legge sulla mediazione (Seimas 13 giugno 2024; in vigore 1° set. 2024 e 1° gennaio 2025): istituisce la Camera dei mediatori (autogoverno professionale, adesione automatica); ore di mediazione obbligatoria coperte dal bilancio pubblico da 6 a 8. (in vigore/adozione: 2024-06-13). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Lussemburgo

Il Lussemburgo è disciplinato dalla Loi du 24 février 2012 portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale, che ha inserito nel Nouveau Code de procédure civile gli articoli 1251-1 e seguenti, recependo la direttiva 2008/52/CE. La legge distingue la mediazione convenzionale, avviata dalle parti, la mediazione giudiziale, disposta dal giudice con il loro accordo, e la mediazione familiare, quest'ultima integrata da un regolamento granducale dedicato. La materia coperta comprende le controversie civili e commerciali su diritti disponibili. Il procedimento è volontario, riservato e imparziale, e non costituisce, in via generale, condizione di procedibilità. La normativa disciplina l'agrément (accreditamento) dei mediatori giudiziali e familiari da parte del Ministro della Giustizia, con requisiti di onorabilità, qualificazione e formazione specifica, e presidia la riservatezza con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in mediazione. L'accordo raggiunto può essere omologato dal giudice competente, che gli conferisce forza esecutiva, ovvero, per le mediazioni transfrontaliere, secondo il regime di riconoscimento previsto. Il Lussemburgo, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario degli ADR e degli sviluppi internazionali connessi alla Convenzione di Singapore, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Malta

Malta è disciplinata dal Mediation Act, Chapter 474 delle Laws of Malta (Act XVI of 2004), in vigore dal 21 dicembre 2004, che ha istituito il Malta Mediation Centre, operativo dal 2005 quale organismo pubblico incaricato di promuovere e amministrare la mediazione. La legge regola la mediazione in materia civile, commerciale, familiare e industriale quale procedimento volontario: le parti possono ricorrervi spontaneamente o essere invitate dal giudice o da altra autorità, senza che essa costituisca, in via generale, condizione di procedibilità, fermi restando specifici percorsi in ambito familiare. Il procedimento è riservato: la legge garantisce la confidenzialità delle comunicazioni svolte in mediazione, che non possono essere fatte valere nei successivi giudizi salvo eccezioni. La disciplina definisce i requisiti dei mediatori, l'iscrizione negli elenchi tenuti presso il Centre e i principi deontologici, in coerenza con la direttiva 2008/52/CE, recepita nell'ordinamento maltese. L'accordo raggiunto vincola le parti e può acquisire efficacia esecutiva mediante le forme previste dall'ordinamento, anche in caso di recepimento giudiziale. Malta, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario degli ADR; l'applicazione della Convenzione di Singapore segue le determinazioni dell'Unione.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Paesi Bassi

I Paesi Bassi non dispongono, allo stato, di una legge organica sulla mediazione: l'istituto opera quale procedimento volontario e non codificato, radicato nella prassi e sostenuto da organismi privati di autoregolamentazione, in particolare dal registro dei mediatori tenuto dalla Mediatorsfederatie Nederland (MfN), che fissa standard di qualità, formazione e deontologia su base non statale. La mediazione, giudiziale o stragiudiziale, è promossa dalle corti nell'ambito del rinvio delle cause civili e familiari, senza costituire, in via generale, condizione di procedibilità. Il procedimento è riservato per accordo delle parti e i relativi scambi sono di regola sottratti all'uso processuale. È in avanzato iter parlamentare un pacchetto normativo (Wet bevordering mediation), destinato a introdurre un registro pubblico dei mediatori, un titolo protetto e una vigilanza disciplinare: nel febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta un provvedimento connesso relativo al comitato consultivo del registro centrale, ma lo stato di adozione della disciplina organica va verificato quanto a contenuti e decorrenza. L'accordo raggiunto ha natura contrattuale e può acquisire efficacia esecutiva mediante atto notarile od omologazione. I Paesi Bassi, quale Stato membro UE, operano nel quadro eurounitario degli ADR.

Aggiornamento (2020–2026): Pacchetto di tre proposte di legge (Wet registermediator e leggi di promozione della mediazione in diritto civile e amministrativo; consultazione 2023-2024, in iter): istituzione di un registro pubblico statale dei mediatori con titolo protetto di 'beëdigd mediator'. Non ancora legge in vigore. (in vigore/adozione: 2024). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Polonia

La mediazione civile e commerciale è disciplinata organicamente dagli artt. 183(1)-183(15) del Codice di procedura civile (kpc), introdotti nel 2005 e potenziati dalla legge di promozione

dell'ADR del 2015. Il quadro attuale recepisce le modifiche della legge del 9 marzo 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, che ha inciso sulla disciplina procedurale e sul raccordo tra mediazione e processo. La mediazione resta di regola volontaria e può essere avviata su base contrattuale, su iniziativa delle parti o per rinvio del giudice, il quale può indirizzare le parti in ogni stato e grado, senza imporre l'obbligo di raggiungere l'accordo. Il mediatore può essere scelto liberamente o tratto dagli elenchi tenuti presso le corti d'appello e dalle organizzazioni professionali abilitate. L'accordo raggiunto, una volta approvato od omologato dal giudice, acquista efficacia esecutiva assimilabile a quella della transazione giudiziale. Vigé un regime di riservatezza che preclude l'uso processuale delle dichiarazioni rese in mediazione. È in discussione, secondo i lavori di novella del kpc, un'ulteriore espansione degli ambiti a mediazione obbligatoria, la cui effettiva decorrenza resta da verificare.

Aggiornamento (2020–2026): Legge 5 agosto 2025 (norme sulla mediazione dal 10 settembre 2025): consenso presunto alla mediazione, mediazione obbligatoria nelle cause commerciali (nuovo art. 458^{3a} c.p.c.) e in materia edilizia, incentivi (rimborso spese) e omologazione di accordi online. Riforma anteriore dal 1° luglio 2023. (in vigore/adozione: 2025-08-05). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Portogallo

L'ordinamento portoghese dispone di una legge organica, la Lei n.º 29/2013 del 19 aprile (Lei da Mediação), tuttora vigente, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE estendendone i principi anche alla mediazione interna. Il testo fissa i principi generali della procedura (volontarietà, riservatezza, imparzialità, indipendenza, competenza ed esecutorietà), disciplina la mediazione civile e commerciale e definisce lo statuto giuridico del mediatore. La mediazione è di regola volontaria: le parti vi accedono per accordo o su suggerimento del giudice, senza che ne derivi una condizione di procedibilità generale. Accanto alla mediazione privata operano i sistemi pubblici di mediazione (familiare, penale, del lavoro e presso i julgados de paz), organizzati dal Ministério da Justiça. La legge riconosce all'accordo di mediazione condotto secondo i requisiti previsti forza esecutiva diretta, senza necessità di omologazione quando ricorrano le condizioni di legge, tra cui la conduzione da parte di mediatore iscritto nelle liste ministeriali. È previsto un regime di formazione e iscrizione dei mediatori in appositi elenchi. Quale Stato membro UE, il Portogallo è vincolato all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR.

Aggiornamento (2020–2026): Decreto-Lei n.º 26/2024 (3 aprile 2024): crea la Piattaforma RAL+ per la gestione dei procedimenti presso giudici di pace e centri di arbitrato di consumo; digitalizza le procedure ADR. Impianto sostanziale invariato (Lei 29/2013). (in vigore/adozione: 2024-04-03). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca dispone di una legge organica, la Legge n. 202/2012 Coll. sulla mediazione (Zákon o mediaci), che disciplina la mediazione registrata condotta da mediatori iscritti, i requisiti di accesso alla professione (esame dinanzi al Ministero della Giustizia, con abilitazione specifica per i mediatori-avvocati presso l'ordine forense) e gli effetti dell'avvio della procedura, tra cui la sospensione della prescrizione. La mediazione è di regola volontaria, ma il codice di

procedura civile (OSŘ), al § 100, comma 2, consente al giudice di ordinare alle parti un primo incontro con un mediatore registrato per una durata massima di tre ore, sospendendo il procedimento; le parti non sono però obbligate a proseguire. Vigé un rigoroso regime di riservatezza a tutela delle informazioni acquisite dal mediatore. L'accordo di mediazione ha natura contrattuale e acquista efficacia esecutiva mediante approvazione giudiziale o redazione in forma di atto notarile con clausola esecutiva. Il quadro è in evoluzione: la legge n. 268/2025 Coll., quale modifica del codice di procedura, incide sul raccordo tra mediazione e processo, ma la portata e la decorrenza esatta delle nuove disposizioni restano da verificare. Quale Stato membro UE, la Repubblica Ceca è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR.

Fonti: [Gazzetta ufficiale fonte sulla mediazione](#)

Romania

La Romania dispone di una legge organica, la Legge n.192/2006 sulla mediazione e sull'organizzazione della professione di mediatore, più volte modificata, che disciplina la procedura, lo statuto del mediatore e il Consiglio di mediazione (Consiliul de mediere), organismo pubblico incaricato della formazione, dell'autorizzazione e della tenuta del registro dei mediatori. La mediazione è oggi di regola volontaria: il legislatore aveva introdotto una sessione informativa preliminare obbligatoria come condizione di ricevibilità della domanda giudiziale, ma la Corte costituzionale, con la decisione n.266/2014, ne ha dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con il libero accesso alla giustizia, ripristinando la piena facoltatività dell'accesso alla procedura. Permane la facoltà del giudice di invitare le parti a valutare la mediazione e di informarle sui suoi vantaggi. Vigé un regime di riservatezza che tutela le dichiarazioni rese in sede di mediazione, di norma non utilizzabili nel successivo processo. L'accordo raggiunto può essere trasfuso in una transazione e reso esecutivo mediante omologazione giudiziale o autenticazione notarile, con eventuali benefici in materia di restituzione del contributo giudiziale. Quale Stato membro UE, la Romania è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei; ulteriori modifiche restano da verificare.

Fonti: [Gazzetta ufficiale fonte sulla mediazione](#)

Slovacchia

La Slovacchia dispone di una legge organica, la Legge n. 420/2004 Coll. sulla mediazione (Zákon o mediácii), modificata nel 2010 e nel 2015 (segnatamente dalla legge n. 390/2015, nel testo consolidato vigente), applicabile alle controversie nascenti da rapporti civili, familiari, commerciali e di lavoro, comprese quelle transfrontaliere, in recepimento della direttiva 2008/52/CE. La procedura è di regola volontaria, avviata mediante accordo scritto tra le parti, e non costituisce condizione generale di procedibilità; l'avvio della mediazione produce effetti sospensivi sui termini di prescrizione e decadenza. La legge disciplina i requisiti di accesso alla professione di mediatore (formazione specialistica ed esame, iscrizione nel registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia) e l'attività dei centri di mediazione. Vigé un regime di riservatezza che vincola il mediatore. L'accordo di mediazione redatto in forma scritta acquista efficacia esecutiva se trasfuso in un atto notarile munito di clausola esecutiva o se approvato quale transazione giudiziale dinanzi al tribunale o all'arbitro. Quale Stato membro UE, la Slovacchia è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei in materia di ADR; ulteriori modifiche al testo consolidato restano da verificare.

Aggiornamento (2020–2026): Modifica della legge sulla mediazione n. 420/2004 (in vigore 1° luglio 2024): recepisce l'ADR di consumo; per le liti di consumo il compenso non dipende dall'esito, quota massima a carico del consumatore 10% (max 20 €), conclusione entro 90 giorni. (in vigore/adozione: 2024-07-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Slovenia

La Slovenia dispone di un articolato quadro normativo fondato su due leggi principali. Lo Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ, UL RS 56/2008) disciplina la mediazione nelle controversie civili, commerciali, del lavoro, familiari e in altri rapporti patrimoniali, recependo i principi della direttiva 2008/52/CE, tra cui volontarietà, riservatezza, effetti sulla prescrizione ed esecutività dell'accordo. A questo si affianca lo Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS, UL RS 97/2009), sull'ADR annesso al giudizio, che obbliga i tribunali a predisporre e offrire alle parti programmi di risoluzione alternativa, in particolare la mediazione, nell'ambito delle controversie pendenti, configurando un onere organizzativo a carico delle corti e un forte incentivo al ricorso alla procedura, senza tuttavia imporre alle parti l'obbligo di raggiungere l'accordo. La mediazione resta dunque di regola volontaria quanto all'adesione delle parti. L'accordo di mediazione può acquisire efficacia esecutiva mediante trasfusione in una transazione giudiziale, in un atto notarile esecutivo o in un lodo arbitrale su accordo. Vigge un rigoroso regime di riservatezza. Quale Stato membro UE, la Slovenia è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR; eventuali novelle recenti restano da verificare.

Aggiornamento (2020–2026): Regolamento sulla mediazione nelle controversie su diritto d'autore e diritti connessi (Uradni list RS 64/23, 16 giugno 2023): procedura, requisiti e compenso del mediatore; elenco dei mediatori adottato nel 2024. (in vigore/adozione: 2023-06-16). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Spagna

La Spagna dispone della Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE estendendone i principi alla mediazione interna e disciplinando procedura, statuto del mediatore, riservatezza ed esecutività dell'accordo (mediante elevazione a scrittura pública o omologazione giudiziale). La svolta più recente è la Ley Orgánica 1/2025 del 2 gennaio, sulle misure di efficienza del servizio pubblico di giustizia, che rende il ricorso ai MASC (medios adecuados de solución de controversias) un requisito di procedibilità: per un'ampia gamma di controversie civili e commerciali è ora necessario, prima di adire il giudice, aver tentato un mezzo adeguato di composizione (tra cui la mediazione, la conciliazione, l'offerta vincolante confidenziale o l'attività negoziale tramite avvocati), a pena di inammissibilità della domanda. Il requisito è divenuto operativo il 3 aprile 2025. Il rifiuto ingiustificato di partecipare, o la condotta abusiva, rilevano ai fini della ripartizione delle spese. Vigge un rigoroso regime di riservatezza a tutela delle informazioni scambiate. L'accordo raggiunto conserva l'esecutività secondo la Ley 5/2012. Quale Stato membro UE, la Spagna è

vincolata all'evoluzione degli strumenti europei; l'attuazione applicativa della riforma del 2025 è in corso di consolidamento.

Aggiornamento (2020–2026): Ley Orgánica 1/2025 (BOE 3 gennaio 2025, in vigore 3 aprile 2025): rende obbligatorio, prima della causa civile/commerciale, il tentativo di un MASC (mediazione, conciliazione, perizia, offerta vincolante, negoziazione); la prova del tentativo è requisito di procedibilità (con eccezioni). (in vigore/adozione: 2025-01-02). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Svezia

In Svezia la disciplina è contenuta nella Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister, legge sulla mediazione in determinate controversie di diritto privato, adottata in attuazione della direttiva europea 2008/52/CE e applicabile alle liti civili e commerciali, anche transfrontaliere. La procedura è integralmente volontaria: non è prevista alcuna condizione di procedibilità, e le parti vi accedono per accordo o su invito del giudice. La legge sancisce riservatezza e imparzialità del mediatore, disciplina la sospensione dei termini di prescrizione durante la mediazione e limita la possibilità di escutere il mediatore quale testimone sui contenuti della procedura, in coerenza con il regime europeo. Profilo qualificante è l'esecutività dell'accordo: su richiesta delle parti il giudice può dichiarare esecutivo l'accordo di mediazione, conferendogli efficacia di titolo. Sul versante penale opera parallelamente la Lag (2002:445) om medling med anledning av brott, che regola la mediazione tra autore e vittima del reato, in particolare con riferimento ai minori, con finalità riparative e senza incidere sull'azione penale. L'assetto riflette la tradizione nordica di mediazione a bassa formalizzazione; requisiti di accreditamento dei mediatori e sviluppi 2023-2026 restano affidati alla prassi, da verificare.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Ungheria

In Ungheria la disciplina generale è contenuta nella Legge LV del 2002 sull'attività di mediazione (2002. évi LV. törvény), in vigore dal 17 marzo 2003 e più volte modificata sino al testo consolidato vigente, adottata in linea con gli standard europei e ispirata ai principi di volontarietà, imparzialità e riservatezza. La legge istituisce un registro dei mediatori tenuto dal Ministero, cui accedono i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione e formazione previsti, e disciplina i doveri del mediatore, il regime di riservatezza e l'inutilizzabilità nel successivo processo delle informazioni acquisite in mediazione. Il quadro è stato progressivamente esteso: dal 2013 è stata introdotta la mediazione giudiziale (court mediation) condotta all'interno del sistema giudiziario, e dal 2018 la mediazione in materia amministrativa. Non è configurata in via generale una condizione di procedibilità, restando la mediazione volontaria, sebbene il giudice possa incentivarne o disporne l'impiego in determinati ambiti, in particolare familiare. Quanto agli effetti, l'accordo ha natura negoziale e può acquisire efficacia esecutiva secondo le forme di legge, in particolare mediante omologazione o recepimento in un provvedimento giudiziale. Gli aggiornamenti del testo consolidato e gli sviluppi 2023-2026, anche in relazione alla Convenzione di Singapore, restano da verificare quanto ai dettagli.

Aggiornamento (2020–2026): Legge LXIV del 2024 (in vigore 1° gennaio 2025): amplia e flessibilizza la mediazione penale e la giustizia riparativa; la mediazione può svolgersi in

parallelo al procedimento penale, con nuova opzione riparativa. (in vigore/adozione: 2024).
[fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

Bibliografia essenziale

Opere dell'autore

- C. A. Calcagno, *Arbitrato e negoziato in Europa*, Cendon/Book, 2020.
- C. A. Calcagno, *Il legale e la mediazione*, Aracne, 2014.
- C. A. Calcagno, *Breve storia della risoluzione del conflitto*, Aracne, 2014.
- C. A. Calcagno, *Manuale del geometra mediatore e conciliatore*, UTET, 2011.
- C. A. Calcagno, contributi e dossier su mediareinformati.it e mediaresenzaconfini.org (2011-2026).

Fonti normative italiane

- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia); decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 216 (correttivo).
- D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (indennità e criteri); D.M. 27 ottobre 2023, n. 151 (mediatore familiare).

Fonti europee e internazionali

- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla mediazione civile e commerciale.
 - Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione (Convenzione di Singapore, UNCITRAL, 2019).
 - Consiglio d'Europa, Raccomandazioni R(98)1, R(99)19, Rec(2001)9, Rec(2002)10.
 - CEPEJ, rapporti di valutazione dei sistemi giudiziari europei; Commissione europea, EU Justice Scoreboard 2026.
-

Prontuario ragionato dei termini

ADR. Alternative Dispute Resolution: l'insieme dei metodi di soluzione delle controversie alternativi al processo (mediazione, conciliazione, arbitrato, negoziazione assistita). L'equivalente italiano è MASC.

MASC. Metodi (o Mezzi) Alternativi/Adeguati di Soluzione delle Controversie: locuzione italiana per gli strumenti stragiudiziali, valorizzata dalla riforma Cartabia. Comprende mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.

Mediazione. Attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta (art. 1 d.lgs. 28/2010). Vedi Diritto della mediazione.

Conciliazione. La composizione della lite raggiunta attraverso il procedimento di mediazione: indica l'esito, cioè l'accordo, mentre la mediazione è il procedimento.

Mediatore. La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo priva del potere di rendere decisioni vincolanti per le parti. Iscritto presso un organismo. Vedi Deontologia del mediatore.

Organismo di mediazione. L'ente, pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, presso cui si svolge il procedimento di mediazione.

Condizione di procedibilità. In alcune materie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: senza il tentativo, il giudice non può decidere nel merito (art. 5 d.lgs. 28/2010). Vedi Quando la mediazione è obbligatoria.

Mediazione obbligatoria. La mediazione richiesta come condizione di procedibilità nelle materie elencate dalla legge (ampliate dalla riforma Cartabia). Si distingue dalla mediazione facoltativa e da quella demandata dal giudice.

Mediazione demandata dal giudice. La mediazione disposta dal giudice, anche in appello, valutata la natura della causa e lo stato dell'istruzione (art. 5-quater d.lgs. 28/2010). Vedi La mediazione demandata dal giudice.

Primo incontro. L'incontro di programmazione in cui il mediatore chiarisce funzione e modalità della mediazione e le parti verificano la possibilità di proseguire (art. 8 d.lgs. 28/2010). Vedi Il primo incontro.

Mediazione telematica. Lo svolgimento del procedimento, in tutto o in parte, con collegamento audiovisivo da remoto (art. 8-bis d.lgs. 28/2010). Vedi La mediazione telematica.

Proposta del mediatore. La proposta di conciliazione che il mediatore può formulare alle parti; il suo rifiuto può avere conseguenze sulle spese del successivo giudizio (artt. 11 e 13 d.lgs. 28/2010).

Verbale di mediazione. L'atto che documenta l'esito del procedimento, con esito positivo (accordo) o negativo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore (art. 11 d.lgs. 28/2010).

Esecutività dell'accordo. L'accordo di conciliazione, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; ove necessario, è omologato dal presidente del tribunale (art. 12 d.lgs. 28/2010).

Riservatezza. Il regime di riservatezza e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento (artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010): un pilastro della fiducia nella mediazione.

Indennità di mediazione. Le somme dovute all'organismo per il servizio, determinate secondo i parametri ministeriali (d.m. 150/2023). Vedi Costi e indennità.

Incentivi fiscali. Le agevolazioni collegate alla mediazione, tra cui il credito d'imposta sulle indennità e sui compensi (art. 20 d.lgs. 28/2010) e, dopo la riforma Cartabia, il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

Direttiva 2008/52/CE. La direttiva europea sulla mediazione in materia civile e commerciale, quadro di riferimento per i sistemi nazionali dell'Unione. Vedi La mediazione in Europa e Sistemi nazionali (UE).

Convenzione di Singapore. Convenzione delle Nazioni Unite (UNCITRAL, 2019) sugli accordi commerciali internazionali risultanti dalla mediazione: ne consente il riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera negli Stati aderenti.

Negoziiazione assistita. Procedura ADR in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, cercano un accordo tramite una convenzione (d.l. 132/2014): distinta dalla mediazione, che si svolge presso un organismo con un mediatore terzo.

Arbitrato. Metodo ADR in cui le parti affidano la decisione della controversia a uno o più arbitri, la cui pronuncia (lodo) è vincolante: a differenza della mediazione, l'esito è deciso da un terzo, non concordato dalle parti.

BATNA. Best Alternative To a Negotiated Agreement: la migliore alternativa all'accordo negoziato, cioè ciò che una parte può ottenere se la trattativa fallisce. Misura il potere negoziale reale e segna la soglia sotto la quale non conviene accordarsi.

WATNA. Worst Alternative To a Negotiated Agreement: la peggiore alternativa all'accordo negoziato. Considerare il proprio WATNA, e stimare quello della controparte, aiuta a valutare realisticamente i rischi del mancato accordo.

ZOPA. Zone Of Possible Agreement: la zona di possibile accordo, cioè l'intervallo compreso tra i prezzi di riserva delle parti entro il quale un'intesa è razionalmente conveniente per entrambe. Se i prezzi di riserva non si sovrappongono la ZOPA è negativa e l'accordo, a quei termini, non esiste.

Ancoraggio. Anchoring: l'effetto per cui la prima cifra proposta condiziona l'intera trattativa, fungendo da punto di riferimento. Studiata da Tversky e Kahneman, è tecnica e insieme trappola cognitiva (anchor bias) di cui l'avvocato negoziatore deve essere consapevole.

Framing e reframing. Il modo in cui una questione è formulata (framing) e la sua riformulazione (reframing): trasformare una posizione rigida in un interesse, o un'accusa in una domanda, è uno strumento centrale del mediatore e dell'avvocato per sbloccare l'impasse.

Caucus. La sessione separata in cui il mediatore incontra una sola parte, in via riservata, per esplorare interessi, opzioni e margini che difficilmente emergerebbero al tavolo comune. Strumento tattico tipico della mediazione facilitativa.

Giudice-mediatore. Il magistrato che conduce in prima persona il tentativo di conciliazione, figura presente in un numero rilevante di ordinamenti. Si distingue dalla mediazione delegata, in cui il giudice rinvia le parti a un mediatore terzo.